

PRÁTICA JURÍDICA

12ª Edição

Constitucional

Erival da Silva Oliveira

Indicado para a 2ª Fase do Exame da OAB com:

- Abordagem teórica dos principais temas
- Modelos de peças práticas
- Peças e questões do Exame da OAB com gabarito

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva.

A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

ISBN 9788553615889

Oliveira, Erival da Silva

Constitucional / Erilval da Silva Oliveira. - Prática Jurídica - 12. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.

632 p.

Bibliografia

1. Direito constitucional. I. Título.

20-0040

CDD 340

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Direito constitucional 342(81)

Direção executiva *Flávia Alves Bravin*

Direção editorial *Renata Pascual Müller*

Gerência editorial *Roberto Navarro*

Gerência de produção e planejamento *Ana Paula Santos Matos*

Gerência de projetos e serviços editoriais *Fernando Penteado*

Consultoria acadêmica *Murilo Angeli Dias dos Santos*

Planejamento *Clarissa Boraschi Maria (coord.)*

Novos projetos *Melissa Rodriguez Arnal da Silva Leite*

Edição *Liana Ganiko Brito Catenacci*

Produção editorial *Verônica Pivisan Reis*

Arte e digital *Mônica Landi (coord.) | Amanda Mota Loyola | Camilla Felix Cianelli Chaves | Claudirene de Moura Santos Silva | Deborah Mattos | Fernanda Matajs | Guilherme H. M. Salvador | Tiago Dela Rosa | Verônica Pivisan Reis*

Planejamento e processos *Clarissa Boraschi Maria (coord.) | Juliana Bojczuk Fermino | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Fernando Penteado | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Projetos e serviços editoriais *Juliana Bojczuk Fermino | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Diagramação (Livro Físico) *Desígnios Editoriais*

Revisão *Desígnios Editoriais*

Capa *Aero Comunicação*

Livro digital (E-pub)

Produção do e-pub *Guilherme Henrique Martins Salvador*

Data de fechamento da edição: 1º-10-2019

Dúvidas?

Acesse sac.sets@somoseducacao.com.br

Nota do Autor

PRIMEIRA PARTE - Teórica

1. Poder Constituinte

1.1. Poder Constituinte Originário, de 1.º grau, primário ou genuíno

1.2. Poder Constituinte Derivado de reforma, de emendabilidade, de 2.º grau, secundário de mudança ou reformador

1.2.1. Espécies de limitações ao Poder Constituinte Derivado

1.3. Poder Constituinte Derivado Decorrente ou Secundário Federativo

2. Repartição das competências constitucionais

2.1. Competência não legislativa (administrativa/material)

2.2. Competência legislativa

3. Classificação doutrinária da Constituição de 1988

3.1. Quanto à forma

3.2. Quanto à elaboração

3.3. Quanto à origem

3.4. Quanto à estabilidade, alterabilidade, consistência ou mutabilidade

3.5. Quanto à extensão

3.6. Quanto à sistematização ou estrutura

3.7. Quanto à religião

4. Fenômenos ou teorias que surgem com uma nova Constituição

4.1. Recepção

- 4.2. Repristinação
- 4.3. Desconstitucionalização
- 5. Aplicabilidade das normas constitucionais
 - 5.1. Normas constitucionais de eficácia plena
 - 5.2. Normas constitucionais de eficácia contida
 - 5.3. Normas constitucionais de eficácia limitada
- 6. Controle de constitucionalidade
 - 6.1. Conceito e origem
 - 6.2. Inconstitucionalidade
 - 6.2.1. Inconstitucionalidade por ação
 - 6.2.2. Inconstitucionalidade por omissão
 - 6.3. Classificação do controle de constitucionalidade
 - 6.3.1. Quanto ao momento em que é exercido
 - 6.3.1.1. Preventivo, a priori ou priorístico
 - 6.3.1.2. Repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo
 - 6.3.2. Quanto ao número de órgãos encarregados do controle
 - 6.3.2.1. Concentrado, reservado, objetivo, fechado, abstrato ou austríaco
 - 6.3.2.2. Difuso, aberto, indireto, subjetivo, ou norte-americano
 - 6.3.3. Quanto aos efeitos da decisão
 - 6.3.3.1. Inter partes
 - 6.3.3.2. Erga omnes
 - 6.4. As ações do controle concentrado de constitucionalidade (Adin, Adecon e ADPF)
 - 6.4.1. Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica (ADIn/ADIn Genérica)
 - 6.4.2. Representação Interventiva (ou Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva – ADIn/ADIn Interventiva)

6.4.2.1. ADIn Interventiva Federal

6.4.2.2. ADIn Interventiva Estadual

6.4.3. Ação Direta de Inconstitucionalidade Supridora da Omissão ou por Omissão (ADIn/ADIn-SO, ADIn/ADIn-PO ou ADO)

6.4.4. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADECON/ADECO/ADC)

6.4.5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

6.4.6. Decisões no controle concentrado de constitucionalidade

6.4.7. Quadro comparativo das ações do controle concentrado

6.5. Atribuição do Advogado-Geral da União, do Procurador-Geral da República e do amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade

6.6. Bloco de constitucionalidade

7. Federalismo

7.1. Forma do estado

7.1.1. Estado unitário

7.1.2. Estado federal

7.2. Federalismo no Brasil

7.3. Componentes do Estado Federal Brasileiro

7.3.1. União

7.3.2. Estados federados

7.3.3. Municípios

7.3.4. Distrito Federal

7.3.5. Territórios federais

7.4. Vedações constitucionais existentes no federalismo do Brasil

7.5. Princípios Constitucionais Vinculados ao Federalismo

7.5.1. Princípios estabelecidos

7.5.2. Princípios sensíveis

7.5.3. Princípios extensíveis

8. Intervenção federal

8.1. Procedimento detalhado

8.1.1. Iniciativa

8.1.2. Fase judicial

8.1.3. Decreto interventivo

8.1.4. Controle político

8.1.5. Controle jurisdicional

9. Estado de defesa

9.1. Controle do estado de defesa

9.1.1. Controle político

9.1.2. Controle jurisdicional

Estado de Defesa (arts. 136, 140 e 141 da CF/88)

10. Estado de sítio

10.1. Controle do Estado de Sítio

10.1.1. Controle político

10.1.2. Controle jurisdicional

Motivo

11. Nacionalidade

11.1. Natureza jurídica do direito da nacionalidade

11.2. Espécies de nacionalidade e peculiaridades

11.2.1. Primária, de origem ou originária

11.2.2. Secundária ou adquirida

11.3. Modos de aquisição da nacionalidade

11.3.1. Critério da origem sanguínea (ius sanguinis)

11.3.2. Critério da origem territorial (ius solis)

- 11.4. Reflexos da nacionalidade
- 11.5. A nacionalidade no direito constitucional brasileiro
 - 11.5.1. Os brasileiros natos
 - 11.5.2. Os brasileiros naturalizados
 - 11.5.2.1. Naturalização ordinária
 - 11.5.2.2. Naturalização extraordinária
- 11.6. Aspectos jurídicos do brasileiro nato e do naturalizado
- 11.7. Perda da nacionalidade
- 11.8. Reaquisição da nacionalidade brasileira
- 11.9. Institutos ligados à nacionalidade
 - 11.9.1. Extradicação
 - 11.9.2. Expulsão
 - 11.9.3. Deportação
 - 11.9.4. A língua e os símbolos nacionais
 - 11.9.5. Assuntos pertinentes aos estrangeiros
- 12. Direitos políticos
 - 12.1. Cidadania
 - 12.1.1. Aquisição da cidadania
 - 12.1.2. Institutos de participação direta do povo
 - 12.2. Alistabilidade e elegibilidade
 - 12.2.1. Sufrágio
 - 12.3. Sistemas eleitorais
 - 12.3.1. Sistema majoritário
 - 12.3.2. Sistema proporcional
 - 12.4. Restrições aos direitos políticos
 - 12.5. Reaquisição dos direitos políticos

12.6. Inelegibilidades

12.6.1. Absolutas

12.6.2. Relativas

12.6.2.1. Restrição por motivos funcionais

12.6.2.2. Restrição por motivo de casamento, parentesco ou afinidade

12.6.2.3. Restrição dos militares

12.6.2.4. Restrição por previsões de ordem legal

12.6.2.5. Restrição por motivo de domicílio eleitoral na circunscrição

12.7. Desincompatibilização

12.8. Partidos políticos

12.9. Processo judicial eleitoral

13. Poder Legislativo

13.1. Peculiaridades do congresso nacional

13.1.1. Mesas da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso Nacional

13.1.2. Comissões parlamentares

13.1.3. Polícia e serviços administrativos

13.1.4. Comissão representativa

13.1.5. Funcionamento do Congresso Nacional

13.1.6. Quórum para deliberação

13.1.6.1. Maioria simples

13.1.6.2. Maioria absoluta

13.1.6.3. Maioria qualificada

13.1.7. Prerrogativas dos congressistas

13.1.7.1. Inviolabilidade

13.1.7.2. Imunidade propriamente dita ou “imunidade formal ou relativa”

13.1.7.3. Privilégio de foro

- 13.1.7.4. Limitação ao dever de testemunhar
 - 13.1.7.5. Isenção do serviço militar
 - 13.1.8. Incompatibilidades dos congressistas
 - 13.1.8.1. Negociais
 - 13.1.8.2. Funcionais
 - 13.1.8.3. Profissionais
 - 13.1.9. Perda do mandato
 - 13.1.10. Tribunal de Contas da União
- 13.2. Espécies normativas
 - 13.2.1. Emenda constitucional
 - 13.2.2. Lei complementar
 - 13.2.3. Lei ordinária
 - 13.2.3.1. Regime de urgência
 - 13.2.4. Medida provisória (art. 62 da CF/88 e EC n. 32/2001)
 - 13.2.5. Lei delegada
 - 13.2.6. Decreto legislativo
 - 13.2.7. Resolução
- 14. Poder Executivo
 - 14.1. Composição
 - 14.2. Eleição, posse e sucessão
 - 14.3. Iniciativa reservada
 - 14.4. Compete ao presidente da república (art. 84 da CF/88), em especial
 - 14.4.1. Participação no processo legislativo
 - 14.4.2. Regulamentação das normas
 - 14.4.3. Atuação no plano internacional
 - 14.4.4. Atuação quanto ao funcionalismo público federal

14.4.5. Atuação em relação às Forças Armadas

14.4.6. Nomeação de autoridades

14.5. Conselho da república e conselho de defesa nacional

14.6. O impeachment

14.7. Processo e julgamento do presidente da república nos crimes comuns

14.8. Quadro comparativo do poder executivo

15. Poder Judiciário

15.1. Garantias constitucionais

15.1.1. Vitaliciedade

15.1.2. Inamovibilidade

15.1.3. Irredutibilidade de subsídio

15.2. Principais pontos da EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004 –
Reforma do Poder Judiciário

15.3. Supremo Tribunal Federal

15.3.1. Competência do Supremo Tribunal Federal

15.3.2 Súmula vinculante: art. 103-A (EC n. 45/2004)

15.4. Superior Tribunal de Justiça

15.4.1. Competência do Superior Tribunal de Justiça

15.5. Reclamação

16. Remédios constitucionais

16.1. Habeas corpus

16.2. Habeas data

16.3. Mandado de injunção

16.4. Mandado de injunção coletivo

16.5. Mandado de segurança

16.6. Mandado de segurança coletivo

- 16.7. Ação popular
- 16.8. O direito de petição
- 16.9. Ação civil pública
- 16.10. Quadro comparativo dos remédios constitucionais
- 17. Elementos das Constituições
 - 17.1. Elementos orgânicos
 - 17.2. Elementos limitativos
 - 17.3. Elementos socioideológicos
 - 17.4. Elementos de estabilização constitucional
 - 17.5. Elementos formais de aplicabilidade
- 18. História das Constituições brasileiras
 - 18.1. Constituição de 1824
 - 18.2. Constituição de 1891
 - 18.3. Constituição de 1934
 - 18.4. Constituição de 1937
 - 18.5. Constituição de 1946
 - 18.6. Constituição de 1967
 - 18.7. Constituição de 1969
 - 18.8. Constituição de 1988
- 19. Princípios constitucionais da Administração Pública
- 20. Das funções essenciais à Justiça
 - 20.1. O Ministério Público
 - 20.2. A Advocacia Pública
 - 20.3. Da Advocacia e da Defensoria Pública
- 21. Direitos sociais
- 22. Petições e recursos processuais e prática constitucional

- 22.1. Petição inicial
- 22.2. Contestação
- 22.3. Embargos de declaração
- 22.4. Agravo de instrumento
- 22.5. Agravo interno
- 22.6. Agravo em recurso especial e em recurso extraordinário
- 22.7. Apelação
- 22.8. Recurso extraordinário
- 22.9. Recurso especial
- 22.10. Recurso ordinário constitucional – ROC
- 22.11. Embargos de divergência
- 22.12. Reclamação constitucional
- 22.13. Parecer
- 22.14. Impugnação ao registro da candidatura
- 22.15. Ações de investigação judicial eleitoral
- 22.16. Recurso contra a diplomação
- 22.17. Ação de impugnação de mandato eletivo

SEGUNDA PARTE - Peças Práticas

1. Ações do controle concentrado de constitucionalidade – ADIn, ADECON e ADPF

1.1. Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica (ADIN/ADIN Genérica)

1.1.1. Modelo esquemático de Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica

1.2. Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva (ADIN/ADIn Interventiva) ou representação interventiva

1.2.1. Modelo esquemático de Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva

1.3. Ação Direta de Inconstitucionalidade Supridora da Omissão ou por Omissão (ADIN/ADIN-SO ou ADIN/ADIN-PO)

1.3.1. Modelo esquemático de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ou Supridora da Omissão

1.4. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADECON/ADECO/ADC)

1.4.1. Modelo esquemático de Ação Declaratória de Constitucionalidade

1.5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

1.5.1. Modelo esquemático de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

2. Remédios constitucionais

2.1. Habeas Corpus

2.1.1. Modelo esquemático de habeas corpus liberatório

2.2. Habeas data

2.2.1. Modelo esquemático de habeas data

2.3. Mandado de Injunção

2.3.1. Modelo esquemático de mandado de injunção

2.4. Mandado de Injunção Coletivo

2.4.1. Modelo esquemático de mandado de injunção coletivo

2.5. Mandado de Segurança

2.5.1. Modelo esquemático de mandado de segurança

2.6. Mandado de Segurança Coletivo

2.6.1. Modelo esquemático de mandado de segurança coletivo

2.7. Ação Popular

2.7.1. Modelo esquemático de ação popular

2.8. Direito de Petição

2.8.1. Modelo esquemático do direito de petição

2.9. Ação Civil Pública

2.9.1. Modelo esquemático de ação civil pública

3. Petições e recursos processuais

3.1. Petição Inicial

3.1.1. Modelo esquemático de petição inicial – rito ordinário

3.2. Contestação

3.2.1. Modelo esquemático de contestação

3.3. Embargos de Declaração

3.3.1. Modelo esquemático de embargos de declaração

3.4. Agravo de instrumento

3.4.1. Minuta de agravo de instrumento

3.4.2. Petição de comprovante de interposição de recurso de agravo de instrumento: art. 1.018 do Código de Processo Civil

3.5. Apelação

3.5.1. Modelo esquemático de apelação

a) Peça de interposição

b) Razões de apelo

3.6. Recurso extraordinário

3.6.1. Modelo esquemático de recurso extraordinário

a) Peça de interposição

b) Razões de recurso extraordinário

3.7. Recurso Especial

3.7.1. Modelo esquemático de recurso especial

a) Peça de interposição

b) Razões de recurso especial

3.8. Recurso Ordinário Constitucional – ROC

3.8.1. Modelo esquemático de recurso ordinário em habeas corpus

a) Peça de interposição

b) Razões de recurso ordinário constitucional

3.9. Embargos de Divergência

3.9.1. Modelo esquemático de embargos de divergência

3.10. Reclamação Constitucional

3.10.1. Modelo esquemático de reclamação no Supremo Tribunal Federal

3.11. Parecer

3.11.1. Modelo esquemático de parecer

4. Peças práticas das provas do Exame da OAB

5. Gabarito das peças práticas das provas do Exame da OAB

TERCEIRA PARTE - Questões Dissertativas

1. Questões dissertativas das provas do Exame da OAB

2. Gabarito das questões dissertativas OAB

Referências

Anexo I

1. Assuntos de maior incidência nas peças de segunda fase em Direito Constitucional

2. Temas recorrentes nas questões dissertativas

Para minha Professora-Assistente,
Dra. Rosa Maria Rodrigues Vaz,
sem a qual esta obra não seria realizada.

Para os Professores Bárbara Bertagnoni, Clint Rodrigues,
Diogo Vailatti, Felipe Genari, Gabriela Astini,
Gustavo Goldzveig, Habacuque Wellington Sodré,
João Pezarini, Paulo Henrique Lêdo Peixoto,
Ricardo Sanchez Baronovsky, Pedro Amadei,
Rafael Matheus e Pedro José Vilar Godoy Horta,
pela dedicação e auxílio.

Para meus alunos e colegas, pelo carinho e respeito.
Para meus colegas e amigos, pelo incentivo e apoio.

“Exerce o Senhor a Justiça,e a todos os oprimidos restitui o Direito.”

Salmos 102:6

Nota do Autor

Esta obra tem por objetivo auxiliar os bacharéis em direito e os profissionais da área jurídica na compreensão da teoria e prática do direito constitucional.

Possui os temas recorrentes na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e nos concursos públicos.

São tratadas de modo objetivo e atualizado as questões dissertativas e as peças processuais desde a primeira prova já realizada pela OAB (CESPE) na disciplina de direito constitucional.

A experiência do autor, que atua há mais de vinte anos preparando alunos para a OAB e concursos, ajuda na visão precisa daquilo que é necessário para o sucesso dos discentes.

Almeja-se contribuir para o sucesso dos leitores.

PRIMEIRA PARTE

TEÓRICA

1

1.1. PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, DE 1.º GRAU, PRIMÁRIO OU GENUÍNO

É um poder de fato que institui a Constituição de um Estado, com as seguintes características: inicial, absoluto, soberano, ilimitado, independente e incondicionado.

É a expressão da vontade suprema do povo, social e juridicamente organizado. Nesse sentido, apresenta-se o conteúdo do parágrafo único do art. 1.º da CF/88 vigente, onde se lê: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Constituição, genericamente, é o ato de constituir, de estabelecer algo, ou ainda significa o modo pelo qual se constitui uma coisa.

No mundo jurídico, a Constituição é fruto de um movimento denominado “constitucionalismo” e pode ser conceituada como a Lei Fundamental e o limite de poder de um Estado e, desse modo, determina a organização dos seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula as formas do Estado e de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Nesse sentido, José Afonso da Silva (p. 42) e José Joaquim Gomes Canotilho (Direito constitucional e teoria da constituição, p. 51).

O objeto maior da Constituição é estruturar o Estado e limitar o seu poder sobre as pessoas e as instituições que o compõem.

A atual Constituição brasileira é composta de um preâmbulo, nove títulos, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, emendas constitucionais e emendas constitucionais de revisão.

Não se pode esquecer de que a vedação do retrocesso no campo dos direitos humanos é uma limitação ao poder constituinte originário. Entende-se por vedação do retrocesso o impedimento de se reduzir um direito previsto em tratado internacional de que o país faça parte. É uma espécie de efeito cliquet (ampliação de direitos, sem possibilidade de redução).

1.2. PODER CONSTITUINTE DERIVADO DE REFORMA, DE EMENDABILIDADE, DE 2.º GRAU, SECUNDÁRIO DE MUDANÇA OU REFORMADOR

É a possibilidade de alterar uma Constituição. No Brasil, tal atribuição cabe ao Congresso Nacional (legislador ordinário).

Características: secundário, relativo, condicionado e limitado. São exemplos: o art. 60 da CF/88 (emendas constitucionais) e o art. 3.º do ADCT (emendas constitucionais de revisão).

O art. 3.º do ADCT da CF/88 assim estabelece: “A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral”.

Dessa forma, a revisão constitucional só poderia iniciar-se após 5 de outubro de 1993, fato que realmente ocorreu com a edição das seis emendas constitucionais de revisão existentes.

ATENÇÃO

As emendas constitucionais estão previstas nos arts. 59, I, e 60 da CF/88.

1.2.1. Espécies de limitações ao Poder Constituinte Derivado

a) **Limitações procedimentais:** O art. 60, nos seus incisos I, II e III, trata da iniciativa, ou seja, de quem pode apresentar uma proposta de emenda constitucional (PEC); nos §§ 2.º, 3.º e 5.º, como deve ser o procedimento para emendar a Constituição. Tem-se, então, que:

- **iniciativa:** de no mínimo um terço dos Deputados ou Senadores Federais; do Presidente da República; ou de mais da metade das Assembleias Legislativas da Federação brasileira, manifestando-se a maioria relativa de seus membros em cada uma delas;
- **trâmite:** A proposta será discutida e votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em dois turnos, com a obtenção em cada um deles de três quintos dos votos dos respectivos membros de cada Casa. Se aprovada, a emenda constitucional será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (Presidente, 1.º vice-presidente, 2.º vice-presidente, 1.º, 2.º, 3.º e 4.º secretários).

ATENÇÃO

Cumprе destacar que a matéria constante de emenda constitucional rejeitada ou prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

b) **Limitações circunstanciais:** O art. 60, § 1.º, estabelece que, havendo determinadas circunstâncias, a Constituição não poderá ser emendada. São os casos de vigência de intervenção federal (arts. 34-36 da CF/88), de estado de defesa (art. 136 da CF/88) ou de estado de sítio (arts. 137-139 da CF/88).

IMPORTANTE

Pela primeira vez depois que entrou em vigor a CF/88 foi realizada a intervenção federal. O Decreto Presidencial n. 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, determina a intervenção federal na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública com o prazo previsto de vigência até 31 de dezembro de 2018. Durante sua vigência, não pode ser modificada a CF/88.

c) **Limitações materiais:** são as chamadas limitações materiais explícitas, cláusulas pétreas, cerne fixo da Constituição, cláusulas inabolíveis, cláusulas de inamovibilidade, cláusulas inamovíveis, ou núcleos constitucionais intangíveis, ou seja, são partes da Constituição que não podem ser modificadas por emendas constitucionais para abolir direitos. As cláusulas pétreas só poderão ser retiradas da Constituição se houver uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que, como se sabe, não encontra limites, salvo a vedação do retrocesso previsto em tratados internacionais sobre direitos humanos. As cláusulas pétreas explícitas estão previstas no § 4.º do art. 60 e são os seguintes casos: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. Existem as cláusulas pétreas implícitas, que são mandamentos constitucionais que, apesar de não estarem previstos no § 4.º do art. 60, não podem ser retirados da Constituição, pois o espírito do órgão constituinte assim o desejou. São exemplos: o próprio procedimento das emendas constitucionais, o art. 127: “O Ministério Público é instituição permanente (...)” e o art. 142: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares (...)” (grifos nossos).

1.3. PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE OU SECUNDÁRIO FEDERATIVO

É o Poder dos Estados-membros da Federação de se constituírem, ou seja, de elaborarem suas próprias Constituições, respeitando os princípios constitucionais da Constituição Federal de 1988. Fundamento legal: art. 25 da CF/88 (Estados).

ATENÇÃO

- É possível ampliar esse poder para englobar os Municípios (art. 29) e o Distrito Federal (art. 32), destacando que estes se regem por Lei Orgânica.
- Destaque-se: o STF entende que a Lei Orgânica do Município não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade, pois se trata na verdade de uma crise de legalidade, de modo que há parte da doutrina que sustenta que a Lei Orgânica Municipal não seria fruto de Poder Constituinte.
- “Recurso Extraordinário. 2. Controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal em face da Lei Orgânica do Município. Inexistência de previsão constitucional. 3. Recurso não conhecido” (STF, RE 175.087/SP, 2.^a T., j. 19-3-2002, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17-5-2002, p. 73).

Decisões sobre o tema:

“É juridicamente possível o controle abstrato de constitucionalidade que tenha por objeto emenda à Constituição Federal quando se alega violação das cláusulas pétreas inscritas no art. 60, § 4.º, da CF/88. Precedente citado: ADIn 939-DF (RTJ 151/755)” (STF, ADIn 1.946/DF, j. 7-4-1999, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 16-4-1999).

“O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Min. Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, Min. Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Min. Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, Min. Celso de Mello, DJ 15-9-2003; MS 24.593/DF, Min. Maurício Corrêa, DJ 8-8-2003; MS 24.576/DF, Min. Ellen

Gracie, DJ 12-9-2003; MS 24.356/DF, Min. Carlos Velloso, DJ 12-9-2003” (STF, MS 24.667-AgR, j. 4-12-2003, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 23-4-2004).

“O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional, quando se alega, na inicial, que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da Constituição originária (art. 60, § 4.º, da CF/88). Precedente: ADIn 939 (RTJ 151/755)” (STF, ADIn 1.946-MC, j. 29-4-1999, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 14-9-2001).

“Processo de reforma da Constituição estadual. Necessária observância dos requisitos estabelecidos na CF/88 (art. 60, §§ 1.º a 5.º). Impossibilidade constitucional de o Estado-membro, em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma da Constituição estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa. Exigência que virtualmente esteriliza o exercício da função reformadora pelo Poder Legislativo local. A questão da autonomia dos Estados-membros (CF/88, art. 25). Subordinação jurídica do Poder Constituinte decorrente às limitações que o órgão investido de funções constituintes primárias ou originárias estabeleceu no texto da CF/88 (...)” (STF, ADIn 486, j. 3-4-1997, rel. Min. Celso de Mello, DJ 10-11-2006).

“Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios (...)” (STF, ADIn 3.756, j. 21-6-2007, rel. Min. Carlos Britto, DJ 19-10-2007).

“Antes de adentrar no mérito da questão aqui debatida, anoto que, muito embora não tenha o constituinte incluído o Distrito Federal no art. 125, § 2.º, que atribui competência aos Tribunais de Justiça dos Estados para instituir a representação de inconstitucionalidade em face das constituições estaduais, a Lei Orgânica do Distrito Federal apresenta, no

dizer da doutrina, a natureza de verdadeira Constituição local, ante a autonomia política, administrativa e financeira que a Carta Magna confere a tal ente federado. Por essa razão, entendo que se mostrava cabível a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo MPDFT no caso sob exame” (STF, RE 577.025, j. 11-12-2008, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6-3-2009).

“Emenda ou revisão, como processos de mudança na Constituição, são manifestações do Poder Constituinte instituído e, por sua natureza, limitado. Está a ‘revisão’ prevista no art. 3.º do ADCT de 1988 sujeita aos limites estabelecidos no § 4.º e seus incisos do art. 60 da CF/88. O resultado do plebiscito de 21 de abril de 1993 não tornou sem objeto a revisão a que se refere o art. 3.º do ADCT, após 5 de outubro de 1993, cabia ao Congresso Nacional deliberar no sentido da oportunidade ou necessidade de proceder à aludida revisão constitucional, a ser feita ‘uma só vez’. As mudanças na Constituição, decorrentes da ‘revisão’ do art. 3.º do ADCT, estão sujeitas ao controle judicial, diante das ‘cláusulas pétreas’ consignadas no art. 60, § 4.º e seus incisos, da Lei Magna de 1988” (STF, ADIn 981-MC, j. 17-12-1993, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 5-8-1994).

“A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo Poder Constituinte (redundantemente chamado de ‘originário’) não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo Poder Reformador, essas têm sua validade e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas. O art. 78 do ADCT, acrescentado pelo art. 2.º da EC 30/2000, ao admitir a liquidação ‘em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos’ dos ‘precatórios pendentes na data de promulgação’ da emenda, violou o direito adquirido do

beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Atentou ainda contra a independência do Poder Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, máxime no concernente ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e fazer cumpridas as suas decisões, inclusive contra a Fazenda Pública, na forma prevista na Constituição e na lei. Pelo que a alteração constitucional pretendida encontra óbice nos incisos III e IV do § 4.º do art. 60 da CF/88, pois afronta 'a separação dos Poderes' e 'os direitos e garantias individuais'" (STF, ADIn 2.356-MC e ADIn 2.362-MC, Pleno, j. 25-11-2010, rel. Min. Néri da Silveira, rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, DJe 18-5-2011).

"A Lei Orgânica tem força e autoridade equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às Constituições promulgadas pelos Estados-membros, como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta" (STF, ADIn 980, Plenário, j. 6-3-2008, rel. Min. Menezes Direito, DJe 1.º-8-2008).

PODER CONSTITUINTE	Originário (1.º grau, genuíno, primário) • Poder para fazer a 1.ª ou nova Constituição para um Estado. "O povo elege a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) para fazer uma Constituição" (Povo: titular do poder constituinte/ ANC: exercente do poder constituinte/Objeto: Constituição). • Características: inicial, soberano, absoluto, ilimitado, independente e incondicionado (pode tudo), salvo em relação aos direitos humanos (vedação do retrocesso).
	Derivado reformador (2.º grau, de revisão, de emendabilidade, secundário de mudança, derivado de reforma etc.) • Depende do Poder Originário. Se a Constituição for imutável, não haverá esse poder. • Características: secundário, relativo, condicionado e limitado. • Art. 3.º, ADCT – Emendas Constitucionais de Revisão. Após 5 anos da promulgação. Maioria absoluta (total de membros). Congresso Nacional. Única votação. São apenas 6 e não podem mais ser usadas por decisão do STF (ADIn 815 e 981). • Art. 60 da CF/88 – Emenda Constitucional – único meio de mudança da

CF/88.

Derivado decorrente (decorrente ou secundário federativo)

- Depende do Poder Originário.
- É o poder que autoriza os entes federativos a elaborarem suas normas fundamentais.
- Art. 25, caput, da CF/88: Cada Estado-membro pode elaborar sua Constituição, respeitando a CF/88.
- Art. 32, caput, da CF/88: O DF pode elaborar Lei Orgânica, respeitando a CF/88.
- Art. 29, caput, da CF/88: Os Municípios podem fazer suas Leis Orgânicas, respeitando a Constituição Estadual e a CF/88.

Repartição das competências constitucionais

Competência, em sentido estrito, é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Pode, ainda, ser considerada como a capacidade de distribuir poder.

Na Constituição Federal vigente, em relação à repartição de competências entre as entidades federativas, há o princípio da predominância do interesse, segundo o qual à União caberão as matérias e questões de predominante interesse geral, ao passo que aos Estados ficarão as matérias e assuntos de interesse regional, e aos Municípios, as questões de predominante interesse local.

Os poderes da União são enumerados nos arts. 21 e 22 da CF/88; os Estados ficam com os poderes remanescentes (art. 25, § 1.º, da CF/88); e os Municípios ficam com os poderes indicados genericamente no art. 30 da CF/88. Alguns poderes podem ser delegados, como o poder da União para legislar a respeito de certas matérias. Nesse caso, o art. 22, parágrafo único, da CF/88 autoriza a delegação da atribuição legislativa aos Estados, mediante lei complementar. Em determinadas áreas, permite-se a atuação concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 24 e 30, II, da CF/88). Por fim, há a competência comum entre os entes federativos (art. 23 da CF/88).

Trata-se de divisão doutrinária sobre o tema “competências constitucionais”, que segundo a doutrina majoritária, pode ser considerada

conforme os itens a seguir.

2.1. COMPETÊNCIA NÃO LEGISLATIVA (ADMINISTRATIVA/MATERIAL)

Trata-se de uma competência organizacional (gerencial) do Estado, podendo ser dividida em:

- a) **exclusiva da União:** só é admitida legislação federal (art. 21 da CF/88);
- b) **comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:** todos os entes da Federação podem agir de forma independente (art. 23 da CF/88).

2.2. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

Trata-se da competência de fazer normas gerais e abstratas que, normalmente, são aplicadas a todos indistintamente. É classificada da seguinte forma:

- a) **exclusiva:** cabe apenas a uma entidade o poder de legislar, sendo inadmissível qualquer delegação (art. 21 da CF/88 – só a União);
- b) **privativa:** da União, mas é delegável aos Estados por lei complementar (art. 22, parágrafo único, da CF/88).
- c) **concorrente:** da União, dos Estados e do Distrito Federal, que devem agir de forma coordenada, segundo estabelecido nos parágrafos do art. 24 da CF/88, onde se lê: “(...) § 1.º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais; § 2.º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados; § 3.º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades; § 4.º A

superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”;

d) **residual**: são as competências não previstas expressamente à União ou aos Municípios. Essa é a previsão do art. 25, § 1.º, da CF/88, que assim estabelece: “São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”;

e) **local**: normalmente em concursos é a competência dos Municípios, conforme previsão do art. 30, I, da CF/88: “Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de interesse local; (...)”;

CUIDADO

O Município pode legislar em matéria de competência legislativa concorrente desde que suplemente a legislação federal e estadual e que a matéria seja de interesse local (art. 30, I e II c/c § 2.º, art. 24, da CF/88).

Sobre o tema competência municipal o STF se manifestou no seguinte sentido:

- “O Tribunal, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei n. 10.991/91, do Município de São Paulo, o qual estabelecia que a licença de localização de novas farmácias e drogarias seria concedida somente quando o estabelecimento ficasse situado a uma distância mínima de duzentos metros da farmácia ou drogaria mais próxima, já existente. Entendeu-se violado o disposto no art. 170, IV e

V, da CF (“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna (...) observados os seguintes princípios: (...) IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor”). Precedente citado: RE 203.909-SC (DJU 6-2-1998)” STF, RE 193.749-SP, j. 4-6-1998, rel. originário Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ 4-5-2001).

- “Com base nos mesmos fundamentos do julgamento acima referido, o Tribunal, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei n. 6.545/91, do Município de Campinas, que restringia a instalação de farmácias e drogarias a um raio de distância de quinhentos metros uma da outra. Vencido o Min. Carlos Velloso” (STF, RE 199.517-SP, j. 4-6-1998, rel. originário Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ 13-11-1998).

Súmula Vinculante 38: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.

f) **cumulativa**: é a competência atribuída ao Distrito Federal no art. 32, § 1.º, da CF/88: “Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”.

Destaque-se a previsão constitucional dos arts. 147 e 155 da CF/88: “Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais” (grifo nosso). “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; III – propriedade de veículos automotores” (grifo nosso).

Decisões sobre o tema:

“Competência privativa da União para legislar sobre serviço postal. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade de normas estaduais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes: ADIns 2.815, Sepúlveda Pertence (propaganda comercial), n. 2.796-MC, Gilmar Mendes (trânsito), n. 1.918, Maurício Corrêa (propriedade e intervenção no domínio econômico), n. 1.704, Carlos Velloso (trânsito), n. 953, Ellen Gracie (relações de trabalho), n. 2.336, Nelson Jobim (direito processual), n. 2.064, Maurício Corrêa (trânsito) e n. 329, Ellen Gracie (atividades nucleares). O serviço postal está no rol das matérias cuja normatização é de competência privativa da União (CF, art. 22, V). É a União, ainda, por força do art. 21, X, da Constituição, o ente da Federação responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público” (STF, ADIn 3.080, j. 2-8-2004, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 27-8-2004).

“(...) Lei n. 11.562/2000 do Estado de Santa Catarina. Mercado de trabalho. Discriminação contra a mulher. Competência da União para legislar sobre Direito do trabalho. (...) A Lei n. 11.562/2000, não obstante o louvável conteúdo material de combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, incide em inconstitucionalidade formal, por invadir a competência da União para legislar sobre direito do trabalho (...)” (STF, ADIn 2.487, j. 30-8-2007, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 28-3-2008).

“O Tribunal, por maioria, concedeu habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, I e II, do CP, e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei paulista n. 11.819/2005, que previu a utilização de aparelho de videoconferência nos procedimentos judiciais destinados ao interrogatório e à audiência de presos – v. Informativo 518. Na espécie, o interrogatório do paciente, a despeito da discordância de sua defesa, realizara-se sem a presença do paciente na sala da audiência, por meio da videoconferência. Entendeu-se que a norma em questão teria invadido a competência privativa da União para legislar sobre direito processual” (STF, HC 90.900, j. 30-10-2008, rel. p/ o ac. Min. Menezes Direito, Informativo 526). No mesmo sentido: STF, HC 91.859, j. 4-11-2008, rel. Min. Carlos Britto, DJe 13-3-2009.

“Invade a competência da União, norma estadual que disciplina matéria referente ao valor que deva ser dado a uma causa, tema especificamente inserido no campo do direito processual” (ADIn 2.655, j. 9-3-2004, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26-3-2004). “O Tribunal concedeu medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para suspender a eficácia, ex nunc, do art. 7.º da Lei n. 6.816/2007, do Estado de Alagoas, que condiciona a interposição de recurso inominado cível nos Juizados Especiais do referido Estado-membro ao recolhimento das custas judiciais

e do depósito recursal. Entendeu-se que a norma impugnada, em princípio, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (...), bem como ofende as garantias do amplo acesso à jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (...)" (STF, ADIn 4.161-MC, j. 29-10-2008, rel. Min. Menezes Direito, Informativo 526).

"Por vislumbrar afronta ao art. 22, XI, da CF/88, que atribui à União a competência privativa para legislar sobre trânsito, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta proposta pelo Governador do Distrito Federal para declarar a inconstitucionalidade da Lei distrital n. 1.925/98, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iluminação interna dos veículos automotores fechados, no período das dezoito às seis horas, quando se aproximarem de blitz ou barreira policial. Salientou-se que inexistente lei complementar que autorize o DF a legislar sobre a fiscalização e o policiamento de trânsito e que tal matéria, que envolve tipificação de ilícitos e cominação de penas, foi objeto de tratamento específico do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, editado no exercício daquela competência privativa" (STF, ADIn 3.625, j. 4-3-2009, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, Informativo 537). No mesmo sentido: STF, ADIn 3.897, j. 4-3-2009, rel. Min. Gilmar Mendes, Informativo 537.

"O art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente não cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2.º) e competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, § 3.º). Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais (art. 24, § 1.º), poderão os Estados e o DF, no uso da competência suplementar, preencher os vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais (art. 24, § 2.º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a competência legislativa plena 'para atender a suas peculiaridades' (art. 24, § 3.º). Sobrevindo a lei federal de

normas gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4.º). A Lei n. 10.860, de 31 de agosto de 2001, do Estado de São Paulo foi além da competência estadual concorrente não cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2.º e § 3.º” (STF, ADIn 3.098, j. 24-11-2005, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10-3-2006).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital n. 3.460. Instituição do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em uso no âmbito do Distrito Federal. Alegação de violação do disposto no art. 22, XI, da Constituição do Brasil – Inocorrência – O ato normativo impugnado não dispõe sobre trânsito ao criar serviços públicos necessários à proteção do meio ambiente por meio do controle de gases poluentes emitidos pela frota de veículos do Distrito Federal. A alegação do requerente de afronta ao disposto no art. 22, XI, da CF/88 não procede. A lei distrital apenas regula como o Distrito Federal cumprirá o dever-poder que lhe incumbe – proteção ao meio ambiente. O DF possui competência para implementar medidas de proteção ao meio ambiente, fazendo-o nos termos do disposto no art. 23, VI, da CF/88. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (STF, ADIn 3.338, j. 31-8-2005, rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, DJ 6-9-2007).

“Competência legislativa. Direito do trabalho. Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade. (...) Competências exclusivas da União. (...) É inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito” (STF, ADIn 3.610, j. 1.º-8-2011, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 21-9-2011). Vide: STF, ADIn 3.679, j. 18-6-2007, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 3-8-2007. “São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento” (Súmula 722 do STF).

O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional expressão de lei paranaense que fixava como condição para participação de empresas em licitação destinada à compra de veículos oficiais a exigência de os carros serem produzidos no Paraná (STF, ADIn 3.583, Plenário, j. 21-2-2008, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 14-3-2008)

Súmula Vinculante 39: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”.

Súmula Vinculante 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.

Classificação doutrinária da Constituição de 1988

A Constituição Federal de 1988 admite diversas classificações doutrinárias, porém a de maior incidência em concursos e provas jurídicas será analisada a seguir.

3.1. QUANTO À FORMA

Escrita: é uma Constituição codificada e sistematizada num texto único e que foi elaborada por um órgão constituinte (Assembleia Nacional Constituinte).

3.2. QUANTO À ELABORAÇÃO

Dogmática: é uma Constituição escrita e elaborada por um órgão constituinte, sistematizando os dogmas ou as ideias fundamentais da teoria política e do Direito dominante naquele momento.

3.3. QUANTO À ORIGEM

Popular ou democrática: é uma Constituição originária de um órgão constituinte composto por representantes do povo, eleitos para o fim de elaborá-la e estabelecê-la. Além disso, a Constituição é promulgada.

3.4. QUANTO À ESTABILIDADE, ALTERALIDADE, CONSISTÊNCIA OU MUTABILIDADE

Rígida: é uma Constituição somente alterável mediante processos,

solenidades e exigências formais especiais, diferentes e mais difíceis que os de formação das leis ordinárias e complementares. No Brasil são exigidos três quintos em dois turnos, nas duas Casas do Congresso Nacional – § 2.º do art. 60 da CF/88. Alguns autores a classificam como super-rígida, pois contém as cláusulas pétreas (posição minoritária).

3.5. QUANTO À EXTENSÃO

Analítica ou prolixa: É uma Constituição que contém um número elevado de artigos. Possui normas constitucionais materiais (separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais etc.) e formais (do meio ambiente, dos índios, da família etc.).

3.6. QUANTO À SISTEMATIZAÇÃO OU ESTRUTURA

Orgânica ou reduzida: contida em um documento único. Alguns autores entendem que atualmente a Constituição brasileira seria inorgânica ou variada (é a somatória de vários instrumentos normativos), em virtude de o Decreto n. 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo) ser equivalente a uma emenda constitucional e estar no topo da pirâmide jurídica brasileira junto com a Constituição Federal vigente.

3.7. QUANTO À RELIGIÃO

Laica (leiga ou não confessional): é aquela Constituição que não adota uma religião oficial (art. 19, I, da CF/88). Saliente-se que já existiu uma Constituição teocrática ou confessional (é aquela Constituição que adota uma religião oficial: primeira Constituição brasileira – 1824 – religião: católica apostólica romana).

Pode-se inferir que a Constituição Federal vigente é escrita, dogmática, popular, rígida, analítica e orgânica. Além disso, pode ser considerada

democrática, pluralista, promulgada, laica, entre outras classificações possíveis.

IMPORTANTE

STF conclui julgamento sobre ensino religioso nas escolas públicas

Em 27 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.439, na qual a Procuradoria-Geral da República questionava o modelo de ensino religioso nas escolas da rede pública de ensino do país. Por maioria dos votos (6 x 5), os ministros entenderam que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ter natureza confessional, ou seja, vinculado às diversas religiões. Com a leitura dos três votos proferidos nesta quarta-feira, o Supremo concluiu o julgamento da ADIn. Votaram pela improcedência do pedido os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Ficaram vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (relator), Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello, que se manifestaram pela procedência da ação (STF, ADIn 4.439, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27-9-2017).

Decisão sobre o tema:

“Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa” (STF, ADIn 2.076, j. 15-8-2002, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 8-8-2003).

Fenômenos ou teorias que surgem com uma nova Constituição

É importante destacar a seguinte regra: a nova Constituição revoga a Constituição anterior e a legislação infraconstitucional incompatível materialmente (direito).

De acordo com a doutrina majoritária existem fenômenos ou teorias que surgem com uma nova Constituição. Veremos a seguir.

4.1. RECEPÇÃO

Toda legislação infraconstitucional anterior compatível materialmente com a nova Constituição continua em pleno vigor. São exemplos: O Código de Processo Penal (Decreto-lei n. 3.689/41), o Código Penal (Decreto-lei n. 2.848/40), entre outros. Saliente-se que normas infraconstitucionais anteriores à CF/88 não podem contrariar materialmente, mas podem contrariar formalmente (procedimento, por exemplo, a espécie normativa). Desse modo, tanto o Código de Processo Penal quanto o Código Penal, que foram criados por decretos-leis, foram recepcionados como leis ordinárias.

É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal não admite a chamada inconstitucionalidade superveniente de ato normativo produzido antes da nova Constituição perante o novo modelo. Assim, pode haver compatibilidade e recepção ou revogação por incompatibilidade material. Tem-se o princípio da contemporaneidade (uma lei é constitucional perante o paradigma de confronto em relação ao qual ela foi produzida).

4.2. REPRISTINAÇÃO

A nova Constituição revalida ou revigora a legislação infraconstitucional revogada pela Constituição que a antecedeu. Essa restauração de eficácia, conhecida por repristinação, não deve ser admitida em nosso ordenamento jurídico no plano constitucional em virtude dos princípios da segurança e da estabilidade das relações sociais.

Não obstante, destaque-se no plano infraconstitucional, o § 3.º do art. 2.º do Decreto-lei n. 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, antiga LICC), bem como o efeito repristinatório de decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de ADIn genérica (o STF declara inconstitucional a lei revogadora, revigorando a lei revogada).

4.3. DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO

A nova Constituição recebe a anterior como legislação infraconstitucional (lei ordinária). Esta tese não vigora entre nós, pois não há justificativa e lógica para que as leis constitucionais sejam rebaixadas para legislação ordinária.

ATENÇÃO

Destaque-se que, para alguns autores, haveria o instituto da **prorrogação**, que seria a continuação de atos anteriores até a efetiva regulamentação de acordo com a Constituição Federal de 1988. Por exemplo, arts. 27, § 1.º, 29, § 3.º, 34 e 70, todos do ADCT da CF/88.

Decisões sobre o tema:

“A recepção de lei ordinária como lei complementar pela Constituição posterior a ela só ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação desta, não havendo que pretender-se a ocorrência de efeito repristinatório, porque o nosso sistema jurídico, salvo disposição em contrário, não admite a repristinação (LINDB, art. 2.º, §

3.º)” (STF, AI 235.800-AgRg/RS, j. 25-5-1999, rel. Min. Moreira Alves, DJ 25-6-1999) [Observação: a CF/88 foi alterada pela EC 40/2003 que revogou o § 3.º do art. 192].

“Recurso extraordinário. Lei n. 9.430/96. COFINS. Isenção. Revogação. Sociedades de Prestação de Serviços de Profissão Legalmente Regulamentada. Ressalva de óptica pessoal. O Plenário, apreciando os RE 377.457-3/PR e 381.964-0/MG, concluiu mostrar-se legítima a revogação, mediante o art. 56 da Lei n. 9.430/96, da isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS relativa às sociedades de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada, estabelecida no art. 6.º, II, da LC n. 70/91” (STF, RE 477.099-AgRg/RS, j. 16-12-2008, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20-3-2009).

“I. Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2.º, IV, c, da Lei Estadual n. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de Pernambuco, que estabelece a vinculação da Defensoria Pública estadual à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: violação do art. 134, § 2.º, da CF, com a redação da EC n. 45/2004: inconstitucionalidade declarada. 1. A EC n. 45/2004 outorgou expressamente autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2.º): donde ser inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública à Secretaria de Estado. 2. A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2.º, da CF pela EC n. 45/2004 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos. II. Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de Justiça, por força da Lei Complementar Estadual (PE) n. 20/98: revogação, dada a incompatibilidade com o novo Texto Constitucional. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal – malgrado o dissenso do Relator – que a antinomia entre norma ordinária anterior e a Constituição superveniente se resolve em mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta a ação

direta. 2. O mesmo raciocínio é aplicado quando, por força de emenda à Constituição, a lei ordinária ou complementar anterior se torna incompatível com o texto constitucional modificado: precedentes” (STF, ADIn 3.569/PE, j. 2-4-2007, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 11-5-2007).

“Direito constitucional. Medida cautelar em ação de descumprimento de preceito fundamental. Processo de impeachment. Definição da legitimidade constitucional do rito previsto na Lei n. 1.079/50. Cabimento da ação e concessão de medidas cautelares” (STF, ADPF 378, Plenário, j. 17-12-2015, rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 8-3-2016).

RECEPÇÃO	Toda legislação infraconstitucional anterior compatível materialmente com a nova Constituição continua em pleno vigor.
REPRISTINAÇÃO	A nova Constituição revalida a legislação infraconstitucional revogada pela Constituição que a antecedeu.
DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO	A nova Constituição recebe a anterior como legislação infraconstitucional (lei ordinária).
PRORROGAÇÃO	A continuação de institutos, entes ou atos anteriores até a efetiva regulamentação de acordo com a nova Constituição.

Aplicabilidade das normas constitucionais

Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica (plano abstrato), porém nem todas possuem efetividade (plano concreto), e, segundo a doutrina majoritária, podem ser classificadas conforme os itens a seguir.

5.1. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA PLENA

São aquelas de aplicabilidade imediata, direta, integral, independentemente de legislação infraconstitucional para sua inteira operatividade. Por exemplo, arts. 1.º (fundamentos); 2.º (poderes); 13 (língua portuguesa); 14, § 2.º (inalistáveis), § 4.º (inelegíveis); 17, § 4.º (vedação de organização paramilitar); 37, III (validade de concurso); 44, parágrafo único (legislatura); 69 (aprovação de lei complementar), 230, § 2.º (gratuidade de transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos); entre outros, da CF/88.

5.2. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA CONTIDA

São aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, plena, mas podem ter reduzido o seu alcance pela atividade do legislador ordinário, em virtude de autorização constitucional. São também chamadas de normas de eficácia redutível ou restringível. Por exemplo, arts. 5.º, VIII, XIII, XV, XXVII, XXXIII, LVIII, LX, LXI, LXVII; 170, parágrafo único; 184; entre outros da CF/88.

Possuem muita incidência em prova: a) inciso XIII do art. 5.º da CF/88:

“É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, desse modo, pode ser aprovada lei federal regulamentando certa profissão, que anteriormente não exigia requisitos legais para o seu exercício; b) inciso LVIII do art. 5.º da CF/88: “O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei”, portanto, quem possui documento que o identifique (Registro Geral – RG, Carteira da OAB, Carteira funcional) não precisa passar por processo de identificação, salvo nos casos que a lei determinar.

Destaque-se que a limitação das normas constitucionais pode ser realizada não apenas por normas infraconstitucionais, mas, também, por normas constitucionais. É o caso, por exemplo, da decretação de estado de defesa e do estado de sítio, em que há a possibilidade de restrição de direitos constitucionais. São exemplos os arts. 136, § 1.º, e 139, da CF/88.

5.3. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA LIMITADA

São aquelas que dependem da emissão de uma normatividade futura, em que o legislador ordinário, integrando-lhes a eficácia, mediante lei, lhes dê capacidade de execução em termos de regulamentação dos interesses visados.

São exemplos e possuem muita incidência em prova: a) art. 5.º, XXVIII (direito de imagem), XXIX (direito autoral) e XXXII (direito do consumidor); b) art. 7.º, IV (salário mínimo) e XXIII (adicional de insalubridade); c) 37, I (acesso aos cargos e empregos públicos) e VII (direito de greve); d) art. 153, VII, (grandes fortunas), todos da CF/88.

Neste tópico pode, ainda, existir uma subdivisão classificatória:

- a) **normas de princípio institutivo:** são aquelas que dependem da lei para dar corpo às instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição. São exemplos da Constituição Federal vigente: § 3.º do art. 18 (novos

Estados), § 3.º do art. 25 (regiões metropolitanas), art. 224 (Conselho de Comunicação Social), entre outros.

b) **normas de princípio programático**: são aquelas que estabelecem programas a serem desenvolvidos mediante legislação integrativa da vontade constituinte. São exemplos da CF/88: o parágrafo único do art. 4.º, os arts. 196 (saúde), 205 (educação), 214 (educação), 215 (cultura), entre outros.

As normas constitucionais de eficácia limitada contêm eficácia jurídica indireta, independentemente de regulamentação, pois revogam a legislação anterior contrária aos ditames da nova Constituição, bem como impossibilitam a elaboração de leis e atos normativos contrários à Lei Fundamental. Além disso, autorizam a busca da regulamentação por intermédio do Poder Judiciário (mandado de injunção ou ADIn/ADIn supridora da omissão ou por omissão).

IMPORTANTE

Neoconstitucionalismo ou Ativismo Judicial é uma concepção teórico-jurídica que, no Brasil e em outros países, visa à materialização de direitos em virtude da atuação do Poder Judiciário, assim tem aproximado as concepções de direito e justiça por meio de um diálogo racional. Nesse sentido, o STF decidiu que o Poder Judiciário pode obrigar o Poder Executivo a reformar estabelecimentos prisionais (STF, RE 592.581/RS, j. 13-8-2015, v.u., rel. Min. Ricardo Lewandowski, e RE 650.085/SP, j. 1.º-9-2011, rel. Min. Carmen Lúcia).

ATENÇÃO

Para Maria Helena Diniz (Norma constitucional e seus efeitos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 101-115), as normas constitucionais podem ter: a) supereficácia ou eficácia absoluta: não podem ser emendadas (art. 60, § 4.º – cláusulas pétreas); b) eficácia plena: não dependem de regulamentação; c) eficácia relativa restringível: admitem redução da extensão do direito por norma infraconstitucional (semelhante à eficácia contida); d) eficácia relativa complementável: dependem de regulamentação para sua efetividade (semelhante a eficácia limitada).

Para Uadi Lammêgo Bulos (Constituição federal anotada. São Paulo: Saraiva, p. 335), normas de

eficácia exaurida são aquelas que já extinguiram a produção de seus efeitos. Por exemplo, as normas do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (arts. 1.º, 2.º, 3.º, 14, 20, 25, entre outros).

Decisões sobre o tema:

“Mandado de injunção. Natureza. Conforme disposto no inciso LXXI do art. 5.º da CF/88, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental, e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. Mandado de injunção. Decisão. Balizas. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. Aposentadoria. Trabalho em condições especiais. Prejuízo à saúde do servidor. Inexistência de lei complementar. Art. 40, § 4.º, da CF/88. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – art. 57, § 1.º, da Lei n. 8.213/91” (STF, MI 721/DF, j. 30-8-2007, rel. Min. Marco Aurélio DJ 30-11-2007). No mesmo sentido: STF, MI 795/DF, j. 15-4-2009, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22-5-2009; STF, MI 788/DF, j. 15-4-2009, rel. Min. Ayres Britto, DJe 8-5-2009.

“Habeas Corpus. Decisão que negou seguimento ao pedido ajuizado no Tribunal Superior do Trabalho. Mitigação da Súmula 691/STF. Depositário judicial. Prisão civil. Inadmissibilidade. Orientação plenária do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida de ofício. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que só é possível a prisão civil do ‘responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia’ (inciso LXVII do art. 5.º da CF/88). Precedentes: HCs 87.585 e 92.566, da relatoria do Min. Marco Aurélio. 2. A norma que se extrai do

inciso LXVII do art. 5.º da CF/88 é de eficácia restringível. Pelo que as duas exceções nela contidas podem ser aportadas por lei, quebrantando, assim, a força protetora da proibição, como regra geral, da prisão civil por dívida. 3. O Pacto de San José da Costa Rica (ratificado pelo Brasil – Decreto n. 678/92), para valer como norma jurídica interna do Brasil, há de ter como fundamento de validade o § 2.º do art. 5.º da Magna Carta. A se contrapor, então, a qualquer norma ordinária originariamente brasileira que preveja a prisão civil por dívida. Noutros termos: o Pacto de San José da Costa Rica, passando a ter como fundamento de validade o § 2.º do art. 5.º da CF/88, prevalece como norma supralegal em nossa ordem jurídica interna e, assim, proíbe a prisão civil por dívida. Não é norma constitucional – à falta do rito exigido pelo § 3.º do art. 5.º –, mas a sua hierarquia intermediária de norma supralegal autoriza afastar regra ordinária brasileira que possibilite a prisão civil por dívida. 4. Na concreta situação dos autos, a prisão civil do paciente foi decretada com base na não localização dos bens penhorados e a ele confiados em depósito. A autorizar, portanto, a mitigação da Súmula 691” (STF, HC 94.935/SP, j. 10-2-2009, rel. Min. Carlos Britto, DJe 13-3-2009).

ATENÇÃO

Trata-se de transcrição de ementa do site do STF.

Quanto ao tema da prisão civil, a Súmula 619 do STF foi revogada (vide HC 92.566-9 SP, DJe 12-12-2008, divulgado em 11-12-2008) (Notícia disponível em: [<http://www.stf.jus.br/porta/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100258>]).

Súmula Vinculante 25: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. Desse modo, havendo o seu descumprimento, cabe reclamação no STF.

“O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas

são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Isso implica, logicamente, que a interpretação do art. 5.º, XIII, da CF/88, na hipótese da profissão de jornalista, se faça, impreterivelmente, em conjunto com os preceitos do art. 5.º, IV, IX, XIV, e do art. 220 da CF/88, que asseguram as liberdades de expressão, de informação e de comunicação em geral. (...) No campo da profissão de jornalista, não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações profissionais. O art. 5.º, IV, IX, XIV, e o art. 220 não autorizam o controle, por parte do Estado, quanto ao acesso e exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística, configura, ao fim e ao cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo art. 5.º, IX, da CF/88. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a fiscalização desse tipo de profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo em que imperam as liberdades de expressão e de informação. Jurisprudência do STF: Rp 930, rel. p/ o ac. Min. Rodrigues Alckmin, DJ de 2-9-1977” (STF, RE 511.961, j. 17-6-2009, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13-11-2009).

Controle de constitucionalidade

6.1. CONCEITO E ORIGEM

O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade vertical que necessariamente deve haver entre a Constituição e as normas infraconstitucionais a ela subordinadas.

ATENÇÃO

As normas infraconstitucionais devem ser posteriores para fins de controle de constitucionalidade, pois se forem anteriores e contrariarem direitos previstos na nova Constituição haverá a “não recepção” de tais normas. Neste caso, é cabível uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Tem por fundamento o princípio da supremacia da Constituição, que determina que todos os atos jurídicos devem estar de acordo com a Constituição.

A doutrina destaca que o controle de constitucionalidade difuso surgiu nos Estados Unidos, em uma Constituição que não o previa expressamente. Porém, o juiz John Marshall, presidente da Suprema Corte norte-americana, ao decidir o caso Marbury x Madison, de 1803, deduziu de seu sistema esse controle e reconheceu pertencer ele ao Judiciário.

No caso, Willian Marbury fora nomeado para o cargo de juiz de paz, no Condado de Washington, no distrito de Columbia, de acordo com os trâmites constitucionais, porém o Secretário de Estado James Madison não queria entregar o título de comissão a Marbury, que por sua vez recorreu ao

Judiciário, momento em que o juiz Marshall demonstrou que, se a Constituição americana era a base do direito e imutável por meios ordinários, as leis comuns que a contradissem não eram verdadeiramente leis, não eram direito. Assim, essas leis seriam nulas, não obrigando os particulares. Além disso, demonstrou que, cabendo ao Judiciário dizer o que é o direito, é a ele que compete indagar da constitucionalidade de uma lei.

Sobre o tema controle de constitucionalidade concentrado é necessário destacar: "Há países que, ao invés de adotarem o sistema da jurisdição difusa, adotam de modo explícito os procedimentos particulares para o controle de constitucionalidade. Na Europa inteira há somente um país (Irlanda) que confere, expressamente, o controle de constitucionalidade à magistratura e mesmo assim com temperamentos, pois atribui o controle apenas a duas Cortes superiores. A partir da Primeira Guerra Mundial, uma série crescente de Constituições tem adotado um terceiro caminho, ou seja, não é atribuído nem ao próprio Legislativo, nem ao Judiciário, o poder de decidir da constitucionalidade das leis. Tal poder eles conferem a um órgão especial, de caráter constitucional e de natureza jurídico-política. São as Cortes Constitucionais (Áustria, 1920, sob influência de Kelsen; Tchecoslováquia, 1920; Espanha Republicana, 1931; Turquia, 1961). Foram, também, adotadas na América Latina (Guatemala, 1965; Chile, 1925). A Constituição austríaca de 1920, ao dispor sobre a jurisdição do Estado, estabelece que os tribunais não têm o direito de apreciar a validade das leis regularmente publicadas. Se um tribunal tiver contra a aplicação de um regulamento objeções deduzidas de sua ilegalidade, deverá interromper o processo e requerer à Alta Corte Constitucional a cassação do regulamento em tela (art. 89). Essa disposição, porém, não se aplica à Corte Constitucional (art. 140, 5), que tem importantes competências (arts. 137 e s.), entre elas a de julgar sobre a inconstitucionalidade das leis, ou de ofício, nos processos que lhe forem submetidos, ou a pedido do Governo

Federal, em relação às leis provinciais, ou a pedido dos Governos provinciais em relação às Leis Federais (art. 140, I)” (Ronaldo Rebello de Britto Poletti, Controle de constitucionalidade das leis, 2. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 62-63).

6.2. INCONSTITUCIONALIDADE

No estudo do controle de constitucionalidade é importante destacar os conceitos de inconstitucionalidade por ação e por omissão.

6.2.1. Inconstitucionalidade por ação

Esse fenômeno surge com a produção de atos legislativos ou administrativos (atos jurídicos) que não estejam de acordo com as normas ou princípios da Constituição.

São atos legislativos: as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções.

São atos normativos (administrativos): resoluções, decretos, portarias, entre outros, editados pelo Poder Executivo, além das normas regimentais dos tribunais federais e estaduais.

O fundamento dessa inconstitucionalidade está ligado ao princípio da supremacia da Constituição, ou seja, só devem existir no mundo jurídico as normas que estejam de acordo com a Constituição.

A inconstitucionalidade por ação pode ser dividida em:

- a) **inconstitucionalidade formal, procedimental, nomodinâmica ou orgânica**: quando há desrespeito ao procedimento previsto na Constituição para a realização de um ato jurídico (iniciativa, sistema de aprovação, espécie normativa, competência do órgão legiferante etc.). Em regra, acarreta uma nulidade total. Por exemplo:

- se é exigida a assinatura de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para a propositura de um projeto de emenda constitucional, qualquer número inferior ao estabelecido caracteriza uma inconstitucionalidade formal:

“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; (...)”.

- violar o sistema de aprovação de uma norma:

“Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta”.

- violar a espécie normativa específica:

“Art. 161. Cabe à lei complementar: I – definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I; II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios; III – dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II”.

Decisões sobre o tema:

“Por ofensa ao art. 61, § 1.º, II, a e c, da CF/88 – que atribuem ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a remuneração e regime jurídico de servidores públicos –, o Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba, para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 39 da Constituição, do mesmo Estado, que assegurava a servidores públicos, em cada nível de

vencimento, como garantia do princípio da hierarquia salarial, 'um acréscimo nunca inferior a cinco por cento do nível imediatamente antecedente, e a fixação, entre cada classe, referência ou padrão, de diferença não inferior a cinco por cento'. Vencidos os Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio, que julgavam improcedente a ação relativamente ao alegado vício formal. Precedente citado: ADIn 1.977/PB (DJU 2-5-2003)" (STF, ADIn 2.863/PB, j. 11-9-2003, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 28-5-2004).

"A alteração substancial do texto constitucional em razão de emenda superveniente prejudica a análise da ação direta de inconstitucionalidade. O controle concentrado de constitucionalidade é feito com base no texto constitucional em vigor. A modificação do texto constitucional paradigma inviabiliza o prosseguimento da ação direta. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada" (STF, ADIn 2.159/DF, j. 12-8-2004, rel. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, DJe 7-12-2007). No mesmo sentido: STF, ADIn 2.813, j. 1.º-8-2011, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26-8-2011; STF, ADIn 307, j. 13-2-2008, rel. Min. Eros Grau, DJe 19-6-2009. Vide: STF, ADIn 2.158 e ADIn 2.189, j. 15-9-2010, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15-12-2010.

"A súmula, porque não apresenta as características de ato normativo, não está sujeita à jurisdição constitucional concentrada" (STF, ADIn 594/DF, j. 19-2-1992, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 15-4-1994). No mesmo sentido: RE 584.188-AgR/SP, j. 28-9-2010, rel. Min. Ayres Britto, DJe 2-12-2010.

b) inconstitucionalidade material ou nomoestática: é a adoção de atos jurídicos que violem as cláusulas pétreas (art. 60, § 4.º, da CF/88) ou direitos materiais constitucionais. Por exemplo: uma emenda constitucional que estabeleça a pena de prisão perpétua estaria violando o inciso IV do § 4.º do art. 60, ou seja, estaria violando uma

garantia fundamental prevista no art. 5.º, XLVII, b. Lembre-se de que o art. 5.º da CF/88 é cláusula pétrea, só admitindo alteração para ampliar direitos.

“Art. 60. (...) § 4.º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes; IV – os direitos e garantias individuais.”

“Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLVII – não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis; (...).”

IMPORTANTE

As normas infraconstitucionais anteriores à CF/88 podem ser recepcionadas, mesmo que haja incompatibilidade formal – como exemplos clássicos têm-se o Código Penal e o Código de Processo Penal, que foram criados através de decreto-lei, mas foram recepcionados como leis ordinárias federais.

Por fim, há a inconstitucionalidade progressiva, que é aquela que acontece quando há uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada e as leis anteriores atuavam sobre o tema até a edição da norma infraconstitucional (lei em trânsito para a inconstitucionalidade). Por exemplo, art. 68 do CPP (enquanto não implementada a Defensoria Pública, o Ministério Público promoverá a ação civil ex delicto).

Decisão sobre o tema:

“O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é

admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional, quando se alega, na inicial, que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da Constituição originária (art. 60, § 4.º, da CF). Precedente: ADIn 939 (RTJ 151/755)” (STF, ADIn 1.946-MC/DF, j. 29-4-1999, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 14-9-2001).

ATENÇÃO

A doutrina também se vale da seguinte classificação:

- Inconstitucionalidade por arrastamento: uma parte da norma é inconstitucional e atrai o resto da norma ou os atos de regulamentação;
- Inconstitucionalidade direta: há uma norma contrária à Constituição;
- Inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua: ato regulamentar contraria a lei;
- Inconstitucionalidade derivada ou consequente: a norma e seus atos regulamentares contrariam a Constituição.

6.2.2. Inconstitucionalidade por omissão

Há uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada, ou seja, existe um direito assegurado na Constituição, porém não é possível exercê-lo em virtude da ausência de regulamentação.

Pode-se citar como exemplo o art. 7.º, XXVII, da CF/88, que prevê a proteção dos trabalhadores em face da automação, na forma da lei, mas, se essa proteção não se formalizar por omissão do legislador em produzir a lei aí referida e necessária à plena aplicação da norma, estar-se-á diante de uma omissão passível de interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou de um mandado de injunção, visando a obter do legislador a elaboração da lei em referência. Outros exemplos da Constituição Federal vigente: arts. 7.º, IV e XXIII; 37, I e VII; 153, VII; 207, § 1.º, entre outros.

Decisão sobre o tema:

“O Tribunal julgou três mandados de injunção impetrados, respectivamente, pelo Sindipol no Estado do Espírito Santo, pelo Sintem do Município de João Pessoa e pelo Sinjep do Estado do Pará, em que se pretendia fosse garantido aos seus associados o exercício do direito de greve previsto no art. 37, VII, da CF/88. O Tribunal, por maioria, conheceu dos mandados de injunção e propôs a solução para a omissão legislativa com a aplicação, no que couber, da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada” (STF, MI 670/ES, j. 25-10-2007, rel. orig. Min. Maurício Corrêa, rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes; STF, MI 708/DF, j. 25-10-2007, rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MI 712/PA, j. 25-10-2007, rel. Min. Eros Grau).

Para buscar a regulamentação pode ser utilizado:

Mandado de Injunção	Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
Controle difuso	Controle concentrado
Autor: qualquer pessoa	Autor: autoridades do art. 103 da CF/88
Foro: STF (art. 102, I, q, CF/88) e STJ (art. 105, I, h, CF/88)	Foro: STF (art. 102, I, a, da CF/88)
Efeitos: concretos (resolve o caso do cliente, por exemplo, conseguir se aposentar ou exercer o direito de greve)	Efeitos: CF/88: art. 103, § 2.º, CF/88) e legislação vigente: art. 12-H da Lei n. 9.868/99
Observação: STF não admite liminar	Observação: admite cautelar (art. 12-F da Lei n. 9.868/99)
Dica: buscar o exercício do direito para certa pessoa ou grupo de pessoas	Dica: buscar a regulamentação da norma para todos

IMPORTANTE

A Lei n. 13.300/2016 regulamentou o mandado de injunção individual e o coletivo. Eles buscam o exercício do direito para certas pessoas ou entidades. A ADIn-PO (ADO – sigla utilizada no STF para a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão) visa a buscar a regulamentação do direito para todos.

6.3. CLASSIFICAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

6.3.1. Quanto ao momento em que é exercido

6.3.1.1. Preventivo, a priori ou priorístico

Opera antes que o ato – particularmente a lei – se aperfeiçoe, ou seja, o controle é feito sobre o Projeto de Lei (PL) ou Proposta de Emenda Constitucional (PEC).

No Brasil, normalmente, o controle preventivo é exercido pelo Poder Legislativo – Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) – e pelo Poder Executivo, por meio do veto presidencial por inconstitucionalidade – veto jurídico (art. 66, § 1.º, da CF/88).

Nada impede que o Poder Judiciário o exerça excepcionalmente, desde que seja acionado.

Temos, assim, o controle preventivo (dentro da normalidade):

- a) **Comissões de Constituição e Justiça:** na esfera federal, previstas nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, examinam a constitucionalidade dos projetos de lei, dando parecer sujeito à apreciação do Plenário. Somente na esfera federal o mesmo projeto de lei passa por duas Comissões de Constituição e Justiça (Câmara dos Deputados e Senado Federal);
- b) **veto presidencial por inconstitucionalidade:** a Constituição Federal vigente, no art. 66, § 1.º, prevê o veto por dois motivos: contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade do projeto de lei. No primeiro caso, o veto não significa controle de constitucionalidade, pois

seu motivo é a simples discordância do Presidente em relação à vontade do Congresso (veto político). No segundo caso, sim, é controle de constitucionalidade, porque o Presidente veta o projeto por considerá-lo contrário à Constituição (veto jurídico);

Decisão sobre o tema:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes” (STF, ADIn 2.867, j. 3-12-2003, rel. Min. Celso de Mello, DJ 9-2-2007). No mesmo sentido: STF, ADIn 1.963-MC/PR e 1.070-MC/MS.

c) o Poder Judiciário, excepcionalmente, realiza o controle preventivo: cite-se, como exemplo, a propositura de mandado de segurança para realizar o controle de constitucionalidade difuso no Supremo Tribunal Federal por parlamentares (Deputados ou Senadores Federais) no processo legislativo em andamento.

Decisão sobre o tema:

“O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Min. Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, Min. Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Min. Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, Min. Celso de Mello, DJ 15-9-2003; MS

24.593/DF, Min. Maurício Corrêa, DJ 8-8-2003; MS 24.576/DF, Min. Ellen Gracie, DJ 12-9-2003; MS 24.356/DF, Min. Carlos Velloso, DJ 12-9-2003” (MS 24.667-AgR/DF, j. 4-12-2003, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 23-4-2004).

6.3.1.2. Repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo

Controle exercido sobre lei ou ato normativo, em regra, já existentes no ordenamento jurídico. A exceção ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada, ainda não regulamentadas (casos de mandado de injunção ou de ADIn/ADIn SO/PO).

No Brasil, o controle repressivo é confiado ao Poder Judiciário. Excepcionalmente, a Constituição Federal admite que o Poder Legislativo retire a efetividade de certas normas infraconstitucionais. São os seguintes casos:

- a) medidas provisórias rejeitadas pelo Congresso Nacional por não atenderem aos requisitos de relevância e urgência ou outra inconstitucionalidade (art. 62, § 5.º, da CF/88);

Decisão sobre o tema:

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de poderes (art. 2.º da CF) (ADIn 2.213, rel. Min. Celso de Mello, DJ 23-4-2004; ADIn 1.647, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26-3-1999; ADIn 1.753-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 12-6-1998; ADIn 162-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 19-9-1997)” (STF, ADC 11-MC/DF, j. 28-3-2007, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29-6-2007).

- b) decreto legislativo do Congresso Nacional visando a sustar atos

normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa (art. 49, V, c/c arts. 84, IV, e 68, da CF/88);

Decisão sobre o tema:

“O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, a tal gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, V, da Constituição da República e que lhe permite ‘sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)’. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da impugnação à validade constitucional da Instrução Normativa STN n. 01/2005” (STF, AC 1.033-AgR-QO/DF, j. 25-5-2006, rel. Min. Celso de Mello, DJ 16-6-2006).

c) resolução do Senado nos termos do inciso X do art. 52 em controle difuso de constitucionalidade: “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; (...)”.

Decisão sobre o tema:

“Não conhecimento, quanto ao art. 8.º, dada a invalidade do dispositivo,

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em processo de controle difuso (RE 146.733), e cujos efeitos foram suspensos pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 11/95. Procedência da arguição de inconstitucionalidade do art. 9.º, por incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição e 56 do ADCT/88, que, não obstante já declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 150.764, 16-12-1992, Min. Aurélio (DJ 2-4-1993), teve o processo de suspensão do dispositivo arquivado, no Senado Federal, que, assim, se negou a emprestar efeitos erga omnes à decisão proferida na via difusa do controle de normas” (STF, ADIn 15, j. 14-6-2007, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 31-8-2007).

ATENÇÃO

Súmula 347 do STF: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”.

Poder Executivo pode realizar o controle repressivo, por exemplo, decreto anterior revogado por decreto posterior.

É possível questionar atos jurídicos tendo por base normas anteriores à norma constitucional, mas que estavam vigentes à época.

Em breve síntese:

Preventivo: Projeto de Lei	Regra: a) Poder Legislativo: Comissão de Constituição e Justiça b) Poder Executivo: Veto por Inconstitucionalidade (Veto Jurídico)
Repressivo: Lei ou ato normativo em vigor	Regra: Poder Judiciário: Controle difuso e concentrado

6.3.2. Quanto ao número de órgãos encarregados do controle

6.3.2.1. Concentrado, reservado, objetivo, fechado, abstrato ou austríaco

Um único órgão desempenha a função de realizar o controle de constitucionalidade. Por exemplo: os Tribunais Constitucionais europeus e, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal na esfera federal.

Decisão sobre o tema:

“Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da CF/88 que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. A Lei Estadual n. 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela EC 41/2003. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da CF/88 que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela EC n. 41/2003. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas cautelares concedidas já há dez anos” (STF, ADIn 2.158/PR e ADIn 2.189/PR, j. 15-9-2010, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15-12-2010). No mesmo sentido: STF, RE 390.840, j. 9-11-2005, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15-8-2006.

6.3.2.2. Difuso, aberto, indireto, subjetivo, ou norte-americano

Todos os magistrados, ao julgarem seus processos, podem exercer o controle de constitucionalidade dentro da sua competência jurisdicional. Por exemplo, recurso extraordinário, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas corpus.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal brasileiro também realiza o controle difuso (art. 102, I, d, i, l, q, r, II, III, da CF/88).

O recurso extraordinário é a última etapa do controle difuso realizado pelos juízes e tribunais do país e é o mecanismo por meio do qual o Supremo Tribunal Federal dá a palavra final sobre uma questão constitucional. Pode ser interposto contra decisão de Tribunal proferida em única ou última instância. É controle incidental (por via de exceção) e repressivo.

As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário são apenas aquelas previstas no art. 102, III, da Constituição Federal vigente.

Os efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário atingem, em princípio, apenas as partes litigantes. Porém, quando o Supremo Tribunal Federal declarar uma lei inconstitucional, por decisão definitiva, o Senado Federal poderá, mediante resolução, suspender a execução da lei em todo o território nacional (art. 52, X, da CF/88), dando, assim, eficácia erga omnes à decisão do Supremo.

“No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (art. 102, § 3.º, da CF/88).

IMPORTANTE

É possível no recurso extraordinário haver efeitos “entre as partes” e/ou “erga omnes”. Neste último caso, por exemplo, uma lei municipal contraria a Constituição Estadual e a norma objeto de

parâmetro é de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Julgada a ADIn estadual, cabe RE para o STF.

ATENÇÃO

A Lei n. 11.418/2006 regulamentou a repercussão geral.

6.3.3. Quanto aos efeitos da decisão

6.3.3.1. Inter partes

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade atingem apenas as partes litigantes. Pessoas na mesma situação devem propor suas próprias ações, para nelas receberem idêntica decisão. É o efeito existente, de regra, no caso concreto. Em caso de inconstitucionalidade, o órgão fracionário lavrará o acórdão e o remeterá ao Plenário. Uma vez julgado, o acórdão será devolvido para o órgão fracionário, para que resolva o caso concreto (arts. 948 a 950 do CPC/2015).

ATENÇÃO

Os efeitos podem ser ampliados para erga omnes em virtude de resolução do Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da CF/88 (suspende os efeitos da norma seja federal, estadual, distrital ou municipal).

Atentar para o art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante 10.

- “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”

Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Cuidado: É possível a mitigação da reserva de plenário nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC:

- “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a

arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”

- “Embora a Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, tenha autorizado o Supremo Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade com efeitos limitados, é lícito indagar sobre a admissibilidade do uso dessa técnica de decisão no âmbito do controle difuso. Ressalte-se que não se está a discutir a constitucionalidade do art. 27 da Lei n. 9.868/99. Cuida-se aqui, tão somente, de examinar a possibilidade de aplicação da orientação nele contida no controle incidental de constitucionalidade. (...) assinala-se que, antes do advento da Lei n. 9.868/99, talvez fosse o STF, muito provavelmente, o único órgão importante de jurisdição constitucional a não fazer uso, de modo expresso, da limitação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade. (...) No que interessa para a discussão da questão em apreço, ressalte-se que o modelo difuso não se mostra incompatível com a doutrina da limitação dos efeitos” (STF, AC 189-MC-QO, j. 9-6-2004, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 27-8-2004).

6.3.3.2. Erga omnes

“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (art. 102, § 2.º, da CF/88). É o efeito existente no controle concentrado, inclusive na arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 10, § 3.º, da Lei n. 9.882/99). Em se tratando de decisão de Tribunal, esta deve ser tomada necessariamente pela maioria absoluta do Plenário ou do órgão especial (cláusula de reserva de plenário: art. 97 c/c art. 93, IX, da CF/88).

6.4. AS AÇÕES DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADIN, ADECON E ADPF)

6.4.1. Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica (ADIn/ADIn Genérica)

Objetivo: banir do ordenamento jurídico a lei ou o ato normativo estadual

ou federal em tese atingidos pelo vício da inconstitucionalidade (art. 102, I, a, da CF/88). Admite-se, também, contra emenda constitucional.

Por ausência de previsão constitucional, o Supremo Tribunal Federal não admite ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal (impossibilidade jurídica do pedido). Nesse caso, é possível o controle difuso, podendo chegar via recursal ao Supremo Tribunal Federal (recurso extraordinário), produzindo efeitos entre as partes.

Se uma lei municipal contrariar a Constituição Estadual é possível uma ADIn Genérica estadual proposta no Tribunal de Justiça (art. 125, § 2.º, da CF/88).

O Supremo Tribunal Federal tem admitido o controle concentrado sobre o decreto autônomo (art. 84, VI e XII, da CF/88) ou os decretos que tenham extravasado o poder regulamentar do Poder Executivo, invadindo matéria reservada à lei.

Em breve síntese, cabe ADI de ato normativo primário, ou seja, das espécies normativas previstas no art. 59 da CF e que forem editadas após a Constituição Federal ou suas emendas constitucionais.

Legitimidade ativa: as pessoas relacionadas no art. 103, I a IX, da CF/88 e no art. 2.º da Lei n. 9.868/99.

Saliente-se que as Mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal e as confederações sindicais (organizadas com no mínimo três federações, estabelecidas em pelo menos três Estados, nos termos do art. 535 da CLT – ADIn 939-7/DF) ou entidades de classe de âmbito nacional (entidades de classe nacionais que possuam filiados em pelo menos nove Estados brasileiros, numa aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos – ADIn 79) devem demonstrar a pertinência temática (interesse) para propor a ação direta de inconstitucionalidade, por isso são também

denominados autores especiais ou interessados reservados. Por outro lado, o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o partido político com representação no Congresso Nacional não necessitam demonstrar interesse especial para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, por isso são denominados de autores universais ou neutros.

Legitimidade passiva: órgão ou autoridade que editou o ato que se pretende impugnar.

Foro competente: Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a, da CF/88).

Quórum de instalação: oito Ministros (dois terços dos membros – art. 22 da Lei n. 9.868/99).

Quórum de aprovação: seis Ministros (maioria absoluta – arts. 97 da CF/88 e 23, caput, da Lei n. 9.868/99).

Admite-se medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade com efeitos contra todos e ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa (arts. 10 a 12 da Lei n. 9.868/99).

Efeitos: declarada inconstitucional, a lei torna-se inaplicável, fazendo a decisão coisa julgada, com efeitos erga omnes e vinculante, de acordo com o art. 102, § 2.º, da CF/88, e art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Normalmente, tem efeito ex tunc, podendo ser dado efeito ex nunc se houver manifestação de dois terços dos Ministros (modulação de efeitos ou modulação temporal – art. 27 da Lei n. 9.868/99). A cautelar tem efeito ex nunc, podendo ser concedida com efeito ex tunc (modulação de efeitos ou modulação temporal – art. 11, § 1.º, da Lei n. 9.868/99). De acordo com o STF, o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não está vinculado às decisões de ADIn.

Cumpra-se observar que a petição inicial deverá ser apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos

documentos necessários para comprovar a impugnação, nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Se a petição inicial for indeferida cabe agravo (art. 4.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99).

Decisões sobre o tema:

“Ação direta de inconstitucionalidade. ADIn. Inadmissibilidade. Art. 14, § 4.º, da CF. Norma constitucional originária. Objeto nomológico insuscetível de controle de constitucionalidade. Princípio da unidade hierárquico-normativa e caráter rígido da Constituição brasileira. Doutrina. Precedentes. Carência da ação. Inépcia reconhecida. Indeferimento da petição inicial. Agravo improvido. Não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário” (STF, ADIn 4.097-AgRg/DF, j. 8-10-2008, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 7-11-2008).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências e remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações. Inconstitucionalidade. Ação direta. Art. 5.º da Lei n. 1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do chefe do Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1.º, II, a, e 84, VI, a, da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos remunerados, bem

como os decretos que lhe deem execução” (STF, ADIn 3.232/TO, j. 14-8-2008, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 3-10-2008). No mesmo sentido: STF, ADIn 3.983 e ADIn 3.990, j. 14-8-2008, rel. Min. Cezar Peluso, Informativo 515.

“Ação direta de inconstitucionalidade. Partido político. Legitimidade ativa. Aferição no momento da sua propositura. Perda superveniente de representação parlamentar. Não desqualificação para permanecer no polo ativo da relação processual. Objetividade e indisponibilidade da ação” (STF, ADIn/DF 2.159-AgRg, j. 12-8-2004, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 6-12-2004). No mesmo sentido: STF, ADIn 2.827-AgR, j. 30-8-2004, rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 8-9-2004.

“Efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Custas judiciais. Destinação a entidades privadas. Inconstitucionalidade. O STF já manifestou, por diversas vezes, o entendimento de que é vedada a destinação dos valores recolhidos a título de custas e emolumentos a pessoas jurídicas de direito privado. Precedentes. Ação julgada procedente. Tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, aplica-se o art. 27 da Lei n. 9.868/99, para atribuir à declaração de inconstitucionalidade efeitos a partir da EC n. 45, de 31 de dezembro de 2004” (STF, ADIn 3.660/MS, j. 13-3-2008, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8-5-2008). Vide: STF, MS 28.141, j. 10-2-2011, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30-6-2011.

“Reclamação com fundamento na preservação da competência do STF. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se impugna lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com

possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta” (STF, Rcl 383, j. 11-6-1992, rel. Min. Moreira Alves, DJ 21-5-1993.) No mesmo sentido: RE 599.633-AgR-AgR, 1.^a T., j. 2-4-2013, rel. Min. Luiz Fux, DJe 24-4-2013; Rcl 12.653-AgR, Plenário, j. 20-6-2012, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11-10-2012; RE 597.165, decisão monocrática, j. 4-4-2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 11-4-2011; Rcl 596-AgR, Plenário, j. 30-5-1996, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 14-11-1996. Vide: AI 694.299-AgR, 1.^a T., j. 13-8-2013, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14-2-2014; Rcl 4.329, j. 17-11-2011, rel. Min. Ayres Britto, DJe 9-12-2011.

“As medidas cautelares deferidas em controle concentrado de constitucionalidade são decisões provisórias de urgência, proferidas em juízo de cognição sumária. São, portanto, decisões temporárias, necessariamente substituídas pela decisão final e definitiva nos autos” (STF, AgRg na ADIn 2.381/RS, Pleno, j. 24-3-2011, voto da rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11-4-2011).

ATENÇÃO

Importante lembrar a Súmula 642 do STF: “Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal”.

Na ADIn Estadual, destaque-se que das decisões do Tribunal de Justiça é cabível Recurso Extraordinário, quando há simetria entre a Constituição do Estado e a Constituição Federal.

Se o partido político perder a representação continua o julgamento da ADIn – ADIn 2.159/DF.

Lei pode ser objeto de ADIn, mesmo tendo caráter concreto – Lei Orçamentária – ADIn 4.048/DF.

6.4.2. Representação Interventiva (ou Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva – ADIn/ADIn Interventiva)

6.4.2.1. ADIn Interventiva Federal

Objetivo: restabelecer o respeito dos princípios constitucionais sensíveis ou expressos previstos no inciso VII do art. 34 da CF/88 (ADIn/ADIn Interventiva Federal).

Legitimidade ativa: Procurador-Geral da República (arts. 129, IV, e 36, III, da CF/88, bem como art. 2.º da Lei n. 12.562/2011) – chefe do Ministério Público da União.

Legitimidade passiva: órgão ou autoridade estadual ou distrital que violou os princípios constitucionais sensíveis. Destaque-se que os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Procurador-Geral do Estado ou do Distrito Federal) exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas (art. 132 da CF/88).

Foro competente: Supremo Tribunal Federal (arts. 36, III, e 102, I, a, da CF/88).

Quórum de instalação: oito Ministros (dois terços dos membros – art. 9.º da Lei n. 12.562/2011).

Quórum de aprovação: seis Ministros (art. 97 da CF/88 e art. 10 da Lei n. 12.562/2011).

Efeitos: restaurar a supremacia constitucional, com efeitos erga omnes e vinculante. Além disso, tem efeito ex nunc em relação à edição do decreto.

ATENÇÃO

Se a decisão final for pela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do Presidente da República para, no prazo improrrogável de quinze dias, dar cumprimento aos §§ 1.º e 3.º do art. 36 da Constituição Federal (art. 11, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011). Sobre o tema, destaque-se a competência do Presidente da República para expedir decretos (art. 84, IV e X, da CF/88).

6.4.2.2. ADIn Interventiva Estadual

Cumprе destacar que é possível a ADIn Interventiva Estadual com as

devidas adaptações (art. 35, IV, da CF/88). Assim, vejamos:

Objetivo: restabelecer o respeito dos princípios constitucionais estaduais desrespeitados por lei municipal (art. 35, IV, da CF/88).

Legitimidade ativa: Procurador-Geral de Justiça (art. 129, IV, da CF/88) – chefe do Ministério Público Estadual.

Legitimidade passiva: órgão ou autoridade municipal que violou os princípios constitucionais sensíveis.

Foro competente: Tribunal de Justiça (art. 35, IV, da CF/88).

Quórum de instalação: dois terços dos membros do Tribunal ou do órgão especial se houver.

Quórum de aprovação: maioria absoluta do Tribunal ou do órgão especial se houver (art. 97 da CF/88).

Efeitos: restaurar a supremacia constitucional, com efeitos erga omnes e vinculante. Além disso, tem efeito ex nunc em relação à edição do decreto.

Em ambos os casos, seja federal ou estadual, a decisão do Poder Judiciário será comunicada ao chefe do Poder Executivo respectivo, que, por meio de decreto, suspenderá a execução do ato impugnado; caso tal ato não seja suficiente para restabelecer a constitucionalidade, poderá o chefe do Poder Executivo decretar a intervenção, nomeando interventor e usando dos demais atos constitutivos necessários.

Cumpra-se observar que a petição inicial deverá ser apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação, nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011. Se a petição inicial for indeferida cabe agravo (art. 4.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011).

A Lei n. 12.562/2011 regulamentou a ADIn Interventiva Federal.

Decisões sobre o tema:

“O descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em

julgado configura pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. A ausência de voluntariedade em não pagar precatórios, consubstanciada na insuficiência de recursos para satisfazer os créditos contra a Fazenda Estadual no prazo previsto no § 1.º do art. 100 da Constituição da República, não legitima a subtração temporária da autonomia estadual, mormente quando o ente público, apesar da exaustão do erário, vem sendo zeloso, na medida do possível, com suas obrigações derivadas de provimentos judiciais” (STF, IF 1.917-AgR/DF, j. 17-3-2004, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 3-8-2007).

“Precatórios judiciais. Não configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com finalidade de não pagamento. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. A intervenção, como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. Adoção da chamada relação de precedência condicionada entre princípios constitucionais concorrentes” (STF, IF 298, j. 3-2-2003, rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, DJ 27-2-2004).

“Representação do Procurador-Geral da República pleiteando intervenção federal no Estado de Mato Grosso, para assegurar a observância dos ‘direitos da pessoa humana’, em face de fato criminoso praticado com extrema crueldade a indicar a inexistência de ‘condição mínima’, no Estado, ‘para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana, que é o direito à vida’. (...) Representação que merece conhecida, por seu fundamento: alegação de inobservância pelo Estado-membro do princípio constitucional sensível previsto no art. 34, VII, b, da Constituição de 1988, quanto aos ‘direitos da pessoa humana’. (...) Hipótese em que estão em causa ‘direitos da pessoa humana’, em sua compreensão mais ampla, revelando-se impotentes as autoridades policiais locais para manter a segurança de três presos que acabaram

subtraídos de sua proteção, por populares revoltados pelo crime que lhes era imputado, sendo mortos com requintes de crueldade. Intervenção federal e restrição à autonomia do Estado-membro. Princípio federativo. Excepcionalidade da medida interventiva. (...) Embora a extrema gravidade dos fatos e o repúdio que sempre merecem atos de violência e crueldade, não se trata, porém, de situação concreta que, por si só, possa configurar causa bastante a decretarse intervenção federal no Estado, tendo em conta, também, as providências já adotadas pelas autoridades locais para a apuração do ilícito (...). (Constituição, arts. 25, § 1.º, 125 e 144, § 4.º)” (STF, IF 114, j. 13-3-1991, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 27-9-1996).

6.4.3. Ação Direta de Inconstitucionalidade Supridora da Omissão ou por Omissão (ADIn/ADIn-SO, ADIn/ADIn-PO ou ADO)

Objetivo: pleitear a regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada (inconstitucionalidade por omissão).

Legitimidade ativa: as pessoas relacionadas no art. 103, I a IX, da CF/88 e art. 12-A da Lei n. 9.868/99 (podem propor os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade).

Saliente-se que as Mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal e as confederações sindicais (organizadas com no mínimo três federações, estabelecidas em pelo menos três Estados, nos termos do art. 535 da CLT – ADIn 939-7/DF) ou entidades de classe de âmbito nacional (entidades de classe nacionais que possuam filiados em pelo menos nove Estados brasileiros, numa aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos – ADIn 79) devem demonstrar a pertinência temática (interesse) para propor a ação direta de inconstitucionalidade, por isso são também

denominados autores especiais ou interessados reservados. Por outro lado, o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o partido político com representação no Congresso Nacional não necessitam demonstrar interesse especial para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, por isso são denominados autores universais ou neutros.

Legitimidade passiva: autoridade ou órgão responsável pela não elaboração do ato necessário à efetividade da norma constitucional.

Foro competente: Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a, da CF/88).

Quórum de instalação: oito Ministros (dois terços dos membros – art. 22 da Lei n. 9.868/99).

Quórum de aprovação: seis Ministros (maioria absoluta – arts. 97 da CF/88 e 23, caput, da Lei n. 9.868/99).

A Lei n. 12.063/2009 alterou a Lei n. 9.868/99 e inovou ao incluir e estabelecer no art. 12-F a possibilidade de medida cautelar na ADIn PO (“Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias. § 1.º A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. § 2.º O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três) dias. § 3.º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal”).

Efeitos: o Supremo Tribunal Federal deverá dar ciência ao Poder competente para que sejam tomadas as medidas necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias (art. 103, § 2.º, da CF/88). Destaque-se que o § 1.º do art. 12-H da Lei n. 9.868/99 estabelece que, em caso de omissão de órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de trinta dias, “ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido”.

Cumpre observar que a petição inicial deverá ser apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação, nos termos do art. 12- B, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Se a petição inicial for indeferida cabe agravo (art. 12-C, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99).

Decisões sobre o tema:

“Não é necessária a manifestação do Advogado-Geral da União, art. 103, § 3.º, da Constituição, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão” (STF, ADIn 480, j. 13-10-1994, rel. Min. Paulo Brossard, DJ 25-11-1994).

Sobre a criação de Municípios:

“O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a mora do Congresso Nacional em elaborar a lei complementar federal a que se refere o § 4.º do art. 18 da CF, na redação dada pela EC n. 15/96, e, por maioria, estabeleceu o prazo de 18 meses para que este adote todas as providências legislativas ao cumprimento da referida norma constitucional. (...) Em seguida, quanto ao mérito, salientou-se que, considerado o lapso temporal de mais de 10 anos, desde a data da

publicação da EC n. 15/96, à primeira vista, seria evidente a inatividade do legislador em relação ao cumprimento do dever constitucional de legislar (CF, art. 18, § 4.º – norma de eficácia limitada). Asseverou-se, entretanto, que não se poderia afirmar uma total inércia legislativa, haja vista os vários projetos de lei complementar apresentados e discutidos no âmbito das Casas Legislativas. Não obstante, entendeu-se que a inertia deliberandi (discussão e votação) também poderia configurar omissão passível de vir a ser reputada morosa, no caso de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável sobre o projeto de lei em tramitação. Aduziu-se que, na espécie, apesar dos diversos projetos de lei apresentados, restaria configurada a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação da lei complementar em questão, sobretudo tendo em conta a plethora de Municípios criados mesmo depois do advento da EC n. 15/96, com base em requisitos definidos em antigas legislações estaduais, alguns declarados inconstitucionais pelo Supremo, ou seja, uma realidade quase que imposta por um modelo que, adotado pela aludida emenda constitucional, ainda não teria sido implementado, em toda a sua plenitude, em razão da falta da lei complementar a que alude o mencionado dispositivo constitucional. Afirmou-se, ademais, que a decisão que constata a existência de omissão constitucional e determina ao legislador que empreenda as medidas necessárias à colmatação da lacuna inconstitucional constitui sentença de caráter nitidamente mandamental, que impõe, ao legislador em mora, o dever, dentro de um prazo razoável, de proceder à eliminação do estado de inconstitucionalidade, e que, em razão de esse estado decorrente da omissão poder ter produzido efeitos no passado, faz-se mister, muitas vezes, que o ato destinado a corrigir a omissão inconstitucional tenha caráter retroativo. Considerou-se que, no caso, a omissão legislativa inconstitucional produzira evidentes efeitos durante o longo tempo transcorrido desde o advento da EC n. 15/96, no qual vários Estados-

membros legislaram sobre o tema e diversos Municípios foram efetivamente criados, com eleições realizadas, poderes municipais estruturados, tributos recolhidos, ou seja, toda uma realidade fática e jurídica gerada sem fundamento legal ou constitucional, mas que não poderia ser ignorada pelo legislador na elaboração da lei complementar federal. Em razão disso, concluiu-se pela fixação de um parâmetro temporal razoável – 18 meses – para que o Congresso Nacional edite a lei complementar federal reclamada, a qual deverá conter normas específicas destinadas a solver o problema dos Municípios já criados. (...)” (STF, ADIn 3.682/MT, j. 9-5-2007, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 5-9-2007).

6.4.4. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADECON/ADECO/ADC)

Objetivo: definir a constitucionalidade da lei ou do ato normativo federal (art. 102, I, a, da CF/88), impugnados em processos concretos, tendo recebido, nas instâncias inferiores, a maioria de decisões desfavoráveis. A prova da controvérsia deve acompanhar a petição inicial (art. 14 da Lei n. 9.868/99).

Legitimidade ativa: art. 103 da CF/88.

Foro: Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a, da CF/88).

Quórum de instalação: oito Ministros (dois terços dos membros – art. 22 da Lei n. 9.868/99).

Quórum de aprovação: seis Ministros (maioria absoluta – arts. 97 da CF/88 e 23, caput, da Lei n. 9.868/99).

Admite-se medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de seus membros, poderá determinar “que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto

da ação até seu julgamento definitivo” (art. 21 da Lei n. 9.868/99).

Efeitos: erga omnes, vinculante, de acordo com o art. 102, § 2.º, da CF/88, e ex tunc. Cumpre destacar que a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória (art. 26 da Lei n. 9.868/99).

De regra, o Advogado-Geral da União não participa da ADC.

Cumpre observar que a petição inicial deverá ser apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade, nos termos do art. 14, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Se a petição inicial for indeferida cabe agravo (art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99).

Decisões sobre o tema:

“As decisões plenárias do Supremo Tribunal Federal – que deferem medida cautelar em sede de ação declaratória de constitucionalidade – revestem-se de eficácia vinculante. Os provimentos de natureza cautelar acham-se instrumentalmente destinados a conferir efetividade ao julgamento final resultante do processo principal, assegurando, desse modo, ex ante, plena eficácia à tutela jurisdicional do Estado, inclusive no que concerne às decisões que, fundadas no poder cautelar geral – inerente a qualquer órgão do Poder Judiciário –, emergem do processo de controle normativo abstrato, instaurado mediante ajuizamento da pertinente ação declaratória de constitucionalidade” (STF, Rcl 1.770/RN, j. 29-5-2002, rel. Min. Celso de Mello, DJ 7-2-2003).

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu em 8 de junho de 2017 o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41 e reconheceu a validade da Lei n. 12.990/2014, que reserva 20% das

vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, no âmbito dos Três Poderes. A decisão foi unânime” (STF, ADC 41, rel. Min. Luís Barroso, j. 8-6-2017).

6.4.5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

Saliente-se que a Lei n. 9.882/99 regulamentou a ADPF prevista no art. 102, § 1.º, da CF/88.

Objetivo: evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público (art. 1.º, caput, da Lei n. 9.882/99). Caberá também quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1.º, parágrafo único, I, da Lei n. 9.882/99).

Destaque-se que cabe ADPF de atos normativos secundários, tais como portarias ministeriais, decisões judiciais conflitantes de âmbito nacional e leis municipais.

Legitimidade ativa: as mesmas pessoas legitimadas para propor a ADIn (art. 103, I a IX, da CF/88 e art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99).

Saliente-se que as Mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal e as confederações sindicais (organizadas com no mínimo três federações, estabelecidas em pelo menos três Estados, nos termos do art. 535 da CLT – ADIn 939-7/DF) ou entidades de classe de âmbito nacional (entidades de classe nacionais que possuam filiados em, pelo menos, nove Estados brasileiros, numa aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos – ADIn 79) devem demonstrar a pertinência temática (interesse) para propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental, por isso são também denominados autores especiais ou interessados reservados. Por

outro lado, o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o partido político com representação no Congresso Nacional não necessitam demonstrar interesse especial para a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental, por isso são denominados autores universais ou neutros.

Legitimidade passiva: autoridade ou órgão que violou preceito fundamental.

Foro competente: Supremo Tribunal Federal (art. 102, § 1.º, da CF/88).

Quórum de instalação: oito Ministros (dois terços dos membros – art. 8.º da Lei n. 9.882/99).

Quórum de aprovação: seis Ministros (maioria absoluta – art. 97 da CF/88).

Admite-se medida liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 5.º da Lei n. 9.882/99).

Efeitos: fixa as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental (art. 10, caput, da Lei n. 9.882/99), com “eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público” (art. 10, § 3.º, da Lei n. 9.882/99). Além disso, em regra, tem efeito ex tunc, podendo ser dado efeito ex nunc se houver manifestação de 2/3 dos Ministros (modulação de efeitos ou modulação temporal – art. 11 da Lei n. 9.882/99). A liminar poderá determinar a suspensão de processos e decisões judiciais, respeitada a coisa julgada (art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99). Por fim, a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em ADPF é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória (art. 12 da Lei n. 9.882/99).

Princípio da subsidiariedade: art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 (não se admite a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade). Observação: no controle abstrato (ADPF 126/DF).

Cumpra observar que a petição inicial deverá ser apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação, nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99.

Se a petição inicial for indeferida cabe agravo (art. 4.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99).

Importante salientar a fungibilidade da ADPF, uma vez que o STF já converteu ADPF em ADIn (ADPF 72/QO/PA – ADIn 349-MC/DF).

Decisões sobre o tema:

“Prevista no § 1.º do art. 102 da Constituição da República, a arguição de descumprimento de preceito fundamental foi regulamentada pela Lei n. 9.882/99, que dispõe no art. 1.º: ‘Art. 1.º A arguição prevista no § 1.º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público’. E, no art. 3.º: ‘Art. 3.º A petição inicial deverá conter: I – a indicação do preceito fundamental que se considera violado; II – a indicação do ato questionado; III – a prova da violação do preceito fundamental; IV – o pedido, com suas especificações; V – se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado’. A arguente funda o pedido em exemplos de atuação do Ministério Público Federal (fls. 23/25), mas desprovidos todos de qualquer conteúdo concreto e específico que implique descumprimento de algum preceito fundamental. Não há, pois, a rigor, objeto determinado na demanda, que apenas revela discordância com formas de atuação do Ministério Público do Trabalho, ao qual a arguente nega competência constitucional para propor ações civis públicas e sugerir assinatura de ajuste de conduta. Ainda que assim não fosse, o conhecimento da ação encontraria óbice no princípio da subsidiariedade.

É que a Lei n. 9.882/99 prescreve, no art. 4.º, § 1.º, que se não admitirá arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ora, no caso, é fora de dúvida que o ordenamento jurídico prevê outros remédios processuais ordinários que, postos à disposição da arguente, são aptos e eficazes para lhe satisfazer de todo a pretensão substantiva que transparece a esta demanda. É o que, aliás, já reconheceu esta Corte, em decisão do Min. Gilmar Mendes, na ADPF 96 (DJ 19-10-2006), onde, em termos idênticos, se questionava atuação do Ministério Público do Trabalho” (STF, ADPF 94/DF, j. 18-5-2007, rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 25-5-2007)” (grifo nosso).

“A possibilidade de instauração, no âmbito do Estado-membro, de processo objetivo de fiscalização normativa abstrata de leis municipais contestadas em face da Constituição Estadual (art. 125, § 2.º, da CF/88) torna inadmissível, por efeito da incidência do princípio da subsidiariedade (art. 4.º, § 1.º da Lei n. 9.882/99), o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental. É que, nesse processo de controle abstrato de normas locais, permite-se, ao Tribunal de Justiça estadual, a concessão, até mesmo in limine, de provimento cautelar neutralizador da suposta lesividade do diploma legislativo impugnado, a evidenciar a existência, no plano local, de instrumento processual de caráter objetivo apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de lesividade, atual ou potencial, alegadamente provocada por leis ou atos normativos editados pelo Município. Doutrina. Precedentes. (...). A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental – revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira

eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. (...). Incide, na espécie, por isso mesmo, o pressuposto negativo de admissibilidade a que se refere o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99, circunstância esta que torna plenamente invocável, no caso, a cláusula da subsidiariedade, que atua – ante as razões já expostas – como causa obstativa do ajuizamento, perante esta Suprema Corte, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sendo assim, tendo em consideração as razões invocadas, não conheço da presente ação constitucional, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar” (STF, ADPF 100-MC/TO, j. 15-12-2008, rel. Min. Celso de Melo, decisão monocrática, DJe 17-12-2008).

“O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem suscitada pelo Procurador-Geral da República, no sentido de assentar a adequação da arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, na qual se pretende obter posicionamento do STF sobre o aborto de feto anencéfalo – vide Informativos 354, 366 e 367. A arguente aponta como violados os preceitos dos arts. 1.º, IV (dignidade da pessoa humana); 5.º, II (princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade); 6.º, caput, e 196 (direito à saúde), todos da CF, e, como ato do Poder Público, causador da lesão, o conjunto normativo ensejado pelos arts. 124, 126, caput, e 128, I e II, do Código Penal, requerendo, em última análise, a interpretação conforme à Constituição dos referidos dispositivos do CP, a fim de explicitar que os mesmos não se aplicam aos casos de aborto de feto anencéfalo. Entendeu-se, nos termos do voto do relator, que os requisitos concernentes à ação foram devidamente atendidos (Lei n. 9.882/99, arts. 1.º, 3.º e 4.º, § 1.º). Salientando de um lado a presença de argumentos em torno de valores básicos inafastáveis no Estado Democrático de Direito e, de outro, os enfoques do Judiciário com arrimo em conclusões sobre o alcance dos dispositivos do Código Penal que

dispõem sobre o crime de aborto, concluiu-se pela necessidade do pronunciamento do Tribunal, a fim de se evitar a insegurança jurídica decorrente de decisões judiciais discrepantes acerca da matéria. Assentou-se a inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade alegada, apontando-se, como fundamento, o que verificado relativamente ao HC 84.025/RJ (DJU 25-6-2004), da relatoria do Min. Joaquim Barbosa, no qual a paciente, não obstante recorrer a essa via processual, antes do pronunciamento definitivo pela Corte, dera à luz a feto que veio a óbito em minutos, ocasionando o prejuízo da impetração. Ressaltou-se, também, o que consignado na ADPF 33 MC/PA (DJU 06-8-2004), por seu relator, Min. Gilmar Mendes, quanto ao caráter acentuadamente objetivo da ADPF e a necessidade de o juízo da subsidiariedade ter em vista os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional – a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Assim, incabíveis estas, como no caso de controle de legitimidade do direito pré-constitucional, possível a utilização daquela” (STF, ADPF 54 QO/DF, j. 27-4-2005, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30-8-2007).

“Encontrando-se saneado o processo, devem ocorrer audiências públicas para ouvir entidades e técnicos não só quanto à matéria de fundo, mas também no tocante a conhecimentos específicos a extravasarem os limites do próprio direito. Antes mesmo de a Procuradoria-Geral da República vir a preconizar a realização, havia consignado, na decisão de 28-9-2004, a conveniência de implementá-las. (...) já agora incluo, no rol de entidades, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. Visando à racionalização dos trabalhos, delimito o tempo de 15 minutos para cada exposição – viabilizada a juntada de memoriais – e designo as seguintes datas das audiências públicas, que serão realizadas no horário matutino, a partir das 9h: (...). Quanto ao requerimento do Ministério Público formalizado à f. 270, no sentido de serem ouvidos oito

professores, sem especificação das respectivas áreas de atuação, indefiro o pedido. Faço-o tendo em conta o que viabilizado em termos de conveniência pela lei regedora da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vale frisar, por oportuno, que a relação de entidades mencionadas já revela a audição sob os diversos ângulos envolvidos na espécie” (STF, ADPF 54/DF, j. 31-7-2008, rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 14-8-2008).

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). Lei de imprensa. Adequação da ação. Regime constitucional da ‘liberdade de informação jornalística’, expressão sinônima de liberdade de imprensa. A ‘plena’ liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. A plenitude da liberdade de imprensa como reforço ou sobretutela das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional. Liberdades que dão conteúdo às relações de imprensa e que se põem como superiores bens de personalidade e mais direta emanção do princípio da dignidade da pessoa humana. O capítulo constitucional da comunicação social como segmento prolongador das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional. Transpasse da fundamentalidade dos direitos prolongados ao capítulo prolongador. Ponderação diretamente constitucional entre blocos de bens de personalidade: o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada. Precedência do primeiro bloco. Incidência a posteriori do segundo bloco de direitos, para o efeito de assegurar o direito de resposta e assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, entre outras consequências do pleno gozo da liberdade de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção a interesses privados que, mesmo incidindo a posteriori, atua sobre as causas para

inibir abusos por parte da imprensa. Proporcionalidade entre liberdade de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e materiais a terceiros. Relação de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. Relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. A imprensa como instância natural de formação da opinião pública e como alternativa à versão oficial dos fatos. Proibição de monopolizar ou oligopolizar órgãos de imprensa como novo e autônomo fator de inibição de abusos. Núcleo da liberdade de imprensa e matérias apenas periféricamente de imprensa. Autorregulação e regulação social da atividade de imprensa. Não recepção em bloco da Lei n. 5.250/67 pela nova ordem constitucional. Efeitos jurídicos da decisão. Procedência da ação. (...) 12. Procedência da Ação. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal n. 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (STF, ADPF 130/DF, j. 30-4-2009, rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 6-11-2009).

“Liberdades fundamentais e ‘Marcha da Maconha’ – Por entender que o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento devem ser garantidos a todas as pessoas, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação de descumprimento de preceito fundamental para dar ao art. 287 do CP, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, ‘de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos’. Preliminarmente, rejeitou-se pleito suscitado pela Presidência da República e pela Advocacia-Geral da União no sentido do não conhecimento da ação, visto que, conforme sustentado, a via eleita não seria adequada para se deliberar sobre a interpretação conforme. Alegava-se, no ponto, que a linha tênue entre o tipo penal e a liberdade de expressão só seria verificável no caso

concreto. Aduziu-se que se trataria de arguição autônoma, cujos pressupostos de admissibilidade estariam presentes. Salientou-se a observância, na espécie, do princípio da subsidiariedade. Ocorre que a regra penal em comento teria caráter pré-constitucional e, portanto, não poderia constituir objeto de controle abstrato mediante ações diretas, de acordo com a jurisprudência da Corte. Assim, não haveria outro modo eficaz de se sanar a lesividade arguida, senão pelo meio adotado. Enfatizou-se a multiplicidade de interpretações às quais a norma penal em questão estaria submetida, consubstanciadas em decisões a permitir e a não permitir a denominada 'Marcha da Maconha' por todo o país. Ressaltou-se existirem graves consequências resultantes da censura à liberdade de expressão e de reunião, realizada por agentes estatais em cumprimento de ordens emanadas do Judiciário. Frisou-se que, diante do quadro de incertezas hermenêuticas em torno da aludida norma, a revelar efetiva e relevante controvérsia constitucional, os cidadãos estariam preocupados em externar, de modo livre e responsável, as convicções que desejariam transmitir à coletividade por meio da pacífica utilização dos espaços públicos" (STF, ADPF 187/DF, j. 15-6-2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 28-5-2014).

"Relação homoafetiva e entidade familiar – A norma constante do art. 1.723 do Código Civil – CC ('É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família') não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal" (STF, ADIn 4.277/DF, j. 5-5-2011, rel. Min. Ayres Britto, DJe 14-10-2011; STF, ADPF 132/RJ, j. 5-5-2011, rel. Min. Ayres Britto, DJe 14-10-2011).

ADPF 132 e ADIn 4.277. Relação homoafetiva e entidade familiar. A norma constante no art. 1.723 do Código Civil (É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada

na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família) não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal.

“(...) não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a ADPF, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato (...)” (STF, ADPF 126/DF, j. 19-12-2007, rel. Min. Celso de Mello, DJe 31-1-2008).

ADPF 378. “STF reafirma rito aplicado ao processo de impeachment de Fernando Collor.

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 378, que discute a validade de dispositivos da Lei n. 1.079/50 que regulamentam o processo de impeachment de Presidente da República. Com o julgamento, firmou-se o entendimento de que a Câmara dos Deputados apenas dá a autorização para a abertura do processo de impeachment, cabendo ao Senado fazer juízo inicial de instalação ou não do procedimento, quando a votação se dará por maioria simples; a votação para escolha da comissão especial na Câmara deve ser aberta, sendo ilegítimas as candidaturas avulsas de deputados para sua composição; e o afastamento de presidente da República ocorre apenas se o Senado abrir o processo.

A corrente majoritária seguiu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, divergente do relator da ação, Ministro Edson Fachin, que rejeitava alguns dos principais pedidos feitos pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), autor da ADPF, como a necessidade de defesa prévia do Presidente da República, a vedação ao voto secreto para a formação da comissão especial e a possibilidade de o Senado rejeitar a instauração do

processo.

Seguiram a divergência as Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia e os Ministros Luiz Fux, Marco Aurélio, em menor extensão, e o presidente, Ministro Ricardo Lewandowski. O Ministro Teori Zavascki divergiu do voto do Ministro Barroso apenas quanto à comissão especial, por entender cabível o voto secreto. Com o relator, votaram os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O Ministro Celso de Mello divergiu do relator em relação ao papel do Senado. Para ele, não há qualquer relação de subordinação do Senado em relação à Câmara.”¹

ATENÇÃO

Liminar da Ministra Rosa Weber suspendeu a Portaria n. 1.129/2017 do Ministério do Trabalho que alterava regras de fiscalização no combate ao trabalho escravo e criava nova definição aos conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo, para, entre outros fins, a concessão de seguro-desemprego (STF, ADPF 489, rel. Min. Rosa Weber, j. 23-10-2017).

6.4.6. Decisões no controle concentrado de constitucionalidade

Se o STF declarar uma lei inconstitucional, ela é nula, não produzindo nenhum efeito jurídico válido. Segundo a doutrina, as declarações de nulidade de lei podem ser:

- a) **nulidade total**: a lei inteira é declarada inconstitucional, normalmente, por vício formal (iniciativa, quórum, procedimento legislativo, entre outros);
- b) **nulidade parcial**: apenas parte da lei é declarada inconstitucional;
- c) **nulidade parcial sem redução de texto**: declara-se a inconstitucionalidade apenas de determinada hipótese de aplicação da lei, reconhecendo a possibilidade de aplicação da lei a outras hipóteses (não cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro, porém nos

próximos exercícios financeiros será possível exigí-lo);

d) **interpretação conforme a Constituição:** havendo duas ou mais interpretações possíveis de uma lei, declara-se aquela que deve ser adotada (constitucional). Por exemplo, o § 3.º do art. 7.º do EOAB (“o advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável (...)”) não abrange a hipótese de desacato à autoridade judiciária (STF, ADIn 1.127-MC/DF). Outro exemplo, sem redução de texto, é o caso da ADIn 2.924/SP: pagamentos complementares “são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força da lei, do índice aplicado” (art. 336, V, Regimento Interno do TJSP da época, e art. 100 da CF/88 – Informativo do STF 478).

Decisões sobre o tema:

“É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade” (ADIn 3.324, j. 16-12-2004, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 5-8-2005)

“Afasta-se o uso da técnica de ‘interpretação conforme’ para a feitura de sentença de caráter aditivo que tencione conferir à Lei de Biossegurança exuberância regratória, ou restrições tendentes a inviabilizar as pesquisas com células-tronco embrionárias. Inexistência dos pressupostos para a aplicação da técnica da ‘interpretação conforme a Constituição’, porquanto a norma impugnada não padece de polissemia ou de plurissignificatidade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente” (ADIn 3.510, j. 29-5-2008, rel. Min. Ayres Britto, DJe 27-5-2010).

6.4.7. Quadro comparativo das ações do controle concentrado

AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO				
AÇÃO	ESPÉCIE	OBJETO	LEG. ATIVA	FORO
ADIn/ADI	GENÉRICA	lei ou ato normativo	art. 103 CF	STF
		federal ou estadual		Quórum de Instalação: 2/3 do STF (8 ministros)
		inconstitucional (art. 102, I, a, CF)		Quórum de Aprovação: maioria absoluta do STF (6 ministros)
ADIn/ADI	SUPRIDORA DA OMISSÃO/POR OMISSÃO	norma constitucional de eficácia limitada	art. 103 CF	STF
		não regulamentada		Quórum de Instalação: 2/3 do STF (8 ministros)
				Quórum de Aprovação: maioria absoluta do STF (6 ministros)
	INTERVENTIVA FEDERAL	União irá intervir nos Estados / Distrito Federal por violação aos princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII)	PGR	STF
				Quórum de Instalação: 2/3 do STF (8 ministros)
				Quórum de Aprovação:

				maioria absoluta do STF (6 ministros)
ADECON		lei ou ato normativo federal que está sendo julgado inconstitucional em processos judiciais	art. 103 CF	STF (Quórum idêntico aos anteriores)
ADPF		lesão de preceito fundamental por órgão público (lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior a CF)	art. 103 CF	STF (Quórum idêntico aos anteriores)

6.5. ATRIBUIÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E DO **AMICUS CURIAE** NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

O Advogado-Geral da União (AGU) tem por atribuição defender a lei ou ato normativo federal ou estadual impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, sustentando a presunção de constitucionalidade das normas infraconstitucionais elaboradas pelo Poder Público (art. 103, § 3.º, da CF/88 e art. 8.º da Lei n. 9.868/99).

Poderá o Advogado-Geral da União ser ouvido em caso de ADPF (art. 5.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99) e no caso de ADIn PO (art. 12-E, § 2.º, da Lei n. 9.868/99).

Segundo decisões do Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a oitiva do AGU no processo da ação declaratória de constitucionalidade, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADIn 480-8/DF), bem como não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade (ADIn 1.616-4/PE).

Art. 103, § 3.º, da CF/88: "Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto

impugnado”.

Art. 8.º da Lei n. 9.868/99: “Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias”.

Art. 5.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99: “O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. (...) § 2.º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias”.

O Procurador-Geral da República é ouvido previamente nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 103, § 1.º, da CF/88).

“Art. 103 (...) § 1.º O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.”

O *amicus curiae* corresponde à possibilidade da participação de órgãos e entidades estranhas à causa, por despacho do ministro relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes (art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99), em que pese a não admissão da intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade (art. 7.º, caput, da Lei n. 9.868/99):

“Art. 7.º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. (...). § 2.º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.

Decisão sobre o tema:

“Admito a aplicação analógica da Lei n. 9.868/99 ao processo referente à arguição de descumprimento de preceito fundamental versada na Lei n. 9.882/99, em cujo processo, assim, de início, é possível a intervenção de terceiro. Entrementes, tal intervenção excepciona a regra do art. 7.º da Lei n. 9.868/99, segundo o qual ‘não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade’. A exceção corre à conta de situação concreta em que o relator, dada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, entenda cabível a manifestação de outros órgãos ou entidades” (STF, ADPF 70, j. 13-6-2005, rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ 20-6-2005).

Há quem entenda que o *amicus curiae* estaria fundamentado nos arts. 9.º, § 1.º, e 20, § 1.º, da Lei n. 9.868/99 e no art. 6.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99.

Importante destacar a lição do Min. Gilmar Mendes sobre o tema: “Constitui, todavia, inovação significativa no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade a autorização para o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, admita a manifestação de outros órgãos ou entidades (art. 7.º, § 2.º). Positiva-se, assim, a figura do *amicus curiae* no processo de controle de constitucionalidade, ensejando a possibilidade de o Tribunal decidir as causas com pleno conhecimento de todas as suas implicações ou repercussões. Trata-se de providência que confere caráter pluralista ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. No que concerne ao prazo para o exercício do direito de manifestação (art. 7.º), parece que tal postulação há de se fazer dentro do lapso temporal fixado para a apresentação das informações por parte das autoridades responsáveis pela edição do ato. É possível, porém, cogitar de hipóteses de admissão de *amicus curiae* fora do prazo das informações na ADIn (art. 9.º,

§ 1.º), especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa. Quanto à atuação do amicus curiae, após ter entendido que ela haveria se limitar à manifestação escrita, houve por bem o Tribunal admitir a sustentação oral por parte desses peculiares partícipes do processo constitucional” (Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 1.070) (grifos nossos).

Decisões sobre o tema:

“Em face do art. 6.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99, admito a manifestação de Conectas Direitos Humanos, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDECA/CE, Centro de Direitos Humanos – CDH, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNCME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, Centro de Cultura Professor Luiz Freire e Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos/Movimento Nacional de Direitos Humanos, que intervirão no feito na condição de amici curiae” (STF, ADPF 71, j. 27-5-2005, rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 3-6-2005) (grifos nossos).

“Admissão de amicus curiae mesmo após terem sido prestadas as informações. Em face da relevância da questão, e com o objetivo de pluralizar o debate constitucional, aplico analogicamente a norma inscrita no § 2.º do art. 7.º da Lei n. 9.868/99, admitindo o ingresso da peticionária, na qualidade de amicus curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o disposto no art. 131, § 3.º, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 15/2004” (STF, ADPF 73, j. 1.º-8-2005, rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ 8-8-2005) (grifos nossos).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Ausência de legitimidade. Interpretação do § 2.º do art. 7.º da Lei n. 9.868/99. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é

assente quanto ao não cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Exceção apenas para impugnar decisão de não admissibilidade de sua intervenção nos autos. Precedentes” (STF, ADIn 3.615-ED/PB, j. 17-3-2008, rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 24-4-2008). No mesmo sentido: STF, ADIn 2.591-ED/DF, j. 14-12-2006, rel. Min. Eros Grau, DJ 13-4-2007.

Nada impede que no controle concreto (difuso) de constitucionalidade também exista a figura do *amicus curiae*.

Sobre o tema participação de *amicus curiae*, do Ministério Público e de outros interessados no incidente de inconstitucionalidade perante os tribunais, ensina o Min. Gilmar Ferreira Mendes: “Diante dos múltiplos aspectos que envolvem a própria argumentação relacionada com os fundamentos da inconstitucionalidade, sustentamos a razoabilidade, se não a obrigatoriedade, de que se reconhecesse a todos aqueles que participam de demandas semelhantes, no âmbito do primeiro grau, o direito de participação no julgamento a ser levado a efeito pelo Pleno ou pelo órgão especial do Tribunal. Idêntica participação deveria ser deferida ao Ministério Público e à pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato normativo. Essa proposta acabou sendo incorporada ao texto da Lei n. 9.868/99 (art. 29). Vê-se, pois, que a alteração introduzida pela Lei n. 9.868/99 admite a manifestação, no incidente de inconstitucionalidade, do Ministério Público, das pessoas jurídicas responsáveis pela edição do ato e dos titulares do direito de propositura na ação direta de inconstitucionalidade. Dentro dessa estrutura plural, facultou-se ao relator a possibilidade de admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos e entidades. Tem-se, assim, oportunidade para a efetiva abertura do processo de controle de constitucionalidade incidental, que passa, nesse ponto, a ter estrutura semelhante à dos processos de índole estritamente

objetiva (ADIn, ADC e ADPF)” (Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 1.022).

6.6. BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE

Segundo a doutrina e a jurisprudência, o bloco de constitucionalidade é a reunião de vários diplomas legais considerados como constitucionais, não obstante terem sido elaborados em momentos diferentes. A França é um exemplo recorrente de país que adota o bloco de constitucionalidade, pois convivem com status constitucional a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), a Constituição de 1946 (parte econômica e social) e a Constituição de 1958.

No Brasil, a Emenda Constitucional n. 45/2004 inseriu o § 3.º ao art. 5.º da CF/88, possibilitando que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos seus membros, sejam equivalentes às emendas constitucionais.

Saliente-se que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, tinham natureza jurídica de normas infraconstitucionais, poderão ser elevados à condição de normas constitucionais.

Existe apenas um tratado internacional de direitos humanos no Brasil com status de emenda constitucional. É o Decreto n. 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

Há quem sustente que o bloco de constitucionalidade já seria possível em relação aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos desde a vigência da Constituição Federal de 1988, em virtude do

conteúdo dos §§ 1.º e 2.º do art. 5.º. Nesse sentido ensina Flávia Piovesan, em sua obra *Direitos humanos e o direito constitucional internacional* (7. ed., São Paulo, Saraiva, p. 55).

Decisão sobre o tema:

“Em conclusão de julgamento, o Tribunal concedeu habeas corpus em que se questionava a legitimidade da ordem de prisão, por 60 dias, decretada em desfavor do paciente que, intimado a entregar o bem do qual depositário, não adimplira a obrigação contratual – v. Informativos 471, 477 e 498. Entendeu-se que a circunstância de o Brasil haver subscrito o Pacto de São José da Costa Rica, que restringe a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia (art. 7.º, 7), conduz à inexistência de balizas visando à eficácia do que previsto no art. 5.º, LXVII, da CF (‘não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel’). Concluiu-se, assim, que, com a introdução do aludido Pacto no ordenamento jurídico nacional, restaram derogadas as normas estritamente legais definidoras da custódia do depositário infiel. Prevaleceu, no julgamento, por fim, a tese do status de supralegalidade da referida Convenção, inicialmente defendida pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do RE 466.343/SP, abaixo relatado. Vencidos, no ponto, os Ministros Celso de Mello, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Eros Grau, que a ela davam a qualificação constitucional, perfilhando o entendimento expendido pelo primeiro no voto que proferira nesse recurso. O Min. Marco Aurélio, relativamente a essa questão, se absteve de pronunciamento” (STF, HC 87.585/TO, j. 3-12-2008, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25-6-2009).

O federalismo, como expressão do direito constitucional, nasceu com a Constituição norte-americana de 1787. Baseia-se na união de coletividades políticas autônomas. Refere-se a uma forma de Estado denominada Federação ou Estado Federal, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucional, ou seja, de autonomia federativa.

O Estado pode ser definido como uma organização jurídica, administrativa e política formada por uma população, assentada em um território, dirigida por um governo soberano e tendo como finalidade o bem comum.

7.1. FORMA DO ESTADO

7.1.1. Estado unitário

Quando existe um único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa e política, do qual emanam todos os comandos normativos. Também chamado de Estado Simples. Exemplo: Cuba.

7.1.2. Estado federal

Quando existe uma repartição constitucional de competências e mais de um centro dotado de capacidade política. É a própria Constituição que estabelece a estrutura federativa, proibindo sua abolição. Também chamado de Estado Composto. Exemplo: Brasil, EUA, Alemanha, entre

outros.

7.2. FEDERALISMO NO BRASIL

No Brasil, os entes que compõem a Federação são: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios (art. 18, caput, da CF/88). A Constituição fala ainda em Territórios, divisões político-administrativas que, atualmente, não existem mais.

O Brasil assumiu a forma de Estado federal em 1889, com a Proclamação da República, o que foi confirmado pela Constituição de 1891 e mantido nas Constituições posteriores. O Brasil evoluiu de um Estado Unitário para um Estado Federal (federalismo por segregação).

IMPORTANTE

Em sessão realizada no dia 22 de maio de 2019, por maioria dos votos, o Plenário do STF reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

Os ministros analisaram embargos de declaração apresentados pela União contra decisão do Plenário Virtual no Recurso Extraordinário 855.178. Ao reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no RE, o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados.

Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23-5-2019 (STF, RE 855.178, plenário, j. 22-5-2019, rel. Min. Luiz Fux).

7.3. COMPONENTES DO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO

7.3.1. União

Pessoa jurídica de direito público com capacidade política, exercendo uma parcela da soberania brasileira. Internamente, atua como uma das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Externamente, diante de Estados estrangeiros, a União exerce a soberania do Estado brasileiro, fazendo valer seus direitos e assumindo suas obrigações.

Poder Legislativo: arts. 44 a 75 da CF/88. Congresso Nacional, integrado pela Câmara dos Deputados – composta por Deputados Federais – e pelo Senado Federal – composto por Senadores Federais. Atualmente, são 513 (quinhentos e treze) Deputados Federais e 81 (oitenta e um) Senadores Federais.

Poder Executivo: arts. 76 a 91 da CF/88. Presidente da República e Vice-Presidente.

Poder Judiciário: arts. 101 a 124 da CF/88.

Bens da União: art. 20 da CF/88.

Impostos da União: art. 153 da CF/88.

IMPORTANTE

Súmula Vinculante 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.

7.3.2. Estados federados

São entes detentores de autonomia política e administrativa. Têm capacidade de elaborar suas próprias Constituições estaduais, observadas as diretrizes da Constituição Federal.

Poder Legislativo: art. 27 da CF/88. Assembleia Legislativa composta por Deputados Estaduais em número calculado com base no art. 27, caput, da

CF/88 (o Estado de São Paulo possui o maior número de Deputados Estaduais: são 94).

Poder Executivo: art. 28 da CF/88. Governador e Vice-Governador.

Poder Judiciário: arts. 125 e 126 da CF/88.

Bens dos Estados: art. 26 da CF/88.

Impostos dos Estados: art. 155 da CF/88.

Criação e extinção: os Estados podem se incorporar entre si, se subdividir ou se desmembrar para se anexarem a outros ou formarem novos Estados. Para isso, precisam da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar (art. 18, § 3.º, da CF/88).

IMPORTANTE

O Decreto Presidencial n. 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, determina a intervenção federal na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública com o prazo previsto de vigência até 31 de dezembro de 2018.

O Decreto Presidencial n. 9.602, de 10 de dezembro de 2018, determina a intervenção federal no Estado de Roraima com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública com o prazo previsto de vigência até 31 de dezembro de 2018.

7.3.3. Municípios

São entes detentores de autonomia política e administrativa. Têm capacidade de elaborar sua Lei Orgânica Municipal.

Poder Legislativo: arts. 29 e 31 da CF/88. Exercido pela Câmara Municipal, composta por Vereadores (de 9 a 55), dependendo da população municipal, conforme art. 29, IV, da CF/88).

Poder Executivo: arts. 29 e 31 da CF/88. Prefeito e Vice-Prefeito.

Poder Judiciário: não há Justiça Municipal.

Impostos: art. 156 da CF/88.

Criação e extinção: art. 18, § 4.º, da CF/88, onde se lê: “A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei”.

Cumpram-se destacar que a Emenda Constitucional n. 57, de 18 de dezembro de 2008, acrescentou o art. 96 ao ADCT, que assim estabelece: “Art. 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação”.

ATENÇÃO

Sobre o tema competência municipal o STF se manifestou no seguinte sentido:

- “O Tribunal, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei n. 10.991/91, do Município de São Paulo, o qual estabelecia que a licença de localização de novas farmácias e drogarias seria concedida somente quando o estabelecimento ficasse situado a uma distância mínima de duzentos metros da farmácia ou drogaria mais próxima, já existente. Entendeu-se violado o disposto no art. 170, IV e V, da CF (“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna (...) observados os seguintes princípios: (...) IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor.”). Vencido o Min. Carlos Velloso, relator, que entendia que a lei municipal – inserida na competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber (CF, art. 30, I e II) –, ao disciplinar o uso do solo distribuindo as farmácias de modo a evitar a concentração delas em determinado local, não estabeleceu uma ‘reserva de mercado’. Precedente citado: RE 203.909/SC (DJU 6-2-1998)” (STF, RE 193.749/SP, j. 4-6-1998, rel. originário Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa).
- “Com base nos mesmos fundamentos do julgamento acima referido, o Tribunal, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei n. 6.545/91, do Município de Campinas, que restringia a instalação de farmácias e drogarias a um raio de distância de quinhentos metros uma da outra. Vencido o Min. Carlos Velloso”

(STF, RE 199.517/SP, j. 4-6-1998, rel. originário Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa).

Súmula Vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

7.3.4. Distrito Federal

Ente detentor de autonomia política e administrativa. Tem capacidade de elaborar sua Lei Orgânica e possui capacidade legislativa, administrativa e judiciária, com as mesmas competências legislativas atribuídas aos Estados e aos Municípios (art. 32, § 1.º, da CF/88).

O Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios (não tem eleições municipais).

Assim como os Estados, o Distrito Federal elege Senadores (três) e Deputados Federais (oito), em número definido por lei complementar; além disso, elege também Deputados Distritais (vinte e quatro).

Lembre-se que Brasília é a capital do Brasil (art. 18, § 1.º, da CF/88).

Poder Legislativo: art. 32, §§ 2.º e 3.º, da CF/88. Câmara Legislativa composta por Deputados Distritais (vinte e quatro).

Poder Executivo: art. 32, § 2.º, da CF/88. Governador e Vice-Governador.

Poder Judiciário: organizado por lei federal (art. 98, I, da CF/88).

Destaque-se que algumas instituições são organizadas e mantidas pela União, tais como, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Além disso, a União presta assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos (Lei n. 10.633/2002).

Cabe ao Distrito Federal organizar a sua Defensoria Pública.

Bens: definidos por lei federal (art. 16, § 3.º, do ADCT da CF/88).

Impostos: arts. 147 e 155 da CF/88. Pode arrecadar impostos estaduais e municipais.

Sobre o tema, o STF tem o seguinte posicionamento:

ATENÇÃO

- “O Distrito Federal é uma unidade federativa de compostura singular, dado que: a) desfruta de competências que são próprias dos Estados e dos Municípios, cumulativamente (art. 32, § 1.º, CF/88); b) algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União (art. 21, XI e XIV, CF/88); c) os serviços públicos a cuja prestação está jungido são financiados, em parte, pela mesma pessoa federada central, que é a União (art. 21, XIV, parte final, CF). 3. Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais próximo da

estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios. Isto porque: a) ao tratar da competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal em pé de igualdade com os Estados e a União (art. 24); b) ao versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs que a ‘União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal’ (art. 34), reservando para os Municípios um artigo em apartado (art. 35); c) o Distrito Federal tem, em plenitude, os três orgânicos Poderes estatais, ao passo que os Municípios somente dois (inciso I do art. 29); d) a Constituição tratou de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados distritais, à duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares etc. (§ 3.º do art. 32); e) no tocante à legitimação para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a Magna Carta dispensou à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento dado às Assembleias Legislativas estaduais (inciso IV do art. 103); f)

no modelo constitucional brasileiro, o Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União; g) tanto os Estados-membros como o Distrito Federal participam da formação da vontade legislativa da União (arts. 45 e 46)” (STF, ADIn 3.756, j. 21-6-2007, rel. Min. Carlos Britto, DJ 19-10-2007).

Súmula Vinculante 39: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”.

- “A Lei Orgânica tem força e autoridade equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às Constituições promulgadas pelos Estados-membros, como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta” (STF, ADIn 980, Plenário, j. 6-3-2009, rel. Min. Menezes Direito, DJe 10-8-2009).

7.3.5. Territórios federais

São meras divisões administrativas da União, podendo ser divididos ou reunidos (arts. 18, § 2.º, e 33 da CF/88). Neles existe autonomia administrativa, mas não política.

Os Territórios Federais elegem quatro Deputados Federais (art. 45, § 2.º, da CF/88), mas não elegem senadores. Atualmente, é apenas uma possibilidade jurídica, já que os arts. 14 e 15 do ADCT da CF/88 extinguiram os últimos existentes, (Roraima, Amapá e Fernando de Noronha) normas que evidentemente não impedem a criação de outros Territórios Federais.

Os Territórios Federais do Amapá e Roraima foram transformados em Estados (art. 14 do ADCT da CF/88). O Território Federal de Fernando de Noronha foi reincorporado ao Estado de Pernambuco (art. 15 do ADCT da CF/88).

O art. 33 da CF/88 estabelece: “A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios. § 1.º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título. § 2.º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. § 3.º Nos Territórios Federais com mais de cem mil

habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa”.

Sobre a competência tributária dos territórios, o art. 147 da CF/88 afirma que: “Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais”.

7.4. VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS EXISTENTES NO FEDERALISMO DO BRASIL

A Constituição Federal vigente, em seu art. 19, estabelece: “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; II – recusar fé aos documentos públicos; III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”.

O Estado brasileiro é laico, bem como é livre o exercício dos cultos religiosos, e, garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias (art. 5.º, VI, da CF/88). Nada impede, como estabelece o texto constitucional, a colaboração de interesse público (manutenção de asilos, creches, entre outros).

ATENÇÃO

“Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Art. 150, VI, b e § 4.º, da Constituição. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. A imunidade prevista no art. 150, VI, b, CF deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados

com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas'. O § 4.º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas b e c do inciso VI do art. 150 da CF. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas" (RE 325.822, Plenário, j. 18-12-2002, rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ 14-5-2004). No mesmo sentido: AgRg no Ag no RE 658.080, 1.ª T., j. 13-12-2011, rel. Min. Luiz Fux, DJe 15-2-2012; AgRg no AgIn 690.712, 1.ª T., j. 23-6-2009, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14-8-2009; AgRg no AgIn 651.138, 2.ª T., j. 26-6-2007, rel. Min. Eros Grau, DJ 17-8-2007.

Os documentos públicos gozam de presunção de veracidade, não podendo ser recusados em razão da origem (escrituras, certidões, entre outros).

Os entes federativos não podem estabelecer distinções ou preferências entre brasileiros em razão de sua origem (Estado, Distrito Federal ou Município). Por exemplo, em um concurso público não se pode estabelecer pontuação maior para quem é natural de certa localidade (nasceu em certa cidade ou em certo Estado).

CUIDADO

Não confundir com as ações afirmativas ou discriminações positivas (ações realizadas pelo Estado para proteger grupos de pessoas prejudicadas historicamente) que são admitidas no sistema jurídico brasileiro (art. 1.º, parágrafo único, VI, da Lei n. 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial).

Lei n. 12.990/2014 – Reserva aos negros 20% das vagas de concursos públicos no âmbito da administração pública federal.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu em 08 de junho de 2017 o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41 e reconheceu a validade da Lei n. 12.990/2014, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, no âmbito dos Três Poderes. A decisão foi unânime" (STF, ADC 41, rel. Min. Luís Barroso, j. 8-6-2017).

7.5. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS VINCULADOS AO FEDERALISMO

7.5.1. Princípios estabelecidos

São limitações diretas e indiretas impostas aos entes federativos. Por exemplo: art. 19 (explícita) e art. 149 (implícita) – só a União pode.

7.5.2. Princípios sensíveis

Geram intervenção federal no Estado-membro ou no Distrito Federal se forem descumpridos. Autorizam a utilização da ADIn Interventiva Federal e estão previstos no inciso VII do art. 34 da CF/88, onde se lê: " A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) VII – assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde".

7.5.3. Princípios extensíveis

A organização da União é extensível aos demais entes federativos, na medida de suas peculiaridades. São exemplos princípios do processo legislativo, a eleição do Poder Executivo, matéria orçamentária, organização e funcionamento do Tribunal de Contas, entre outros. É a simetria federativa ou o paralelismo constitucional.

Destaque-se que o bicameralismo (duas Casas compondo um ente) só existe na esfera federal.

Fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1.º da CF/88):	Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3.º da CF/88):	A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios (art. 4.º da CF/88):
--	---	---

I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa; V – o pluralismo político.	I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.	I – independência nacional; II – prevalência dos direitos humanos; III – autodeterminação dos povos; IV – não intervenção; V – igualdade entre os Estados; VI – defesa da paz; VII – solução pacífica dos conflitos; VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X – concessão de asilo político.
---	---	---

Intervenção federal

No Estado Federal, a autonomia dos entes federativos (Estados, Distrito Federal e Municípios) tem como característica a capacidade de autoconstituição e normatização, autogoverno e autoadministração. No entanto, admite-se o afastamento dessa autonomia política com o objetivo de preservar a existência e a unidade da própria Federação por meio da intervenção.

É medida excepcional e só deve ocorrer nos casos previstos expressamente na Constituição (arts. 34 a 36 da CF/88).

Na atualidade, a União poderá intervir nos Estados-membros e no Distrito Federal, enquanto os Estados-membros somente poderão intervir nos Municípios localizados em seus respectivos territórios.

Infere-se que a União não pode intervir diretamente nos Municípios brasileiros, salvo se localizados em Território Federal (art. 35, caput, da CF/88). Cumpre lembrar que atualmente não existem Territórios Federais.

A intervenção materializa-se por decreto do Presidente da República (art. 84, X, da CF/88) e, ao ser este publicado, tornar-se-á imediatamente eficaz, legitimando os demais atos atinentes à intervenção, submetendo essa decisão à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas (art. 36, § 1.º, da CF/88).

Nos casos de intervenção de ofício ou de solicitação do Legislativo ou Executivo coagidos, previstos no art. 34, I, II, III, IV e V, o Presidente ouvirá os Conselhos da República (art. 90, I, da CF/88) e de Defesa Nacional (art. 91, § 1.º, II, da CF/88), que opinarão a respeito. Após, poderá

discrecionariamente decretar a intervenção no Estado-membro.

Nas hipóteses do art. 34, VI e VII (requisição judicial), o controle político será dispensado (art. 36, § 3.º, da CF/88). Também não é necessária essa espécie de controle no caso do art. 34, IV, por requisição do Supremo Tribunal Federal acionado pelo Poder Judiciário Estadual (TJ) coagido (art. 36, I, da CF/88).

IMPORTANTE

O Decreto Presidencial n. 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, determina a intervenção federal na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública com o prazo previsto de vigência até 31 de dezembro de 2018.

O Decreto Presidencial n. 9.602, de 10 de dezembro de 2018, determina a intervenção federal no Estado de Roraima com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública com o prazo previsto de vigência até 31 de dezembro de 2018.

8.1. PROCEDIMENTO DETALHADO

8.1.1. Iniciativa

A Constituição Federal vigente, dependendo da hipótese prevista para a intervenção federal, indica quem poderá deflagrar o procedimento interventivo. Estão previstos:

- a) o Presidente da República, nas hipóteses dos incisos I, II, III e V do art. 34, pode, de ofício, decretar a intervenção federal (intervenção espontânea);
- b) solicitação dos Poderes locais (art. 34, IV): os Poderes Legislativo (Assembleia ou Câmara Legislativa) e Executivo (Governador do Estado ou do Distrito Federal) locais solicitarão ao Presidente da República a decretação de intervenção no caso de estarem sofrendo coação no exercício de suas funções;

O Poder Judiciário local, por sua vez, solicitará a intervenção ao Supremo Tribunal Federal (STF), que, se for o caso, a requisitará ao Presidente da República.

- c) requisição do STF (Supremo Tribunal Federal), do STJ (Superior Tribunal de Justiça) ou do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na hipótese de desobediência a ordem ou decisão judiciária (art. 34, VI, segunda parte). Desse modo, o STJ e o TSE requisitam ao Presidente da República a decretação da intervenção se descumpridas suas ordens judiciais. Ao STF, além do descumprimento de suas ordens ou decisões judiciais, cabe exclusivamente a requisição de intervenção para assegurar a execução de decisões das Justiças Federal, Estadual, do Trabalho ou Militar. Cumpre destacar que somente o Tribunal de Justiça local tem legitimidade para encaminhar ao STF o pedido de intervenção baseado em descumprimento de suas próprias decisões;
- d) ações propostas pelo Procurador-Geral da República (PGR) nas hipóteses do art. 34, VI e VII, endereçadas ao STF (Ação de Executoriedade de Lei Federal e ADIn Interventiva – art. 36, III).

8.1.2. Fase judicial

Somente nos casos previstos no item d) supracitado o Procurador-Geral da República tem legitimidade para propor as ações, e o STF, para prosseguimento da intervenção, deve julgar procedentes as ações propostas, encaminhando a decisão ao Presidente da República para fins do decreto interventivo. Nesses casos, a decretação da intervenção é ato vinculado, e o Presidente apenas formaliza a decisão tomada pelo órgão do Poder Judiciário.

8.1.3. Decreto interventivo

O decreto presidencial formaliza a intervenção (art. 84, X, da CF/88), e, ao ser publicado, tornar-se-á imediatamente eficaz, legitimando os demais atos atinentes à intervenção.

O decreto de intervenção deve especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se necessário, afastar as autoridades locais e nomear um interventor, submetendo essa decisão à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas (art. 36, § 1.º, da CF/88. Observação: a autorização é por decreto legislativo – art. 49, IV, da CF/88). É medida temporária e excepcional.

Nos casos de intervenções de ofício, previstos no art. 34, I, II, III e V, o Presidente ouvirá os Conselhos da República (art. 90, I, da CF/88) e de Defesa Nacional (art. 91, § 1.º, II, da CF/88), que opinarão a respeito. Após, poderá discricionariamente decretar a intervenção no Estado-membro.

O interventor é considerado, para todos os efeitos legais, como servidor público federal, e sua competência e funções dependerão dos limites previstos no decreto interventivo.

8.1.4. Controle político

Realizado pelo Congresso Nacional, no prazo de 24 horas de sua decretação, que poderá rejeitar ou, mediante decreto legislativo, aprovar a intervenção federal (art. 49, IV, da CF/88).

Se o Congresso Nacional não aprovar a intervenção, o Presidente deverá cassá-la imediatamente, sob pena de crime de responsabilidade (art. 85, II, da CF/88).

Nas hipóteses do art. 34, VI e VII, o controle político será dispensado (art. 36, § 3.º, da CF/88); bem como no caso do art. 34, IV, por requisição do STF acionado pelo Poder Judiciário Estadual (TJ) coagido (art. 36, I, da CF/88).

8.1.5. Controle jurisdicional

Destaque-se que o Poder Judiciário deverá corrigir os abusos e as ilegalidades cometidos durante a intervenção federal.

Decisões sobre o tema:

“Intervenção estadual em Município. Súmula 637 do STF. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a decisão de Tribunal de Justiça que determina a intervenção estadual em Município tem natureza político-administrativa, não ensejando, assim, o cabimento do recurso extraordinário” (STF, AgIn 597.466-AgRg/SP, j. 27-11-2007, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 1.º-2-2008).

“O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentença judiciais (CF, art. 34, VI, e art. 35, IV), a efetivação do ato de intervenção – trate-se de intervenção federal nos Estados-membros, cuide-se de intervenção estadual nos Municípios – reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado perante órgão competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II, e art. 35, IV)” (STF, AgIn 343.461-AgRg/MG, j. 18-6-2002, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29-11-2002). No mesmo sentido: STF, AgIn 666.833-AgRg/, j. 18-12-2007, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14-3-2008.

“Intervenção federal. Inexistência de atuação dolosa por parte do Estado. Indeferimento. Precedentes. Decisão agravada que se encontra em consonância com a orientação desta Corte, no sentido de que o descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada em julgado é pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal” (STF, IF 5.050-AgRg/SP, j. 6-3-2008, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25-4-2008). No mesmo sentido: STF, IF 4.979-AgRg/PI, j. 6-3-2008, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25-4-2008.

“Intervenção Federal no Distrito Federal e Crise Institucional. O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido de intervenção federal no

Distrito Federal, formulado pelo Procurador-Geral da República, por alegada violação aos princípios republicano e democrático, bem como ao sistema representativo (CF, art. 34, II). Na espécie, o pedido de intervenção federal teria como causa petendi, em suma, a alegação da existência de esquema de corrupção que envolveria o ex-Governador do DF, alguns Deputados Distritais e suplentes, investigados pelo STJ, e cujo concerto estaria promovendo a desmoralização das instituições públicas e comprometendo a higidez do Estado Federal. Tais fatos revelariam conspícua crise institucional hábil a colocar em risco as atribuições político-constitucionais dos Poderes Executivo e Legislativo e provocar instabilidade da ordem constitucional brasileira. Preliminarmente, a Corte, por maioria, rejeitou requerimento do Procurador-Geral da República no sentido de adiar o julgamento da causa para a primeira data do mês de agosto em que a Corte estivesse com sua composição plena. Ao salientar a ansiedade da população por uma resposta pronta da Corte quanto ao pedido de intervenção e a proximidade do início formal do período eleitoral, reputou-se estar-se diante de questão importante que demandaria decisão o mais célere possível. Vencidos, no ponto, os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello que deferiam o adiamento, por considerarem que a análise da matéria recomendaria a presença do quórum completo dos integrantes do Tribunal. No mérito, entendeu-se que o perfil do momento político-administrativo do Distrito Federal já não autorizaria a decretação de intervenção federal, a qual se revelaria, agora, inadmissível perante a dissolução do quadro que se preordenaria a remediar. Asseverou-se que, desde a revelação dos fatos, os diversos Poderes e instituições públicas competentes teriam desencadeado, no desempenho de suas atribuições constitucionais, ações adequadas para pôr fim à crise decorrente de um esquema sorrateiro de corrupção no Distrito Federal. Observou-se, assim, que os fatos recentes não deixariam dúvida de que a metástase da corrupção anunciada na representação

interventiva teria sido controlada por outros mecanismos institucionais, menos agressivos ao organismo distrital, revelando a desnecessidade de se recorrer, neste momento, ao antídoto extremo da intervenção, debaixo do pretexto de salvar o ente público. Vencido o Min. Ayres Britto que julgava o pedido procedente. STF, IF 5.179/DF, rel. Min. Cezar Peluso, 30-6-2010” – Informativo 593 do STF.

“Em conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o art. 5.º da Lei n. 11.105/2005 (Lei da Biossegurança), que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento, e estabelece condições para essa utilização – v. Informativo 497. Prevaleceu o voto do Min. Carlos Britto, relator. Nos termos do seu voto, salientou, inicialmente, que o artigo impugnado seria um bem concatenado bloco normativo que, sob condições de incidência explícitas, cumulativas e razoáveis, contribuiria para o desenvolvimento de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades terapêuticas de células extraídas de embrião humano in vitro. Esclareceu que as células-tronco embrionárias, pluripotentes, ou seja, capazes de originar todos os tecidos de um indivíduo adulto, constituiriam, por isso, tipologia celular que ofereceria melhores possibilidades de recuperação da saúde de pessoas físicas ou naturais em situações de anomalias ou graves incômodos genéticos. Asseverou que as pessoas físicas ou naturais seriam apenas as que sobrevivem ao parto, dotadas do atributo a que o art. 2.º do CC denomina personalidade civil, assentando que a Constituição Federal, quando se refere à ‘dignidade da pessoa humana’ (art. 1.º, III), aos ‘direitos da pessoa humana’ (art. 34, VII, b), ao ‘livre exercício dos direitos (...) individuais’ (art. 85, III) e aos ‘direitos e garantias individuais’ (art. 60, § 4.º, IV), estaria falando de direitos e

garantias do indivíduo-pessoa. Assim, numa primeira síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativa, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 5.º diria respeito exclusivamente a um indivíduo já personalizado” (STF, ADIn 3.510/DF, j. 29-5-2008, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-5-2010).

Súmula 614 do STF: Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal.

ATENÇÃO

- Intervenção federal comum ou recorrente: art. 34 da CF/88 – Da União nos Estados--membros e no Distrito Federal
- Intervenção federal anômala ou incomum: art. 35 da CF/88 – 2.ª parte – Da União nos Municípios localizados em Território Federal

Intervenção federal comum ou recorrente

- a) De ofício: art. 34, I, II, III e V, da CF/88
- b) Por solicitação dos Poderes: art. 34, IV, da CF/88
- c) Por requisição judicial: art. 34, VI e VII, da CF/88

Estado de defesa

Consiste na instauração de uma legalidade extraordinária por certo tempo, em locais restritos e determinados, mediante decreto do Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza (art. 136 da CF/88).

Constarão do decreto o tempo de duração, que não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período ou menor, se persistirem as razões; a especificação das áreas abrangidas; a indicação das medidas coercitivas, tais como restrições aos direitos de reunião, de sigilo de correspondência e de comunicação telegráfica e telefônica, e também a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, se a hipótese for de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

9.1. CONTROLE DO ESTADO DE DEFESA

9.1.1. Controle político

- a) Depois de baixar o decreto, o Presidente da República, no prazo de 24 horas, o enviará com a justificativa ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta (Observação: autorização é por decreto legislativo – art. 49, IV, da CF/88). Se estiver em recesso, haverá convocação extraordinária em 5 dias. O Congresso deve apreciar o decreto no prazo de 10 dias, a contar do seu recebimento. Rejeitado o decreto, cessa

imediatamente o Estado de Defesa, sem prejuízo da responsabilidade dos executores (art. 136, §§ 4.º ao 7.º, da CF/88).

- b) Concomitante: nos termos do art. 140 da CF/88, a Mesa do Congresso Nacional designará comissão composta por cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas.
- c) Sucessivo: previsto no parágrafo único do art. 141 da CF/88, logo que cessar o Estado de Defesa as medidas aplicadas na sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Se o Congresso não aceitar a justificativa, poderá ser tipificado algum crime de responsabilidade (art. 85 da CF/88 e Lei n. 1.079/50).

9.1.2. Controle jurisdicional

É previsto no § 3.º do art. 136 da CF/88. Quando da prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, este a comunicará imediatamente ao Juiz, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial.

O estado físico e mental do detido no momento da autuação será declarado pela autoridade.

A prisão ou a detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo se autorizada pelo Poder Judiciário.

Durante e ao término do Estado de Defesa, poderá ocorrer o controle jurisdicional dos atos dos executores da medida que incorreram em abusos ou ilícitos.

ATENÇÃO

Estado de Defesa (arts. 136, 140 e 141 da CF/88)

Motivo: Preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

Prazo: Não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

Direitos que podem ser limitados: a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; b) sigilo de correspondência; c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.

IMPORTANTE

Decreto presidencial pode limitar o direito de reunião na vigência do Estado de Defesa.

Estado de sítio

É a instauração de uma legalidade extraordinária, por determinado tempo e em certa área, com o fim de preservar ou restaurar a normalidade constitucional perturbada por motivo de comoção grave de repercussão nacional, da ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa ou de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira – situação de beligerância com Estado estrangeiro (arts. 137 a 139 da CF/88).

No procedimento devem ser ouvidos os Conselhos da República e o de Defesa Nacional, e há necessidade de autorização pelo voto da maioria absoluta do Congresso Nacional (por decreto legislativo – art. 49, IV, da CF/88) para sua decretação, em atendimento à solicitação fundamentada do Presidente da República (art. 137 da CF/88).

Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente pelo Presidente do Senado, para se reunir no prazo de cinco dias, a fim de apreciar a solicitação. Caso conceda o estado de sítio, deverá o Congresso Nacional permanecer em funcionamento (art. 138 da CF/88).

O decreto de estado de sítio indicará sua duração (exceto em caso de guerra), as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas (somente as do art. 139 no caso do art. 137, I, da CF/88). Em caso de guerra, a Constituição não estabelece limites.

10.1. CONTROLE DO ESTADO DE SÍTIO

10.1.1. Controle político

a) **Prévio:** depende de autorização do Congresso Nacional pelo voto da maioria absoluta (art. 137, parágrafo único, da CF/88).

Autorização é por decreto legislativo – art. 49, IV, da CF/88.

b) **Concomitante:** cinco membros da Mesa do Congresso Nacional (art. 140 da CF/88).

c) **Sucessivo:** relatório do Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional (art. 141, parágrafo único, da CF/88).

10.1.2. Controle jurisdicional

Durante o período de exceção, deverá o Poder Judiciário corrigir os abusos e as ilegalidades, podendo ser usado o habeas corpus ou o mandado de segurança. Da mesma forma, haverá a atuação desse órgão após o Estado de Sítio.

Estado de sítio (arts. 137 a 141 da CF/88)

Motivo

Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

Prazo: não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior;

Limites: art. 139 da CF/88 (I – obrigação de permanência em localidade determinada; II – detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns; III – restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei; IV – suspensão da liberdade de reunião; V – busca e apreensão em domicílio; VI – intervenção nas empresas de serviços públicos; VII – requisição de bens).

IMPORTANTE

Decreto Presidencial pode limitar o direito de reunião e estabelecer censura na vigência do Estado de Sítio.

No Estado de Defesa, a oitiva do Congresso Nacional é posterior à sua decretação. De outro modo, no Estado de Sítio, o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à decretação.

ATENÇÃO

Coincidências entre Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio:

- os três são criados por decreto do Presidente da República;
- os três são limitações circunstanciais às emendas constitucionais (art. 60, § 1.º, da CF/88);
- os três são legalidades extraordinárias temporárias;
- normalmente, devem ser ouvidos os Conselhos da República e de Defesa Nacional, sem prejuízo do controle político, feito pelo Congresso Nacional, salvo nos casos de intervenção federal por requisição judicial.

Nacionalidade

A nacionalidade define o elo que une o indivíduo a um Estado determinado, ou seja, é a qualidade atribuída por norma que, por sua vez, tem por objeto indicar o Estado de que depende cada um.

O Estado é o poder soberano de um governo, exercido sobre uma população assentada em um território, voltado a uma finalidade (bem comum). O vínculo da nacionalidade decorre da relação entre o elemento humano (população) e o território, submetendo-se à ordenação jurídico-política ali existente.

A nacionalidade tem fundamental importância para um Estado soberano, de modo que a maioria dos países determina o modo de aquisição e perda da nacionalidade nas suas Constituições.

Para melhor compreensão do tema, é imprescindível conhecer alguns conceitos correlatos à nacionalidade.

- a) **População:** é o conjunto dos residentes no território, sejam nacionais ou estrangeiros. São os habitantes de um território submetidos a um governo soberano.
- b) **Povo:** é o conjunto de habitantes dotados de capacidade eleitoral ativa e/ou passiva. Pode ser entendido como o conjunto dos eleitores que se qualificam pela posse da cidadania.
- c) **Nação:** é o conjunto de pessoas que partilham a mesma identidade sócio e étnico-cultural.

Podemos deduzir que há um critério democrático para definir população,

um critério político para o conceito de povo e um critério étnico-cultural para a nação. Destaque-se que o termo nacionalidade, em seu enfoque jurídico, pode se distanciar do conceito de nação, pois serão nacionais todos aqueles unidos por um vínculo político com o Estado, independentemente de afinidades étnico-culturais.

d) **Nacional:** é o brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, aquele que se vincula por nascimento ou naturalização ao território brasileiro.

e) **Cidadão:** é o termo que qualifica o nacional no gozo dos direitos políticos.

CUIDADO

Não se deve confundir nacionalidade com naturalidade, pois esta se refere ao local físico onde se nasce e não necessariamente coincide com a nacionalidade. Por exemplo, o indivíduo pode ser londrino, por ter nascido em Londres, mas ser brasileiro nato, por ser filho de diplomata brasileiro que lá se encontra em serviço.

11.1. NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DA NACIONALIDADE

No Brasil, a nacionalidade é um direito de ordem constitucional (material e formalmente), pois está prevista no art. 12 da CF/88.

11.2. ESPÉCIES DE NACIONALIDADE E PECULIARIDADES

11.2.1. Primária, de origem ou originária

Esta espécie de nacionalidade está vinculada ao fato natural do nascimento. Adotam-se dois critérios:

a) **da territorialidade (ius solis):** atribui a nacionalidade a quem nasce no território do Estado de que se trata; e

b) **da consanguinidade (ius sanguinis):** são nacionais os descendentes de

nacionais.

No caso da nacionalidade primária, teremos o brasileiro nato.

11.2.2. Secundária ou adquirida

É a nacionalidade que se adquire pela vontade do indivíduo ou do Estado por meio da naturalização (fato artificial). Nesse caso, temos o brasileiro naturalizado.

11.3. MODOS DE AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE

Os modos de aquisição da nacionalidade dependem de cada Estado, mas em qualquer deles é involuntária sua aquisição originária (primária), e decorre da ligação do fato natural do nascimento com um critério estabelecido pelo Estado, enquanto é voluntária sua aquisição secundária.

Como já visto, dois são os critérios para a determinação da nacionalidade primária (nascimento).

11.3.1. Critério da origem sanguínea (**ius sanguinis**)

Pelo qual se confere a nacionalidade em função do vínculo do sangue, reputando-se nacionais os descendentes de nacionais.

11.3.2. Critério da origem territorial (**ius solis**)

Pelo qual se atribui a nacionalidade ao nascimento em determinado território, ou seja, a criança deve nascer em determinado território do Estado para possuir aquela nacionalidade.

Historicamente, os Estados de emigração (maioria dos europeus – metrópoles) preferem o critério do *ius sanguinis*, pois mesmo com a saída de sua população para outros países não há a diminuição de seus nacionais. Já, por sua vez, os Estados de imigração (maioria dos americanos – ex-colônias) acolhem o critério do *ius solis*, pelo qual os filhos e demais

descendentes da massa dos imigrantes passam a ter sua nacionalidade.

11.4. REFLEXOS DA NACIONALIDADE

Em virtude dos dois critérios adotados para a determinação da nacionalidade primária, pode-se ter um polipátrida ou um apátrida.

O polipátrida é o indivíduo que possui mais de uma nacionalidade, o que acontece, por exemplo, quando seu nascimento se vincula aos dois critérios de determinação da nacionalidade primária. É o caso dos filhos cujos pais são oriundos de Estado que adota o critério do ius sanguinis e nascem num Estado que adota o do ius solis.

O apátrida ou "heimatlos" (expressão alemã) significa sem pátria, ou seja, indica que um indivíduo é desprovido de nacionalidade. É o caso dos filhos cujos pais são oriundos de Estado que adota o critério do ius solis e que nascem num Estado que adota o do ius sanguinis.

11.5. A NACIONALIDADE NO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

A aquisição da nacionalidade brasileira está prevista no art. 12 da Constituição Federal vigente. De acordo com a citada regra constitucional, os brasileiros podem ser: natos, que correspondem aos de nacionalidade primária (art. 12, I), e naturalizados, que são os que adotam a nacionalidade brasileira (art. 12, II).

No que diz respeito à legislação infraconstitucional referente à nacionalidade deve ser lida a Lei de Migração (Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017) que define os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante.

11.5.1. Os brasileiros natos

A Constituição considera brasileiro nato aquele que adquire a nacionalidade brasileira pelo fator nascimento. Somente o art. 12, I, da CF/88 fornece os critérios e pressupostos para que alguém seja considerado brasileiro nato, a saber:

a) **critério do ius solis (territorialidade):** são brasileiros natos os nascidos em território brasileiro, excetuados os filhos de pais estrangeiros quando no Brasil a serviço de seu país – art. 12, I, a, da CF/88;

O território é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo exclusivo o poder de império sobre as pessoas e os bens. São considerados território brasileiro:

- as terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, seus rios, lagos, baías, golfos, ilhas, bem como o espaço aéreo e o mar territorial;
- os navios e aeronaves de guerra brasileiros, onde quer que se encontrem;
- os navios mercantes brasileiros em alto-mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro; e
- as aeronaves civis brasileiras em voo sobre o alto-mar ou de passagem sobre águas territoriais ou espaços aéreos estrangeiros.

b) **critério do ius sanguinis aliado a serviço do Brasil:** são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (União, Estado, Município, Distrito Federal, Território e até entidades da Administração indireta). Não estão descartados os serviços realizados para empresas privadas contratadas por entes públicos (art. 12, I, b, da CF/88);

c) **critério do ius sanguinis somado à opção pessoal:** são exigidas as seguintes condições:

- ser nascido no estrangeiro;

- ser nascido de brasileiro ou brasileira, nato ou naturalizado;
- ser registrado em repartição brasileira competente;
- vir, a qualquer tempo, a residir no Brasil;
- optar, também a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, depois de atingida a maioridade (art. 12, I, c, da CF/88).

Tem-se, então, a aquisição da nacionalidade primária, unindo-se o critério do ius sanguinis, o vínculo territorial e ainda a manifestação da vontade do interessado maior de idade, à semelhança da nacionalidade secundária.

ATENÇÃO

Saliente-se que a Emenda Constitucional n. 54, de 20 de setembro de 2007, determinou que os filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro serão brasileiros natos, desde que seus pais providenciem o registro de seu nascimento em repartição brasileira competente (repartição diplomática ou consular).

Por fim, o art. 2.º da citada Emenda Constitucional n. 54/2007 estabelece que: “Os nascidos no estrangeiro entre 07 de junho de 1994 e a data da promulgação desta Emenda Constitucional [20-9-2007], filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil” (art. 95 do ADCT).

11.5.2. Os brasileiros naturalizados

Os brasileiros naturalizados são os estrangeiros que, por meio do processo de naturalização, adquirem a nacionalidade brasileira. O art. 12, II, da CF/88 estabelece tal situação. Além da previsão constitucional, existe a legislação infraconstitucional complementando as regras da naturalização (Lei de Migração – Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, e Decreto n.

9.199, de 20 de novembro de 2017).

Atualmente, só se reconhece a naturalização expressa, ou seja, aquela que depende de requerimento do naturalizando, que, de acordo com a doutrina e a previsão constitucional, compreende as duas classes abaixo mencionadas.

11.5.2.1. Naturalização ordinária

É a que se concede ao estrangeiro, residente no País, que preencha os requisitos previstos na Lei de Naturalização, exigidas aos originários de países de língua portuguesa (originários de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Açores, Cabo Verde, Príncipe, Goa, Gamão, Dio, Macau e Timor) apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral (art. 12, II, a, da CF/88).

11.5.2.2. Naturalização extraordinária

É a reconhecida aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal (no Brasil e no exterior), desde que requeiram a nacionalidade brasileira (art. 12, II, b, da CF/88). Adquire-se pelo simples fato de residência no País, por mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Justificativa: quem colaborou com o Estado brasileiro por tanto tempo sem ter condenação penal merece esse reconhecimento. Trata-se de um direito subjetivo do estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente no País, facultando-lhe pleitear a naturalização por mero requerimento.

11.6. ASPECTOS JURÍDICOS DO BRASILEIRO NATO E DO NATURALIZADO

Quando a Constituição mencionar em seu texto o termo brasileiro, sem qualquer predicativo, entende-se que a expressão inclui o brasileiro nato e o naturalizado. Quando o constituinte quiser excluir o brasileiro naturalizado,

mencionará expressamente em seu texto a expressão brasileiro nato.

As distinções existentes entre o brasileiro nato e o naturalizado são somente aquelas consignadas na Constituição. Nisso ela foi expressa no art. 12, § 2.º, segundo o qual: "A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição".

Na Constituição Federal vigente existem atualmente as seguintes limitações ao brasileiro naturalizado:

- a) são privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa (art. 12, § 3.º);
- b) é privativa de cidadão brasileiro nato a função de membro do Conselho da República (art. 89, VII);
- c) o brasileiro naturalizado há menos de 10 anos não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 222). Devem-se observar os §§ 1.º e 2.º do referido artigo, que restringem a participação de brasileiros naturalizados há 10 anos ou menos nos meios de comunicação;
- d) o brasileiro nato não pode ser extraditado, o que pode ocorrer com o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei (art. 5.º, LI).

Saliente-se que os brasileiros natos e naturalizados ou estrangeiros que se encontrem no Brasil podem ser entregues ao Tribunal Penal Internacional (art. 5.º, § 4.º, da CF/88 e art. 102 do Estatuto de Roma do TPI).

Observação: por entrega entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao Tribunal nos termos do Estatuto; por extradição entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado conforme previsto em tratado, em convenção ou no direito interno.

11.7. PERDA DA NACIONALIDADE

O § 4.º do art. 12 da CF vigente estabelece que perderá a nacionalidade brasileira aquele que: “I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis”.

O primeiro caso atingirá o brasileiro naturalizado e trata do cancelamento da naturalização válida e eficaz, por sentença judicial, obedecido o devido processo legal, onde se constata o exercício de atividade nociva ao interesse nacional. O efeito do cancelamento é de desconstituição da naturalização e atinge o ato com o trânsito em julgado da sentença, tendo efeito ex nunc.

O segundo caso de perda da nacionalidade refere-se tanto ao brasileiro nato quanto ao naturalizado e decorre da aquisição de outra nacionalidade por naturalização voluntária, ou seja, o nacional adquire voluntariamente outra nacionalidade. Esse ato engloba tanto o pedido como a aceitação da naturalização oferecida por outro Estado.

ATENÇÃO

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, dia 28 de março de 2017, o pedido de extradição de Cláudia Cristina Sobral, nascida no Brasil, requerido pelo governo dos Estados Unidos da América. Ela é acusada de ter assassinado o marido norte-americano no Estado de

Ohio, em 2007. O entendimento da Turma na Extradicação (EXT) 1462 é de que Cláudia renunciou à nacionalidade brasileira ao adotar a cidadania norte-americana em 1999.

O relator do processo, Ministro Luís Roberto Barroso, mencionou em seu voto a decisão já proferida pela Turma no julgamento do Mandado de Segurança (MS) 33.864, ocorrido em abril de 2016. Na ocasião, a defesa de Cláudia Cristina Sobral questionou portaria do Ministério da Justiça de 2013 na qual foi decretada a perda da nacionalidade brasileira, tendo em vista a aquisição voluntária da nova nacionalidade.

Segundo o art.12, § 4.º, II, da Constituição Federal, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. As exceções são o reconhecimento da nacionalidade originária pelo país estrangeiro ou a imposição da naturalização como condição para permanência ou exercício de direitos em outro país.

De acordo com os autos, a extraditanda mudou-se para os EUA em 1990 e obteve o green card. Em 1999, ao obter a cidadania norte-americana, nos termos da lei local, ela declarou renunciar e abjurar fidelidade a qualquer outro Estado ou soberania.

A decisão pela extradicação foi acompanhada por maioria do colegiado, vencido o Ministro Marco Aurélio. Ele considerou que o direito à nacionalidade é indisponível, observando ainda que, segundo a Constituição Federal, até mesmo para o estrangeiro naturalizado brasileiro perder essa condição é preciso sentença judicial, não apenas decisão administrativa.

Na decisão da Turma, ficou ressaltado que o deferimento do pedido da extradicação é condicionado ao compromisso formal de o país de destino não aplicar penas interditas pelo direito brasileiro, em especial a prisão perpétua ou pena de morte, bem como ficando a prisão restrita ao prazo máximo de 30 anos, como prevê o regramento brasileiro (STF, EXT 1.462, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28-3-2017).

11.8. REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA

O brasileiro naturalizado que teve a naturalização cancelada por atividade nociva ao interesse nacional poderá recuperá-la se o cancelamento for desfeito por ação rescisória.

A ação rescisória é um remédio processual que serve para desconstituir ou revogar acórdão ou sentença de mérito transitado em julgado. Essa ação deverá ser proposta dentro de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão (art. 966 do CPC/2015).

O que perdeu a nacionalidade por naturalização voluntária poderá readquiri-la, por decreto do Presidente da República, se estiver domiciliado

no Brasil. Destaque-se que essa reaquisição tem efeitos ex nunc e o nacional readquire a condição que perdera, ou seja, de brasileiro nato ou naturalizado.

IMPORTANTE

O Decreto n. 3.453/2000 delega ao Ministro da Justiça a competência para declarar a perda e a reaquisição da nacionalidade brasileira.

Decisões sobre o tema:

“As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de nacionalidade primária ou originária (da qual emana a condição de brasileiro nato), quer se cuide de nacionalidade secundária ou derivada (da qual resulta o status de brasileiro naturalizado), decorrem, exclusivamente, em função de sua natureza mesma, do texto constitucional, pois a questão da nacionalidade traduz matéria que se sujeita, unicamente, quanto à sua definição, ao poder soberano do Estado brasileiro” (QO no HC 83.113, j. 26-6-2003, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29-8-2003).

“O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado, pelo Brasil, a pedido de governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do jus solis, seja pelo critério do jus sanguinis, de nacionalidade brasileira primária ou originária. Esse privilégio constitucional, que beneficia, sem exceção, o brasileiro nato (CF, art. 5.º, LI), não se descaracteriza pelo fato de o Estado estrangeiro, por lei própria, haver-lhe reconhecido a condição de titular de nacionalidade originária pertinente a esse mesmo Estado (CF, art. 12, § 4.º, II, a). Se a extradição não puder ser concedida, por

inadmissível, em face de a pessoa reclamada ostentar a condição de brasileira nata, legitimar-se-á a possibilidade de o Estado brasileiro, mediante aplicação extraterritorial de sua própria lei penal (CP, art. 7.º, II, b, e respectivo § 2.º) – e considerando, ainda, o que dispõe o Tratado de Extradução Brasil/Portugal (art. IV) –, fazer instaurar, perante órgão judiciário nacional competente (CPP, art. 88), a concernede persecutio criminis, em ordem a impedir, por razões de caráter ético-jurídico, que práticas delituosas, supostamente cometidas, no exterior, por brasileiros (natos ou naturalizados), fiquem impunes” (QO no HC 83.113, j. 26-6-2003, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29-8-2003).

“A norma inscrita no art. 12, § 1.º, da CR – que contempla, em seu texto, hipótese excepcional de quase nacionalidade – não opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo eficaz, seja no que se refere a todas as consequências jurídicas que dela derivam, pois, para incidir, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, depende, ainda, de requerimento do súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher os requisitos estipulados pela Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses” (Extradução 890, 1.ª T., j. 5-8-2004, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28-10-2004). No mesmo sentido: HC 100.793, Plenário, j. 2-12-2010, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1.º-2-2011.

“Não se revela possível, em nosso sistema jurídico-constitucional, a aquisição da nacionalidade brasileira jure matrimonii, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil. Magistério da doutrina” (Extradução 1.121, Plenário, j. 18-12-2009, rel. Min. Celso de Mello, DJe 25-6-2010).

11.9. INSTITUTOS LIGADOS À NACIONALIDADE

11.9.1. Extradição

É o ato pelo qual um Estado entrega à Justiça de outro Estado um indivíduo acusado de um delito ou já condenado, por considerá-lo competente para julgá-lo e puni-lo.

Compete à União legislar sobre extradição (art. 22, XV), vigorando a respeito os arts. 81 a 99 da Lei n. 13.445/2017.

Limites constitucionais à extradição:

- a) art. 5.º, LI, da CF/88: “Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”;
- b) art. 5.º, LII, da CF/88: “Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião”.

Compete ao STF processar e julgar originariamente a extradição solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, g, da CF/88).

“Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro” (Súmula 421 do STF).

Decisões sobre o tema:

“Negativa, pelo Presidente da República, de entrega do extraditando ao país requerente. (...). O Tratado de Extradicação entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, no seu art. III, 1, f, permite a não entrega do cidadão da parte requerente quando ‘a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição’. (...). Deveras, antes de deliberar sobre a existência de poderes discricionários do Presidente da República em matéria de extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes da decisão proferida pelo Colegiado anteriormente, é necessário

definir se o ato do chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, em abstrato. O art. 1.º da CF assenta como um dos fundamentos do Estado brasileiro a sua soberania – que significa o poder político supremo dentro do território, e, no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do Brasil com outros Estados soberanos, nos termos do art. 4.º, I, da Carta Magna. A soberania nacional no plano transnacional funda-se no princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da República, consoante suas atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei Maior. A soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a exteriorização da vontade popular (art. 14 da CF) através dos representantes do povo no Parlamento e no governo; na segunda, a sua expressão no plano internacional, por meio do Presidente da República. No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável do presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas Leis, nos Tratados e na própria decisão do E. STF na Ext 1.085. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao STF, que não exerce soberania internacional, máxime para impor a vontade da República italiana ao chefe de Estado brasileiro, cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art. 92 da Carta das Nações Unidas de 1945” (Rcl 11.243, Plenário, j. 8-6-2011, rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 5-10-2011).

“Questão sobre existência jurídica, validade e eficácia de ato administrativo que conceda refúgio ao extraditando é matéria preliminar inerente à cognição do mérito do processo de extradição e, como tal, deve ser conhecida de ofício ou mediante provocação de interessado jurídico na causa. (...). Eventual nulidade absoluta do ato administrativo que concede refúgio ao extraditando deve ser pronunciada, mediante provocação ou de ofício, no processo de extradição. (...). Não configura

crime político, para fim de obstar o acolhimento de pedido de extradição, homicídio praticado por membro de organização revolucionária clandestina, em plena normalidade institucional de Estado Democrático de Direito, sem nenhum propósito político imediato ou conotação de reação legítima a regime opressivo. (...). Não caracteriza a hipótese legal de concessão de refúgio, consistente em fundado receio de perseguição política, o pedido de extradição para regular execução de sentenças definitivas de condenação por crimes comuns, proferidas com observância do devido processo legal, quando não há prova de nenhum fato capaz de justificar receio atual de desrespeito às garantias constitucionais do condenado” (Ext 1.085, Plenário, j. 16-12-2009, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 16-4-2010).

“Extradição e prisão perpétua: necessidade de prévia comutação, em pena temporária (máximo de trinta anos), da pena de prisão perpétua. Revisão da jurisprudência do STF, em obediência à Declaração Constitucional de Direitos (art. 5.º, XLVII, b, da CF). A extradição somente será deferida pelo STF, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir, formalmente, quanto a ela, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (art. 75 do CP), eis que os pedidos extradicionais – considerado o que dispõe o art. 5.º, XLVII, b, da CF, que veda as sanções penais de caráter perpétuo – estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Novo entendimento derivado da revisão, pelo STF, de sua jurisprudência em tema de extradição passiva” (Ext 855, Plenário, j. 26-8-2004, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1.º-7-2005). No mesmo sentido: Ext 1.201, Plenário, j. 17-2-2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15-3-2011.

“A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência more uxorio do extraditando com pessoa de

nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. (...). Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que, com esta, possua filho brasileiro. A Súmula 421 do STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (Ext 1.201, Plenário, j. 17-2-2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15-3-2011). No mesmo sentido: Ext 1.196, Plenário, j. 16-6-2011, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26-9-2011.

ATENÇÃO

“STF encaminha pedido de extradição de Pizzolato ao Ministério da Justiça” – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, determinou o encaminhamento, ao Ministério da Justiça, do pedido de extradição de Henrique Pizzolato, condenado na Ação Penal (AP) 470.

A decisão responde a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que encaminhe a extradição ao Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Preso em Modena, na Itália, no último dia 5, Pizzolato foi condenado a 12 anos e sete meses de prisão pela prática dos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, por seu envolvimento no desvio de recursos do Banco do Brasil relacionado ao conjunto de ações ligadas ao chamado “mensalão”. A decisão do Ministro Joaquim Barbosa

determina ainda o encaminhamento ao Ministério da Justiça da certidão de trânsito em julgado da condenação de Henrique Pizzolato, de seu mandado de prisão e da decisão que mandou expedir-lo. Também ficou registrado no despacho proferido pelo ministro que a PGR fica incumbida de preparar toda a documentação, inclusive as traduções exigidas pelo Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália. À PGR caberá também instruir o pedido de extradição, podendo-se valer, se necessário, do apoio da Secretaria do STF.

Se o crime político for infração penal comum ou o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal, será possível a extradição (art. 82, § 1.º, da Lei n. 13.445/2017).

11.9.2. Expulsão

Expulsão é um modo coativo de retirar o estrangeiro do território nacional por delito, infração ou ato que o torne inconveniente à defesa e à conservação da ordem interna do Estado. A União é a entidade política que tem a competência para legislar sobre expulsão (art. 22, XV, da CF/88).

É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à convivência e aos interesses nacionais, entre outros casos previstos em lei (arts. 54 a 60 da Lei 13.445/2017).

Compete exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão, ou sua revogação, que se fará por decreto passível de controle de constitucionalidade e de legalidade pelo Poder Judiciário.

Não ocorrerá a expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira ou o expulsando:

- a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela;
- b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente;
- c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no país;
- d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10 (dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão (art. 55 da Lei n. 13.445/2017)

11.9.3. Deportação

É a saída compulsória do estrangeiro que ingressou ou permanece

irregularmente no território nacional, ou seja, é o modo coativo de devolver o estrangeiro ao exterior em virtude de desobediência ao ordenamento jurídico que trata da entrada e permanência no Brasil (art. 5.º, XV, da CF/88).

A deportação não decorre da prática de delito no território, mas do não cumprimento dos requisitos para entrar ou permanecer no território. Quando o estrangeiro não se retirar voluntariamente no prazo determinado, será feita a deportação para o país de origem ou de procedência dele, ou para outro que consinta em recebê-lo. Não sendo ela exequível ou existindo indícios sérios de periculosidade ou de indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á a sua expulsão. Mas não se dará a deportação se esta implicar em extradição vedada pela lei brasileira (art. 53 da Lei n. 13.445/2017).

Em resumo:

- a) **extradição**: há um delito praticado fora do território nacional. É vedada de modo absoluto a de brasileiro nato, sendo possível a de brasileiro naturalizado;
- b) **expulsão**: há um delito praticado no território nacional por estrangeiro. Não há expulsão de brasileiro; e
- c) **deportação**: é a devolução compulsória de estrangeiro pelo não cumprimento dos requisitos para entrar ou permanecer no território. Não há deportação de brasileiro.

Cumprir destacar que não existe mais o instituto do banimento, que era o envio compulsório de brasileiro para o exterior. Há, inclusive, a vedação constitucional de seu restabelecimento no art. 5.º, XLVII, d, da CF/88. Segundo a doutrina, o banimento temporário é chamado de ostracismo.

ATENÇÃO

Se na questão de prova for feita menção ao termo entrega trata-se do tema Tribunal Penal Internacional (Estatuto de Roma – Decreto n. 4.388/2002). Nesse caso, podem ser entregues brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros ao TPI.

11.9.4. A língua e os símbolos nacionais

A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil (art. 13, caput, da CF/88), podendo as comunidades indígenas utilizar também suas línguas maternas (art. 210, § 2.º, da CF/88).

A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional são símbolos da República Federativa do Brasil, podendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ter símbolos próprios (art. 13, §§ 1.º e 2.º, da CF/88).

11.9.5. Assuntos pertinentes aos estrangeiros

Locomoção no território nacional: é livre como a qualquer brasileiro (art. 5.º, XV, da CF/88). A lei, contudo, disciplina o direito de qualquer pessoa entrar no território nacional, nele permanecer ou dele sair só ou com seus bens (art. 5.º, XV, da CF/88). A lei que regula esses preceitos no tocante aos estrangeiros é o Estatuto do Estrangeiro supracitado.

Entrada: todo estrangeiro pode entrar no País, desde que preencha os requisitos legais e obtenha visto de entrada (temporário, de cortesia, oficial ou diplomático). Não se concede visto a estrangeiro menor de 18 anos, desacompanhado de seu responsável.

Permanência: deverá registrar-se no Ministério da Justiça e obter o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).

Aquisição e perda dos direitos civis: a lei não distingue nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e gozo dos direitos civis. Só haverá distinção quando a Constituição Federal autorizar.

Limitações: a Constituição Federal determina que cabe à lei disciplinar os investimentos de capital estrangeiro e regular a remessa de lucros para o

exterior (art. 172 da CF/88).

“A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo [jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica] somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou por empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas” (art. 176, § 1.º, da CF/88).

Não podem também os estrangeiros ser proprietários de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nem responsáveis por sua administração e orientação intelectual (art. 222 da CF/88).

Aquisição de direitos políticos: os estrangeiros não adquirem direitos políticos, não podem votar nem ser votados (art. 14, § 2.º, da CF/88), nem intentar ação popular (art. 5.º, LXXIII, da CF/88).

Asilo político: é o recebimento de estrangeiro no território nacional, sem os requisitos de ingresso, a seu pedido, para evitar punição ou perseguição no seu país de origem, por delito de natureza política ou ideológica. A Constituição Federal vigente prevê a concessão de asilo político (art. 4.º, X). O asilado não poderá sair do País sem prévia autorização do governo brasileiro, sob pena de renúncia ao asilo e de impedimento de reingresso nessa condição.

Portugueses residentes no Brasil: vide Decreto n. 3.927/2001 – Tratado de Amizade (art. 12, § 1.º, da CF/88).

IMPORTANTE

Devem ser lidos: a Lei de Migração (Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017) e o Decreto n. 9.199,

de 20 de novembro de 2017.

Direitos políticos

Os direitos políticos merecem um relevo especial na estrutura do Estado contemporâneo. Com o advento da democracia, a cada dia uma soma maior de pessoas interfere na vida política do País, e o faz através do uso e gozo dos direitos políticos. Tais direitos implicam em um conjunto de regras que possibilita a participação dos cidadãos (eleitores) na distribuição do poder no Estado. No Brasil, o cidadão participa ativamente da composição dos Poderes Legislativo e Executivo.

De modo geral, os direitos políticos são os que asseguram a participação do indivíduo no governo de seu país, seja votando, seja sendo votado.

Infere-se que os direitos políticos estão intimamente ligados à cidadania e consistem na reunião dos meios necessários ao exercício da chamada soberania popular, ou seja, o poder que os cidadãos têm através do voto para interferir na estrutura do governo de um Estado.

12.1. CIDADANIA

A doutrina afirma que a cidadania formal é a participação dos cidadãos (eleitores) na vida do Estado através do voto, e a cidadania material ou real vai além desse ato, com a participação da população na fiscalização e resolução dos problemas do Estado. Pode ser externada através de campanhas de moralização das instituições públicas, de formação de organizações não governamentais para incentivo e auxílio nas atividades do Estado, de denúncias de corrupção e desvio de verbas públicas, entre outros.

Em sentido estrito (jurídico), cidadão é o indivíduo dotado de capacidade eleitoral ativa (votar), podendo, se preencher determinadas exigências legais, possuir também a capacidade eleitoral passiva (ser votado).

12.1.1. Aquisição da cidadania

Os direitos da cidadania adquirem-se mediante alistamento eleitoral na forma da lei. O alistamento se faz mediante qualificação e inscrição da pessoa como eleitor perante a Justiça Eleitoral.

A qualidade de eleitor decorre do alistamento, obrigatório para os brasileiros de ambos os sexos, maiores de 18 anos de idade, e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos (art. 14, § 1.º, I e II, da CF/88).

Não são alistáveis como eleitores, os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório (art. 14, § 2.º, da CF/88). Os conscritos são os nacionais convocados para o serviço militar obrigatório; porém, se se engajarem no serviço militar permanente, serão obrigados a se alistar como eleitores.

Segundo a legislação infraconstitucional, as providências para o alistamento deverão se efetivar ao brasileiro nato até os 19 anos de idade e ao naturalizado até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, sob pena de multa (cf. art. 8.º da Lei n. 4.737/65).

Em suma, a cidadania é adquirida com a obtenção do título de eleitor válido, qualificando o nacional como eleitor.

12.1.2. Institutos de participação direta do povo

Iniciativa popular: o povo (conjunto de eleitores) pode apresentar projetos de lei, desde que subscritos por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Devem ser apresentados à Câmara

dos Deputados (art. 14, III, e art. 61, § 2.º, da CF/88).

Referendo popular: é uma consulta popular em que existe a ratificação do povo sobre projetos de lei, já aprovados pelo Legislativo, de modo que o projeto só será aprovado se receber votação favorável do corpo eleitoral – do contrário, reputar-se-á rejeitado (art. 14, II, da CF/88). É atribuição exclusiva do Congresso Nacional autorizá-lo (art. 49, XV, da CF/88).

Plebiscito: consiste, também, em uma consulta popular e visa a decidir previamente um assunto institucional ou político antes dos trâmites legislativos (art. 14, I, da CF/88). Por esse motivo se diferencia do referendo popular, que, como visto acima, versa sobre a aprovação de textos de projeto de lei ou de emenda constitucional já aprovados pelo Poder Legislativo.

O plebiscito pode autorizar o início de um processo legislativo, enquanto o referendo ratifica ou rejeita projeto já elaborado.

O plebiscito é indicado em casos específicos, como a formação de novos Estados e de novos Municípios (art. 18, §§ 3.º e 4.º, da CF/88). Compete ao Congresso Nacional convocar o plebiscito (art. 49, XV, da CF/88).

ATENÇÃO

Art. 2.º do ADCT da CF/88: “No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País”.

Cumpre destacar que os três institutos jurídico-constitucionais mencionados foram regulamentados pela Lei n. 9.709/98.

12.2. ALISTABILIDADE E ELEGIBILIDADE

A alistabilidade diz respeito à capacidade eleitoral ativa, ou seja, à capacidade de ser eleitor, e a elegibilidade diz respeito à capacidade

eleitoral passiva, ou seja, à capacidade de ser eleito.

Vale lembrar que nem sempre da alistabilidade decorre a elegibilidade.

Na forma da lei, existem as seguintes condições de elegibilidade (art. 14, § 3.º, da CF/88):

- a) nacionalidade brasileira: no caso de candidato a Presidente e a Vice-Presidente da República, exige-se ser brasileiro nato (art. 12, § 3.º, I, da CF/88);
- b) pleno exercício dos direitos políticos (direito de votar e de ser votado);
- c) alistamento eleitoral (título de eleitor);
- d) domicílio eleitoral na circunscrição eleitoral correspondente (Presidente – todo o País; Governador, Senadores, Deputados Federais, Estaduais e Distritais – o Estado ou o Distrito Federal; Prefeitos e Vereadores – o Município);
- e) filiação partidária;
- f) idade mínima (conforme o caso: 35 anos para Presidente da República, Vice-Presidente e Senador; 30 anos para Governador e Vice-Governador; 21 anos para Deputados, Prefeito e Vice-Prefeito, Juiz de Paz e Ministro de Estado; e 18 anos para Vereador).

Ressalte-se que os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis (art. 14, § 4.º, da CF/88).

Por fim, devemos observar que elegibilidade e inelegibilidade são matérias da Constituição Federal e de competência legislativa federal naquilo em que a própria Constituição permita ser objeto de lei complementar ou de lei ordinária, pois cabe à União legislar sobre cidadania (direitos políticos) e direito eleitoral (art. 22, I e XIII, da CF/88).

12.2.1. Sufrágio

É o direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão de eleger, ser eleito e participar do governo.

Formas de sufrágio

Quanto à extensão, pode ser:

- a) **universal**: é o direito de votar titularizado por todos os nacionais com capacidade política. Essa é a forma acolhida pela nossa Constituição Federal vigente em seu art. 14, caput;
- b) **restrito**: é o direito de voto conferido a indivíduos qualificados por condições econômicas (censitário) ou intelectuais (capacitário).

Quanto à igualdade, pode ser:

- a) **igual**: os votos são iguais, ou seja, têm o mesmo valor;
- b) **desigual**: concede-se a certos eleitores em virtude de situações especiais o direito de votar mais de uma vez ou de dispor de mais de um voto para prover o mesmo cargo.

Espécies:

- a) **voto múltiplo**: o eleitor tem o direito de votar mais de uma vez, ou seja, em mais de uma circunscrição eleitoral, e pode votar, por exemplo, na circunscrição do seu domicílio, no de seu local de trabalho, entre outros;
- b) **voto plural**: o eleitor pode votar mais de uma vez em uma mesma circunscrição, ou seja, poderá votar duas ou mais vezes no mesmo local;
- c) **voto familiar**: o eleitor chefe de família (pai) dispõe de um ou mais votos em função do número dos membros do núcleo familiar.

Cabe observar que o voto é a manifestação do sufrágio no plano prático. É o ato político que materializa na prática o direito de votar.

O voto tem como características ser secreto (ninguém, além do eleitor, deve conhecer o candidato quando da votação); igual (mesmo peso político para todos os eleitores); livre (o cidadão vota em quem quiser e se quiser,

pois pode votar em branco ou anular o voto); pessoal (não se admite voto por correspondência ou procuração); direto (os eleitores escolhem por si e sem intermediários os governantes e representantes); e, por fim, de acordo com a nossa Constituição Federal vigente, é também obrigatório (os eleitores não podem se eximir de votar, salvo motivo justo).

Cumpre lembrar que escrutínio é o modo pelo qual os votos são recolhidos e apurados nas eleições.

Desse modo, sufrágio é um direito; voto é o exercício desse direito; e escrutínio é o modo de apuração dos votos.

12.3. SISTEMAS ELEITORAIS

O sistema eleitoral é um conjunto de regras que tem por fim organizar as eleições. No Brasil, atualmente, pode ser de dois tipos. Veremos a seguir.

12.3.1. Sistema majoritário

É o sistema em que vence a eleição o candidato que obtiver a maioria dos votos. Pode ser:

- a) **maioria simples (ou sistema de escrutínio a um só turno):** pelo qual, por uma única votação, se proclama o candidato que tiver obtido a maioria simples ou relativa;
- b) **maioria absoluta:** segundo o qual somente se considerará eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos em primeiro turno. Se nenhum candidato conseguir, será feito o segundo turno, normalmente entre os dois mais votados, e deste modo um deverá alcançar a maioria absoluta dos votos. Por esse motivo o sistema por maioria absoluta é também conhecido por sistema majoritário a dois turnos ou sistema de escrutínio a dois turnos.

O sistema majoritário, de acordo com a Constituição Federal, é usado da

seguinte forma:

- a) por maioria absoluta (se necessário em dois turnos) para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da República (art. 77 e § 2.º); de Governador e Vice-Governador de Estado (art. 28) ou Distrito Federal (§ 2.º do art. 32); e de Prefeito e Vice-Prefeito para Municípios com mais de 200 mil eleitores (art. 29, II);
- b) por maioria relativa para a eleição de Senadores Federais (art. 46) e Prefeitos de Municípios com 200 mil eleitores ou menos (art. 29, II).

12.3.2. Sistema proporcional

Neste sistema a representação se dá na mesma proporção da preferência do eleitorado pelos partidos políticos. É o sistema adotado para a eleição de Deputados Federais (art. 45), Deputados Estaduais (§ 1.º do art. 27), Deputados Distritais (§ 3.º do art. 32) e Vereadores por extensão.

Mecanismo a ser adotado:

- a) determinar os votos válidos (dados à legenda e aos candidatos);
- b) determinar o quociente eleitoral, dividindo o número de votos válidos pelo número de lugares a preencher (de acordo com o caso, despreza-se a fração igual ou inferior a 0,5 e arredonda-se para uma fração superior a 0,5);
- c) determinar o quociente partidário, que é o número de lugares cabível a cada partido, que se obtém dividindo o número de votos obtidos pela legenda (incluindo os dos candidatos) pelo quociente eleitoral, desprezada a fração;
- d) distribuir os restos: podem sobrar lugares a serem preenchidos em consequência de restos de votos em cada legenda não suficientes para fazer mais um eleito. O direito brasileiro adotou o método de maior média, que consiste em adicionar mais um lugar aos obtidos por cada

um dos partidos. Caberá ao partido que obtiver a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha o candidato atendido a exigência de votação mínima repetindo-se a mesma operação tantas vezes quantos forem os lugares restantes que devam ser preenchidos (art. 109 do Código Eleitoral). Cabe observar que somente concorrerão a essa distribuição os partidos que tiverem quociente eleitoral, ou seja, que elegeram pelo menos um candidato.

IMPORTANTE

No Brasil, só os votos válidos são considerados na eleição (art. 77, § 2.º, da CF/88). Se houver empate entre candidatos qualifica-se o mais idoso (art. 77, § 5.º, da CF/88).

12.4. RESTRIÇÕES AOS DIREITOS POLÍTICOS

As restrições aos direitos políticos podem ser entendidas como regras que proíbem a pessoa de votar e de ser eleito, previstas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A privação definitiva denomina-se perda dos direitos políticos, e a privação temporária é conhecida como suspensão. A Constituição Federal vigente, no art. 15, não indica expressamente quais os casos de perda e de suspensão, mas a doutrina procura elucidar essa questão, de modo que são casos de suspensão:

inciso I: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

inciso II: incapacidade civil absoluta (interdição do incapaz). Por exemplo: menores de 16 anos de idade, entre outros;

inciso III: condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

inciso IV: recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5.º, VIII, da CF/88;

inciso V: improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4.º, da CF/88.

Por conseguinte, é caso de perda o inciso I do mesmo art. 15: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, atentando-se para o prazo de dois anos da ação rescisória.

A competência para decidir sobre a perda ou suspensão dos direitos políticos é do Poder Judiciário (art. 5.º, XXXV, da CF/88).

12.5. REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

A reaquisição dos direitos políticos suspensos se dará automaticamente, com a cessação dos motivos que determinaram a suspensão.

No caso da escusa de consciência (art. 15, IV, da CF/88), pode a pessoa readquiri-los, declarando, perante a autoridade competente (Ministro da Justiça ou outro órgão a que a lei der competência), que está pronta para suportar o ônus que recusou. A Lei n. 8.239/91 prevê essa reaquisição, quando diz que o inadimplente poderá a qualquer tempo regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas (art. 4.º, § 2.º).

No caso de perda dos direitos políticos por cancelamento da naturalização, o indivíduo não os readquirirá mais, a menos que, por ação rescisória (prazo de dois anos do trânsito em julgado), seja rescindido o julgado, de modo que o naturalizado recuperará a nacionalidade brasileira, ficando obrigado a novo alistamento eleitoral.

12.6. INELEGIBILIDADES

As inelegibilidades são impedimentos à capacidade eleitoral passiva. Os casos estão previstos dos §§ 4.º a 7.º do art. 14 da Constituição Federal vigente.

As normas constitucionais sobre inelegibilidade são de eficácia plena e de aplicação imediata. As inelegibilidades serão analisadas a seguir.

12.6.1. Absolutas

Impedem que o indivíduo concorra a qualquer cargo eletivo. São casos excepcionais, que devem ser previstos apenas pela Constituição Federal. São os seguintes esses casos:

- a) os analfabetos podem votar, porém não podem concorrer a nenhum cargo político eletivo (Executivo e Legislativo) – possuem apenas a capacidade eleitoral ativa;
- b) os inalistáveis são aquelas pessoas que não podem se alistar nas repartições eleitorais, ou seja, não podem adquirir o título de eleitor e, por consequência, não podem votar nem ser votados. São eles os menores de 16 anos de idade, os estrangeiros, os conscritos e os privados definitiva ou temporariamente dos seus direitos políticos.

12.6.2. Relativas

Consistem em restrições à elegibilidade para determinados mandatos em razão de situações especiais em que, no momento da eleição, se encontre o cidadão. Podem ser previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional. O cidadão é elegível, mas sofre certas restrições. Analisaremos as espécies a seguir.

12.6.2.1. Restrição por motivos funcionais

Para o mesmo cargo: não existe mais (Emenda Constitucional n. 16/97 – da reeleição). Os ocupantes dos cargos do Poder Executivo podem ser reeleitos para um único período subsequente (art. 14, § 5.º, da CF/88).

Para outros cargos: são inelegíveis para concorrer a outros cargos os titulares de cargos do Poder Executivo que não renunciarem aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. É uma das hipóteses da chamada desincompatibilização concretizada pela renúncia (art. 14, § 6.º, da CF/88).

12.6.2.2. Restrição por motivo de casamento, parentesco ou afinidade

São inelegíveis no território da circunscrição (e não de jurisdição, como prevê a CF/88 no art. 14, § 7.º) do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins (sogra, cunhado), até o 2.º grau ou por adoção, dos cargos do Poder Executivo ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição. Essa restrição é também conhecida como inelegibilidade reflexa. Por exemplo: o cônjuge e parentes até o 2.º grau consanguíneos ou afins de Prefeito não podem se candidatar a Vereador ou Prefeito. O cônjuge e parentes até o 2.º grau consanguíneos ou afins de Governador não poderão se candidatar a qualquer cargo eletivo no Estado (Vereador, Prefeito, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador e Governador do mesmo Estado). Cumpre observar que a Constituição permite que concorra à reeleição o cônjuge, parente ou afim que já possuir mandato eletivo.

ATENÇÃO

“A Súmula Vinculante 18 do STF não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges”.

12.6.2.3. Restrição dos militares

O militar alistável é elegível, desde que: se contar com menos de dez anos de serviço, afastar-se da atividade; se contar com mais de dez anos de serviço, for agregado pela autoridade superior; e, se eleito, passar automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade (art. 14, § 8.º, da CF/88).

12.6.2.4. Restrição por previsões de ordem legal

A Constituição Federal, no § 9.º do art. 14, autorizou a edição de lei

complementar (LC n. 64/90 e 81/94) para dispor sobre outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Infere-se que a lei complementar é a única espécie normativa autorizada constitucionalmente para disciplinar a criação e estabelecer os prazos de duração de outras inelegibilidades relativas, sendo-lhe proibida a criação de inelegibilidade absoluta, pois esta é prevista expressamente.

12.6.2.5. Restrição por motivo de domicílio eleitoral na circunscrição

Os candidatos aos cargos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, deverão ter domicílio eleitoral na circunscrição em que concorrerem.

12.7. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

É o ato pelo qual o candidato se desvincula da inelegibilidade a tempo de concorrer à eleição. Em algumas hipóteses, a desincompatibilização só se dará com o afastamento definitivo da situação funcional em que se ache o candidato, o cônjuge ou o parente. Em outros casos, basta o licenciamento (autoridades policiais, agentes administrativos, entre outros).

O § 6.º do art. 14 da CF/88 estabelece que, “para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito”.

Decisões sobre o tema:

“O domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária, constituindo condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 3.º), revelam-se passíveis de válida disciplinação mediante simples lei ordinária. Os requisitos de elegibilidade não se confundem, no plano jurídico-conceitual, com as hipóteses de inelegibilidade, cuja definição – além das situações já previstas diretamente pelo próprio texto constitucional (CF, art. 14, §§ 5.º a 8.º) – só pode derivar de norma inscrita em lei complementar (CF,

art. 14, § 9.º)” (STF, ADIn 1.063-MC/DF, j. 18-5-1994, rel. Min. Celso de Mello, DJ 27-4-2001).

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em duas ações diretas de inconstitucionalidade, a primeira ajuizada contra a Resolução n. 22.610/2007, pelo Partido Social Cristão – PSC, e a segunda, também contra a Resolução n. 22.733/2008, pelo Procurador-Geral da República, ambas do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, as quais disciplinam o processo de perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa, bem como de justificação de desfiliação partidária. Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu das ações (...). No mérito, julgaram-se válidas as resoluções impugnadas até que o Congresso Nacional disponha sobre a matéria. Considerou-se a orientação fixada pelo Supremo no julgamento dos MS 26.602/DF (DJe 17-10-2008), 26.603/DF (j. 4-10-2007) e 26.604/DF (DJe 3-10-2008), no sentido de reconhecer aos partidos políticos o direito de postular o respeito ao princípio da fidelidade partidária perante o Judiciário, e de, a fim de conferir-lhes um meio processual para assegurar concretamente as consequências decorrentes de eventual desrespeito ao referido princípio, declarar a competência do TSE para dispor sobre a matéria durante o silêncio do Legislativo. Asseverou-se que de pouco adiantaria a Corte admitir a existência de um dever, qual seja a fidelidade partidária, mas não colocar à disposição um mecanismo ou um instrumental legal para garantir sua observância. Salientando que a ausência do mecanismo leva a quadro de exceção, interpretou-se a adequação das resoluções atacadas ao art. 23, IX, do Código Eleitoral, este interpretado conforme a CF. Concluiu-se que a atividade normativa do TSE recebeu seu amparo da extraordinária circunstância de o Supremo ter reconhecido a fidelidade partidária como requisito para permanência em cargo eletivo e a ausência expressa de mecanismo destinado a assegurá-lo” (STF, ADIn 3.999 e ADIn 4.086, j. 12-11-2008, rel. Min. Joaquim Barbosa,

Informativo 528). No mesmo sentido: STF, AgIn 733.387/DF, j. 16-12-2008, rel. Min. Celso de Mello, Informativo 533.

“Inelegibilidade. Art. 14, § 7.º, da Constituição do Brasil. O art. 14, § 7.º, da Constituição do Brasil deve ser interpretado de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder” (STF, RE 543.117-AgRg/AM, j. 24-6-2008, rel. Min. Eros Grau, DJe 22-8-2008).

“Elegibilidade de ex-cônjuge de prefeito reeleito. Cargo de vereador. Impossibilidade. Art. 14, § 7.º, da Constituição. Separação judicial no curso do segundo mandato eletivo. Separação de fato no curso do primeiro mandato eletivo. Oportuna desincompatibilização. Inocorrência. (...) A dissolução da sociedade conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7.º, da CF/88. Se a separação judicial ocorrer em meio à gestão do titular do cargo que gera a vedação, o vínculo de parentesco, para os fins de inelegibilidade, persiste até o término do mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge ao pleito subsequente, na mesma circunscrição, a não ser que aquele se desincompatibilize seis meses antes das eleições” (STF, RE 568.596/MG, j. 1.º-10-2008, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21-11-2008).

“Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de vereador. CF, art. 14, § 6.º. Inaplicabilidade das regras dos §§ 5.º e 7.º do art. 14, CF” (STF, RE 345.822/SP, j. 18-11-2003, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12-12-2003).

“As condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 3.º) e as hipóteses de inelegibilidade (CF, art. 14, § 4.º a § 8.º), inclusive aquelas decorrentes de legislação complementar (CF, art. 14, § 9.º), aplicam-se de pleno direito, independentemente de sua expressa previsão na lei local, à eleição indireta para governador e vice-governador do Estado, realizada

pela Assembleia Legislativa em caso de dupla vacância desses cargos executivos no último biênio do período de governo” (STF, ADIn 1.057-MC/BA, j. 20-4-1994, rel. Min. Celso de Mello, DJ 6-4-2001).

“A exigência de coisa julgada – que representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica – não colide, por isso mesmo, com a cláusula de probidade administrativa nem com a que se refere à moralidade para o exercício do mandato eletivo, pois a determinação de que se aguarde a definitiva formação da autoridade da res judicata, além de refletir um claro juízo de prudência do legislador, quer o constituinte (CF, art. 15, III), quer o comum (LC n. 64/90, art. 1.º, I, d, g e h), encontra plena justificação na relevantíssima circunstância de que a imposição, ao cidadão, de gravíssimas restrições à sua capacidade eleitoral, deve condicionar-se ao trânsito em julgado da sentença, seja a que julga procedente a ação penal, seja aquela que julga procedente a ação civil por improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92, art. 20, caput). Mostra-se relevante acentuar o alto significado que assume, em nosso sistema normativo, a coisa julgada, pois, ao propiciar a estabilidade das relações sociais e, ao dissipar as dúvidas motivadas pela existência de controvérsia jurídica (res judicata pro veritate habetur) e, ao viabilizar a superação dos conflitos, culmina por consagrar a segurança jurídica, que traduz, na concreção de seu alcance, valor de transcendente importância política, jurídica e social, a representar um dos fundamentos estruturantes do próprio Estado Democrático de Direito” (STF, AC 2.763-MC/RO, j. 16-12-2010, decisão monocrática, rel. Min. Celso de Mello, DJe 1.º-2-2011).

“Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do

cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. Inteligência do disposto no § 5.º do art. 14 da CF” (STF, RE 366.488/SP, j. 4-10-2005, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28-10-2005). No mesmo sentido: STF, AgIn 782.434-AgRg, j. 8-2-2011, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24-3-2011.

“Diversamente do que sucede ao militar com mais de dez anos de serviço, deve afastar-se definitivamente da atividade o servidor militar que, contando menos de dez anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo” (STF, RE 279.469, j. 16-3-2011, rel. p/ o Ac. Min. Cezar Peluso, DJe 20-6-2011).

“A perda da elegibilidade constitui situação impregnada de caráter excepcional, pois inibe o exercício da cidadania passiva, comprometendo a prática da liberdade em sua dimensão política, eis que impede o cidadão de ter efetiva participação na regência e na condução do aparelho governamental” (STF, AC 2.763-MC, j. 16-12-2010, decisão monocrática, rel. Min. Celso de Mello, DJe 1.º-2-2011).

12.8. PARTIDOS POLÍTICOS

É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional; proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; prestação de contas à Justiça Eleitoral; e funcionamento parlamentar de acordo com a lei (art. 17, I a IV, da CF/88).

Aos partidos políticos é assegurada “autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas

eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária” (art. 17, § 1.º, da CF/88).

Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (art. 17, § 2.º, da CF/88).

Destaque-se que somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

II – tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação (art. 17, § 3.º, da CF/88).

IMPORTANTE

É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar (art. 17, § 4.º, da CF/88). São características de organização paramilitar a existência de armamento, fardamento ou uniforme e hierarquia e disciplina.

ATENÇÃO

- “Lei Complementar n. 135/2010, denominada Lei da Ficha Limpa. Inaplicabilidade às eleições gerais de 2010. (...) O pleno exercício de direitos políticos por seus titulares (eleitores, candidatos e partidos) é assegurado pela Constituição por meio de um sistema de normas que conformam o que se poderia denominar devido processo legal eleitoral. Na medida em que

estabelecem as garantias fundamentais para a efetividade dos direitos políticos, essas regras também compõem o rol das normas denominadas cláusulas pétreas e, por isso, estão imunes a qualquer reforma que vise a aboli-las. O art. 16 da Constituição, ao submeter a alteração legal do processo eleitoral à regra da anualidade, constitui uma garantia fundamental para o pleno exercício de direitos políticos. Precedente: ADIn 3.685, j. 22-3-2006, rel. Min. Ellen Gracie. A LC n. 135/2010 interferiu numa fase específica do processo eleitoral, qualificada na jurisprudência como a fase pré-eleitoral, que se inicia com a escolha e a apresentação das candidaturas pelos partidos políticos e vai até o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Essa fase não pode ser delimitada temporalmente entre os dias 10 e 30 de junho, no

qual ocorrem as convenções partidárias, pois o processo político de escolha de candidaturas é muito mais complexo e tem início com a própria filiação partidária do candidato, em outubro do ano anterior. A fase pré-eleitoral de que trata a jurisprudência desta Corte não coincide com as datas de realização das convenções partidárias. Ela começa muito antes, com a própria filiação partidária e a fixação de domicílio eleitoral dos candidatos, assim como o registro dos partidos no TSE. A competição eleitoral se inicia exatamente um ano antes da data das eleições e, nesse interregno, o art. 16 da Constituição exige que qualquer modificação nas regras do jogo não terá eficácia imediata para o pleito em curso. (...) Toda limitação legal ao direito de sufrágio passivo, isto é, qualquer restrição legal à elegibilidade do cidadão constitui uma limitação da igualdade de oportunidades na competição eleitoral. Não há como conceber causa de inelegibilidade que não restrinja a liberdade de acesso aos cargos públicos, por parte dos candidatos, assim como a liberdade para escolher e apresentar candidaturas por parte dos partidos políticos. E um dos fundamentos teleológicos do art. 16 da Constituição é impedir alterações no sistema eleitoral que venham a atingir a igualdade de participação no prélio eleitoral. (...) O princípio da anterioridade eleitoral constitui uma garantia fundamental também destinada a assegurar o próprio exercício do direito de minoria parlamentar em situações nas quais, por razões de conveniência da maioria, o Poder Legislativo pretenda modificar, a qualquer tempo, as regras e critérios que regerão o processo eleitoral. A aplicação do princípio da anterioridade não depende de considerações sobre a moralidade da legislação. O art. 16 é uma barreira objetiva contra abusos e desvios da maioria, e dessa forma deve ser aplicado por esta Corte.

A proteção das minorias parlamentares exige reflexão acerca do papel da Jurisdição Constitucional nessa tarefa. A jurisdição constitucional cumpre a sua função quando aplica rigorosamente, sem subterfúgios calcados em considerações subjetivas de moralidade, o princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição, pois essa norma constitui uma garantia da minoria, portanto, uma barreira contra a atuação sempre ameaçadora da maioria” (STF, RE 633.703, j. 23-3-2011, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18-11-2011, com repercussão geral.) No mesmo sentido: Segundo STF, AgRg no RE 636.359, j. 3-11-2011, rel. Min. Luiz Fux, DJe 25-11-2011.

- “Moralidade, probidade administrativa e vida pregressa. Inelegibilidade. Registro de candidatura. LC n. 135/2010. Ficha limpa. Alínea k do § 1.º do art. 1.º da LC n. 64/90. Renúncia ao

mandato. Empate. Manutenção do acórdão do TSE. (...) O recurso extraordinário trata da aplicação, às eleições de 2010, da LC n. 135/2010, que alterou a LC n. 64/90 e nela incluiu novas causas de inelegibilidade. Alega-se ofensa ao princípio da anterioridade ou da anualidade eleitoral, disposto no art. 16 da CF. O recurso extraordinário objetiva, ainda, a declaração de inconstitucionalidade da alínea k do § 1.º do art. 1.º da LC n. 64/90, incluída pela LC n. 135/2010, para que seja deferido o registro de candidatura do recorrente. Alega-se ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, da segurança jurídica e da presunção de inocência, bem como contrariedade ao art. 14, § 9.º, da Constituição, em razão do alegado desrespeito aos pressupostos que autorizariam a criação de novas hipóteses de inelegibilidade. Verificado o empate no julgamento do recurso, a Corte decidiu aplicar, por analogia, o art. 205, parágrafo único, II, do RISTF, para manter a decisão impugnada, proferida pelo TSE” (STF, RE 631.102, j. 27-10-2010, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20-6-2011). Vide: STF, RE 633.703, j. 23-3-2011, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18-11-2011, com repercussão geral.

- “O procedimento de registro partidário, embora formalmente instaurado perante órgão do Poder Judiciário (TSE), reveste-se de natureza materialmente administrativa. Destina-se a permitir ao TSE a verificação dos requisitos constitucionais e legais que, atendidos pelo partido político, legitimarão a outorga de plena capacidade jurídico-eleitoral à agremiação partidária interessada. A natureza jurídico-administrativa do procedimento de registro partidário impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação, pela via recursal extraordinária, da decisão nele proferida” (STF, RE 164.458-AgR, j. 27-4-1995, rel. Min. Celso de Mello, DJ 2-6-1995).

12.9. PROCESSO JUDICIAL ELEITORAL

O processo eleitoral é o conjunto de atos e procedimentos relacionados às eleições, desde as convenções partidárias (escolha de candidatos e coligações) até a diplomação. Saliente-se que fatos anteriores à convenção partidária poderão ser julgados pela Justiça Eleitoral, tal como abuso do poder político ou econômico.

O processo eleitoral é célere, possui regras próprias, esparsas em diversos diplomas legais, aplicando-se, subsidiariamente, o Código de Processo Civil.

Em regra, no processo eleitoral, são legitimados ativos para a propositura das ações: o Ministério Público, os candidatos, os partidos e as coligações.

Os prazos do processo eleitoral são peremptórios e contínuos, e correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo

para registro de candidatos (cinco de julho do ano das eleições), não se suspendem aos sábados, domingos e feriados (art. 16 da LC n. 64/90). Com relação aos prazos deve-se observar o art. 224 do CPC/2015.

Não há custas e preparo, exceção feita ao recurso extraordinário.

Normalmente, são usados os seguintes mecanismos processuais: impugnação ao registro da candidatura, ações de investigação judicial eleitoral, recurso contra a diplomação, ação de impugnação de mandato eletivo, entre outros.

Poder Legislativo

A separação dos Poderes foi necessária em virtude dos abusos cometidos pelos detentores do poder político. Foi estudada por diversos autores, tais como Aristóteles, na obra Política; John Locke, em seu Tratado sobre o governo; Jean-Jacques Rousseau, no Contrato social; e Charles Louis de Secondat Montesquieu, em sua célebre obra O espírito das leis.

A divisão dos poderes estabelecida por Montesquieu tenta impedir o arbítrio, estabelecendo um sistema de freios e contrapesos em que os três Poderes são independentes, mas subordinados ao princípio da harmonia. Este não significa nem domínio de um pelo outro nem usurpação de atribuições, mas a consciente colaboração e o controle recíproco.

É a separação clássica de poderes ou tripartite de Montesquieu: o Poder Legislativo elabora as leis, o Poder Executivo administra o Estado de acordo com as leis e o Poder Judiciário dirime as lides (conflitos de interesses resistidos) com fundamento nas normas e princípios estabelecidos.

Decisões sobre o tema:

“Separação e independência dos Poderes: freios e contrapesos: parâmetros federais impostos ao Estado-membro. Os mecanismos de controle recíproco entre os Poderes, os ‘freios e contrapesos’ admissíveis na estruturação das unidades federadas, sobre constituírem matéria constitucional local, só se legitimam na medida em que guardem estreita similaridade com os previstos na Constituição da República: precedentes. consequente plausibilidade da alegação de ofensa do princípio fundamental por dispositivos da Lei Estadual n. 11.075/98-RS (inciso IX

do art. 2.º e arts. 33 e 34), que confiam a organismos burocráticos de segundo e terceiro graus do Poder Executivo a função de ditar parâmetros e avaliações do funcionamento da Justiça (...)” (ADIn 1.905-MC, j. 19-11-1998, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 5-11-2004).

“Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção norma estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o Governador e o Vice-Governador possam ausentar-se do país por qualquer prazo. Espécie de autorização que, segundo o modelo federal, somente se justifica quando o afastamento exceder a quinze dias. Aplicação do princípio da simetria” (ADIn 738, j. 13-11-2002, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 7-2-2003). No mesmo sentido: ADIn 775-MC, j. 23-10-1992, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1.º-12-2006).

“A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição Federal pode legitimar. Do relevo primacial dos ‘pesos e contrapesos’ no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional – aí incluída, em relação à Federal, a Constituição dos Estados-membros –, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou apresentação) de sua Casa ou comissão” (ADIn 3.046, Plenário, j. 15-4-2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28-5-2004).

O Poder Legislativo é aquele que tem o poder de fazer, emendar, alterar

e revogar as leis (arts. 44 a 75 da CF/88). Entre nós, ele se divide em três esferas:

a) Na esfera federal, temos o Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, integrados respectivamente por Deputados e Senadores Federais – sistema denominado bicameralismo. Não há predominância substancial de uma Casa sobre a outra. Formalmente, contudo, a Câmara dos Deputados tem o privilégio referente ao início do processo legislativo federal, pois é perante ela que o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os cidadãos promovem a iniciativa do processo de elaboração das leis. Por conta disso, a Câmara dos Deputados é chamada de Casa iniciadora (arts. 61, § 2.º, 62, § 8.º, e 64 da CF/88). Portanto, é possível que o Senado Federal seja a Casa iniciadora e a Câmara dos Deputados seja a revisora se a iniciativa legislativa partir dos Senadores.

Câmara dos Deputados: é composta por representantes do povo, eleitos atualmente pelos Estados e pelo Distrito Federal de acordo com o sistema proporcional. O art. 45, § 1.º, da CF/88 estabelece que a Câmara dos Deputados tenha representação proporcional ao número de cadeiras do partido político de cada unidade federativa e à população de cada Estado e do Distrito Federal. Cumpre observar que nenhuma das unidades federativas terá menos de oito ou mais de setenta Deputados Federais, com exceção dos Territórios Federais (se voltarem a existir), que elegerão quatro Deputados Federais.

Senado Federal: como versa o art. 46 da CF/88, o Senado Federal é composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema majoritário simples. O número de Senadores é fixo por unidade federativa, e cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. Destaque-se que cada Senador será

eleito com dois suplentes. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

b) Na esfera estadual, o Poder Legislativo é composto por Deputados Estaduais, eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de quatro anos. Sua Casa Legislativa é a Assembleia Legislativa.

Insere-se nessa esfera, por possuir status de Estado-membro, o Distrito Federal, que possui Câmara Legislativa, composta por Deputados Distritais, também eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de quatro anos.

As regras da CF/88 referentes aos membros do Congresso Nacional aplicam-se aos Deputados Estaduais e Distritais (sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas – arts. 27, § 1.º, e 32, § 3.º, da CF/88).

c) Na esfera municipal, temos os Vereadores Municipais compondo o Poder Legislativo. São eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de quatro anos, e sua Casa Legislativa é conhecida como Câmara Municipal. Os Vereadores gozam apenas das imunidades materiais (art. 29, VIII, da CF/88). Cabe lembrar que Vereador pode ser chamado de Edil.

13.1. PECULIARIDADES DO CONGRESSO NACIONAL

Funções atípicas: controle das contas públicas federais, autorização para instauração de processo contra certas autoridades, julgamento de crimes de responsabilidade, além de funções meramente deliberativas, como autorizações para viagens do Presidente, plebiscitos e referendos.

A atividade de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional

e patrimonial da União e de entidades da administração direta e indireta é feita por cada Poder, internamente, e pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 74 da CF/88), abordado no final do presente tópico. Existem também Tribunais de Contas nos Estados, no Distrito Federal e em alguns Municípios (art. 75 da CF/88).

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal possuem seus respectivos regimentos internos e órgãos próprios destinados a ordenar seus trabalhos. Abaixo constam seus principais órgãos.

13.1.1. Mesas da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso Nacional

As Mesas são órgãos diretivos da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso Nacional. Normalmente, são compostas pelo Presidente, dois Vice-Presidentes, quatro secretários e quatro suplentes, podendo sua composição ser alterada pelos regimentos.

Para assegurar a autonomia das Casas Legislativas, as Mesas serão compostas por membros pertencentes a seus quadros e eleitos por seus pares.

O mandato para ocupar cargo na Mesa da respectiva Casa será de dois anos, elegendo-se os ocupantes no primeiro ano da legislatura e sendo vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente (art. 57, § 4.º, da CF/88). Porém, pode haver a reeleição se a Mesa for eleita nos dois últimos anos da legislatura.

A Mesa do Congresso Nacional é constituída por membros das Mesas do Senado e da Câmara. A presidência é exercida pelo Presidente do Senado, e os demais cargos serão ocupados alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (art. 57, § 5.º, da CF/88).

A Constituição Federal estabelece certas atribuições para as Mesas, tais

como convocar Ministros para comparecimento (art. 50, § 1.º, da CF/88); solicitar por escrito informações aos Ministros de Estado (art. 50, § 2.º, da CF/88); provocar a perda de mandato (art. 55, § 2.º, da CF/88); declarar a perda do mandato (art. 55, § 3.º, da CF/88); propor ação de inconstitucionalidade (art. 103, II e III, da CF/88).

13.1.2. Comissões parlamentares

As comissões parlamentares são comissões formadas por membros do Poder Legislativo encarregadas de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres.

As comissões parlamentares podem ser temporárias ou especiais, permanentes, mistas e de inquérito.

As comissões parlamentares temporárias ou especiais são constituídas para opinar sobre determinadas matérias e se extinguem com o preenchimento do fim a que se destinam.

As comissões parlamentares permanentes são as que subsistem através das legislaturas, organizando-se em razão da matéria. Normalmente, coincidem com o campo funcional dos Ministérios (art. 58, § 2.º, da CF/88). São também chamadas de comissões temáticas.

As comissões parlamentares mistas são as compostas por Deputados e Senadores federais com o objetivo de apreciar assuntos expressamente fixados, em especial aqueles que devam ser decididos pelo Congresso Nacional (arts. 62, § 9.º, 72, 166, § 1.º, da CF/88).

A comissão parlamentar de inquérito é uma comissão nomeada por uma Casa, composta por membros desta e que agem em seu nome para realizar uma investigação sobre determinado objeto. Esse objeto pode ser um fato ou um conjunto de fatos alusivos a acontecimentos políticos, abusos ou ilegalidades da Administração, questões financeiras, agrícolas, industriais, entre outros, desde que atinentes à boa atividade do Estado.

No direito brasileiro, a comissão parlamentar de inquérito pode ser constituída no âmbito federal, bem como na esfera estadual, municipal e distrital. Na esfera federal e distrital é também chamada de CPI, enquanto nas esferas estadual e municipal, além dessa denominação, é conhecida por Comissão Especial de Inquérito (CEI). Observe-se que uma CPI no Distrito Federal (distrital), ou seja, promovida pela Câmara Legislativa, pode investigar matérias de competência estadual e municipal, em virtude da competência legislativa cumulativa do Distrito Federal (art. 32, § 1.º, da CF/88).

São requisitos constitucionais de uma CPI na esfera federal: requerimento de 1/3 dos membros da respectiva casa, para investigar fato determinado e por prazo certo, com poderes próprios de autoridades judiciais. Suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, que promoverá a responsabilidade civil e criminal dos infratores (art. 58, § 3.º, da CF/88).

Na atualidade, a Lei n. 1.579, de 18-3-1952, a Lei n. 4.595, de 31-12-1964, a Lei n. 10.001, de 4-9-2000 e a Lei n. 10.679, de 23-5-2003, são as leis ordinárias federais a tratar das comissões parlamentares de inquérito. A primeira regulamenta a investigação parlamentar prevista no art. 53 da Constituição de 1946; a segunda amplia o poder das comissões parlamentares de inquérito, ao autorizar a quebra do sigilo bancário; e a terceira estabelece uma “prioridade” de providências que devem ser adotadas nos procedimentos encaminhados pelas CPIs. Destaque-se que a Lei n. 10.679/2003, alterando o art. 3.º da Lei n. 1.579/52 estabeleceu: “(...) § 2.º O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta”. Por fim, a Lei Complementar n. 105, de 10-1-2001, em seu art. 4.º, possibilita expressamente a quebra do sigilo bancário pelas CPIs federais.

O início dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito não impede que se proceda a uma investigação pelos órgãos do Poder Executivo

ou do Poder Judiciário, e vice-versa.

Os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito devem, no máximo, findar com a legislatura que a instituiu ou antes, pelo decurso do prazo estabelecido no Regimento Interno ou pela realização dos fins a que se destinou.

Os mecanismos de instrução das comissões parlamentares de inquérito podem ser os mesmos utilizados nos juízos civil, administrativo e penal. No Brasil, de regra, são usadas as disposições do Código de Processo Penal, havendo liberdade para que os parlamentares conduzam as investigações da maneira que melhor lhes aprouver, desde que não cometam abusos ou ilegalidades. Dessa forma, podem fazer visitas em determinados locais, pedir perícias ou exames laboratoriais, notificar pessoas, realizar oitivas, pedir a quebra do sigilo telefônico, bancário (art. 4.º, § 1.º, da LC n. 105/2001), telemático e fiscal (nesses casos de quebra de sigilo, podem determinar diretamente aos órgãos, desde que o façam fundamentadamente, as CPIs federais – da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e mista), entre outros. Destaque-se que, no segundo semestre de 2004, o STF autorizou que as CPIs estaduais quebrassem diretamente o sigilo bancário (mandado de segurança movido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra ato do Banco Central – CPI da Loterj –, Informativo do STF 408, de 7 a 11-11-2005, ACO 730/RJ). As CPIs municipais se quiserem realizar as quebras de sigilo, devem requerer ao juiz criminal da comarca.

Ao findarem seus trabalhos, devem as comissões parlamentares de inquérito apresentar um relatório, que pode conter a decisão de arquivamento ou de remessa do procedimento às autoridades competentes para que procedam na forma da lei (ver art. 58, § 3.º, da CF/88).

Quanto à limitação de poderes das CPIs, é recomendada a leitura do Informativo do STF 416: “CPI – Poderes – Presença de advogado”. Normalmente, cabe mandado de segurança ou habeas corpus contra os

abusos cometidos por parlamentares na condução dos trabalhos investigatórios: se for contra representantes do Congresso Nacional ou de suas Casas, o foro é o Supremo Tribunal Federal; se for contra representantes das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa, o foro é o Tribunal de Justiça local; e se for contra representantes da Câmara Municipal, o foro é o juiz de direito da comarca.

ATENÇÃO

Conforme decidiu o STF nenhuma CPI pode:

- determinar a interceptação telefônica (grampo);
- expedir mandado de prisão (só quem pode expedir o mandado de prisão é a autoridade judicial. Não confundir com prisão em flagrante, pois esta pode ser feita por qualquer pessoa);
- expedir mandado de busca e apreensão.

As CPIs federais, estaduais e distritais podem requerer diretamente aos órgãos desde que o façam fundamentadamente as quebras de sigilo:

- a) bancário (extratos);
- b) telefônico (extratos);
- c) fiscal (cópia da declaração de imposto de renda).

As CPIs Municipais, se quiserem, devem requerer ao juiz criminal da comarca.

Cada CPI investiga aquilo que o respectivo Legislativo pode legislar ou fiscalizar.

- “A duração do inquérito parlamentar – com o poder coercitivo sobre particulares, inerentes à sua atividade instrutória e à exposição da honra e da imagem das pessoas a desconfiar e conjecturas injuriosas – e um dos pontos de tensão dialética entre a CPI

e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal do funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada à lei do que aos regimentos: donde, a recepção do art. 5.º, § 2.º, da Lei n. 1.579/52, que situa, no termo final de legislatura em que constituída, o limite intransponível de duração, ao qual, com ou sem prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer CPI” (STF, HC 71.261, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 11-5-1994, DJ 24-6-1994; RE 194.346 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 14-9-2010, 2ª T., DJe 8-10-2010)

CPI – fato determinado: Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão (art. 35, § 1.º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados).

13.1.3. Polícia e serviços administrativos

As Casas do Congresso Nacional possuem um corpo de segurança próprio, destinado ao policiamento interno, bem como há serviços administrativos, que são as secretarias, incluindo serviços gráficos, bibliotecas e assessorias, regulados nos respectivos regimentos internos.

13.1.4. Comissão representativa

A Comissão representativa tem por função representar o Congresso Nacional durante o recesso parlamentar (art. 58, § 4.º, da CF/88). O recesso parlamentar ocorre normalmente nos períodos de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1.º de fevereiro.

13.1.5. Funcionamento do Congresso Nacional

O Congresso Nacional realiza suas atividades por legislaturas, sessões legislativas ordinárias ou extraordinárias, sessões ordinárias ou extraordinárias.

A legislatura tem duração de quatro anos (parágrafo único do art. 44 da CF/88) e corresponde ao período que vai do início do mandato dos membros da Câmara dos Deputados até seu término, pois o Senado é contínuo, sendo renovado apenas parcialmente (por um terço e dois terços) em cada período de quatro anos (§ 2.º do art. 46 da CF/88).

Sessão Legislativa Ordinária: é o período anual em que deve estar reunido o Congresso para os trabalhos legislativos. Divide-se em dois períodos: de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1.º de agosto a 22 de dezembro. Cumpre observar que não há interrupção da sessão legislativa se o projeto de lei de diretrizes orçamentárias não for aprovado (art. 57, caput e § 2.º, da CF/88). No primeiro ano da legislatura a sessão legislativa ordinária começa em 1.º de fevereiro (art. 57, § 4.º, da CF/88).

Recesso Parlamentar: é o intervalo entre os períodos legislativos e serve

para o descanso dos parlamentares. Durante o recesso, o Congresso Nacional só funciona se for convocado extraordinariamente. Nesse período, como visto, funcionará a Comissão representativa do Congresso (art. 58, § 4.º, da CF/88). A convocação extraordinária está regulada no art. 57, §§ 6.º e 7.º, da CF/88. Se esta ocorrer, teremos a sessão legislativa extraordinária.

Sessões Ordinárias: são as reuniões diárias dos congressistas, que se processam nos dias úteis (de segunda a sexta-feira). São reguladas pelos regimentos internos.

Nesse horário ou em outro realizam-se também sessões solenes de comemoração de datas ou feitos históricos, de reverência à memória de pessoas ilustres ou de recepção de personalidades estrangeiras em visita ao País. E no início de cada legislatura ocorrem, a partir de 1.º de fevereiro, as sessões preparatórias e as sessões de organização do Congresso e de suas Casas.

Sessões Extraordinárias: são aquelas realizadas fora do horário preestabelecido para apreciar matéria determinada ou concluir a apreciação do que já tenha tido a discussão iniciada.

Reuniões Conjuntas: a Constituição prevê hipóteses em que as Casas do Congresso Nacional se reunirão em sessão conjunta (art. 57, § 3.º, da CF/88), por exemplo, para inaugurar a sessão legislativa, conhecer do veto e sobre ele deliberar, entre outras finalidades.

13.1.6. Quórum para deliberação

13.1.6.1. Maioria simples

“Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros” (art. 47 da CF/88). Levam-se em consideração os presentes. Só haverá necessidade de maioria absoluta ou

de maioria qualificada quando a Constituição o exigir expressamente.

13.1.6.2. Maioria absoluta

Corresponde ao primeiro número inteiro superior à metade dos membros do Congresso, de suas Casas ou de suas Comissões. É necessária, por exemplo, para alguns casos de perda do mandato parlamentar (art. 55, § 2.º, da CF/88), a rejeição do veto presidencial (art. 66, § 4.º, da CF/88), a aprovação de leis complementares (art. 69 da CF/88), a aprovação, pelo Senado Federal, de indicação do Presidente da República para o cargo de Ministro do STF (art. 101, parágrafo único, da CF/88), bem como a aprovação dos Ministros do STJ (art. 104, parágrafo único, da CF/88), entre outros.

Na atualidade, tais números na esfera federal são: Câmara dos Deputados: 513 Deputados Federais; maioria absoluta: 257 Deputados Federais; Senado Federal: 81 Senadores Federais; maioria absoluta: 41 Senadores Federais; Congresso Nacional: 594 membros; maioria absoluta: 298 membros.

13.1.6.3. Maioria qualificada

Corresponde a um número superior à maioria absoluta. Esses casos são apenas os determinados expressamente pela Constituição. Exemplos: 2/3 dos Deputados Federais para autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República (art. 51, I, da CF/88); 3/5 dos membros de cada Casa para aprovação de projeto de emenda constitucional (art. 60, § 2.º, da CF/88) ou para a “constitucionalização” de tratado internacional sobre direitos humanos (art. 5.º, § 3.º, da CF/88); 2/3 do Senado Federal no julgamento do Presidente da República e outros por crime de responsabilidade (art. 52, I e II, c/c parágrafo único).

13.1.7. Prerrogativas dos congressistas

As prerrogativas dos congressistas são benefícios ligados ao cargo. Esses benefícios serão analisados a seguir.

13.1.7.1. Inviolabilidade

Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Isso significa que não cometem crime, pois não há ilicitude (ato contrário à lei), nem respondem na ordem civil por tais atos. A doutrina denomina essa inviolabilidade “imunidade material ou absoluta” (art. 53, caput, da CF/88). A doutrina e a jurisprudência destacam que os referidos atos devem estar vinculados ao “exercício da atividade parlamentar”. Desse modo, um parlamentar embriagado, em uma boate, na madrugada, ofendendo as pessoas, não estará protegido pela inviolabilidade.

13.1.7.2. Imunidade propriamente dita ou “imunidade formal ou relativa”

Neste caso, o crime existe, porém podem ocorrer restrições quanto ao processo ou à prisão do parlamentar.

Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão (art. 53, § 2.º, da CF/88).

Recebida a denúncia contra Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação (art. 53, § 3.º, da CF/88).

O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela Mesa Diretora (art. 53, § 4.º, da CF/88).

A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato (art. 53, § 5.º, da CF/88).

As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional incompatíveis com a execução da medida (art. 53, § 8.º, da CF/88).

Ressalte-se que ambas as prerrogativas citadas aplicam-se aos Deputados Estaduais e Distritais, com as devidas adaptações.

ATENÇÃO

- “A imunidade parlamentar não se estende ao corrêu sem essa prerrogativa” (Súmula 245 do STF).
- “As imunidades são irrenunciáveis e indisponíveis” (STF, INQ 510, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19-4-1991).
- “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual” (Súmula 721 do STF).
- In casu, o querelado é acusado de ter publicado, através do Facebook, trecho cortado de um discurso do querelante, conferindo-lhe conotação racista. É que, no trecho publicado, reproduz-se unicamente a frase “uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa”. Ocorre que, ao conferir-se a íntegra do discurso no site do Congresso Nacional, verifica-se que o sentido da fala do querelante era absolutamente oposto ao veiculado pelo querelado, conforme se extrai do seguinte trecho: “Há um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa”. O ato de edição, corte ou montagem, segundo a lição especializada, “tem por objetivo guiar o

espectador”, razão pela qual o seu emprego, quando voltado a difamar a honra de terceiros, configura o dolo da prática, em tese, criminosa. Consectariamente, conclui-se que a publicação do vídeo, mediante corte da fala original, constituiu emprego de expediente fraudulento, voltado a atribuir ao querelante fato ofensivo à sua honra, qual seja, a prática de preconceito racial e social. O animus difamandi conduz, nesta fase, ao recebimento da queixa-crime. (a) A imunidade parlamentar material cobra, para sua incidência no momento do recebimento da denúncia, a constatação, *primo ictu oculi*, do liame direto entre o fato apontado como crime contra a honra e o exercício do mandato parlamentar, pelo ofensor. A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar, *ratione muneris*, impõe contornos à imunidade material, nos limites estritamente necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano que norteia a CF. A imunidade parlamentar material, estabelecida para fins de proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação,

com o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à reputação de terceiros. Consectariamente, cuidando-se de manifestação veiculada por meio de ampla divulgação (rede social), destituída, ao menos numa análise *prelibatória*, de relação intrínseca com o livre exercício da função parlamentar, deve ser afastada a incidência da imunidade prevista no art. 53 da CF” (STF, *Pet 5.705*, rel. Min. Luiz Fux, j. 5-9-2017, 1.^a T., DJe 13-10-2017).

- In casu, (i) o parlamentar é acusado de incitação ao crime de estupro, ao afirmar que não estupraria uma deputada federal porque ela “não merece”; (ii) o emprego do vocábulo “merece”, no sentido e contexto presentes no caso sub iudice, teve por fim conferir a este gravíssimo delito, que é o estupro, o atributo de um prêmio, um favor, uma benesse à mulher, revelando interpretação de que o homem estaria em posição de avaliar qual mulher “poderia” ou “mereceria” ser estuprada. (...) In casu, (i) a entrevista concedida a veículo de imprensa não atrai a imunidade parlamentar, porquanto as manifestações se revelam estranhas ao exercício do mandato legislativo, ao afirmar que “não estupraria” deputada federal porque ela “não merece”; (ii) o fato de o parlamentar estar em seu gabinete no momento em que concedeu a

entrevista é fato meramente accidental, já que não foi ali que se tornaram públicas as ofensas, mas sim através da imprensa e da internet; (...) (i) A imunidade parlamentar incide quando as palavras tenham sido proferidas do recinto da Câmara dos Deputados: “Despiciendo, nesse caso, perquirir sobre a pertinência entre o teor das afirmações supostamente contumeliosas e o exercício do mandato parlamentar” (Inq 3.814, 1ª T., rel. Min. Rosa Weber, unânime, j. 7-10-2014, DJe 21-10-2014). (ii) Os atos praticados em local distinto escapam à proteção da imunidade, quando as manifestações não guardem pertinência, por um nexo de causalidade, com o desempenho das funções do mandato parlamentar. (...) Ex positis, à luz dos requisitos do art. 41 do CPC, recebo a denúncia pela prática, em tese, de incitação ao crime; e recebo parcialmente a queixa-crime, apenas quanto ao delito de injúria. Rejeito a queixa-crime quanto à imputação do crime de calúnia (STF, Inq 3.932 e Pet 5.243, rel. Min. Luiz Fux, j. 21-6-2016, 1.ª T., DJe 9-9-2016. Vide Inq 1.958, rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, j. 29-10-2003, DJ 18-2-2005).

IMPORTANTE

As votações são abertas (nominais, não secretas ou sigilosas).

CUIDADO

Plenário do STF nega liminares em ADIs sobre imunidade de deputados estaduais

As ações foram ajuizadas contra dispositivos das constituições do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e de Mato Grosso, que estendem aos deputados estaduais imunidades previstas na Constituição Federal para parlamentares federais, como a possibilidade de a Casa Legislativa resolver sobre a prisão de seus membros.

Na sessão extraordinária da manhã de 8 de maio de 2019, o Plenário do STF negou, por seis votos a cinco, medidas cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIns) 5.823, 5.824 e 5.825, nas quais se discute a extensão a deputados estaduais das imunidades formais previstas no art. 53 da Constituição Federal (CF) para deputados federais e senadores. Prevaleceu o entendimento do relator da ADIn 5.823, ministro Marco Aurélio, de

que as regras da Constituição Federal relativas à imunidade dos deputados federais são aplicáveis aos deputados estaduais. Votaram nesse sentido o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o decano, Celso de Mello. Já os ministros Edson Fachin (relator das ADIns 5.824 e 5.825), Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia concediam as liminares.

As ações foram ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) contra dispositivos das constituições do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e de Mato Grosso que estendem aos deputados estaduais imunidades formais previstas no art. 53 da CF para parlamentares federais

(STF, ADIn 5.823, plenário, j. 8-5-2019, rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADIns 5.824 e 5.825, plenário, j. 8-5-2019, rel. Min. Edson Fachin).

13.1.7.3. Privilégio de foro

Os Deputados e Senadores Federais, desde a expedição do diploma, são julgados perante o Supremo Tribunal Federal (art. 53, § 1.º, da CF/88).

Decisões sobre o tema:

“O réu, na qualidade de detentor do mandato de parlamentar federal, detém prerrogativa de foro perante o STF, onde deve ser julgado pela imputação da prática de crime doloso contra a vida. A norma contida no art. 5.º, XXXVIII, da CF/88, que garante a instituição do Júri, cede diante do disposto no art. 102, I, b, da Lei Maior, definidor da competência do STF, dada a especialidade deste último. Os crimes dolosos contra a vida estão abarcados pelo conceito de crimes comuns. Precedentes da Corte. A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a declinação da competência do STF para o juízo criminal de primeiro grau. Ausente o abuso de direito que os votos vencidos vislumbraram no ato. Autos encaminhados ao juízo atualmente competente” (STF, APn 333, Plenário, j. 5-12-2007, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11-4-2008). Vide: APn 396, Plenário, j. 28-10-2010, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28-4-2011.

“A diplomação do réu como deputado federal opera o deslocamento, para o STF, da competência penal para a persecutio criminis, não tendo o condão de afetar a integridade jurídica dos atos processuais, inclusive os de caráter decisório, já praticados, com base no ordenamento positivo vigente à época de sua efetivação, por órgão judiciário até então competente” (STF, HC 70.620, Plenário, j. 16-12-1993, rel. Min. Celso de Mello, DJ 24-11-2006). No mesmo sentido: Inq 2.767, Plenário, j. 18-6-2009, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 4-9-2009; APn 428, Plenário, j. 12-

6-2008, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28-8-2009.

“Uma vez iniciado o julgamento de parlamentar nesta Suprema Corte, a superveniência do término do mandato eletivo não desloca a competência para outra instância” (STF, Inq 2.295, Plenário, j. 23-10-2008, rel. p/ o ac. Min. Menezes Direito, DJe 5-6-2009).

“Deputado federal. Renúncia ao mandato. Abuso de direito: reconhecimento da competência do STF para continuidade do julgamento da presente ação penal. (...) Renúncia de mandato: ato legítimo. Não se presta, porém, a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas, que não podem ser objeto de escolha pessoal. Impossibilidade de ser aproveitada como expediente para impedir o julgamento em tempo à absolvição ou à condenação e, neste caso, à definição de penas. No caso, a renúncia do mandato foi apresentada à Casa Legislativa em 27-10-2010, véspera do julgamento da presente ação penal pelo Plenário do Supremo Tribunal: pretensões nitidamente incompatíveis com os princípios e as regras constitucionais porque exclui a aplicação da regra de competência deste Supremo Tribunal. (...) As provas documentais e testemunhais revelam que o réu, no cargo de diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, praticou os crimes de peculato, na forma continuada, e de quadrilha narrados na denúncia, o que impõe a sua condenação. Questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer a subsistência da competência deste STF para continuidade do julgamento” (APn 396, Plenário, j. 28-10-2010, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28-4-2011). Vide: APn 333, Plenário, j. 5-12-2007, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11-4-2008.

13.1.7.4. Limitação ao dever de testemunhar

O Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 221, que, dentre outras autoridades, os Deputados e Senadores Federais serão inquiridos em

local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Os congressistas, contudo, não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações (art. 53, § 6.º, da CF/88).

13.1.7.5. Isenção do serviço militar

A incorporação dos congressistas (mesmo se militares e em caso de guerra) às Forças Armadas depende da prévia licença da respectiva Casa Legislativa, salvo se renunciar ao mandato (art. 53, § 7.º, da CF/88).

13.1.8. Incompatibilidades dos congressistas

As incompatibilidades dizem respeito a vedações impostas aos congressistas. Sua classificação será analisada a seguir.

13.1.8.1. Negociais

Vinculam-se a atos comerciais (desde a diplomação). É o caso do art. 54, I, a, da CF/88.

13.1.8.2. Funcionais

Dizem respeito basicamente a aceitar cargo ou função. São os casos do art. 54, I, b (desde a diplomação), e II, b e d (desde a posse), da CF/88. Exceção: art. 56, I, da CF/88.

13.1.8.3. Profissionais

Relacionam-se ao exercício de uma atividade laborativa. São os casos do art. 54, II, a e c, da CF/88 (desde a posse).

13.1.9. Perda do mandato

Os casos de perda de mandato dos congressistas estão previstos no art.

55 da CF/88.

A doutrina, dentro dos casos de perda, costuma diferenciar a cassação da extinção do mandato. A primeira refere-se à perda do mandato em virtude de o parlamentar ter cometido falta funcional; já a segunda está relacionada à ocorrência de ato ou fato que torna automaticamente inexistente o mandato (morte, renúncia, ausência injustificada, entre outros).

Os casos de cassação (incisos I, II e VI do art. 55 da CF/88) são decididos pela maioria absoluta da respectiva Casa, por voto aberto, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional (§ 2.º do art. 55 da CF/88).

Nos casos de extinção (incisos III a V do art. 55 da CF/88), a perda será apenas declarada pela Mesa da respectiva Casa Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional (§ 3.º do art. 55 da CF/88).

Destaque-se que em ambos os casos é assegurado constitucionalmente a ampla defesa.

13.1.10. Tribunal de Contas da União

A doutrina ensina que já na Antiguidade havia, em Atenas, uma corte de contas constituída por 10 membros eleitos anualmente pela assembleia popular, encarregada de fiscalizar as contas públicas e de julgar o peculato.

No Brasil Império, embora não existisse uma corte especializada, as contas públicas já eram fiscalizadas pelo Poder Legislativo. A Constituição de 1824 exigia a apresentação dos orçamentos à Câmara dos Deputados, nos termos do art. 172, assim redigido: "O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros ministros os orçamentos relativos às despesas das suas repartições, fará na Câmara dos Deputados, anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço geral de todas as despesas públicas do

ano futuro e da importância de todas as contribuições e rendas públicas”.

Em 7 de novembro de 1890, o Decreto n. 966-A criou no Brasil o Tribunal de Contas, porém este não chegou a ser executado nem teve regulamentação. A Constituição republicana de 1891, no seu art. 89, o instituiu, com a seguinte redação: “É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso”. Houve a regulamentação infraconstitucional por meio do Decreto n. 1.116/1892, permitindo o efetivo funcionamento.

Estava assim implantado, no direito brasileiro, o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle externo das atividades financeira e orçamentária da União.

O Tribunal de Contas da União é composto por nove Ministros e tem sede no Distrito Federal. Tem quadro próprio de pessoal e jurisdição (competência) em todo o território nacional. Exerce, no que couber, as atividades previstas no art. 96 (art. 73 da CF/88).

Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre os brasileiros possuidores dos seguintes requisitos (§ 1.º do art. 73 da CF/88): mais de 35 e menos de 65 anos de idade (inciso I); idoneidade moral e reputação ilibada (inciso II); notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública (inciso III); mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados anteriormente (inciso IV).

Deverão ser escolhidos da seguinte forma (§ 2.º do art. 73 da CF/88): 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo critérios de antiguidade e merecimento; 2/3 pelo Congresso Nacional.

Cumprе lembrar que, embora os Membros do Tribunal de Contas da

União sejam designados Ministros, não são eles magistrados. Todavia, por força do art. 73, § 3.º, da Constituição Federal de 1988, gozam das mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. No que diz respeito à aposentadoria e pensão, deverão respeitar as regras contidas no art. 40 da Constituição.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas da União. Trata-se da participação popular na fiscalização dos atos do Estado, exercida por meio do direito de petição (art. 5.º, XXXIV, a, da CF/88).

As Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros (art. 75, parágrafo único, da CF/88).

De acordo com o texto constitucional, poderão existir também os Tribunais de Contas no Distrito Federal e nos Municípios, como, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro (arts. 75 e 31 da CF/88).

Ressalte-se que o § 4.º do art. 31 da Constituição vigente veda a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

A doutrina afirma que o Tribunal de Contas é um órgão técnico e não jurisdicional. O ato de julgar contas ou a legalidade de atos para registro é manifestamente atribuição de caráter técnico.

IMPORTANTE

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram, na sessão de 17 de agosto de 2016, as teses de repercussão geral decorrentes do julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários (REs) 848.826 e 729.744, ocorrido no Plenário em 10 de agosto de 2016, quando foi decidido que é exclusiva da Câmara de Vereadores a competência para julgar as contas de governo e de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de

dois terços dos vereadores. O STF decidiu também que, em caso de omissão da Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera a inelegibilidade prevista no art. 1.º, I, g, da Lei Complementar n. 64/90 (com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa).

Na atual Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) está previsto no art. 71 como auxiliar do Congresso Nacional, embora a ele não vinculado, cujas incumbências incluem: apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado no prazo de 60 dias a contar de seu recebimento; realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira e orçamentária, além de outras tarefas.

Súmula Vinculante 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”

“O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público” (Súmula 347 do STF).

Além disso, o plenário do STF, no julgamento do MS 25.092, firmou o entendimento de que as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União.

- “A LC n. 105, de 10 de janeiro de 2001, não conferiu ao TCU poderes para determinar a quebra do sigilo bancário de dados constantes do Banco Central do Brasil. O legislador conferiu esses poderes ao Poder Judiciário (art. 3.º), ao Poder Legislativo Federal (art. 4.º), bem como às CPIs, após prévia aprovação do pedido pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas CPIs (§ 1.º e § 2.º do art. 4.º). Embora as atividades do TCU, por sua natureza, verificação de contas e até mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no art. 71, II, da CF/88, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não houve essa determinação na lei específica que tratou do tema, não cabendo a interpretação extensiva, mormente porque há princípio constitucional que protege a intimidade e a vida privada, art. 5.º, X, da CF/88, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário (...)” (STF, MS 22.801, Plenário, j. 17-12-2007, rel. Min. Menezes Direito, DJe 14-3-2008).

- “No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha” (Súmula 653 do STF).

13.2. ESPÉCIES NORMATIVAS

13.2.1. Emenda constitucional

É um mecanismo jurídico utilizado para alterar a Constituição (art. 60 da CF/88). A matéria já abordada anteriormente no tópico “Poder Constituinte Derivado de Reforma ou de Emendabilidade”.

13.2.2. Lei complementar

Tem o mesmo processo legislativo das leis ordinárias, com exceção do quórum, pois o art. 69 da CF/88 exige maioria absoluta. Desse modo, as matérias reservadas à lei complementar não podem ser tratadas por medida provisória ou lei delegada.

Destaque-se que a lei complementar só existe quando expressamente requisitada sua edição na própria Constituição (especificidade de matéria).

Exemplos: imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII, da CF/88), Estatuto da Magistratura (art. 93, caput, da CF/88).

O quórum para aprovação é o de maioria absoluta; no mais, segue o processo legislativo para elaboração das leis ordinárias. Destaque-se que todas as deliberações nas Comissões e no Plenário serão tomadas por maioria absoluta, sob pena de inconstitucionalidade.

Decisão sobre o tema:

“Recurso extraordinário. Lei n. 9.430/96. COFINS. Isenção. Revogação. Sociedades de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada. Ressalva de óptica pessoal. O Plenário, apreciando os RE 377.457-3/PR e 381.964-0/MG, concluiu mostrar-se legítima a revogação, mediante o art. 56 da Lei n. 9.430/96, da isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS relativa às sociedades de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada,

estabelecida no art. 6.º, II, da LC n. 70/91” (STF, AgRg no RE 477.099/RS, j. 16-12-2008, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19-3-2009).

13.2.3. Lei ordinária

É a chamada lei comum, ou seja, tem incidência quando não há previsão específica.

A elaboração das leis ordinárias abrange três fases: a iniciativa, a deliberação propriamente dita e a fase complementar.

a) **Iniciativa:** apresentação do projeto de lei. O projeto de lei deve ser articulado e devidamente fundamentado e justificado. São espécies de iniciativa:

Iniciativa geral: projetos relativos a matérias não reservadas a órgãos ou autoridades específicas. Cabe ao eleitorado (iniciativa popular – art. 61, § 2.º, da CF/88: “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”), ao Presidente da República, a qualquer membro ou comissão do Congresso ou de suas Casas. Tal iniciativa também é chamada de concorrente.

Iniciativa reservada: apresentada por certas autoridades em matérias específicas, como o Presidente da República (arts. 61, § 1.º, e 165 da CF/88), o Supremo Tribunal Federal (arts. 93 e 96, II, da CF/88), os Tribunais Superiores (art. 96, II, da CF/88) e os Procuradores-Gerais (art. 128, § 5.º, da CF/88).

b) **Deliberação:** Abrange os debates nas Comissões e no Plenário, podendo haver apresentação de emendas em cada uma das Casas do Congresso e a manifestação do Presidente da República.

A deliberação é feita em cada uma das Casas do Congresso

separadamente, devendo o projeto ser aprovado por maioria simples (art. 47 da CF/88).

Trâmite: normalmente, o projeto passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que examina sua constitucionalidade nos aspectos material e formal, e por comissões relacionadas à matéria debatida (educação, transportes, defesa etc.). Em seguida, normalmente, o projeto é remetido ao Plenário para votação. Destaque-se que tanto nas Comissões quanto no Plenário podem ser apresentadas emendas ao projeto, isto é, proposições acessórias que modificam o texto original. Dependendo da matéria, pode ser dispensada a apreciação do Plenário (art. 58, § 2.º, I, da CF/88).

Aprovado o projeto na Casa iniciadora, ele é remetido à Casa revisora. Lá, passa também pelas Comissões e pelo Plenário, podendo ser rejeitado, emendado ou aprovado (art. 65 da CF/88). Se for rejeitado, é arquivado, só podendo ser novamente apresentado na mesma sessão legislativa por manifestação da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (art. 67 da CF/88). Se for aprovado por ambas as Casas, o projeto é encaminhado para a elaboração do autógrafo, que é o instrumento formal de aprovação do Congresso Nacional. Depois, o projeto é remetido ao Presidente da República para sanção ou veto. Se for emendado, voltará à Casa iniciadora (art. 65, caput e parágrafo único, da CF/88), que apreciará apenas as emendas da Casa revisora (princípio da primazia da apresentação do projeto), e será remetido em seguida para o autógrafo e depois para o Presidente da República, para sanção ou veto.

A sanção é a concordância do Presidente da República ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. A concordância pode ser expressa ou tácita (no prazo de 15 dias, o silêncio importará sanção – art. 66, § 3.º, da CF/88). Pela lógica, são 15 dias úteis, pois, como adiante se verá, o veto pode ser apresentado nesse período, que é maior que 15 dias corridos.

Não dependem de sanção do Presidente da República: emenda constitucional, decreto legislativo, resoluções das Casas Legislativas,

convocação de plebiscito ou referendo, entre outros.

O veto é a discordância do Presidente da República em relação ao projeto de lei aprovado, por entendê-lo inconstitucional ou contrário ao interesse público. O veto deve ser apresentado em 15 dias úteis e seus motivos comunicados ao Presidente do Senado em 48 horas (art. 66, § 1.º, da CF/88). O veto pode abranger todo o projeto ou apenas parte dele, visto que “o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea” (art. 66, § 2.º, da CF/88).

No prazo de 30 dias a partir do recebimento pelo Presidente do Senado, o Congresso Nacional, em sessão conjunta, pode rejeitar o veto pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores (art. 66, § 4.º, da CF/88). Se não houver deliberação em 30 dias, o projeto entra na ordem do dia, impedindo deliberação sobre outras matérias (art. 66, § 6.º, da CF/88).

Encerrada a apreciação do veto, o projeto é enviado ao Presidente da República para promulgação. Se este não o fizer, o Presidente do Senado o fará. Se houver a negativa deste, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo (art. 66, § 7.º, da CF/88).

ATENÇÃO

Sanção do Presidente da República não convalida o vício de iniciativa (STF, ADIn 1.070-MC/MS, rel. Min. Celso de Mello, j. 23-11-1994, DJe 15-9-1995).

c) Fase complementar: promulgação e publicação.

A promulgação é a comunicação da criação da lei aos seus destinatários. É ato meramente formal e obrigatório, no qual a autoridade competente afirma que a norma foi criada segundo as regras pertinentes, passando a integrar o ordenamento jurídico. Cabe ao Presidente da República promulgar a lei no prazo de 48 horas após a sanção ou derrubada do veto. Se não o fizer, como visto anteriormente, devem fazê-lo em igual prazo,

sucessivamente, o Presidente ou o Vice-Presidente do Senado.

A publicação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento público a existência da lei. A partir da publicação ou após o período de vacância, a lei se torna exigível, obrigatória, e ninguém pode deixar de cumpri-la alegando seu desconhecimento.

13.2.3.1. Regime de urgência

O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa (art. 64, § 1.º, da CF/88). Neste caso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem se manifestar sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobrestando-se todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação (art. 64, § 2.º, da CF/88). Os prazos em questão não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código (art. 64, § 4.º, da CF/88). A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados será feita no prazo de 10 dias (art. 64, § 3.º, da CF/88).

13.2.4. Medida provisória (art. 62 da CF/88 e EC n. 32/2001)

O art. 62 da CF/88 disciplina as medidas provisórias e determina que, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotá-las, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

No § 1.º, há o rol das matérias que não podem ser objeto de edição de medidas provisórias: "I – relativa a: a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; b) direito penal, processual penal e processual civil; c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3.º; II – que vise a detenção ou

sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; III – reservada a lei complementar; IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República”.

No § 2.º, há a previsão de que, através de medida provisória, é possível a instituição ou a majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzindo efeitos no exercício financeiro seguinte se a medida provisória houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Atentar para novidade introduzida pela Emenda Constitucional n. 42/2003, ou seja, para a noventena, ou princípio da anterioridade qualificada ou nonagesimal, prevista no art. 150, III, c, da CF/88, que estabelece o prazo de 90 dias da publicação da lei para a cobrança de tributos.

No § 3.º, há prazo para a eficácia da medida provisória: ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do § 7.º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

O § 4.º estabelece que “o prazo a que se refere o § 3.º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional”.

O § 5.º prevê que a deliberação em cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

O § 6.º estabelece o regime de urgência: “Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando”.

O § 7.º prevê que será prorrogada uma única vez, por igual período, a vigência da medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado da sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

O § 8.º determina que a Câmara dos Deputados é a Casa iniciadora: “As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados”.

O § 9.º estabelece a criação de uma comissão mista de Deputados e Senadores para examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

O § 10 prevê a vedação de reedição, na mesma sessão legislativa (ordinária – anual), de medida provisória que tenha sido rejeitada ou perdido sua eficácia por decurso de prazo.

O § 11 estabelece a possibilidade de perpetuação de relações jurídicas em virtude da inércia do Congresso Nacional: “Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3.º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”.

O § 12 determina que, aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta será mantida integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.

Destaque-se que existe a possibilidade de regulamentação de artigos da Constituição Federal vigente por medida provisória após a promulgação da Emenda Constitucional n. 32/2001, conforme se infere da alteração feita no art. 246: “É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1.º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive”.

O art. 2.º da Emenda Constitucional n. 32/2001 estabelece que as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda (11-9-2001, pois tal emenda foi publicada em 12-9-2001) continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

Por fim, deve-se esclarecer que, se a medida provisória (projeto de conversão) for aprovada sem alteração em seu texto original, haverá a promulgação pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional para a publicação no Diário Oficial da União. Se houver alteração no projeto de conversão da medida provisória, deverá ser seguido o processo legislativo comum, ou seja, será encaminhado para o Presidente da República para sanção ou veto. Posteriormente, havendo a sanção ou derrubada do veto, segue-se a promulgação e publicação do texto da lei pelo Presidente da República (previsão na Res. n. 1/2002-CN, arts. 12 e 13).

ATENÇÃO

Não existe proibição para a previsão de medida provisória nas esferas estadual, distrital e municipal.

13.2.5. Lei delegada

Trata-se da possibilidade de o Presidente da República pedir ao Congresso Nacional, através de mensagem, delegação para legislar sobre certos assuntos. A delegação se efetiva por resolução, que fixará os limites (art. 68 da CF/88) e, eventualmente, a necessidade de aprovação do projeto do Presidente pelo Congresso, em votação única, vedada qualquer emenda (art. 68, § 3.º, da CF/88).

Não podem ser objeto de lei delegada matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional e de suas Casas, matérias reservadas à lei complementar e relativas ao orçamento, à organização do Ministério Público

e do Poder Judiciário e a questões referentes à nacionalidade, à cidadania, aos direitos individuais, políticos e eleitorais (art. 68, § 1.º, da CF/88).

As leis delegadas são pouco utilizadas, pois é mais fácil o Presidente da República editar medida provisória.

13.2.6. Decreto legislativo

É uma espécie normativa de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo promulgado pelo Presidente do Senado, e não sujeito a sanção ou veto (art. 59, VI, da CF/88). Pode tratar de matéria concreta (art. 49, II a VI, IX, XII, XVII, da CF/88), de atos normativos e de matéria abstrata (art. 49, VII e VIII, da CF/88).

13.2.7. Resolução

Vincula-se às competências privativas de cada uma das Casas do Congresso Nacional (arts. 59, VII, 51 e 52 da CF/88). Não está sujeita a sanção ou veto, sendo promulgada pela Mesa da Casa que a editou. Se for ato do Congresso Nacional, será promulgada pela Mesa do Senado (art. 68, § 2.º, da CF/88).

São, também, previstas algumas resoluções com efeitos externos, como as que visam concretizar a delegação de competências, em caráter temporário, do Legislativo para o Executivo (art. 68, § 2.º, da CF/88), a suspensão da eficácia de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário (art. 52, X, da CF/88) ou ainda a fixação de alíquotas aplicáveis a certas operações (art. 155, § 2.º, IV, da CF/88).

Poder Legislativo no Brasil (arts. 44 a 75 da CF/88)

Esferas			Representantes	Representam	Mandato	Siste Eleiç

Federal	Congresso Nacional bicameralismo	Câmara dos Deputados	Deputados Federais (mínimo de 8 e máximo de 70), proporcional à população do Estado. Total de 513	Povo	Mandato de 4 anos	Prop
		Senado Federal	Senadores Federais ou Senadores da República Representam os Estados- -membros e o DF 3 por unidade federativa Total de 81	26 Estados- -membros + DF (27 UF)	Mandato de 8 anos, renova-se na proporção 1/3 por 2/3 alternadamente	Majo Simp Rela
Estadual	Assembleia Legislativa	26 Assembleias Legislativas	Deputados Estaduais	Povo	Mandato de 4 anos	Prop
Distrital DF	Câmara Legislativa	1 Câmara Legislativa	Deputados Distritais	Povo	Mandato de 4 anos	Prop
Municipal	Câmara Municipal	+ de 5.560 Câmaras Municipais	Vereadores (Edil)	Povo	Mandato de 4 anos	Prop

Poder Executivo

Tem a finalidade (função típica) de administrar e gerenciar o Estado. Realiza atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Além disso, também exerce a função legislativa por meio de medidas provisórias e leis delegadas. Participa, ainda, do processo legislativo pela iniciativa, sanção ou veto e promulgação das leis.

O Poder Executivo está previsto na Constituição Federal vigente no Capítulo II do Título IV (arts. 76 a 91 da CF/88).

14.1. COMPOSIÇÃO

Na esfera federal é chefiado pelo Presidente da República (cidadão brasileiro nato, idade mínima de 35 anos: art. 14, § 3.º, VI, a, da CF/88), tendo como auxiliares diretos o Vice-Presidente e os Ministros de Estado.

Na esfera estadual é chefiado pelo Governador do Estado (cidadão brasileiro, idade mínima de 30 anos: art. 14, § 3.º, VI, b, da CF/88), tendo como auxiliares diretos o Vice-Governador e os Secretários Estaduais. No Distrito Federal há também Governador e Vice-Governador, porém existem Secretários Distritais.

Na esfera municipal é chefiado pelo Prefeito do Município (cidadão brasileiro, idade mínima de 21 anos: art. 14, § 3.º, VI, c, da CF/88), tendo como auxiliares diretos o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais. Destaque-se que em Municípios com 200 mil eleitores ou menos a eleição é feita em um só turno (art. 29, II, da CF/88).

14.2. ELEIÇÃO, POSSE E SUCESSÃO

A eleição do Presidente da República e do Vice-Presidente com ele registrado será realizada no primeiro domingo de outubro (primeiro turno) e, se necessário, também no último domingo de outubro (segundo turno) do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente (art. 77 da CF/88). Os vencedores devem alcançar a maioria absoluta de votos válidos (sistema majoritário absoluto), não computados os em branco e os nulos (art. 77, § 2.º, da CF/88).

A posse será no dia 1.º de janeiro do ano seguinte à sua eleição, perante o Congresso Nacional (art. 82 da CF/88). Se a posse de qualquer deles não ocorrer em até 10 dias depois desse prazo, salvo motivo de força maior, o cargo será considerado vago (parágrafo único do art. 78 da CF/88).

O Presidente será substituído e sucedido pelo Vice-Presidente (art. 79 da CF/88) e, na falta deste, sucessivamente, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Senado Federal e pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 80 da CF/88). A sucessão por estes três últimos é sempre provisória, pois, se vagarem os cargos tanto de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, deverão ser realizadas novas eleições para o preenchimento de ambos os cargos, e os eleitos apenas completarão o período remanescente do mandato presidencial (art. 81, § 2.º, da CF/88).

No momento em que ocorrer a vacância de ambos os cargos, se faltarem mais de dois anos para o término do mandato, as eleições serão diretas e realizadas em 90 dias (art. 81, caput, da CF/88). Se faltar período inferior a dois anos, a eleição será indireta, pelo Congresso Nacional, em 30 dias (art. 81, § 1.º, da CF/88).

14.3. INICIATIVA RESERVADA

De acordo com o § 1.º do art. 61 da CF/88, são de iniciativa privativa do

Presidente da República as leis que: "I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; II – disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva".

Decisões sobre o tema:

"Por ofensa ao art. 61, § 1.º, II, a e c, da CF/88 – que atribuem ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a remuneração e o regime jurídico de servidores públicos –, o Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba, para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 39 da Constituição, do mesmo Estado, que assegurava a servidores públicos, em cada nível de vencimento, como garantia do princípio da hierarquia salarial, 'um acréscimo nunca inferior a cinco por cento do nível imediatamente antecedente, e a fixação, entre cada classe, referência ou padrão, de diferença não inferior a cinco por cento'. Vencidos os Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio, que julgavam improcedente a ação relativamente ao alegado vício formal. Precedente citado: ADIn 1.977/PB (DJU 2-5-2003)" (STF, ADIn 2.863/PB, j. 11-9-2003, rel. Min. Nelson Jobim).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.848 em que o governador do Estado do Rio de Janeiro questionava dispositivo da Constituição estadual que trata da revisão da remuneração de servidores públicos. Em concordância com o voto do relator, Ministro Marco Aurélio, os ministros, por unanimidade, constataram a existência de vício de origem, pois a norma foi introduzida por iniciativa parlamentar, contrariando o disposto no art. 61, § 10, II, alínea “c”, da Constituição da República, que estabelece ser privativa do chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico de servidores públicos (STF, ADIn 3.848/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, j. 11-2-2015, DJe 19-3-2015).

14.4. COMPETE AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (ART. 84 DA CF/88), EM ESPECIAL

14.4.1. Participação no processo legislativo

Nas leis ordinárias e complementares, o Presidente participa da fase de iniciativa (apresentando projetos), da fase deliberativa (por meio da sanção ou do veto) e da fase complementar (por meio da promulgação e determinação de publicação) – art. 84, III a V, da CF/88. Além disso, pode apresentar projetos de emenda constitucional, editar medidas provisórias com força de lei (art. 84, XXVI, da CF/88) e elaborar leis delegadas (art. 68 da CF/88).

14.4.2. Regulamentação das normas

Elaboração de decretos e regulamentos para assegurar a fiel execução das leis – o decreto é o veículo de manifestação do Presidente da República. O presidente expede decretos de nomeação, de remoção ou de demissão. Além disso, ao Executivo cabe regulamentar a lei para lhe dar aplicação.

14.4.3. Atuação no plano internacional

Cabe ao Presidente “manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos” (art. 84, VII, da CF/88), “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” (art. 84, VIII, da CF/88), declarar a guerra (art. 84, XIX, da CF/88), celebrar a paz (art. 84, XX, da CF/88) e, ainda, autorizar, nos termos de lei complementar, “que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente” (art. 84, XXII, da CF/88).

14.4.4. Atuação quanto ao funcionalismo público federal

Ao Presidente da República compete nomear e exonerar os Ministros de Estado livremente (art. 84, I, da CF/88), exercer a direção superior da administração federal (art. 84, II, da CF/88), dispor, mediante decreto, sobre sua organização e funcionamento (art. 84, VI, a, da CF/88) e prover e extinguir os cargos públicos federais (art. 84, XXV, da CF/88).

IMPORTANTE

“O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações” (art. 84, parágrafo único, da CF/88).

14.4.5. Atuação em relação às Forças Armadas

Ao Presidente compete exercer o comando supremo das Forças Armadas (art. 84, XIII, da CF/88).

14.4.6. Nomeação de autoridades

Compete ao Presidente nomear, com a aprovação do Senado Federal, os

Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os Diretores do Banco Central, os Ministros do Tribunal de Contas da União (art. 84, XIV e XV, da CF/88), e nomear livremente os magistrados, o Advogado-Geral da União, nos casos previstos na Constituição (art. 84, XVI, da CF/88), os membros do Conselho de República, nos termos do art. 89, VII, da CF/88 (art. 84, XVII, da CF/88), os membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça (arts. 130-A e 103-B da CF/88).

14.5. CONSELHO DA REPÚBLICA E CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Ambos são órgãos de consulta do Presidente da República e emitem pareceres não vinculativos, podendo ser acolhidos ou não.

- **Conselho da República:** órgão superior de consulta do Presidente da República composto por autoridades públicas, membros do Congresso e seis cidadãos brasileiros natos (art. 89, VII, da CF/88), sendo dois eleitos pela Câmara dos Deputados, dois eleitos pelo Senado Federal (arts. 51, V, e 52, XIV, da CF/88) e dois nomeados pelo Presidente da República.

O Conselho da República pronuncia-se sobre intervenção federal, decretação de estado de defesa e estado de sítio e outras questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas (art. 90 da CF/88).

- **Conselho de Defesa Nacional:** composto pelo Vice-Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pelos Ministros da Justiça, de Estado da Defesa, das Relações Exteriores e do Planejamento e pelos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica (art. 91 da CF/88).

Compete a tal Conselho opinar em matérias relativas à defesa do território nacional, especialmente nas áreas de fronteiras, em decretação de estado de defesa ou de sítio e intervenção federal.

14.6. O IMPEACHMENT

O impeachment (impedimento) deve ser entendido como o processo pelo qual o Poder Legislativo pune a conduta da autoridade pública que cometeu crime de responsabilidade, destituindo-a do cargo e impondo-lhe uma pena de caráter político.

No Brasil, o impeachment está previsto desde a Constituição de 1824 e esteve presente em todas as Constituições republicanas.

O art. 86 da CF/88 vigente divide o processo de impeachment em duas fases:

a) a Câmara dos Deputados, depois de admitida a acusação feita por qualquer cidadão, limita-se pela maioria de 2/3 de seus membros a receber ou não a denúncia. Esse ato de recebimento ou não da denúncia, decisão que não julga o mérito do processo, é chamado pela doutrina de juízo de admissibilidade (tribunal de pronúncia – art. 80 da Lei n. 1.079/50).

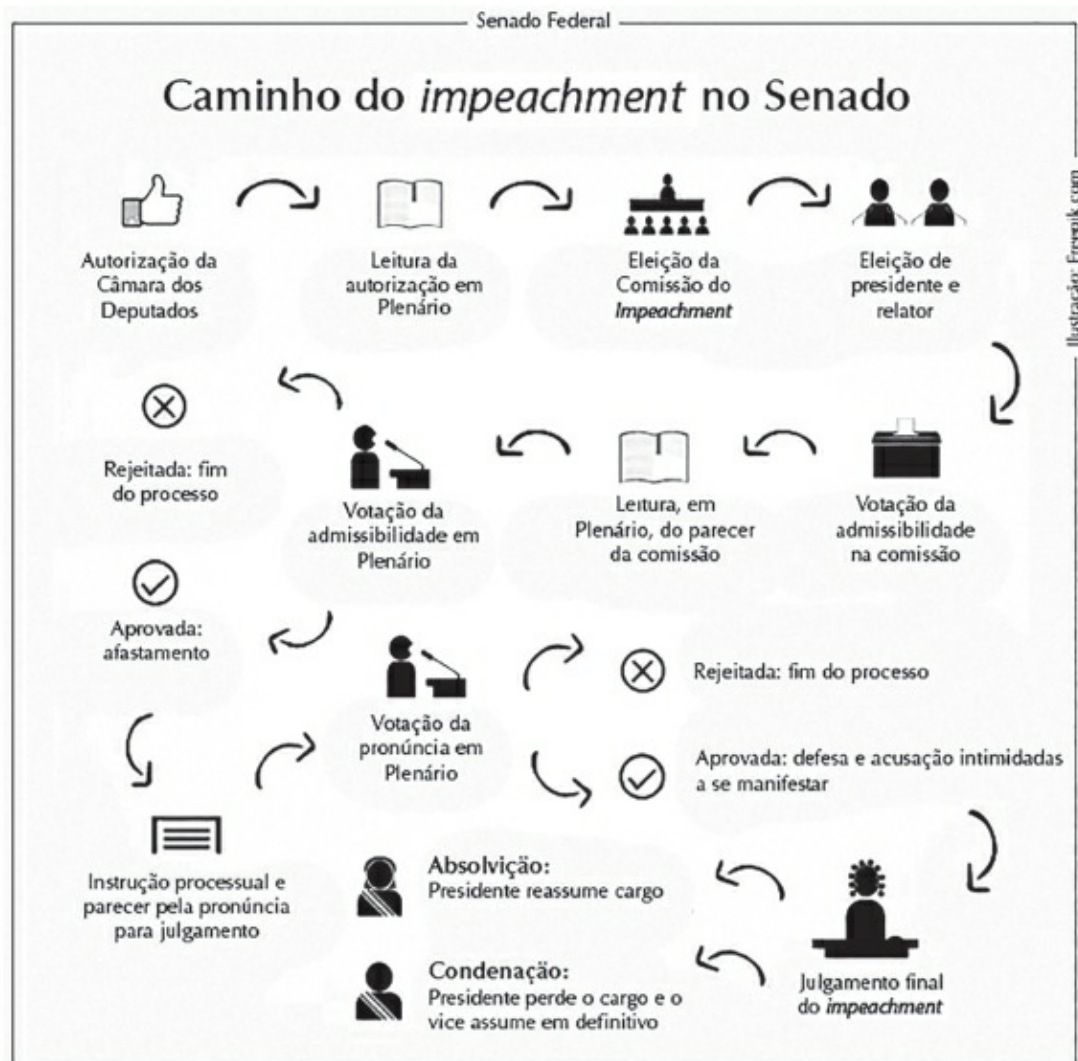
Tal pronúncia, realizada pela Câmara dos Deputados, implica tão somente na processabilidade do Presidente da República ou de seus Ministros, se realizarem crimes conexos com aquele, ou seja, a Câmara considerou haver indícios e razoáveis provas do ato imputado ao acusado. Se não constataste tal situação, poderia opinar pelo arquivamento.

b) a acusação é encaminhada ao Senado Federal (crimes de responsabilidade), que, se instaurar o processo, suspenderá o Presidente de suas funções (art. 86, § 1.º, II, da CF/88). Se, decorrido o prazo de 180 dias, “o julgamento não estiver concluído, cessará o

afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo” (art. 86, § 2.º, da CF/88).

O papel do Senado, ao apreciar a imputação ao acusado de atos atentatórios à Constituição e à lei, previstos de forma genérica no art. 85 da CF/88 e especificados em lei ordinária especial (Lei n. 1.079/50), deverá limitar-se à verificação da adequação deles às hipóteses legais. É uma atividade jurisdicional.

O julgamento, presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, poderá resultar em absolvição, com o arquivamento do processo, ou em condenação por 2/3 dos votos do Senado Federal, limitando-se a decisão à perda do cargo, “com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis” (art. 52, parágrafo único, da CF/88).²



Fonte: [<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/04/27/o-caminho-do-processo-no-senado>].

Além do Presidente da República e do Vice-Presidente, de acordo com a Constituição Federal, podem ser passíveis de punição pelo cometimento de crimes de responsabilidade os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes conexos com aqueles; os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União (art. 52, I e II, da CF/88).

As condutas definidas como crimes de responsabilidade do Presidente da República estão elencadas no art. 85 da CF/88 e na Lei n. 1.079/50.

Decisões sobre o tema:

“São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento” (Súmula 722).

“O processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo STF. Inaplicabilidade do disposto nos arts. 51, I, e 52, I, da Carta de 1988 e 14 da Lei n. 1.079/50, dado que é prescindível autorização política da Câmara dos Deputados para a sua instauração. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do MPF (CF, art. 129, I). Ilegitimidade ativa ad causam dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao Parquet” (STF, Pet 1.954/DF, j. 11-9-2002, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 1.º-8-2003).

“Os atos de improbidade administrativa são tipificados como crime de responsabilidade na Lei n. 1.079/50, delito de caráter político-administrativo. Distinção entre os regimes de responsabilização político-administrativa. O sistema constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4.º (regulado pela Lei n. 8.429/92) e o regime fixado no art. 102, I, c, (disciplinado pela Lei n. 1.079/50). Se a competência para processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4.º) pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, c, da CF. (...) Os Ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, c; Lei n. 1.079/50), não se submetem

ao modelo de competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92). Crimes de responsabilidade. Competência do STF. Compete exclusivamente ao STF processar e julgar os delitos político-administrativos, na hipótese do art. 102, I, c, da Constituição. Somente o STF pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos. Ação de improbidade administrativa. Ministro de Estado que teve decretada a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de oito anos e a perda da função pública por sentença do juízo da 14.^a Vara da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra agente político que possui prerrogativa de foro perante o STF, por crime de responsabilidade, conforme o art. 102, I, c, da Constituição. Reclamação julgada procedente” (STF, Rcl 2.138/DF, j. 13-6-2007, rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 18-4-2008). No mesmo sentido: STF, RE 579.799-AgR/MG, j. 2-12-2008, rel. Min. Eros Grau, DJe 19-12-2008. Vide: STF, Rcl 4.119-AgR/BA, j. 6-10-2011, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28-10-2011.

ATENÇÃO

Governadores (Lei n. 1.079/50) e Prefeitos (Decreto-lei n. 201/67).

14.7. PROCESSO E JULGAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NOS CRIMES COMUNS

Se o Presidente da República comete crime comum no exercício da função, a sua responsabilização depende de autorização pela Câmara dos Deputados por 2/3 dos membros (art. 86, caput, da CF/88).

Autorizado o processo pela Câmara dos Deputados, este será instaurado

pelo Supremo Tribunal Federal, com o recebimento da denúncia (oferecida pelo Procurador-Geral da República), tendo como consequência imediata a suspensão do Presidente da República de suas funções (art. 86, § 1.º, da CF/88), prosseguindo o processo nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal e da legislação pertinente (Lei n. 8.038/90).

Nesse caso, a condenação do Presidente importa em consequências de natureza penal e, somente por efeitos reflexos e indiretos, na perda do cargo (art. 15, III, da CF/88). Destaque-se que o Presidente da República só pode ser julgado por crime comum em razão da função (irresponsabilidade relativa – imunidade temporária – prescrição suspensa).

ATENÇÃO

Art. 86, §§ 3.º e 4.º, da CF/88: § 3.º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão. § 4.º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

IMPORTANTE

O plenário da Câmara dos Deputados barrou em 25 de outubro de 2017, pela segunda vez, o prosseguimento de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. O placar da acusação por obstrução da Justiça e organização criminosa foi mais apertado para o peemedebista do que o da primeira denúncia, por corrupção passiva, suspensa em agosto de 2017.

Temer recebeu o apoio de 251 deputados federais e 233 votaram para autorizar a continuidade das investigações. Na primeira denúncia, foram 263 votos pró-governo e 227 pelo prosseguimento da denúncia.

O presidente foi acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato e de integrar uma organização criminosa ao lado dos Ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

Disponível em: <<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-derruba-segunda-denuncia-contra-michel-temer-e-ministros,70002060600>>.

14.8. QUADRO COMPARATIVO DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO NO BRASIL (arts. 76 a 91 da CF/88)	Federal: • Presidente da República + Vice-Presidente (brasileiros natos) • Mandato: 4 anos (possível reeleição) • Sistema majoritário absoluto
	Estadual: • Governador Distrital + Vice-Governador • Mandato: 4 anos (possível reeleição) • Sistema majoritário absoluto
	Distrital • Governador Distrital + Vice-Governador • Mandato: 4 anos (possível reeleição) • Sistema majoritário absoluto
	Municipal • Prefeito Municipal + Vice-Prefeito • Mandato: 4 anos (possível reeleição) Observação: → Sistema majoritário absoluto = Município com + de 200 mil eleitores → Sistema majoritário simples = Município com até 200 mil eleitores

Observação: sobre o tema reeleição, vide o art. 14, § 5.º, da CF/88.

Poder Judiciário

Tem a função de exercer a jurisdição, ou seja, compete a ele resolver as lides. Desse modo, com o objetivo de resolver o litígio, deve aplicar o direito ao caso concreto.

No Brasil, o Poder Judiciário pode ser dividido em uma Justiça de âmbito federal (comum ou especializada) e em uma Justiça de âmbito estadual (residual – matéria que não for da competência federal comum ou especializada).

A Justiça Federal comum de primeira instância tem a competência estabelecida no art. 109 da CF/88. São consideradas como Justiça especializada federal a Justiça Trabalhista, a Eleitoral e a Militar (arts. 111 a 124 da CF/88).

Destaque-se que há autorização constitucional para a criação de Juizados Especiais e da Justiça de Paz (art. 98, I e II, da CF/88) e da Justiça Militar Estadual (art. 125, § 3.º, da CF/88).

A Constituição Federal de 1988 estabelece os órgãos do Poder Judiciário no art. 92, no qual temos: o Supremo Tribunal Federal (tutela constitucional), o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

O ingresso na carreira da magistratura é feito por meio de concurso público de provas e títulos, no cargo inicial de juiz substituto, com a

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se à ordem de classificação nas nomeações (art. 93, I, da CF/88).

Destaque-se que 1/5 dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios será composto por membros do Ministério Público e por advogados com mais de 10 anos de carreira ou de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação (art. 94 e parágrafo único da CF/88). A Emenda Constitucional n. 45/2004 inseriu o quinto constitucional na Justiça do Trabalho: nos Tribunais Regionais do Trabalho – art. 115, I, da CF/88 e no Tribunal Superior do Trabalho – art. 111-A, I, da CF/88.

15.1. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Com o objetivo de assegurar a imparcialidade e a tranquilidade dos magistrados no exercício de suas funções, foram estabelecidas as seguintes garantias (art. 95 da CF/88):

15.1.1. Vitaliciedade

Ao magistrado é assegurada a prerrogativa de só ser demitido após o trânsito em julgado da decisão judicial. A vitaliciedade, no primeiro grau de jurisdição, é adquirida após dois anos de estágio probatório, que se inicia com o efetivo exercício depois da posse. Já no segundo grau de jurisdição, a vitaliciedade se dá com o efetivo exercício (quinto constitucional). Há necessidade de aprovação em curso a ser realizado na escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados (art. 93, IV, da CF/88).

15.1.2. Inamovibilidade

É a vedação de remoção do magistrado de um cargo para outro, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão por voto da maioria absoluta do respectivo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa (art. 93, VIII, da CF/88).

15.1.3. Irredutibilidade de subsídio

Assegura que o magistrado não tenha diminuído o valor de seus subsídios, salvo imposição constitucional (ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e § 2.º, I).

15.2. PRINCIPAIS PONTOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004 – REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO

a) Instituição do princípio da celeridade, também denominado brevidade ou razoável duração do processo: art. 5.º, LXXVIII, da CF/88: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Cumprir lembrar que já havia tal previsão na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992: “Art. 7.º Direito à liberdade pessoal: (...) 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. (...); Art. 8.º Garantias judiciais: 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer

outra natureza. (...)” (grifos nossos).

O princípio indica que todos os processos administrativos ou judiciais devem ser realizados de forma célere.

Decisão judicial sobre o tema:

“Habeas corpus. Writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Demora no julgamento. Direito à razoável duração do processo. Natureza mesma do habeas corpus. Primazia sobre qualquer outra ação. Ordem concedida. O habeas corpus é a via processual que tutela especificamente a liberdade de locomoção, bem jurídico mais fortemente protegido por uma dada ação constitucional. O direito à razoável duração do processo, do ângulo do indivíduo, transmuta-se em tradicional garantia de acesso eficaz ao Poder Judiciário. Direito a que corresponde o dever estatal de julgar. No habeas corpus, o dever de decidir se marca por um tônus de presteza máxima. Assiste ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento. Isso, é claro, sempre que o impetrante se desincumbir do seu dever processual de pré-constituir a prova de que se encontra padecente de ‘violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (inciso LXVIII do art. 5.º da CF/88). Ordem concedida para que a autoridade impetrada apresente em mesa, na primeira sessão da Turma em que oficia, o writ ali ajuizado” (STF, HC 91.041, j. 5-6-2007, rel. p/ acórdão Min. Carlos Britto, DJ 17-8-2007).

b) Constitucionalização dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, com aprovação do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Serão equivalentes às emendas constitucionais: art. 5.º, § 3.º, da CF/88 (possibilidade do bloco de constitucionalidade), onde se lê: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

Anteriormente à Emenda Constitucional n. 45/2004, os tratados internacionais, segundo o Supremo Tribunal Federal, se incorporavam ao ordenamento jurídico brasileiro como normas infraconstitucionais, com status de lei ordinária. Nesse sentido, por maioria de votos, manifestou-se o Pretório Excelso (ADI n. 1.480-3/ML, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 83:809; RO em HC 79.785-3/RJ, rel. Min. Moreira Alves, DJ 22-11-2002; HC 72.131-1/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1.º-8-2003).

Após a Emenda Constitucional n. 45/2004 houve a possibilidade de “constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos”, ou seja, utilizando o mesmo sistema de aprovação de uma emenda constitucional, pode-se elevar um tratado internacional sobre direitos humanos em que o Brasil faça parte ao status de norma constitucional.

Tal situação caracteriza o chamado “bloco de constitucionalidade”, que é a somatória de vários diplomas legais considerados como normas constitucionais, não obstante terem sido elaborados em momentos diferentes.

Destaque-se que ilustres doutrinadores entendem que o “bloco de constitucionalidade” já era admitido no direito brasileiro com fundamento no art. 5.º, § 2.º, da CF/88, onde se lê: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

A constitucionalização dos Tratados é uma faculdade atribuída ao Congresso Nacional de elevar um tratado internacional sobre direitos humanos da condição de norma supralegal para a condição de emenda

constitucional. Cite-se, como exemplo, o Decreto Legislativo n. 186, de 09 de julho de 2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007, que foi promulgado pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009.

No histórico julgamento do RE 466.343, de dezembro de 2008, preponderou no Pleno do Supremo Tribunal Federal o voto do Min. Gilmar Mendes. Assim, os tratados de direitos humanos não referendados nos termos do § 3.º do art. 5.º da CF/88 são considerados normas supralegais (acima das leis, mas abaixo da Constituição Federal).

ATENÇÃO

HC 87.585/TO, j. 3-12-2008, rel. Min. Marco Aurélio: prevaleceu a tese do status de supralegalidade da Convenção Americana de Direitos Humanos (Informativo 531).

c) **Submissão do Brasil à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão:** “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão” (art. 5.º, § 4.º, da CF/88).

O art. 7.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias já previa: “O Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos”.

O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) foi concluído em 17 de julho de 1998 e entrou em vigor na ordem internacional em 1.º de julho de 2002, em conformidade com seu art. 126.

O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que foi ratificado pelo Decreto Legislativo n. 112, de 6 de junho de 2002 (nos termos do art. 49, I, da CF/88), e promulgado pelo Decreto n. 4.388, de 25 de setembro de 2002. Seu instrumento de ratificação foi depositado em 20 de junho de 2002.

O Estatuto de Roma prevê que o Tribunal Penal Internacional será uma instituição permanente e que terá jurisdição complementar às jurisdições penais dos Estados-partes: "Art. 1.º O Tribunal. É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional ('o Tribunal'). O Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto" (grifos nossos).

O Tribunal tem sede em Haia, Países Baixos ("o Estado anfitrião"), conforme previsão do art. 3.º do Estatuto, e, "sempre que entender conveniente, o Tribunal poderá funcionar em outro local" (art. 3.º, 3).

Sua competência para julgar crimes mais graves está prevista no art. 5.º do Estatuto: "Crimes da competência do Tribunal. 1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: a) o crime de genocídio; b) crimes contra a humanidade; c) crimes de guerra; d) o crime de agressão".

Cumprе ressaltar que tais crimes são imprescritíveis (art. 29), e são excluídos de tal jurisdição os menores de 18 anos na data da prática do crime (art. 26).

ATENÇÃO

O Estatuto de Roma, em seu art. 120, não admite reservas, e o art. 5.º, § 4.º, da CF/88 estabelece que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional cuja criação tenha manifestado adesão. O próprio Estatuto, no art. 102, estabelece a diferença entre os institutos da entrega e da extradição:

"a) por 'entrega' entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao Tribunal nos termos do presente Estatuto;

b) por 'extradição' entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado conforme

previsto em um tratado, em uma convenção ou no direito interno”.

A CF/88, no art. 5.º, LI, determina: “Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”.

Da comparação das citadas normas percebe-se o afastamento do aparente conflito, sendo possível a entrega de brasileiros natos ou naturalizados para o Tribunal Penal Internacional, pois a Constituição veda a extradição, não a entrega. Além disso, o Brasil aderiu constitucionalmente ao Estatuto de Roma.

d) **Exigência ao bacharel em direito de três anos de atividade jurídica para ingresso na magistratura e no Ministério Público:** arts. 93, I, e 129, § 3.º, da CF/88: “Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (...)”; “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) § 3.º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação”.

O Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Resolução n. 75, de 12 de maio de 2009, regulamentou o critério de atividade jurídica para a inscrição em concurso público de ingresso na carreira da magistratura nacional (Somente será computada a atividade jurídica posterior à obtenção do grau de bacharel em Direito: “Art. 59. Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 58, § 1.º, alínea i: I – aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito; II – o efetivo exercício de advocacia, inclusive

voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei n. 8.906, 4-7-1994, art. 1.º) em causas ou questões distintas; III – o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico; IV – o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano; V – o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. § 1.º É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito. § 2.º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. (...) Art. 90. Fica revogada a Resolução n. 11/CNJ, de 31 de janeiro de 2006, assegurado o cômputo de atividade jurídica decorrente da conclusão, com frequência e aproveitamento, de curso de pós-graduação comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor da presente Resolução”).

O Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução n. 29, de 31-3-2008, considerando como atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em Direito, aquela exercida por ocupante do cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, para cujo desempenho se faça imprescindível a conclusão do curso de direito. No art. 2.º da citada Resolução determina que a comprovação do período de três anos de atividade jurídica deverá ser documentada e formalizada no ato da inscrição definitiva ao concurso.

- e) **Fim das férias coletivas:** a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente – art. 93, XII, da CF/88.
- f) **Para o vitaliciamento, passa a ser etapa obrigatória a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados:** art. 93, IV, da CF/88.
- g) **Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão:** art. 93, II, e, da CF/88: “Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: (...) e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão”.
- h) **Controle externo da magistratura e do Ministério Público, que será exercido pelos Conselhos Nacionais da Magistratura e do Ministério Público (CNJ e CNMP):** arts. 103-B, §§ 1.º a 7.º, e 130-A, §§ 1.º a 5.º, respectivamente, da CF/88:

“Art. 103-B. (...) § 1.º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. § 2.º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. § 3.º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. § 4.º Compete ao Conselho [Nacional de Justiça] o controle da atuação administrativa e financeira do

Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; VI – elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. § 5.º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-

Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competendo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: I – receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários; II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; III – requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. § 6.º Junto ao Conselho oficialão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. § 7.º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça”.

“Art. 130-A. (...) § 1.º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei [Lei n. 11.372/2006]. § 2.º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério

Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; V – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI. § 3.º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: I – receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; III – requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. § 4.º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. § 5.º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.”

Compete ao Presidente da República nomear, com a aprovação do Senado Federal por maioria absoluta, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130-A, caput, da CF/88) e do Conselho Nacional de Justiça, salvo o Presidente do CNJ que é o Presidente do STF (art. 103-B, §§

1.º e 2.º, da CF/88).

A Constituição Federal de 1988 estabelece os órgãos do Poder Judiciário no art. 92, onde temos: o Supremo Tribunal Federal (tutela constitucional), o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar as ações contra os Conselhos é prevista no art. 102, I, r, da CF/88, que assim estabelece: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (...) r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (...)”.

Decisão sobre o tema:

“A Lei n. 8.223/2007, decretada e sancionada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Estado da Paraíba, não pode ter o controle de constitucionalidade realizado pelo CNJ, pois a CR confere essa competência, com exclusividade, ao STF” (STF, AC 2.390-MC-REF/PB, j. 19-8-2010, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2-5-2011).

i) **Justiça itinerante e descentralizada:** arts. 107, §§ 2.º e 3.º (JF), 115, §§ 1.º e 2.º (JT), e 125, §§ 6.º e 7.º (TJ), todos da CF/88: “Art. 107. (...) § 2.º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. § 3.º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do

jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo”; “Art. 115. (...) § 1.º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. § 2.º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo”; “Art. 125. (...) § 6.º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. § 7.º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários”.

j) **Extinção dos Tribunais de Alçada:** a Emenda Constitucional n. 45/2004 assim estabelece: “Art. 4.º Ficam extintos os Tribunais de Alçada, onde houver, passando os seus membros a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a antiguidade e classe de origem. Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado da promulgação desta Emenda, os Tribunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão a integração dos membros dos tribunais extintos em seus quadros, fixando-lhes a competência e remetendo, em igual prazo, ao Poder Legislativo, proposta de alteração da organização e da divisão judiciária correspondentes, assegurados os direitos dos inativos e pensionistas e o aproveitamento dos servidores no Poder Judiciário estadual”.

Destaque-se que no Estado de São Paulo havia o 1.º e o 2.º Tribunal de Alçada Civil, bem como o Tribunal de Alçada Criminal.

k) **Instituição da “quarentena” dos membros da magistratura e do**

Ministério Público (três anos) para o exercício da advocacia nos juízos ou tribunais de que se afastaram: arts. 95, parágrafo único, V, e 128, § 6.º, respectivamente, da CF/88: “Art. 95. (...) Parágrafo único. Aos juízes é vedado: (...) V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração”; “Art. 128. (...) § 6.º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V”.

A finalidade de tal limitação foi impedir eventual tráfico de influência ou exploração de prestígio em prejuízo da moralidade administrativa.

l) **Ampliação da legitimidade ativa da ação declaratória de constitucionalidade (Adecon/Adeco/ADC):** “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I – o Presidente da República; II – a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da Câmara dos Deputados; IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI – o Procurador-Geral da República; VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.

Anteriormente, somente o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados e o Procurador-Geral da República tinham legitimidade para propor a Adecon/Adeco/ADC.

m) **O Supremo Tribunal Federal julgará a decisão recorrida que julgou válida lei local contestada em face de lei federal:** art. 102, III, d, da CF/88 (verifica-se tal hipótese no desrespeito às regras de competência legislativa concorrente previstas no art. 24 da CF/88): “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da

Constituição, cabendo-lhe: (...) III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (...) d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”.

O recurso extraordinário é a última etapa do controle difuso de constitucionalidade e é o mecanismo por meio do qual o Supremo Tribunal Federal dá a palavra final sobre uma questão constitucional. Pode ser interposto contra decisão de Tribunal proferida em única ou última instância. É controle incidental (por via de exceção) e repressivo.

As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário são apenas aquelas previstas no art. 102, III, da Constituição Federal vigente.

Os efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário atingem, em princípio, apenas as partes litigantes. Porém, quando o Supremo Tribunal Federal declarar uma lei inconstitucional, por decisão definitiva, o Senado Federal poderá, mediante resolução, suspender a execução da lei em todo o território nacional (art. 52, X, da CF/88), dando assim eficácia erga omnes à decisão do Supremo.

n) **Repercussão geral das questões constitucionais, nos termos da lei, a fim de que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso extraordinário:** art. 102, § 3.º, da CF/88 (Lei n. 11.418/2006 e Emenda Regimental n. 21/2007, do Supremo Tribunal Federal): “§ 3.º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.

“O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo” (art. 1.035 do

CPC/2015).

“Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (art. 1.035, § 1.º, do CPC/2015).

“O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 1.035, § 2.º, do CPC/2015).

“Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; II – tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos (inciso revogado pela Lei n. 13.256/2016); III – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal” (art. 1.035, § 3.º, do CPC/2015).

O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre matérias que têm e que não têm repercussão geral – vide no site [<http://www.stf.jus.br>].

o) O Superior Tribunal de Justiça julgará, em recurso especial, a decisão recorrida que julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal e, processará e julgará, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias: art. 105, III, b, e I, i, respectivamente, da CF/88: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, originariamente: (...) i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; (...) III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: (...) b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (...)”.

Nesses casos, houve uma troca de competências, pois a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias pertenciam ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, h, da CF/88, alínea hoje revogada, conforme EC n. 45/2004).

Da alínea b do inciso III do art. 105 da CF/88 (recurso especial) foi excluída a decisão que julgou válida lei local contestada em face de lei federal, deslocada para a competência do STF (art. 102, III, d, da CF/88).

p) A federalização dos crimes graves contra os direitos humanos, mediante incidente suscitado pelo Procurador-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça, deslocando a competência para a Justiça Federal: art. 109, caput, V-A, e § 5.º, da CF/88: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) V-A – as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5.º deste artigo; (...) § 5.º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal”.

Trata-se de mudança de competência da Justiça local (estadual) para a Justiça Federal.

A primeira vez que se pediu a federalização (incidente de deslocamento de competência) envolveu a apuração da morte da Irmã Dorothy Stang, que foi assassinada, com seis tiros, aos 73 anos de idade, no dia 12 de fevereiro de 2005, em uma estrada de terra de difícil acesso a 53 quilômetros da sede do Município de Anapu, no Estado do Pará, por ordem de um fazendeiro em virtude de sua atividade em prol da reforma agrária e de melhores condições de vida para o povo paraense.

No citado caso, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de

deslocamento de competência por entender que foi correta a atuação da Justiça local.

Em 27 de outubro de 2010, houve a primeira decisão favorável à federalização. Trata-se do caso Manoel Mattos (IDC 2/DF 2009/0121262-6).

Por maioria de votos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o crime contra o ex-vereador Manoel Mattos fosse processado pela Justiça Federal. O caso é de responsabilidade da Justiça Federal da Paraíba.

O advogado pernambucano Manoel Bezerra de Mattos Neto foi assassinado em 24 de janeiro de 2009, no Município de Pitimbu/PB, depois de sofrer diversas ameaças e vários atentados, em decorrência, ao que tudo leva a crer, de sua persistente e conhecida atuação contra grupos de extermínio que agem impunes há mais de uma década na divisa dos Estados da Paraíba e de Pernambuco, entre os Municípios de Pedras de Fogo e Itambé.

Ficou consignado na decisão que o risco de responsabilização internacional pelo descumprimento de obrigações derivadas de tratados internacionais aos quais o Brasil anuiu (dentre eles, vale destacar, a Convenção Americana de Direitos Humanos) é bastante considerável, mormente pelo fato de já ter havido pronunciamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com expressa recomendação ao Brasil para adoção de medidas cautelares de proteção a pessoas ameaçadas pelo tão propalado grupo de extermínio atuante na divisa dos Estados da Paraíba e Pernambuco, as quais, no entanto, ou deixaram de ser cumpridas ou não foram efetivas. Além do homicídio de Manoel Mattos, outras três testemunhas da CPI da Câmara dos Deputados foram mortas, dentre eles Luiz Tomé da Silva Filho, ex-pistoleiro, que decidiu denunciar e testemunhar contra os outros delinquentes. Também Flávio Manoel da Silva, testemunha da CPI da Pistolagem e do Narcotráfico da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, foi assassinado a tiros em Pedra de Fogo, Paraíba, quatro dias

após ter prestado depoimento à Relatora Especial da ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais. E, mais recentemente, uma das testemunhas do caso Manoel Mattos, Maximiano Rodrigues Alves, sofreu um atentado à bala no Município de Itambé, Pernambuco, e escapou por pouco.

As circunstâncias apontaram para a necessidade de ações estatais firmes e eficientes, as quais, por muito tempo, as autoridades locais não foram capazes de adotar, até porque a zona limítrofe potencializa as dificuldades de coordenação entre os órgãos dos dois Estados. Mostrou-se, portanto, oportuno e conveniente a imediata entrega das investigações e do processamento da ação penal em tela aos órgãos federais.

O pedido ministerial foi parcialmente acolhido para deferir o deslocamento de competência para a Justiça Federal no Estado da Paraíba da ação penal 022.2009.000.127-8, a ser distribuída para o Juízo Federal Criminal com jurisdição no local do fato principal, bem como da investigação de fatos diretamente relacionados ao crime em tela.

IMPORTANTE

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu por unanimidade, em 13 de agosto de 2014, o pedido da Procuradoria-Geral da República do Incidente de Deslocamento de Competência (federalização) do processo que apura o assassinato do Promotor de Justiça Thiago Faria, em outubro de 2013, no Agreste Pernambucano – IDC 5 PE (2014/0101401-7). Com a decisão, o caso passou a ser conduzido pela Justiça Federal no Estado. De acordo com o relator, Ministro Rogério Schietti, todas as linhas de investigação dos órgãos estaduais apontam para vingança ou ciúmes. No julgamento, os ministros destacaram que as próprias autoridades locais manifestaram estar impedidas de investigar adequadamente o caso, que também envolveria grupos de extermínio. No dia 14 de outubro de 2013, o promotor de Justiça de Itaíba (PE) Thiago Faria Soares foi morto a tiros enquanto viajava pela Rodovia PE-300, no Agreste Pernambucano, em direção à cidade de Itaíba, Município situado no denominado “triângulo da pistolagem”.

q) Ampliação da competência da Justiça do Trabalho e do número de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho (de 17 para 27) e

estabelecimento do quinto constitucional na área trabalhista: arts. 114, 111-A, I e II, e 115, I e II, da CF/88.

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II – as ações que envolvam exercício do direito de greve; III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”.

Sobre o assunto é interessante destacar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIn 3.395/DF, onde ficou consignado: “É inconstitucional toda e qualquer interpretação (...) que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”.

Outro tema interessante decidido pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito ao interdito proibitório. No julgamento do RE 579.648/MG ficou consignado que é da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários

e de clientes a agências bancárias sob o risco de serem interditadas em decorrência de movimento grevista. Considerou-se que se está diante de ação que envolve o exercício do direito de greve, matéria afeta à competência da Justiça Trabalhista, conforme disposto no art. 114, II, da CF/88.

“Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; II – os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior”.

IMPORTANTE

Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 111-A, § 3.º, da CF/88).

“Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; II – os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e

merecimento, alternadamente”.

O quinto constitucional foi criação de Getúlio Vargas, sendo mantido pela reforma do Poder Judiciário, inclusive ampliado. Nos citados casos, a nomeação será feita pelo Presidente da República. Destaque-se que, no caso do quinto constitucional no Tribunal Superior do Trabalho, há necessidade de prévia aprovação do indicado pelo Senado Federal por maioria absoluta.

r) **Súmula vinculante:** art. 103-A da CF/88, onde se lê: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. § 1.º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. § 2.º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. § 3.º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

s) **Possibilidade de o Tribunal de Justiça propor a criação de varas**

especializadas, para dirimir conflitos fundiários, com competência exclusiva para questões agrárias: art. 126 da CF/88.

- t) Estabelecimento da maioria absoluta (somado ao interesse público) para violação da inamovibilidade dos magistrados e membros do Ministério Público: arts. 93, VIII, e 128, § 5.º, I, b, da CF/88: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) VIII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (...)”; “Art. 128. (...) § 5.º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: I – as seguintes garantias: (...) b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (...)”.

Nos dois casos foi reduzido o quórum de dois terços (maioria qualificada) para a maioria absoluta.

- u) Autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas Estaduais: art. 134, § 2.º, da CF/88, que assim estabelece: “§ 2.º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2.º”. O disposto no § 2.º do art. 134 também se aplica às Defensorias Públicas da União e o DF, conforme o § 3.º do art. 134 da CF/88.

- v) As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão

efeito vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial: art. 8.º da Emenda Constitucional n. 45/2004.

15.3. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão máximo do Poder Judiciário. Acha-se instalado na Capital Federal (art. 92, § 1.º, da CF/88) e tem como função fundamental a guarda da Constituição Federal (art. 102 da CF/88).

Composição: 11 membros denominados Ministros, escolhidos dentre cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

Forma de nomeação: nomeados pelo Presidente da República com aprovação prévia do Senado por maioria absoluta de votos (art. 101, parágrafo único, da CF/88).

15.3.1. Competência do Supremo Tribunal Federal

a) **Originária (só cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar):** são as hipóteses do inciso I do art. 102 da CF/88 – Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade; infrações penais comuns do Presidente da República, do Vice-Presidente, dos membros do Congresso Nacional, de seus próprios Ministros e do Procurador-Geral da República; infrações penais comuns e crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado e dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, exceto nos crimes de responsabilidade conexos com o Presidente da República (art. 52, I, da CF/88), dos membros dos Tribunais Superiores, dos membros do Tribunal de Contas da União e dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, entre outros casos. Destaque-se que o § 1.º do art. 102 da CF/88 estabelece que caberá ao Supremo Tribunal Federal

julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental.

b) **Recursal ordinária (recurso ordinário constitucional – ROC)**: inciso II do art. 102 da CF/88 – julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.

c) **Recursal extraordinária (recurso extraordinário – RE)**: inciso III do art. 102 da CF/88 – julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Cumpra-se observar que cabe recurso extraordinário das decisões proferidas pelo colégio recursal nos recursos inominados no Juizado Especial Cível.

Observe-se que, na propositura do recurso extraordinário, “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (art. 102, § 3.º, da CF/88).

“O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecurável, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo” (art. 1.035 do CPC/2015).

“Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (art. 1.035, § 1.º, do CPC/2015).

“O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para

apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 1.035, § 2.º, do CPC/2015).

“Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; II – tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos (inciso revogado pela Lei 13.256/2016); III – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal” (art. 1.035, § 3.º, do CPC/2015).

Sobre a repercussão geral para admissão do recurso extraordinário, deve-se verificar, no site do Supremo Tribunal Federal [<http://www.stf.jus.br>], quais matérias o Supremo considera como de repercussão geral ou não.

Súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre recurso extraordinário:

- **Súmula 279:** “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
- **Súmula 281:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
- **Súmula 282:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
- **Súmula 283:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
- **Súmula 284:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
- **Súmula 285:** “Não sendo razoável a arguição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra c do art. 101, III, da Constituição Federal” (refere-se à CF/46 – vide art.102, III, c, da CF/88).

- **Súmula 286:** “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

- **Súmula 287:** “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

- **Súmula 289:** “O provimento do agravo por uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário”.

- **Súmula 299:** “O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança, ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno”.

- **Súmula 369:** “Julgados do mesmo tribunal não servem para fundamentar o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial”.

- **Súmula 454:** “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.

- **Súmula 456:** “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”.

- **Súmula 636:** “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.

- **Súmula 637:** “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município”.

- **Súmula 638:** “A controvérsia sobre a incidência, ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário”.

- **Súmula 640:** “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida

por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”.

- **Súmula 727:** “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

- **Súmula 728:** “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei n. 6.055/74, que não foi revogado pela Lei n. 8.950/94”.

- **Súmula 733:** “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”.

- **Súmula 735:** “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.

O Supremo Tribunal Federal, desde 1.º de agosto de 2010, exige que sejam protocoladas na Corte exclusivamente por meio eletrônico as seguintes peças: Ação Cautelar; Ação Rescisória; Habeas Corpus; Mandado de Segurança; Mandado de Injunção; Suspensão de Liminar; Suspensão de Segurança e Suspensão de Tutela Antecipada. As três últimas classes são processos de competência da Presidência da Corte.

Em fevereiro de 2010 passaram a tramitar de forma exclusivamente eletrônica seis tipos de ações originárias, ou seja, que têm início no STF: Reclamações, Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Ações Declaratórias de Constitucionalidade, Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão, Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental e Propostas de Súmula Vinculante.

O Recurso Extraordinário foi o precursor do processo eletrônico na Corte, com início em junho de 2007.

IMPORTANTE

STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. O Plenário concluiu, no dia 13 de junho de 2019, o julgamento das ações que tratam da matéria e decidiu que, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas se enquadram na tipificação da Lei do Racismo (Lei n. 7.716/89).

O Plenário do STF entendeu que houve omissão constitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia. O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, de relatoria do ministro Celso de Mello, e do Mandado de Injunção (MI) 4733, relatado pelo ministro Edson Fachin, foi concluído. Por maioria, o Plenário aprovou a tese proposta pelo relator da ADO, ministro Celso de Mello, formulada em três pontos. O primeiro prevê que, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, se enquadram nos crimes previstos na Lei n. 7.716/2018 e, no caso de homicídio doloso, constitui circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe. No segundo ponto, a tese prevê que a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Finalmente, a tese estabelece que o conceito de racismo ultrapassa aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos e alcança a negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio (STF, ADO 26, plenário, j. 13-6-2019, rel. Min. Celso de Mello; STF, MI 4733, plenário, j. 13-5-2019, rel. Min. Edson Fachin).

15.3.2 Súmula vinculante: art. 103-A (EC n. 45/2004)

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. § 1.º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre

questão idêntica. § 2.º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. § 3.º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

A Lei n. 11.417/2006 regulamentou a súmula vinculante, e dentre as novidades houve a ampliação da legitimidade ativa para sua criação, revisão ou cancelamento (Defensor Público-Geral da União, Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Militares). Além disso, admite-se incidentalmente a propositura pelos Municípios – art. 3.º, caput, VI, XI, e § 1.º.

Saliente-se o conteúdo dos enunciados das seguintes súmulas vinculantes:

- **Súmula Vinculante 1:** “Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar n. 110/2001”.

- **Súmula Vinculante 2:** “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”.

- **Súmula Vinculante 3:** “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o

interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.

- **Súmula Vinculante 4:** “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

- **Súmula Vinculante 5:** “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

- **Súmula Vinculante 6:** “Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”.

- **Súmula Vinculante 7:** “A norma do § 3.º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

- **Súmula Vinculante 8:** “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5.º do Decreto-lei 1.569/77 e os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.

- **Súmula Vinculante 9:** “O disposto no art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do art. 58”.

- **Súmula Vinculante 10:** “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

- **Súmula Vinculante 11:** “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil

e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

- **Súmula Vinculante 12:** “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”.

- **Súmula Vinculante 13:** “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.

- **Súmula Vinculante 14:** “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

- **Súmula Vinculante 15:** “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.

- **Súmula Vinculante 16:** “Os arts. 7.º, IV, e 39, § 3.º (redação da EC n. 19/98), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.

- **Súmula Vinculante 17:** “Durante o período previsto no § 1.º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

- **Súmula Vinculante 18:** “A dissolução da sociedade ou do vínculo

conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7.º do art. 14 da Constituição Federal”.

- **Súmula Vinculante 19:** “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o art. 145, ii, da Constituição Federal”.

- **Súmula Vinculante 20:** “A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa instituída pela Lei n. 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do art. 5.º, parágrafo único, da Lei n. 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1.º da Medida Provisória n. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos”.

- **Súmula Vinculante 21:** “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.

- **Súmula Vinculante 22:** “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004”.

- **Súmula Vinculante 23:** “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.

- **Súmula Vinculante 24:** “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

- **Súmula Vinculante 25:** “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

- **Súmula Vinculante 26:** “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

- **Súmula Vinculante 27:** “Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”.

- **Súmula Vinculante 28:** “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”.

- **Súmula Vinculante 29:** “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.

- **Súmula Vinculante 31:** “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”.

- **Súmula Vinculante 32:** “O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras”.

- **Súmula Vinculante 33:** “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4.º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

- **Súmula Vinculante 34:** “A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei n.

10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória n. 198/2004, convertida na Lei n. 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC n. 20/98, n. 41/2003 e n. 47/2005)".

- **Súmula Vinculante 35:** "A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei n. 9.099/95 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial".

- **Súmula Vinculante 36:** "Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil".

- **Súmula Vinculante 37:** "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

- **Súmula Vinculante 38:** "É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial".

- **Súmula Vinculante 39:** "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal".

- **Súmula Vinculante 40:** "A contribuição confederativa de que trata o art. 8.º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo".

- **Súmula Vinculante 41:** "O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa".

- **Súmula Vinculante 42:** "É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de

correção monetária”.

- **Súmula Vinculante 43:** “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

- **Súmula Vinculante 44:** “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

- **Súmula Vinculante 45:** “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual”.

- **Súmula Vinculante 46:** “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.

- **Súmula Vinculante 47:** “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

- **Súmula Vinculante 48:** “Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembarço aduaneiro”.

- **Súmula Vinculante 49:** “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.

- **Súmula Vinculante 50:** “Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”.

- **Súmula Vinculante 51:** “O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis n. 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações

decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais”.

- **Súmula Vinculante 52:** “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.

- **Súmula Vinculante 53:** “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados”.

- **Súmula Vinculante 54:** “A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda Constitucional n. 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição”.

- **Súmula Vinculante 55:** “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.

- **Súmula Vinculante 56:** “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

15.4. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e acha-se instalado na Capital Federal (art. 92, § 1.º, da CF/88), tendo como função principal assegurar a supremacia da legislação federal em todo o País (art. 105 da CF/88).

Composição: no mínimo 33 Ministros (art. 104, caput, da CF/88).

Forma de nomeação: nomeados pelo Presidente da República, dentre

brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: “I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; II – um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94” (art. 104, parágrafo único, I e II, da CF/88).

15.4.1. Competência do Superior Tribunal de Justiça

a) **Originária (só cabe ao Superior Tribunal de justiça julgar):** são as hipóteses do inciso I do art. 105 da CF/88 – processar e julgar, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias (art. 105, I, i, da CF/88), entre outros casos.

b) **Recursal ordinária (recurso ordinário constitucional – ROC):** são as hipóteses do inciso II do art. 105 da CF/88 – julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; e as causas em que forem

partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

c) **Recursal especial (recurso especial – REsp)**: são as hipóteses do inciso III do art. 105 da CF/88 – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; e c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal.

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre recurso especial:

- **Súmula 5**: “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
- **Súmula 7**: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
- **Súmula 13**: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”.
- **Súmula 83**: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
- **Súmula 86**: “Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento”.
- **Súmula 98**: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
- **Súmula 116**: “A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça”.
- **Súmula 123**: “A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e

constitucionais”.

- **Súmula 126:** “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.

- **Súmula 203:** “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.

- **Súmula 211:** “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.

- **Súmula 316:** “Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial”.

Destaque-se que funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante (art. 105, parágrafo único, II, da CF/88). Além disso, funcionará a escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira (art. 105, parágrafo único, I, da CF/88).

Quadro comparativo do STF □ STJ:

Art. 102 da CF/88	Art. 105 da CF/88
Inciso I – competência originária – STF: ADIn, ADC, ADPF, Extradução, entre outros. Atentar para as hipóteses de HC, MS e MI. Julgar deputado federal e senador que cometer crime comum durante o mandato e vinculado à função legislativa.	Inciso I – competência originária – STJ: Governador de Estado que comete crime comum, homologação de sentença estrangeira, entre outros. Atentar para as hipóteses de HC, MS e MI. Julgar governador de Estado que comete crime comum durante o mandato e vinculado à função administrativa.

Inciso II – competência ordinária – ROC. Indeferimento HC em única instância por Tribunal Superior, entre outros.	Inciso II – competência ordinária – ROC. Indeferimento HC em única ou última instância por TJ/TRF, entre outros.
Inciso III – RE (observar o § 3.º do art. 102 que prevê repercussão geral para admissão do RE, disciplinada pela Lei n. 11.418/2006 – arts. 1.035 e 1.036 do CPC/2015).	Inciso III – REsp.

15.5. RECLAMAÇÃO

A reclamação tem por objetivo preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões (arts. 102, I, I, e 105, I, f, ambos da CF/88). Admite-se, também, em face da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente (art. 7.º, caput, da Lei n. 11.417/2006 e art. 103-A, § 3.º, da CF/88).

De acordo com o art. 988 do CPC/2015, “caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do Tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do Tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (incisos III e IV com redação da Lei n. 13.256/2016).

“A reclamação pode ser proposta perante qualquer Tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir” (art. 988, § 1.º, do CPC/2015).

“A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao

Presidente do Tribunal” (art. 988, § 2.º, do CPC/2015).

“Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível” (art. 988, § 3.º, do CPC/2015).

“As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam” (art. 988, § 4.º, do CPC/2015).

É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5.º, do CPC/2015 com redação da Lei n. 13.256/2016).

“A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação” (art. 988, § 6.º, do CPC/2015).

Ao despachar a reclamação, o relator: “I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias, II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação” (art. 989, I a III, do CPC/2015).

“Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante” (art. 990 do CPC/2015).

“Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado” (art. 991 do CPC/2015).

“Julgando procedente a reclamação, o Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia” (art. 992 do CPC/2015).

“O Presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente” (art. 993 do CPC/2015).

IMPORTANTE

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministra Cármen Lúcia, julgou procedente a Reclamação (RCL) 29.508 e cassou decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em 20 de janeiro de 2018, havia autorizado a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) no cargo de Ministra do Trabalho. Constatada a usurpação da competência da Presidência do STF para julgar o caso, a Ministra determinou que os autos do processo em curso no STJ sejam encaminhados ao Supremo (STF, RCL 29.508. rel. Min. Cármen Lúcia, j 21-1-2018).

Decisões sobre o tema:

“Reclamação. Natureza jurídica. Alegado desrespeito a autoridade de decisão emanada do STF. Inocorrência. Improcedência. A reclamação, qualquer que seja a qualificação que se lhe dê – ação (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, t. V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (Moacyr Amaral Santos, RTJ 56/546-548; Alcides de Mendonça Lima, O Poder Judiciário e a nova Constituição, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (Orozimbo Nonato apud Cordeiro de Mello, O processo no Supremo Tribunal Federal, v. 1/280), incidente processual (Moniz de Aragão, A correição parcial, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, v. 3, 2.^a parte, p. 199, item 653, 9. ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (Min. DJaci Falcão, RTJ 112/518-522) –, configura, modernamente, instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ

112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídico, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, I) e do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, f). Não constitui ato ofensivo à autoridade de decisão emanada do Supremo Tribunal Federal o procedimento de magistrado inferior que, motivado pela existência de várias execuções penais ainda em curso, referentes a outras condenações não desconstituídas pelo writ, deixa de ordenar a soltura imediata de paciente beneficiado por habeas corpus concedido, em caso diverso e específico, por esta Corte” (STF, Rcl 336/DF, j. 19-12-1990, rel. Min. Celso de Mello, DJ 15-3-1991).

“Reclamação. Constituição estadual. Admissibilidade. É admissível ao Estado-membro criar, em sua Constituição, o instrumento processual da reclamação para a preservação da competência dos tribunais estaduais e garantia do respeito às suas decisões” (STF, ADIn 2.212-1/CE, j. 2-10-2003, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 14-11-2003).

“Reclamação. Usurpação da competência do Supremo. Avocação do processo. Irrelevância. Surge irrelevante avocar o processo quando, estabelecida a competência do Supremo, nota-se a carência da ação proposta na origem ante a ilegitimidade da parte ativa” (STF, Rcl 5.096/SP, Plenário, j. 20-5-2009, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19-6-2009).

Remédios constitucionais

São meios postos à disposição dos indivíduos e dos cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando a corrigir ilegalidade ou abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais. São também chamados de garantias constitucionais ou ações constitucionais.

Os direitos e garantias fundamentais correspondem às normas que possibilitam as condições mínimas para a convivência em sociedade, estabelecendo direitos e limitações aos particulares e ao Estado, e normalmente estão expressamente previstos nas Constituições dos Estados contemporâneos.

A Constituição Federal de 1988 estabelece os direitos e garantias fundamentais do cidadão em seu Título II – “Dos direitos e garantias fundamentais” –, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos (art. 5.º), direitos sociais (arts. 6.º a 11), nacionalidade (arts. 12 e 13), direitos políticos e partidos políticos (arts. 14 a 17).

Na atualidade, os doutrinadores mais requeridos em concursos públicos classificam os direitos vinculados aos seres humanos da primeira à terceira geração, conforme ensinamentos lançados por Karel Vasak, que em conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos em 1979, classificou em três gerações os direitos humanos. Cada geração foi associada ao lema da Revolução Francesa: “Liberté, Egalité et Fraternité”. Há, porém, quem entenda existir até a sexta geração de direitos.

Cumprе destacar que se trata de uma divisão meramente acadêmica,

pois os direitos dos seres humanos não devem ser divididos em gerações estanques. Tais gerações apenas retratam a valorização de determinados direitos em momentos históricos distintos.

Críticas são feitas com a utilização do termo geração. José Joaquim Gomes Canotilho sustenta que:

“Critica-se a pré-compreensão que lhes está subjacente, pois ela sugere a perda de relevância e até a substituição dos direitos das primeiras gerações. A ideia de generatividade geracional também não é totalmente correta: os direitos são de todas as gerações” (Direito constitucional e teoria da constituição, p. 386).

Passou-se, então, a também se admitir o termo dimensão no lugar de geração, pois não se tem a conotação de substituição. Saliente-se que nas decisões do Supremo Tribunal Federal são citadas “gerações de direitos”.

Os direitos de 1.^a geração ou dimensão são os direitos e garantias individuais e políticos clássicos que têm no indivíduo o centro de proteção (liberdades públicas: direito à vida, à liberdade, à expressão e à locomoção). Representam um limite na atuação do Estado, ou seja, não mate, não prenda, entre outras atividades constitutivas.

Tem origem nas revoluções liberais, tais como a Magna Carta de 1215, Habeas Corpus Act (1679), Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), entre outros.

No dizer de Paulo Bonavides:

“Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado” (Curso de direito constitucional, p. 563-564).

Verificam-se nos direitos previstos no art. 5.º da CF/88 (direito à vida, à liberdade, entre outros) excelentes exemplos da exteriorização da 1.ª geração ou dimensão.

Os direitos de 2.ª geração ou dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais que valorizam grupos de indivíduos, tais como os trabalhadores e aposentados (direito ao trabalho, ao seguro social, à subsistência, amparo à doença, à velhice, entre outros). Espera-se uma ação positiva por parte do Estado viabilizando tais direitos. Seu eixo central está na igualdade de condições para os seres humanos.

Surgem em virtude dos excessos da revolução industrial, que consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Além disso, houve a omissão do Estado liberal, ou seja, o Estado interfere de modo mínimo na sociedade.

Destacam-se como documentos importantes vinculados à 2.ª geração de direitos: a Constituição Mexicana de 1917, a Declaração Russa dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918, a Constituição Alemã de 1919 (Weimar), a criação da Organização Internacional do Trabalho (1919), Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, entre outros.

A efetivação dos direitos de 2.ª geração ou dimensão é realizada de modo progressivo pelo Estado, porém nada impede que se proponha uma demanda no Poder Judiciário para que num caso concreto tais direitos sejam implementados de imediato. Por exemplo, a matrícula de um aluno em escola pública, a construção de uma creche (educação), o fornecimento de remédios para uma pessoa doente, ou a construção de um hospital (saúde).

Sobre a comparação entre o Pacto Internacional de Direitos Civis e

Políticos (1966) que representa a 1.^a geração e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 que representa a 2.^a geração, são valiosas as considerações de Flávia Piovesan:

“Se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano pelo Estado, sem escusa ou demora – têm a chamada autoaplicabilidade – os direitos sociais, econômicos e culturais, por sua vez, nos termos em que estão concebidos pelo Pacto, apresentam realização progressiva. Vale dizer, são direitos que estão condicionados à atuação do Estado, que deve adotar medidas econômicas e técnicas, isoladamente e através de assistência e cooperação internacionais, até o máximo de seus recursos disponíveis, com vistas a alcançar progressivamente a completa realização dos direitos previstos pelo Pacto” (Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 180).

Os artigos da Constituição brasileira que estabelecem os direitos trabalhistas e previdenciários descrevem direitos da 2.^a geração ou dimensão. Cite-se, por exemplo, arts. 7.^o, 194, entre outros.

Os direitos da 3.^a geração são conhecidos por direitos de fraternidade ou solidariedade e abrangem um meio ambiente equilibrado, a fraternidade entre os povos, além de outros direitos difusos. Desse modo, busca-se proteger um número indeterminado e indeterminável de pessoas. São enfatizados após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com a criação da Organização das Nações Unidas (1945) e a internacionalização dos direitos humanos.

André Ramos Tavares afirma que:

“São direitos de terceira dimensão aqueles que se caracterizam pela sua titularidade coletiva ou difusa, como o direito do consumidor e o direito ambiental. Também costumam ser denominados como direitos de solidariedade ou fraternidade” (Curso de direito constitucional, p. 471).

Pode-se citar como exemplo da 3.^a geração ou dimensão na CF/88, o art. 225 (proteção do meio ambiente).

Numa visão mais atualizada sobre o tema, há a ampliação doutrinária até a sexta geração de direitos, quais sejam:

Os direitos fundamentais de 4.^a geração, também chamados de direito dos povos, são provenientes da última fase da estruturação do “Estado Social” (globalização do Estado Neoliberal), e englobam o direito à democracia, à informação, ao pluralismo, do patrimônio genético, entre outros. Há quem entenda ser o direito vinculado à evolução da ciência (genética, DNA, clonagem, biodireito, biotecnologia, entre outros).

Os direitos fundamentais de 5.^a geração são aqueles vinculados à paz universal. Nesse sentido, o texto constitucional determina que o Brasil nas suas relações internacionais adota os princípios da não intervenção, da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos (art. 4.^o, IV, VI e VII, da CF/88).

Os direitos fundamentais de 6.^a geração são aqueles referentes ao acesso à água potável. No texto constitucional há a preocupação em proteger o meio ambiente no art. 225 da CF/88.

No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos e garantias fundamentais têm a natureza jurídica de direitos constitucionais, pois estão expressamente elencados no Título II da Constituição Federal vigente. Tais direitos e garantias fundamentais, de regra, têm aplicação imediata (§ 1.^o do art. 5.^o). Porém, para seu efetivo exercício, por vezes, é necessária regulamentação infraconstitucional (são exemplos os incisos XXXII, XLI, LXXVI do art. 5.^o, entre outros).

Decisão sobre o tema:

“Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos

econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade” (STF, MS 22.164/SP, j. 30-10-1995, rel. Min. Celso de Mello, DJ 17-11-1995).

Diferença entre direitos e garantias

Direitos são disposições declaratórias de poder sobre determinados bens e pessoas. Representam por si só certos bens. São principais e visam a realização das pessoas. Direito é o poder para realizar algo, pois o ordenamento jurídico possibilita.

Garantias, em sentido estrito, são os mecanismos de proteção e de defesa dos direitos. Traduzem-se na garantia de os cidadãos exigirem dos Poderes Públicos a proteção dos seus direitos, bem como o reconhecimento de meios processuais adequados a essa finalidade. Por exemplo: habeas corpus, mandado de segurança, entre outros. São acessórios, estando vinculados aos direitos.

Destinatários da proteção (amplitude da proteção)

A CF/88, em seu art. 5.º, estabelece: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.

Abrangência: assegurar a validade e gozo dos direitos fundamentais dentro do território brasileiro, não se excluindo o estrangeiro em trânsito. São protegidas também as pessoas jurídicas. Dessa forma, são titulares dos direitos e garantias fundamentais: os brasileiros, os estrangeiros, as pessoas físicas e jurídicas.

Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5.º da CF/88)

O rol de direitos elencados no art. 5.º e seus 78 incisos é exemplificativo, e não exaustivo, o que se deduz do § 2.º do art. 5.º, que dispõe: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Direitos protegidos no art. 5.º, caput, da CF/88:

Direito à vida

É o primeiro e mais importante dos direitos fundamentais.

O Estado deve proteger a vida de maneira global, inclusive a vida uterina, além de viabilizar a subsistência dos necessitados.

O direito à vida engloba a não interrupção do processo vital senão pela morte espontânea e inevitável. Exceção: pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5.º, XLVII, a, da CF/88).

Decisão sobre o tema:

“Lei da Biossegurança e ADIn. Em conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o art. 5.º da Lei federal n. 11.105/2005 (Lei da Biossegurança), que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento, e estabelece condições para essa utilização – v. Informativo 497. Prevaleceu o voto do Min. Carlos Britto, relator. Nos termos do seu voto, salientou, inicialmente, que o artigo impugnado seria um bem concatenado bloco normativo que, sob condições de incidência explícitas, cumulativas e razoáveis, contribuiria para o desenvolvimento de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades terapêuticas de células extraídas de embrião humano in vitro. Esclareceu que as células-tronco embrionárias,

pluripotentes, ou seja, capazes de originar todos os tecidos de um indivíduo adulto, constituiriam, por isso, tipologia celular que ofereceria melhores possibilidades de recuperação da saúde de pessoas físicas ou naturais em situações de anomalias ou graves incômodos genéticos. Asseverou que as pessoas físicas ou naturais seriam apenas as que sobrevivem ao parto, dotadas do atributo a que o art. 2.º do CC/2002 denomina personalidade civil, assentando que a Constituição Federal, quando se refere à “dignidade da pessoa humana” (art. 1.º, III), aos ‘direitos da pessoa humana’ (art. 34, VII, b), ao ‘livre exercício dos direitos (...) individuais’ (art. 85, III) e aos ‘direitos e garantias individuais’ (art. 60, § 4.º, IV), estaria falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Assim, numa primeira síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativa, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 5.º diria respeito exclusivamente a um indivíduo já personalizado. O relator reconheceu, por outro lado, que o princípio da dignidade da pessoa humana admitiria transbordamento e que, no plano da legislação infraconstitucional, essa transcendência alcançaria a proteção de tudo que se revelasse como o próprio início e continuidade de um processo que desaguasse no indivíduo-pessoa, citando, no ponto, dispositivos da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), da Lei n. 9.434/97, e do Decreto-lei n. 2.848/40 (Código Penal), que tratam, respectivamente, dos direitos do nascituro, da vedação à gestante de dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo e do ato de não oferecer risco à saúde do feto, e da criminalização do aborto, ressaltando, que o bem jurídico a tutelar contra o aborto seria um organismo ou entidade pré-natal sempre no interior do corpo feminino. Aduziu que a lei em questão se referiria, por sua vez, a embriões derivados de uma fertilização artificial, obtida fora da relação sexual, e que o emprego das células-tronco embrionárias para os fins a

que ela se destina não implicaria aborto. Afirmou que haveria base constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que incluísse a fertilização in vitro, que os arts. 226 e s. da CF/88 dispõem que o homem e a mulher são as células formadoras da família e que, nesse conjunto normativo, estabelecer-se-ia a figura do planejamento familiar, fruto da livre decisão do casal e fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável (art. 226, § 7.º), inexistindo, entretanto, o dever jurídico desse casal de aproveitar todos os embriões eventualmente formados e que se revelassem geneticamente viáveis, porque não imposto por lei (CF/88, art. 5.º, II) e incompatível com o próprio planejamento familiar (ST, ADIn 3.510/DF, j. 29-5-2008, rel. Min. Ayres Britto, DJe 28-5-2008).

Considerou, também, que, se à lei ordinária seria permitido fazer coincidir a morte encefálica com a cessação da vida de uma certa pessoa humana, a justificar a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo ainda fisicamente pulsante para fins de transplante, pesquisa e tratamento (Lei n. 9.434/97), e se o embrião humano de que trata o art. 5.º da Lei da Biossegurança é um ente absolutamente incapaz de qualquer resquício de vida encefálica, a afirmação de incompatibilidade do último diploma legal com a Constituição haveria de ser afastada. Por fim, acrescentou a esses fundamentos, a rechaçar a inconstitucionalidade do dispositivo em questão, o direito à saúde e à livre expressão da atividade científica. Frisou, no ponto, que o § 4.º do art. 199 da CF/88 ('A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização') faria parte, não por acaso, da seção normativa dedicada à saúde, direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), que seria garantida por meio de ações e serviços qualificados como de relevância pública, com o que se teria o

mais venturoso dos encontros entre esse direito à saúde e a própria Ciência (art. 5.º, IX, da CF/88)” (STF, ADIn 3.510/DF, j. 29-5-2008, rel. Min. Ayres Britto, DJ 28-5-2010).

Direito à igualdade

As Constituições reconhecem a igualdade no sentido jurídico-formal, ou seja, a igualdade perante a lei. Neste sentido, encontra-se o caput do art. 5.º, onde se lê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Também se pode notar no mesmo art. 5.º, I, que declara: “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. Depois, no art. 7.º, XXX e XXXI, há regras de igualdade material que proíbem distinções fundadas em certos fatores, ao vedarem “diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” e “qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”. Vide, também, arts. 3.º, III e IV, 7.º, XXXIV, 170, 193, 196 e 205 da CF/88.

O legislador, ao criar as normas, não poderá se afastar do princípio da igualdade, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade, sujeitando-se ao controle de constitucionalidade.

O intérprete ou a autoridade pública não poderão aplicar as leis e os atos normativos aos casos concretos de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias.

Por fim, o particular não poderá pautar-se por condutas discriminatórias, preconceituosas ou racistas, sob pena de responsabilidade civil e penal nos termos da legislação em vigor.

IMPORTANTE

STF reconhece a transgêneros possibilidade de alteração de registro civil sem mudança de sexo
O Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a alteração de nome e gênero no assento de registro civil mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. A ação

foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) a fim de que fosse dada interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58 da Lei n. 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, no sentido de ser possível a alteração de prenome e gênero no registro civil mediante averbação no registro original, independentemente de cirurgia de transgenitalização. Todos os ministros da Corte reconheceram o direito, e a maioria entendeu que, para a alteração, não é necessária autorização judicial. Votaram nesse sentido os Ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e a presidente da Corte, Cármen Lúcia. Ficaram vencidos, nesse ponto, o Ministro Marco Aurélio (relator), que considerou necessário procedimento de jurisdição voluntária (em que não há litígio) e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que exigiam autorização judicial para a alteração. O Ministro Dias Toffoli se deu por impedido (STF, Plenário, ADIn 4.275, j. 1.º-3-2018, rel. Min. Marco Aurélio).

Decisões sobre o tema:

“Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem/mulher (gênero), seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. A proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal. Homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural. Liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade. Direito à intimidade e à vida privada. Cláusula pétrea. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3.º da CF/88, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de ‘promover o bem de todos’. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana ‘norma geral negativa’, segundo a qual ‘o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido’. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanção do princípio da ‘dignidade da pessoa humana’: direito a autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo

da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. (...) Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do CC/2002, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de 'interpretação conforme à Constituição'. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva" (STF, ADIn 4.277 e ADPF 132, j. 5-5-2011, rel. Min. Ayres Britto, DJe 14-10-2011). No mesmo sentido: STF, AgRg no RE 477.554, j. 16-8-2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 26-8-2011.

"A vedação constitucional de diferença de critério de admissão por motivo de idade (CF/88, art. 7.º, XXX) é corolário, na esfera das relações de trabalho, do princípio fundamental de igualdade (CF/88, art. 5.º, caput), que se estende, à falta de exclusão constitucional inequívoca (como ocorre em relação aos militares – CF/88, art. 42, § 11), a todo o sistema do pessoal civil. É ponderável, não obstante, a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher. Esse não é o caso, porém, quando, como se dá na espécie, a lei dispensa do limite os que já sejam servidores públicos, a evidenciar que não se cuida de discriminação ditada por exigências etárias das funções do cargo considerado" (STF, RMS 21.046, j. 14-12-1990, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14-11-1991). No mesmo sentido: STF, AgRg no AgIn 722.490, j. 3-2-2009, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6-3-2009.

A liberdade, em sentido genérico, tem vinculação estreita com o conhecimento. O conteúdo da liberdade se amplia com a evolução da humanidade; portanto, a liberdade é uma conquista constante.

De acordo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, “a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei”.

Genericamente, podem ser elencados, na Constituição Federal de 1988, os seguintes direitos, cujo objeto é a liberdade: de locomoção (art. 5.º, LXVIII); de pensamento (art. 5.º, IV, VI, VII, VIII e IX); de reunião (art. 5.º, XVI); de associação (art. 5.º, XVII a XXI); de profissão (art. 5.º, XIII); de ação (art. 5.º, II); de liberdade sindical (art. 8.º); e de greve (art. 9.º).

Decisões sobre o tema:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado” (Súmula Vinculante 11).

“Por entender que o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento devem ser garantidos a todas as pessoas, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação de descumprimento de preceito fundamental para dar, ao art. 287 do CP, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. (...)”

Destacou-se estar em jogo a proteção às liberdades individuais de reunião e de manifestação do pensamento. Em passo seguinte, assinalou-se que a liberdade de reunião, enquanto direito-meio, seria instrumento viabilizador da liberdade de expressão e qualificar-se-ia como elemento apto a propiciar a ativa participação da sociedade civil na vida política do Estado. A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito de reunião, passaria a ser o espaço, por excelência, para o debate. E, nesse sentido, salientou-se que esta Corte, há muito, firmara compromisso com a preservação da integridade das liberdades fundamentais contra o arbítrio do Estado. Realçou-se que a reunião, para merecer a proteção constitucional, deveria ser pacífica, ou seja, sem armas, violência ou incitação ao ódio ou à discriminação. Ademais, essa liberdade seria constituída por cinco elementos: pessoal, temporal, intencional, espacial e formal. Ponderou-se que, embora esse direito possa ser restringido em períodos de crise institucional, ao Estado não seria permitido, em período de normalidade, inibir essa garantia, frustrar-lhe os objetivos ou inviabilizá-la com medidas restritivas. Apontou-se, ademais, que as minorias também titularizariam o direito de reunião. Observou-se que isso evidenciaria a função contra majoritária do STF no Estado Democrático de Direito. Frisou-se, nessa contextura, que os grupos majoritários não poderiam submeter, à hegemonia de sua vontade, a eficácia de direitos fundamentais, especialmente tendo em conta uma concepção material de democracia constitucional. (...) Concluiu-se que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas ou de proposta abolicionista a outro tipo penal, não significaria ilícito penal, mas, ao contrário, representaria o exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião” (STF, ADPF 187, j. 15-6-2011, rel. Min. Celso de Mello, Informativo 631).

“Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas

com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais” (RE 898.450, rel. Min. Luiz Fux, DJ 17-8-2016).

IMPORTANTE

No julgamento do RE 898.450, o Ministro Luiz Fux, observou que a criação de barreiras arbitrárias para impedir o acesso de candidatos a cargos públicos fere os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Assim, qualquer obstáculo a acesso a cargo público deve estar relacionado unicamente ao exercício das funções como, por exemplo, idade ou altura que impossibilitem o exercício de funções específicas.

A jurisprudência do STF prevê que o limite de idade estabelecido em lei é constitucional, desde que justificável em relação à natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Deste modo, a tatuagem, por si só, não pode ser confundida como uma transgressão ou conduta atentatória aos bons costumes.

Sustentou-se que a tatuagem passou a representar uma autêntica forma de liberdade de manifestação do indivíduo, pela qual não pode ser punido, sob pena de flagrante violação dos princípios constitucionais (STF, RE n. 898.450 RG/SP, j. 17-8-2016, rel. Min. Luiz Fux).

Direito à propriedade

O art. 1.228 do Código Civil de 2002 assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e o direito de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua ou detenha.

A propriedade, bem como os demais direitos fundamentais, deve sujeitar-se às limitações exigidas pelo bem comum, podendo ser perdida em favor do Estado quando o interesse público o reclamar.

Na Constituição Federal de 1988, sobre a propriedade podem-se citar as seguintes normas constitucionais: art. 5.º, XXII (em geral), XXIII (função social), XXIV (desapropriação); artística, literária e científica: art. 5.º, XXVII a XXIX; hereditária: art. 5.º, XXX e XXXI.

A Constituição Federal, no art. 5.º, XXII, XXIII e XXIV, reconhece o direito de propriedade, cujo uso deverá ser condicionado ao bem-estar social. Esse direito é garantido pela exigência de que toda expropriação se faça

mediante prévia e justa indenização, que em princípio deve ser paga em dinheiro.

A desapropriação é uma evolução jurídica, pois no início o monarca apropriava-se das terras que desejasse sem qualquer espécie de indenização. Não existia proteção jurídica sobre o direito de propriedade contra o confisco do Estado. Com a evolução histórica, o liberalismo fez nascer o Estado de Direito, limitando o poder do monarca às leis.

Ao confisco (não indenizável, imotivado, fruto do capricho e da voluntariedade) sucede a desapropriação (indenizável, de acordo com a lei, mediante prévia e justa indenização).

ATENÇÃO

Função social – Art. 182, § 2.º (propriedade urbana), art. 186 (propriedade rural), usucapião constitucional urbano (art. 183) e rural (art. 191), desapropriação rural para reforma agrária (art. 184). Destaque-se que há o confisco previsto no art. 243 da CF/88 para as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. As propriedades serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular.

Direito à segurança

É considerado um conjunto de garantias e direitos composto por situações, proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum direito individual fundamental. Por exemplo:

- a) a segurança do domicílio (art. 5.º, XI): “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”;

Para a aplicação do citado dispositivo, deve ser observado o que dispõe o Código Penal, no art. 150, § 4.º, onde se lê: “A expressão ‘casa’ compreende: I – qualquer compartimento habitado; II – aposento ocupado

de habitação coletiva; III – compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade”.

ATENÇÃO

O § 5.º do artigo em referência destaca: “Não se compreendem na expressão ‘casa’: I – hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n. II do parágrafo anterior; II – taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero”.

b) a segurança de comunicações pessoais (art. 5.º, XII);

Decisão sobre o tema:

“Escuta ambiental e exploração de local. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no período noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. (...) Inteligência do art. 5.º, X e XI, da CF/88; art. 150, § 4.º, III, do CP; e art. 7.º, II, da Lei n. 8.906/94. (...) Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão” (STF, Inq 2.424/RJ, j. 26-11-2008, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 26-3-2010).

c) a segurança em matéria penal (art. 5.º, XXXVII a XLVII);

d) a segurança em matéria tributária (art. 150).

Destaque-se que a leitura do art. 5.º da CF/88 (caput, 78 incisos e quatro parágrafos) é imprescindível para entender a amplitude e a complexidade do tema “direitos e garantias fundamentais”. Além disso, este é tema recorrente nos concursos públicos brasileiros.

Após a Emenda Constitucional n. 45/2004 houve: (a) a

“constitucionalização” dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 5.º, § 3.º, da CF/88); (b) a submissão do Brasil à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão (art. 5.º, § 4.º, da CF/88).

IMPORTANTE

No art. 5.º da CF/88 podemos encontrar alguns dos grandes princípios do direito, tais como:

a) Princípio da isonomia: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição” (art. 5.º, I);

Doutrina e jurisprudência assentam que o princípio da igualdade jurídica consiste em assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, com as obrigações correspondentes, ou, segundo a forma clássica, “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na proporção em que se desigualem”. Por isso, a isonomia tanto admite, por exemplo, que a licença-maternidade seja maior que a licença-paternidade (em razão da diferença entre homens e mulheres quanto à gravidez), quanto assegura que a licença-maternidade de todas as mulheres seja definida pela lei com igual alcance.

b) Princípio da legalidade: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5.º, II, da CF/88);

c) Princípio da irretroatividade da lei: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5.º, XXXVI, da CF/88);

d) Princípio do acesso ao Judiciário: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5.º, XXXV, da CF/88);

ATENÇÃO

“Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa” (Súmula 667 do STF).

e) Princípio do juiz natural: “não haverá juízo ou tribunal de exceção” e “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” (art. 5.º, XXXVII e LIII, da CF/88);

f) Princípio do devido processo legal: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5.º, LIV, da CF/88);

g) Princípio do contraditório e da ampla defesa: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5.º, LV, da CF/88);

h) Princípio da celeridade: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5.º, LXXVIII, da CF/88).

Decisões sobre o tema:

“Reconhecimento e qualificação da união homoafetiva como entidade familiar. O STF – apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando princípios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade) – reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar, atribuindo-lhe, em consequência, verdadeiro estatuto de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências no plano do direito, notadamente no campo previdenciário, e, também, na esfera das relações sociais e familiares. A extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição Federal de 1988 (arts. 1.º, III e 3.º, IV), fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar. (...). O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (art. 1.º, III, da CF/88) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que

conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. (...) O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma ideia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana” (STF, AgRg no RE 477.554/MG, 2.^a T., j. 16-8-2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 26-8-2011.) No mesmo sentido: STF, ADIn 4.277/DF e ADPF 132/RJ, Plenário, j. 5-5-2011, rel. Min. Ayres Britto, DJe 14-10-2011.

“Prazo para a Fazenda Pública opor embargos à execução. (...) Aplicação do prazo ampliado de trinta dias, previsto no art. 730 do CPC), dando-se processamento imediato à petição, em respeito à razoável duração do processo” (STF, AgRg na Rcl 10.202/SP, Plenário, j. 18-11-2010, rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17-5-2011).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 39 e 94 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). (...). Aplicabilidade dos procedimentos previstos na Lei n. 9.099/95 aos crimes cometidos contra idosos. (...). Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme a Constituição brasileira, com redução de texto, para suprimir a expressão ‘do Código Penal e’. Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e

de interpretação benéfica ao autor do crime” (STF, ADIn 3.096/DF, Plenário, j. 16-6-2010, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3-9-2010). Vide: STF, HC 106.212/MS, Plenário, j. 24-3-2011, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 13-6-2011.

“Extrapola o limite do razoável o não julgamento de recurso de apelação interposto há quase dois anos e meio. Impõe-se rever o entendimento de que o excesso de prazo deve ser computado somente até a prolação da sentença, quando há a formação da culpa. Há de se impor, também, tempo razoável para o julgamento dos recursos, notadamente porque o CPP contém previsão expressa nesse sentido” (STF, HC 99.425/SP, 2.^a T., j. 15-12-2009, rel. Min. Eros Grau, DJe 16-4-2010). No mesmo sentido: STF, HC 96.665/SP, 2.^a T., j. 1.^o-2-2011, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 16-3-2011.

16.1. HABEAS CORPUS

O art. 5.^o, LXVIII, da CF/88 estabelece: “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

O endereçamento do habeas corpus deverá ser para a autoridade imediatamente superior à coatora, tal como se vê nos seguintes exemplos:

Autoridade coatora	Autoridade competente
Autoridade policial estadual	Juiz de Direito da Vara Criminal
Autoridade policial estadual em infração de menor potencial ofensivo	Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal
Autoridade policial estadual em crime doloso contra a vida	Juiz de Direito da Vara do Júri
Autoridade policial federal	Juiz Federal da Vara Criminal
Autoridade policial federal em infração de menor	Juiz Federal do Juizado Especial Criminal

potencial ofensivo	Federal
Promotor de Justiça	Tribunal de Justiça
Procurador da República	Tribunal Regional Federal
Juiz de Direito	Tribunal de Justiça
Juiz Federal	Tribunal Regional Federal
Juiz do Juizado Especial Criminal	Turma Recursal do Juizado Especial Criminal
Juiz do Juizado Especial Criminal Federal	Turma Recursal do Juizado Especial Criminal Federal
Turma Recursal	Tribunal de Justiça
Turma Recursal Federal	Tribunal Regional Federal
Tribunal de Justiça	Superior Tribunal de Justiça
Tribunal Regional Federal	Superior Tribunal de Justiça
Superior Tribunal de Justiça	Supremo Tribunal Federal
Particular em crime estadual	Juiz de Direito da Vara Criminal
Particular em crime federal	Juiz Federal da Vara Criminal

Sujeito ativo (impetrante): qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, inclusive pessoa jurídica. Atentar para a previsão do art. 654, caput, do CPP, onde se lê: “O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público”.

Desse modo, são legitimados ativos:

- a) qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, independentemente de habilitação legal ou de representação por advogado. Incluem-se o estrangeiro, o menor de idade, o insano mental e o analfabeto (desde

que alguém assine a petição a rogo – art. 654, § 1.º, c, do CPP);

- b) o Ministério Público, exceto no juízo em que atua (como, por exemplo, para trancar a ação penal por ele proposta), pois, do contrário, estaria criando impedimento para oficiar nos autos. O Ministério Público é legitimado a impetrar habeas corpus, inclusive perante Tribunais, sendo que, nesse caso, caberá ao órgão oficiante em 2.ª instância acompanhá-lo, oferecer sustentação oral, recorrer etc.;
- c) em relação ao juiz, é importante destacar que, nessa condição, não pode impetrar habeas corpus, uma vez que cabe a ele a função de julgá-lo. Pode, porém, conceder o habeas corpus de ofício, no curso do processo em que tenha competência, nos termos do art. 654, § 2.º, do CPP.

Percebe-se que não há a exigência de capacidade postulatória nem dependência de representação por advogado.

Paciente (vítima): qualquer pessoa física, maior ou menor de idade, brasileiro ou estrangeiro.

ATENÇÃO

Em crimes ambientais, pessoas jurídicas podem se utilizar do habeas corpus para trancar o inquérito ou o processo criminal ilegal ou abusivo (posição minoritária).

Sobre o tema, em virtude de sua grande incidência em concursos públicos, é importante a leitura da alínea d do inciso I do art. 102, bem como da alínea c do inciso I do art. 105 da CF/88.

O primeiro dispositivo (art. 102, I, d, da CF/88) dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o habeas corpus cujo paciente seja o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República, os

Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.

O outro dispositivo mencionado (art. 105, I, c, da CF/88), dispõe que caberá, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, julgar os habeas corpus, no caso de o coator ou paciente ser Governador dos Estados e do Distrito Federal, bem como desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, membro dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, membro dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e do Ministério Público da União que officie perante tribunais. Outrossim, caberá o recurso quando se tratar o coator de tribunal sujeito à sua jurisdição, de Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Sujeito passivo: autoridade ou agente público.

Trata-se do coator, ou seja, a pessoa que, por ilegalidade ou abuso de poder, está causando o constrangimento ou a ameaça à liberdade de locomoção de alguém.

É possível que o particular figure no polo passivo, pois a Constituição Federal de 1988 não se referiu apenas ao “abuso de poder” (próprio das autoridades públicas), mas também à “ilegalidade”, que pode decorrer, também, de conduta do particular.

Ressalte-se, porém, que há posição na doutrina minoritária que defende não ser possível o particular como sujeito passivo do habeas corpus.

Espécies:

a) **preventivo**: visa a evitar a ocorrência de uma violação à liberdade. O juiz expede salvo-conduto, para impedir a prisão ou a detenção pelo motivo alegado;

b) **liberatório ou repressivo**: objetiva a cessação da efetiva coação ao direito de ir e vir. O juiz expede o alvará de soltura (se o paciente se encontrar preso) ou o contramandado (se contra o paciente houver a expedição de mandado de prisão).

Visa, assim, a afastar o constrangimento ilegal já existente à liberdade de locomoção.

É isento de custas.

Regulamentação: arts. 647 a 667 do CPP.

As hipóteses de cabimento do habeas corpus estão elencadas nos incisos do art. 648 do CPP:

“I – quando não houver justa causa”

O inciso se refere à prisão em que não há fundamentos legais e fáticos para a prisão, para o inquérito policial ou para a ação penal.

Em relação à prisão, somente há justa causa quando ocorrer em razão de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial, salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar definido em lei (art. 5.º, LXI, da CF/88).

“II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei”

Existindo excesso de prazo não justificado para a restrição da liberdade de um preso, indiciado ou réu, haverá constrangimento ilegal na sua permanência na prisão.

Para a instrução processual, a jurisprudência estabeleceu um prazo para a prisão de 81 dias (rito ordinário perante a Justiça Estadual) e de 101 dias (perante a Justiça Federal).

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

- **Súmula 21:** “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
- **Súmula 52:** “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
- **Súmula 64:** “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

“III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo”

A prisão somente poderá ser determinada por decisão fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo as hipóteses legais de flagrante delito e nas hipóteses de transgressão militar ou crime militar.

“IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação”

Desaparecida a causa que determinou a prisão, esta deve cessar – se, por exemplo, o paciente já tiver cumprido a totalidade da pena imposta.

“V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza”

A fiança constitui garantia constitucional prevista no inciso LXVI do art. 5.º da CF/88 (“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”), e as suas hipóteses de cabimento estão previstas nos arts. 323, 324 e 325 do CPP.

ATENÇÃO

Verificar as alterações promovidas pela Lei n. 12.403/2011.

“VI – quando o processo for manifestamente nulo”

Trata-se de hipótese de existência de patente nulidade, em relação à qual não há dúvida, e que pode atingir o processo total ou parcialmente – por exemplo, se violado o devido processo legal, haverá incidência de constrangimento ilegal representado pela ação penal.

“VII – quando extinta a punibilidade”

Ocorrendo uma causa extintiva de punibilidade (art. 107 do CP), o inquérito policial ou a ação penal devem ser trancados.

A petição do habeas corpus deve conter os requisitos previstos no § 1.º do art. 654 do CPP e será dirigida ao juiz ou tribunal competente, juntamente com todas as provas que demonstram a existência da ilegalidade ou do abuso de poder (prova pré-constituída).

Admite-se o pedido de liminar, desde que, de plano, se demonstre a ilegalidade ou o abuso da coação (*fumus boni iuris*) e o perigo da demora (*periculum in mora*).

O juiz ou Tribunal requisitará as informações da autoridade apontada como coatora (art. 662 do CPP), que devem ser apresentadas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de multa (art. 655 do CPP).

Se o habeas corpus for impetrado perante o magistrado de 1.º grau, o Ministério Público não intervirá antes de proferida a decisão, salvo se for o próprio impetrante. Todavia, nada impede que o magistrado lhe abra vista dos autos. Porém, se impetrado perante tribunal, o Ministério Público terá vista dos autos, pelo prazo de dois dias, após as informações da autoridade coatora, conforme estabelece o art. 1.º, § 2.º, do Decreto-lei n. 552/69.

Prestadas as informações e após a manifestação do Ministério Público, nos casos em que for necessária, a autoridade judicial proferirá decisão fundamentada.

Da decisão proferida no habeas corpus pode-se ter o seguinte:

- a) concedida a ordem (liberatório), o paciente deverá ser imediatamente solto, salvo se por outro motivo deve ser mantido preso (art. 660, § 1.º, do CPP);
- b) concedida a ordem (preventivo), será expedido salvo-conduto em favor do paciente (art. 660, § 4.º, do CPP);
- c) concedida a ordem para trancar o inquérito policial ou a ação penal, ficará impedida a instauração de outro procedimento ou processo que trate dos mesmos fatos (inciso I do art. 648 do CPP);
- d) concedida a ordem, será arbitrado o valor da fiança, que, uma vez prestada, permitirá a liberação do paciente (inciso V do art. 648 do CPP);
- e) concedida a ordem para anular o processo, este será renovado a partir do momento em que se verificou a nulidade (inciso VII do art. 648 e art. 652 do CPP).

Recursos:

- a) da decisão do juiz que concede ou nega a ordem de habeas corpus caberá recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, X, do CPP;
- b) da decisão do juiz que concede a ordem de habeas corpus há, ainda, a previsão do recurso de ofício, nos termos do art. 574, I, do CPP;
- c) da decisão denegatória da ordem de habeas corpus proferida por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal cabe, no prazo de 5 dias (art. 30 da Lei n. 8.038/90), recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, II, a, da CF/88;
- d) da decisão denegatória da ordem de habeas corpus proferida por Tribunais Superiores cabe, no prazo de 5 dias (art. 310 do Regimento Interno do STF), recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88.

Cumpra-se destacar que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer da decisão que concede habeas corpus, devendo ser intimado da decisão proferida.

Quando denegatória a decisão, são legitimados para recorrer o impetrante e o paciente.

Prevalecia na jurisprudência o entendimento de que, em vez de recorrer, o impetrante pode impetrar outro habeas corpus diretamente ao órgão jurisdicional superior, por ter o inferior se transformado em autoridade coatora, não havendo proibição expressa quanto a esse procedimento no Código de Processo Penal. Parte da doutrina, entretanto, afirmava que esse procedimento somente seria possível quando já houvesse trânsito em julgado da decisão original, pois, enquanto isso não ocorresse, o procedimento adequado seria a interposição do recurso previsto em lei.

A jurisprudência do STJ e do STF modificou entendimento no sentido de que da denegação do habeas corpus em competência originária deve ser utilizado o Recurso Ordinário Constitucional, sendo inadequado o uso do HC substitutivo de recurso. Nesse sentido: "Habeas corpus. Julgamento por Tribunal Superior. Impugnação. A teor do disposto no art. 102, II, a, da CF/88, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus" (STF, HC 109.956, 1.^a T., j. 7-8-2012, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11-9-2012.) No mesmo sentido: HC 113.281, 1.^a T., j. 11-9-2012, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10-10-2012; HC 108.181, 1.^a T., j. 21-8-2012, rel. Min. Luiz Fux, DJe 6-9-2012. Em sentido contrário: HC 110.270, 2.^a T., j. 6-12-2011, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19-12-2011; HC 97.293, 1.^a T., j. 16-6-2009, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16-4-2010. Vide: HC 115.168, 1.^a T., j. 21-5-2013, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17-6-2013.

Decisões sobre o tema:

O Supremo Tribunal Federal tem admitido a utilização do habeas corpus para o desentranhamento de prova ilícita em procedimento penal, bem como para o trancamento de inquérito policial ou ação penal onde se constata ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, pode-se citar o HC 80.949/RJ, o HC 80.420/RJ, entre outros.

As Comissões Parlamentares de Inquérito não podem decretar a condução coercitiva de testemunha, busca e apreensão, indisponibilidade de bens e prisão temporária (Informativo 416 do STF, HC 88.015/DF e MS 25.832/DF).

As auditorias militares estaduais somente podem julgar policiais militares e bombeiros militares, mas não civis (STF, HC 70.604/SP; HC 72.022/PR, entre outros).

De acordo com o STF, os tratados e convenções internacionais são incorporados como normas infraconstitucionais (STF, RHC 80.035/SC, entre outros). Não se trata de uma obrigação, mas sim de uma faculdade atribuída ao Congresso Nacional de equipará-los à emenda constitucional.

É inconstitucional o art. 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/90 – Lei dos Crimes Hediondos –, que dispunha que as penas ali previstas seriam cumpridas integralmente no regime fechado, por afrontar o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, XLVI, da CF/88 (STF, HC 82.959/SP, Plenário, j. 23-2-2006, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1.º-9-2006).

A gravação de conversa entre duas pessoas, feita por uma delas sem o consentimento da outra, registrando o fato para prevenir uma negação futura, é considerada lícita, sendo possível a utilização do registro como meio de defesa. Esse tipo de gravação clandestina é considerado lícito somente para utilização como meio de defesa. Nesse sentido, podem-se citar, como exemplo, as seguintes decisões: STF, HC 74.678/SP e AgRg no Ag 50.3617/PR.

Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por

desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. Nesse sentido, há decisão do Supremo Tribunal Federal: STF, HC 80.867/PI.

O Supremo Tribunal Federal, mudando seu antigo posicionamento, decidiu que o habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal é de competência do Tribunal de Justiça. A competência do Supremo Tribunal Federal está prevista de forma exaustiva no art. 102, I, da CF/88. Deixa de se aplicar a Súmula 690 (HC 86.834/SP).

“Competência. Habeas corpus. Definição. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos – paciente e impetrante. Competência – Habeas corpus – Ato de Turma Recursal. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenha praticado. Competência. Habeas corpus. Liminar. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente” (STF, HC 86.834/SP, Plenário, j. 23-8-2006, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 9-3-2007).

“Habeas corpus. Publicação de livros: antissemitismo. Racismo. Crime imprescritível. Conceituação. Abrangência constitucional. Liberdade de expressão. Limites. Ordem denegada. Escrever, editar, divulgar e comercializar livros ‘fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias’ contra a comunidade judaica (Lei n. 7.716/89, art. 20, na redação dada pela Lei n. 8.081/90) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF/88, art. 5.º, XLII)” (STF, HC 82.424, Plenário, j. 17-9-2003, rel. p/ acórdão Min. Presidente Maurício Corrêa, DJ 19-3-2004).

“É cabível habeas corpus para apreciar toda e qualquer medida que

possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou, ainda, agravar as restrições a esse direito. Esse o entendimento da Segunda Turma ao deferir habeas corpus para assegurar a detento em estabelecimento prisional o direito de receber visitas de seus filhos e enteados. (...) De início, rememorou-se que a jurisprudência hodierna da Corte estabelece sérias ressalvas ao cabimento do writ, no sentido de que supõe violação, de forma mais direta, ao menos em exame superficial, à liberdade de ir e vir dos cidadãos. Afirmou-se que essa orientação, entretanto, não inviabilizaria, por completo, o processo de ampliação progressiva que essa garantia pudesse vir a desempenhar no sistema jurídico brasileiro, sobretudo para conferir força normativa mais robusta à Constituição. A respeito, ponderou-se que o Supremo tem alargado o campo de abrangência dessa ação constitucional, como no caso de impetrações contra instauração de inquérito criminal para tomada de depoimento, indiciamento de determinada pessoa, recebimento de denúncia, sentença de pronúncia no âmbito do processo do Júri e decisão condenatória, entre outras. Enfatizou-se que a Constituição teria o princípio da humanidade como norte e asseguraria aos presidiários o respeito à integridade física e moral [CF/88, art. 5.º: 'XLIX (...)']. (...) Aludiu-se que a visitação seria desdobramento do direito de ir e vir, na medida em que seu empecilho agravaria a situação do apenado" (STF, HC 107.701, 2.ª T., j. 13-9-2011, rel. Min. Gilmar Mendes, Informativo 640).

O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus em que se questionava a legitimidade da ordem de prisão, por 60 dias, decretada em desfavor do paciente que, intimado a entregar o bem do qual era depositário, não adimplira a obrigação contratual (Informativo 531 do STF, HC 87.585/TO) – Vide Súmula Vinculante 25.

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu habeas corpus

impetrado em favor de depositário judicial, e averbou expressamente a revogação da Súmula 619 (“a prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura da ação de depósito”) (Informativo 531 do STF, HC 92.566/SP) – Vide Súmula Vinculante 25.

Súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre habeas corpus:

- **Súmula 395:** “Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção”.

- **Súmula 431:** “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.

- **Súmula 692:** “Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito”.

- **Súmula 693:** “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”.

- **Súmula 694:** “Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”.

- **Súmula 695:** “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.

Súmulas do STJ sobre o tema:

- **Súmula 21:** “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

- **Súmula 52:** “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

- **Súmula 64:** “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

16.2. HABEAS DATA

O art. 5.º, LXXII, da CF/88 enuncia: “Conceder-se-á habeas data: (a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; (b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”.

O endereçamento do habeas data dependerá da autoridade que nega as informações, tal como se vê nos seguintes exemplos:

Autoridade coatora	Autoridade competente
Autoridade estadual, dirigentes ou serventuários estaduais ou municipais	Juiz de Direito
Autoridade federal, dirigentes ou serventuários federais – art. 109, VIII, CF/88	Juiz Federal
Autoridade do Tribunal Regional Federal ou juiz Federal – art. 108, I, c, CF/88	Tribunal Regional Federal
Ministro de Estado, Comandantes da Marinha, Exército ou Aeronáutica ou autoridade do STJ – art. 105, I, b, CF/88	Superior Tribunal de Justiça
Presidente da República, Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de contas da União, do Procurador-Geral da República e autoridade do Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, d, CF/88	Supremo Tribunal Federal

É um remédio constitucional que tem por finalidade proteger a esfera íntima dos indivíduos (pessoas físicas ou jurídicas), possibilitando a obtenção e a retificação de dados e informações constantes de entidades governamentais ou de caráter público. Por exemplo, dados sobre origem racial, ideológica, religiosa, política, filiação partidária ou sindical, orientação sexual, regularidade fiscal, entre outros.

Considera-se de caráter público, de acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.507/97, “todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações”.

Sujeito ativo: característica – em regra, é ação personalíssima, não se admitindo pedido de terceiros nem sucessão no direito de pedir. Porém, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, os herdeiros legítimos do falecido ou seu cônjuge supérstite podem impetrá-lo para a defesa da honra e do nome da família ou do próprio falecido.

Sujeito passivo: devem figurar sempre as entidades governamentais ou de caráter público. Portanto, podem figurar como sujeito passivo os órgãos da administração direta e indireta, bem como das entidades de caráter público, ou seja, entidades privadas que prestam serviço público por meio de concessão, permissão, licença ou autorização.

É necessário demonstrar a recusa ao acesso às informações, sua retificação ou decurso do prazo legal sem decisão, sob pena de carência de ação por falta de interesse de agir (art. 8.º, parágrafo único, I, II e III, da Lei n. 9.507/97).

O habeas data necessita da atuação de advogado.

Regulamentação: Lei n. 9.507/97. Observação: Certidões: Lei n. 9.051/95.

IMPORTANTE

Lei n. 12.527/2011 regulamentou o acesso às informações públicas.

Decisões sobre o tema:

“Habeas data. Legitimidade. Viúva. Demora. Administração. O cônjuge

supérstite tem legitimidade para impetrar habeas data em defesa do interesse do falecido. A utilização desse instrumento relaciona-se diretamente a uma pretensão resistida consubstanciada na recusa de a autoridade responder, implícita ou explicitamente, a seu pedido, daí a razão da Súmula 2-STJ. Dessa forma, a demora de atender o pedido formulado administrativamente (mais de um ano) não é razoável, quanto mais ao considerar-se a idade avançada da impetrante, tudo a impor a concessão da ordem.” Precedente citado do STF: RHD 22-DF, DJ 1.º-9-1995 (HD 147-DF, j. 12-12-2007, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

“Habeas data – Dados de cônjuge falecido – Legitimidade do supérstite – art. 5.º, LXXII, a, da Constituição Federal. Viúva de Militar da Aeronáutica. Acesso a documentos funcionais. Ilegitimidade passiva e ativa. Não ocorrência. Omissão da Administração Caracterizada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas data n. 147/DF, implementou ordem, consignando que, embora, na ação, não se busque informações acerca da pessoa da recorrida, mas do marido desta, falecido, está em jogo a própria garantia constitucional inserta no art. 5.º, LXXII. Os documentos requisitados teriam o condão de influenciar o patrimônio moral e financeiro dos herdeiros. Proclamou não ser razoável a demora de mais de um ano, do Ministro da Defesa, em fornecer os dados relativos ao curso realizado na Escola de Sargentos Aviadores da Aeronáutica” (STF, RE 589.257/DF, j. 5-8-2014, rel. Min. Marco Aurélio).

A utilização de habeas data como remédio jurídico-constitucional-processual destinado a garantir o direito de acesso a registros públicos e de retificação destes depende de condições prévias. É o previsto no art. 8.º, parágrafo único, I, II e III, da Lei n. 9.507/97. Nesse sentido é a decisão do STF: RHD 22/DF.

“ O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada,

o exercício da pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: a) direito de acesso aos registros existentes; b) direito de retificação dos registros errôneos; e c) direito de complementação dos registros insuficientes ou incompletos. Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, que representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem” (STF, HD 75/DF, rel. Min. Celso de Mello).

“A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo” (AgRg no HD 90, Plenário, j. 18-2-2010, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 19-3-2010). No mesmo sentido: AgRg no HD 92, Plenário, j. 18-8-2010, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3-9-2010.

“O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5.º da CF/88, sua impetração deve ter por objetivo ‘assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante’” (AgRg no HD 87, Plenário, j. 25-11-2009, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5-2-2010).

16.3. MANDADO DE INJUNÇÃO

O art. 5.º, LXXI, da CF/88 estabelece: “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

O endereçamento do mandado de injunção dependerá da autoridade que poderá regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada, tal como se vê nos seguintes exemplos:

Autoridade omissa	Autoridade competente
Congresso Nacional ou Presidente da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal	Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, q, da CF/88)
Órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal	Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, h, da CF/88)

Fundamento: existência de uma norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada impedindo o exercício de um direito em caso concreto (inconstitucionalidade por omissão).

ATENÇÃO

A mesma situação autoriza uma ADIn por omissão, que pertence ao controle concentrado e tem os legitimados ativos previstos no art. 12-A da Lei n. 9.868/99 e art. 103 da CF/88.

Historicamente, o Supremo Tribunal Federal entendia haver apenas uma mera recomendação ao Poder Legislativo para que editasse a norma, sem qualquer consequência no caso de não atendimento. Porém, recentemente, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeito concreto ao pedido requerido pela parte em face da omissão do Poder Legislativo (MI 670/ES, 721/DF e 712/PA).

Nesse sentido já se posicionava a doutrina, que afirmava ser possível a solução apenas do caso concreto pelo Poder Judiciário. Note-se que, se a omissão fosse do Poder Executivo, havia a ordem para regulamentação, sob pena de se incorrer em crime de responsabilidade (art. 85, VII, da CF/88).

Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.

Sujeito ativo: as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas pendentes de regulamentação.

Sujeitos passivos: o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

Procedimento:

A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculado. Se não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados.

Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original, ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 (dez) dias, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à segunda via da petição.

Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação.

Recebida a petição inicial, será ordenada: I – a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações; II – a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito.

Destaque-se que a petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente.

Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo, em 5 (cinco) dias, para o órgão colegiado competente para o julgamento da

impetração.

Terminado o prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 (dez) dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para decisão.

Reconhecida a mora legislativa, será deferida a injunção para:

I – determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II – estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Será dispensada a determinação do prazo razoável para a edição da norma quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

Saliente-se que a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora.

IMPORTANTE

Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator.

O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios.

Cumprido destacar que sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito.

A ação de revisão observará, no que couber, o procedimento estabelecido na Lei n. 13.300, de 2016.

A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc (pro futuro) em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável.

Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito.

Previsões constitucionais: art. 102, I, q (STF); art. 105, I, h (STJ); art. 121, § 4.º, V (TSE); e art. 125, § 1.º (TJ).

Regulamentação: Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016.

Decisões sobre o tema:

O Supremo Tribunal Federal atribuiu efeito concreto ao pedido requerido pela parte em face da omissão do Poder Legislativo (MI 670/ES, 721/DF e 712/PA).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível a concessão de medida liminar em Mandado de injunção (MI 342/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1.º-1-1991; MI 530-3/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 8-3-1996; MI 535-4/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14-3-1996; MI 584-2/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 3-8-1998).

1) Aposentadoria especial do art. 40, § 4.º, da CF/88

“O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em mandado de injunção impetrado contra o Presidente da República, por servidora do Ministério da Saúde, para, de forma mandamental, assentar o direito da impetrante à contagem diferenciada do tempo de serviço, em decorrência de atividade em trabalho insalubre prevista no § 4.º do art. 40 da CF/88, adotando como parâmetro o sistema do regime geral de previdência social (Lei n. 8.213/91, art. 57), que dispõe sobre a

aposentadoria especial na iniciativa privada. Na espécie, a impetrante, auxiliar de enfermagem, pleiteava fosse suprida a falta da norma regulamentadora a que se refere o art. 40, § 4.º, a fim de possibilitar o exercício do seu direito à aposentadoria especial, haja vista ter trabalhado por mais de 25 anos em atividade considerada insalubre” (STF, MI 721/DF, j. 30-8-2007, rel. Min. Marco Aurélio).

“Na linha da nova orientação jurisprudencial fixada no julgamento do MI 721/DF (DJe 30-11-2007), o Tribunal julgou procedente pedido formulado em mandado de injunção para, de forma mandamental, assentar o direito do impetrante à contagem diferenciada do tempo de serviço em decorrência de atividade em trabalho insalubre prevista no § 4.º do art. 40 da CF/88, adotando como parâmetro o sistema do regime geral de previdência social (Lei n. 8.213/91, art. 57), que dispõe sobre a aposentadoria especial na iniciativa privada. Tratava-se, na espécie, de writ impetrado por servidor público federal, lotado na função de tecnologista, na Fundação Oswaldo Cruz, que pleiteava o suprimento da lacuna normativa constante do aludido § 4.º do art. 40, assentando-se o seu direito à aposentadoria especial, em razão de trabalho, por 25 anos, em atividade considerada insalubre, em que mantinha contato com agentes nocivos, portadores de moléstias humanas e com materiais e objetos contaminados. Determinou-se, por fim, a comunicação ao Congresso Nacional para que supra a omissão legislativa” (STF, MI 758/DF, j. 1.º-7-2008, rel. Min. Marco Aurélio).

Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4.º, III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

2) Aviso prévio proporcional

“O Tribunal julgou procedentes quatro pedidos formulados em mandado de injunção para declarar a mora legislativa do Congresso Nacional na regulamentação do direito ao aviso prévio proporcional previsto no art. 7.º, XXI, da CF/88, e para determinar a comunicação da decisão a esse órgão (...)”. (MI 369/DF, rel. org. Min. Sydney Sanches, rel. p/ o acórdão Min. Francisco Rezek; MI 95/RR, j. 7-10-1992, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Sepúlveda Pertence; MI 124/SP, j. 7-10-1992, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Sepúlveda Pertence; MI 278/MG, j. 3-10-2001, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Ellen Gracie; MI 695/MA, j. 1.º-3-2007, rel. Min. Sepúlveda Pertence).

16.4. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO

O endereçamento do mandado de injunção dependerá da autoridade que poderá regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada, tal como se vê nos seguintes exemplos:

Autoridade omissa	Autoridade competente
Congresso Nacional ou Presidente da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal	Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, q, da CF/88)
Órgão, entidade ou autoridade federal, da Administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal	Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, h, da CF/88)

Fundamento: existência de uma norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada impedindo o exercício de um direito em caso concreto (inconstitucionalidade por omissão).

Sujeitos ativos: I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária; III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial; IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados (que comprovarem insuficiência de recursos).

Sujeitos passivos: o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria.

No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator.

IMPORTANTE

O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva.

Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança e do Código de Processo Civil.

Regulamentação: Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016.

Decisões sobre o tema:

“A jurisprudência do STF admite legitimidade ativa ad causam aos sindicatos para a instauração, em favor de seus membros ou associados, do mandado de injunção coletivo” (STF, MI 472-2/DF, j. 16-11-1994, rel. Min. Celso de Mello; STF, MI 102/PE, Pleno, j. 12-2-1998, Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 25-10-2002).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível a concessão de medida liminar em Mandado de injunção (MI 342/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1.º-1-1991; MI 530-3/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 8-3-1996; MI 535-4/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14-3-1996; MI 584-2/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 3-8-1998).

“A jurisprudência do STF admite legitimidade ativa ad causam aos sindicatos para a instauração, em favor de seus membros ou associados, do mandado de injunção coletivo” (STF, MI 102/PE, j. 12-2-1998, Pleno, rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, DJU 25-10-2002). “Apesar das modificações implementadas pela EC n. 19/98 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF/88, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a

todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. (...) Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão somente no sentido de que se aplique a Lei n. 7.783/89 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF/88, art. 37, VII). Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de 'serviços ou atividades essenciais', nos termos do regime fixado pelos arts. 9.º a 11 da Lei n. 7.783/89. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses 'serviços ou atividades essenciais' seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos 'essenciais'. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9.º a 11 da Lei n. 7.783/89. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9.º a 11 da Lei n. 7.783/89 é apenas exemplificativa (numerus apertus). O processamento e o julgamento de

eventuais dissídios de greve que envolvam servidores públicos civis devem obedecer ao modelo de competências e atribuições aplicável aos trabalhadores em geral (celetistas), nos termos da regulamentação da Lei n. 7.783/89. A aplicação complementar da Lei n. 7.701/88 visa à judicialização dos conflitos que envolvam os servidores públicos civis no contexto do atendimento de atividades relacionadas a necessidades inadiáveis da comunidade que, se não atendidas, coloquem 'em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população' (Lei n. 7.783/89, parágrafo único, art. 11). (...) Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei n. 7.701/88 (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF/88. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da CF/88, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos – um elemento

fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade. (...) Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis n. 7.701/88 e 7.783/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis” (STF, MI 708, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25-10-2007, DJe 31-10-2008). No mesmo sentido: MI 670 e MI 712.

16.5. MANDADO DE SEGURANÇA

O art. 5.º, LXIX, da CF/88 preceitua: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O endereçamento do mandado de segurança dependerá da autoridade que poderá desfazer o ato impugnado, tal como se vê nos seguintes exemplos:

Autoridade coatora	Autoridade competente
Autoridade estadual, dirigentes ou serventuários estaduais ou municipais	Juiz de Direito
Autoridade estadual em situações referentes à Lei n. 9.099/95	Juiz de Direito do Juizado Especial
Autoridade federal – art. 109, VIII, da CF/88	Juiz Federal
Autoridade federal em situações referentes à Lei n. 10.259/2001	Juiz Federal

Juiz de Direito Mesa de Assembleia Legislativa	Tribunal de Justiça (Previsão: Constituição Estadual)
Juiz Federal	Tribunal Regional Federal
Juiz do Juizado Especial Criminal	Turma Recursal
Turma Recursal	Turma Recursal/Tribunal de Justiça
Tribunal de Justiça Tribunal Regional Federal Superior Tribunal de Justiça Supremo Tribunal Federal	Pleno ou Órgão Especial dos referidos Tribunais, dependendo do caso
Ministro de Estado, Comandantes da Marinha, Exército ou Aeronáutica ou autoridade do STJ – art. 105, I, b, da CF/88	Superior Tribunal de Justiça
Presidente da República, Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de contas da União, do Procurador-Geral da República e autoridade do Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, d, da CF/88	Supremo Tribunal Federal

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Desse modo, o direito deve vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Não há prova testemunhal nem pericial.

Sujeito ativo: somente o próprio titular do direito violado tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança individual. Pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, desde que tenha capacidade de direito e seja titular do direito violado.

Sujeito passivo: a) autoridades públicas: compreende todos os agentes públicos, ou seja, todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal, como os agentes políticos e os agentes administrativos; b) agentes

de pessoas jurídicas com atribuições de Poder Público: todos os agentes de pessoas jurídicas privadas que executem, a qualquer título, atividades, serviços e obras públicas. Por exemplo: universidades privadas.

Cumpra-se destacar que o mandado de segurança deve ser proposto contra a autoridade coatora e deve ser indicada a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (art. 6.º, caput, da Lei n. 12.016/2009).

A autoridade coatora será a pessoa física que concretiza a lesão a direito individual como decorrência de sua vontade. Não se levam em consideração as pessoas que estabelecem regras e determinações genéricas, nem tampouco aquela que meramente executa a ordem. Infere-se que os atos normativos gerais não estão sujeitos a mandado de segurança. Além disso, não cabe mandado de segurança contra ato de particular e o mérito de decisão impugnada.

A participação do Ministério Público é indispensável, justificada na tutela do interesse público.

Prazo decadencial: 120 dias a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Tal prazo não se suspende nem se interrompe.

Regulamentação: Lei n. 12.016, de 7-8-2009.

ATENÇÃO

Restrição de liminar contra o Poder Público: Leis n. 8.437/92, arts. 1.º e 2.º, e 9.494/97, art. 2.º-B.

Art. 5.º da Lei n. 12.016/2009: restrição ao mandado de segurança. Art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 12.016/2009: restrição à medida liminar em mandado de segurança.

Decisões sobre o tema:

As Comissões Parlamentares de Inquérito não podem decretar a

condução coercitiva de testemunha, busca e apreensão, indisponibilidade de bens e prisão temporária (HC 88.015/DF e MS 25.832/DF – Informativo 416 do STF).

O processo legislativo da emenda constitucional pode, por meio de mandado de segurança interposto perante o Supremo Tribunal Federal (STF), ser objeto de controle de constitucionalidade, para o qual estariam legitimados os parlamentares federais (Deputados Federais e Senadores). Nesses termos: STF, MS 20.247/DF e MS 20.471/DF.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público pode requisitar diretamente, ou seja, sem intervenção judicial, informações revestidas de sigilo bancário ou fiscal quando se tratar de verbas públicas. Nos termos do art. 129, VI, da CF/88, onde se lê que “são funções institucionais do Ministério Público (...) expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva”; e nos termos do art. 8.º, VIII, da Lei Complementar n. 75/93, onde se lê que o Ministério Público tem “acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública” (MS 21.729/DF, MS 21.172/DF, entre outros).

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as universidades públicas se submetem ao controle do Tribunal de Contas da União; aplica-se o art. 71, II, da CF/88 (STF, RMS no Ag 22.047/DF, entre outros).

O mandado de segurança pode ser utilizado para suscitar o controle de constitucionalidade, inclusive de emendas constitucionais. Nesse sentido é a doutrina e a jurisprudência: STF, MS em MC no Ag 21.077/GO.

Súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre mandado de segurança:

- **Súmula 101:** “O mandado de segurança não substitui a ação popular”.
- **Súmula 248:** “É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da

União”.

- **Súmula 266:** “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
- **Súmula 267:** “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
- **Súmula 268:** “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
- **Súmula 269:** “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
- **Súmula 270:** “Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei n. 3.780/60, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa”.
- **Súmula 271:** “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
- **Súmula 272:** “Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança”.
- **Súmula 294:** “São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança”.
- **Súmula 299:** “O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança, ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno”.
- **Súmula 304:** “Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria”.
- **Súmula 319:** “O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus ou mandado de segurança, é de cinco dias”.
- **Súmula 330:** “O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados”.

- **Súmula 405:** “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

- **Súmula 429:** “A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade”.

- **Súmula 430:** “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”.

- **Súmula 433:** “É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista”.

- **Súmula 474:** “Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal”.

- **Súmula 510:** “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.

- **Súmula 512:** “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

- **Súmula 597:** “Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança decidiu, por maioria de votos, a apelação”.

- **Súmula 622:** “Não cabe agravo regimental contra decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança” (restou prejudicada pelo art. 16, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009).

- **Súmula 623:** “Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, n, da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros”.

- **Súmula 624:** “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
- **Súmula 625:** “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”.
- **Súmula 626:** “A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”.
- **Súmula 627:** “No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento”.
- **Súmula 629:** “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
- **Súmula 630:** “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”.
- **Súmula 631:** “Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário”.
- **Súmula 632:** “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”.
- **Súmula 701:** “No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo”.

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

- **Súmula 41:** “O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos”.
- **Súmula 105:** “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios”.
- **Súmula 169:** “São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança”.
- **Súmula 177:** “O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado”.
- **Súmula 213:** “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.
- **Súmula 333:** “Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública”.

16.6. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

O art. 5.º, LXX, da CF/88 enuncia: “O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados”.

O endereçamento do mandado de segurança coletivo dependerá da autoridade que poderá desfazer o ato impugnado, tal como se vê nos seguintes exemplos:

Autoridade coatora	Autoridade competente
Autoridade estadual, dirigentes ou serventuários estaduais ou municipais	Juiz de Direito
Autoridade federal, dirigentes ou serventuários federais – art. 109, VIII, da	

CF/88	Juiz Federal
Juiz de Direito Mesa de Assembleia Legislativa	Tribunal de Justiça (Previsão: Constituição Estadual)
Juiz Federal	Tribunal Regional Federal
Juiz do Juizado Especial	Turma Recursal
Tribunal de Justiça Tribunal Regional Federal Superior Tribunal de Justiça Supremo Tribunal Federal	Pleno ou órgão especial dos referidos Tribunais, dependendo do caso
Ministro de Estado, Comandantes da Marinha, Exército ou Aeronáutica ou autoridade do STJ – art. 105, I, b, da CF/88	Superior Tribunal de Justiça
Presidente da República, Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de contas da União, do Procurador-Geral da República e autoridade do Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, d, da CF/88	Supremo Tribunal Federal

Nas alíneas a e b do inciso LXX do art. 5.º há a legitimidade ativa (sujeito ativo) para propositura do mandado de segurança coletivo: “a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados”.

Sujeito passivo: a) autoridades públicas: compreende todos os agentes públicos, ou seja, todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal, como os agentes políticos e os agentes administrativos; b) agentes de pessoas jurídicas com atribuições de Poder Público: todos os agentes de pessoas jurídicas privadas que executem, a qualquer título, atividades, serviços e obras públicas. Por exemplo: universidades privadas.

Cumpra-se destacar que o mandado de segurança deve ser proposto contra a autoridade coatora e deve ser indicada a pessoa jurídica que esta integra,

à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (art. 6.º, caput, da Lei n. 12.016/2009).

Saliente-se que devem estar preenchidos os demais requisitos do mandado de segurança individual, ou seja, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas (art. 2.º da Lei n. 8.437/92; art. 22, § 2.º, da Lei n. 12.016/2009).

O art. 21 da Lei n. 12.016/2009 determina que: “O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: I – coletivos, assim entendidos, para efeitos desta Lei os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; II – individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante”

Decisões sobre o tema:

Segundo posicionamento do STF, nos mandados de segurança coletivos

impetrados por sindicato em defesa de direito subjetivo comum aos integrantes da categoria, não se exige, na inicial, a autorização expressa dos sindicalizados (Súmula 629 do STF). É caso de legitimidade extraordinária – substituição processual (MS 22.132/RJ, entre outros).

“Legitimidade. Mandado de segurança coletivo. Sindicato. Registro no Ministério do Trabalho. A legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório próprio, sendo indiferente estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério do Trabalho” (STF, RE 370.834, 1.^a T., j. 30-8-2011, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26-9-2011).

“De saída, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo presidente da República. É que a impetrante demonstrou ser associação legalmente constituída há mais de um ano. Sua legitimidade para a impetração de mandado de segurança, portanto, decorre diretamente do texto constitucional (inciso LXX do art. 5.^o), não obstante o silêncio do estatuto da autora quanto à representação judicial de seus associados” (STF, MS 25.347, Plenário, j. 17-2-2010, rel. Min. Ayres Britto, DJe 19-3-2010).

Súmulas do STF sobre o tema:

- **Súmula 629:** “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
- **Súmula 630:** “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”.

16.7. AÇÃO POPULAR

O art. 5.º, LXXIII, da CF/88 estabelece: “Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

O endereçamento da ação popular dependerá da autoridade que poderá desfazer o ato impugnado, tal como se vê nos seguintes exemplos:

Autoridade coatora	Autoridade competente
Autoridade estadual ou municipal	Juiz de Direito
Autoridade federal	Juiz Federal

Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município (art. 5.º da Lei n. 4.717/65).

Destaque-se que, em regra, a ação popular deve ser proposta perante o juízo de primeiro grau, não havendo competência originária de Tribunal para conhecê-la. É considerada exceção a previsão da alínea n do inciso I do art. 102 da CF/88 e de lides nas quais se verifique conflito entre a União e Estado-membro. Nesses casos, a competência seria do STF, conforme se vê: “Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação popular em que os respectivos autores, com pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense, postulam a declaração da invalidade da Portaria n. 820/98, do Ministério da Justiça. Também incumbe a esta Casa de Justiça apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação da referida reserva indígena” (Rcl 2.833/2005 e Rcl 3.331/2006, rel. Min. Carlos Britto).

Cumpra lembrar que não há foro privilegiado para os chefes do Poder Executivo ou qualquer outra autoridade.

Saliente-se que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal (art. 109, § 2.º, da CF/88).

Sujeito ativo: cidadão brasileiro (eleitor).

Sujeito passivo: o administrador da entidade lesada e os beneficiários.

Natureza jurídica: ação constitucional de natureza civil.

Formas: a) preventiva: ajuizada antes da consumação dos efeitos do ato, podendo ser deferida a suspensão liminar do ato impugnado; b) repressiva: visa a corrigir os atos danosos consumados; c) supridora da omissão (supletiva): o autor obriga a Administração omissa a atuar.

Cabimento: em casos como a incompetência de quem praticou os atos danosos, forma não prescrita em lei, desvio de finalidade, ilegalidade do objeto, entre outros.

O Ministério Público deve funcionar como fiscal da lei e substituir o autor caso este venha a desistir da ação (legitimidade extraordinária).

Na sentença, normalmente, o juiz deverá determinar a invalidade do ato e a condenação dos responsáveis ao ressarcimento das perdas e danos. A sentença de improcedência da ação, por falta de fundamento da pretensão, faz coisa julgada; porém, caso a improcedência se dê por insuficiência de provas, não faz coisa julgada, podendo a ação ser proposta novamente.

Execução: pode ser feita pelo autor, qualquer outro cidadão ou o Ministério Público (se o autor não promover a execução em 60 dias da publicação da sentença). Destaque-se que a execução é ajuizada contra os responsáveis pelo ato.

É necessária a atuação de advogado.

Regulamentação: Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965.

A ação popular prescreve em cinco anos (art. 21 da Lei n. 4.717/65).

IMPORTANTE

A Ministra Cármen Lúcia decidiu que cabe ao STF analisar processo sobre posse de Cristiane Brasil. A presidente julgou procedente a Reclamação (Rcl) 29.508 e cassou decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em 20 de janeiro de 2018, havia autorizado a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) no cargo de Ministra do Trabalho. O caso teve início em ação popular ajuizada por um grupo de cidadãos na Justiça Federal. Em liminar, o juízo da 4.^a Vara Federal de Niterói (RJ) impediu a posse da deputada, e esta decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2.^a Região (TRF-2). Em seguida, ao apreciar pedido de suspensão de liminar e de sentença, o vice-presidente do STJ, Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência daquele tribunal, suspendeu a decisão da Justiça Federal e autorizou a posse. Na Rcl 29.508, os titulares da ação popular sustentaram que houve usurpação de competência do STF pelo STJ, uma vez que a liminar da origem foi fundamentada no princípio constitucional da moralidade administrativa, o que direciona a atribuição da causa ao Supremo (STF, Rcl 29.508, j. 21-1-2018, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1.º-2-2018).

Decisões sobre o tema:

A ação popular e a ação civil pública podem ser utilizadas no controle de constitucionalidade incidental, ou seja, desde que a questão constitucional seja aventada como fundamento de outra pretensão, que não a mera declaração de inconstitucionalidade da norma. Nesse sentido estão as seguintes decisões: STF, Pleno, Rcl 721-0/AL, Rcl 554-2/MG, entre outras.

“O mandado de segurança não substitui a ação popular” (Súmula 101 do STF).

“Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular” (Súmula 365 do STF).

É competente a Justiça Comum para julgar ação popular contra o Sebrae (RE 366.168/SC; Súmula 516 do STF: “O Serviço Social da Indústria (Sesi) está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual”).

“Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. (...) Inexistência de

vícios processuais na ação popular. Nulidade dos atos, ainda que formais, tendo por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras situadas na área indígena Raposa Serra do Sol. Pretensos titulares privados que não são partes na presente ação popular. Ação que se destina à proteção do patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (inciso LXXIII do art. 5.º da CF/88), e não à defesa de interesses particulares. Ilegitimidade passiva do Estado de Roraima, que não foi acusado de praticar ato lesivo ao tipo de bem jurídico para cuja proteção se preordena a ação popular. Impossibilidade de ingresso do Estado-membro na condição de autor, tendo em vista que a legitimidade ativa da ação popular é tão somente do cidadão. Ingresso do Estado de Roraima e de outros interessados, inclusive de representantes das comunidades indígenas, exclusivamente como assistentes simples. Regular atuação do Ministério Público” (STF, Pet 3.388, Plenário, j. 19-3-2009, rel. Min. Ayres Britto, DJe 1.º-7-2010).

16.8. O DIREITO DE PETIÇÃO

O “direito de petição” é o remédio constitucional que pertence a uma pessoa ou grupo de pessoas e que consiste em invocar a atenção dos Poderes Públicos em defesa de direitos sobre uma questão ou situação ilegal ou abusiva.

O art. 5.º, XXXIV, a, da CF/88, estabelece o “direito de petição” aos Poderes Públicos, assegurando-o a todos, independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Desse modo, o “direito de petição” tem natureza jurídica de direito constitucional.

A titularidade desse direito pode ser exercida por pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras, ou até mesmo entes sem personalidade jurídica. Não exige formalismo técnico nem necessita de advogado. É um direito público subjetivo.

O “direito de petição” pode ser materializado por documento escrito, denúncia oral, que será reduzida a termo, entre outros.

Destaque-se que o “direito de petição” não se confunde com o “direito de certidão” previsto no art. 5.º, XXXIV, b, da CF/88, que assegura a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

No plano infraconstitucional, há a Lei n. 9.051/95, que dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 1.º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor. Art. 2.º Nos requerimentos que objetivam a obtenção das certidões a que se refere esta Lei, deverão os interessados fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido”.

Cumpra-se observar que as informações solicitadas devem existir e não pode haver sigilo sobre o assunto, como, por exemplo, a segurança nacional.

Decisões sobre o tema:

“É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo” (Súmula Vinculante 21).

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Parágrafo 1.º do art. 636 da CLT: não recepção pela Constituição de 1988. Incompatibilidade da exigência de depósito prévio do valor correspondente à multa como condição de admissibilidade de recurso administrativo interposto junto à autoridade trabalhista (§ 1.º do art. 636

da CLT) com a Constituição de 1988. Inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5.º, LIV e LV); do princípio da isonomia (art. 5.º, caput); do direito de petição (art. 5.º, XXXIV, a)” (STF, ADPF 156, Plenário, j. 18-8-2011, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28-10-2011).

“O direito de petição, presente em todas as Constituições brasileiras, qualifica-se como importante prerrogativa de caráter democrático. Trata-se de instrumento jurídico-constitucional posto à disposição de qualquer interessado – mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica –, com a explícita finalidade de viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos ou valores revestidos tanto de natureza pessoal quanto de significação coletiva. Entidade sindical que pede ao PGR o ajuizamento de ação direta perante o STF. Provocatio ad agendum. Pleito que traduz o exercício concreto do direito de petição. Legitimidade desse comportamento” (STF, MC na ADIn 1.247, Plenário, j. 17-8-1995, rel. Min. Celso de Mello, DJ 8-9-1995).

16.9. AÇÃO CIVIL PÚBLICA

O art. 129, III, da CF/88 estabelece: “São funções institucionais do Ministério Público: (...) III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

Origem e finalidade: a ação civil pública (ACP) foi introduzida no Brasil pela Lei n. 7.347/85, para a proteção dos direitos do consumidor, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, da ordem econômica e urbanística. Posteriormente, outras leis ampliaram ou reforçaram o seu âmbito de proteção: Lei n. 7.853/89: pessoas portadoras de deficiência (necessidades especiais); Lei n. 7.913/89: investidores no mercado mobiliário; Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Lei n.

8.429/92 (improbidade administrativa); Lei n. 11.105/2005 (biossegurança); Lei n. 12.966/2014 (proteção à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos); entre outras.

Natureza jurídica: é uma ação constitucional.

Competência: funcional e absoluta do lugar do dano (art. 2.º da Lei n. 7.347/85).

Sujeito ativo: Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista ou associações constituídas há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, que tenham por fim a proteção de interesses difusos e coletivos (art. 5.º, caput, I a V, da Lei n. 7.347/85).

Cumpra observar que pode haver a dispensa do prazo de um ano tendo em vista o direito a ser protegido (art. 82, § 1.º, da Lei n. 8.078/90 – manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido).

Sujeito passivo: em face da Administração Pública ou de particular.

O Ministério Público intervém obrigatoriamente em todas as ações civis públicas, seja como parte ou como fiscal da lei. É possível o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados (art. 5.º, §§ 1.º e 5.º, da Lei n. 7.347/85). Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade da ação (art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 7.347/85).

Destaque-se que, no mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas (art. 2.º da Lei n. 8.437/92; art. 22, § 2.º, da Lei n. 12.016/2009).

O inquérito civil é um procedimento administrativo preliminar por meio

do qual o membro do Ministério Público apura a existência ou não de atos lesivos aos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos para a propositura de ação civil pública (art. 8.º, § 1.º, da Lei n. 7.347/85). O inquérito civil é dispensável se já houver provas suficientes para a ação.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) corresponde à formalização de uma transação celebrada pelos órgãos públicos, também conhecido por compromisso de ajustamento de conduta (art. 5.º, § 6.º, da Lei n. 7.347/85). As associações civis, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista não podem transacionar. Trata-se de um acordo extrajudicial, não se exigindo homologação judicial. Porém, se o acordo for celebrado em ação judicial, será necessária a homologação judicial para extinguir o processo.

Condenação e execução: a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 3.º da Lei n. 7.347/85). Qualquer dos colegitimados pode promover a execução e o Ministério Público deverá promover a execução se for autor da ação ou se o colegitimado não promover a execução em 60 dias do trânsito em julgado da sentença (art. 15 da Lei n. 7.347/85). O juiz poderá determinar multa diária em razão do não cumprimento da sentença (astreinte), que reverterá para um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados. Tal fundo também receberá os valores provenientes de condenação em dinheiro.

Interesses difusos: os titulares são pessoas indeterminadas, ligadas por uma situação de fato, possuindo interesses indivisíveis. Por exemplo, viver em um meio ambiente sadio, o respeito aos direitos humanos, entre outros.

Interesses coletivos: os titulares são pessoas determináveis, ligadas por um vínculo jurídico, possuindo interesses indivisíveis. Por exemplo, reajuste de mensalidade de uma entidade particular de ensino, entre outros.

Interesses individuais homogêneos: os titulares são pessoas determinadas, ligadas por uma situação de fato, possuindo interesses

divisíveis. Por exemplo, compradores de veículos com o mesmo defeito, entre outros.

Regulamentação: Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.

Decisões sobre o tema:

A ação civil pública pode ser utilizada como instrumento de controle de constitucionalidade das leis desde que seja incidentalmente, ou seja, no curso de um processo concreto. Neste caso, os efeitos estarão vinculados às partes do processo. Cabe observar que, se a questão constitucional for o objeto principal da demanda, não se admitirá a ação civil pública, pois os seus efeitos são erga omnes, e deste modo haveria a equiparação aos efeitos do controle concentrado e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 633-6/SP; Rcl 1.733/SP, entre outros.

“Petição. Ação civil pública contra decisão do CNJ. Incompetência, em sede originária, do STF. Nos termos do art. 102 e incisos da Magna Carta, esta Suprema Corte não detém competência originária para processar e julgar ações civis públicas. Precedentes. Agravo desprovido” (STF, AgRg na Pet 3.986, Plenário, j. 25-6-2008, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5-9-2008).

Súmulas sobre o tema:

- **Súmula 329 do STJ:** “O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”.
- **Súmula 643 do STF:** “O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares”

16.10. QUADRO COMPARATIVO DOS REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS



Remédio	Fundamento	Objeto
Direito de Petição	Art. 5.º, XXXIV, a, da CF/88	Defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do pagamento de taxas.
Habeas corpus	Art. 5.º, LXVIII, da CF/88	Quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Habeas data	Art. 5.º, LXXII, da CF/88	a) Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) Retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
Mandado de injunção	Art. 5.º, LXXI, da CF/88	Falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Mandado de segurança	Art. 5.º, LXIX, da CF/88	Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Mandado de segurança coletivo	Art. 5.º, LXX, da CF/88	Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Cuidado: a diferença do MS individual é a legitimidade ativa (pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados).
Ação popular	Art. 5.º, LXXIII, da CF/88	Qualquer cidadão pode propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
Ação civil pública	Art. 129, III, da CF/88	Proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Elementos das Constituições

Os elementos das Constituições correspondem aos seus componentes, que, em geral, são agrupados em títulos, capítulos e seções, em função do conteúdo específico que os vincula.

Diversa é a classificação doutrinária a respeito do tema. Adotou-se a prevalente, a saber:

17.1. ELEMENTOS ORGÂNICOS

São normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Podemos elencar como exemplo o Título III (Da organização do Estado) da Constituição Federal vigente.

17.2. ELEMENTOS LIMITATIVOS

São normas que limitam a atuação do Estado. Manifestam-se expressamente no elenco dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, no Título II da Constituição Federal de 1988. Devem ser excetuados, porém, os direitos sociais, que compõem o Capítulo II de tal Título, pois ingressam na categoria seguinte.

17.3. ELEMENTOS SOCIOIDEOLÓGICOS

São normas que expressam o compromisso das Constituições modernas no que tange a diferenciar o Estado individualista do Estado social. Na Constituição Federal de 1988, são encontrados no Capítulo II do Título II, ou seja, sob a denominação Dos direitos sociais, e também nos Títulos VII e

VIII, respectivamente Da ordem econômica e financeira e Da ordem social.

17.4. ELEMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO CONSTITUCIONAL

São normas que possibilitam a integração e a harmonia constitucional. Asseguram a solução dos conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas, estabelecendo os meios e as técnicas contra sua alteração e infringência, bem como para sua modificação. São encontrados nos arts. 34 a 36 (Da intervenção nos Estados e Municípios), nos arts. 59, I, e 60 (do processo de emendas à Constituição), nos arts. 102 e 103 (jurisdição constitucional) e no Capítulo I do Título V, intitulado Do estado de defesa e do estado de sítio.

17.5. ELEMENTOS FORMAIS DE APLICABILIDADE

São normas que estabelecem regras de aplicação das Constituições, como o preâmbulo, o Título IX (Das disposições constitucionais gerais), o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como o § 1.º do art. 5.º da CF/88, segundo o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Decisão sobre o tema:

“A interpretação da Constituição não é para ser procedida à margem da realidade, sem que se a compreenda como elemento da norma resultante da interpretação. A práxis social é, nesse sentido, elemento da norma, de modo que interpretações corretas são incompatíveis com teorizações nutridas em idealismo que não a tome, a práxis, como seu fundamento. Ao interpretá-la, a Constituição, o intérprete há de tomar como objeto de compreensão também a realidade em cujo contexto dá-se a interpretação, no momento histórico em que ela se dá. Em recente pronunciamento, no julgamento do HC 94.916 (sessão de 30-9-2008), esta Corte afirmou que situações de exceção não ficam à margem do

ordenamento, sendo por este capturadas, de modo que a preservação dos princípios impõe, seguidas vezes, a transgressão das regras. No presente caso, as regras de competência (art. 109, I, da CF/88), cuja última razão se encontra na distribuição do exercício da jurisdição, segundo alguns critérios, aos órgãos do Poder Judiciário, não podem prevalecer 43 anos após a propositura da ação. Assim há de ser em virtude da efetiva entrega da prestação jurisdicional, que já se deu, e à luz da garantia constitucional à razoável duração do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF/88). Observe-se que a lide foi duas vezes – uma na Justiça Estadual, outra na Justiça Federal – resolvida, em sentenças de mérito, pela procedência da ação. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 433.512, 2.ª T., j. 26-5-2009, rel. Min. Eros Grau, DJe 6-8-2009).

História das Constituições brasileiras

18.1. CONSTITUIÇÃO DE 1824

Constituição política do Império do Brasil, outorgada por D. Pedro I em 25 de março de 1824. Também conhecida como Carta Imperial, adotou a forma monárquica de governo, dividiu o território em províncias (antigas capitanias então existentes) e definiu o catolicismo como religião oficial do Império (Estado confessional), o que determinou, desse modo que só os católicos apostólicos romanos pudessem ser eleitos para os cargos oficiais. Outrossim, instituiu-se a formulação quadripartite de poder, de Benjamim Constant, ou seja, os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e Moderador.

O Poder Moderador era exercido privativamente pelo Imperador, como dirigente supremo da Nação, e por seu primeiro representante, para que incessantemente velasse pela manutenção da independência e pelo equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. O Poder Executivo, exercido pelos Ministros de Estado, tinha o Imperador como chefe. O Poder Judiciário era composto por juízes e jurados. O Poder Legislativo era composto por Deputados e Senadores, sendo os primeiros eleitos e temporários e os demais membros vitalícios nomeados pelo Imperador dentre componentes de uma lista tríplice eleita por província. O sufrágio era indireto e censitário.

Sob a égide desta Constituição, houve pela primeira vez a implantação do regime parlamentarista de governo, que vigorou de 1847 até 1889. Por fim, cabe ressaltar que foi instituída a forma unitária de Estado, com forte centralização político-administrativa.

18.2. CONSTITUIÇÃO DE 1891

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891.

Estabeleceu como forma de governo a República e constituiu-se pela união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias (21) em Estados Unidos do Brasil. Cada uma das antigas províncias formou um Estado-membro, e o antigo Município neutro se transformou no Distrito Federal, que continuou a ser a capital da União. Nasceu, portanto, o Estado Federal brasileiro.

Adotou a formulação clássica de separação de Poderes, ou seja, a doutrina tripartite de Montesquieu, estabelecendo como órgãos da soberania nacional os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, harmônicos e independentes entre si.

O presidencialismo foi previsto como regime de governo, abolindo-se o parlamentarismo, sendo o Presidente da República eleito pelo sufrágio direto do povo. Ampliou a declaração de direitos humanos, introduzindo expressamente, pela primeira vez, o instituto do habeas corpus (§ 22 do art. 72).

O Brasil passou a ser um Estado laico (sem religião oficial).

18.3. CONSTITUIÇÃO DE 1934

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934.

Manteve a estrutura fundamental anterior, a saber: a República, a Federação, a divisão dos Poderes, o presidencialismo e o regime representativo. Aumentou os poderes do Executivo, definiu os direitos políticos e o sistema eleitoral, admitindo o voto secreto, estendido às mulheres.

Estabeleceu alguns direitos trabalhistas, como salário mínimo, descanso

semanal, férias, e regulamentou o trabalho das mulheres e dos menores.

Inovação no plano constitucional foi a integração da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral como órgãos do Poder Judiciário, bem como a previsão da Justiça do Trabalho.

Introduziu o ensino primário gratuito e obrigatório, e criou, no plano da declaração de direitos, o mandado de segurança e a ação popular. Instituiu, ao lado do Ministério Público e do Tribunal de Contas, os conselhos técnicos como órgãos de cooperação nas atividades governamentais.

Inspirada na Constituição alemã de Weimar de 1919, inseriu capítulos referentes à ordem econômica e social, à família, à educação e à cultura. Além disso, deve-se citar a criação de normas relativas ao funcionalismo público e às Forças Armadas.

18.4. CONSTITUIÇÃO DE 1937

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, outorgada por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937. Inspirada na Constituição fascista da Polônia, recebeu o apelido de “Polaca”.

O Brasil passou a ser um Estado apenas formalmente federal, despojando das unidades federativas sua autonomia.

Há o fortalecimento do Poder Executivo federal, ou seja, concentram-se nas mãos do Presidente da República os Poderes Executivo e Legislativo. Getúlio Vargas legisla por meio de decretos-leis que ele próprio depois aplicava, como órgão do Executivo.

Nesse período, há a suspensão dos institutos do mandado de segurança e da ação popular, bem como o surgimento do “quinto constitucional”.

18.5. CONSTITUIÇÃO DE 1946

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 18 de setembro de 1946.

Restaurou a autonomia das entidades federadas, criou novamente o cargo de Vice-Presidente da República, extinto nas Constituições de 1934 e 1937, reintroduziu os remédios do mandado de segurança e da ação popular. Fortaleceu o regime democrático, assegurando o pluripartidarismo.

Sob o comando desta Constituição, houve a reintrodução do regime parlamentarista no Brasil, que durou de 1961 até 1963.

18.6. CONSTITUIÇÃO DE 1967

Constituição do Brasil, o Ato Institucional n. 4, de 07 de dezembro de 1966, convocou o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, e promulgar (Mesa da Câmara e do Senado Federal) o projeto de Constituição que o governo apresentou.

Em 24 de janeiro de 1967 foi ela promulgada, entrando em vigor em 15 de março de 1967, quando assumia a Presidência o Marechal Arthur da Costa e Silva. Preocupou-se fundamentalmente com a segurança nacional, promoveu a centralização dos Poderes no Executivo federal, reduziu a autonomia individual, permitindo a suspensão dos direitos e garantias constitucionais, e, por fim, criou as eleições indiretas para Presidente da República (Colégio Eleitoral).

18.7. CONSTITUIÇÃO DE 1969

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada (outorgada) em 17 de dezembro de 1969, como Emenda Constitucional n. 1 à Constituição do Brasil, para entrar em vigor em 30 de outubro de 1969.

Teórica e tecnicamente não se tratou de emenda, pois uma emenda constitucional é um mecanismo para alterar parte de uma Constituição, e não para fazer uma nova. A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que, na verdade, foi promulgado um texto integralmente

reformulado. Em que pese o texto do art. 34 do ADCT da CF/88, a doutrina prevalente entende que tal emenda é verdadeira Constituição.

Outorgada por três ministros militares (Augusto Hamann Rademaker Grünewald, Aurélio de Lira Tavares e Márcio de Souza e Mello), promoveu grande concentração do poder político nas mãos do Executivo federal, à semelhança da Constituição anterior.

18.8. CONSTITUIÇÃO DE 1988

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada e publicada em 05 de outubro 1988.

É conhecida como a “Constituição Cidadã”. Instituiu o Estado Democrático de Direito, autolimitando o poder do Estado ao cumprimento das leis que a todos subordinam. Assegurou a livre participação dos cidadãos na vida política, o sufrágio passou a ser universal, direto e secreto nas três esferas administrativas, os analfabetos conquistaram o direito ao voto e jovens acima de 16 anos de idade receberam o direito facultativo de votar.

Estabeleceu também o pluripartidarismo, fortaleceu o federalismo, conferindo maior autonomia aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criou os remédios constitucionais do habeas data, do mandado de injunção e do mandado de segurança coletivo, acabou com a censura aos meios de comunicação, entre outras inovações.

Princípios constitucionais da Administração Pública

A Administração Pública brasileira deve obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, caput, da CF/88).

A legalidade implica em que todos os atos realizados pela Administração Pública devem estar em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, inclusive quando realiza atos discricionários.

O conceito de impessoalidade possui duas vertentes, a saber: a Administração, quando age, não o faz em nome de determinado administrador, mas em nome do ente político-administrativo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal); de outro lado, a ação da Administração deve beneficiar toda a coletividade, alcançando o bem comum, e não alguns poucos privilegiados.

O princípio da moralidade implica em que os atos da Administração devem ao menos respeitar as normas jurídicas, porque pressupõem a correção e a ética na sua elaboração. A moralidade é a busca do melhor e mais justo para a sociedade. Para a proteção da probidade administrativa existe a Lei n. 8.429/92.

A publicidade indica que os atos realizados pela Administração Pública, via de regra, devem ser públicos, ou seja, levados ao conhecimento de todos os componentes da sociedade, salvo imposição legal de sigilo.

Por fim, a eficiência determina que as ações da Administração Pública devem buscar o maior resultado com o menor custo, seja operacional ou

financeiro.

ATENÇÃO

Súmulas do STF

- Súmula Vinculante 6: "Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial".
- Súmula Vinculante 13: "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal".
- Súmula 346: "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos".
- Súmula 473: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
- Súmula 636: "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida".
- Súmula 683: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".
- Súmula 686: "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público".

Decisões sobre o tema:

- "(...) configurada a prática de nepotismo cruzado, tendo em vista que a assessora nomeada pelo impetrante para exercer cargo em comissão no TRT 17.ª Região, sediado em Vitória/ES, é nora do magistrado que nomeou a esposa do impetrante para cargo em comissão no TRT 1.ª Região, sediado no Rio de Janeiro/RJ. A nomeação para o cargo de assessor do impetrante é ato formalmente lícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade contrária ao interesse público, qual seja, uma troca de favores entre membros do Judiciário, o ato deve ser invalidado, por violação ao princípio da moralidade administrativa e por estar caracterizada a sua ilegalidade, por desvio de finalidade" (STF, MS 24.020, 2.ª T., j. 6-3-2012, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13-6-2012).
- "Concurso público. (...) Surge extravagante implementar-se, para candidatos remanescentes em razão de haverem buscado o Judiciário, exigências extras, não constantes do edital" (STF,

RE 596.482, 1.^a T., j. 7-6-2011, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25-8-2011)

- “Não há violação aos princípios da isonomia e da publicidade quando a divulgação das notas dos candidatos em concurso público ocorre em sessão pública, mesmo que em momento anterior ao previsto no edital, ainda mais quando, como no caso, todos forem informados de sua ocorrência. A inobservância de regra procedimental de divulgação de notas não acarreta a nulidade de concurso público quando não demonstrado prejuízo aos concorrentes” (STF, AO 1.395-ED, Plenário, j. 24-6-2010, rel. Min. Dias Toffoli, DJ 21-10-2010)

IMPORTANTE

Responsabilidade objetiva do Estado

O § 6.º do art. 37 da Constituição Federal vigente assim estabelece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, os entes públicos em geral respondem pelos danos que os servidores públicos causarem.

Decisões sobre o tema:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6.º, da CF/88. A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço público é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado” (STF, RE 591.874, Plenário, j. 26-8-2009, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 17-12-2009, com repercussão geral). No mesmo sentido: AI 831.327-AgR, 1.^a T., j. 22-2-2011, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23-3-2011. Em sentido contrário: RE 262.651, 2.^a T., j. 16-11-2004, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 6-5-2005.

“Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais” (RE 898.450, rel. Min. Luiz Fux, DJ 17-8-

2016).

Das funções essenciais à Justiça

20.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO

A doutrina ensina que o Ministério Público (Parquet) surgiu historicamente com o advento da divisão de Poderes do Estado moderno. Por tal motivo, sua proximidade mais direta é com os advogados e procuradores criados no século XIV, na França. Os advogados do rei tinham atribuições exclusivamente cíveis, enquanto os procuradores, além das funções de defesa do Fisco, tinham funções de natureza criminal. O Ministério Público francês nasceu da fusão dessas duas instituições, unidas pela ideia básica de defender os interesses do soberano, que representava os interesses do próprio Estado. Posteriormente, na França, o Ministério Público veio a ser definido de maneira mais clara com os Códigos Napoleônicos, em especial o Código de Instrução Criminal e a Lei de 20 de abril de 1810, que lhe conferiu o importante papel de promotor da ação penal.

No Brasil, o Ministério Público encontra suas raízes no direito lusitano, vigente no País nos períodos colonial, imperial e início da República. As Ordenações Manuelinas de 1521 já mencionavam o promotor de justiça e suas obrigações perante as Casas de Suplicação e nos Juízos das Terras. O promotor atuava como um fiscal da lei e de sua execução.

Cumprir destacar que a Lei do Ventre Livre (Lei n. 2.040/1871) dava ao promotor de justiça a função de protetor do “fraco e indefeso” (os indivíduos hipossuficientes), ao estabelecer que a ele cabia zelar para que os filhos livres de mulheres escravas fossem devidamente registrados.

O Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890 (revogado pelo Decreto n. 11/91), que criava e regulamentava a Justiça Federal, dispôs sobre a estrutura do Ministério Público Federal. O decreto foi elaborado pelo Ministro da Justiça Campos Sales, que por tal motivo foi considerado o patrono do Ministério Público.

A Constituição Federal de 1937 criou o “quinto constitucional”. A Constituição Federal de 1946 tratou do Ministério Público em título especial, sem vinculação a qualquer dos outros Poderes da República, e instituiu os Ministérios Públicos Federais e Estaduais, garantindo aos seus membros a estabilidade na função, o concurso de provas e títulos, a promoção e a remoção apenas por representação da Procuradoria-Geral.

A Constituição Federal de 1967 subordinou o Ministério Público ao Poder Judiciário e acabou com os “concursos internos”. Ao integrar o Poder Judiciário, o Ministério Público deu grande passo na conquista de sua autonomia e independência por meio da equiparação com os magistrados. Tais conquistas somente foram consagradas na Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal de 1969 (EC n. 1) retirou do Ministério Público as condições de aposentadoria e os vencimentos atribuídos aos juízes e, também, a independência, com sua inclusão no capítulo do Poder Executivo (arts. 94 a 96).

A Emenda Constitucional n. 7/77 alterou o art. 96 da Constituição de 1969 e autorizou os Ministérios Públicos a se organizarem em carreira por leis estaduais.

A Constituição Federal de 1988 trata do Ministério Público nos arts. 127 a 130-A. Pode-se considerar como pontos principais:

- a) o Ministério Público é instituição permanente. Isso significa que, enquanto o Brasil for regido por essa Constituição, o Ministério Público não poderá ser extinto. Este é um exemplo de cláusula pétrea implícita;

- b) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional são princípios institucionais do Ministério Público;
- c) ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa;
- d) o ingresso na carreira do Ministério Público é feito por meio de concurso de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação;
- e) o Ministério Público abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. O Ministério Público da União compreende os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territórios (art. 128);
- f) o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República (nomeado pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal – § 1.º do art. 128; o Procurador-Geral da República pode ser destituído por iniciativa do Presidente da República, precedida a destituição de autorização da maioria absoluta do Senado Federal – § 2.º do art. 128), e os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais têm a denominação de Procurador-Geral de Justiça;
- g) são garantias constitucionais do Ministério Público: vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; inamovibilidade (restrição à transferência), salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; e irredutibilidade de subsídio;
- h) são funções institucionais do Ministério Público promover,

privativamente, a ação penal pública, o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, entre outros;

- i) o Conselho Nacional do Ministério Público foi instituído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, no art. 130-A da CF/88.

Decisões sobre o tema:

“O ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública pressupõe a completa inércia do Ministério Público, que se abstém, no prazo legal, de oferecer denúncia, ou de requerer o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, ou, ainda, de requisitar novas (e indispensáveis) diligências investigatórias à autoridade policial. (...) O STF tem enfatizado que, arquivado o inquérito policial, por decisão judicial, a pedido do Ministério Público, não cabe a ação penal subsidiária” (HC 74.276, 1.^a T., j. 3-9-1996, rel. Min. Celso de Mello, DJE 23-2-2011). No mesmo sentido: RE 274.115-AgR, 2.^a T., j. 12-8-2003, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 19-9-2003; HC 68.540, 1.^a T., j. 21-5-1991, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 28-6-1991; HC 67.502, 2.^a T., j. 5-12-1989, rel. Min. Paulo Brossard, DJ 9-2-1990.

“O procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, termos de declarações ou depoimentos, laudos periciais e demais subsídios probatórios coligidos no curso da investigação, não podendo o Parquet sonegar, selecionar ou deixar de juntar aos autos quaisquer desses elementos de informação, cujo conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser tornado acessível tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu advogado. O regime de sigilo, sempre excepcional, eventualmente prevalecente no contexto de investigação penal promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao investigado e ao advogado por este constituído, que terão direito de acesso – considerado o princípio da comunhão das provas

– a todos os elementos de informação que já tenham sido formalmente incorporados aos autos do respectivo procedimento investigatório” (HC 89.837, 2.^a T., j. 20-10-2009, rel. Min. Celso de Mello, DJe 20-11-2009).

20.2. A ADVOCACIA PÚBLICA

De acordo com a Constituição Federal vigente, a Advocacia Pública da União é exercida pela Advocacia-Geral da União (AGU), que representa a União judicial ou extrajudicialmente, inclusive nas atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. O chefe da instituição é o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ingresso nas classes iniciais da carreira é feito por meio de concurso de provas e títulos (art. 131, §§ 1.^o e 2.^o, da CF/88).

Na esfera dos Estados e do Distrito Federal há os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, que exercem a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. O ingresso na carreira é feito por meio de concurso de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Após três anos de efetivo exercício e de avaliações dos órgãos próprios, inclusive das Corregedorias, ao procurador é assegurada a estabilidade (art. 132, parágrafo único, da CF/88).

Destaque-se que na execução da dívida ativa de natureza tributária a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (art. 131, § 3.^o, da CF/88).

20.3. DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Constituição Federal vigente afirma em seu art. 133: “O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” (Lei n. 8.906/94

- Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB).

Para ser advogado é necessário ser bacharel em direito e ter aprovação no exame de Ordem dos Advogados do Brasil.

A Defensoria Pública é o órgão público incumbido da orientação jurídica e da defesa, em todos os graus, dos necessitados (arts. 5.º, LXXIV, e 134 da CF/88).

Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2.º da CF/88 (art. 134, § 2.º, da CF/88). O disposto no § 2.º do art. 134 também se aplica às Defensorias Públicas da União e do DF, conforme § 3.º do art. 134 da CF/88.

O ingresso na carreira será mediante concurso de provas e títulos, garantida a inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais (art. 134, § 1.º, da CF/88 e LC n. 80/94 – Organiza a Defensoria Pública da União e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados).

Decisões sobre o tema:

“O direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. Diante da ausência de intimação de defensor público para fins de julgamento do recurso, constata-se, no caso concreto, que o constrangimento alegado é inegável. No que se refere à prerrogativa da intimação pessoal, nos termos do art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/50, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que essa há de ser respeitada” (HC 89.176, 2.ª T., j. 22-8-2006, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 22-9-2006).

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo

aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (Súmula Vinculante 14).

“O sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial. Tratando-se de local onde existem documentos que dizem respeito a outros sujeitos não investigados, é indispensável a especificação do âmbito de abrangência da medida, que não poderá ser executada sobre a esfera de direitos de não investigados. Equívoco quanto à indicação do escritório profissional do paciente, como seu endereço residencial, deve ser prontamente comunicado ao magistrado para adequação da ordem em relação às cautelas necessárias, sob pena de tornar nulas as provas oriundas da medida e todas as outras exclusivamente delas decorrentes. Ordem concedida para declarar a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão no escritório de advocacia do paciente, devendo o material colhido ser desentranhado dos autos do Inq 544 em curso no STJ e devolvido ao paciente, sem que tais provas, bem assim quaisquer das informações oriundas da execução da medida, possam ser usadas em relação ao paciente ou a qualquer outro investigado, nesta ou em outra investigação” (HC 91.610, 2.^a T., j. 8-6-2010, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21-10-2010).

“O Plenário desproveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade dos arts. 8.^o, IV, e § 1.^o; e 44, II, ambos da Lei n. 8.906/94, que versam sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (...). No tocante à proporcionalidade e compatibilidade entre o exame de conhecimentos jurídicos e a garantia do livre exercício profissional, inicialmente reputou-se que, a fim de assegurar a liberdade

de ofício, impor-se-ia ao Estado o dever de colocar à disposição dos indivíduos, em condições equitativas de acesso, os meios para que aquela fosse alcançada. Destacou-se que esse dever entrelaçar-se-ia sistematicamente com a previsão do art. 205, caput, da CF/88 (...). Frisou-se que a obrigação estatal seria a de não opor embaraços irrazoáveis ou desproporcionais ao exercício de determinada profissão, e que existiria o direito de se obterem as habilitações previstas em lei para a prática do ofício, observadas condições equitativas e qualificações técnicas previstas também na legislação. Sublinhou-se que essa garantia constitucional não se esgotaria na perspectiva do indivíduo, mas teria relevância social (CF/88, art. 1.º, IV). Assim, nas hipóteses em que o exercício da profissão resultasse em risco predominantemente individual, como, por exemplo, mergulhadores e técnicos de rede elétrica, o sistema jurídico buscaria compensar danos à saúde com vantagens pecuniárias (adicional de insalubridade, de periculosidade) ou adiantar-lhes-ia a inativação. Essas vantagens, entretanto, não feririam o princípio da isonomia. Quando, por outro lado, o risco suportado pela atividade profissional fosse coletivo, hipótese em que incluía a advocacia, caberia ao Estado limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício (CF/88, art. 5.º, XIII). Nesse sentido, o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício. No concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição – assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo a evitar danos à coletividade – aduziu-se que a aprovação do candidato seria elemento a qualificá-lo para o exercício profissional” (RE 603.583, Plenário, j. 26-10-2011, rel. Min. Marco Aurélio, Informativo 646, com repercussão geral).

Direitos sociais

Os direitos sociais vinculam-se a realizações proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, buscando a igualização de situações sociais desiguais.

Segundo a doutrina, os direitos sociais podem ser classificados em cinco classes:

- a) relativos ao trabalhador (arts. 7.º a 11 da CF/88);
- b) relativos à seguridade social (direito à saúde, à previdência e assistência social – arts. 194 a 204 da CF/88);
- c) relativos à educação e à cultura (arts. 205 a 217 da CF/88);
- d) relativos à família, à criança, ao adolescente e ao idoso (arts. 226 a 230 da CF/88);
- e) relativos ao meio ambiente (art. 225 da CF/88).

Decisões sobre animais

STF declara a constitucionalidade de lei gaúcha que permite sacrifício de animais em rituais religiosos

O Plenário negou recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e validou lei estadual que entende que o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana não se enquadra como maus-tratos.

Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu

que a lei do Rio Grande do Sul que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos é constitucional. O Plenário da Corte finalizou, em 28 de março de 2019, o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 494601, no qual se discutia a validade da Lei Estadual n. 12.131/2004 (STF, RE 494.601, plenário, j. 28-3-2019, rel. Min. Marco Aurélio).

STJ sobre animais em condomínio

A Terceira Turma do STJ decidiu que a convenção de condomínio residencial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas, quando o animal não apresentar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do local. Em seu voto, o relator do recurso, ministro Villas Bôas Cueva, destacou que a convenção condominial, conforme previsto nos arts. 1.332, 1.333 e 1.344 do Código Civil (CC) de 2002, representa o exercício da autonomia privada, regulando, em um rol exemplificativo, as relações entre os condôminos, a forma de administração, a competência das assembleias e outros aspectos, com vistas a manter a convivência harmônica.

Entretanto, o relator ressaltou que as limitações previstas nas convenções são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário sob o aspecto da legalidade e da necessidade do respeito à função social da propriedade, de acordo com o art. 5.º, XXII, da Constituição Federal (STJ, REsp 1.783.076, 3.ª Turma, j. 14-5-2019, rel. Min. Villas Bôas Cueva).

Além dessa, outra classificação é apresentada:

- a) direitos sociais do homem como produtor: liberdade de instituição sindical, direito de greve, direito de determinar as condições de trabalho, direito de cooperar na gestão da empresa e direito de obter um emprego (arts. 7.º a 11 da CF/88);
- b) direitos sociais do homem como consumidor: direito à saúde, à alimentação, à segurança social (segurança material), ao

desenvolvimento intelectual, igual acesso das crianças e adultos à instrução, à formação profissional e à cultura, e garantia ao desenvolvimento da família (art. 6.º e Título VIII – Da ordem social, arts. 193 a 232, da CF/88).

DICA

A Lei n. 13.845, de 18 de junho de 2019, dá nova redação ao inciso V do art. 53 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

Na atualidade, fortalece-se na doutrina a corrente do neoconstitucionalismo, que procura dar eficácia concreta à Constituição, em especial, com relação aos direitos sociais fundamentais.

Desse modo, torna-se imperativo no mundo concreto efetivar a previsão abstrata de direitos contidos na Constituição. O Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais – arts. 5.º a 17 da CF/88) e o Título VIII (Da Ordem Social – arts. 193 a 232 da CF/88) devem ser implementados para os titulares dos direitos e garantias fundamentais que se encontrem no território nacional, desde que preencham os requisitos estabelecidos. Tal ação deveria ser realizada voluntariamente pelo Estado, porém, diante de sua inércia, é necessário acionar o Poder Judiciário para efetivá-los.

Em grande parte dos casos é possível a utilização dos remédios constitucionais. Pode-se citar como exemplo, a utilização de uma ação civil pública para a proteção ambiental, o fornecimento de medicamentos ou, ainda, para a obtenção de assistência médica.

Infere-se que a Constituição, para os neoconstitucionalistas, é uma norma jurídica superior e imperativa, que garante as condições dignas mínimas. Sua efetividade se propaga em relação aos particulares e ao Estado. Há imposição dos valores referentes à dignidade da pessoa humana

(aspecto axiológico concreto).

IMPORTANTE

Meio Ambiente e crueldade aos animais: no início de outubro de 2016 o STF julgou inconstitucional lei cearense que regulamentava a vaquejada. O Plenário do STF julgou procedente a ADIn n. 4.983, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a Lei n. 15.299/2013, do Estado do Ceará, que regulamentava a vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Ministro Marco Aurélio, que considerou haver “crueldade intrínseca” aplicada aos animais na vaquejada. Afirmou que o dever de proteção ao meio ambiente (art. 225 da Constituição Federal) sobrepõe-se aos valores culturais da atividade desportiva.

O Ministro Marco Aurélio afirmou que laudos técnicos contidos no processo demonstram consequências nocivas à saúde dos animais: fraturas nas patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, eventual arrancamento do rabo e comprometimento da medula óssea. Também os cavalos, de acordo com os laudos, sofrem lesões. Seguiram o relator os Ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e a presidente da Corte, Ministra Cármen Lúcia. Ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Em resposta o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional n. 96, de 6 de Junho de 2017, acrescentando o § 7.º ao art. 225 da Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis, nas condições que especifica.

“§ 7.º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1.º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1.º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”. Agora é aguardar o julgamento da ADIn 5.728 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli em face da Emenda Constitucional n. 96/2017.

Observação: Precedentes o Recurso Extraordinário (RE) 153.531 e as ADIns 2.514 e 3.776, que dispõem sobre “rinhas e brigas de galo” e “farra do boi” inconstitucionais.

ATENÇÃO

Neoconstitucionalismo ou Ativismo Judicial é uma concepção teórico-jurídica que, no Brasil e em outros países, visa à materialização de direitos em virtude da atuação do Poder Judiciário, assim tem aproximado as concepções de direito e justiça por meio de um diálogo racional. Nesse sentido, o STF decidiu que o Poder Judiciário pode obrigar o Poder Executivo a reformar estabelecimentos prisionais (RE 592.581/RS – rel. Min. Ricardo Lewandowski – STF por

unanimidade em 13-8-2015 e RE 650.085/SP – rel. Min. Carmen Lúcia, j. 1.º-9-2011).

A OAB é contra a redução da maioria penal, pois fere “cláusula pétrea” prevista no art. 60, § 4.º, IV, da CF/88 – direito individual.

Decisões sobre o tema:

“A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanção direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. (...) A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1.º, III, e art. 3.º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)” (STF, ARE 639.337-AgR, 2.ª T., j. 23-8-2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15-9-2011).

“A Constituição de 1988 traz um robusto conjunto normativo que visa à proteção e à efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. A existência de trabalhadores a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total violação da liberdade e da autodeterminação de cada um, configura crime contra a organização do trabalho. Quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos e instituições com atribuições para proteger os direitos e

deveres dos trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os em esferas que lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a organização do trabalho, se praticadas no contexto das relações de trabalho” (STF, RE 398.041, Plenário, j. 30-11-2006, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 19-12-2008). No mesmo sentido: RE 541.627, 2.^a T., j. 14-10-2008, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 21-11-2008.

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá efetividade a preceitos fundamentais da CF/88 (arts. 5.^o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade” (STF, RE 271.286-AgR, 2.^a T., Plenário, rel. Min. Celso de Mello, j. 12-9-2000, DJ 24-11-2000). No mesmo sentido: STF, RE 368.564, 1.^a T., j. 13-4-2011, rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, DJe 10-8-2011; STF, STA 175-AgR, Plenário, j. 17-3-2010, rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, DJe 30-4-2010.

“Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais,

manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão” (STF, RE 414.426, Plenário, j. 1.º-8-2011, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10-10-2011.) No mesmo sentido: STF, RE 509.409, j. 31-8-2011, decisão monocrática, rel. Min. Celso de Mello, DJe 08-9-2011.

“O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (STF, RE 559.646-AgR, 2.ª T., j. 7-6-2011, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 24-6-2011).

Decisão do STF desobriga Estado de fornecer medicamento sem registro na Anvisa

Entendimento ressalva casos excepcionais e foi firmado no julgamento do RE n. 657.718, com repercussão geral.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 22 de maio de 2019, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), salvo em casos excepcionais. A decisão foi tomada, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 657.718, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do ministro Marco Aurélio.

O Plenário, por maioria de votos, fixou a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral: 1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; 2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; 3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei n. 13.411/2016),

quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União (STF, RE 657.718, plenário, j. 22-5-2019, rel. Min. Marco Aurélio).

- **Súmula 596 do STJ:** “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

- **Súmula Vinculante 55:** “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.

Petições e recursos processuais e prática constitucional

Dicas Importantes das Petições Iniciais:

O art. 319 do CPC/2015 serve como um roteiro básico. Partindo deste dispositivo, deve-se adequar a redação da peça à medida judicial a ser formulada, levando-se em consideração as peculiaridades existentes nas leis específicas. Por exemplo, a Lei n. 4.717/65, que trata da ação popular, prevê no art. 1.º, § 3.º, a juntada do título de eleitor ou documento que demonstre a quitação eleitoral.

Modalidades de Endereçamento:

- a) Justiça Estadual: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da _____ Vara Cível da Comarca de _____
- b) Justiça Federal: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da _____ Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de _____
- c) TJ: Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de _____
- d) TRF: Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da _____ Região
- e) STJ: Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
- f) STF: Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal

Raciocínio Jurídico:

Ao desenvolver a fundamentação de mérito da peça, é imprescindível demonstrar a relação entre os fatos alegados e o direito violado. Não é suficiente a indicação do dispositivo da Constituição Federal ou da lei que foi aviltado, mas se deve concatenar o raciocínio explicando o conteúdo do artigo com a situação fática descrita.

Pedidos:

Tanto o pedido da tutela provisória (urgência ou evidência), quanto o pedido de mérito devem ser especificados, isto é, não basta requerer a “procedência do pedido” de modo genérico, mas, sim, a “procedência do pedido para o fim de _____”. Exemplo prático: Mandado de Segurança cuja finalidade é a concessão de medicamentos – “Ante o exposto, requer-se a procedência do pedido para concessão da segurança a fim de que sejam fornecidos os medicamentos ao Impetrante”.

Requisitos Formais:

O examinando deve ficar atento às formalidades de cada medida judicial proposta, por exemplo, a intimação do representante judicial da pessoa jurídica a que está vinculada a autoridade coatora, no caso de mandado de segurança (art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009); intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República na Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 8.º da Lei n. 9.868/99); entre outras especificidades.

Valor da Causa:

Nos termos do art. 319 do CPC/2015, toda inicial possui valor da causa. Entretanto, a dúvida entre os examinandos consiste na necessidade de se indicar um valor expresso. Nas provas da Banca FGV, em direito constitucional, quando o enunciado não traz nenhuma informação, deve-se indicar um valor específico, a saber: R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Por outro lado, se o enunciado fizer referência a um valor expresso, este é que deverá

ser indicado ao final.

Muito Importante: nas provas não se deve criar nenhum tipo de dado que não conste do enunciado.

22.1. PETIÇÃO INICIAL

Os requisitos de uma petição inicial estão previstos nos arts. 319 a 321 do CPC/2015.

O art. 319 do CPC/2015 determina que a petição inicial indicará:

“I – o juízo a que é dirigida”

Trata-se da competência para conhecer da ação.

Cumprir destacar a competência estabelecida na Constituição Federal de 1988 para as seguintes matérias: a) Justiça Militar (art. 124), b) Justiça do Trabalho (art. 114), c) Justiça Eleitoral (art. 121), d) Justiça Federal (art. 109) e e) Justiça Estadual (art. 125).

Deve-se atentar para as regras de competência previstas no CPC/2015 (arts. 42 a 53) e nas leis especiais, como a Lei n. 8.078/90 – CDC (art. 101), a Lei n. 7.347/85 (Ação Civil Pública), a Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis), e a Lei n. 10.259/2001 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais), entre outras.

“II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”

Trata-se da qualificação completa das partes (autor e réu).

“III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”

É a narrativa dos fatos que constituam lesão ou ameaça de lesão a direito. Deve-se tomar cuidado para não falar do direito, mas apenas dos fatos que violam o direito. Os fatos devem ser narrados objetivamente.

Quanto aos fundamentos jurídicos, deve-se indicar os dispositivos legais em que os fatos narrados se enquadram e que servirão de fundamento para, ao final, fazer os pedidos.

“IV – o pedido com as suas especificações”

O pedido deve ser certo (expresso) e determinado (delimitado em relação à qualidade e quantidade), devendo conter todas as pretensões do autor.

Na prática, são admissíveis os seguintes pedidos implícitos (na prova prático-profissional devem ser feitos expressamente): a) juros legais; b) correção monetária; c) verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios (art. 322, § 1.º do CPC/2015) e d) prestações sucessivas (art. 323 do CPC/2015).

É possível pedido genérico nos casos previstos no art. 324, § 1.º do CPC/2015: nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. O disposto no citado artigo aplica-se à reconvenção.

O Código de Processo Civil permite, ainda, pedidos em ordem subsidiária (art. 326) e pedidos cumulados (art. 327).

“V – o valor da causa”

O art. 291 do CPC/2015 determina que a toda causa seja atribuído um valor certo (proveito que o autor terá com a procedência da demanda), ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Deve-se observar o previsto nos arts. 291 a 293 do CPC/2015.

“VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”

O autor deve protestar pela produção de todos os tipos de prova admitidos no direito, especificando as provas que já tem interesse em produzir, por exemplo, prova testemunhal e pericial.

Tratando-se de relação de consumo, deve-se pedir a inversão do ônus da prova (art. 6.º, VIII, do CDC).

“VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação”

Há como novidade a realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. O autor deve requerer a citação do réu por oficial de justiça, com os benefícios do art. 212 do CPC/2015. Sobre o tema, consultar arts. 246 a 249 do CPC/2015.

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

- **Súmula 6:** “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de Polícia Militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade”.

- **Súmula 11:** “A presença da União ou de qualquer de seus entes, na ação de usucapião especial, não afasta a competência do foro da situação do imóvel”.

- **Súmula 34:** “Compete à Justiça Estadual processar e julgar causa relativa a mensalidade escolar, cobrada por estabelecimento particular de ensino”.

- **Súmula 42:** “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes

praticados em seu detrimento”.

- **Súmula 55:** “Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal”.
- **Súmula 137:** “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário”.
- **Súmula 150:** “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
- **Súmula 177:** “O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado”.

Súmula do Supremo Tribunal Federal:

- **Súmula 736:** “Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”.

atenção

Conforme o CDC (art. 6.º, VIII), deve-se pedir a inversão do ônus da prova. Se for o caso, dependendo do informado pelo enunciado, devem ser pedidos os benefícios da justiça gratuita (Lei n. 1.060/50).

22.2. CONTESTAÇÃO

É o meio processual pelo qual o réu apresenta defesa, processual e de mérito, impugnando os termos da petição inicial.

Os requisitos estão previstos nos arts. 335 a 342 do CPC/2015:

- 1) Endereçamento: juiz ou Tribunal a que é dirigida.

A contestação deve ser endereçada ao juiz da causa, nos termos do art. 335 do CPC/2015: “O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II – do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4.º, I;

III – prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos”.

Observação: no caso de litisconsórcio passivo, ler §§ 1.º e 2.º do art. 335 do CPC/2015.

2) Identificação do processo: indicação das partes, do número do processo e do nome da ação.

3) Apresentação da defesa: Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC/2015).

Assim, contém as razões de fato e de direito com que se contesta o pedido do autor:

- no item “Dos Fatos”: faz-se breve resumo da petição inicial (fatos alegados pelo autor) e, após, relata-se a versão do réu sobre os fatos.
- no item “Do Direito”: antes de contestar o mérito, porém, cabe ao réu sustentar matéria preliminar, se houver, e, no mérito, impugnar as alegações do autor.

Neste item pode ser feita, então, a seguinte divisão:

a) “Das Preliminares”: estão previstas no art. 337 do CPC/2015 as preliminares processuais, que são as seguintes: “I – inexistência ou nulidade da citação; II – incompetência absoluta e relativa; III – incorreção do valor da causa; IV – inépcia da petição inicial; V – perempção; VI – litispendência; VII – coisa julgada; VIII – conexão; IX – incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X – convenção de arbitragem; XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII – falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII – indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça”.

O rol das preliminares não é taxativo. O réu pode arguir, também, qualquer das hipóteses previstas no art. 485 do CPC/2015, bem como a existência de algum vício processual ou alguma matéria que possa ensejar o indeferimento, de plano, da inicial pelo juiz.

b) “Do Mérito”: iniciar alegando, se for o caso, a prescrição e a decadência, que são matérias de mérito. Após, o réu deve se manifestar precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, pois, de acordo como o previsto no art. 341 do CPC/2015, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados.

Somente se admite a “contestação genérica” ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial (art. 341, parágrafo único, do CPC/2015).

4) Pedido: se houve alegação de preliminares processuais, deve-se fazer o pedido de acolhimento da preliminar, pedindo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Se houve alegação de prescrição e decadência, deve-se pedir o seu reconhecimento e a extinção do processo com resolução do mérito (art.

487, II, do CPC/2015).

Em relação ao mérito, deve-se pedir a improcedência total do pedido pelo autor, com extinção do processo com resolução do mérito. Pedir, ainda, a imposição de todos os ônus de sucumbência ao autor.

5) Requerimentos de provas: protestar por provas que poderão demonstrar a veracidade dos fatos alegados (art. 336 do CPC/2015). Compete ao réu especificar as provas que pretende produzir (documental, pericial e testemunhal), desde que estejam de acordo com o art. 369 e s. do CPC/2015. O réu deve desde logo apresentar as provas documentais existentes. Depois da contestação, somente será possível a apresentação de documentos novos, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC/2015.

Caso o autor tenha feito pedido de inversão do ônus da prova, cabe ao réu, na contestação, impugnar esse pedido.

22.3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC/2015 e são cabíveis de qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Além disso, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º do CPC/2015.

Destaque-se que no Juizado Especial Cível caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão (art. 83 da Lei n. 9.099/95). Nesse caso, deverão ser interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão (art. 49 da Lei n. 9.099/95).

Podem, ainda, ser opostos para fins de prequestionamento de recurso especial e extraordinário, nos termos da Súmula 356 do STF: “O ponto omissa da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

O art. 1.023 do CPC/2015 estabelece os requisitos dos embargos declaratórios: a) devem ser opostos em petição dirigida ao juiz; b) no prazo de 5 (cinco) dias; c) com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Não estão sujeitos a preparo.

No pedido deverá ser requerido que seja sanada a irregularidade.

Destaque-se que o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada (art. 1.023, § 2.º, do CPC/2015).

Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, mas não possuem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC/2015).

22.4. AGRAVO DE INSTRUMENTO

O recurso de agravo de instrumento é aquele cabível contra decisões interlocutórias (art. 1.015 do CPC/2015).

Decisão interlocutória é aquela que resolve uma questão incidente ou provoca algum prejuízo à parte ou interessado, sem, porém, encerrar o processo (art. 203, § 2.º, do CPC/2015).

Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC/2015, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais (art. 203, § 1.º, do CPC/2015).

Dos despachos não cabe recurso (art. 1.001 do CPC/2015).

Caberá agravo por instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1.º, outros casos expressamente referidos em lei. Também caberá contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (art. 1.015, I a XIII e parágrafo único, do CPC/2015).

O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao Tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos (art. 1.016 do CPC/2015):

“I – os nomes das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”.

A petição de agravo de instrumento será instruída:

“I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados

do agravante e do agravado;

II – com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis” (art. 1.017 do CPC/2015).

“Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais” (art. 1.017, § 1.º, do CPC/2015).

No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

“I – protocolo realizado diretamente no Tribunal competente para julgá-lo;

II – protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III – postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV – transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V – outra forma prevista em lei” (art. 1.017, § 2.º, do CPC/2015).

Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único (art. 1.017, § 3.º, do CPC/2015).

Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original (art. 1.017, § 4.º, do CPC/2015).

Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia (art.

1.017, § 5.º, do CPC/2015).

O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso (art. 1.018, caput, do CPC/2015).

Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento (art. 1.018, § 1.º, do CPC/2015).

Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento (art. 1.018, § 2.º, do CPC/2015).

O descumprimento da exigência de que trata o § 2.º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento (art. 1.018, § 3.º, do CPC/2015).

Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

“I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II – ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III – determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 1.019 do CPC/2015).

O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado (art. 1.020 do CPC/2015).

22.5. AGRAVO INTERNO

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC/2015).

Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1.º, do CPC/2015).

O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta (art. 1.021, § 2.º, do CPC/2015).

É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (art. 1.021, § 3.º, do CPC/2015).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015).

A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4.º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5.º, do CPC/2015).

22.6. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Cabe agravo contra decisão de Presidente ou de Vice-Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (art. 1.042 do CPC/2015 com redação dada pela Lei n. 13.256/2016).

A petição de agravo será dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação (art. 1.042, § 2.º, do CPC/2015 com redação dada pela Lei n. 13.256/2016).

O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.042, § 3.º, do CPC/2015).

Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal superior competente (art. 1.042, § 4.º, do CPC/2015).

O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do Tribunal respectivo (art. 1.042, § 5.º, do CPC/2015).

Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido (art. 1.042, § 6.º, do CPC/2015).

Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao Tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.042, § 7.º, do CPC/2015).

Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado (art. 1.042, § 8.º, do CPC/2015).

Súmula do Superior Tribunal de Justiça referente ao tema:

- **Súmula 118:** “O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação”.

22.7. APELAÇÃO

A apelação é o recurso cabível contra a sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, com o objetivo de ver a matéria ser reexaminada pelo órgão superior (art. 1.009 do CPC/2015).

Considera-se sentença o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais (art. 203, § 1.º, do CPC/2015).

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015).

Se as questões referidas no § 1.º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009, § 2.º, do CPC/2015).

O disposto no caput do art. 1.009 do CPC/2015 aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença (art. 1.009, § 3.º, do CPC/2015).

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

“I – os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão” (art. 1.010 do CPC/2015).

O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1.º, do CPC/2015).

Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2.º, do CPC/2015).

Após as formalidades previstas nos §§ 1.º e 2.º, os autos serão remetidos ao Tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3.º, do CPC/2015).

Recebido o recurso de apelação no Tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

“I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, III a V;

II – se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado” (art. 1.011 do CPC/2015).

A apelação terá efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC/2015).

Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

“I – homologa divisão ou demarcação de terras;

II – condena a pagar alimentos;

III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI – decreta a interdição” (art. 1.012, § 1.º, do CPC/2015).

Nos casos do § 1.º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento

provisório depois de publicada a sentença (art. 1.012, § 2.º, do CPC/2015).

O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

“I – Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II – relator, se já distribuída a apelação” (art. 1.012, § 3.º, do CPC/2015).

Nas hipóteses do § 1.º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4.º, do CPC/2015).

A apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do CPC/2015).

Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (art. 1.013, § 1.º, do CPC/2015).

Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento dos demais (art. 1.013, § 2.º, do CPC/2015).

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação (art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015).

Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau (art. 1.013, § 4.º, do CPC/2015).

O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação (art. 1.013, § 5.º, do CPC/2015).

As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).

Cumprir lembrar que da sentença no juizado especial cível cabe recurso inominado (art. 41 e s. da Lei n. 9.099/95).

Súmula do Superior Tribunal de Justiça referente ao tema:

- **Súmula 331:** “A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo”.

22.8. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

O recurso extraordinário (RE), a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cabe nas causas decididas em única ou última instância, nos termos do art. 102, III, da CF/88, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo da Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

São requisitos do recurso extraordinário:

- a) o prazo para interposição e para resposta é de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5.º do CPC/2015;

- b) será interposto por petição dirigida ao Presidente do Tribunal ou Vice-Presidente (depende do regimento interno) recorrido, acompanhada das razões recursais, nos termos do art. 1.029 do CPC/2015;
- c) requer preparo, destacando-se que a Fazenda Pública está dispensada, nos termos do art. 1.007, caput e § 1.º, do CPC/2015;
- d) a petição de interposição deve ter os seguintes elementos: endereçamento ao presidente do tribunal recorrido; nomes e qualificação das partes (ou já qualificadas nos autos), para os recorrentes e recorridos; indicação de que se trata de recurso extraordinário; indicação de que preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme as razões juntadas; requerimento para que seja o recorrido intimado para apresentar contrarrazões no prazo legal; requerimento para que o recurso seja devidamente processado, pois preenche os pressupostos de admissibilidade, remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal; requerimento de juntada das guias de custas de preparo, porte de remessa e retorno dos autos;
- e) as razões de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.029 do CPC/2015, devem ter os seguintes requisitos: breve resumo da demanda; demonstração do cabimento do recurso (uma das hipóteses dos art. 102, III, da CF/88); demonstração da existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015 (consideram-se de repercussão geral “as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” e “contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal”); demonstração da existência de prequestionamento da matéria; razões jurídicas do pedido de reforma da decisão recorrida.

Cumpram-se destacar que o recorrente pode ingressar, ao mesmo tempo, com

recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, desde que o faça em petições separadas, preenchendo, em cada uma delas, os respectivos requisitos (arts. 1.029 e 1.031 do CPC/2015).

O recorrido terá 15 dias para apresentar contrarrazões. Findo tal prazo, os autos serão conclusos ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6.º do art. 1.036;

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão

geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o Tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação (art. 1.030 do CPC/2015).

Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao Tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (art. 1.030, § 1.º, do CPC/2015).

Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (art. 1.030, § 2.º, do CPC/2015).

Súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

- **Súmula 279:** “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
- **Súmula 281:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
- **Súmula 282:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
- **Súmula 283:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
- **Súmula 284:** “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
- **Súmula 285:** “Não sendo razoável a arguição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra c do art. 101, III, da CF/88” (refere-se à CF/46 – vide art. 102, III, c, da CF/88).
- **Súmula 286:** “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
- **Súmula 287:** “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na

sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

- **Súmula 289:** “O provimento do agravo por uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário”.

- **Súmula 299:** “O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança, ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno”.

- **Súmula 369:** “Julgados do mesmo tribunal não servem para fundamentar o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial”.

- **Súmula 454:** “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.

- **Súmula 456:** “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”.

- **Súmula 636:** “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.

- **Súmula 637:** “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município”.

- **Súmula 638:** “A controvérsia sobre a incidência, ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário”.

- **Súmula 640:** “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”.

- **Súmula 727:** “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão

que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.

- **Súmula 728:** “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei n. 6.055/74, que não foi revogado pela Lei n. 8.950/94”.

- **Súmula 733:** “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”.

- **Súmula 735:** “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.

ATENÇÃO

Súmula 699 do STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei n. 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei n. 8.950/94 ao Código de Processo Civil”.

22.9. RECURSO ESPECIAL

O recurso especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe nas causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 105, III, da CF/88, quando a decisão recorrida: “a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal”.

São características do recurso especial:

- a) o prazo para interposição e para resposta é de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5.º do CPC/2015;

- b) é interposto por petição dirigida ao Presidente do Tribunal ou Vice-Presidente (depende do regimento interno) recorrido, acompanhada das razões recursais, nos termos do art. 1.029 do CPC/2015;
- c) requer preparo, destacando-se que a Fazenda Pública está dispensada, nos termos do art. 1.007, caput e § 1.º, do CPC/2015;
- d) a petição de interposição deve ter os seguintes elementos: endereçamento ao presidente do tribunal recorrido; nomes e qualificação das partes (ou já qualificadas nos autos), para os recorrentes e recorridos; indicação de que se trata de recurso especial; indicação de que preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme as razões juntadas; requerimento para que seja o recorrido intimado para apresentar contrarrazões no prazo legal; requerimento para que o recurso seja devidamente processado, pois preenche os pressupostos de admissibilidade, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça; requerimento de juntada das guias de custas de preparo, porte de remessa e retorno dos autos;
- e) as razões de recurso especial, nos termos do art. 1.029 do CPC/2015, devem ter os seguintes requisitos: breve resumo da demanda; demonstração do cabimento do recurso (uma das hipóteses do art. 105, III, da CF/88); demonstração da existência de prequestionamento da matéria; razões jurídicas do pedido de reforma da decisão recorrida.

Cumprе destacar que o recorrente pode ingressar, ao mesmo tempo, com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, desde que o faça em petições separadas, preenchendo, em cada uma delas, os respectivos requisitos (arts. 1.029 e 1.031 do CPC/2015).

O recorrido terá 15 dias para apresentar contrarrazões. Findo tal prazo, os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6.º do art. 1.036;

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o Tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação (art. 1.030 do CPC/2015)

Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao Tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (art. 1.030, § 1.º, do CPC/2015).

Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo

interno, nos termos do art. 1.021 (art. 1.030, § 2.º, do CPC/2015).

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

- **Súmula 5:** "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial".
- **Súmula 7:** "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
- **Súmula 13:** "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial".
- **Súmula 83:** "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
- **Súmula 86:** "Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento".
- **Súmula 98:** "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório".
- **Súmula 116:** "A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça".
- **Súmula 123:** "A decisão que admite, ou não, o recurso especial, deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais".
- **Súmula 126:** "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
- **Súmula 203:** "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais".
- **Súmula 211:** "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".

- **Súmula 216:** “A tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da secretaria e não pela data da entrega na agência do correio”.

- **Súmula 316:** “Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial”.

ATENÇÃO

Súmula 699 do STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei n. 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei n. 8.950/94 ao Código de Processo Civil”.

22.10. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – ROC

O recurso ordinário constitucional, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cabe nas causas que julgarem o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, nos termos do art. 102, II, a e b, da CF/88.

O recurso ordinário constitucional, a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe nos casos de habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; de mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; e das causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País (art. 105, II, a, b e c, da CF/88).

São características do recurso ordinário constitucional:

- a) o prazo para interposição e para resposta é de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015; “o prazo de recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, ou mandado de segurança é de cinco dias” (Súmula 319 do STF);
- b) será interposto por petição dirigida ao Presidente do Tribunal ou Vice-Presidente (depende do regimento interno) recorrido, acompanhada das razões recursais, nos termos do art. 1.029 do CPC/2015;
- c) por cautela deve ser feito preparo, destacando-se que a Fazenda Pública está dispensada, nos termos do art. 1.007, § 1.º, do CPC/2015;
- d) a petição de interposição deve ter os seguintes elementos: endereçamento ao presidente do tribunal ou vice-presidente (depende do regimento interno) recorrido; nomes e qualificação das partes (ou já qualificadas nos autos), para os recorrentes e recorridos; indicação de que se trata de recurso ordinário constitucional; indicação de que preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme as razões juntadas; requerimento para que seja o recorrido intimado para apresentar contrarrazões no prazo legal; requerimento para que o recurso seja devidamente processado, pois preenche os pressupostos de admissibilidade, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal; requerimento de juntada das guias de custas de preparo, porte de remessa e retorno dos autos;
- e) as razões de recurso ordinário constitucional, nos termos dos arts. 1.027 e 1.028 do CPC/2015 devem ter os seguintes requisitos: breve resumo da demanda; demonstração do cabimento do recurso (uma das hipóteses dos arts. 105, II, ou 102, II, da CF/88); ratificação da tese sustentada no instrumento processual recorrido.

Saliente-se que compete ao juiz federal de primeira instância julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País (art. 109, II, da CF/88) e o crime

político (art. 109, IV, da CF/88). Nesses casos, de tais decisões caberá recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça (causas internacionais – art. 105, II, c, da CF/88) e para o Supremo Tribunal Federal (crime político – art. 102, II, b, da CF/88).

IMPORTANTE

Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015 (Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I – reformar sentença fundada no art. 485; II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação) e 1.029, § 5.º do CPC/2015 (o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo (com a redação da Lei n. 13.256/2016); II – ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 do CPC/2015 – com a redação da Lei n. 13.256/2016).

Súmula do Supremo Tribunal Federal:

- **Súmula 272:** “Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança”.

22.11. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

Os embargos de divergência são cabíveis de divergências de julgamentos do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, e o procedimento está estabelecido nos regimentos internos respectivos (arts. 994, IX, e 1.043 do CPC/2015).

Os embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal estão disciplinados nos arts. 330 a 336 do seu Regimento Interno e no Superior

Tribunal de Justiça nos arts. 266 e 267 do seu Regimento Interno.

O objetivo de tais embargos é obter a uniformização de jurisprudência interna do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, reformando-se ou anulando-se o acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.043 do CPC/2015:

É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;

II – (Revogado pela Lei n. 13.256/2016);

III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

IV – (Revogado pela Lei n. 13.256/2016).

Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária (art. 1.043, § 1.º, do CPC/2015).

A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual (art. 1.043, § 2.º, do CPC/2015).

Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros (art. 1.043, § 3.º, do CPC/2015).

O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução

de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados (art. 1.043, § 4.º, do CPC/2015).

No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal superior (art. 1.044, caput, do CPC/2015).

A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes (art. 1.044, § 1.º, do CPC/2015).

Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação (art. 1.044, § 2.º, do CPC/2015).

Os embargos de divergência devem ser opostos na referida secretaria no prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015), sendo juntados aos autos independentemente de despacho. Feita a distribuição, os autos serão conclusos ao relator, que irá admitir ou não os embargos de divergência. Admitidos os embargos e efetuado o preparo (salvo no STJ – art. 41-B da Lei n. 8.038/90 e art. 112 do RISTJ), será feita a intimação do embargado para apresentar contrarrazões.

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

- **Súmula 158:** “Não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio com acórdão de Turma ou Seção que não mais tenha competência para a matéria neles versada”.
- **Súmula 168:** “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”.
- **Súmula 316:** “Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em

agravo regimental, decide recurso especial”.

22.12. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

A reclamação tem por objetivo preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões (arts. 102, I, I e art. 105, I, f, ambos da CF/88). Admite-se, também, em face da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente (art. 7.º, caput, da Lei n. 11.417/2006 e art. 103-A, § 3.º, da CF/88).

De acordo com o art. 988 do CPC/2015, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

“I – preservar a competência do Tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (incisos III e IV com a redação da Lei n. 13.256/2016).

A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir (art. 988, § 1.º, do CPC/2015).

A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao Presidente do Tribunal (art. 988, § 2.º, do CPC/2015).

Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível (art. 988, § 3.º, do CPC/2015).

As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da

tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam (art. 988, § 4.º, do CPC/2015).

É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5.º, do CPC/2015 com redação dada pela Lei n. 13.256/2016).

A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação (art. 988, § 6.º, do CPC/2015).

Ao despachar a reclamação, o relator: I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias, II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável ou III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, I a III, do CPC/2015).

Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante (art. 990 do CPC/2015).

Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado (art. 991 do CPC/2015).

Julgando procedente a reclamação, o Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 do CPC/2015).

O Presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente (art. 993 do CPC/2015). É

cabível o pedido de liminar na reclamação, devendo ser demonstrado o *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Se a reclamação for por desrespeito a enunciado de súmula vinculante, julgado procedente o pedido, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, nos termos do art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 11.417/2006.

Súmulas do STF sobre o tema:

- **Súmula 368:** “Não há embargos infringentes no processo de reclamação”.
- **Súmula 734:** “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

22.13. PARECER

O parecer é a manifestação de especialista sobre assuntos submetidos a sua consideração. É uma opinião fundamentada (juízo de valor motivado). Basicamente, possui a estrutura do texto jurídico: premissa maior, premissa menor e conclusão.

São objetivos do parecer: a) orientar o consulente/interessado; b) informar as opções válidas para uma conduta ou procedimento; e c) interpretar dispositivos legais na ausência de atos administrativos normativos ou ordinatórios.

22.14. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DA CANDIDATURA

Pode ser ajuizada no prazo de cinco dias a contar da data da publicação do edital contendo a relação nominal dos pedidos de registro de candidatura. Caberá a qualquer candidato, a partido político, a coligação ou ao Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada

(art. 3.º, caput, da LC n. 64/90).

Na petição inicial, o impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de seis (art. 3.º, § 3.º, da LC n. 64/90). Recomenda-se usar a estrutura do art. 319 do CPC/2015.

O motivo para a impugnação poderá ser a ausência de qualquer requisito constitucional ou legal para a candidatura, tais como, a idade inferior à prevista na Constituição, candidato analfabeto ou que não possui domicílio eleitoral na circunscrição na qual vai disputar o cargo eletivo, entre outros.

Saliente-se que compete ao juiz eleitoral o indeferimento das candidaturas que não atendam aos requisitos constitucionais e legais, independente de impugnação.

Aplica-se procedimento previsto nos arts. 2.º a 16 da Lei Complementar n. 64/90, sendo a competência prevista no art. 2.º. Nas eleições municipais, da sentença cabe recurso ao TRE no prazo de três dias (art. 8.º da LC n. 64/90). Da decisão do regional cabe, no mesmo prazo, recurso ao TSE (art. 11, § 2.º, da LC n. 64/90).

O trânsito em julgado da decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, terá por consequência a nulidade do registro ou, se for o caso, o cancelamento da diplomação com a consequente perda do mandato (art. 15, caput, da LC n. 64/90).

Não se aplicam as regras dos arts. 180 e 229 do CPC/2015 (ampliação de prazo).

22.15. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

As ações de investigação judicial eleitoral, em geral, seguem o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90 e são divididas em: ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder (art. 1.º, I, d, art. 19 e art. 22 da LC n. 64/90), ação por captação ou gasto ilícito de recursos para

fins eleitorais (art. 30-A da Lei n. 9.504/97), ação por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei n. 9.504/97) e ação por conduta vedada (art. 73 e s. da Lei n. 9.504/97).

Tais ações visam a proteger a legitimidade do pleito e especificamente:

- a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder objetiva a declaração de inelegibilidade por 8 anos e cassação do registro;
- a ação por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais almeja a negação de diploma ou sua cassação;
- a ação por captação ilícita de sufrágio tem por fim a cassação do registro ou do diploma e multa;
- a ação por conduta vedada visa à cassação do registro ou do diploma e multa.

Como estabelece o art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, os legitimados poderão representar à Justiça Eleitoral relatando os fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político. Aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Recomenda-se usar a estrutura do art. 319 do CPC/2015 na elaboração das iniciais.

Para o julgamento de tais ações será competente o TSE nas eleições presidenciais, os Tribunais Regionais Eleitorais nas eleições federais e estaduais, e caberá aos juízes eleitorais nas eleições municipais.

22.16. RECURSO CONTRA A DIPLOMAÇÃO

Esta ação, que pode ser ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, candidatos, partidos ou coligações, visa à nulidade da diplomação em face de erro na contagem dos votos ou inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato (art. 262 do Código Eleitoral – prazo de 3 dias da diplomação).

Exige prova pré-constituída, isto é, não admite dilação probatória.

A competência será do TRE nas eleições municipais e do TSE nas eleições gerais.

Embora o processo eleitoral se encerre com a diplomação, posterior julgamento definitivo das ações que impugnaram a diplomação tem efeito ex tunc, cancelando o ato de diplomação, com a consequente perda do mandato.

22.17. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO

Prevista no art. 14, §§ 10 e 11, da CF/88. Independe de prova pré-constituída. Cuida-se de ação civil a qual tem por objeto o cancelamento do mandato do candidato que tiver agido com abuso de poder econômico, fraude ou corrupção.

A ação tramita em segredo de justiça evitando sua utilização para finalidades pessoais de candidatos ou partidos em detrimento do bem comum e da democracia.

O procedimento a ser adotado é o da Lei Complementar n. 64/90 (arts. 2.º a 16), aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Recomenda-se usar a estrutura do art. 319 do CPC/2015 na inicial.

A competência para o julgamento cabe, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, à Justiça Eleitoral, ou seja, quem tiver competência para efetivar o ato de diplomação do candidato será competente para julgar a ação (Juiz Eleitoral – Prefeito, Vereador; TRE – Governador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador; TSE – Presidente da República).

São legitimados para o ajuizamento qualquer partido político, coligação, candidato ou o Ministério Público.

No polo passivo deverá constar o candidato diplomado acusado de agir com fraude, corrupção ou abuso.

O constituinte determinou o prazo decadencial de 15 dias contados da diplomação, para o ajuizamento da ação.

Após o trânsito em julgado, será destituído do cargo o condenado.

ATENÇÃO

Com relação ao tema recursos em matéria eleitoral devem ser lidos do art. 257 ao art. 282 do Código Eleitoral. No que se refere à competência: TSE – art. 22; TRE – art. 29 e aos juízes eleitorais – art. 35, todos do Código Eleitoral.

SEGUNDA PARTE

Peças Práticas

1

Ações do controle concentrado de constitucionalidade – ADIn, ADECON e ADPF

1.1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE GENÉRICA (ADIN/ADIN GENÉRICA)

1.1.1. Modelo esquemático de Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

[Pessoas relacionadas no art. 103 da Constituição Federal de 1988 e art. 2.º da Lei n. 9.868/99], por seu advogado inscrito na OAB/____ sob n. ____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso [doc. ____]), com endereço sito na (Rua ____, n. ____, Bairro ____, [Cidade/Estado], CEP: ____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do CPC/2015), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 103, inciso (____), art. 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988, arts. 2.º, inciso (____) e 10 da Lei n. 9.868/99 e art. 319 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR em face de _____
[Legitimidade passiva: órgão ou autoridade que editou o ato que se pretende impugnar].

I – DA NORMA IMPUGNADA

[Da norma impugnada]

Resumo do enunciado apresentado, indicando que a norma que se impugna ofende a Constituição Federal e padece, portanto, de inconstitucionalidade.

II – FORO COMPETENTE [Do foro]

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

[Justificativa para a legitimidade ativa]

[Indicar que o autor da ação tem legitimidade ativa para propor a ADIn Genérica. Não se esquecer de justificar a pertinência temática, se for o caso. Por exemplo:]

O autor da presente ação é Governador de Estado e, desse modo, nos termos do art. 103, V, da Constituição Federal de 1988 e art. 2.º, V,

da Lei n. 9.868/99 é parte legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, sendo considerado legitimado especial.

O Decreto presidencial n. ____/____ que estabelece (assunto) está causando grave prejuízo ao Estado do requerente, motivo que justifica a propositura da presente ação e preenche o requisito da pertinência temática.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

[Justificativa da legitimidade passiva]

[Demonstrar que a autoridade indicada no polo passivo (requerido) é a responsável pela edição do ato que se pretende impugnar. Por exemplo:]

A legitimidade passiva da ação direta de inconstitucionalidade em referência é do Presidente da República, que assinou o tratado internacional e após aprovação do Congresso Nacional, na forma de decreto legislativo, editou decreto promulgando-o e ratificando-o (art. 84, VIII, da Constituição Federal de 1988).

V – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL/FORMAL [dependendo do caso]

[Fundamentação jurídica]

[Indicar que a lei ou ato normativo impugnado é inconstitucional]

Artigo ____

Fato ____

Doutrina ____

Jurisprudência ____

Conclusão ____

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

Em ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a previsão do art. 102, I, alínea p, da Constituição Federal de 1988 e art. 10 da Lei n. 9.868/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade constante da inicial em virtude da patente contrariedade [indicar a ofensa à Constituição Federal] – fumus boni iuris. Está igualmente atendido o requisito do periculum in mora, em face do dano irreparável causado [especificar de acordo com o enunciado].

VII – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pelo ato normativo questionado, manifeste-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.868/99;

b) a concessão de medida cautelar com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender a eficácia do dispositivo _____ (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

c) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pela incorporação do tratado questionado, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

d) a intimação do senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional

do art. 103, § 3.º, da Constituição Federal de 1988;

e) a intimação do senhor Procurador-Geral da República, para emitir seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da Constituição Federal de 1988;

f) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo _____ [Cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99].

Valor da causa R\$ _____ (valor por extenso)

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

1.2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA (ADIN/ADIN INTERVENTIVA) OU REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA

1.2.1. Modelo esquemático de Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 34, VII, 36, III, 129, IV e 102, I, a, todos da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.562/2011 propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA em face de _____ [Legitimidade passiva: órgão ou autoridade estadual ou distrital que violou os princípios constitucionais sensíveis, conforme a seguir será demonstrado]:

I – DA NORMA IMPUGNADA OU ATO IMPUGNADO

[Da norma impugnada]

[Breve resumo dos fatos, por exemplo:]

O Governador do Estado-membro não está respeitando os direitos da pessoa humana (alínea b do inciso VII do art. 34 da Constituição Federal de 1988), previstos no art. 5.º, incisos (____), da Constituição Federal de 1988.

II – FORO COMPETENTE

[Do foro]

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)”.

Além disso, o art. 36, III, da Constituição Federal determina que:

“Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: (...) III – de

provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade interventiva é originária do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema existe a previsão dos arts. 169 a 178 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

[Justificativa para a legitimidade ativa]

O autor da presente ação é exclusivamente o Procurador-Geral da República nos termos do art. 36, III, da Constituição Federal de 1988 e art. 2.º da Lei n. 12.562/2011.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

[Justificativa da legitimidade passiva]

É órgão ou autoridade estadual ou distrital que violou os princípios constitucionais sensíveis.

V – DO CABIMENTO DA INTERVENÇÃO

[Fundamentação jurídica]

[Descrever a situação fática que se enquadra na previsão constitucional]

VI – DA MEDIDA LIMINAR

[Da liminar]

Em ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida liminar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a previsão do art. 102, I, p, da Constituição Federal de 1988 e art. 5.º da Lei n. 12.562/2011.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade constante da inicial em virtude da patente contrariedade [indicar a ofensa à Constituição Federal] – *fumus boni iuris*. Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face do dano irreparável causado [especificar de acordo com o enunciado].

VII – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pelo ato normativo questionado, manifeste-se, querendo, no prazo de dez dias, sobre o pedido de concessão de medida liminar, com fundamento no art. 6.º, caput, da Lei n. 12.562/2011;

b) a concessão de medida liminar com base no art. 5.º, § 2.º, da Lei n. 12.562/2011, para suspender a eficácia do dispositivo _____ (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011);

c) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pelo desrespeito dos princípios constitucionais sensíveis, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de dez dias, nos termos do art. 6.º, § 1.º, da Lei n. 12.562/2011;

d) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a

inconstitucionalidade do dispositivo estadual ou distrital com edição do decreto interventivo.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Procurador-Geral da República

1.3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPRIDORA DA OMISSÃO OU POR OMISSÃO (ADIN/ADIN-SO OU ADIN/ADIN-PO)

1.3.1. Modelo esquemático de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ou Supridora da Omissão

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

(Pessoas relacionadas no art. 103 da Constituição Federal de 1988 e art. 12-A da Lei n. 9.868/99), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 103, inciso (_____), 102, I, a, da Constituição Federal de 1988, art. 12-A da Lei n. 9.868/99 e art. 319 e

s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO com pedido de medida cautelar em face de _____ [Legitimidade passiva: órgão ou autoridade responsável pela não edição do ato necessário à efetividade da norma constitucional].

I – DA NORMA NÃO REGULAMENTADA

[Da norma não regulamentada]

[Resumo do enunciado apresentado, indicando que existe uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada que impede o exercício de um direito, caracterizando uma inconstitucionalidade por omissão].

II – FORO COMPETENTE

[Do foro]

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão é originária do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

[Justificativa para a legitimidade ativa]

[Indicar que o autor da ação tem legitimidade ativa para propor a ADIn por omissão (art. 103 da Constituição Federal de 1988 e art. 12-A da Lei n. 9.868/99)]

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

[Justificativa da legitimidade passiva]

[Demonstrar que a autoridade indicada no polo passivo (requerido) é a responsável pela omissão na edição da norma.]

V – INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

[Fundamentação jurídica]

[Indicar o direito previsto na Constituição e que não foi regulamentado]

Artigo _____

Fato _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

[Da cautelar]

Em ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure a suspensão da aplicação da lei ou ato normativo

questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. Nesse sentido é a previsão do art. 102, I, p, da Constituição Federal de 1988 e art. 12-F da Lei n. 9.868/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade por omissão constante da inicial em virtude da patente omissão [indicar a ofensa à Constituição Federal] – *fumus boni iuris*. Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face da excepcional urgência e relevância da matéria [especificar de acordo com o enunciado].

VII – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pela omissão inconstitucional, manifeste-se no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com fundamento no art. 12-F da Lei n. 9.868/99;

b) a concessão de medida cautelar com base no art. 12-F, § 1.º, da Lei n. 9.868/99, para suspender ou a providência a ser adotada (cópias anexas nos termos do art. 12-B, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

c) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pela não edição da norma, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

d) a intimação do senhor Advogado-Geral da União, para se

manifestar, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 12-E, § 2.º da Lei n. 9.868/99;

e) a intimação do senhor Procurador-Geral da República, para emitir seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 12-E, § 3.º, da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da Constituição Federal de 1988;

f) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, e dar ciência ao Poder competente para adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazer em trinta dias ou em prazo razoável a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido [verificar o caso apresentado – § 2.º do art. 103 da Constituição Federal de 1988 e art. 12-H, § 1.º, da Lei n. 9.868/99].

Dá-se à causa o valor de R\$ _____ (valor por extenso)

Termos em que,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

1.4. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADECON/ADECO/ADC)

1.4.1. Modelo esquemático de Ação Declaratória de Constitucionalidade

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de 5 linhas)

[Legitimidade ativa]

(Pessoas relacionadas no art. 103 da Constituição Federal de 1988), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 103, inciso (_____), 102, I, a, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 21 da Lei n. 9.868/99 e art. 319 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR tendo por objeto o art. (_____) da Lei federal_____, conforme a seguir será demonstrado:

I – DA NORMA CONSTITUCIONAL

[Da norma impugnada]

[Indicar o dispositivo federal declarado judicialmente inconstitucional objeto da ação declaratória de constitucionalidade e resumo do enunciado].

II – FORO COMPETENTE

[Do foro]

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação declaratória de constitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

[Justificativa para a legitimidade ativa]

[Indicar que o autor da ação tem legitimidade ativa para propor a ação declaratória de constitucionalidade. Não se esquecer de justificar a pertinência temática, se for o caso]

IV – DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA

[A situação de incerteza quanto à constitucionalidade dos dispositivos legais em razão das decisões nas quais se evidencia a existência de controvérsia sobre a legitimidade constitucional. Sustentar a constitucionalidade da norma federal]

V – DA MEDIDA CAUTELAR

[Da cautelar]

Em ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido, é a previsão do art. 21 da Lei n. 9.868/99.

Para concessão de cautelar em ação declaratória de

constitucionalidade é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Há plausibilidade jurídica, pois não resta dúvida sobre a constitucionalidade da norma objeto desta ação declaratória de constitucionalidade (fumus boni iuris). Está igualmente atendido o requisito do periculum in mora, em face das sucessivas impugnações que a norma tem sofrido nas instâncias ordinárias, ao longo do período de sua vigência, causando prejuízo ao erário federal.

VI – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a concessão de medida cautelar com base no art. 21 da Lei n. 9.868/99, para que sejam sobrestados os julgamentos dos processos que envolvam a aplicação do preceito normativo objeto desta ação, assim como a suspensão dos efeitos de quaisquer decisões que tenham afastado a sua aplicação, até o final julgamento do processo (cópias anexas nos termos do art. 14, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

b) a intimação do senhor Procurador-Geral da República, para emitir seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 19 da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da Constituição Federal de 1988;

c) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a constitucionalidade do dispositivo mencionado (indicar os artigos e a lei), produzindo tal decisão, nos termos do § 2.º do art. 102 da Constituição Federal, eficácia contra todos e efeito vinculante.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB _____

1.5. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF)

1.5.1. Modelo esquemático de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de 5 linhas)

[Legitimidade ativa]

(Pessoas relacionadas no art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99 c/c art. 103 da Constituição Federal de 1988), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado]), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, § 1.º, da Constituição Federal de 1988, art. 1.º e s. da Lei n. 9.882/99 e art. 319 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR em face da _____ [Legitimidade passiva: autoridade ou órgão que violou os seguintes

preceitos fundamentais (indicar quais foram os preceitos fundamentais da Constituição Federal que foram vulnerados), conforme a seguir será demonstrado:

I – DO PRECEITO FUNDAMENTAL NO CASO APRESENTADO

[Do preceito fundamental]

Descrever o preceito fundamental (constitucional) que foi violado.

II – FORO COMPETENTE

[Do foro]

O art. 102, § 1.º, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental é originária do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

[Justificativa para a legitimidade ativa]

Nos termos do art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99, a legitimidade ativa para a propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental recai sobre aqueles que têm o direito de propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, constantes no art. 103 da Constituição Federal.

[Indicar que o autor da ação tem legitimidade ativa para propor a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Não se

esquecer de justificar a pertinência temática, se for o caso]

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

[Justificativa da legitimidade passiva]

São aqueles que supostamente tenham praticado o ato violador de preceito fundamental.

V – DO CABIMENTO DA ADPF – DA INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PROCESSUAL IDÔNEO E EFICAZ PARA SANAR A LESIVIDADE

[Fundamentação jurídica]

[Observar o previsto no art. 3.º da Lei n. 9.882/99]

Princípio da Subsidiariedade – art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 (não se admite a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade).

VI – DA MEDIDA LIMINAR

[Da liminar]

Em ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida liminar que assegure, temporariamente, força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a determinação do art. 5.º da Lei n. 9.882/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de descumprimento de preceito fundamental constante da inicial em virtude da patente contrariedade do preceito fundamental [indicar a ofensa à Constituição Federal] – *fumus boni iuris*. Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face do dano irreparável causado [especificar de acordo com o enunciado].

VII – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pelo ato normativo questionado, manifeste-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida liminar, com fundamento no art. 5.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99;

b) a concessão de medida liminar para determinar que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da presente ação (art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99);

c) a intimação do órgão/autoridade para que, como autoridade responsável pela prática do ato questionado, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de dez dias, nos termos do art. 6.º, caput, da Lei n. 9.882/99;

d) a intimação do senhor Procurador-Geral da República, para emitir seu parecer, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99;

e) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a violação do preceito fundamental, fixando-se as condições e o seu modo de interpretação e aplicação (nos termos do art. 10 da Lei n. 9.882/99).

Dá-se à causa o valor de R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

Remédios constitucionais

2.1. HABEAS CORPUS

2.1.1. Modelo esquemático de **habeas corpus** liberatório

[Endereçamento]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE _____ [vai depender da
autoridade coatora]

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

(IMPETRANTE), advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil
_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato
incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____,
Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações
(art. 77, V, do Código de Processo Civil) vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, LXVIII, da
Constituição Federal, e arts. 647 e 648 (inciso _____) do Código de
Processo Penal, impetrar HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
em favor de (NOME DO PACIENTE), (nacionalidade), (estado civil),
(profissão), portador do documento de identidade Registro Geral (RG)

n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o n. _____, (residente e domiciliado na Rua _____, n. _____, Bairro _____ Cidade/Estado, CEP: _____) contra ato do MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA _____ CRIMINAL DA COMARCA DE _____ [colocar autoridade coatora], pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Breve resumo dos fatos _____

II – DO DIREITO

[Fundamentação jurídica]

Artigo da Constituição e/ou da lei que foi violado (direito de ir e vir)

Fato lesivo (ameaça ou prisão ilegal ou abusiva) _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DA LIMINAR

[Do pedido liminar]

Presentes o fumus boni iuris, tendo em vista que a prisão é inconstitucional, bem como o periculum in mora, pois existe dano irreparável à liberdade de locomoção do Paciente, justifica-se plenamente o pedido de liminar.

O Superior Tribunal de Justiça admitindo a liminar em habeas corpus assim decidiu:

“Habeas corpus é ação constitucionalizada para preservar o direito

de locomoção contra atual, ou iminente ilegalidade, ou abuso de poder (art. 5.º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988). Admissível a concessão de liminar. A provisional visa a atacar, com a possível presteza, conduta ilícita, a fim de resguardar o direito de liberdade” (STJ, HC 5.574/SP, 6.ª T., rel. p/ acórdão Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 18-8-1997, p. 37.916).

IV – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o Impetrante que o Colendo Tribunal se digne conceder a liminar no presente pedido de habeas corpus, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, confirmando-se no julgamento do mérito, a sua liberdade.

Junta, ao presente feito, os documentos que comprovam a prisão ilegal do Paciente.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Conforme o caso concreto que seja apresentado, deve-se:

- a) requerer a expedição de salvo conduto: HC preventivo;
- b) requerer alvará de soltura: no HC liberatório;
- c) por fim, requer-se contramandado de prisão, quando ela está na iminência de acontecer (quando já há, portanto, mandado de prisão expedido).

2.2. HABEAS DATA

2.2.1. Modelo esquemático de **habeas data**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE _____ [Depende da autoridade coatora, no caso é autoridade federal]

(espaço de cinco linhas)

(NOME DO IMPETRANTE), (qualificação completa: nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. _____, residente e domiciliado na _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, LXXII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 9.507/97, impetrar HABEAS DATA em face do ato do GERENTE DE ATENDIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) da unidade _____ (autoridade coatora), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Demonstrar a negativa no fornecimento de informações do impetrante, inclusive prova da recusa ou decurso de prazo (documento em anexo, nos termos do art. 8.º, parágrafo único, da Lei n. 9.507/97).

II – DO DIREITO

Artigo _____ [art. 5.º, LXXII, da Constituição Federal de 1988 e art. 7.º da Lei n. 9.507/97]

Fato _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência se digne:

- a) notificar o coator sobre os fatos narrados a fim de prestar as informações que entender necessárias (art. 9.º da Lei n. 9.507/97);
- b) determinar a oitiva do representante do Ministério Público no prazo de cinco dias (art. 12 da Lei n. 9.507/97);
- c) julgar procedente o pedido, determinando ao Impetrado o fornecimento das informações pleiteadas (art. 13 da Lei n. 9.507/97).

Valor da causa, para efeitos de alçada, R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Art. 5.º, LXXVII, da Constituição Federal de 1988: “São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania; (...)”. Vide ainda:

2.3. MANDADO DE INJUNÇÃO

2.3.1. Modelo esquemático de mandado de injunção

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [Dependerá da autoridade omissa]

(espaço de cinco linhas)

(NOME DA PARTE), (qualificação completa: nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. _____, residente e domiciliado no endereço _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, LXXI, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 13.300/2016 impetrar MANDADO DE INJUNÇÃO em face da ausência de regulamentação do direito constitucional de _____, [se a omissão for do Poder Legislativo Federal, o mandado de injunção será ajuizado em face do CONGRESSO NACIONAL; se a iniciativa de lei for privativa do PRESIDENTE DA REPÚBLICA (art. 61, § 1.º, da Constituição Federal de 1988), o mandado de injunção será ajuizado em face do próprio Presidente da República] pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

[Descrever a situação apresentada no enunciado proposto]

II – DO DIREITO

Artigo (art. 5.º, LXXI, da Constituição Federal de 1988).

Fato [demonstrar no caso concreto a inviabilidade do exercício de direito constitucional em virtude da ausência de regulamentação do direito constitucional]

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a notificação da autoridade omissa para prestar informações no prazo legal de dez dias, como de direito e ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial;

b) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer.

c) a concessão do direito pleiteado, em virtude da procedência do pedido.

Valor da causa

Dá-se à causa, para efeitos fiscais e de alçada, o valor de R\$ _____
(valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

ATENÇÃO

Em virtude do atual posicionamento do STF, que atribui efeito concreto ao mandado de injunção, deve-se pleitear especificamente o direito a ser concedido.

Observação: indicar a pessoa jurídica que a autoridade coatora integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

2.4. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO

2.4.1. Modelo esquemático de mandado de injunção coletivo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [Dependerá da autoridade omissa]

(espaço de cinco linhas)

(NOME DA PARTE), (qualificação completa: nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. _____, residente e domiciliado no endereço _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, LXXI, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 13.300/2016, impetrar MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO em face da ausência de

regulamentação do direito constitucional de _____, [se a omissão for do Poder Legislativo Federal, o mandado de injunção será ajuizado em face do CONGRESSO NACIONAL; se a iniciativa de lei for privativa do PRESIDENTE DA REPÚBLICA (art. 61, § 1.º, da Constituição Federal de 1988), o mandado de injunção será ajuizado em face do próprio Presidente da República] pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

[Descrever a situação apresentada no enunciado proposto]

II – DO DIREITO

Artigo (art. 5.º, LXXI, da Constituição Federal de 1988).

Fato [demonstrar no caso concreto a inviabilidade do exercício de direito constitucional em virtude da ausência de regulamentação do direito constitucional]

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a notificação da autoridade omissa para prestar informações no prazo legal de dez dias, como de direito e ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial;

b) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer.

c) a concessão do direito pleiteado, em virtude da procedência do pedido.

Valor da causa

Dá-se à causa, para efeitos fiscais e de alçada, o valor de R\$ _____
(valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

2.5. MANDADO DE SEGURANÇA

2.5.1. Modelo esquemático de mandado de segurança

[Endereçamento]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DA COMARCA DE _____ [dependerá da autoridade coatora]

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

(NOME DO IMPETRANTE), (nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. _____), residente e domiciliado no endereço _____, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações

(art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, art. 319 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009 impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR [Lembre-se: se for preventivo, deve-se colocar a indicação] em face do _____ [Legitimidade passiva: ato praticado pelo (NOME DO IMPETRADO – se possível – e CARGO)], com sede de suas atividades na [indicar órgão e endereço] e indicar a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições, pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

[Tecer breve relato dos fatos]

II – DO DIREITO

Artigo da Constituição e/ou da lei que foi violado _____

Fato lesivo _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

Deve-se destacar a ilegalidade ou abusividade do ato da autoridade, o direito líquido e certo do impetrante e a prova pré-constituída que deve instruir a petição inicial (art. 6.º da Lei n. 12.016/2009, deve a petição inicial ser apresentada em duas vias e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópia).

III – DA LIMINAR

[Do pedido de liminar]

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

IV – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência:

a) conceda, in limine, a segurança requerida, com a expedição do competente ofício determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9.º da Lei n. 12.016/2009), assegurando-se ao Impetrante o direito de _____ até o julgamento do mérito do presente mandado;

b) acate as provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia do ato impugnado);

c) determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, entregando-lhe a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009);

d) intime pessoalmente o representante judicial da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

e) determine a oitiva do membro do Ministério Público para oferecer parecer (art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009);

f) fixe multa, nos termos do § 2.º do art. 77 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança e a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo (especificar) do impetrante.

Valor da causa

Dá-se à causa, para efeitos fiscais e de alçada, o valor de R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

2.6. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

2.6.1. Modelo esquemático de mandado de segurança coletivo

[Endereçamento]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DA COMARCA DE _____ [Dependerá da autoridade coatora]

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

(NOME DO IMPETRANTE [Somente os previstos nas alíneas a e b do inciso LXX do art. 5.º da Constituição]), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob n. _____, com sede e domicílio no endereço _____, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos incisos LXIX e LXX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, art. 319 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 21 e s. da Lei n. 12.016/2009 impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR [Lembre-se: se for preventivo deve-se colocar a indicação] em face do ato praticado pelo [Legitimidade passiva: NOME DO IMPETRADO – se possível – e CARGO] com sede de suas atividades no [indicar órgão e endereço] e indicar a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições, pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

[Breve relato dos fatos]

II – DO DIREITO

Artigo da Constituição e/ou da lei que foi violado _____

Fato lesivo _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

Deve-se destacar a ilegalidade ou abusividade do ato da autoridade, o direito líquido e certo do impetrante e a prova pré-constituída que

deve instruir a petição inicial (art. 6.º da Lei n. 12.016/2009, deve a petição inicial ser apresentada em duas vias e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópia).

III – DA LIMINAR

[Do pedido de liminar]

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

IV – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência:

a) determine a oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público à qual se encontra vinculada a autoridade impetrada, para se pronunciar no prazo de 72 horas, nos termos do art. 22, § 2.º da Lei n. 12.016/2009;

b) conceda, *in limine*, a segurança requerida, com a expedição do competente ofício determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, assegurando-se ao impetrante o direito de _____ até o julgamento do mérito do presente mandado;

c) acate as provas que demonstram o direito líquido e certo do

impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia do ato impugnado);

d) determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, entregando-lhe a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009);

e) intime pessoalmente o representante judicial da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

f) determine a oitiva do membro do Ministério Público para oferecer parecer (art. 12 da Lei n. 12.016/2009);

g) fixe multa, nos termos do § 2.º do art. 77 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança e a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo (especificar) do impetrante.

Valor da causa

Dá-se à causa o valor de R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 rege o MS individual e o coletivo.

Foram revogadas as Leis n. 1.533/51, 4.166/62, 4.348/64, 5.021/66, art. 3.º da Lei n.

6.014/73, art. 1.º da Lei n. 6.071/74, art. 12 da Lei n. 6.978/82 e art. 2.º da Lei n. 9.259/96. A Súmula 622 do STF restou prejudicada pela Lei n. 12.016/2009, mais especificamente, art. 16, parágrafo único.

2.7. AÇÃO POPULAR

2.7.1. Modelo esquemático de ação popular

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE _____ [dependerá da autoridade coatora]

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

(NOME DA PARTE – cidadão), (qualificação completa: nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. _____, residente e domiciliado no endereço _____), portador do Título de eleitor n. _____, Seção _____, Zona _____, cidadão em pleno gozo de seus direitos [Documento deve estar anexado, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65] por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 4.717/65, impetrar AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR em face de ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e do DIRETOR DE VENDAS DA EMPRESA _____ com sede na _____ (pessoas públicas ou privadas e os beneficiários do ato ou contrato lesivo, nos termos do art.

6.º, caput, da Lei n. 4.717/65), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

[Breve resumo dos fatos apresentados]

II – DO DIREITO

Artigo _____ [Arts. 2.º, 3.º ou 4.º da Lei n. 4.717/65; demonstrar a ilegalidade e a lesividade; violação dos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988. Falar da legitimação ativa e da necessidade de prova documental, inclusive do título de eleitor – art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65. Se for o caso, falar da ordem para juntada de documentos que somente possam ser obtidos com o réu – art. 1.º, §§ 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, da Lei n. 4.717/65].

Fato _____ [Demonstrar a ilegalidade do contrato administrativo e a lesão ao erário].

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DA LIMINAR

Demonstrada a existência do fumus boni iuris [especificar] e do periculum in mora [especificar] é cabível a concessão de liminar, nos termos do art. 5.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência:

a) conceda liminarmente a suspensão do contrato (ato ou omissão) proibindo ou obrigando o impetrado a (especificar);

b) determine a citação do(s) Impetrado(s) para contestar, sob pena de revelia (art. 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65);

c) determine a intimação do representante do Ministério Público (arts. 6.º, § 4.º e 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65);

d) determine a juntada dos seguintes documentos: (especificar).

[Observação: o pedido deve ser feito apenas se houver necessidade de documentos que somente possam ser obtidos com o impetrado]

e) ao final, julgue procedente o pedido, confirmando a liminar e determine a anulação do contrato administrativo.

f) condene o(s) Impetrado(s) no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65) bem como ao ressarcimento das perdas e danos (art. 11 da Lei n. 4.717/65).

V – PROVAS

Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Valor da causa: R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Súmula 101 do STF: "O mandado de segurança não substitui a ação popular".

2.8. DIREITO DE PETIÇÃO

2.8.1. Modelo esquemático do direito de petição

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OUVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE _____
[Dependerá da autoridade coatora]

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

(NOME DA PARTE, qualificação completa: nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. _____, residente e domiciliado no endereço _____, Cidade/Estado, CEP: _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, XXXIV, a, da Constituição Federal de 1988, requerer seu DIREITO DE PETIÇÃO em face do ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

[Breve resumo dos fatos apresentados. Por exemplo, se o Secretário Municipal de Educação não está respeitando os procedimentos previstos na legislação para a realização de licitações para a compra de

uniformes escolares.]

II – DO DIREITO

Artigo _____

Fato _____ [Demonstrar a ilegalidade do ato administrativo]

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o impetrante que Vossa Senhoria determine a apuração e correção dos atos ilegais cometidos pela autoridade administrativa.

IV – PROVAS

Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Rol de testemunhas:

1. _____

2. _____

3. _____

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

2.9. AÇÃO CIVIL PÚBLICA

2.9.1. Modelo esquemático de ação civil pública

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DA COMARCA DE _____ [Do local do dano]

(espaço de cinco linhas)

(NOME DA PARTE – art. 5.º da Lei n. 7.347/85), (qualificação completa: sede e domicílio no endereço e CNPJ/MF), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei n. 7.347/85, impetrar AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR em face da EMPRESA (qualificação completa), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

[Breve resumo dos fatos apresentados]

II – DO DIREITO

Artigo _____

Fato _____ [Demonstrar no caso concreto a lesão aos bens protegidos pela Lei n. 7.347/85, meio ambiente, consumidor, entre outros – art. 1.º]

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DA LIMINAR

O art. 12 da Lei da Ação Civil Pública prevê que o juiz poderá conceder mandado liminar com ou sem justificção prévia. [Se a ação civil pública tiver por fundamento a defesa do consumidor, a previsão legal está no art. 84, § 3.º, do Código de Defesa de Consumidor.]

[Deve-se demonstrar expressamente o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.]

[Cumpre observar que se no polo passivo da demanda estiver uma pessoa jurídica de direito público deve-se observar o disposto no art. 2.º da Lei n. 8.437/92 – “No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.”]

IV – DO PEDIDO

Posto isso, o impetrante requer a Vossa Excelência:

a) a citação do impetrado, na pessoa de seu representante legal, para responder, sob pena de revelia aos termos da presente ação, bem como para se manifestar sobre o pedido de liminar no prazo de 72 (setenta e duas) horas (art. 2.º da Lei n. 8.437/92 – se for contra ato do Poder Público);

b) a concessão de medida liminar para que se suspendam [descrever o ato lesivo que se pretende suspender – art. 12 da Lei n. 7.347/85];

c) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer (art. 5.º, § 1.º, da Lei n. 7.347/85);

d) ao final seja o pedido julgado procedente, tornando definitiva a liminar concedida, e condenando-se o impetrado a (pagar ou devolver dinheiro; fazer ou não fazer, especificar de acordo com o art. 3.º da Lei n. 7.347/85);

e) a condenação do impetrado ao pagamento de custas e honorários de advogado.

V – DAS PROVAS

Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Valor da causa: R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Súmula 329 do STJ: "O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público".

Petições e recursos processuais

3.1. PETIÇÃO INICIAL

3.1.1. Modelo esquemático de petição inicial – rito ordinário

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DA COMARCA DE _____

(espaço de cinco linhas)

(NOME DO AUTOR), nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Regis'tro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob n. _____, residente e domiciliado no endereço _____, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 319 e s. do Código de Processo Civil e a Lei ____/ano, propor a presente AÇÃO _____ [Indenizatória, anulatória, declaratória etc.] em face de (NOME DO RÉU), qualificação completa, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DOS FATOS

[Breve relato dos fatos, utilizar os dados fornecidos pelo enunciado.]

II – DO DIREITO

Artigo _____

Fato _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DO CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA

[Se for o caso e o enunciado indicar a urgência]

O art. 294 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência (art. 300 e s.) ou evidência (art. 311)

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que Vossa Excelência:

a) conceda a tutela provisória, nos termos do Código de Processo Civil, para _____ [Especificar urgência (art. 300 e s.) ou evidência (art. 311)];

b) ordene a citação do réu, no endereço indicado, por oficial de justiça (art. 247, V, do Código de Processo Civil, com os benefícios do art. 212, § 2.º, do Código de Processo Civil), para que, querendo, possa apresentar defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia;

c) julgue totalmente procedente o pedido _____ [Especificar: condenando, revisando, anulando etc.]

d) condene o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos arts. 82, § 2.º, 84 e 85 do Código de

Processo Civil.

Protesta provar o alegado, por todos os meios em direito admitidos, em especial [se o enunciado permitir, especificar: prova testemunhal, pericial, documental etc. – art. 369 e s. do CPC/2015].

Valor da causa

Dá-se à causa o valor de R\$ _____ [Valor por extenso, correspondente ao proveito econômico – ler arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil].

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Quando o autor não tiver condições de suportar as custas processuais, requerer os benefícios da Lei n. 1.060/50 (Observação: ler art. 1.072, III, do CPC/2015, pois foram revogados os arts. 2.º a 4.º, 6.º, 7.º, 11, 12 e 17 da Lei n. 1.060/50). Neste caso, não esquecer a juntada do correspondente “atestado de pobreza”. Vide também termos da Lei n. 9.265/96 e art. 5.º, LXXVII, da Constituição Federal de 1988.

3.2. CONTESTAÇÃO

3.2.1. Modelo esquemático de contestação

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DA COMARCA DE _____ [Indicar a vara e a comarca da ação principal]

(espaço de cinco linhas)

Rito ordinário

Autos do processo n. _____

(NOME DO RÉU), já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, dentro do prazo legal previsto no art. 335 e nos termos do art. 336 e s. todos do Código de Processo Civil, oferecer a presente CONTESTAÇÃO à ação (especificar o nome da ação que o enunciado deve indicar) que lhe move [NOME DO AUTOR], já qualificado, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DOS FATOS

[Breve relato dos fatos alegados pelo Autor na Ação já proposta e a versão do réu]

II – DO DIREITO

Dividir o item “Do Direito”: [se for o caso]

1) Preliminares processuais (arts. 485 e 337 do Código de Processo Civil)

2) Do mérito, [desenvolver:]

Artigo _____

Fato _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o autor a Vossa Excelência:

a) acolher a preliminar arguida, julgando extinto, sem apreciação do mérito, o presente processo, nos termos do art. 485, inciso _____ (especificar) do Código de Processo Civil;

b) se afastada a preliminar, julgue improcedente os pedidos formulados pelo Autor, por não existir o direito alegado [Se tiver pedido alternativo, indique: subsidiariamente, em caso de procedência do pedido principal, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, seja: especificar de acordo com o enunciado, por exemplo, diminuindo o valor pedido];

c) condene o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Protesta provar o alegado, por todos os meios em direito admitidos, em especial (se o enunciado permitir especificar: prova testemunhal, pericial, documental etc.).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Cumprir observar que o Réu, também, dependendo de sua condição econômica, pode pleitear os benefícios da justiça gratuita (Lei n. 1.060/50 – Observação: ler art. 1.072, III, do CPC/2015,

pois foram revogados os arts. 2.º a 4.º, 6.º, 7.º, 11, 12 e 17 da Lei n. 1.060/50).

3.3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

3.3.1. Modelo esquemático de embargos de declaração

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR _____
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE _____ [vai depender da
autoridade que proferiu a decisão – Juiz ou Relator]

(espaço de cinco linhas)

Epígrafe _____

Autos da ação _____

Legitimidade ativa

(NOME DO EMBARGANTE), já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 1.022 e s. do Código de Processo Civil, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão (ou sentença a depender do caso) de fls. _____, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

[Breve resumo dos fatos]

II – DO DIREITO

[Fundamentação jurídica]

[Esclarecer qual foi o resultado do julgamento ou da decisão, se procedente ou improcedente]

Demonstrar, conforme o caso:

- 1) a obscuridade existente na decisão judicial;
- 2) a contradição existente entre o que foi decidido e o que foi requerido;
- 3) o ponto ou questão sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador e sua omissão na decisão;
- 4) o erro material objeto da decisão ou julgamento;
- 5) fazer o prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou recurso especial (dependendo do caso)

III – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer o Embargante que sejam acolhidos estes embargos, a fim de que seja sanada a obscuridade/contradição/omissão/erro material (a depender do caso) apontada, com a consequente _____ [Especificar o pedido].

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

- Vale a pena diferenciar a utilização dos seguintes termos:

a) propor: ação;

b) interpor: recurso (exceto embargos de declaração);

c) opor: embargos de declaração/exceção;

d) impetrar: mandado de segurança, habeas corpus, entre outros.

- Súmula 98 do STJ: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório”.
- O recurso de embargos de declaração é isento de preparo (art. 1.023, caput, do CPC/2015).

3.4. AGRAVO DE INSTRUMENTO

3.4.1. Minuta de agravo de instrumento

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO _____

(espaço de cinco linhas)

(NOME DO AGRAVANTE), qualificação, autor/réu nos autos da ação de rito ordinário, em trâmite perante a _____ Vara _____, promovida em face da Fazenda Pública do Estado _____, vem respeitosa e tempestivamente, por seu advogado, nos termos dos arts. 1.015 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, interpor RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, pelas seguintes razões.

I – BREVE RELATO

[Descrever o problema e a decisão interlocutória]

II – DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O magistrado de primeira instância, ao apreciar o pedido de liminar em mandado de segurança formulado pelo autor, ora agravante, a indeferiu sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos

do art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009.

A liminar pleiteada tinha como objetivo garantir ao agravante o direito de realizar um transplante de órgãos na rede pública.

Assim, a situação exige provimento jurisdicional de urgência, justificando o agravo na forma de instrumento, isso conforme estabelece a exceção do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

[Tese jurídica]

IV – DO CABIMENTO DO EFEITO _____

[A esse respeito, o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, autoriza ao relator conceder tutela antecipada recursal].

Para tanto, o art. 995, parágrafo único, do mesmo Código impõe como requisitos para a liminar no agravo a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No presente caso _____ [especificar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso.]

Inferre-se, portanto, presentes os requisitos para a concessão do efeito _____

V – DO REQUERIMENTO E INFORMAÇÕES

Por todo o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão agravada para _____

Requer, ainda, a concessão do efeito _____

Por oportuno, informa o agravante que, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo será instruído com as seguintes cópias: [Vide art. 1.017 do Código de Processo Civil]

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____.

Informa, também, que estão constituídos nos autos os seguintes advogados: a) pela agravante _____ [Nome e endereço do Advogado]; b) pela agravada _____ (nome e endereço do Advogado), nos termos do art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a intimação da parte contrária para responder no prazo legal (art. 1.019, II, do Código de Processo Civil).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data

Advogado/OAB

ATENÇÃO

- 1) Quando o recorrente não for beneficiário da Lei n. 1.060/50, será necessário mencionar a juntada das respectivas custas de preparo. Além disso, pode ser informado o previsto no art. 1.018 do Código de Processo Civil.
- 2) Ouvir o Ministério Público quando for o caso. Exemplo: mandado de segurança (art. 1.019, III, do Código de Processo Civil).

3.4.2. Petição de comprovante de interposição de recurso de agravo de instrumento: art. 1.018 do Código de Processo Civil

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA _____ VARA CÍVEL DA
COMARCA DE _____

(espaço de cinco linhas)

Processo _____

Rito _____

AUTOR _____, por seu advogado que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe que move em face de Réu _____, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar, no tríduo legal, que interpôs RECURSO DE AGRAVO, na forma de Instrumento, conforme comprovação em anexo.

Outrossim, informa que o aludido Recurso foi instruído com as peças obrigatórias, conforme disposto no art. 1.017, do Código de Processo Civil, além dos documentos a seguir arrolados:

- a)
- b)
- (...).

Desta feita, estando cumprida a disposição do art. 1.018 do Código de Processo Civil, requer a Vossa Excelência, em querendo, se retrate da decisão agravada.

Termos em que,
pede deferimento.

Local, data

Advogado – OAB

3.5. APELAÇÃO

3.5.1. Modelo esquemático de apelação

a) Peça de interposição

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE _____ [Juízo a quo – sentenciante – especificar vara e comarca]

(espaço de cinco linhas)

Processo autuado sob n. _____

(NOME DO APELANTE), já qualificado nos autos da AÇÃO _____, de RITO ORDINÁRIO, de número em epígrafe, que move em face de (NOME DO APELADO), vem respeitosa e tempestivamente, por seu advogado, interpor RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do art. 1.009 e s. do Código de Processo Civil, cujas razões e guia comprobatória de preparo seguem acostadas.

Por oportuno, requer que o recurso seja recebido em seus regulares efeitos e após a intimação da parte contrária para contrarrazões, sejam remetidos os autos ao Tribunal.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

b) Razões de apelo

[Peça que segue à interposição]

RAZÕES DE APELAÇÃO

Apelante: _____

Apelado: _____

Origem: _____ [Dados da 1.^a instância]

Egrégio Tribunal

Ilustres Desembargadores

I – BREVE RELATO

[Narrativa do problema]

No entanto, como será demonstrado a seguir, a sentença merece ser reformada.

II – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

Artigo _____

Fato lesivo _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

[Tese jurídica]

III – DO REQUERIMENTO

Por todo o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal seja o presente recurso de apelação conhecido e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento, no sentido de reformar a sentença para _____ [conhecimento e provimento]

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB (endereço comercial)

ATENÇÃO

Pode ser requerida a inversão do ônus da sucumbência com a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82, § 2.º, 84 e 85 do Código de Processo Civil.

3.6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

3.6.1. Modelo esquemático de recurso extraordinário

a) Peça de interposição

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA _____ REGIÃO
[Recurso será endereçado ao presidente do Tribunal que apreciou a
apelação, portanto pode ser endereçado ao Presidente do Tribunal de
Justiça]

(espaço de cinco linhas)

Dados da ação: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

(NOME DO RECORRENTE), qualificado nos autos, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, III, alínea _____ (deverá indicar a alínea correspondente ao caso concreto quando for realizar a prova) da Constituição Federal e art. 1.029 e s. do Código de Processo Civil, interpor RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face do respeitável acórdão proferido nas fls. _____, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da ação em epígrafe, em face do RECORRIDO (qualificado nos autos).

Requer seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após, seja o recurso admitido e encaminhado com as inclusas razões ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

b) Razões de recurso extraordinário

Dados da ação: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

Colenda Turma,
Ínclitos Julgadores,

(Nome do recorrente), não se conformando com o respeitável acórdão de fls. _____, vem, respeitosamente, apresentar as razões do presente recurso extraordinário.

I – BREVE RESUMO

[Descrever o caso apresentado]

II – PRELIMINARMENTE – DA REPERCUSSÃO GERAL

[Demonstrar que há repercussão geral (art. 1.035 do Código de Processo Civil) e o recurso merece ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal]

III – DO CABIMENTO DO RECURSO

[Descrever a violação da norma constitucional, enquadrando-a em uma das hipóteses do art. 102, III, alínea _____ da Constituição Federal. Destacar a tempestividade do recurso nos termos do art. 1.003, § 5.º, do Código de Processo Civil].

IV – DO PREQUESTIONAMENTO

[Salientar que a matéria foi devidamente questionada na instância inferior, esgotando todas as instâncias para o exame da instância superior]

V – DO DIREITO

[Mérito do recurso]

Artigo _____

Fato _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

VI – DO PEDIDO

Diante do exposto, o recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se (ou anulando-se) a respeitável decisão recorrida de fls. _____ [complementar com a especificação do pedido].

Inversão do ônus da sucumbência, condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82, § 2.º, 84 e 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a notificação do Ministério Público.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Súmula 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”.

3.7. RECURSO ESPECIAL

3.7.1. Modelo esquemático de recurso especial

a) Peça de interposição

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE _____ [Recurso será endereçado ao presidente do Tribunal que apreciou a apelação, portanto pode ser endereçado ao Presidente do Tribunal Regional Federal de certa Região]

(espaço de cinco linhas)

Dados da ação: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

(NOME DO RECORRENTE) qualificado nos autos, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, III, alínea _____ (deverá indicar a alínea correspondente ao caso concreto quando for realizar a prova) da Constituição Federal e art. 1.029 e s. do Código de Processo Civil, interpor o presente RECURSO ESPECIAL contra o respeitável acórdão proferido nas fls. _____, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da ação em epígrafe, em face do RECORRIDO qualificado nos autos.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após seja o recurso admitido e encaminhado com as inclusas razões ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Termos em que,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

b) Razões de recurso especial

Dados da ação: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

Superior Tribunal de Justiça,

Colenda Turma,

Ínclitos Julgadores,

(Nome do recorrente), não se conformando com o respeitável acórdão de fls. _____, vem, respeitosamente, apresentar as razões do presente recurso especial.

I – BREVE RESUMO

[Descrever o caso apresentado]

II – DO CABIMENTO DO RECURSO

[Descrever a violação da norma federal (o recurso deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988) e salientar que a matéria foi devidamente questionada (existência de prequestionamento, pode ser feito em item próprio) na instância inferior, esgotando todas as instâncias para o exame da instância superior e que merece ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Destacar a tempestividade do recurso nos termos do art. 1.003,

§ 5.º, do Código de Processo Civil.]

III – DO DIREITO

[Mérito do recurso]

Artigo _____

Fato _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

IV – DO PEDIDO

Diante do exposto, o recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso especial, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, com a reforma (anulação) da respeitável decisão recorrida, (complementar com a especificação do pedido), como medida de inteira justiça.

Inversão do ônus da sucumbência, condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82, § 2.º, 84 e 85 do Código de Processo Civil.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

3.8. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – ROC

3.8.1. Modelo esquemático de recurso ordinário em **habeas**

corpus

a) Peça de interposição

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE _____ [Recurso será
endereçado ao presidente do Tribunal que apreciou o Habeas Corpus]

(espaço de cinco linhas)

Dados da ação: _____

Recorrente: _____

Recorrido: _____

(Nome do recorrente), já qualificado nos autos, por seu advogado que esta subscreve, não se conformando com a respeitável decisão denegatória do habeas corpus em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988, na Lei n. 8.038/90 e arts. 1.027 e 1.028 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL em face de (NOME DO RECORRIDO), já qualificado, pelas razões de fato e de direito apresentadas na minuta em anexo.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após seja o recurso encaminhado com as inclusas razões ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Termos em que,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

b) Razões de recurso ordinário constitucional

Dados da ação:

Recorrente:

Recorrido:

Superior Tribunal de Justiça,

Colenda Turma,

Ínclitos Julgadores,

(Nome do recorrente), não se conformando com o respeitável acórdão de fls. _____, vem, respeitosamente, apresentar as razões do presente recurso ordinário constitucional.

I – BREVE RESUMO

[Descrever o caso apresentado]

II – DO DIREITO

Artigo _____

Fato _____

Doutrina _____

Jurisprudência _____

Conclusão _____

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, o Recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se (ou anulando-se) a respeitável decisão recorrida de fls. _____, (complementar com a especificação do pedido), concedendo-se a _____ (suspensão condicional da pena, entre outros) expedindo-se o alvará de soltura em favor do recorrente.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

3.9. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

3.9.1. Modelo esquemático de embargos de divergência

[Endereçamento]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR _____ DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [Ou Superior Tribunal de Justiça]

(espaço de cinco linhas)

Epígrafe _____

Autos do processo n. _____

Legitimidade ativa _____

(NOME DO EMBARGANTE) qualificado nos autos, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 1.043 e 1.044 do Código de

Processo Civil, interpor EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA em virtude do venerando acórdão de fls. _____, nos autos do processo em epígrafe, que move em face de (NOME DO EMBARGADO), já qualificado, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DOS FATOS

[Breve resumo dos fatos, especificar o trecho do venerando acórdão em que se demonstrará a divergência, se possível, fazer a transcrição]

II – DO DIREITO

[Fundamentação jurídica]

[Demonstrar o cabimento dos Embargos: arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil e sua tempestividade – art. 1.003, § 5.º, do Código de Processo Civil). Deve-se indicar que há entendimento em outra Turma do Tribunal (STF) que diverge o apresentado no venerando acórdão embargado, se possível transcrever essa parte para ser o confronto]

Não obstante, sobre a matéria discutida no presente recurso, o entendimento da _____ Turma deste Colendo STF, diverge daquele apresentado no venerando acórdão ora embargado:

“_____ [Transcrever o acórdão ou parte dele que seja divergente da decisão que ora se ataca].”

Conclusão _____

III – DO PEDIDO

[Do pedido]

Posto isso, requer seja conhecido e provido o presente recurso, alterando-se a decisão recorrida, adotando-se o entendimento da

_____ Turma deste Egrégio Tribunal, para _____ [Especificar o pedido e a finalidade da alteração do acórdão].

Nesses termos,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

3.10. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

3.10.1. Modelo esquemático de reclamação no Supremo Tribunal Federal

[Endereçamento]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

[Legitimidade ativa]

(NOME DO RECLAMANTE), (qualificação completa: nacionalidade, profissão, estado civil, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob n. _____, residente e domiciliado no endereço _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77,

V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, I, I, da Constituição Federal de 1988, arts. _____ do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e arts. 319 e s. e 988 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL em face _____ [Legitimidade passiva: indicar a autoridade reclamada a quem é imputada a prática do ato impugnado], [especificar o ato que não preservou a competência e/ou autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal], consoante os motivos e fatos a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

[Breve resumo dos fatos]

II – DO DIREITO

[Demonstrar o cabimento da reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões, destacando que a petição inicial da reclamação é instruída com prova documental que confirma os fatos e o direito alegados (art. 988 do CPC/2015). Nos termos do art. 989, II, do CPC/2015, é cabível o pedido de liminar na Reclamação. Se for o caso de ter fumus boni iuris e periculum in mora, fazer um item “Da Liminar”. No item “Do Pedido”, deverá, então, ser pedida a concessão da liminar]

III – DO PEDIDO

Em face do exposto, pleiteia o reclamante:

a) que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de dez dias, como de direito, bem como a intimação do Ministério Público para oferecer parecer.

b) julgue procedente a reclamação, cassando a decisão [especificar

de acordo com o caso concreto] exorbitante de seu julgado e/ou determine a medida adequada à preservação de sua competência (o pedido dependerá do caso concreto) – art. 992 do CPC/2015.

Valor da causa: R\$ _____

Termos em que.

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

3.11. PARECER

3.11.1. Modelo esquemático de parecer

Parecer n. _____

Interessado: _____ [Quem requereu o parecer]

Assunto: _____ [Solicitação de parecer sobre a possibilidade de _____]

Ementa: _____ [Item opcional – deve caminhar do ponto mais geral para o mais específico, por exemplo:

Controle de constitucionalidade – Legitimidade Ativa – Autores especiais – Governador de Estado – Pertinência temática]

I – RELATÓRIO

[No relatório é preciso indicar a pessoa que solicitou o parecer, o tema a ser desenvolvido, um breve resumo dos fatos e as questões formuladas]

[Sugestão de redação:

(Nome da pessoa que solicitou o parecer) solicita a elaboração de

parecer jurídico sobre (tema a ser desenvolvido), descrevendo os fatos como segue: (breve resumo dos fatos de acordo com o enunciado proposto)

Expostos os fatos, foram formulados os seguintes quesitos:

(apontar as questões formuladas, se for o caso).

É o relatório.]

II – FUNDAMENTAÇÃO

[Desenvolver o raciocínio e a tese: abordar os aspectos possíveis sobre o tema. Deve-se fundamentar com legislação e jurisprudência. Raciocínio: premissa maior, premissa menor e conclusão.]

III – CONCLUSÃO

[Responder de forma objetiva e direta às questões, se houver]

[Elabore um parágrafo final]

Ante o exposto, concluímos que _____ [Conclusão do parecer]

É o parecer.

Local/data.

Advogado/OAB

Pecas práticas das provas do Exame da OAB

4.1. (OAB CESPE 2006.1) A lei estadual que organiza a Polícia Militar do Espírito Santo (PM/ES) exige, como requisito para aprovação no respectivo concurso público, a aprovação em exame médico, realizado por junta médica, com o objetivo de avaliar as condições de saúde dos candidatos e selecionar os candidatos aptos ao exercício das funções policiais.

Para regulamentar essa lei, o Comando Geral da PM-ES editou a Portaria n. 71/99, em que se definem critérios para a realização do exame. Entre esses critérios, há uma série de causas de incapacitação, como patologias ortopédicas, doenças do aparelho digestivo e alterações dermatológicas, que, se apresentadas pelo candidato, causam automaticamente sua eliminação. As alterações dermatológicas causadoras de inaptidão são hanseníase, dermatites crônicas, afecções dermatológicas crônicas com comprometimento estético e tatuagens definitivas.

Com base nessa legislação, a junta médica do concurso público para provimento do cargo de soldado da PM-ES declarou um dos candidatos, Augusto, inapto a exercer as funções policiais, devido à existência de uma tatuagem de um ideograma japonês, que significa harmonia, em seu ombro esquerdo, apesar de ele ter sido aprovado nas provas de conhecimentos. Essa reprovação no exame médico impede que Augusto participe do teste físico, a ser realizado em Vitória – ES.

Considerando a situação hipotética descrita acima, redija uma peça processual adequada para garantir os interesses de Augusto mediante a realização de controle judicial de constitucionalidade.

4.2. (OAB CESPE 2006.2) O Município de Guarapari – ES editou a Lei n. 555/2006, que veda a instalação de novas farmácias a menos de 200 metros de estabelecimento da mesma natureza, sob os argumentos de que o Município é competente para estabelecer o zoneamento das atividades produtivas e de que era necessário impedir a concorrência predatória que vinha ocorrendo na cidade.

Essa lei entrou em vigor no mesmo dia em que a Farmácias Mil Ltda. solicitou ao Município a expedição de alvará autorizando o funcionamento de uma farmácia a 50 metros de um estabelecimento gerido por uma empresa concorrente.

O Secretário de Administração do Município indeferiu a solicitação do alvará, sob o argumento de que seria ilegal a autorização do funcionamento do referido estabelecimento, por violação da Lei n. 555/2006.

Com base nessa situação hipotética, elabore peça judicial que impugne, com base em argumentos de índole constitucional, a validade do ato administrativo que indeferiu a solicitação de expedição do mencionado alvará.

4.3. (OAB CESPE 2006.3) João Lima ingressou com ação contra a Caixa Econômica Federal no Juizado Especial Federal, pleiteando a correção dos depósitos do seu fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), em decorrência dos expurgos inflacionários dos planos Collor e Verão I.

Julgada improcedente a ação, João recorreu à Turma Recursal, sustentando, entre outras razões, precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecendo esse direito. No entanto, o recurso foi desprovido, contrariando decisões do STF, apesar de ter sido prequestionada a matéria constitucional invocada. Dessa forma, João interpôs recurso extraordinário, fundado na violação a dispositivo da Constituição, que, contudo, não foi admitido. Interposto agravo de instrumento, O presidente da Turma Recursal negou-lhe seguimento, tendo como fundamento o descabimento

do recurso extraordinário nos Juizados Especiais.

Diante dessa situação hipotética, como advogado de João Lima, proponha a medida judicial que entender cabível, para se preservar a competência do STF e se viabilizar o trânsito do agravo dirigido a esse tribunal, contra a inadmissão do recurso extraordinário.

4.4. (OAB CESPE 2007.1) Maria adquiriu um veículo popular por meio de contrato de arrendamento mercantil (leasing), em 60 prestações de R\$ 800,00. A partir da 24.^a prestação, Maria começou a ter dificuldades financeiras e resolveu vender o veículo a Pedro, o qual se comprometeu a pagar as prestações vincendas e vencidas. Tal fato não foi comunicado ao agente financeiro, já que havia o risco de o valor da prestação ser majorado.

Pedro deixou de pagar mais de cinco prestações, o que suscitaria rescisão contratual. O agente financeiro houve por bem propor ação de busca e apreensão do veículo, tentativa essa que restou frustrada em face de Maria não possuir o veículo em seu poder, já que o alienara a Pedro.

O agente financeiro pediu a transformação, nos mesmos autos, da ação de busca e apreensão em ação de depósito e requereu a prisão de Maria, por ser depositária infiel do referido veículo. O juiz competente determinou a prisão civil de Maria até que ela devolvesse o referido veículo ou pagasse as prestações em atraso. Maria não tem mais o veículo em seu poder e perdeu o seu emprego em virtude da prisão civil.

Dois dias depois da efetivação da prisão, o advogado contratado interpôs, inicialmente, recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão judicial, o qual não foi conhecido pelo tribunal, diante da ausência de documento imprescindível ao seu processamento. Ingressou com ação de rito ordinária contra Pedro, com pedido de tutela antecipada, visando receber as prestações em atraso, ação essa que foi extinta sem julgamento de mérito. Ingressou, ainda, com ação de rito ordinário contra o arrendador

discutindo algumas cláusulas do contrato de arrendamento, ação essa que continua em curso, sem sentença.

Maria continua presa. Por ter perdido a confiança nesse advogado, ao qual pagou os honorários devidos e do qual recebeu o devido substabelecimento, sem reservas de poderes, Maria resolveu contratar os serviços de outro advogado.

Diante da situação hipotética apresentada, na condição de atual advogado de Maria, redija um texto que contenha a peça judicial mais apropriada ao caso, a ser apresentada ao órgão judicial competente, com os argumentos que reputar pertinentes.

4.5. (OAB CESPE 2007.2) O Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado X, órgão judicial com atribuições disciplinares, emitiu o Provimento Y, datado de 6 de junho de 2007 e publicado nessa data, determinando, em seu art. 3.º, que os advogados “serão atendidos, nos ofícios de Justiça de primeira instância e nos cartórios de segunda instância, a partir das 10 horas”, reservando-se o intervalo das 9 às 10 horas “ao expediente interno das unidades cartorárias.”

O presidente da Seção da OAB do Estado X pretende impugnar o referido provimento, sob o argumento de que estaria sendo violado o art. 7.º, VI, c, da Lei n. 8.906/94, que permite ao advogado “ingressar livremente (...) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial (...), dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado.”

Requerida administrativamente a revogação do art. 3.º do Provimento Y, o presidente do Conselho, que é também presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, defendeu a legalidade do ato, já que este estaria apoiado no regimento interno do tribunal, elaborado de acordo com o inciso I do art. 96 da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece a competência do Conselho de Magistratura do referido tribunal para disciplinar os serviços

internos do Tribunal de Justiça, em nome do Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a assessoria jurídica da seção da OAB do Estado X entendeu pela inviabilidade da impetração de vários mandados de segurança individuais para cada advogado daquela seção. Sustentou ainda pela inviabilidade da via do mandado de segurança individual, já que isso representaria uma impetração contra a lei em tese. Por outro lado, destacou que o regimento interno do respectivo tribunal atribui a competência do Conselho Especial para julgar mandados de segurança, habeas data e habeas corpus contra ato de membro ou órgão do Tribunal de Justiça.

A presidência da Seção da OAB do Estado X, concordando em parte com os argumentos de sua assessoria jurídica, requereu ao advogado da instituição que preparasse a ação judicial cabível a espécie, na defesa dos advogados inscritos naquela seção.

Na qualidade de advogado da seção da OAB do Estado X, redija a peça jurídica mais adequada ao caso em tela, com os argumentos que entender cabíveis, em especial os argumentos da assessoria jurídica e do presidente do conselho, atentando, ainda, para os seguintes pontos:

1. Competência do órgão julgador;
2. Legitimidade ativa e passiva;
3. Argumentos em prol da ilegalidade do Provimento Y;
4. Outros requisitos formais da peça judicial proposta.

4.6. (OAB CESPE 2007.3) Um contingente de servidores públicos do Município A, inconformado com a política salarial adotada pelo governo municipal, decidiu, após ter realizado paralisação grevista sem qualquer sucesso, tomar providências para fazer valer um suposto direito a reajuste de 15% sobre o vencimento básico percebido. O referido valor corresponderia a um aumento remuneratório real, equiparando ao reajuste obtido, nos últimos três anos, por diversas classes profissionais.

Os servidores públicos procuraram a entidade sindical correspondente e esta decidiu ajuizar, na Justiça Comum, ação ordinária a fim de satisfazer o pleito apresentado. Dada a premência do tempo em ver reconhecido, pelo Judiciário, o reajuste de 15%, a entidade sindical formulou, na própria petição inicial, pedido de antecipação de tutela, sob a alegação de que, na situação, estavam em jogo verbas de caráter nitidamente alimentar, o que reforçaria a necessidade de um provimento judicial mais célere.

Ao fazer uma primeira análise, o juiz do feito decidiu indeferir o pedido de tutela antecipada.

Após pedido de reconsideração formulado pela entidade sindical, o juiz decidiu reverter seu primeiro posicionamento e optou por deferir o pedido de tutela antecipada, determinando a imediata implementação em folha de pagamento do reajuste de 15% sobre o vencimento básico dos servidores públicos.

Inconformado com a decisão judicial, o município decidiu contratar serviços advocatícios para promover as medidas cabíveis e reverter a situação o quanto antes, em virtude do iminente impacto orçamentário do reajuste concedido. O advogado tentou, por todos os modos possíveis, suspender a decisão que concedeu a tutela antecipada no Tribunal de Justiça competente, sem ter obtido êxito. A antecipação de tutela continua mantida, em toda sua extensão, e o mérito da ação ainda não foi apreciado.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-MC 4, assim decidiu: “Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos, para se suspender, ex nunc, e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, sustando-se, igualmente ex nunc, os efeitos futuros das decisões já proferidas, nesse sentido”.

Diante da situação hipotética apresentada, na condição de advogado do Município A, redija a peça judicial apropriada para o caso, a ser apresentada ao órgão judicial competente, com os argumentos que reputar pertinentes.

4.7. (OAB CESPE 2008.1) O Presidente da República apresenta ao Congresso Nacional proposição legislativa que trata de criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem de territórios federais. O trâmite da proposição tem início na Câmara dos Deputados. Após análise nas comissões específicas, que não veem vício de qualquer natureza na proposição legislativa, esta segue para votação em plenário. Durante uma sessão tumultuada, com a ausência de 213 deputados federais e sob protesto da bancada oposicionista presente, a proposição é votada com o seguinte resultado: 197 votos favoráveis, 95 votos contrários e 8 abstenções. A proposição é, então, dada por aprovada em 31 de março de 2008, e encaminhada para análise e deliberação do Senado Federal. Ainda quando em trâmite no Senado Federal, um deputado federal que não esteve presente no momento da votação procura os serviços de um advogado, alegando que tem dúvidas sobre o trâmite regular da proposição legislativa na Câmara dos Deputados. Informa, ainda, que há previsão de a proposição legislativa ser votada no Senado Federal em um prazo de sete dias.

Em face da situação hipotética apresentada, na qualidade de advogado(a) do deputado federal, redija a peça jurídica mais adequada ao caso, levando em conta que a citada proposição legislativa ainda se encontra em trâmite no Senado Federal e atentando aos seguintes aspectos:

- competência do órgão julgador;
- legitimidade ativa e passiva;
- argumentos de mérito;
- requisitos formais da peça judicial proposta.

4.8. (OAB CESPE 2008.2) O governo brasileiro, preocupado com os índices crescentes de ataques terroristas no mundo, vinculou-se à Convenção sobre os Direitos Humanos das Vítimas de Atividades Terroristas, convenção internacional, de âmbito multilateral, que estabelece restrições aos direitos dos presos condenados por crimes resultantes de atividades terroristas. O Presidente da República assinou o Tratado e a enviou ao Congresso Nacional, conforme disposição do art. 49, I, da Constituição Federal e, não, de acordo com o § 3.º do art. 5.º dessa Carta, e, em poucos meses, o Congresso Nacional aprovou o texto do Tratado na forma de decreto legislativo. Após isso, o Presidente da República editou decreto promulgando e ratificando o Tratado.

Já estando internamente em vigor o referido decreto, percebeu-se que vários juízes, em todo o território nacional, aplicavam plenamente o art. 22 do Tratado, no qual se lê: “as presas condenadas por crimes resultantes de atividades de terrorismo, logo após darem à luz, deverão deixar seus filhos sob a responsabilidade de entidade pública de assistência social até que cumpram integralmente a pena”.

Visando a impossibilitar, de algum modo, a aplicação do referido artigo, sob o argumento de sua inconstitucionalidade, o Presidente de um partido político com representação no Congresso Nacional procurou, em nome do partido, os serviços advocatícios de um(a) profissional, pretendendo uma solução urgente e uniforme para o caso, de modo que, com apenas uma ação, seja alcançado efeito para todos os indivíduos no território brasileiro.

Na qualidade de advogado(a) contratado(a) pelo partido político mencionado nessa situação hipotética, redija a peça jurídica mais adequada ao caso, de acordo com a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos:

- competência do órgão julgador;
- legitimidade ativa e passiva;

- possibilidade de contestação judicial da constitucionalidade do referido tratado;
- argumentos a favor da inconstitucionalidade do mencionado art. 22;
- requisitos formais da peça judicial proposta.

4.9. (OAB CESPE 2008.3) Joana Augusta laborou, durante vinte e seis anos, como enfermeira do quadro do hospital universitário ligado a determinada universidade federal, mantendo, no desempenho de suas tarefas, em grande parte de sua carga horária de trabalho, contato com agentes nocivos causadores de moléstias humanas bem como com materiais e objetos contaminados.

Em conversa com um colega, Joana obteve a informação de que, em razão das atividades que ela desempenhava, poderia requerer aposentadoria especial, com base no § 4.º do art. 40 da Constituição Federal, de 1988.

A enfermeira, então, requereu administrativamente sua aposentadoria especial, invocando como fundamento de seu direito o referido dispositivo constitucional.

No dia 30 de novembro de 2008, Joana recebeu notificação de que seu pedido havia sido indeferido, tendo a Administração Pública justificado o indeferimento com base na ausência de lei que regulamente a contagem diferenciada do tempo de serviço dos servidores públicos para fins de aposentadoria especial, ou seja, sem uma lei que estabeleça os critérios para a contagem do tempo de serviço em atividades que possam ser prejudiciais à saúde dos servidores públicos, a aposentadoria especial não poderia ser concedida. Nessa linha de entendimento, Joana deveria continuar em atividade até que completasse o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de serviço.

Inconformada, Joana procurou escritório de advocacia, objetivando ingressar com ação para obter sua aposentadoria especial.

Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a)

contratado(a) por Joana, redija a petição inicial da ação cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos:

- competência do órgão julgador;
- legitimidade ativa e passiva;
- argumentos de mérito;
- requisitos formais da peça judicial proposta.

4.10. (OAB CESPE 2009.1) Na Assembleia Legislativa de determinado Estado da Federação, um terço dos seus parlamentares subscreveu documento, requerendo abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar, por prazo certo, determinado fato. Os líderes dos partidos da base do governo, visando impedir a instauração da comissão, firmaram acordo no sentido de que nenhum partido indicasse o respectivo representante para integrar a referida CPI. Instalado o impasse, a mesa diretora da Casa, por seu presidente, entendeu que a criação da CPI deveria ser submetida à deliberação do plenário, arguindo falta de previsão regimental para regular a espécie. Levada a matéria ao plenário, a maioria da Casa opôs-se à criação da CPI. Após a decisão proferida pelo presidente, o deputado estadual Antônio, um dos parlamentares que solicitaram a criação da CPI, não se conformou com a situação.

Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a) constituído(a) pelo parlamentar inconformado, redija a medida judicial cabível, apresentando toda a argumentação que entender pertinente.

4.11. (OAB CESPE 2009.2) João, nascido e domiciliado em Florianópolis – SC, indignou-se ao saber, em abril de 2009, por meio da imprensa, que o senador que merecera seu voto nas últimas eleições havia determinado a reforma total de seu gabinete, orçada em mais de R\$ 1.000.000,00, a qual seria custeada pelo Senado Federal. A referida reforma incluía aquecimento

e resfriamento com controle individualizado para o ambiente e instalação de ambiente físico para projeção de filmes em DVD, melhorias que João considera suntuosas, incompatíveis com a realidade brasileira. O senador declarara, em entrevistas, que os gastos com a reforma seriam necessários para a manutenção da representação adequada ao cargo que exerce.

Tendo tomado conhecimento de que o processo de licitação já se encerrara e que a obra não havia sido iniciada, João, temendo que nenhum ente público tomasse qualquer atitude para impedir o início da referida reforma, dirigiu-se a uma delegacia de Polícia Civil, onde foi orientado a que procurasse a Polícia Federal. Supondo tratar-se de um “jogo de empurra-empurra”, João preferiu procurar ajuda de profissional da advocacia para aconselhar-se a respeito da providência legal que poderia ser tomada no caso.

Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a) constituído(a) por João, redija a medida judicial mais apropriada para impedir que a reforma do gabinete do referido Senador da República onere os cofres públicos.

4.12. (OAB CESPE 2009.3) A empresa pública Água Para Todos, criada para a produção dos materiais e a prestação dos serviços pertinentes à instalação de rede hidráulica no Município X, é, atualmente, presidida por Moura, que tem estreita relação de amizade com Ferreira, prefeito do referido Município.

Moura observou que grande parte da receita do Município X decorria do imposto sobre serviços (ISS) recolhido pela empresa Água Para Todos. Assim, valendo-se desse fato e de sua grande amizade com o prefeito, pediu-lhe que, independentemente de aprovação em concurso público, nomeasse seu filho, Moura Júnior, para o cargo efetivo de analista administrativo da Prefeitura Municipal. O pedido foi atendido e Moura Júnior tomou posse, só comparecendo à Prefeitura ao final de cada mês para

assinar o ponto.

Em retribuição ao gesto de amizade, Moura determinou ao departamento de divulgação da empresa Água Para Todos, representado por Correa, que promovesse uma homenagem ao prefeito, em veículo de comunicação de massa, parabenizando-o por seu aniversário.

A empresa Água Para Todos contratou uma produtora de mídia e um minuto em horário nobre na emissora de maior visibilidade local para a veiculação da propaganda.

No dia do aniversário do prefeito, a propaganda foi veiculada, mencionando as realizações da Prefeitura Municipal na gestão de Ferreira, tendo sido divulgada, ao final, a seguinte mensagem: "A Água Para Todos parabeniza o prefeito Ferreira pelo seu aniversário".

Tendo tomado conhecimento dos fatos, Durval, vereador e líder comunitário, resolveu tomar providências contra o que estava ocorrendo no Município e, para tanto, procurou auxílio de profissional da advocacia.

Em face dessa situação hipotética, na condição de advogado(a) constituído(a) por Durval, redija a peça processual cabível para pleitear a declaração de nulidade do ato de nomeação de Moura Júnior, com o seu imediato afastamento do cargo, e do processo administrativo que culminou na contratação da propaganda, com a respectiva reparação do patrimônio público lesado.

4.13. (OAB CESPE 2010.1 – Prova Unificada I) O secretário de administração do Estado-membro Y, com a finalidade de incentivar o aprimoramento profissional de certa categoria de servidores públicos, criou, por meio de lei específica, tabela de referências salariais com incremento de 10% entre uma e outra, estando a mudança de referência baseada em critérios de antiguidade e merecimento. O pagamento do mencionado percentual seria feito em seis parcelas mensais e sucessivas. Os servidores que adquiriram todas as condições para o posicionamento na referência

salarial subsequente já haviam recebido o pagamento de três parcelas quando sobreveio a edição de medida provisória revogando a sistemática estabelecida na lei. Assim, no mês seguinte à edição dessa medida, o valor correspondente à quarta parcela foi excluído da folha de pagamento. Em decorrência dessa exclusão, os servidores requereram à Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão a respectiva inserção na folha de pagamento, sob pena de submeter a questão ao Poder Judiciário.

Em resposta, o secretário indeferiu o pedido, fundado nos seguintes argumentos:

- a) em razão da revogação da lei, promovida pela medida provisória, os servidores não mais teriam direito ao recebimento do percentual;
- b) seria possível a alteração do regime remuneratório, em face de ausência de direito adquirido a regime jurídico, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal;
- c) os servidores teriam, na hipótese, mera expectativa de direito, e não, direito adquirido;
- d) não cabe ao Poder Judiciário atuar em área própria do Poder Executivo e conceder reajuste pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Em face da situação hipotética apresentada, na qualidade de advogado(a) contratado(a) pelo sindicato dos servidores, redija a medida judicial cabível para impugnação do ato da autoridade que determinou a exclusão do pagamento dos servidores dos percentuais previstos em lei, destacando os argumentos necessários à adequada defesa dos interesses de seus clientes.

4.14. (OAB FGV 2010.2 – Prova Unificada II) Mévio de Tal, com quarenta e dois anos de idade, pretende candidatar-se a cargo vago, mediante concurso público, organizado pelo Estado X, tendo, inclusive, se matriculado em escola preparatória. Com a publicação do edital, é surpreendido com a limitação, para inscrição, dos candidatos com idade de,

no máximo, vinte e cinco anos. Inconformado, apresenta requerimento ao responsável pelo concurso, que aduz o interesse público, tendo em vista que, quanto mais jovem, maior tempo permanecerá no serviço público o aprovado no certame, o que permitirá um menor déficit nas prestações previdenciárias, um dos problemas centrais do orçamento do Estado na contemporaneidade.

O responsável pelo concurso é o Governador do Estado X. Não há previsão legal para o estabelecimento de idade mínima, sendo norma constante do edital do concurso.

Não há necessidade de produção de provas e o prazo entre a publicação do edital e da impetração da ação foi menor que 120 (cento e vinte) dias.

Na qualidade de advogado contratado por Mévio, redigir a peça cabível ao tema, observando:

- a) competência do Juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
- d) os requisitos formais da peça inaugural;
- e) necessidade de tutela de urgência.

4.15. (OAB FGV 2010.3 – Prova Unificada III) Tício, brasileiro, casado, engenheiro, na década de setenta participou de movimentos políticos que faziam oposição ao Governo então instituído. Por força de tais atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de Segurança do Estado, organizados por agentes federais. Após longos anos, no ano de 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo seu pedido indeferido, em todas as instâncias administrativas. Esse foi o último ato praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório na necessidade de

preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejado estão indisponíveis para todos os cidadãos. Tício, inconformado, procura aconselhamentos com seu sobrinho Caio, advogado, que propõe apresentar ação judicial para acessar os dados do seu tio.

Na qualidade de advogado contratado por Tício, redija a peça cabível ao tema, observando:

- a) competência do juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
- d) os requisitos formais da peça inaugural.

4.16. (IV Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Tício, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado no Município M, inconformado com ato praticado pelo Governador do seu Estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular, impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária, para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada, pretendendo o impetrante interpor recurso alegando a violação de preceitos constitucionais, como o direito de petição, o acesso à Justiça e os atinentes à Administração Pública. Não houve deferimento da gratuidade de Justiça.

Na qualidade de advogado, elabore a peça cabível contra a decisão que denegou a segurança, observando:

- a) competência do Juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
- d) os requisitos formais da peça;
- e) adequação do recurso.

(Valor: 5,0).

4.17. (V Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Mévio, brasileiro, solteiro, estudante universitário, domiciliado na capital do Estado W, requereu o seu ingresso em programa de bolsas financiado pelo Governo Federal, estando matriculado em Universidade particular. Após apresentar a documentação exigida, é surpreendido com a negativa do órgão federal competente, que aduz o não preenchimento de requisitos legais. Entre eles, está a exigência de pertencer a determinada etnia, uma vez que o programa é exclusivo de inclusão social para integrantes de grupo étnico descrito no edital, podendo, ao arbítrio da Administração, ocorrer integração de outras pessoas, caso ocorra saldo no orçamento do programa. Informa, ainda, que existe saldo financeiro e que, por isso, o seu requerimento ficará no aguardo do prazo estabelecido em regulamento. O referido prazo não consta na lei que instituiu o programa, e o referido ato normativo também não especificou a limitação do financiamento para grupos étnicos. Com base na negativa da Administração Federal, a matrícula na Universidade particular ficou suspensa, prejudicando a continuação do curso superior. O valor da mensalidade por ano corresponde a R\$ 20.000,00, sendo o curso de quatro anos de duração. O estudante pretende produzir provas de toda a espécie, receoso de que somente a prova documental não seja suficiente para o deslinde da causa. Isso foi feito em atendimento à consulta respondida pelo seu advogado Tício, especialista em Direito Público, que indicou a possibilidade de prova pericial complexa, bem como depoimentos de pessoas para comprovar a sua necessidade financeira e outros depoimentos para indicar possíveis beneficiários não incluídos no grupo étnico referido pela Administração. Aduz ainda que o pleito deve restringir-se ao reconhecimento do seu direito constitucional e que eventuais perdas e danos deveriam ser buscadas em outro momento. Há urgência, diante da proximidade do início do semestre letivo.

Na qualidade de advogado contratado por Mévio, elabore a peça cabível ao tema, observando:

- a) competência do juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
- d) os requisitos formais da peça inaugural.

(Valor: 5,0)

4.18. (VI Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Esculápio da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na capital do Estado WYK, é comunicado por amigos que a Administração do Estado está providenciando um plano de obras custosas e pretendendo que elas sejam entregues, independentemente de licitação, a empresas com vínculos pessoais com dirigentes do seu partido político. Os valores correspondentes às obras são incluídos no orçamento, observado o devido processo legislativo. Quando da realização das obras, aduz a necessidade de urgência diante de evento artístico de grande repercussão a realizar-se em aproximadamente um ano, o que inviabilizaria a realização de procedimento licitatório e designa três empresas para repartir as verbas orçamentárias, cabendo a cada uma realizar parte da obra preconizada. As empresas Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A. aceitam, de bom grado, o encargo e assinam os contratos com a Administração. O valor das obras corresponde a um bilhão de reais. Inconformado com esse fato, Esculápio da Silva, cidadão que gosta de participar ativamente da defesa da Administração Pública e está em dia com seus direitos políticos, procura orientação jurídica e, após, resolve ajuizar a competente ação.

Na qualidade de advogado, elabora a peça cabível, observando:

- a) competência do juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;

- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
 - d) os requisitos formais da peça;
 - e) tutela de urgência.
- (valor: 5,0).

4.19. (VII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) O Estado KXY editou norma determinando a gratuidade dos estacionamento privados vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping centers, estabelecendo multas pelo descumprimento e gradação nas punições administrativas, além de delegar ao Procon local a responsabilidade pela fiscalização dos estabelecimentos relacionados no instrumento normativo. Tício, contratado como advogado júnior da Confederação Nacional do Comércio, é consultado sobre a possibilidade de ajuizamento de medida judicial, apresentando seu parecer positivo quanto à matéria, pois a referida lei afrontaria a CF. Em seguida, diante desse pronunciamento, a Diretoria autoriza a propositura da ação judicial constante do parecer.

Na qualidade de advogado, elabore a peça cabível, observando:

- a) competência do Juízo;
 - b) legitimidade ativa e passiva;
 - c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
 - d) requisitos formais da peça;
 - e) tutela de urgência.
- (Valor: 5,0)

4.20. (VIII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Com fundamento na recente Lei n. 1.234, do Estado Y, que exclui as entidades de direito privado da Administração Pública do dever de licitar, o banco X (empresa pública daquele Estado) realiza a contratação direta de uma empresa de

informática – a Empresa W – para atualizar os sistemas do banco.

O caso vem a público após a revelação de que a empresa contratada pertence ao filho do presidente do banco e nunca prestou tal serviço antes. Além disso, o valor pago (milhões de reais) estava muito acima do preço de mercado do serviço em outras empresas.

José, cidadão local, ajuíza ação popular em face do Presidente do banco X e da empresa W perante o Juízo de 1.^a instância da capital do Estado Y, em que pleiteia a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos, ao fundamento de violação ao art. 1.º, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 (norma geral sobre licitação e contratos) e a diversos princípios constitucionais.

A sentença, entretanto, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, afirmando ser válida a lei estadual que autoriza a contratação direta, sem licitação, pelas entidades de direito privado da Administração Pública, analisada em face da lei federal, não considerando violados os princípios constitucionais invocados. José interpõe recurso de apelação, ao qual se negou provimento, por unanimidade, pelo mesmo fundamento levantado na sentença.

Dez dias após a publicação da decisão que rejeitou os seus embargos declaratórios, José procura um advogado para assumir a causa e ajuizar a medida adequada.

Na qualidade de advogado, elabore a peça cabível, observando todos os requisitos formais e a fundamentação pertinente ao tema. (Valor: 5,0).

4.21. (IX Exame de Ordem Unificado OAB FGV) José, brasileiro, desempregado, domiciliado no Município “ABC”, capital do Estado “X”, chegou a um hospital municipal que não possui Centro de Tratamento Intensivo (CTI) – sentindo fortes dores de cabeça. José aguardou atendimento na fila de emergência pelo período de 12 (doze) horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do

hospital, que, entre outros comportamentos aviltantes, debocharam do fato de José estar de pé há tanto tempo esperando atendimento. Após tamanha espera e sofrimento, o quadro de saúde de José agravou-se e ele entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação, momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo. Adamastor, também desempregado, pai de José, revela que, segundo laudo do médico responsável, seu filho necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois José corre o risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer. Informa, ainda, que o médico mencionou a existência de hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades de onde José se encontra internado, todos possuidores de CTI.

Ocorre que José e Adamastor são economicamente hipossuficientes, de modo que não possuem condições financeiras de arcar com a remoção para outro hospital público, nem de custear a internação em hospital particular, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Indignado com todo o ocorrido, e ansioso para preservar a saúde de seu filho, Adamastor o procura para, na qualidade de advogado, identificar e minutar a medida judicial adequada à tutela dos direitos de José em face de todos os entes que possuem hospitais próximos ao local onde José se encontra, e que seja levado em consideração o tratamento hostil por ele recebido no hospital municipal. (Valor: 5,0)

4.22. (X Exame de Ordem Unificado OAB FGV) O Tribunal de Justiça do Estado J julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município W, tendo o acórdão declarado constitucional norma da Lei Orgânica Municipal que dispôs que o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período sem autorização da Câmara Municipal. No prazo recursal, foram ofertados embargos declaratórios, improvidos.

Contratado como advogado pelo Prefeito do Município, após a decisão proferida nos embargos declaratórios, apresente a peça cabível. (Valor: 5,0)

4.23. (XI Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Fábio é universitário domiciliado no Estado K e pretende ingressar no Ensino Superior através de nota obtida pelo Exame Nacional, organizado pelo Ministério da Educação. Após a divulgação dos resultados, Fábio é surpreendido com seu baixo desempenho nas questões discursivas, a transparecer que não corrigiram adequadamente sua prova, ou deixaram de lançar ou somar as notas das questões, o que inviabiliza seu ingresso na entidade preferida. Não há previsão de vista de prova e nem de recurso administrativo no edital, sendo certo que existe agente público do Ministério da Educação responsável pelo exame em cada Estado da Federação, denominado Coordenador Estadual do Exame Nacional, sediado na capital. Fábio requereu vista de prova e revisão da mesma ao Coordenador Estadual do Exame Nacional, tendo o seu pedido sido indeferido, por ausência de previsão editalícia. Inconformado, Fábio contrata advogado que impetra mandado de segurança, objetivando ter vista de prova, tendo a liminar sido indeferida, sem interposição de recurso. Após trinta dias de tramitação, surge sentença que julga improcedente o pedido, confirmando a legalidade da recusa de acesso à prova por falta de previsão no edital. A decisão restou clara, sem qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Fábio, por meio de seu advogado, apresenta recurso pertinente.

Redija a peça recursal cabível ao tema. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua. (Valor: 5,0)

4.24. (XII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Após mais de 40 (quarenta) dias de intensa movimentação popular, em protestos que chegaram a reunir mais de um milhão de pessoas nas ruas de diversas cidades do Estado, e que culminaram em atos de violência, vandalismo e

depredação de patrimônio público e particular, o Governador do Estado X edita o Decreto n. 1.968. A pretexto de disciplinar a participação da população em protestos de caráter público, e de garantir a finalidade pacífica dos movimentos, o decreto dispõe que, além da prévia comunicação às autoridades, o aviso deve conter a identificação completa de todos os participantes do evento, sob pena de desfazimento da manifestação. Além disso, prevê a revista pessoal de todos, como forma de preservar a segurança dos participantes e do restante da população.

Na qualidade de advogado do Partido Político "Frente Brasileira Unida", de oposição ao Governador, você ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado X, alegando a violação a normas da Constituição do Estado referentes a direitos e garantias individuais e coletivos (que reproduzem disposições constantes da Constituição da República). O Plenário do Tribunal de Justiça local, entretanto, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado, de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do decreto estadual, por entender compatíveis as previsões constantes daquele ato com a Constituição do Estado, na interpretação que restou prevalecente na Corte. Alguns dos Desembargadores registraram em seus votos, ainda, a impossibilidade de propositura de ação direta tendo por objeto um decreto estadual. Entendendo que a decisão da corte estadual, apesar de não conter obscuridade, omissão ou contradição, foi equivocada, e que não apenas as disposições do decreto são inconstitucionais, como, também, a própria interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o ordenamento jurídico nacional, os dirigentes do Partido pedem que você proponha a medida judicial cabível a impugnar aquela decisão. Elabore a peça judicial adequada. (Valor: 5,0)

4.25. (XIII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) O Presidente da República editou o Decreto n. 5.555, estabelecendo a obrigatoriedade,

como exigência à obtenção do diploma de graduação em engenharia, de um elevado aproveitamento nas disciplinas do curso, e, para inscrição nos Conselhos Regionais, a conclusão de uma pós-graduação com carga horária mínima de 480 horas de aula. A medida tem por objetivo conferir maior controle sobre a formação do profissional, num momento de expansão das obras de infraestrutura no país.

A Confederação Sindical dos Engenheiros, entidade que reúne 18 (dezoito) Federações de sindicatos em diferentes Estados, cada uma com ao menos 10 (dez) sindicatos, procura os seus serviços para impugnar o Decreto expedido pelo Presidente da República, salientando que o mesmo viola diretamente a Constituição, sendo certa a urgência na obtenção de um provimento judicial favorável, tendo em vista a aproximação do final de ano, época em que, tradicionalmente, são formados milhares de bacharéis em todo o território nacional. Considerando a hipótese acima, formule a peça adequada. (Valor: 5,0)

4.26. (XIV Exame de Ordem Unificado OAB FGV) João e José são pessoas com deficiência física, tendo concluído curso de nível superior. Diante da abertura de vagas para preenchimento de cargos vinculados ao Ministério da Agricultura, postularam a sua inscrição no número que deveria ser reservado, por força de disposição em lei federal, aos deficientes físicos com o grau de deficiência de João e José, o que restou indeferido por ato do próprio Ministro de Estado, aduzindo que a citada lei, apesar de vigente há 2 (dois) anos e com plena eficácia, não se aplicaria àquele concurso, pois não houve previsão no seu edital. Irresignados, os candidatos apresentaram Mandado de Segurança originariamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo a seção competente, por maioria de votos, denegado a segurança, dando razão ao Ministro de Estado. Houve embargos de declaração, improvidos. Ainda inconformados, apresentaram o recurso cabível contra a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Redigir o recurso cabível contra a decisão da Corte Especial. (Valor: 5,0)

4.27. (XV Exame de Ordem Unificado OAB FGV) João, sócio-diretor da empresa MM Ltda., foi surpreendido com uma notificação do Município X para pagar multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e encerrar as atividades empresariais na cidade em um período de até 90 (noventa) dias. Atônito, João, ao ler a notificação, descobre que foi aberto um processo administrativo para apurar denúncia de violação ao Decreto Municipal n. 5.678, de 2014, sem lastro em prévia lei municipal, que veda a instalação de lojas de produtos eletrônicos em bairros de perfil residencial, determina a aplicação de multa e estabelece um prazo de até 90 (noventa) dias para o encerramento das atividades empresariais no Município. Após a abertura do processo e instrução com registro fotográfico, foi proferida decisão, pelo Secretário de Posturas do Município, sem prévia oitiva da empresa, determinando a aplicação da multa, no valor indicado, bem como fixando o prazo de 90 (noventa) dias para o encerramento das atividades empresariais, sob pena de interdição e lacre do estabelecimento, na forma do decreto municipal. A notificação vem acompanhada de cópia integral daquele processo administrativo.

Você foi contratado como advogado para ajuizar a medida necessária à defesa dos interesses do cliente – afastar a exigência da multa e garantir a permanência das atividades empresariais.

Elabore a peça adequada, considerando-se aquela que tem, em tese, o rito mais célere e considerando que, desde o recebimento da notificação, já se passaram 60 (sessenta) dias, tendo transcorrido in albis o prazo para eventual recurso administrativo. (Valor: 5,0)

A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão.

4.28. (XVI Exame de Ordem Unificado OAB FGV) A Assembleia

Legislativa do Estado Y edita, em 1.º de março de 2015, a Lei n. 8.888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos. Ressalta-se que não há qualquer Lei Complementar que autorize excepcionalmente ao Estado Y dispor sobre a questão, sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção desses postes de energia, cujo serviço fica a expensas dos usuários interessados. Há notícia também de que o Governador do Estado Y vetou integralmente o projeto de Lei Estadual, mas restou superado pela vontade da Assembleia Legislativa do Estado, que, ao final, promulgou a referida Lei. Diante da relevância e da urgência da questão, o partido político “Para Frente Brasil” – PFB, representado unicamente por um Deputado Federal, procura os seus serviços para objetar contra a lei estadual, por entender que a norma estadual viola diretamente a Constituição Federal. Considerando os dados acima, formule a peça adequada, fazendo introito sobre a legitimidade ativa e observando que o partido entende ser urgente a questão. (Valor: 5,0)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

4.29. (XVII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) O Partido Político “Z”, que possui apenas três representantes na Câmara dos Deputados, por entender presente a violação de regras da CF/88, o procura para que, na qualidade de advogado especialista em direito constitucional, se posicione sobre a possibilidade de ser obtida alguma medida judicial em face da Lei Estadual “Y”, de janeiro de 2015, que contém 3 (três) artigos. De acordo com a exposição de motivos do projeto que culminou na Lei Estadual “Y”, o seu objetivo é criar, no âmbito estadual, ambiente propício às discussões políticas de âmbito nacional, e, para alcançar esse objetivo, estabelece, em

sua parte dispositiva, novas regras eleitorais, sendo estabelecidas, em seu art. 1.º, regras temporais sobre a criação de partidos políticos; em seu art. 2.º fica retirada a autorização para que partidos políticos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado; e, por fim, em seu art. 3.º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação. Elabore a peça adequada, considerando a narrativa acima. (Valor: 5,0)

4.30. (XVIII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Após receber “denúncia de irregularidades” em contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A, que possui sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito civil e penal para apurar os fatos. Neste âmbito, são colhidas provas robustas de superfaturamento e fraude nos quatro últimos contratos celebrados por esta Autarquia Federal, sendo certo que estes fatos e grande parte destas provas acabaram divulgados na imprensa. Assim é que o cidadão Pedro da Silva, indignado, procura se inteirar mais sobre o acontecido, e acaba ficando ciente de que estes contratos foram realizados nos últimos 2 (dois) anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Mas não só. Pedro obtém, também, documentos que comprovam, mais ainda, a fraude e a lesão, além de evidenciarem a participação do presidente da Autarquia A, de um Ministro de Estado e do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M. Diante deste quadro, Pedro, eleitor regular e ativo do Município do Rio de Janeiro/RJ, indignado com o descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público, pretende mover ação judicial em face dos envolvidos nos escândalos citados, objetivando desfazer os atos ilegais, com a restituição à Administração dos gastos indevidos, bem como a sustação imediata dos atos lesivos ao patrimônio público. Na condição de advogado(a) contratado(a) por Pedro, considerando os dados acima, elabore a medida judicial cabível, utilizando-se do

instrumento constitucional adequado. (Valor: 5,0).

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não será pontuada.

4.31. (XIX Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Determinado partido político, que possui dois deputados federais e dois senadores em seus quadros, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar, em nome do partido, a medida judicial objetiva apropriada, visando à regulamentação do art. 7.º, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos. Considerando a narrativa acima descrita, elabore a peça processual judicial objetiva adequada. (Valor : 5,0)

4.32. (XX Exame de Ordem Unificado OAB FGV) O Prefeito do Município Alfa, preocupado com a adequada conduta no seu mandato, procura o presidente nacional do seu partido político Beta, o qual possui representação no Congresso Nacional, e informa que a Lei Orgânica do Município Alfa, publicada em 30 de maio de 1985, estabelece, no seu art. 11, diversas condutas como crime de responsabilidade do Prefeito, entre elas o não atendimento, ainda que justificado, a pedido de informações da Câmara Municipal, inclusive com previsão de afastamento imediato do Prefeito a partir da abertura do processo político. Informou, também, que a mesma Lei Orgânica, em seu art. 12, contém previsão que define a competência de processamento e julgamento do Prefeito pelo cometimento de crimes comuns perante Justiça Estadual de primeira instância. Por fim, informou que, em razão de disputa política local, houve recente representação oferecida por Vereadores da oposição com o objetivo de

instaurar processo de apuração de crime de responsabilidade com fundamento no referido art. 11 da Lei Orgânica, a qual poderá ser analisada a qualquer momento. O partido político, após o devido trâmite interno estabelecido no seu estatuto, conclui que a norma municipal está em dissonância com a CF/88 e decide adotar providência judicial em relação ao tema. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) do partido político Beta, utilizando-se do instrumento constitucional adequado, elabore a medida judicial de controle objetivo cabível. (Valor: 5,00)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

4.33. (XXI Exame de Ordem Unificado OAB FGV) A Associação Alfa, constituída há 3 (três) anos, cujo objetivo é a defesa do patrimônio social e, particularmente, do direito à saúde de todos, mostrou-se inconformada com a negativa do Posto de Saúde Gama, gerido pelo Município Beta, de oferecer atendimento laboratorial adequado aos idosos que procuram esse serviço. O argumento das autoridades era o de que não havia profissionais capacitados e medicamentos disponíveis em quantitativo suficiente. Em razão desse estado de coisas e do elevado número de idosos correndo risco de morte, a Associação resolveu peticionar ao Secretário municipal de Saúde, requerendo providências imediatas para a regularização do serviço público de Saúde. O Secretário respondeu que a situação da Saúde é realmente precária e que a comunidade precisa ter paciência e esperar a disponibilização de repasse dos recursos públicos federais, já que a receita prevista no orçamento municipal não fora integralmente realizada. Reiterou, ao final e pelas razões já aventadas, a negativa de atendimento laboratorial aos idosos. Apesar disso, as obras públicas da área de lazer do bairro em que estava situado o Posto de Saúde Gama, nos quais eram utilizados exclusivamente recursos públicos municipais, continuaram a ser realizadas. Considerando os dados acima, na condição de advogado(a) contratado(a)

pela Associação Alfa, elabore a medida judicial cabível para o enfrentamento do problema, inclusive com providências imediatas, de modo que seja oferecido atendimento adequado a todos os idosos que venham a utilizar os serviços do Posto de Saúde. A demanda exigirá dilação probatória. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

4.34. (XXII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Servidores públicos do Estado Beta, que trabalham no período da noite, procuram o Sindicato ao qual são filiados, inconformados por não receberem adicional noturno do Estado, que se recusa a pagar o referido benefício em razão da inexistência de lei estadual que regule as normas constitucionais que asseguram o seu pagamento. O Sindicato resolve, então, contratar escritório de advocacia para ingressar com o adequado remédio judicial, a fim de viabilizar o exercício em concreto, por seus filiados, da supramencionada prerrogativa constitucional, sabendo que há a previsão do valor de vinte por cento, a título de adicional noturno, no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. Considerando os dados acima, na condição de advogado(a) contratado(a) pelo Sindicato, utilizando o instrumento constitucional adequado, elabore a medida judicial cabível. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

4.35. (XXIII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Edson, idoso aposentado por invalidez pelo regime geral de previdência social, recebe um salário mínimo por mês. Durante mais de três décadas, esteve exposto a agentes nocivos à saúde, foi acometido por doença que exige o uso contínuo de medicamento controlado, cuja ministração fora da forma

exigida pode colocar em risco a sua vida. Em razão de sua situação pessoal, todo dia 5 comparece ao posto de saúde existente na localidade em que reside, retirando a quantidade necessária do medicamento para os próximos trinta dias. No último dia 5, foi informado, pelo Diretor do referido posto, que a central de distribuição não entregara o medicamento, já que o Município, em razão da crise financeira, não pagava os fornecedores havia cerca de seis meses. Inconformado com a informação recebida, Edson formulou, logo no dia seguinte, requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Saúde, autoridade responsável pela administração das dotações orçamentárias destinadas à área de saúde e pela aquisição dos medicamentos encaminhados à central de distribuição, órgão por ele dirigido. Na ocasião, esclareceu que a ausência do medicamento poderia colocar em risco sua própria vida. Em resposta escrita, o Secretário reconheceu que Edson tinha necessidade do medicamento, o que fora documentado pelos médicos do posto de saúde, e informou que estavam sendo adotadas as providências necessárias à solução da questão, mas que tal somente ocorreria dali a 160 (cento e sessenta) dias, quando o governador do Estado prometera repassar receitas a serem aplicadas à saúde municipal. Nesse meio-tempo, sugeriu que Edson procurasse o serviço de emergência sempre que o seu estado de saúde apresentasse alguma piora. Edson, de posse de toda a prova documental que por si só basta para demonstrar os fatos narrados, em especial a resposta do Secretário Municipal de Saúde, procura você, uma semana depois, para contratar seus serviços como advogado(a), solicitando o ajuizamento da medida judicial que ofereça resultados mais céleres, sem necessidade de longa instrução probatória, para que consiga obter o medicamento de que necessita. Levando em consideração as informações expostas, ciente da desnecessidade da dilação probatória, elabore a medida judicial adequada, com todos os fundamentos jurídicos que conferem sustentação ao direito de Edson. (Valor: 5,00)

4.36. (XXIV Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Após anos de defasagem salarial, milhares de trabalhadores que integravam o mesmo segmento profissional reuniram-se na sede do Sindicato W, legalmente constituído e em funcionamento há vinte anos, que representava os interesses da categoria, em assembleia geral convocada especialmente para deliberar a respeito das medidas a serem adotadas pelos sindicalizados. Ao fim de ampla discussão, decidiram que, em vez da greve, que causaria grande prejuízo à população e à economia do país, iriam se encontrar nas praças da capital do Estado Alfa, com o objetivo de debater publicamente os interesses da categoria de forma organizada e ordeira, e ainda fariam passeatas semanais pelas principais ruas da capital. Em situações dessa natureza, a lei dispõe que seria necessária a prévia comunicação ao comandante da Polícia Militar. No mesmo dia em que recebeu a comunicação dos encontros e das passeatas semanais, que teriam início em dez dias, o comandante da Polícia Militar, em decisão formalmente comunicada ao Sindicato W, decidiu indeferi-los, sob o argumento de que atrapalhariam o direito ao lazer nas praças e a tranquilidade das pessoas, os quais são protegidos pela ordem jurídica. Inconformado com a decisão do comandante da Polícia Militar, o Sindicato W procurou um advogado e solicitou o manejo da ação judicial cabível, que dispensasse instrução probatória, considerando a farta prova documental existente, para que os trabalhadores pudessem cumprir o que foi deliberado na assembleia da categoria, no prazo inicialmente fixado, sob pena de esvaziamento da força do movimento. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

4.37. (XXV Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Em matéria jornalística amplamente divulgada pela mídia, o prefeito do Município Alfa,

situado no Estado Beta, é acusado pela imprensa local de negligenciar a saúde pública, deixando de realizar os investimentos constitucionais obrigatórios nos estabelecimentos médico-hospitalares situados na região. Com o objetivo de tirar proveito da situação para se autopromover, o prefeito elabora a seguinte estratégia: após obter expressa aprovação do Secretário Municipal do Meio Ambiente, em procedimento administrativo formalmente instaurado, às custas do erário e sob o subterfúgio de publicidade institucional, providencia a instalação de um grande painel de publicidade (outdoor) na encosta de um dos morros da cidade, o que era vedado pela legislação ambiental federal. Trata-se de área de proteção ambiental e notório ponto turístico, tendo ampla visibilidade. No outdoor, são elencadas todas as ações e investimentos da prefeitura relacionados à área da saúde durante a gestão do atual prefeito. Logo após a conclusão das obras, ambientalistas filiados a uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção ao meio ambiente comparecem ao local e detectam, dentre outras consequências prejudiciais, que a iluminação usada no outdoor durante o período noturno traria resultados nocivos à biodiversidade, ameaçando a sobrevivência de espécies animais notívagas da região. Essa nocividade se tornaria irreversível caso a iluminação viesse a ser utilizada por algumas semanas. Carlos, maior de idade, brasileiro nato no pleno gozo de seus direitos políticos, morador do Município Alfa, fica estarecido ao tomar ciência do fato e indignado com a inércia das autoridades locais competentes. Diante disso, comparece a um escritório de advocacia indagando se poderia, devidamente representado em juízo por advogado(a) legalmente habilitado(a), adotar pessoalmente alguma providência judicial diante das irregularidades apontadas. Com base no caso concreto apresentado acima, utilizando o instrumento constitucional adequado, redija a petição inicial da medida judicial cabível. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou

transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

4.38. (XXVI Exame de Ordem Unificado OAB FGV) Com o objetivo de zelar pelo primado da ética, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa aprovou e o Governador do Estado sancionou uma minirreforma política, que direcionaria as eleições seguintes para os cargos de Deputado Estadual do Estado em questão.

Essa reforma foi veiculada por meio da Lei "X". O art. 1.º dispunha que não seria admitido o registro de candidatura de qualquer pessoa com antecedentes criminais; o art. 2.º afastava a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e na televisão para os partidos políticos que abrigassem, em seus quadros, pessoas com antecedentes criminais; o art. 3.º dispunha sobre as distintas formas de exercício da cidadania no território do respectivo Estado.

A Lei "X" do Estado Alfa foi saudada com grande entusiasmo pela população. Como o art. 4.º da Lei "X" dispunha que sua entrada em vigor seria imediata, aplicando-se inclusive às eleições que seriam realizadas três meses depois, era grande a expectativa de que as mudanças fossem percebidas de imediato.

Apesar desse entusiasmo, o Partido Político Sigma, que tem representantes no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), e sofreria grandes prejuízos com a entrada em vigor da Lei "X", por deliberação do seu Diretório Nacional, decidiu ingressar com a medida judicial adequada, utilizando, como paradigma, a Constituição da República. Esperava com esse procedimento que a constitucionalidade in abstracto desse diploma normativo fosse questionada perante o tribunal competente. Considerando a narrativa acima, na condição de advogado(a) do Partido Político Sigma, elabore a petição inicial da medida judicial cabível. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que

possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

4.39. (XXVII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) O crescimento da exploração de diamantes no território do Estado Alfa ampliou a circulação de riquezas e fez com que a densidade demográfica aumentasse consideravelmente, juntamente com os riscos ao meio ambiente. Esse estado de coisas mobilizou a população local, o que levou um grupo de Deputados Estaduais a apresentar proposta de emenda à Constituição Estadual disciplinando, detalhadamente, a forma de exploração de diamantes no território em questão. A proposta incluía os requisitos formais a serem cumpridos junto às autoridades estaduais e os limites quantitativos a serem observados na extração, no armazenamento e no transporte de cargas. Após regular aprovação na Assembleia Legislativa, a Emenda à Constituição Estadual n. 5/2018 foi sancionada pelo Governador do Estado, sendo isso imediatamente comunicado às autoridades estaduais competentes para que exigissem o seu cumprimento. Preocupada com a situação no Estado Alfa e temendo o risco de desemprego dos seus associados, isso em razão dos severos requisitos estabelecidos para a exploração de diamantes, a Associação Nacional dos Geólogos, que há décadas luta pelos direitos da categoria, contratou os seus serviços como advogado(a) para que elabore a petição inicial da medida judicial cabível, de modo que o Tribunal Superior competente reconheça a incompatibilidade do referido ato normativo com a Constituição da República Federativa do Brasil. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

4.40. (XXVIII Exame de Ordem Unificado OAB FGV) A sociedade empresária K, concessionária do serviço de manutenção de uma estrada

municipal, na qual deveria realizar investimentos sendo remunerada com o valor do pedágio pago pelos usuários do serviço, decidiu ampliar suas instalações de apoio. Após amplos estudos, foi identificado o local que melhor atenderia às suas necessidades. Ato contínuo, os equipamentos foram alugados e foi providenciado o cerco do local com tapumes. De imediato, foi fixada a placa, assinada por engenheiro responsável, indicando a natureza da obra a ser realizada e a data do seu início, o que ocorreria trinta dias depois, prazo necessário para a conclusão dos preparativos. João da Silva, usuário da rodovia e candidato ao cargo de deputado estadual no processo eleitoral que estava em curso, ficou surpreso com a iniciativa da sociedade empresária K, pois era público e notório que o local escolhido era uma área de preservação ambiental permanente do Município Alfa. Considerando esse dado, formulou requerimento, dirigido à concessionária, solicitando que a obra não fosse realizada. A sociedade empresária K indeferiu o requerimento, sob o argumento de que o local escolhido fora aprovado pelo Município, que concedeu a respectiva licença, assinada pelo prefeito Pedro dos Santos, permitindo o início das obras. O local, ademais, era o que traria maiores benefícios aos usuários. João da Silva, irresignado com esse estado de coisas, contratou seus serviços, como advogado(a). Ele afirmou que quer propor uma ação judicial para que seja declarada a nulidade da licença concedida e impedida a iminente realização das obras no local escolhido, que abriga diversas espécies raras da flora e da fauna silvestre. Levando em consideração as informações expostas, elabore a medida judicial adequada, com todos os fundamentos jurídicos que confirmam sustentação à pretensão. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

4.41. (XXIX Exame de Ordem Unificado OAB FGV) João, cidadão

politicamente atuante e plenamente consciente dos deveres a serem cumpridos pelos poderes constituídos em suas relações com a população, decidiu fiscalizar a forma de distribuição dos recursos aplicados na área de educação no Município Alfa, sede da Comarca X e vizinho àquele em que residia, considerando as dificuldades enfrentadas pelos moradores do local. Para tanto, compareceu à respectiva Secretaria Municipal de Educação e requereu o fornecimento de informações detalhadas a respeito das despesas com educação no exercício anterior, a discriminação dos valores gastos com pessoal e custeio em geral e os montantes direcionados a cada unidade escolar, já que as contratações eram descentralizadas. O requerimento formulado foi indeferido por escrito, pelo Secretário Municipal de Educação, sob o argumento de que João não residia no Município Alfa; os gastos com pessoal eram sigilosos, por dizerem respeito à intimidade dos servidores; as demais informações seriam disponibilizadas para o requerente e para o público em geral, via Internet, quando estivesse concluída a estruturação do “portal da transparência”, o que estava previsto para ocorrer em 2 (dois) anos. João não informou de que modo usaria as informações. Inconformado com o indeferimento do requerimento que formulara, João contratou os seus serviços como advogado(a) poucos dias após a prolação da decisão e solicitou o ajuizamento da medida cabível, de modo que pudesse obter, com celeridade, as informações almejadas, o que permitiria sua divulgação à população interessada, permitindo-lhe avaliar a conduta do Prefeito Municipal, candidato à reeleição no processo eleitoral em curso. Elabore a petição da medida judicial adequada, considerando-se como tal aquela que não exija instrução probatória. (Valor: 5,00)

Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito das peças práticas das provas do Exame da OAB

5.1. PROVA OAB CESPE 2006.1¹⁻²

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: lei estadual que foi regulamentada por portaria. Candidato impedido de prosseguir em concurso público por ter sido reprovado em exame médico devido à existência de uma tatuagem.
- Ação: mandado de segurança – art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.

ATENÇÃO

Pedido de liminar para prosseguir no concurso (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

- Competência: Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Vitória/ES.
- Legitimidade Ativa: Augusto (candidato).
- Legitimidade Passiva: Junta Médica do Concurso Público. De acordo com o art. 6.º da Lei n. 12.016/2009, deve ser incluída a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
- Fundamentos: art. 1.º, III (dignidade da pessoa humana), art. 42, § 1.º (aplicação de normas aos militares), art. 142, § 3.º, X (normas de ingresso nas Forças Armadas), art. 37, I (requisitos de ingresso na Administração

Pública), todos da Constituição Federal de 1988. Ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Declaração de inconstitucionalidade do ato concreto.

– Outros requisitos formais da peça: a prova pré-constituída deve instruir a petição inicial (art. 6.º da Lei n. 12.016/2009), requisição de liminar inaudita altera parte, notificação da autoridade coatora, bem como ciência do feito ao órgão de representação judicial, intimação do membro do Ministério Público para oferecer parecer, concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida. Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

5.2. PROVA OAB CESPE 2006.2

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: lei municipal proíbe a abertura de estabelecimento comercial de mesma natureza a menos de duzentos metros.
- Ação: Mandado de Segurança – art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.

ATENÇÃO

Pedido de liminar para a expedição de alvará para o funcionamento da farmácia (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

- Competência: Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES.
- Legitimidade Ativa: Pessoa física que representa a Farmácias Mil Ltda.
- Legitimidade Passiva: Secretário de Administração do Município. De acordo com o art. 6.º da Lei n. 12.016/2009, deve ser incluído o Município de Guarapari.

– Fundamentos: art. 170, caput (livre-iniciativa), IV (livre concorrência), V (defesa do consumidor) e parágrafo único (livre exercício de qualquer atividade econômica) todos da Constituição Federal de 1988.

Observação: não obstante a competência legislativa concorrente (art. 24, I, §§ 1.º e 2.º c/c art. 30, I, II e VIII, todos da Constituição Federal de 1988).

– Outros requisitos formais da peça: a prova pré-constituída deve instruir a petição inicial (art. 6.º da Lei n. 12.016/2009), requisição de liminar, notificação da autoridade coatora, intimação do membro do Ministério Público, concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida, não ocorrência do prazo decadencial e valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

5.3. PROVA OAB CESPE 2006.3

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Não admissão de recurso extraordinário mesmo havendo precedentes do STF reconhecendo o direito pleiteado. Interposto agravo de instrumento que foi negado.

– Ação: Reclamação Constitucional – arts. 13 a 18 da Lei n. 8.038/90 e art. 102, I, I, da Constituição Federal de 1988.

– Competência: Supremo Tribunal Federal.

– Legitimidade Ativa: João Lima.

– Legitimidade Passiva: Juiz-Presidente da Turma Recursal Federal.

– Fundamentos: art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988 (competência do STF), art. 544 do Código de Processo Civil (cabimento do agravo quando não admitido RE ou REsp), Súmula 640 do STF, usurpação de competência (STF, RT 717/290).

– Outros requisitos formais da peça: Requisição ao STF da reforma da decisão da Turma Recursal ordenando que lhe seja remetido para o exame do recurso de agravo de instrumento, sob pena de usurpação de sua

competência constitucional, viabilizando assim o prosseguimento do RE. A reclamação deve ser instruída com prova documental (art. 13, parágrafo único, da Lei n. 8.038/90). Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

O art. 1.072, IV, do CPC de 2015 revogou os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei n. 8.038/90. A reclamação é prevista nos arts. 988 a 993 do CPC de 2015.
Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

5.4. PROVA OAB CESPE 2007.1

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: prisão civil da paciente por ter sido considerada depositária infiel em ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito.
- Ação: Habeas Corpus – art. 5.º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal.
- Competência: Tribunal de Justiça do Estado.
- Legitimidade Ativa: Maria, representada por seu advogado.
- Legitimidade Passiva: Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca.
- Fundamentos: demonstrar que a referida prisão constitui coação ilegal contra a paciente. Pacto de São José da Costa Rica (art. 7.º, número 7), inserido no direito positivo interno pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, art. 5.º, LXVII, da Constituição Federal de 1988.
- Outros requisitos formais da peça: pedido de liminar na concessão da ordem de HC com a expedição do alvará de soltura e ao final a ratificação da ordem. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Importante citar doutrina e jurisprudência: HC 90.172/SP Informativo 470 do STF, HC 87.585 e RE 466.343 – Informativo 477 do STF. Atualmente, em virtude do enunciado da Súmula Vinculante 25, caberia reclamação ao STF.

– O art. 39 do CPC de 1973 corresponde ao art. 77, V, do CPC de 2015.

5.5. PROVA OAB CESPE 2007.2

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Provimento do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado X que restringiu o horário de atendimento dos advogados.

– Ação: Mandado de Segurança Coletivo – art. 5.º, LXIX, e, LXX, b, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.

ATENÇÃO

Pedido de liminar para a não aplicação do art. 3.º do Provimento Y até que sobrevenha a decisão final do mandado de segurança (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

– Competência: Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Estado X.

– Legitimidade Ativa: OAB do Estado X.

– Legitimidade Passiva: Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado X, representado pelo Presidente do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado X.

– Fundamentos: demonstrar que a referida medida administrativa contraria uma garantia do advogado prevista no art. 7.º, VI, c, da Lei n. 8.906/94. O regimento interno dos Tribunais deve respeitar as garantias processuais das partes, nos termos do art. 96, I, a, da Constituição Federal de 1988.

– Outros requisitos formais da peça: a prova pré-constituída que instruir a petição inicial (art. 6.º da Lei n. 12.016/2009), notificação da autoridade coatora para apresentar informações, bem como que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial, intimação do membro do Ministério Público para oferecer parecer, pedido de liminar do mandado de segurança inaudita altera parte, uma vez que foram demonstrados o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* e, ao final, a ratificação da ordem, não ocorrência do prazo decadencial e valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

5.6. PROVA OAB CESPE 2007.3

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: Ação ordinária proposta por sindicato de servidores públicos a fim de obter reajuste salarial com pedido de antecipação de tutela (deferida pelo juiz de primeiro grau).
- Ação: Reclamação – art. 102, I, I, da Constituição Federal de 1988, arts. 13 e 14, II, da Lei n. 8.038/90 e arts. 156 a 162 do RISTF.

ATENÇÃO

Pedido de liminar para suspender a decisão proferida.

O art. 1.072, IV, do CPC de 2015 revogou os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei n. 8.038/90. A reclamação é prevista nos arts. 988 a 993 do CPC de 2015;

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

- Competência: Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, a, Constituição Federal de 1988.
- Legitimidade Ativa: Município A.
- Legitimidade Passiva: Juízo monocrático da Comarca do Estado.
- Fundamentos: art. 1.º da Lei n. 9.494/97 e art. 7.º, § 2.º, da Lei n.

12.016/2009. Não é cabível tutela antecipada e concessão de liminar visando ao aumento ou extensão de vantagens de servidor público. Ainda, arts. 5.º, II, 37, 61 e 167 da Constituição Federal de 1988 (legalidade orçamentária, separação entre os poderes).

– Outros requisitos formais da peça: concessão de medida liminar, requisição de informações da autoridade que praticou o ato impugnado, no prazo de dez dias, nos termos do art. 14, I, da Lei n. 8.038/90, intimação do sindicato, intimação do membro do Ministério Público, nos termos do art. 16 da Lei n. 8.038/90, e, ao final, ratificação da liminar deferida para garantir a autoridade da decisão proferida pela STF. Art. 13, parágrafo único, da Lei n. 8.038/90: a reclamação será instruída com a prova documental. Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

5.7. PROVA OAB CESPE 2008.1

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: O Presidente da República apresenta ao Congresso Nacional proposição legislativa que trata de criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem de territórios federais. Na Câmara dos Deputados é analisada, discutida e votada, dada por aprovada, segue para o Senado Federal.

– Ação: Mandado de Segurança – art. 5.º, LXIX, Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.

ATENÇÃO

Pedido de liminar para evitar que se realize a votação no Senado Federal (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

- Competência: Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 e art. 200, parágrafo único, do RISTF.
- Legitimidade Ativa: Deputado Federal.
- Legitimidade Passiva: Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados.
- Fundamentos: art. 18, §§ 2.º e 3.º, art. 69, todos da Constituição Federal de 1988. Ofensa ao quórum (maioria absoluta) para aprovação de lei complementar.
- Outros requisitos formais da peça: a prova pré-constituída deve instruir a petição inicial (art. 6.º da Lei n. 12.016/2009), requisição de liminar, notificação da autoridade coatora, ciência do feito ao órgão de representação judicial, intimação do membro do Ministério Público, não ocorrência do prazo decadencial, concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida. Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

5.8. PROVA OAB CESPE 2008.2

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: Trata-se de Convenção sobre os Direitos Humanos das Vítimas de Atividades Terroristas, convenção internacional, de âmbito multilateral, que estabelece restrições aos direitos dos presos condenados por crimes resultantes de atividades terroristas. O art. 22 do tratado determina: “As presas condenadas por crimes resultantes de atividades de terrorismo, logo após darem à luz, deverão deixar seus filhos sob a responsabilidade de entidade pública de assistência social até que cumpram integralmente a pena”.

No caso em questão há violação direta do inciso L do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, que assim estabelece: “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;”

- Ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido Cautelar – art. 10 da Lei n. 9.868/99 e art. 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988.
- Competência: Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988.
- Legitimidade Ativa: Partido Político com representação no Congresso Nacional – art. 103, VIII, da Constituição Federal de 1988.
- Legitimidade Passiva: Presidente da República, em virtude da edição do decreto presidencial que promulgou e ratificou o tratado.
- Fundamentos: art. 5.º, L (inconstitucionalidade material), art. 102, I, a (foro competente), e p (cautelar na ADIn) art. 103, VIII (legitimação ativa), todos da Constituição Federal de 1988 e arts. 2.º, VIII (legitimação ativa) e 10 (cautelar) da Lei n. 9.868/99.
- Outros requisitos formais da peça: concessão de medida cautelar, requisição de informações da autoridade que praticou o ato impugnado, no prazo de dez dias, intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, ao final, confirmação da cautelar da ADIn pelo STF. Cumprimento dos requisitos do art. 3.º da Lei n. 9.868/99 (“A petição indicará: I – o dispositivo da lei ou ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações; II – o pedido, com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”). Valor da causa (Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo – ADIn 4.161 do Conselho Federal da OAB, 17-10-2008). Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

5.9. PROVA OAB CESPE 2008.3

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Joana Augusta laborou, durante vinte e seis anos, como enfermeira do quadro do hospital universitário ligado a determinada universidade federal, mantendo, no desempenho de suas tarefas, em grande parte de sua carga horária de trabalho, contato com agentes nocivos causadores de moléstias humanas bem como com materiais e objetos contaminados. A enfermeira requereu administrativamente sua aposentadoria especial, invocando como fundamento de seu direito o § 4.º do art. 40 da Constituição Federal de 1988. No dia 30 de novembro de 2008, Joana recebeu notificação de que seu pedido havia sido indeferido, tendo a Administração Pública justificado o indeferimento com base na ausência de lei que regulamente a contagem diferenciada do tempo de serviço dos servidores públicos para fins de aposentadoria especial, ou seja, sem uma lei que estabeleça os critérios para a contagem do tempo de serviço em atividades que possam ser prejudiciais à saúde dos servidores públicos, a aposentadoria especial não poderia ser concedida. Nessa linha de entendimento, Joana deveria continuar em atividade até que completasse o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de serviço.

– Ação: Mandado de Injunção – art. 5.º, LXXI, da Constituição Federal de 1988; ao mandado de injunção aplica-se, no que couber, a Lei n. 12.016/2009, conforme determina o art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.038/90.

– Competência: Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, q, Constituição Federal de 1988.

– Legitimidade Ativa: Joana Augusta – pessoa que tem o exercício de seu

direito impedido por falta de norma regulamentadora (art. 40, § 4.º, III, da Constituição Federal de 1988).

– Legitimidade Passiva: Presidente da República – a lei, no caso, é de iniciativa do Presidente da República como estabelece o art. 61, § 1.º, II, c, da Constituição Federal de 1988.

– Fundamentos: art. 5.º, LXXI (previsão constitucional do mandado de injunção), art. 102, I, q (foro competente), art. 40, § 4.º, III (norma constitucional não regulamentada, impedindo o exercício do direito), art. 61, § 1.º, II, c (legitimidade passiva), todos da Constituição Federal de 1988 e art. 57, caput e § 1.º, da Lei n. 8.213/91 (norma passível de ser aplicada para se obter efeito concreto no mandado de injunção).

– Outros requisitos formais da peça: requisição de informações da Autoridade Impetrada (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009), no prazo de dez dias; intimação do representante judicial do Impetrado (art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009); oitiva do representante do Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/2009); pedido para que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade da omissão (art. 40, § 4.º, III, da Constituição Federal de 1988); seja declarada a mora da autoridade impetrada; seja determinada a solução da omissão suprindo-se a lacuna normativa, possibilitando a aposentadoria especial da Impetrante (poderia pedir a aplicação do art. 57, § 1.º, da Lei n. 8.213/91). Cumprimento dos requisitos do art. 6.º da Lei n. 12.016/2009 (a petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias com as cópias dos documentos que comprovem o alegado.) Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o mandado de injunção não comporta

concessão de medida liminar (MI 342/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1.º-2-1991; MI 530-3/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 08-3-1996; MI 535-4/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14-3-1996). Os arts. 39, 282 e 283 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, 319 e 320 do CPC de 2015.

Houve a regulamentação do processo e julgamento dos mandados de injunção pela Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016.

IMPORTANTE

Atualmente, existe a Súmula Vinculante 33, que trata da aposentadoria especial de servidor público, a qual, violada, autorizaria uma Reclamação a ser proposta no STF com fundamento no art. 103-A, § 3.º, da CF/88 e arts. 988 e s. do CPC de 2015.

5.10. OAB CESPE 2009.1

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: Requerimento para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito subscrito por um terço dos parlamentares de uma assembleia legislativa de determinado Estado da Federação. Para impedir a instauração da comissão os líderes dos partidos da base do governo não indicaram os respectivos representantes para integrar a referida CPI. Instalado o impasse, a mesa diretora da Casa, por seu presidente, entendeu que a criação da CPI deveria ser submetida à deliberação do plenário, arguindo falta de previsão regimental para regular a espécie. Levada a matéria ao plenário, a maioria da Casa opôs-se à criação da CPI.
- Ação: Mandado de Segurança – art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal de 1988, e Lei n. 12.016/2009.

ATENÇÃO

Pedido de liminar (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V,

- Competência: Tribunal de Justiça do Estado.
- Legitimidade Ativa: Deputado Estadual Antônio.
- Legitimidade Passiva: Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
- Fundamentos: art. 58, § 3.º, da Constituição Federal de 1988. Os requisitos para instalação de uma CPI foram devidamente preenchidos: mínimo de 1/3 dos membros da Casa Legislativa; prazo certo e fato determinado. Direito da oposição (prerrogativa da minoria parlamentar); direito constitucional de investigação do parlamentar e simetria com a Constituição Federal.
- Outros requisitos formais da peça: a prova pré-constituída deve instruir a petição inicial (art. 6.º da Lei n. 12.016/2009), pedido de liminar, notificação da autoridade coatora (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009), intimação do membro do Ministério Público, não ocorrência do prazo decadencial, concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida. Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

5.11. OAB CESPE 2009.2

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: João (eleitor) indignou-se ao saber, em abril de 2009, por meio da imprensa, que o senador que merecera seu voto nas últimas eleições havia determinado a reforma total de seu gabinete, orçada em mais de R\$ 1.000.000,00, a qual seria custeada pelo Senado Federal. A referida reforma incluía aquecimento e resfriamento com controle individualizado para o ambiente e instalação de ambiente físico para projeção de filmes em DVD, melhorias que João considera suntuosas, incompatíveis com a realidade brasileira. O senador declarara, em

entrevistas, que os gastos com a reforma seriam necessários para a manutenção da representação adequada ao cargo que exerce. Tendo tomado conhecimento de que o processo de licitação já se encerrara e que a obra não havia sido iniciada, João, temendo que nenhum ente público tomasse qualquer atitude para impedir o início da referida reforma, dirigiu-se a uma delegacia de Polícia Civil, onde foi orientado a que procurasse a Polícia Federal. Supondo tratar-se de um “jogo de empurra-empurra”, João preferiu procurar ajuda de profissional da advocacia para aconselhar-se a respeito da providência legal que poderia ser tomada no caso.

– Ação: Ação Popular – art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 4.717/65.

ATENÇÃO

Pedido de liminar (art. 5.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65).

– Competência: Juiz Federal da Vara Cível Federal de Florianópolis da Seção Judiciária de Santa Catarina.

– Legitimidade Ativa: João.

– Legitimidade Passiva: Senador da República.

– Fundamentos: arts. 37, caput (moralidade e eficiência), 5.º, LXXIII (ação popular) da Constituição Federal e Lei n. 4.717/65.

– Outros requisitos formais da peça: comprovar a condição de cidadão com a cópia do título de eleitor (documento anexo, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), concessão liminar da suspensão do contrato; determinação da citação do impetrado para contestar, sob pena de revelia (art. 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65), a intimação do representante do Ministério Público (arts. 6.º, § 4.º e 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65), a juntada dos documentos, julgar procedente o pedido, confirmando a liminar e determinar a anulação do contrato administrativo, condenar o impetrado no

pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65), bem como ao ressarcimento das perdas e danos (art. 11 da Lei n. 4.717/65). Provas (todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas). Valor da causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

ATENÇÃO

Críticas ao gabarito oficial divulgado: no presente caso cabe liminar na ação popular, tanto é que os candidatos que a utilizaram foram aprovados. Apresentou-se no gabarito oficial o cabimento de tutela antecipada. Não se pode trazer fatos novos na resposta, pois poderia ser considerada a identificação da peça e do candidato. Não admite, por exemplo, trazer dados que não constavam no enunciado, tais como, endereço, nome do advogado, número da OAB, entre outros.

5.12. OAB CESPE 2009.3

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos:

A empresa pública Água Para Todos, criada para a produção dos materiais e a prestação dos serviços pertinentes à instalação de rede hidráulica no Município X, é, atualmente, presidida por Moura, que tem estreita relação de amizade com Ferreira, prefeito do referido Município.

Moura, valendo-se do fato de que grande parte da receita do Município decorria do imposto sobre serviços (ISS) recolhido pela empresa e de sua grande amizade com o prefeito, pediu-lhe que, independentemente de aprovação em concurso público, nomeasse seu filho, Moura Júnior, para o cargo efetivo de analista administrativo da Prefeitura Municipal. O pedido foi

atendido e Moura Júnior tomou posse, só comparecendo à prefeitura ao final de cada mês para assinar o ponto. Em retribuição ao gesto de amizade, Moura determinou ao departamento de divulgação da empresa Água Para Todos, representado por Correa, que promovesse uma homenagem ao prefeito, em veículo de comunicação de massa, parabenizando-o por seu aniversário. A empresa contratou uma produtora de mídia e um minuto em horário nobre na emissora de maior visibilidade local para a veiculação da propaganda. No dia do aniversário do prefeito, a propaganda foi veiculada.

Durval, ora Impetrante, é vereador e líder comunitário, ciente dos fatos não teve outra alternativa a não ser impetrar a presente Ação Popular.

– Ação: Ação Popular – art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 4.717/65.

ATENÇÃO

Pedido de liminar (art. 5.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65).

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

– Competência: Juiz Estadual da Vara Cível da Comarca X.

– Legitimidade Ativa: Durval.

– Legitimidade Passiva: Ferreira (prefeito), Moura (presidente da empresa Água Para Todos), Moura Júnior (beneficiado com a nomeação) e Correa (departamento de divulgação da empresa Água Para Todos): nos termos do art. 6.º da Lei n. 4.717/65.

– Fundamentos: art. 37, caput e § 1.º, art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal e Lei n. 4.717/65.

– Outros requisitos formais da peça: comprovar a condição de cidadão com a cópia do título de eleitor (documento anexo, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), concessão liminar da suspensão da nomeação de Moura

Júnior; citação dos Impetrados para contestar, sob pena de revelia (art. 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65), a intimação do representante do Ministério Público (arts. 6.º, § 4.º e 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65), a juntada dos documentos, julgar procedente o pedido, confirmando a liminar e determinar a invalidade dos atos impugnados, afastando em definitivo Moura Júnior do cargo e determinando a devolução dos valores recebidos a título de remuneração, condenar o Impetrado, Moura, a devolver o dinheiro gasto na produção e divulgação da propaganda, condenar os Impetrados no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65), bem como ao ressarcimento das perdas e danos (art. 11 da Lei n. 4.717/65). Provas (todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas). Valor da causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

5.13. OAB CESPE 2010.1 – PROVA UNIFICADA I

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos:

O secretário de administração do Estado-membro Y criou, por meio de lei específica, tabela de referências salariais com incremento de 10% entre uma e outra, estando a mudança de referência baseada em critérios de antiguidade e merecimento. O pagamento do mencionado percentual seria feito em seis parcelas mensais e sucessivas. Os servidores que adquiriram todas as condições para o posicionamento na referência salarial subsequente já haviam recebido o pagamento de três parcelas quando sobreveio a edição de medida provisória revogando a sistemática estabelecida na lei. Assim, no mês seguinte à edição dessa medida, o valor correspondente à quarta parcela foi excluído da folha de pagamento. Em decorrência dessa exclusão, os servidores requereram à Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão a respectiva inserção na folha de pagamento,

sob pena de submeter a questão ao poder judiciário.

Em resposta, o secretário indeferiu o pedido, fundado nos seguintes argumentos:

- a) em razão da revogação da lei, promovida pela medida provisória, os servidores não mais teriam direito ao recebimento do percentual;
 - b) seria possível a alteração do regime remuneratório, em face de ausência de direito adquirido a regime jurídico, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal;
 - c) os servidores teriam, na hipótese, mera expectativa de direito, e não, direito adquirido;
 - d) não cabe ao Poder Judiciário atuar em área própria do Poder Executivo e conceder reajuste pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.
- Ação: Mandado de Segurança coletivo – art. 5.º, LXX, b, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.

ATENÇÃO

Pedido de liminar (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

- Competência: Tribunal de Justiça do Estado ou do Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca do Estado-membro Y.
- Legitimidade Ativa: Sindicato dos Servidores.
- Legitimidade Passiva: Secretário Estadual de Planejamento e Gestão.
- Fundamentos: art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988 (direito adquirido) e art. 37, XV, da Constituição Federal de 1988 (irredutibilidade dos vencimentos).
- Outros requisitos formais da peça: pedido de liminar (art. 7.º, III, da Lei

n. 12.016/2009), notificação da autoridade coatora (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009) e da entidade da qual ele faz parte (art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009), intimação do membro do Ministério Público, não ocorrência do prazo decadencial, concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida para a declaração definitiva de nulidade do ato que determinou a exclusão da parcela do reajuste na folha de pagamento. Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO Y

(espaço de cinco linhas)

O SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO Y, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por seu presidente (qualificação completa), conforme documento anexo (doc. 1), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso – doc. 2), com endereço na (Rua _____, _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos incisos LXIX e LXX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, art. 282 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009 impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR em face do SECRETÁRIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO Y, conforme os motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

O Secretário de Administração do Estado-membro Y, com a finalidade de incentivar o aprimoramento profissional de certa categoria de servidores públicos, criou, por meio de lei específica, tabela de referências salariais com incremento de 10% entre uma e outra, estando a mudança de referência baseada em critérios de antiguidade e merecimento. O pagamento do mencionado percentual seria feito em seis parcelas mensais e sucessivas. Os servidores que adquiriram todas as condições para o posicionamento na referência salarial subsequente já haviam recebido o pagamento de três parcelas quando sobreveio a edição de medida provisória revogando a sistemática estabelecida na lei. Assim, no mês seguinte à edição dessa medida, o valor correspondente à quarta parcela foi excluído da folha de pagamento. Em decorrência dessa exclusão, os servidores requereram à Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão a respectiva inserção na folha de pagamento, sob pena de submeter a questão ao Poder Judiciário.

Em resposta, o secretário indeferiu o pedido, fundado nos seguintes argumentos:

- a) em razão da revogação da lei, promovida pela medida provisória, os servidores não mais teriam direito ao recebimento do percentual;
- b) seria possível a alteração do regime remuneratório, em face de ausência de direito adquirido a regime jurídico, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal;
- c) os servidores teriam, na hipótese, mera expectativa de direito, e não, direito adquirido;
- d) não cabe ao Poder Judiciário atuar em área própria do Poder Executivo e conceder reajuste pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

II – DO DIREITO

A competência para apreciação do presente mandado de segurança é do Tribunal de Justiça do Estado em virtude do foro privilegiado para o julgamento de mandados de segurança em face de atos realizados por Secretários de Estado nos termos da Constituição do Estado. Nesse caso, verifica-se claramente a aplicação da simetria federativa, uma vez que os mandados de segurança contra atos de Ministros de Estado são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Constituição Federal de 1988).

A legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança coletivo no caso em questão é prevista na alínea b do inciso LXX do art. 5.º da Constituição Federal que estabelece ser competente a organização sindical em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

O Sindicato é legitimado para tutelar os interesses dos sindicalizados e age em nome próprio na defesa dos interesses dos seus membros. Nessa hipótese há legitimidade ativa extraordinária ocorrendo, no caso, substituição processual.

A autoridade coatora é o Secretário Estadual de Planejamento e Gestão do Estado Y que negou o pagamento das três últimas parcelas de acréscimo salarial.

O prazo decadencial para interposição do mandado de segurança é de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte

dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

No presente caso, tal prazo decadencial não ocorreu, pois a ação constitucional foi proposta no mês posterior à suspensão do pagamento.

O art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988 estabelece que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada;”

No presente caso, deve-se entender a aplicação do direito adquirido uma vez que os servidores já haviam adquirido todas as condições para o recebimento do percentual relativo à referência salarial subsequente, tanto que já estavam recebendo o pagamento de forma parcelada. Desse modo, os servidores já haviam adquirido, por força da legislação específica, o direito ao recebimento do percentual.

O pagamento foi efetuado de forma parcelada, mas o direito ao recebimento do percentual já havia integrado o patrimônio dos servidores, quando da edição da medida provisória.

Inferre-se que a medida provisória não poderia desrespeitar o direito já incorporado ao patrimônio dos servidores, ou seja, não poderia desrespeitar o direito adquirido previsto constitucionalmente.

O art. 37, XV, da Constituição Federal de 1988 determina que:

“O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I;”.

Verifica-se que os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Assim, a subtração das parcelas a que fariam jus os servidores públicos em virtude de sua incorporação ao seu patrimônio configura indevida afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos assegurado constitucionalmente.

No caso analisado, o ato do Secretário Estadual de Planejamento e Gestão do Estado Y que negou o pagamento das três últimas parcelas de acréscimo salarial concedido legalmente violou direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos assegurados constitucionalmente.

III – DA LIMINAR

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

Assim, estão presentes o *fumus boni iuris*, pois a ilegalidade é manifesta, uma vez que foi violado o direito adquirido de acréscimo salarial concedido por meio de lei e o princípio da irredutibilidade de vencimentos assegurado constitucionalmente, bem como o *periculum in mora*, pois o não pagamento das parcelas faltantes afeta o patrimônio dos servidores públicos, justificando plenamente o pedido de liminar.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência:

a) determine a oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público à qual se encontra vinculada a autoridade Impetrada, para se pronunciar no prazo de 72 horas, nos termos do § 2.º do art. 22 da Lei n. 12.016/2009;

b) a concessão de medida liminar, com a expedição do respectivo ofício à Autoridade coatora, considerando que os requisitos: *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* restam evidenciados, no sentido de assegurar o pagamento das três últimas parcelas do acréscimo salarial previsto em lei até que sobrevenha a decisão final do presente mandado de segurança;

c) determinar a notificação pessoal da autoridade coatora para

prestar informações no prazo legal de dez dias, dar ciência do feito ao órgão de representação judicial, bem como a intimação do Ministério Público para oferecer parecer;

d) determinar a ordem para que o direito ao pagamento do acréscimo salarial seja reconhecido, considerando a ilegalidade da suspensão do pagamento, conforme demonstrado;

e) a fixar multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil.

As provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia do ato impugnado);

Requer, por fim, a concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida assegurando, definitivamente, o pagamento das três últimas parcelas do acréscimo salarial.

(Valor da causa)

Dá-se à causa o valor de R\$ _____ (valor por extenso).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.14. OAB FGV 2010.2 – PROVA UNIFICADA II

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Mévio de Tal, com quarenta e dois anos de idade, é impedido de fazer a inscrição para candidatar-se a cargo vago em concurso público, pois o edital do concurso estabelece para inscrição dos candidatos a idade de, no máximo, vinte e cinco anos.

– Ação: mandado de segurança – art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.

ATENÇÃO

Pedido de liminar para que possa ser feita a inscrição no concurso (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

- Competência: Tribunal de Justiça do Estado X.
- Legitimidade Ativa: Mévio de Tal (candidato).
- Legitimidade Passiva: Governador do Estado X.
- Fundamentos: art. 1.º, III (dignidade da pessoa humana), Constituição Federal de 1988. Ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o princípio que veda qualquer forma de discriminação (art. 19, III, e art. 37, caput, I e II, ambos da Constituição Federal de 1988).
- Outros requisitos formais da peça: pedido de liminar, notificação da autoridade coatora: Governador, notificação da pessoa jurídica que a autoridade coatora integra: o Estado X, bem como ciência do feito ao órgão de representação judicial, intimação do membro do Ministério Público para oferecer parecer, deferimento do writ, com a concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida, garantindo a tutela para que a restrição do edital seja afastada, possibilitando que Mévio se inscreva no concurso e realize as provas normalmente. Indicar que foi observado o art. 6.º, caput, da Lei n. 12.016/2009 – petição inicial em duas vias com os documentos comprobatórios. Valor da causa (R\$ 1.000,00). Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO X

(espaço de cinco linhas)

Mévio de Tal, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (RG) n. _____, (CPF/MF) n. _____, (residente e domiciliado na Rua _____, Bairro _____, nesta _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, art. 282 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face do Governador do Estado X, pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

O Impetrante, Mévio de Tal, atualmente com quarenta e dois anos de idade, pretendendo candidatar-se a cargo vago, mediante concurso público, foi surpreendido com a previsão do edital do concurso que estabelece para inscrição dos candidatos a idade de, no máximo, vinte e cinco anos.

Tal previsão impede que o ora Impetrante possa fazer a sua inscrição para se candidatar ao cargo vago mediante concurso público.

Inconformado, apresentou requerimento ao responsável pelo concurso, que é o Governador do Estado X, que aduziu o interesse público, tendo em vista que, quanto mais jovem for o candidato, maior tempo permanecerá no serviço público se aprovado no certame, o que

permitirá um menor déficit nas prestações previdenciárias.

Com fundamento na previsão editalícia do concurso, Mévio de Tal está sendo impedido de, sequer, inscrever-se no certame, caracterizando um ato inconstitucional e abusivo.

II – DO DIREITO

De acordo com o inciso III do art. 1.º da Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil tem com o fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Desse modo, todos os entes federativos ao agir devem respeitar os direitos e garantias da pessoa humana, assegurando o mínimo necessário para sua existência.

Para a proteção dos trabalhadores urbanos e rurais é proibido adotar critérios de admissão por motivo de idade (art. 7.º, XXX, da Constituição Federal de 1988).

O Texto Maior prevê, ainda, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (art. 19, caput, III).

Assim, os entes federativos não podem estabelecer discriminações negativas entre os nacionais, como é o caso em questão.

Além disso, no art. 37, caput e I, da Constituição Federal vigente há a determinação de que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos entes federativos, inclusive os Estados-membros, devem respeitar, dentre outros princípios, a legalidade, bem como assegurar que os cargos, empregos e funções públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

O Edital, objeto da lide, que organiza o concurso para provimento de cargo vago exige como requisito para inscrição no respectivo concurso público, que os candidatos tenham a idade de, no máximo, vinte e cinco anos.

Há evidente desrespeito ao art. 37, II, da Constituição Federal brasileira que estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, não havendo, para o caso em tela, previsão legal para o estabelecimento de idade máxima.

Desse modo, verifica-se que o Edital que estabelece como critério de eliminação dos candidatos, já na fase de inscrição, o simples fato de terem idade superior a vinte e cinco anos, exorbitou a imposição constitucional que exige uma lei para estabelecer os critérios de ingresso e classificatórios de ingresso na carreira pública.

Por conta das regras estabelecidas no Edital, sob responsabilidade do Governador, o Impetrante teve negada a sua inscrição no concurso, pois já tem a idade de 42. Tal situação afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que determinam a utilização da ponderação e da lógica na aplicação das normas legais.

Sobre o tema da possibilidade de fixação de requisitos razoáveis para o provimento de cargos públicos o Supremo Tribunal Federal se manifestou no seguinte sentido:

“I – Servidores públicos estaduais estatutários: ao Estado-membro cabe legislar, observados os princípios constitucionais federais relativos ao serviço público. Impertinência da invocação da competência legislativa da União inscrita no art. 22, I e XVI. II – Pode o legislador, observado o princípio da razoabilidade, estabelecer requisitos para a investidura em cargo, emprego ou função pública” (STF, ADIn 1.326-2/SC, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26-9-1997).

Percebe-se que podem ser exigidos requisitos razoáveis e proporcionais para ingresso no serviço público previstos em lei. O que não condiz com a restrição descabida e mantida pelo Senhor Governador ao justificar, sob o manto do interesse público, que quanto mais jovem 'for o candidato, maior tempo permanecerá no serviço público se aprovado no certame, o que permitirá um menor déficit nas prestações previdenciárias.

Assim, embora o edital seja a lei do concurso, não se pode impor restrição sem respaldo em lei formal, ainda que tal lei seja razoável.

Desse modo, o interesse público meramente financeiro ou orçamentário, sustentado por uma autoridade que preside um concurso público não pode vedar a candidatura de pessoas com idade superior à prevista no edital.

Verifica-se que, com base no edital, o Impetrante teve negado seu pedido de inscrição no certame para o provimento de cargo público, independente da análise de seu conhecimento.

Novamente, tal situação afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois inexiste uma correlação lógica entre o fator discriminador utilizado com a aptidão do Impetrante para o cargo. Ademais, eventuais déficits na Previdência devem ser dirimidos com uma melhor divisão e gerenciamento do orçamento público e não com o cerceamento do direito constitucionalmente previsto. Portanto, não constando em lei os critérios, que devem ser razoáveis e proporcionais, a serem observados e que causem recusa a inscrição no certame, não pode o edital impor tal limitação de idade, uma vez que os incisos I e II do art. 37 da Constituição brasileira estabelecem uma reserva legal, e, portanto, apenas a lei pode determinar critérios específicos a serem observados e que, se descumpridos, podem acarretar a automática eliminação do concurso.

Patente é o direito líquido e certo consubstanciado na legislação constitucional e corroborando esse entendimento há a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

“A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de admitir que a lei estabeleça limite de idade para o ingresso no serviço público, desde que se mostre compatível com o conjunto de atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido” (STF, Pleno, RMS 21.046/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 135/528; 1.^a T., RE 144.822/RS, Min. Ilmar Galvão, DJU 29-9-1995; 2.^a T., RE 177.570/BA, Min. Carlos Velloso, DJU 15-3-1996, entre outros).

Ante o exposto, ficou demonstrado que a Autoridade Coatora desrespeitou direito líquido e certo do Impetrante ao impedir a sua inscrição no concurso de ingresso da carreira pública, ofendendo expressamente o disposto nos arts. 1.^o, III, 7.^o, XXX, 19, III e 37, I e II, todos da Constituição Federal de 1988.

No Edital foram criadas restrições que não são razoáveis nem proporcionais, devendo, desse modo, ser incidentalmente declarado inconstitucional, afastando-se sua aplicação e anulando-se o ato coator praticado, autorizando-se que o Impetrante se inscreva no concurso e realize as provas normalmente.

III – DA LIMINAR

O art. 7.^o, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni*

iuris. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

Assim, estão presentes o *fumus boni iuris*, pois a inconstitucionalidade é manifesta, uma vez que foi violada a determinação constitucional de que é uma lei quem deve estabelecer os requisitos para o ingresso na carreira pública, bem como o *periculum in mora*, pois, não podendo sequer se inscrever o Impetrante estará excluído definitivamente do concurso, justificando plenamente o pedido de liminar.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência se digne:

a) conceder, in limine, a segurança requerida, expedindo ofício à Autoridade Coatora para suspender o ato abusivo previsto no edital do concurso e para cumprir as determinações legais (art. 9.º da Lei n. 12.016/2009), possibilitando ao candidato, ora Impetrante, inscrever-se no concurso;

b) determinar a notificação pessoal da autoridade coatora, o Senhor Governador, para prestar informações no prazo legal de dez dias, como de direito, entregando-lhe a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia;

c) dar ciência do feito ao representante judicial da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

d) determinar a intimação do Ministério Público para oferecer parecer, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009;

e) acatar as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia

do ato impugnado);

f) a fixar multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida permitindo a inscrição do candidato no concurso público para que, assim, faça as provas normalmente.

Dá-se à causa, para efeitos fiscais e de alçada, o valor de R\$ 1.000,00.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.15. OAB FGV 2010.3 – PROVA UNIFICADA III

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Tício, na década de setenta, participou de movimentos políticos que faziam oposição ao Governo então instituído. Por força de tais atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de Segurança do Estado, organizados por agentes federais. Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, no ano de 2010, e teve o seu pedido indeferido, em todas as instâncias administrativas. Esse foi o último ato praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, que justificou seu ato decisório, na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado.

– Ação: Habeas data – art. 5.º, LXXII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 9.507/97.

ATENÇÃO

É necessário esgotar a via administrativa, sob pena de carência de ação por falta de interesse de agir (art. 8.º, parágrafo único, I, II e III, da Lei n. 9.507/97).

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

- Competência: Superior Tribunal de Justiça, art. 105, I, b, da Constituição Federal e art. 20, I, b, da Lei n. 9.507/97.
- Legitimidade Ativa: Tício.
- Legitimidade Passiva: Ministro de Estado da Defesa.
- Fundamentos: art. 1.º, III, da Constituição Federal de 1988 (dignidade da pessoa humana). Direito à informação pessoal (art. 5.º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988), abuso de autoridade (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988).
- Outros requisitos formais da peça: notificação da autoridade coatora: Ministro de Estado da Defesa, bem como ciência do feito ao órgão de representação judicial, intimação do membro do Ministério Público para oferecer parecer, procedência do habeas data determinando o acesso à ficha de informações pessoais de Tício. Indicar que foi observado o art. 8.º, caput, e parágrafo único, da Lei n. 9.507/97 – petição inicial em duas vias com os documentos comprobatórios do prévio requerimento administrativo. Valor da causa (R\$ 1.000,00). Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(ESPAÇO DE CINCO LINHAS)

TÍCIO, brasileiro, engenheiro, casado, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n. _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. _____, residente e domiciliado na _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, LXXII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 9.507/97, impetrar HABEAS DATA em face do ato do SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA (autoridade coatora), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Tício atuou em movimentos políticos que faziam oposição ao Governo então instituído, na década de setenta. Por força de tais atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, foi preso para averiguações. Teve seus movimentos monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de Segurança do Estado,

organizados por agentes federais. No ano de 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo seu pedido indeferido, em todas as instâncias administrativas. Esse foi o último ato praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, que justificou seu ato decisório, na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejado estão indisponíveis para todos os cidadãos. Como se verá, não deve prosperar tal entendimento.

II – DO DIREITO

A Constituição Federal de 1988, no art. 5.º, LXXII, estabelece que o Habeas data tem a finalidade específica de assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do Impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de

caráter público, ou para a retificação de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

A Lei n. 9.507/97 regulamentou o direito de acesso a informações e disciplinou o rito processual do Habeas data, estabelecendo, igualmente, em seu art. 7.º a finalidade de garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício do direito de acesso, de retificação e de complementação das informações pessoais dos registros de caráter público.

É o Habeas data um relevante remédio constitucional a ser utilizado nas situações que lesam, de forma efetiva ou potencial, o acesso de dados pessoais do impetrante e que são direitos fundamentais da pessoa.

E como restará provado, Tício teve seus direitos fundamentais efetivamente violados com a recusa, em todas as instâncias administrativas, de acesso à sua ficha de informações pessoais. Fica desse modo, legitimado o Impetrante a figurar no polo ativo da presente ação (art. 7.º, I, da Lei n. 9.507/97).

O legitimado passivo, ora Impetrado, é o Senhor Ministro de Estado da Defesa, pois foi a autoridade administrativa que negou o acesso às informações, embasando sua decisão na preservação do sigilo das atividades do Estado.

E por ser a autoridade coatora um Ministro de Estado, a competência para processar e julgar este Habeas data é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal e do art. 20, I, b, da Lei n. 9.507/97.

Fica, desde logo, nos termos do art. 8.º, parágrafo único, da Lei n. 9.507/97, comprovado o interesse de agir do Impetrante, legitimador do presente Habeas data, pois junta-se cópia do anterior indeferimento

do pedido de acesso à ficha das informações pessoais, no período em que Tício foi monitorado pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de Segurança do Estado.

Como se verifica dos documentos juntados, a atitude da Autoridade Coatora viola, flagrantemente, o direito do Impetrante em ter acesso, às suas informações pessoais e, portanto, de seu pessoal interesse, que estão nos arquivos públicos do período em que foi monitorado e preso para averiguações.

Houve o desrespeito do direito constitucional expresso no art. 5.º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, pois ainda que haja a ressalva do sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, não se pode confundir a preservação das atividades do Estado, com o direito, também, constitucional de ter-se acesso, somente, às suas informações pessoais, de interesse claramente particular.

O sigilo estaria preservado e o respeito à Lei Maior também, pois o acesso pretendido é somente dos dados pessoais do Impetrante, não houve e não há pedido para acesso de dados de terceiras pessoas constante dos arquivos públicos do período desejado.

E neste ponto, não se pode deixar de lamentar que o Senhor Ministro tenha, ao cumprir seus deveres constitucionais (arts. 37, caput, e 87, parágrafo único, IV, da Constituição Federal de 1988), abusado de sua autoridade e afrontado o fundamento maior da República Federativa do Brasil, a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1.º, III, da Constituição Federal de 1988).

Tício participou, sim, de movimentos políticos que faziam oposição ao Governo instituído, na década de setenta. Foi vigiado, monitorado e preso para averiguações.

Não se questiona a necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado ou o fato de os arquivos públicos do período

desejado estarem indisponíveis para a consulta pública, o que não se pode aceitar é o aviltamento do direito constitucionalmente protegido de ter acesso às informações, pois hoje o que Tício pretende é ter acesso à sua ficha de informações pessoais que constam nos arquivos públicos e que dizem respeito a um período de sua história pessoal.

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência se digne:

a) notificar o coator, o Senhor Ministro de Estado da Defesa, sobre os fatos narrados a fim de prestar as informações que entender necessárias (art. 9.º da Lei n. 9.507/97);

b) determinar a oitiva do representante do Ministério Público, para oferecer parecer, no prazo de cinco dias (art. 12 da Lei n. 9.507/97);

c) julgar procedente o pedido, determinando ao Impetrado o fornecimento das informações pleiteadas, determinando o acesso à ficha de informações pessoais de Tício (art. 13 da Lei n. 9.507/97).

Valor da causa, para efeitos de alçada, R\$ 1.000,00.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.16. IV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Tício, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado no Município M, inconformado com ato praticado pelo Governador do seu Estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular, impetrou Mandado

de Segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária, para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada, pretendendo o impetrante interpor recurso alegando a violação de preceitos constitucionais, como o direito de petição, o acesso à Justiça e os atinentes à Administração Pública. Não houve deferimento da gratuidade de Justiça.

– Ação: Recurso Ordinário Constitucional – art. 105, II, b, da Constituição Federal de 1988, Lei n. 8.038/90, Lei n. 12.016/2009 e Regimento Interno do STJ (art. 247).

– Competência: Superior Tribunal de Justiça, art. 105, II, b, da Constituição Federal.

– Legitimidade Ativa: Tício.

– Legitimidade Passiva: Governador do Estado.

– Fundamentos: art. 5.º, XXXIII (direito à informação), XIV, XXXIV, b, XXXV, LXIX, LXXIII, todos da Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 (legalidade), art. 1.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65.

– Outros requisitos formais da peça: são requisitos procedimentais do recurso ordinário os mesmos da apelação (arts. 539 e 540 do Código de Processo Civil), há peça de interposição (art. 540 do Código de Processo Civil), demonstração de preparo na peça de interposição (art. 511 do Código de Processo Civil), conhecimento e procedência do pedido para reforma da decisão possibilitando o fornecimento das informações necessárias. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 511, 539 e 540 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 1.007, 1.027, 1.028 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

(espaço de cinco linhas)

Dados da Ação (autos n.):

Recorrente: Tício

Recorrido: Governador do Estado

Tício, já qualificado nos autos, por seu advogado que esta subscreve, não se conformando com a respeitável decisão denegatória do mandado de segurança em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal de 1988 e na Lei n. 8.038/90, tempestivamente, interpor RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL em face do Governador do Estado, já qualificado, pelas razões de fato e de direito apresentadas na minuta em anexo.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após, seja o recurso encaminhado com as inclusas razões ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

Dados da ação:

Recorrente: Tício
Recorrido: Governador do Estado
Superior Tribunal de Justiça,
Colenda Turma,
Íncritos Julgadores,

Tício, não se conformando com o respeitável acórdão de fls. _____, que denegou o mandado de segurança em seu favor, vem, respeitosamente, apresentar as razões do presente recurso ordinário constitucional:

I – BREVE RESUMO

Tício, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado no Município M, inconformado com ato praticado pelo Governador do seu Estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular, impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária, para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada, pretendendo o impetrante interpor recurso alegando a violação de preceitos constitucionais, como o direito de petição, o acesso à Justiça e os atinentes à Administração Pública.

II – DO DIREITO

Não pode prosperar a respeitável decisão que denegou o mandado de segurança, por encontrar-se desprovida de respaldo constitucional e legal.

O art. 105, II, b, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) II – julgar, em recurso ordinário: (...) b) os mandados de segurança decididos em

única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;”

Previsão semelhante é estabelecida no art. 33 da Lei n. 8.038/90.

No caso em questão, a impetração do mandado de segurança era cabível, não havendo razão jurídica plausível para ter sido negado pelo Tribunal de Justiça.

O mandado de segurança é remédio constitucional, previsto no art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e que visa a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O Governador do Estado é uma autoridade pública e, ao negar acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular, violou vários dispositivos constitucionais e legais.

O art. 5.º, XXXIII, da Constituição Federal vigente estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

No mesmo sentido, aponta o inciso XIV do art. 5.º da Norma Fundamental prevendo que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Saliente-se que para viabilizar o acesso às informações assevera a

Constituição que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como possibilita-se a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5.º, XXXIV, a e b, da Constituição Federal de 1988).

Além disso, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal de 1988).

Desse modo, não há dúvida que é um mandamento constitucional o direito à informação, seja para a defesa individual ou para a defesa do bom funcionamento da Administração Pública.

No presente caso, o Recorrente, está inconformado com ato praticado pelo Governador do seu Estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar vindoura ação popular.

Tal ação é regulamentada pela Lei n. 4.717/65 que, no § 4.º do art. 1.º, estabelece que para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade a que se destinam.

Destaque-se que no § 5.º do art. 1.º da Lei n. 4.717/65 há a previsão de que as certidões e informações solicitadas deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.

É cediço que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como bem estabelece o caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Por fim, dispõe a Constituição vigente que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na Administração Pública direta e indireta, regulando especialmente, o seu acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5.º, X e XXXIII (art. 37, § 3.º, II, da Constituição Federal de 1988).

Infere-se, de todo o exposto, que o direito de obter certificações para possibilitar a propositura da ação popular tem respaldo constitucional e legal. No mesmo sentido, caminham a doutrina e a jurisprudência.

Assim, o Governador do Estado, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular incorreu em ato inconstitucional e ilegal.

O Recorrente, conforme já noticiado, impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária, para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada, ato que autoriza a interposição do presente Recurso Ordinário Constitucional, com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal de 1988, no art. 33 da Lei n. 8.038/90 e no art. 247 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez é interposto dentro do prazo legal.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, o Recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se a respeitável decisão recorrida de fls. _____, possibilitando o acesso a elementos que permitam a certificação de situações capazes de gerar a ação popular, concedendo-se a ordem para fornecimento dos documentos necessários ao Recorrente.

Por fim, requer a notificação do Ministério Público.

Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado/OAB

5.17. V EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: Mévio requereu o seu ingresso em programa de bolsas financiado pelo Governo Federal, tendo o pedido negado após apresentar a documentação exigida. O órgão federal aduz o não preenchimento de requisitos legais. Entre eles, está a exigência de pertencer a determinada etnia, uma vez que o programa é exclusivo de inclusão social para integrantes de grupo étnico descrito no edital, podendo, ao arbítrio da Administração, ocorrer integração de outras pessoas, caso ocorra saldo no orçamento do programa. Informa, ainda, que existe saldo financeiro e que, por isso, o seu requerimento ficará no aguardo do prazo estabelecido em regulamento. O referido prazo não consta na lei que instituiu o programa, e o referido ato normativo também não especificou a limitação do financiamento para grupos étnicos. Com base na negativa da Administração Federal, a matrícula na Universidade particular ficou suspensa, prejudicando a continuação do curso superior.

– Ação: Ação Ordinária com tutela antecipada ou Mandado de Segurança.

– Competência: Justiça Federal.

– Legitimidade Ativa: Mévio.

– Legitimidade Passiva: Governo Federal e Universidade Particular.

– Fundamentos constitucionais: art. 5.º, caput – ofensa ao princípio da isonomia, pois esse tipo de financiamento não pode beneficiar somente determinado grupo étnico; art. 5.º, II – ofensa ao princípio da legalidade,

uma vez que há confronto entre o regulamento e o texto legal; art. 37, caput – ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública, pois o ato da Administração não pode ser arbitrário, mas pode ser discricionário; art. 206 – ofensa ao direito constitucional à educação; art. 1.º, III – princípio da dignidade humana.

– Outros requisitos formais da peça: No caso da ação ordinária: requerimento de provas, valor da causa R\$ 80.000,00, procedência do pedido, requerimento de citação dos réus; tutela de urgência: verossimilhança, urgência, postulação da tutela antecipada.

No caso do Mandado de Segurança: notificação das autoridades coatoras, valor da causa (R\$ 80.000,00, mas a FGV admitiu qualquer valor), postulação da procedência do pedido, requerimento de intervenção do MP, requerimento de liminar (pressupostos do fumus boni juris e periculum in mora). Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 20, 39, 172, § 2.º, 222, f, 273 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 82, § 2.º, 84 e 85, 212, § 2.º, 247, V, 294 a 311, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA
CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO W

(espaço de cinco linhas)

Mévio, brasileiro, solteiro, estudante universitário, (RG) n. _____,
(CPF/MF) n. _____, (residente e domiciliado na Rua _____, Bairro

_____, capital do Estado W), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com os arts. 273 e 282 do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face da União Federal (órgão federal que negou o financiamento), com endereço (endereço completo) e da Universidade Particular do Estado W, na pessoa de seu representante legal (qualificação completa), com endereço (endereço completo), pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

O Autor, Mévio, requereu o seu ingresso em programa de bolsas de estudo financiado pelo Governo Federal, tendo o pedido negado após apresentar a documentação exigida. O órgão federal aduziu o não preenchimento de requisitos legais. Entre eles, a exigência de pertencer a determinada etnia, uma vez que o programa é exclusivo de inclusão social para integrantes de grupo étnico descrito no edital, podendo, ao arbítrio da Administração, ocorrer integração de outras pessoas, caso haja saldo no orçamento do programa. Consta que existe saldo financeiro e que, por isso, o requerimento de Mévio ficará no aguardo do prazo estabelecido em regulamento. O referido prazo não consta na lei que instituiu o programa, e o citado ato normativo também não especificou a limitação do financiamento para grupos étnicos. Com base na negativa da Administração Federal, a matrícula do Autor na Universidade particular ficou suspensa, prejudicando a continuação do curso superior.

II – DO DIREITO

De acordo com o inciso III do art. 1.º da Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil tem como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Desse modo, todos os órgãos governamentais ao agir devem respeitar os direitos e garantias da pessoa humana, assegurando o mínimo necessário para sua existência, inclusive, a possibilidade de continuidade de seus estudos.

No presente caso, a atuação do Governo Federal, em negar o financiamento ao Autor, e da Universidade Particular, ao suspender sua matrícula, está violando o princípio

da dignidade da pessoa humana. Desse modo, na legitimidade passiva devem constar a União Federal, que negou o financiamento e a Universidade que suspendeu a matrícula, por força do primeiro ato. Esse litisconsórcio se afigura necessário para resolver a situação do Autor, de forma definitiva, condenando ambos os sujeitos passivos, nos limites das suas responsabilidades.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas de que possibilitar aos indivíduos o estudo está vinculado à dignidade da pessoa humana. Além disso, na Constituição vigente está previsto que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da Constituição Federal de 1988). Corroborando tal afirmação, consta que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I, da Constituição Federal de 1988).

Infere-se, assim, que as condutas do Governo Federal e da Universidade particular feriram o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à educação.

No caput do art. 5.º da Constituição Federal vigente está previsto que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Assim, como regra, não se pode admitir distinções entre nacionais.

No mesmo sentido, está a previsão do inciso II do art. 5.º da norma

fundamental que determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

O Texto Maior prevê, ainda, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (art. 19, caput e III, da Constituição Federal de 1988).

Desse modo, a Constituição Federal brasileira determina a aplicação dos princípios da isonomia e da legalidade no tratamento dos indivíduos que se encontram no território nacional.

No presente caso, há criação de restrições para a concessão de financiamento estudantil no edital governamental, tais como a etnia e o prazo para liberação. Ocorre que na lei que cria o programa governamental, tais restrições não estão previstas ou especificadas. Assim, foram violados os princípios da isonomia e da legalidade.

A Constituição Federal em vigor determina, no art. 37, caput, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, o Estado só pode agir de acordo com a lei, visando a proteger todas as pessoas, causando a menor lesão ao erário, atuando com publicidade e eficiência. Admite-se a discricionariedade em certas atuações, mas jamais a arbitrariedade. Tais princípios visam à segurança jurídica. Nesse sentido, posicionam-se a doutrina e a jurisprudência.

No caso em questão, o Autor apresentou a documentação exigida para o ingresso em programa de bolsas de estudo financiado pelo Governo Federal, sendo surpreendido com a negativa do órgão federal competente, que sustentou o não preenchimento de requisitos legais,

dentre os quais, a exigência de pertencer à determinada etnia,

prevista no edital, podendo ao arbítrio da Administração, ocorrer a integração de outras pessoas, caso houvesse saldo no orçamento do programa. Ocorre que existe saldo financeiro e que, por isso o requerimento do Autor ficará no aguardo do prazo estabelecido em regulamento. Importante destacar que tal prazo não consta na lei que instituiu o programa de bolsas e o referido ato normativo também não especificou a limitação do financiamento para grupos étnicos.

A não concessão do financiamento pelo Governo Federal fez com que a matrícula do Autor na Universidade particular ficasse suspensa, impedindo o prosseguimento de seus estudos.

Conclui-se que as atuações do órgão federal e da Universidade particular foram inconstitucionais, ilegais e arbitrárias, pois violaram os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da legalidade, da administração pública e o direito constitucional à educação obrigando a busca do Poder Judiciário para a correção de tal injustiça.

III – DO CABIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA

O art. 273, caput e I, do Código de Processo Civil autorizam ao juiz conceder a antecipação dos efeitos da tutela, isso quando estiverem presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano.

Há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações, pois o Autor acostou os documentos que comprovam o seu requerimento de ingresso em programa de bolsas com a documentação exigida, a recusa inicial por não ser integrante do grupo étnico descrito no edital e a possibilidade de integração no programa a depender de saldo no orçamento, saldo este existente, mas que seria necessário aguardar o lapso de tempo previsto no regulamento (documentos de fls. ____).

O perigo de dano irreparável fica evidenciado, pois com base na negativa da Administração Pública, a matrícula do Autor na Universidade particular está suspensa. Tal situação prejudica a

continuação do curso superior, não podendo o Autor iniciar o ano letivo que se aproxima.

Desse modo, e diante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, há de ser deferida a antecipação da tutela pleiteada para que seja autorizado o ingresso no programa de bolsas sem o aguardo do lapso temporal previsto no regulamento, permitindo-se, assim, a matrícula e a continuação do curso superior.

Por oportuno, caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de tutela antecipada, o que se admite apenas para se argumentar, e como estão igualmente presentes os requisitos para a concessão da cautelar incidental (aplicação do disposto no § 7.º do art. 273 do Código de Processo Civil), aplicando-se os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, seja a liminar deferida.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que Vossa Excelência:

a) conceda a tutela antecipada, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, expedindo-se ofícios para a autoridade da União Federal, responsável pelo programa de bolsas, e para o Responsável da Universidade particular, para garantir o ingresso no programa de bolsas sem o aguardo do lapso temporal previsto no regulamento, permitindo-se a liberação dos valores e, assim, a matrícula e a continuação do curso superior;

b) ordene a citação pessoal dos réus, nos endereços indicados, por oficial de justiça (art. 222, f, do Código de Processo Civil, com os benefícios do art. 172, § 2.º, do Código de Processo Civil), para que, querendo, possam apresentar defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia;

c) intimação do representante judicial da União Federal conforme

determinação legal;

d) julgue totalmente procedente o pedido, ratificando a tutela deferida, garantindo, desse modo, o ingresso de imediato no programa de bolsas financiado pelo Governo Federal permitindo-se, assim, a liberação dos valores pleiteados para a matrícula e a continuação do curso superior;

e) condene os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, os últimos, no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil.

Protesta provar o alegado, por todos os meios em direito admitidos, em especial prova testemunhal, pericial, documental (documentos ora juntadas).

Requer, por fim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo alimentar próprio ou de sua família (documento de fls. _____ – declaração de hipossuficiente).

Dá-se à causa o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

ATENÇÃO

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA
CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO W

(espaço de cinco linhas)

Mévio, brasileiro, solteiro, estudante universitário, (RG) n. _____, (CPF/MF) n. _____, (residente e domiciliado na Rua _____, Bairro _____, capital do Estado W), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da Constituição

Federal de 1988, no art. 282 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face da autoridade da União Federal (órgão federal que negou o financiamento), com endereço (endereço completo), e da Universidade Particular do Estado W, na pessoa de seu representante legal (qualificação completa), com endereço (endereço completo), pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

O Impetrante, Mévio, requereu o seu ingresso em programa de bolsas financiado pelo Governo Federal, tendo o pedido negado após apresentar a documentação exigida. O órgão federal aduziu o não preenchimento de requisitos legais. Entre eles, a exigência de pertencer a determinada etnia, uma vez que o programa é exclusivo de inclusão social para integrantes de grupo étnico descrito no edital, podendo, ao arbítrio da Administração, ocorrer integração de outras pessoas, caso ocorra saldo no orçamento do programa. Consta que existe saldo financeiro e que, por isso, o seu requerimento ficará no aguardo do prazo estabelecido em regulamento. O referido prazo não

consta na lei que instituiu o programa, e o citado ato normativo também não especificou a limitação do financiamento para grupos étnicos. Com base na negativa da Administração Federal, a matrícula do Impetrante na Universidade particular ficou suspensa, prejudicando a continuação do curso superior.

Nas ações coatoras foram criadas restrições que não são constitucionais e nem legais, sendo consideradas arbitrárias, devendo, desse modo, ser incidentalmente declaradas inconstitucionais, afastando-se sua aplicação e anulando os atos coatores praticados, autorizando-se que o Impetrante venha a receber o financiamento governamental e ser matriculado na Universidade particular.

III – DA LIMINAR

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

Assim, estão presentes o *fumus boni iuris*, pois a inconstitucionalidade é manifesta, uma vez que foi violada a determinação constitucional de que é uma lei quem deve estabelecer os requisitos para o financiamento estudantil, bem como o *periculum in mora*, pois a matrícula na Universidade particular está suspensa, prejudicando a continuidade dos estudos do Impetrante, justificando plenamente o pedido de liminar.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência se digne:

a) conceder, in limine, a segurança requerida, expedindo ofícios às Autoridades Coatoras (representantes da União Federal e da Universidade privada) para suspenderem os atos abusivos previstos no regulamento e para cumprirem as determinações

legais (art. 9.º da Lei n. 12.016/2009), possibilitando ao Impetrante, o acesso ao financiamento governamental e a matrícula na Universidade privada para a continuação do curso superior;

b) determinar a notificação pessoal das autoridades coatoras (representantes da União Federal e da Universidade privada), para prestarem informações no prazo legal de dez dias, como de direito, entregando-lhes a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia;

c) dar ciência do feito aos representantes judiciais das pessoas jurídicas aos quais estão vinculadas as autoridades coatoras, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

d) determinar a intimação do Ministério Público para oferecer parecer, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009;

e) acatar as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia dos atos impugnados);

f) a fixar multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida permitindo ao Impetrante o acesso ao financiamento governamental e a matrícula na Universidade privada para a continuação do curso superior.

Dá-se à causa o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Termos em que,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.18. VI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Esculápio da Silva (cidadão em dia com seus direitos políticos) foi comunicado, por amigos, que a Administração do Estado WYK está providenciando um plano de obras custosas e pretendendo que, independentemente de licitação, as referidas obras sejam entregues para empresas com vínculos pessoais com dirigentes do seu partido político. Os valores correspondentes às obras são incluídos no orçamento, observado o devido processo legislativo. Quando da realização das obras, a Administração aduz a necessidade de urgência diante de evento artístico de grande repercussão a realizar-se em aproximadamente um ano, o que inviabilizaria a realização de procedimento licitatório e designa três empresas para repartir as verbas orçamentárias, cabendo a cada uma realizar parte da obra preconizada. As empresas Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A. aceitam, de bom grado, o encargo e assinam os contratos com a Administração. O valor das obras corresponde a um bilhão de reais.

Esculápio da Silva, ora Impetrante, cidadão que gosta de participar ativamente da defesa da Administração Pública e está em dia com seus direitos políticos, ciente dos fatos, não teve outra alternativa a não ser impetrar a presente Ação Popular.

– Ação: Ação Popular – art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 4.717/65.

Pedido de liminar (art. 5.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65).

- Competência: Juiz Estadual da Vara Cível da Comarca (Observação: o juízo competente é aquele com competência fazendária, se na Comarca houver a Vara especializada): art. 5.º da Lei n. 4.717/65.
- Legitimidade Ativa: Esculápio da Silva.
- Legitimidade Passiva: Governador do Estado WYK e os responsáveis pelas empresas beneficiadas: Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A. (art. 6.º da Lei n. 4.717/65).
- Fundamentos: art. 37, caput (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e XXI (necessidade de licitação), e art. 5.º, LXXIII (ação popular), ambos da Constituição Federal e Lei n. 4.717/65.
- Outros requisitos formais da peça: comprovar a condição de cidadão com a cópia do título de eleitor (documento anexo, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65); concessão liminar da suspensão dos contratos que já foram assinados impedindo o início das obras; determinação da citação dos impetrados para contestarem, sob pena de revelia (art. 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65); a intimação do representante do Ministério Público (arts. 6.º, § 4.º e 7.º, I, a, da Lei n. 4.717/65); a juntada dos documentos; julgar procedente o pedido, confirmando a liminar, anulando os contratos administrativos; condenar os impetrados no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65), bem como ao ressarcimento das perdas e danos (art. 11 da Lei n. 4.717/65). Provas (todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas). Valor da causa (um bilhão de reais). Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO WYK

(espaço de cinco linhas)

ESCULÁPIO DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua _____, n. _____, Capital do Estado WYK, RG n. _____, CPF n. _____, portador do título de eleitor n. _____, Seção _____, Zona _____, cidadão em pleno gozo de seus direitos (doc. para a comprovação da legitimidade ativa para a presente ação, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), por seu advogado inscrito na OAB, sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso, doc. _____), com endereço na Rua _____, n. _____, local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXXIII do art. 5.º da Constituição Federal e na Lei n. 4.717/65, impetrar AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR em face do Senhor Governador do Estado WYK (qualificação completa), com domicílio profissional na sede do Governo estadual, e dos senhores responsáveis legais pelas EMPRESAS MASTODONTE S.A., MAMUTE S.A. E DENTE DE SABRE S.A. (qualificações completas e com domicílios profissionais respectivos), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Esculápio da Silva é domiciliado na capital do Estado WYK e foi comunicado, por amigos, que a Administração do Estado está

providenciando um plano de obras custosas e que, independentemente de licitação pretende que as obras sejam entregues para empresas com vínculos pessoais com dirigentes do partido político ao qual pertence essa Administração. Os valores correspondentes às obras foram incluídos no orçamento, observado o devido processo legislativo. Quando da realização das obras, a Administração aduziu a necessidade de urgência diante de evento artístico de grande repercussão a realizar-se em aproximadamente um ano, o que inviabilizaria a realização de procedimento licitatório e designa três empresas para repartir as verbas orçamentárias, cabendo a cada uma realizar parte da obra preconizada. As empresas Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A. aceitam o encargo e assinam os contratos com a Administração. O valor das obras corresponde a um bilhão de reais.

O Impetrante é um cidadão que gosta de participar ativamente da defesa da Administração Pública, está em dia com seus direitos políticos, e uma vez ciente dos fatos, não teve alternativa a não ser impetrar a presente Ação Popular.

II – DO DIREITO

A ação popular é um remédio constitucional usado para a proteção do patrimônio público e como tal está previsto na Constituição Federal, no inciso LXXIII do seu art. 5.º, onde se lê:

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Como se verifica “qualquer Cidadão” é legitimado ativo para propor a ação popular. Entende-se por cidadão o brasileiro em pleno gozo de seus direitos políticos, o que o Impetrante, Esculápio da Silva,

comprova juntando o Título de Eleitor e a certidão de regularidade da Justiça Eleitoral (doc. _____).

A exigência de ser cidadão também está expressamente prevista no art. 1.º da Lei n. 4.717/65, abaixo transcrito:

“Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.

No art. 6.º da Lei da Ação Popular, há a determinação de que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1.º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os seus beneficiários diretos.

Desse modo, devem figurar no polo passivo da presente demanda o Estado WYK e as empresas Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A, que foram beneficiadas com os contratos.

A competência para julgar a presente causa é prevista no caput do art. 5.º da Lei n. 4.717/65, onde se lê:

“Art. 5.º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a

organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município”.

Destaque-se que, em regra, a ação popular deve ser proposta perante o juízo de primeiro grau, não havendo competência originária de Tribunal para conhecê-la, ou seja, não há foro privilegiado para os chefes do Poder Executivo ou qualquer outra autoridade.

O que é perfeitamente possível é, por questões de organização judiciária, que haja a denominada Vara Fazendária Especializada, que reúne os feitos propostos em face do Poder Executivo dos Estados e dos Municípios.

Para a propositura da ação popular há, ainda, os requisitos legais previstos no art. 2.º da Lei n. 4.717/65 onde se lê:

“Art. 2.º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: (...) d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;”

A ação popular é meio processual constitucional e, como instrumento da cidadania, também protege os princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Desse modo, bastaria a ilegalidade do ato administrativo para invalidá-lo, por se desviar dos princípios que norteiam a Administração Pública.

No caso em análise, o prejuízo ao Erário é iminente, pois os valores correspondentes às obras já foram incluídos no orçamento, bem como

já foram assinados os contratos com as três empresas escolhidas para repartirem as verbas orçamentárias. Clara a ofensa aos princípios da Administração Pública e ao art. 2.º da Lei n. 4.717/65, em especial à alínea e (desvio de finalidade), pois a escolha das três empresas, independentemente de licitação, ao que se observa, somente tem respaldo nos vínculos pessoais dos dirigentes do partido político da atual Administração com as referidas empresas.

Sobre o tema, decidiu o STF: “A Administração Pública é norteada por princípios conducentes à segurança jurídica – da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A variação de enfoques, seja qual for a justificativa, não se coaduna com os citados princípios, sob pena de grassar a insegurança” (STF, MS 24.872, Plenário, j. 30-6-2005, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 30-9-2005).

Há, ainda, a afronta ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988 que estabelece que, ressalvados os casos especificados na legislação, a contratação de

obras, serviços, compras e alienações serão, como regra, contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A Lei n. 8.666/93 regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e prevê no art. 3.º que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. A referida lei estabelece no art. 24 as hipóteses para a dispensa da licitação e, especificamente no inciso IV, a dispensa nos casos de emergência ou de calamidade pública e quando a obra possa ser concluída no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Ainda que fosse possível argumentar que há uma situação de emergência, o que realmente não se pode concordar, fica claro que a não realização da licitação cria uma odiosa deferência às empresas contratadas e, mais do que isso, impossibilita qualquer avaliação técnica e financeira da capacitação real das contratadas. O valor do contrato, já no início, atinge a assombrosa cifra de um bilhão de reais e não há como prever ou garantir o real custo final das obras.

Diante de todo o exposto e da gravidade dos fatos, a presente ação

deve ser julgada procedente.

III – DA LIMINAR

Assim estabelece o art. 5.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65:

Art. 5.º (...) “§ 4.º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”.

Há um plano de obras orçadas em um bilhão de reais, com contratos assinados com as empresas Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A. Tais obras foram contratadas sem o processo licitatório e serão custeadas com o dinheiro público do Estado WYK e, como já demonstrado, tal situação atenta contra os princípios da administração pública (art. 37, caput, e XXI, da Constituição Federal), o que demonstra inequivocamente o *fumus boni iuris*.

Uma vez que o processo de licitação sequer foi realizado, os contratos já foram assinados e considerando que as obras ainda não foram iniciadas, presente está o *periculum in mora*, pois se deve evitar que gastos sejam efetuados, tendo em vista a enorme dificuldade de reembolso ou ressarcimento futuro do Erário.

Presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, é cabível o pedido e necessária a concessão da liminar.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência:

a) conceda liminarmente a suspensão dos contratos assinados e de qualquer ato visando a atender às despesas relativas ao início das obras, bem como a sustação de qualquer ato que se digne a pagar tais despesas com recursos públicos;

b) determine a citação dos Impetrados, nos prazos e termos dos incisos I, a, e IV do art. 7.º da Lei n. 4.717/65, com cópia da presente,

bem como documentos acostados;

c) determine que a Administração do Estado WYK junte, aos autos, todos os documentos referentes ao evento artístico de grande repercussão e ao plano de obras (projetos, orçamentos, planilhas de execução, divisão dos trabalhos entre as contratadas etc.), nos termos do art. 1.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65, visando à apuração de eventuais gastos já realizados e se o projeto é realmente exequível;

d) determine a manifestação do Ministério Público (art. 6.º, § 4.º e art. 7.º, I, a, ambos da Lei n. 4.717/65);

e) ao final, julgue procedente o pedido, confirmando a liminar, e determine a anulação dos contratos assinados com os Impetrados, bem como de quaisquer atos administrativos que visem ao pagamento de despesas referentes aos referidos contratos;

f) caso já tenha havido algum pagamento referente às obras contratadas sem licitação, condene os Impetrados à devolução dos valores aos cofres públicos, com a comunicação ao Ministério Público para as devidas ações penal e de improbidade que entender pertinentes;

g) condene os Impetrados no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65).

Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.19. VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

- Resumo dos fatos: O Estado KUY editou norma determinando a gratuidade dos estacionamento privados vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping centers, determinando multas pelo descumprimento, estabelecendo gradação nas punições administrativas e delegando ao Procon local a responsabilidade pela fiscalização dos estabelecimentos relacionados no instrumento normativo. No caso em questão há inconstitucionalidade formal, pois apenas lei federal poderia tratar do tema cobrança de estacionamento em estabelecimentos privados. É competência privativa da União legislar sobre direito civil (art. 22, I, da Constituição Federal de 1988). Percebe-se também que existe inconstitucionalidade material, pois há violação dos direitos de usar, gozar e fruir da propriedade privada, bem como da livre-iniciativa assegurados na Constituição Federal vigente (art. 1.º, IV, art. 5.º, XXII e art. 170, caput e II, todos da Constituição Federal de 1988).
- Ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido Cautelar – art. 10 da Lei n. 9.868/99 e art. 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988.
- Competência: Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, a, Constituição Federal de 1988.
- Legitimidade Ativa: Confederação Nacional do Comércio, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal de 1988 e do art. 2.º, IX, da Lei n. 9.868/99.
- Legitimidade Passiva: Governador do Estado e da Assembleia Legislativa estadual.
- Fundamentos: art. 102, I, a (foro competente), e p (cautelar na ADIn), art. 103, IX (legitimação ativa), todos da Constituição Federal de 1988, e art. 2.º, IX (legitimação ativa) e art. 10 (cautelar) da Lei n. 9.868/99, É competência privativa da União legislar sobre direito civil (art. 22, I, da Constituição Federal de 1988), propriedade privada, bem como livre-

iniciativa assegurados na Constituição Federal vigente (art. 1.º, IV, art. 5.º, XXII e art. 170, caput e II, todos da Constituição Federal de 1988).

– Outros requisitos formais da peça: concessão de medida cautelar, requisição de informações da autoridade que praticou o ato impugnado, no prazo de dez dias, intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, ao final, confirmação da cautelar da ADIn pelo STF. Cumprimento dos requisitos do art. 3.º da Lei n. 9.868/99 (“A petição indicará: I – o dispositivo da lei ou ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações; II – o pedido, com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”) Valor da causa: R\$ 1.000,00. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

Confederação Nacional do Comércio, por seu advogado inscrito na
OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato

anexo [doc. _____]), com endereço sito na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 103, IX, art. 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988, arts. 2.º, IX, e 10 da Lei n. 9.868/99 e art. 282 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR em face da Lei Estadual editada pelo Estado KUY elaborada pelo Governador do Estado e a Assembleia Legislativa estadual.

I – DA NORMA IMPUGNADA

O Estado KUY editou norma determinando a gratuidade dos estacionamento privados vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping centers, determinando multas pelo descumprimento, estabelecendo

gradação nas punições administrativas e delegando ao Procon local a responsabilidade pela fiscalização dos estabelecimentos relacionados no instrumento normativo. Percebe-se que a norma que se impugna ofende a Constituição Federal e padece, portanto, de inconstitucionalidade.

II – FORO COMPETENTE

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

O autor da presente ação é a Confederação Nacional do Comércio, e desse modo, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal de 1988 e do art. 2.º, IX, da Lei n. 9.868/99, é parte legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, sendo considerada legitimada especial, motivo que justifica a propositura da presente ação e preenche o requisito da pertinência temática, uma vez que a norma questionada causa lesão aos seus associados.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva da ação direta de inconstitucionalidade em referência é do Governador do Estado e da Assembleia Legislativa estadual que criaram a norma estadual inconstitucional.

V – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL/MATERIAL

Há inconstitucionalidade formal, pois apenas lei federal poderia tratar do tema cobrança de estacionamento em estabelecimentos privados. É competência privativa da União legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, da Constituição Federal de 1988).

Percebe-se também que existe inconstitucionalidade material, pois há violação dos direitos de usar, gozar e fruir da propriedade privada, bem como da livre-iniciativa assegurados na Constituição Federal vigente (art. 1.º, IV, art. 5.º, XXII, e art. 170, caput e II, todos da Constituição Federal de 1988).

Assim, há a violação da competência legislativa para o Direito Civil privativa da União Federal, pelo Congresso Nacional (art. 22, I, da Constituição Federal de 1988), e também ocorre desrespeito ao direito de propriedade assegurado constitucionalmente (art. 5.º, XXII, da Constituição Federal de 1988).

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

Em ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a previsão do art. 102, I, p, da Constituição Federal de 1988 e do art. 10 da Lei n. 9.868/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade constante da inicial em virtude da patente contrariedade ao texto constitucional – *fumus boni iuris*.

Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face do dano irreparável causado pela existência da norma que viola o direito de propriedade dos associados da Confederação.

VII – DO PEDIDO

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a intimação do Governador do Estado e do Presidente da Assembleia Legislativa para que, como autoridade responsável pelo ato normativo questionado, manifeste-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.868/99;

b) a concessão de medida cautelar com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender a eficácia da lei estadual (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

c) a intimação do Governador do Estado e do Presidente da Assembleia Legislativa para que, como autoridade responsável pela criação da norma estadual, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

d) a intimação do senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência do art. 103, § 3.º, da Constituição Federal de 1988;

e) a intimação do senhor Procurador-Geral da República (representante do MP), para emitir seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da Constituição Federal de 1988;

f) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei estadual [cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99].

Valor da causa R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.20. VIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: com fundamento na Lei n. 1.234 do Estado Y, que exclui as entidades de direito privado da Administração Pública do dever de licitar, o banco X (empresa pública daquele Estado) realizou a contratação direta de uma empresa de informática – a Empresa W – para atualizar os sistemas do banco. O caso vem a público após a revelação de que a empresa contratada pertence ao filho do presidente do banco e nunca prestou tal serviço antes. Além disso, o valor pago (milhões de reais) estava muito acima do preço de mercado do serviço em outras empresas.

O Recorrente, cidadão local, ajuizou ação popular em face dos Presidentes

do banco X e da empresa W perante o Juízo de 1.^a instância da capital do Estado Y, pela qual pleiteava a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos, ao fundamento de violação ao art. 1.º, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 (norma geral sobre licitação e contratos) e a diversos princípios constitucionais.

A sentença, entretanto, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, afirmando ser válida a lei estadual, analisada em face da lei federal, não considerando violados os princípios constitucionais invocados. O Recorrente interpôs recurso de apelação, ao qual se negou provimento, por unanimidade, pelo mesmo fundamento levantado na sentença. Além disso, foi interposto embargos declaratórios para o prequestionamento da matéria constitucional suscitada e não apreciada.

– Ação: Recurso Extraordinário – art. 102, III, a e d da Constituição Federal de 1988, Lei n. 8.038/90, art. 541 e s. do CPC.

– Competência: Supremo Tribunal Federal.

– Legitimidade Ativa: José (autor da ação popular).

– Legitimidade Passiva: Presidente do banco X e responsáveis da empresa W.

– Fundamentos: art. 22, XXVII, art. 37, caput, ambos da Constituição Federal, Lei n. 8.666/93, arts. 541 e 543-A do Código de Processo Civil.

– Outros requisitos formais da peça: há peça de interposição e razões, prequestionamento, repercussão geral, conhecimento e procedência do pedido para reforma da decisão possibilitando a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos ao Erário. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 20, 541 e 543-A do CPC de 1973 correspondem aos arts. 82, § 2.º, 84 e 85, 1.029 e 1.035 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO Y

(espaço de cinco linhas)

Dados da ação: _____

Recorrente: José (autor da ação popular)

Recorridos: Presidente do banco X e responsáveis da empresa W

José, qualificado nos autos, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, no art. 541 e s. do Código de Processo Civil e na Lei n. 8.038/90, interpor RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face do respeitável acórdão proferido nas fls. _____, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da ação em epígrafe, em face dos RECORRIDOS (qualificados nos autos).

Requer seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após, seja o recurso admitido e encaminhado com as inclusas razões ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

Razões de Recurso Extraordinário

Dados da ação: _____

Recorrente: José

Recorridos: Presidente do banco X e responsáveis da empresa W

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

Colenda Turma,

Íncritos Julgadores,

José, não se conformando com o respeitável acórdão de fls. _____, vem, respeitosamente, apresentar as razões do presente recurso extraordinário.

I – BREVE RESUMO

Com fundamento na Lei n. 1.234 do Estado Y, que exclui as entidades de direito privado da Administração Pública do dever de licitar, o banco X (empresa pública daquele Estado) realizou a contratação direta de uma empresa de informática – a Empresa W – para atualizar os sistemas do banco.

O caso vem a público após a revelação de que a empresa contratada pertence ao filho do presidente do banco e nunca prestou tal serviço antes. Além disso, o valor pago (milhões de reais) estava muito acima do preço de mercado do serviço em outras empresas.

O Recorrente, cidadão local, ajuizou ação popular em face do Presidente do banco X e da empresa W perante o Juízo de 1.^a instância da capital do Estado Y, em que pleiteava a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos, ao fundamento de violação ao art. 1.^o, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 (norma geral sobre licitação e contratos) e a diversos princípios constitucionais.

A sentença, entretanto, julgou improcedente o pedido formulado na

petição inicial, afirmando ser válida a lei estadual, analisada em face da lei federal, não considerando violados os princípios constitucionais invocados. O Recorrente interpôs recurso de apelação, ao qual se negou provimento, por unanimidade, pelo mesmo fundamento levantado na sentença. Além disso, foi interposto embargos declaratórios para o prequestionamento da matéria constitucional suscitada e não apreciada.

II – PRELIMINARMENTE – DA REPERCUSSÃO GERAL

Verifica-se que existe questão relevante do ponto de vista jurídico, uma vez que foi violada competência constitucional para legislar sobre licitação pelo Estado Y. Além

disso, há prejuízo de milhões de reais do erário pela fraude descrita e à moralidade administrativa, sendo relevante do ponto de vista econômico, político e social, nos termos do art. 543-A, § 2.º, do CPC.

Por fim, a questão jurídica envolvida no caso transcende o interesse das partes – art. 102, § 3.º, da Constituição Federal e art. 543-A do Código de Processo Civil. Assim, o recurso merece ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

III – DO CABIMENTO DO RECURSO

Percebe-se, no presente caso, que a Lei n. 1.234, do Estado Y, que exclui as entidades de direito privado da Administração Pública do dever de licitar e a contratação direta de uma empresa de informática – a Empresa W – para atualizar os sistemas do banco X (empresa pública daquele Estado) violaram dispositivo da Constituição Federal vigente (hipóteses de dispensa de licitação – art. 22, XXVII da Constituição Federal), bem como o próprio ato de contratação também afronta a Norma Fundamental do Estado brasileiro (art. 102, III, a e d), por (i) contrariar dispositivo desta Constituição, e (ii) julgar válida lei local

contestada em face de lei federal).

Saliente-se que o recurso foi interposto tempestivamente nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

IV – DO PREQUESTIONAMENTO

Foi realizado o prequestionamento da matéria constitucional, em virtude da efetiva manifestação do Tribunal de origem, bem como pela interposição de embargos declaratórios, estando superados o contido nas Súmulas 282 e 356 do STF. Desse modo, a matéria foi devidamente questionada na instância inferior, esgotando todas as esferas inferiores para o exame da instância superior.

V – DO DIREITO

Há violação da competência constitucional para legislar sobre normas gerais de licitação prevista no art. 22, XXVII, da Constituição Federal, sendo que essa competência foi exercida pela União por meio da edição da Lei n. 8.666/93.

Também foram violados princípios norteadores da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, quais sejam, os princípios da moralidade e impessoalidade, pois foi contratada, sem licitação, uma empresa sem experiência na área, por um preço muito acima do valor de mercado, apenas pelo fato de pertencer ao filho do dirigente do banco estatal (empresa pública).

Além disso, também foi violado o inciso XXI do mesmo art. 37 da Constituição Federal, que determina a realização de licitação no caso apresentado.

A Lei n. 1.234, do Estado Y, ultrapassou os limites da competência do Estado e, portanto, é inválida. Nada obstante, o Tribunal de origem entendeu válida a lei local contestada em face da lei federal (que impõe a licitação às empresas públicas), e, assim, configura-se um

conflito quanto às competências de cada ente federativo (União e Estado Y).

Por fim, também foram violadas as normas do art. 173, § 1.º, III, da Constituição Federal (as empresas públicas têm o dever de licitar como regra), bem como a do art. 175 da Constituição Federal (a necessidade de licitação para a prestação de serviços públicos).

VI – DO PEDIDO

Diante do exposto, o recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se a respeitável decisão recorrida de fls. _____ para a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos ao Erário.

Inversão do ônus da sucumbência, condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a notificação do Ministério Público.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.21. IX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: José, em razão de fortes dores de cabeça, foi até um hospital municipal que não possui Centro de Tratamento Intensivo.

Aguardou, junto com seu pai Adamastor, atendimento na fila de emergência pelo período de 12 (doze) horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital. Após tanta demora, o seu quadro de saúde agravou-se e José entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação, momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo. Segundo o laudo do médico responsável, José necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois corre o risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer. Há hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades do hospital no qual José se encontra internado e todos possuem CTI. José e Adamastor não possuem condições financeiras de arcar com a remoção para outro hospital público, nem de custear a internação em hospital particular, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Indignado com todo o ocorrido, e ansioso para preservar a saúde de seu filho, Adamastor não vê alternativa a não ser a presente ação.

– Ação: Ordinária de Obrigação de Fazer (art. 282 e s. do CPC) com pedido de antecipação de tutela (art. 273 do CPC).

– Competência: Juiz Federal da Vara Cível da Seção Judiciária de “X”.

– Legitimidade Ativa: José, representado por Adamastor.

– Legitimidade Passiva: Município ABC, Estado “X” e União.

– Fundamentos:

1. Para a obrigação de Fazer: direito à internação e ao tratamento de saúde adequado, nos termos do art. 196 da CF/88; pedido de reconhecimento de solidariedade entre o Município, o Estado e a União.

2. Para a obrigação de reparar os danos morais: o direito à reparação por danos morais é em face do Município, considerando a demonstração da conduta ilícita, nexos causal e resultado danoso; tal fundamentação se faz com base na teoria do risco administrativo, com responsabilidade objetiva, bem como no § 6.º do art. 37 da CF/88. Para o pedido de gratuidade de

justiça, alegar o preenchimento dos requisitos contidos no art. 4.º da Lei n. 1.060/50 (revogado pelo CPC/2015).

3. Antecipação da tutela, nos termos do art. 273 do CPC: especificar a verossimilhança das alegações (demonstrar concretamente a aparência do bom direito) e o periculum in mora (perigo na demora da prestação jurisdicional).

– Outros requisitos formais da peça: concessão da tutela antecipada; requerimento para citação do Município, do Estado e da União; procedência do pedido para condenar a União, o Estado e o Município a promoverem a internação do autor em CTI; fixação de multa em caso de descumprimento da determinação de internação; procedência do pedido de condenação do Município ABC à reparação dos danos morais pelo autor; requerimento para produção de provas (todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas), condenação em honorários sucumbenciais, deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Valor da causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 20, 39, 172, § 2.º, 222, f, 273 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 82, § 2.º, 84 e 85, 212, § 2.º, 247, V, 294 a 311, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA
CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO X

José, brasileiro, estado civil, desempregado, (RG), (CPF/MF),
(residente e domiciliado na Rua _____, Bairro _____, Município ABC,

capital do Estado X), em estado de incapacidade absoluta e, por este motivo, representado por seu pai Adamastor, nacionalidade, estado civil, desempregado, (RG), (CPF/MF), (residente e domiciliado na Rua _____, Bairro _____, Município ABC, capital do Estado X), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do CPC), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com os arts. 273 e 282 do CPC, propor a presente AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, pelo rito ordinário, em face do Município ABC, Estado "X" e União, nas pessoas de seus representantes legais com endereços, respectivamente (endereços completos), pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

José em razão de fortes dores de cabeça foi até um hospital municipal que não possui Centro de Tratamento Intensivo. Aguardou, junto com seu pai Adamastor, atendimento na fila de emergência pelo período de 12 (doze) horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital. Após tanta demora, o seu quadro de saúde se agravou e José entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação, momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo. Segundo o laudo do médico responsável, José necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois corre o risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer. Há hospitais municipais,

estaduais e federais nas proximidades do hospital no qual José se encontra internado e todos possuem CTI. José e Adamastor não possuem condições financeiras de arcar com a remoção

para outro hospital público, nem de custar a internação em hospital particular, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Indignado com todo o ocorrido e ansioso para preservar a saúde de seu filho, Adamastor não vê alternativa a não ser a presente ação.

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

Necessária a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, pois José e Adamastor estão desempregados e são pessoas pobres, na acepção jurídica do termo, não podem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo alimentar próprio ou de sua família (documentos de fls. – declarações de hipossuficiência e cópias das Carteiras de Trabalho).

III – DO DIREITO

De acordo com o inciso III do art. 1.º da CF/88, a República Federativa do Brasil tem como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Desse modo, todos os órgãos governamentais ao agir devem respeitar os direitos e garantias da pessoa humana, assegurando o mínimo necessário para sua existência. É importante destacar que as ações e serviços de saúde são de relevância pública.

E a Carta Magna é clara ao estabelecer o acesso universal e igualitário à saúde. É o que se depreende do art. 196:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O direito à saúde é um direito público subjetivo indisponível e assegurado a todas as pessoas. Não por acaso, o art. 196 está previsto na Constituição Federal no Título VIII – Da Ordem Social, que tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 193) e, além disso, a Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, que tem como um dos objetivos a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, caput, parágrafo único e I).

No presente caso, a situação enfrentada no hospital municipal com a negativa do pronto atendimento a José, ainda que fosse para informá-lo que não havia CTI e direcioná-lo para um dos hospitais públicos nas proximidades e com o recurso necessário, deixando-o por cerca de doze horas e em pé, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o próprio direito fundamental à saúde. Não se pode aceitar que o desmazelo e a incompetência administrativa possam dificultar ou impossibilitar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Desse modo, a legitimidade ativa configura-se, pois José teve seu direito constitucional desrespeitado, e tem que estar representado por seu pai em razão da sua incapacidade, e na legitimidade passiva deve constar o Município ABC, Estado "X", e a União, que têm o dever de aplicar, anualmente, recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde (§ 2.º do art. 198 da CF/88). Ademais, foi informado ao Senhor

Adamastor, ora representante do Autor, a existência de hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades daquele no qual José se encontra internado, e todos com o recurso do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Esse litisconsórcio se afigura necessário para resolver a situação do Autor, de forma definitiva, condenando os sujeitos passivos, nos limites das suas responsabilidades.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de possibilitar aos indivíduos o direito à saúde está vinculado à dignidade da pessoa humana. Além disso, na Constituição vigente, está previsto que a saúde é um direito de todos e dever da União e dos Estados, que legislam de forma concorrente sobre a defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88).

Além disso, a Carta Magna ainda prevê, com relação aos serviços de atendimento municipal que compete aos Municípios, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população (art. 30, VII, da CF/88).

Há, ainda, na CF/88, a previsão do Sistema Único de Saúde e que estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único (arts. 198, 199 e 200).

Infere-se, assim, que as condutas dos servidores do hospital Municipal feriram o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Não se pode esquecer que o direito à saúde está diretamente associado ao direito, também fundamental, do direito à vida que está previsto no art. 5.º da Lei Maior.

Conclui-se que a atuação do hospital municipal que não prestou o atendimento de urgência, que permitiu a degradante espera por longas doze horas, com o agravamento do quadro de saúde do Autor, foi inconstitucional, pois violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, e o direito constitucional à saúde, obrigando a busca do Poder Judiciário para a correção de tal injustiça, o que nos leva ao pedido de danos morais em face do Município ABC, conforme segue.

IV – DOS DANOS MORAIS EM FACE DO MUNICÍPIO ABC

Conforme foi demonstrado, José procurou o hospital municipal em razão de sentir fortes dores de cabeça. Relatou tal situação e, ainda assim, aguardou e esperou na fila da emergência pelo atendimento.

O dano moral é possível se houver uma lesão ao direito da personalidade e à honra da pessoa e, infelizmente, o Autor, além do quadro de intensa dor física, ainda sofreu moralmente com o tratamento humilhante que lhe foi dispensado.

Desse modo, deve o Município ABC responder pelos danos morais sofridos por José. Tais danos decorrem das condutas ilícitas praticadas pelos servidores municipais, que não só negaram o atendimento com a urgência necessária, como ainda debocharam e foram ásperos com o Autor e seu pai em um momento de extrema fragilidade.

Ressalta-se que o Município responde nos termos do art. 37, § 6.º, da CF/88, estando configurado o nexo de causalidade entre a ação e a omissão dos servidores do hospital e o dano moral causado, não só pela total desconsideração da pessoa humana, mas, também, pelo agravamento do estado de saúde do Autor (documento de fls. – laudo médico).

Com relação ao valor da indenização pleiteada, este deve representar um desestímulo à prática de atos irresponsáveis e imprudentes como os praticados.

Segue abaixo, para se Vossa Excelência considerar necessário, o rol de testemunhas que em momento oportuno poderão ser inquiridas para corroborar todo o alegado.

V – DO CABIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA

O art. 273, caput e I, do CPC autorizam ao Juiz conceder a antecipação dos efeitos da tutela, isto quando estiverem presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano.

Há, nos autos, prova inequívoca da verossimilhança das alegações, pois o Autor acostou o laudo do médico responsável relatando que há urgência na remoção para um hospital com CTI, e há nas proximidades hospitais municipais, estaduais e federais (documentos de fls.).

O perigo de dano irreparável fica mais que evidenciado, pois está consignado no laudo médico que há risco de danos irreversíveis à saúde

e, inclusive, o risco de morte, se José não receber o tratamento em uma CTI.

Desse modo, diante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, há de ser deferida e realizada a imediata remoção e internação de José em um dos hospitais públicos, nas proximidades, com CTI.

Por oportuno, caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de tutela antecipada, o que se admite apenas para se argumentar, e como estão igualmente presentes os requisitos para a concessão da cautelar incidental (aplicação do disposto no § 7.º do art. 273 do CPC), aplicando-se os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, seja a liminar deferida.

VI – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que Vossa Excelência:

a) conceda a tutela antecipada, nos termos do art. 273 do CPC, expedindo-se o necessário para a imediata remoção e internação de José para um dos hospitais públicos, nas proximidades, com CTI;

b) ordene a citação pessoal dos réus, para que, querendo, apresentem defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia;

c) determine que se intimem os representantes judiciais dos réus, conforme determinação legal;

d) julgue totalmente procedente o pedido, ratificando a tutela deferida, garantindo, desse modo, a internação e atendimento dignos em hospital público com CTI;

e) julgue totalmente procedente o pedido de indenização por danos morais em face do Município ABC, condenando-o ao pagamento do valor pleiteado;

f) condene os réus ao pagamento das custas e honorários

advocatícios de sucumbência, os últimos, no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 do CPC.

Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, pois o Autor e seu pai Adamastor são pessoas pobres na acepção jurídica do termo e não podem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo alimentar próprio ou de sua família.

Protesta provar o alegado, por todos os meios em direito admitidos, em especial prova testemunhal (rol de testemunhas), pericial e documental (documentos ora juntadas).

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00, para efeitos fiscais.

Nesses termos,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

PARA O MANDADO DE SEGURANÇA

- Ação: Mandado de Segurança com pedido de liminar (Lei n. 12.016/2009).
- Competência: Juiz Federal da Vara Cível da Seção Judiciária de “X”.
- Legitimidade Ativa: José representado por Adamastor.
- Legitimidade Passiva: Município ABC, Estado “X” e União.
- Fundamentos: Direito à internação e ao tratamento de saúde adequado, nos termos do art. 196 da CF/88; importante a caracterização do ato abusivo da autoridade indicada como impetrada. Para o pedido de gratuidade de justiça, alegar o preenchimento dos requisitos contidos no art. 4.º da Lei n. 1.060/50 (revogado pelo CPC/2015).

Liminar, nos termos do art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009. Especificar o

fumus boni iuris (demonstrar concretamente a aparência do bom direito) e o periculum in mora (perigo na demora da prestação jurisdicional).

– Outros requisitos formais da peça: Concessão da liminar; requerimento para notificação da autoridade coatora (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009); ciência do feito ao órgão de representação judicial do impetrado (art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009); procedência do pedido para que seja feita a internação do Impetrante em hospital com CTI; intervenção do Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/2009). Deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Valor da causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO X

José, brasileiro, estado civil, desempregado, (RG), (CPF/MF), (residente e domiciliado na Rua _____, Bairro _____, Município ABC, capital do Estado X), em estado de incapacidade absoluta e, por este motivo, representado por seu pai Adamastor, nacionalidade, estado civil, desempregado, (RG), (CPF/MF), (residente e domiciliado na Rua _____, Bairro _____, Município ABC, capital do Estado X), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 39

do CPC), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da CF/88, art. 282 do CPC e art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009, impetrar o presente

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face da autoridade coatora do Município ABC, na pessoa de seu representante legal com endereço (endereço completo), em face do Estado "X" e da União, nas pessoas de seus representantes legais com endereços, respectivamente (endereços completos), pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

José em razão de fortes dores de cabeça foi até um hospital municipal que não possui Centro de Tratamento Intensivo. Aguardou, junto com seu pai Adamastor, atendimento na fila de emergência pelo período de 12 (doze) horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital. Após tanta demora, o seu quadro de saúde agravou-se e José entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação, momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo. Segundo o laudo do médico responsável, José necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois corre o risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer. Há hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades do hospital no qual José se encontra internado e todos possuem CTI. José e Adamastor não possuem condições financeiras de arcar com a remoção para outro hospital público, nem de custear a internação em hospital particular, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Indignado com todo o ocorrido, e ansioso para preservar a saúde de seu filho, Adamastor não vê alternativa a não ser recorrer ao Poder Judiciário.

II – DO DIREITO

De acordo com o inciso III do art. 1.º da CF/88, a República Federativa do Brasil tem como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Desse modo, todos os órgãos governamentais ao agir devem respeitar os direitos e garantias da pessoa humana, assegurando o mínimo necessário para sua existência. É importante

destacar que as ações e serviços de saúde são de relevância pública.

E a Carta Magna é clara ao estabelecer o acesso universal e igualitário à saúde. É o que se depreende do art. 196:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O direito à saúde é um direito público subjetivo indisponível e assegurado a todas as pessoas. Não por acaso, o art. 196 está previsto na Constituição Federal no Título VIII – Da Ordem Social, que tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 193) e, além disso, a Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, que tem como um dos objetivos a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, caput, parágrafo único, I).

No presente caso, a situação enfrentada no hospital municipal com a negativa do pronto atendimento a José, ainda que fosse para informá-lo que não havia CTI e

direcioná-lo para um dos hospitais públicos nas proximidades e com os recursos necessários, deixando-o por cerca de doze horas e em pé, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o próprio direito líquido e certo à saúde.

Com a ausência de remoção e de internação do Impetrante para um hospital com os recursos necessários, a saber, com Centro de Tratamento Intensivo, resta claro o abuso de poder, caracterizador de ato coator pela autoridade pública gerando, assim, o direito líquido e certo à impetração do presente mandamus. Não se pode aceitar que o desmazelo e a incompetência administrativa possam dificultar ou impossibilitar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Nesse sentido, a Carta Maior, em seu art. 5.º, LXIX, e o art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, que estabelecem que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Desse modo, a legitimidade ativa configura-se, pois José, ora Impetrante, teve seu direito constitucional desrespeitado e tem que estar representado por seu pai em razão da sua incapacidade.

Na legitimidade passiva, constam, além da autoridade do Município ABC, responsável pelo ato coator de omissão, pois não atendeu e não providenciou a remoção do Impetrante para outro hospital com CTI, o Estado X e a União, pois o Senhor Adamastor, ora representante do Impetrante, foi informado da existência de hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades e todos com o recurso do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Esse litisconsórcio se afigura necessário para resolver a situação do Impetrante de forma definitiva, garantindo a remoção e a internação em hospital com CTI, seja o hospital municipal, estadual ou federal, condenando, assim, os Impetrados, nos limites das suas responsabilidades.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que possibilitar aos indivíduos o direito à saúde está vinculado à dignidade da pessoa humana. Além disso, na Constituição vigente, está previsto que a saúde é um direito de todos e dever da União e dos Estados, que legislam de forma concorrente sobre a defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88). A Carta Magna ainda prevê com relação aos serviços de atendimento municipal que compete aos Municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população (art. 30, VII, da CF/88).

Há, também, na CF/88, a previsão do Sistema Único de Saúde, e que estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único (arts. 198, 199 e 200).

Infere-se, assim, que as condutas dos servidores do hospital municipal feriram o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Não se pode esquecer que o direito à saúde está diretamente associado ao direito, também fundamental, à vida, que está previsto no art. 5.º da Lei Maior.

Conclui-se que a atuação do hospital municipal que não prestou o atendimento de urgência, que permitiu a degradante espera por longas doze horas com o agravamento do quadro de saúde do Autor foi inconstitucional, pois violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e o direito constitucional à saúde, obrigando a busca do Poder Judiciário para a correção de tal injustiça.

Desde logo, e como prova pré-constituída, é apresentado o laudo do médico responsável no qual está expressamente consignado que José necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois corre o risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer.

Repisamos que este atendimento somente ocorreu após a espera de 12 (doze) horas na fila de emergência, e de José, em razão do agravamento do quadro de saúde, ter entrado em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação. Foi, ainda, informado ao pai de José que há, nas proximidades, hospitais municipais, estaduais e federais que possuem CTI.

Ante o exposto, ficou demonstrado que as autoridades, ora

Impetradas, violaram os direitos líquidos e certos da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1.º da CF/88) e do direito constitucional ao acesso universal e igualitário à saúde (art. 196 da CF/88).

Por oportuno, consigna-se que, se for o caso e em momento oportuno, será proposta a competente ação para o ressarcimento dos danos morais sofridos, pois neste momento salvar a vida de José dando-lhe um atendimento digno é o mais importante.

III – DA JUSTIÇA GRATUITA

Necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, pois José e Adamastor estão desempregados e são pessoas pobres, na acepção jurídica do termo, não podem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo alimentar próprio ou de sua família (documentos de fls. – declarações de hipossuficiência e cópias das Carteiras de Trabalho).

IV – DA LIMINAR

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

Assim, estão presentes o *fumus boni iuris*, pois a inconstitucionalidade é manifesta, uma vez que foi violada a determinação constitucional de acesso universal e igualitário à saúde, bem como o *periculum in mora*, pois se não houver imediata remoção e

internação em um hospital que possua CTI, o Impetrante corre o risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer, justificando plenamente o pedido de liminar.

V – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência se digne:

a) conceder, in limine, a segurança requerida, expedindo-se o necessário para garantir a imediata remoção e internação de José em um dos hospitais próximos e que tem o recurso do Centro de Tratamento Intensivo;

b) determinar a notificação pessoal das autoridades coatoras (representantes do Município ABC, do Estado X e da União), para prestar informações no prazo legal de dez

dias, como de direito, entregando-lhes a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia;

c) dar ciência do feito ao representante judicial das pessoas jurídicas às quais estão vinculadas as autoridades coatoras, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

d) determinar a intimação do Ministério Público para oferecer parecer, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009;

e) acatar as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (em especial a cópia do laudo médico);

f) a fixar multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CPC.

Requer, ao final, a concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida, garantindo ao Impetrante a remoção e internação em hospital, seja municipal, estadual ou federal, com CTI que lhe garanta o acesso ao atendimento digno e com os recursos necessários para

preservar e restabelecer sua saúde.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, pois o Autor e seu pai Adamastor são pessoas pobres na acepção jurídica do termo e não podem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo alimentar próprio ou de sua família.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nesses termos,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.22. X EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: foi julgada improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município W. No acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado J, foi declarada constitucional norma da lei orgânica municipal que dispôs que o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período sem autorização da Câmara Municipal. Os embargos declaratórios não foram providos.
- Ação: Recurso Extraordinário (art. 102, III, a e c, § 3.º, da CF/88 e arts. 541 a 546 do CPC).
- Competência: Petição de interposição endereçada ao Tribunal de Justiça do Estado J e as Razões do recurso endereçadas ao Supremo Tribunal Federal.
- Legitimidade Ativa: Prefeito do Município W (recorrente).
- Legitimidade Passiva: Câmara Municipal (recorrida).
- Fundamentos: aplicação do princípio da simetria, pois a regra

constitucional que estabelece condições e requisitos para o afastamento do Presidente da República é de observância obrigatória nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas: Arts. 29, caput, 49, III e 83, todos da CF/88. Esclarecer que houve o prequestionamento da questão constitucional, pois o acórdão recorrido é de uma ação de inconstitucionalidade da norma da Lei Orgânica Municipal. Justificar a repercussão geral (art. 102, § 3.º, da CF/88 e art. 543-A, caput e §§ 1.º a 4.º, do CPC), pois a questão diz respeito a todas as leis orgânicas.

– Outros requisitos formais da peça: na peça de interposição, pedir que o recurso seja recebido e processado, intimação do recorrido para contrarrazões, juntar custas de preparo e porte de remessa e retorno. Nas razões, pedir o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que o acórdão seja reformado, declarando inconstitucional a norma da lei orgânica municipal que dispôs que o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período, sem autorização da Câmara Municipal. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 20, 541 e 543-A do CPC de 1973 correspondem aos arts. 82, § 2.º, 84 e 85, 1.029 e 1.035 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO J

Dados da ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade

Recorrente: Prefeito do Município W
Recorrido: Câmara Municipal

PREFEITO DO MUNICÍPIO W, qualificado nos autos, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, III, a e c, § 3.º, da CF/88, no art. 541 e s. do CPC e na Lei n. 8.038/90, interpor RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face do respeitável acórdão proferido nas fls., que declarou constitucional norma da Lei Orgânica Municipal, bem como não deu provimento aos embargos declaratórios, nos autos da ação em epígrafe, em face da CÂMARA MUNICIPAL, na pessoa de seu Presidente (qualificado nos autos).

Requer seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após, seja o recurso admitido e encaminhado com as inclusas razões ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Nesses termos,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

Razões de Recurso Extraordinário

Dados da ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade

Recorrente: Prefeito do Município W

Recorrido: Câmara Municipal

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
Colenda Turma,
Íncritos Julgadores,

PREFEITO DO MUNICÍPIO W, não se conformando com o respeitável acórdão de fls., vem, respeitosamente, apresentar as razões do

presente recurso extraordinário.

I – BREVE RESUMO

Foi julgada improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município W. No acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado J, foi declarada constitucional norma da Lei Orgânica Municipal que dispôs que o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período, sem autorização da Câmara Municipal. Os embargos declaratórios não foram providos.

II – PRELIMINARMENTE – DA REPERCUSSÃO GERAL

Verifica-se que há relevância do ponto de vista jurídico e político, pois a questão diz respeito à aplicação do princípio da simetria federativa em relação à autorização legislativa para a ausência do titular do Poder Executivo por mais de quinze dias, expressa no art. 83 da Constituição Federal vigente.

Os Estados, ao elaborarem suas Constituições, e os Municípios, ao elaborarem suas Leis Orgânicas, devem observar as regras de repetição obrigatória estabelecidas na Constituição Federal.

O tema é passível de ser estendido a todas as Leis Orgânicas, assim, a questão jurídica e política transcende o interesse das partes.

Há repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3.º, da CF/88 e do art. 543-A, §§ 1.º e 2.º, do CPC, e o recurso deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

III – DO CABIMENTO DO RECURSO

Cabível o presente recurso, nos termos do art. 102, III, a e c, da CF/88, pois se percebe que a norma da Lei Orgânica Municipal que dispôs que o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período, sem autorização da Câmara Municipal, viola

o princípio da simetria federativa e o art. 83 da CF/88, que exige a licença legislativa para período superior a quinze dias.

Saliente-se que o recurso foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 508 do CPC.

IV – DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da questão constitucional está devidamente preenchido, pois na origem, ou seja, na ação direta de inconstitucionalidade, pedia-se a declaração de inconstitucionalidade da norma.

Assim, a matéria foi devidamente questionada na instância inferior, houve a efetiva manifestação do Tribunal de origem, bem como houve a interposição de embargos declaratórios, esgotando-se as instâncias para o exame da instância superior.

V – DO DIREITO

Os Municípios são entes detentores de autonomia política e administrativa e reger-se-ão por lei orgânica, votada em dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado. Esta é a previsão do art. 29 da Lei Fundamental brasileira.

Assim, o Município, ao elaborar sua Lei Orgânica, irá, entre outros, organizar os órgãos da Administração Municipal, a relação entre os poderes municipais, Executivo e Legislativo, disciplinar a competência legislativa municipal observando as peculiaridades locais, devendo, ao elaborá-la, fazê-lo em consonância com a Constituição Federal e a

Constituição do Estado ao qual pertence.

Trata-se da observância do princípio da simetria ou paralelismo constitucional. Tal princípio estabelece que os Municípios, ao elaborarem suas Leis Orgânicas, não poderão estabelecer limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do seu Estado. O mesmo se aplica aos Estados que, ao elaborarem suas Constituições, não poderão estabelecer limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil.

O Prefeito do Município W, ao propor, no Tribunal de Justiça do seu Estado, a ação direta de inconstitucionalidade da norma da Lei Orgânica Municipal que dispôs que o Prefeito e o Vice-Prefeito não podem ausentar-se do país, por qualquer período, sem autorização da Câmara Municipal, pretendeu ver resguardado tal princípio.

Em que pese o respeitável acórdão proferido pela constitucionalidade da referida norma, reitera-se neste recurso a necessidade de aplicação do princípio da simetria aos afastamentos determinados na Lei Orgânica. E tal observância deve ser respeitada não apenas pelo Município W, mas por todos os Municípios ao elaborarem ou emendarem suas Leis Orgânicas.

Como parâmetro, deve-se observar o que a Constituição Federal prevê sobre os afastamentos do Presidente e do Vice-Presidente da República.

O tema está disciplinado nos arts. 49 e 83 da CF/88, e, neste ponto, reputa-se como necessária a transcrição que segue:

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...) III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a quinze dias;”

“Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão,

sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.”

Verifica-se, desse modo, que a Câmara Municipal do Município W, ao tratar do tema, não poderia ter imposto a norma da Lei Orgânica Municipal, exigindo a autorização para ausência, seja qual for o período de afastamento do Prefeito e do Vice-Prefeito. A Constituição Federal estabelece a exigência para quando a ausência exceder a quinze dias. Pelo princípio da simetria, tal norma e requisitos são de observância obrigatória nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas. Portanto, patente é a inconstitucionalidade da norma que foi atacada na ação de inconstitucionalidade proposta no Tribunal de Justiça do Estado J, que proferiu o acórdão que se pretende ver reformado.

VI – DO PEDIDO

Diante do exposto, o recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se o venerando acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado J e, por consequência, declarar-se a inconstitucionalidade da norma da Lei Orgânica Municipal, que exige autorização da Câmara Municipal para ausência, seja qual for o período de afastamento, do Prefeito e do Vice-Prefeito (fls.).

Por fim, requer a notificação do Ministério Público.

Nesses termos,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.23. XI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Fábio é universitário e pretende ingressar no ensino superior através de nota obtida pelo Exame Nacional, organizado pelo Ministério da Educação. Com a divulgação dos resultados, Fábio foi surpreendido com seu baixo desempenho nas questões discursivas, a transparecer que não corrigiram adequadamente sua prova, ou deixaram de lançar ou somar as notas das questões, o que inviabiliza seu ingresso na entidade preferida. Não há previsão de vista de prova e nem de recurso administrativo no edital. Fábio requereu vista de prova e sua revisão ao Coordenador Estadual do Exame Nacional, que é o agente público do Ministério da Educação responsável pelo exame em cada Estado, tendo o seu pedido sido indeferido, por ausência de previsão editalícia. Com a recusa, foi impetrado mandado de segurança com pedido de liminar, objetivando ter vista de prova. A liminar foi indeferida e a sentença julgou improcedente o pedido, confirmando a legalidade da recusa de acesso à prova por falta de previsão no edital. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

– Ação: Recurso de Apelação – art. 14 da Lei n. 12.016/2009 e arts. 513 a 521 do CPC.

– Competência: Tribunal Regional Federal (art. 108, II, da CF/88). A peça de interposição é endereçada ao Juízo Federal vinculado à Seção Judiciária do Estado K.

– Legitimidade Ativa: Impetrante – Fábio.

– Legitimidade Passiva: Impetrado – Coordenador Estadual do Exame Nacional, autoridade coatora.

– Fundamentos: princípio da legalidade (art. 5.º, II, da CF/88), princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88), direito de petição (art. 5.º, XXXIV, a, da CF/88), direito à informação (art. 5.º, XXXIII, da CF/88).

– Outros requisitos formais da peça: os requisitos procedimentais do recurso

de apelação estão previstos nos arts. 513 a 521 do CPC: há peça de interposição (art. 514 do CPC), demonstração de preparo na peça de interposição (art. 511 do CPC), conhecimento e procedência do recurso para reforma da sentença (art. 514, III, do CPC). Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 511, 513 a 521 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 1.007, 1.009 ao 1.014 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO K

Mandado de Segurança autuado sob n. _____

FÁBIO, já qualificado nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, de número em epígrafe, que move em face do COORDENADOR ESTADUAL DO EXAME NACIONAL, autoridade coatora, vem, por seu advogado, à presença de Vossa Excelência, tendo em vista a respeitável sentença de fls., interpor RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do art. 14 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 513 e s. do CPC, cujas razões seguem acostadas.

Outrossim, requer seja o presente recurso recebido em seus regulares efeitos, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal, e posterior remessa dos autos para o respectivo Tribunal Regional Federal.

Por fim, seguem anexos os comprovantes dos recolhimentos das

custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local/Data.

Advogado/OAB

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO

Apelante: Fábio.

Apelado: Coordenador Estadual do Exame Nacional.

Egrégio Tribunal Regional Federal

Íncritos Julgadores

I – BREVE RELATO

Fábio é universitário e pretende ingressar no Ensino Superior utilizando a nota obtida pelo Exame Nacional, organizado pelo Ministério da Educação. Com a divulgação dos resultados, foi surpreendido com seu baixo desempenho nas questões discursivas, o que o levou a crer que não corrigiram adequadamente sua prova, ou deixaram de lançar ou somar as notas das questões, o que inviabiliza seu ingresso na entidade preferida. Requereu, então, vista de prova e sua revisão ao Coordenador Estadual do Exame Nacional, que é o agente público do Ministério da Educação responsável pelo exame no Estado. Este pedido foi indeferido com o argumento de que não há previsão de vista de prova e nem de recurso administrativo no edital. Em razão de tal recusa, impetrou mandado de segurança com pedido de liminar objetivando ter vista de prova.

O MM. Juízo a quo indeferiu a liminar e ao final proferiu sentença julgando improcedente o pedido sob o argumento de legalidade da recusa de acesso à prova por falta de previsão no edital. Os embargos

de declaração opostos foram rejeitados.

Todavia, como será demonstrado a seguir, a respeitável sentença proferida merece ser reformada.

II – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

Primeiro, e por oportuno, consigna-se que o apelante, conforme já noticiado, impetrou Mandado de Segurança perante o Juízo Federal vinculado à Seção Judiciária do Estado K, competente para julgar a questão, pois a autoridade que lhe negou a vista da prova é o Coordenador Estadual do Exame Nacional, que é o agente público do Ministério da Educação no Estado K. A segurança foi denegada, o que autoriza a interposição, tempestiva, do presente recurso de apelação, com fundamento no art. 108, II, da CF/88 e no art. 14 da Lei n. 12.016/2009.

A respeitável sentença recorrida deve ser reformada, pois o Apelante tem direito líquido e certo de vista de prova e sua revisão, ainda que não haja previsão editalícia para tal.

No caso em questão, a impetração do mandado de segurança era cabível, não havendo razão jurídica plausível para ter sido negado pelo Juízo.

O mandado de segurança é remédio constitucional, previsto no art. 5.º, LXIX, da CF/88, e que visa a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

As previsões do edital não podem desrespeitar direitos constitucionalmente previstos e foi o que ocorreu quando o Coordenador Estadual do Exame Nacional negou acesso à prova realizada pelo Apelante.

O art. 5.º, XXXIII, da CF/88 estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Saliente-se que para viabilizar o acesso às informações, assevera a Constituição que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como se possibilita a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5.º, XXXIV, a e b, da CF/88). Além disso, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5.º, XXXV, da CF/88).

Não há dúvida de que é um mandamento constitucional o direito à informação, seja para a defesa individual ou para a defesa do bom funcionamento da Administração Pública.

O Apelante está inconformado com ato praticado pelo Coordenador Estadual do Exame Nacional que lhe negou acesso à prova realizada, pois com a divulgação do resultado não obteve o necessário para garantir o seu ingresso na instituição de Ensino Superior escolhida.

Não está o recorrente pretendendo obter a sua aprovação, mas tão somente ter certeza de que não houve algum equívoco.

É perfeitamente possível e plausível que possa ter ocorrido um erro na soma das notas das questões ou, ainda, que a correção, em razão do elevado número de participantes do exame, precise ser revisada.

Excelências, era somente isso que pretendia o esforçado Fábio ao requerer a vista de prova e sua revisão, o que lhe foi negado de forma sumária em flagrante desrespeito aos princípios da Administração Pública expressamente previstos no art. 37, caput, da CF/88.

Senão, vejamos, o Coordenador Estadual do Exame Nacional indeferiu o pedido com o argumento de que não há previsão de vista de prova e nem de recurso administrativo no edital. Assim, foram violados os preceitos constitucionais acima listados.

Não se discute que a lei possa estabelecer limites ou restrições, mas desde que o faça de modo razoável, o que no presente caso não o seria.

Feitas tais considerações, restou demonstrado o direito do Apelante em ter vista da sua prova e, se for o caso, a sua revisão, devendo, assim, ser reformada a respeitável sentença proferida pelo Juiz Federal, por não estar em consonância com os preceitos constitucionais listados.

III – DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal seja o presente Recurso de Apelação conhecido e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento, no sentido de reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido e, assim, concedendo-se a segurança para permitir o acesso à prova.

Nestes termos,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.24. XII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: O Governador do Estado X editou o Decreto n. 1.968 quarenta dias após intensa movimentação popular que culminou em atos de violência, vandalismo e depredação. O referido decreto dispõe que deve haver prévia comunicação às autoridades com a identificação completa de

todos os participantes do evento, sob pena de desfazimento da manifestação. Além disso, prevê a revista pessoal de todos, como forma de preservar a segurança dos participantes e do restante da população. Em razão da violação a normas da Constituição do Estado X referentes a direitos e garantias individuais e coletivos, normas que reproduzem disposições constantes da Constituição da República, o partido político, ora Recorrente, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado X. Porém, o Plenário do Tribunal de Justiça, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado, de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do decreto estadual, por entender que são compatíveis com a Constituição do Estado. Os Desembargadores que registraram seus votos consignaram, ainda, a impossibilidade de propositura de ação direta tendo por objeto um decreto estadual.

– Ação: Recurso Extraordinário: art. 102, III, a e d, da CF/88; Lei n. 8.038/90; arts. 541 e s. do CPC.

– Competência: Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88).

– Legitimidade Ativa: partido político “Frente Brasileira Unida” (autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade)

– Legitimidade Passiva: Governador do Estado X.

– Fundamentos: art. 5.º, caput, II e XVI, da CF/88.

– Outros requisitos formais da peça: há peça de interposição que deve ser endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado X: receber e processar o recurso; intimar a parte contrária, encaminhar ao STF, juntar custas. Razões Recursais dirigidas ao Supremo Tribunal Federal: prequestionamento e repercussão geral; conhecimento e provimento para reforma da decisão, possibilitando a declaração de inconstitucionalidade do decreto editado pelo Governador do Estado, bem como requerer a notificação do Ministério Público. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data, advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 20, 541 e 543-A do CPC de 1973 correspondem aos arts. 82, § 2.º, 84 e 85, 1.029 e 1.035 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO X

Dados da ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Recorrente: partido político "Frente Brasileira Unida" (autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

Recorrido: Governador do Estado X.

Partido político "Frente Brasileira Unida", representado por seu Presidente, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, III, a e § 3.º, da CF/88, art. 541 e s. do CPC e na Lei n. 8.038/90, interpor RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face do venerando acórdão proferido (fls. _____), que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Decreto n. 1.968, formulado nos autos da ação direta de inconstitucionalidade em epígrafe.

Requer seja Recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária, o Governador do Estado X, para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após, seja o recurso admitido e encaminhado com as inclusas razões ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Termos em que,
Pede deferimento.
Local e data.
Advogado/OAB

Razões de Recurso Extraordinário

Dados da ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Recorrente: Partido político "Frente Brasileira Unida" (autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade)

Recorrido: Governador do Estado X.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

Colenda Turma,

Íncritos Julgadores,

Partido político "Frente Brasileira Unida", não se conformando com o respeitável acórdão de fls., respeitosamente apresenta as razões do presente Recurso Extraordinário.

I – BREVE RESUMO

O Governador do Estado X editou o Decreto n. 1.968 quarenta dias após intensa movimentação popular que culminou em atos de violência, vandalismo e depredação. O referido decreto dispõe que deve haver prévia comunicação às autoridades com a identificação completa de todos os participantes do evento, sob pena de desfazimento da manifestação. Além disso, prevê a revista pessoal de todos, como forma de preservar a segurança dos participantes e do restante da população. Em razão da violação a normas da Constituição do Estado X referentes a direitos e garantias individuais e coletivos, normas estas que reproduzem disposições constantes da Constituição da República, o partido político, ora Recorrente, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado X. Porém, o Plenário do Tribunal de Justiça, por maioria, julgou improcedente o

pedido formulado de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do decreto estadual, por entender que são compatíveis com a Constituição do Estado. Os Desembargadores que registraram seus votos consignaram, ainda, a impossibilidade de propositura de ação direta tendo por objeto um decreto estadual.

II – DA REPERCUSSÃO GERAL

Preliminarmente, importante destacar que o recurso preenche o requisito da repercussão geral e há relevância do ponto de vista jurídico e social, pois a questão diz respeito à aplicação do princípio da simetria federativa em relação aos direitos fundamentais titularizados por todos. Os Estados, ao elaborarem suas Constituições, devem observar as regras de repetição obrigatória estabelecidas na Constituição Federal.

A questão, jurídica e social, transcende o interesse das partes, pois o Decreto n. 1.968 cria restrições excessivas e desproporcionais ao exercício de direitos fundamentais assegurados e o faz sem que sequer haja previsão em lei.

Preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3.º, da CF/88 e do art. 543-A, §§ 1.º e 2.º, do CPC, o recurso deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

III – DO CABIMENTO DO RECURSO

Cabível o presente recurso, nos termos do art. 102, III, a, da CF/88, pois o Decreto n. 1.968 não se presta a dar executoriedade ou regulamentar lei estadual. Ao revés,

pretendeu o Governador do Estado X com o referido decreto criar restrições excessivas e desproporcionais ao exercício de direitos fundamentais assegurados. Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência dessa Corte que o decreto autônomo, como ato normativo primário que inova a ordem jurídica, é passível do controle abstrato na ação direta de inconstitucionalidade originariamente proposta no Tribunal de Justiça do Estado X.

Saliente-se que o recurso foi interposto tempestivamente, nos

termos do art. 508 do CPC.

IV – DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da questão constitucional está devidamente preenchido, pois na origem, ou seja, na ação direta de inconstitucionalidade proposta no Tribunal de Justiça do Estado X, pedia-se a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do decreto estadual, por entender que são compatíveis com a Constituição do referido Estado.

Assim, a matéria foi devidamente questionada e esgotada na instância inferior.

V – DO DIREITO

Os Estados-membros têm capacidade de autogoverno e de auto-organização, nos termos do art. 25, caput, da CF/88. São detentores de autonomia política e administrativa, organizam-se e regem-se pelas Constituições Estaduais, observando os princípios da Constituição Federal em razão do princípio da simetria ou paralelismo constitucional.

Tal princípio estabelece que os Estados, ao elaborarem suas Constituições, não poderão estabelecer limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, devem reproduzir as garantias e direitos fundamentais, o processo legislativo, instituir as ações diretas de controle tendo como parâmetro a Constituição do Estado (art. 125, § 2.º, da CF/88), entre outros.

O presente recurso se insurge contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que, ao julgar a ADIn, interpretou a norma da Constituição da República repetida na Constituição Estadual, mas o fez, no presente caso, em sentido incompatível com o da Constituição da República.

O Governador do Estado X, ao editar o Decreto n. 1.968, exerceu sua

competência legislativa, que tem amparo na Lei Maior (art. 84, VI). Não se questiona tal competência e ademais, já pacificado o entendimento da possibilidade da existência dos denominados decretos autônomos, ou seja, o decreto objeto da ADIn não é um ato de regulamentação da lei, mas ato normativo primário, que inova autonomamente a ordem jurídica. Repisa-se, não se questiona a constitucionalidade de um decreto regulamentar que visa a dar execução fiel a uma lei. A ação de inconstitucionalidade foi proposta em face do Decreto Estadual de número 1.968, que não pretendia regulamentar qualquer lei estadual, mas, sim, estabelecer, como ato normativo primário, restrições a direitos fundamentais de toda a coletividade, sob a justificativa de disciplinar a participação da população em protestos de caráter público.

E, nesse sentido, o art. 5.º, II, da CF/88 estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Demonstrado está que o Decreto n. 1.968 viola o princípio da legalidade, pois não se pode criar restrição a direito senão em virtude de lei.

Com a participação que atingiu mais de um milhão de pessoas, a população do Estado X vinha se reunindo em protestos nas ruas. Tais protestos, ao final, resultaram em atos de vandalismo e depredação do patrimônio público e particular. Pois bem, ao pretender disciplinar a realização desses protestos, incorreu o Governador do Estado em flagrante desrespeito a direitos fundamentais expressamente protegidos pela Constituição Federal e, por conseguinte na Constituição Estadual, posto que de observância e reprodução obrigatórias. Como parâmetro, deve-se observar o que a Constituição Federal prevê acerca do direito de reunião em locais abertos ao público e da liberdade de expressão, e, neste ponto, reputa-se como necessária a transcrição que segue:

Art. 5.º, XVI, da CF/88:

“todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;”

Art. 5.º, IV, da CF/88:

“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;”

Observa-se que o Governador do Estado, ao tratar do tema, não poderia, por intermédio do Decreto n. 1.968 exigir: (a) prévia comunicação às autoridades com a identificação completa de todos os participantes do evento, sob pena de desfazimento da manifestação; (b) a revista pessoal de todos, como forma de preservar a segurança dos participantes e do restante da população.

Tais exigências, além de inconstitucionais, violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. De fato, foram praticados atos de vandalismo e depredações, e tais práticas devem ser coibidas e os autores de tais atos, punidos. Porém, ainda que se possa entender possível a restrição ao direito de reunião, isto deve ser feito por lei e da maneira menos gravosa e, ademais, a restrição imposta não pode inviabilizar o próprio direito constitucionalmente previsto, sob pena de inconstitucionalidade.

Em que pese o respeitável acórdão proferido pela constitucionalidade dos dispositivos do decreto, reitera-se, neste recurso, a necessidade de afastar as restrições impostas ao direito de reunião e à liberdade de expressão, pois ofendem os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A Constituição Federal já prevê a situação para se restringir o direito, quando diz que não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, e que deve haver o prévio aviso à

autoridade competente.

Patente é a inconstitucionalidade do Decreto n. 1.968, que foi atacado na ação de inconstitucionalidade proposta no Tribunal de Justiça do Estado X, que proferiu o acórdão que ora se pretende ver reformado.

VI – DO PEDIDO

Diante do exposto, o Recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para a reforma do acórdão para a declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 1.968 editado pelo Governador do Estado X.

Requer, ainda, a notificação do Ministério Público.

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.25. XIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: O Presidente da República editou o Decreto n. 5.555, estabelecendo a obrigatoriedade, como exigência à obtenção do diploma de graduação em engenharia, de um elevado aproveitamento nas disciplinas do curso, e, para inscrição nos Conselhos Regionais, a conclusão de uma pós-graduação com carga horária mínima de 480 horas de aula.
- Ação: Ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar – art. 102, I, a e p, da CF/88, art. 10 da Lei n. 9.868/99.
- Competência: Supremo Tribunal Federal, art. 102, I, a, da CF/88.
- Legitimidade Ativa: Confederação Sindical dos Engenheiros (art. 103, IX,

da CF/88 e art. 2.º, IX, da Lei n. 9.868/99).

– Legitimidade Passiva: Presidente da República, que editou o Decreto n. 5.555 (conforme art. 6.º da Lei n. 9.868/99).

– Fundamentos: art. 102, I, a (foro competente) e p (cautelar na ADIn), art. 103, IX (legitimação ativa) todos da CF/88 e arts. 2.º e 10 da Lei n. 9.868/99, princípio da separação de poderes, princípio da legalidade (art. 5.º, II, e art. 37, caput, ambos da CF/88), princípio da liberdade de exercício de atividades ou profissões (art. 5.º, XIII, da CF/88), princípios da razoabilidade/proporcionalidade.

– Outros requisitos formais da peça: concessão da medida cautelar para suspender o decreto; requisição de informações da autoridade que praticou o ato impugnado, o Presidente da República, para manifestar-se sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99 e sobre o mérito da presente ação, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99; intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República (art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e do art. 103, §§ 1.º e 3.º, da CF/88); a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade do Decreto n. 5.555; cumprimento do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 (cópias anexas). Valor da causa: R\$ 1.000,00. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

A Confederação Sindical dos Engenheiros, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua _____, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na Rua _____, n. _____, Bairro _____, local indicado para receber intimações (art. 39 do CPC), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 103, IX, art. 102, I, a e p, da CF/88,

art. 2.º, IX, e art. 10 da Lei n. 9.868/99 e art. 282 e s. do CPC, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR em face do senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA com endereço para comunicações na rua _____, n. _____, responsável pela edição do Decreto Presidencial n. 5.555 que contraria diretamente a Constituição, conforme a seguir será demonstrado:

I – DA NORMA IMPUGNADA

O Presidente da República editou o Decreto n. 5.555, estabelecendo a obrigatoriedade, como exigência à obtenção do diploma de graduação em engenharia, de um elevado aproveitamento nas disciplinas do curso, e, para inscrição nos Conselhos Regionais, a conclusão de uma pós-graduação com carga horária mínima de 480 horas de aula. A medida tem por objetivo conferir maior controle sobre a formação do profissional, num momento de expansão das obras de infraestrutura no país.

II – FORO COMPETENTE

O art. 102, I, a, da CF/88 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)"

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA e PERTINÊNCIA TEMÁTICA

O Autor da presente ação é a Confederação Sindical dos Engenheiros e, desse modo, nos termos do art. 103, IX, da CF/88 e do art. 2.º, IX, da Lei n. 9.868/99, é parte legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, sendo considerado legitimado especial ou reservado.

No caso, a Confederação Sindical dos Engenheiros é entidade de classe de âmbito nacional, pois reúne 18 (dezoito) Federações de sindicatos em diferentes Estados, cada uma com ao menos 10 (dez) sindicatos. Assim está demonstrado o preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 533 a 535 da CLT ("as Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 Federações" e "é facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em Federação").

Além disso, há a pertinência temática, que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato. Desse modo, existe pertinência temática, na medida em que a Confederação sindical atuará na defesa do interesse de sua classe diretamente atingida pelo decreto impugnado.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva da ação direta de inconstitucionalidade em referência é o Presidente da República que editou o Decreto n. 5.555.

V – POSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO

Cumprir destacar que os decretos do chefe do Poder Executivo podem ser regulamentares ou autônomos (art. 84, IV, da CF/88). Na jurisprudência do STF, somente se admite a propositura de ação direta tendo por objeto decreto autônomo, aquele que inova autonomamente na ordem jurídica, e não o decreto que tenha por escopo regulamentar a lei. Isso porque o decreto regulamentar não possui autonomia normativa.

Se o decreto apenas fere a lei, ou desborda dos limites regulamentares, abrir-se-á a via do controle de legalidade, e não do controle de constitucionalidade.

Desse modo, há a autonomia normativa do Decreto em questão, tendo em vista a ausência de lei da qual decorra aquele ato normativo.

É corrente majoritária na doutrina e na jurisprudência que os decretos, no ordenamento jurídico brasileiro, são considerados normas infraconstitucionais, sendo plenamente possível o seu controle de constitucionalidade por via de ação direta de inconstitucionalidade.

VI – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO DECRETO N. 5.555

No mérito, o decreto presidencial viola o princípio da separação de poderes, pois ingressa em atividade legislativa não autorizada pela Constituição, agindo como se fosse o Poder Legislativo.

Também viola o princípio da legalidade (art. 5.º, II, da CF/88), pois

restringe direitos e disciplina matéria sujeita à lei em sentido formal. No mesmo sentido, é a previsão dos arts. 5.º, LIV, e 37, caput, do texto constitucional vigente.

Ademais, afronta o princípio da liberdade de exercício de atividades ou profissões, que estabelece ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (arts. 1.º e 5.º, XIII, da CF/88).

Além disso, o decreto presidencial viola o princípio da razoabilidade, pois ainda que adequada à finalidade declarada, falha nos subprincípios da necessidade, que impõe a utilização, dentre as possíveis, da medida menos gravosa para atingir determinado objetivo, bem como da proporcionalidade em sentido estrito, que impõe a análise da relação custo-benefício da norma avaliada, de modo que o ônus imposto pela norma seja inferior ao benefício por ela engendrado, sob pena de inconstitucionalidade.

Conclui-se que é patente a inconstitucionalidade, pois um ato normativo (decreto presidencial) invade a esfera de atuação da lei para restringir o exercício de atividade profissional.

VII – DA MEDIDA CAUTELAR

Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a determinação do art. 102, I, p, da CF/88 e do art. 10 da Lei n. 9.868/99.

Os pressupostos à concessão da medida são o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, que restam evidenciados. O primeiro está demonstrado pela violação às normas constitucionais que estabelecem o princípio da separação de poderes, o princípio da

legalidade e a liberdade de exercício de profissão. E o segundo se verifica pela proximidade da

conclusão do curso de milhares de bacharéis que, em virtude de exigência sem previsão legal, estarão impossibilitados de concluir o curso e/ou obter a inscrição nos Conselhos Regionais.

VIII – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que o Supremo Tribunal Federal determine:

a) a intimação do Presidente da República para que, como autoridade responsável pela edição do Decreto n. 5.555, manifeste-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99;

b) a concessão de medida cautelar com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender a eficácia do Decreto n. 5.555 (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

c) a intimação do Presidente da República para que, como autoridade responsável pela edição do Decreto n. 5.555, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

d) a intimação do excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 3.º, da CF/88;

e) a intimação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, para que emita seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da CF/88;

f) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade do Decreto n. 5.555 (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99).

Valor da causa: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Termos em que,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.26. XIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: João e José são pessoas com deficiência física e concluíram curso de nível superior. Com a abertura de vagas para preenchimento de cargos vinculados ao Ministério da Agricultura, postularam a sua inscrição no número que deveria ser reservado, por força de disposição em lei federal, aos deficientes físicos de acordo com o grau de deficiência que têm. Porém, tal pedido foi indeferido por ato do próprio Ministro de Estado, aduzindo que a citada lei, apesar de vigente há 2 (dois) anos e com plena eficácia, não se aplicaria àquele concurso, pois não houve previsão no seu edital. Não se conformando com a decisão, impetraram mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. A decisão proferida, por maioria de votos, denegou a segurança pretendida, dando razão ao Ministro de Estado. No prazo legal, apresentaram embargos de declaração, que não foram providos. Assim, inconformados, apresentaram o presente Recurso Ordinário.

– Ação: Recurso Ordinário Constitucional (art. 102, II, a, da CF/88 e art. 539 do CPC).

– Competência: Supremo Tribunal Federal (art. 102, II, a, da CF/88).
Observação: a peça de interposição deve ser endereçada ao STJ.

– Legitimidade Ativa: João e José.

– Legitimidade Passiva: Ministro de Estado.

– Fundamentos: art. 5.º, caput, II (princípio da isonomia e princípio da legalidade), art. 37, VIII (reserva de vagas para os portadores de

deficiência), ambos da CF/88; Lei n. 7.853/89 (art. 2.º, III, c); Lei n. 8.112/90 (art. 5.º, § 2.º) e Decreto n. 6.949/2009 (art. 27, 1, g).

– Outros requisitos formais da peça: Peça de interposição – endereçamento ao STJ; receber e processar o recurso; intimar a parte contrária, remessa dos autos ao STF, juntar custas (preparo). Razões – cabimento do recurso, conhecimento e provimento para reforma da decisão. Requerimento de intervenção do Ministério Público. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 511, 539 e 540 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 1.007, 1.027 e 1.028 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(espaço de 5 linhas)

Dados da Ação: Mandado de Segurança.

Recorrente: João e José.

Recorrido: Ministro de Estado.

João e José, já qualificados, por seu advogado que esta subscreve, não se conformando com a respeitável decisão denegatória do mandado de segurança em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, II, a, da Constituição Federal, tempestivamente, interpor RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL em face do Ministro de Estado, já qualificado, pelas razões de fato e de direito apresentadas nas razões anexas.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a parte contrária para que ofereça, dentro do prazo legal, as contrarrazões e, após seja o recurso encaminhado com as inclusas razões ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a juntada das custas de preparo e porte de remessa e retorno.

Nestes termos,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

RAZÕES DO RECURSO

Dados da Ação:

Recorrente: João e José.

Recorrido: Ministro de Estado do Ministério da Agricultura.

Supremo Tribunal Federal,

Íncritos Julgadores,

João e José, não se conformando com o venerando acórdão que denegou o mandado de segurança por eles impetrado, respeitosamente, apresentam as razões do presente recurso ordinário constitucional:

I – BREVE RESUMO

João e José têm deficiência física e formação em curso superior completo. Com a abertura de vagas para preenchimento de cargos vinculados ao Ministério da Agricultura, postularam a inscrição no número que deveria ser reservado, por força de disposição em lei federal, aos deficientes físicos de acordo com o grau de deficiência que

têm. Porém, tal pedido foi indeferido por ato do próprio Ministro de Estado, aduzindo que a citada lei, apesar de vigente há dois anos e com plena eficácia, não se aplicaria àquele concurso, pois não houve previsão no seu edital. Não se conformando com a decisão, impetraram Mandado De Segurança no Superior Tribunal de Justiça. A segurança, por maioria de votos, foi denegada, dando-se razão ao Ministro de Estado. No prazo legal, apresentaram embargos de declaração, que não foram providos. Assim, inconformados, apresentam o presente Recurso Ordinário em razão da violação de preceitos constitucionais e legais que reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho e a reserva de vagas para os portadores de deficiência.

II – DO DIREITO

Não pode prosperar a respeitável decisão que denegou o mandado de segurança, por se encontrar desprovida de respaldo constitucional e legal.

O art. 102, II, a, da CF/88 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal (...): II – julgar, em recurso ordinário: (...) a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, quando denegatória a decisão;”

No caso em questão, a impetração do mandado de segurança era cabível, não havendo razão jurídica plausível para ter sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal e visa a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder

Público.

O Ministro de Estado é uma autoridade pública e, ao negar a inscrição de João e José no número de vagas que deveria ter sido reservado aos deficientes físicos, por ausência de previsão no edital do certame, violou dispositivos constitucionais e legais.

O art. 5.º, caput, da Constituição Federal vigente estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o corolário do princípio da igualdade está em tratar de modo desigual os desiguais. Não há dúvida que a Constituição e a lei já fizeram tal tratamento ao reconhecer o direito ao trabalho das pessoas com deficiência.

Prestigiando essa situação, foi aprovada, com status de emenda constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nessa toada, foi promulgado o Decreto n. 6.949 de 25-8-2009, que estabelece como princípios gerais, entre outros, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e a igualdade de oportunidades à pessoa com deficiência.

Há, ainda, previsão para que os Estados Partes, com relação ao trabalho e ao emprego, adotem medidas apropriadas para empregar pessoas com deficiência no setor público, confira-se o art. 27, 1, g, do Decreto n. 6.949/2009.

Ademais, a própria Lei Maior em seu art. 37, VIII, é expressa ao consignar que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Importante, neste ponto, salientar que já há regramento legal para possibilitar a participação das pessoas portadoras de deficiências nos concursos públicos e, por força do princípio da legalidade (inciso II do art. 5.º da CF/88), teria que ter sido observado pelo Ministro de Estado

responsável pelo certame. Em outras palavras o edital não poderia ter sido omissivo quanto à reserva de vagas para portadores de deficiência.

Vejam os o que o ordenamento infraconstitucional prevê acerca do tema, em especial o que se transcreve:

1 – Na Lei n. 7.853/89:

“Art. 2.º: Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos (...)

III – na área da formação profissional e do trabalho: (...)

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência;”

2 – E, ainda, na Lei n. 8.112/90:

“Art. 5.º: São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...)

§ 2.º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso”.

Desse modo, não há dúvida que a exigência de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais em concurso público se impõe e deve ser observada. E mais, como mandamento constitucional a sua inobservância fere a dignidade da pessoa humana de todos e não só do deficiente.

Assim, no presente caso, os Recorrentes estão inconformados com o ato praticado pelo Ministro de Estado, que desrespeitou a Constituição e a lei, violando os princípios da administração pública e as normas que regem a participação dos deficientes nos concursos públicos, em especial a reserva de vagas para os portadores de deficiência.

Por fim, infere-se, de todo o exposto, que o pedido de inscrição no número que deveria ser reservado, por força de disposição em lei federal, aos deficientes físicos de acordo com o grau de deficiência, tem respaldo constitucional e legal. No mesmo sentido, caminham a doutrina e a jurisprudência.

Os Recorrentes, conforme já noticiado, impetraram Mandado de Segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, órgão competente de forma originária, para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada, ato que autoriza a interposição do presente Recurso Ordinário Constitucional, pois o ato do Ministro de Estado é inconstitucional e ilegal.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, os Recorrentes requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se a respeitável decisão recorrida possibilitando a inscrição no número de vagas reservado aos deficientes físicos, e determinando a alteração do edital de modo que cumpra as previsões legais.

Requer-se a intervenção do Ministério Público.

Nestes termos,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.27. XV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: João, sócio-diretor da empresa MM Ltda., foi surpreendido com uma notificação do Município X para pagar multa de R\$

10.000,00 (dez mil reais) e encerrar as atividades empresariais na cidade em um período de até 90 (noventa) dias. Atônito, João, ao ler a notificação, descobre que foi aberto um processo administrativo para apurar denúncia de violação ao Decreto Municipal n. 5.678, de 2014, sem lastro em prévia lei municipal, que veda a instalação de lojas de produtos eletrônicos em bairros de perfil residencial, determina a aplicação de multa e estabelece um prazo de até 90 (noventa) dias para o encerramento das atividades empresariais no Município. Após a abertura do processo e a instrução com registro fotográfico, foi proferida decisão, pelo Secretário de Posturas do Município, sem prévia oitiva da empresa, determinando a aplicação da multa, no valor indicado, bem como fixando o prazo de 90 (noventa) dias para o encerramento das atividades empresariais, sob pena de interdição e lacre do estabelecimento, na forma do decreto municipal. Você foi contratado como advogado para ajuizar a medida necessária à defesa dos interesses do cliente – afastar a exigência da multa e garantir a permanência das atividades empresariais.

- Ação: Mandado de Segurança.
- Competência: Juízo de Fazenda Pública da Comarca X (admitindo-se, ainda, o endereçamento ao “Juízo Cível” ou “Juízo”).
- Legitimidade Ativa: MM Ltda. (representada por seu sócio-diretor João).
- Legitimidade Passiva: Secretário de Posturas.
- Fundamentos: inconstitucionalidade do decreto, por violação ao princípio da legalidade – art. 5.º, II, ou art. 37 da CF/88; violação ao contraditório e ampla defesa – art. 5.º, LV, da CF/88; violação ao devido processo legal – art. 5.º, LIV, da CF/88; inconstitucionalidade do decreto, por ofensa à razoabilidade/ proporcionalidade.
- Fundamentos para a concessão da liminar – fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida final, caso não seja deferida a liminar.
- Outros requisitos formais da peça: notificação da autoridade coatora para

prestar informações; ciência ao órgão de representação judicial do Município; concessão da medida liminar para suspender o ato do secretário de posturas; procedência do pedido para afastar a exigência da multa e garantir a permanência das atividades empresariais; requerimento de oitiva do Ministério Público. Valor da Causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

ATENÇÃO

Os arts. 14, parágrafo único, 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, § 2.º, 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA X (OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

MM Ltda. (representada por seu sócio-diretor João), com sede na Rua _____, Bairro _____, nesta _____, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, no art. 282 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face do Secretário de Posturas do Município X, pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

A empresa MM Ltda., ora Impetrante, é uma loja que atua no ramo de produtos eletrônicos. O seu sócio-gerente, Sr. João, recebeu uma notificação, do Município no qual está instalada, para pagar multa de R\$ 10.000,00 e encerrar as atividades no prazo de 90 dias. A referida notificação resultou de processo administrativo que apurou denúncia de violação ao Decreto Municipal n. 5.678, de 2014, que veda a instalação de lojas de produtos eletrônicos em bairros de perfil residencial, determina a aplicação de multa e o fechamento da empresa. A cópia integral do processo administrativo acompanhou a notificação, o que permitiu que se verificasse que foi instruído com o registro fotográfico e que não houve a prévia oitiva da empresa, permitindo que exercesse o direito de defesa. Também se apurou que não há lei municipal prévia que dê lastro ao Decreto Municipal n. 5.678, de 2014.

Como se vê há violação a princípios constitucionais e urgência em se obter a tutela judicial.

II – DO DIREITO

A Constituição Federal, no inciso II do art. 5.º, determina que:

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Denota-se na Norma Fundamental o princípio da legalidade, que determina a existência de lei para reger os atos no Estado brasileiro.

O Decreto Municipal n. 5.678, de 2014, que veda a instalação de lojas de produtos eletrônicos em bairros de perfil residencial, determina a aplicação de multa e estabelece prazo para o encerramento das atividades empresariais, foi editado sem que houvesse lei prévia a ser regulamentada.

Há, portanto, desrespeito ao citado princípio constitucional.

Além disso, no art. 37 da Constituição Federal vigente há a previsão de que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos entes federativos, o que engloba os Municípios, deve respeitar, dentre outros princípios, a legalidade.

A Constituição Federal, no inciso LIV do art. 5.º, incorporou o princípio do devido processo legal, que tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, estes, também, no inciso LV do referido artigo.

E a observância do devido processo legal, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório, deve ser garantida a todos, seja no processo judicial, seja no processo administrativo, de sorte que nenhuma penalização poderá ser imposta sem que sejam observados e se garanta a possibilidade de defesa. A Impetrante deveria ter ciência inequívoca do processo administrativo instaurado, ser informada dos fatos e das sanções previstas, o que não ocorreu.

No presente caso, a empresa MM Ltda. foi alvo de um processo administrativo e a despeito de a administração municipal conhecer o seu endereço, o referido processo caminhou sem que lhe fosse dado o direito de se defender. Nessas condições, é claro que não se respeitou o justo processo, que exige que se dê à parte contrária o conhecimento das acusações e prazo em que possa apresentar os argumentos que porventura tenha para se defender.

Prosseguindo em seus abusos, a Administração Pública estabelece uma elevada multa e, pior ainda, impede as suas atividades empresariais. As regras estabelecidas no decreto, sob responsabilidade do Secretário de Posturas, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que determinam a utilização da ponderação e da lógica na aplicação das normas.

Podem ser exigidos requisitos razoáveis e proporcionais para o desenvolvimento das atividades empresariais, o que não condiz com a

restrição não justificada do decreto de limitar o local para instalação de empresas.

Assim, embora seja possível um decreto estabelecer regras, não se pode impor restrição sem respaldo em lei formal, mormente quando se estabelece restrições à livre concorrência e à livre-iniciativa.

No presente caso, com base no decreto, a Impetrante teve negado o exercício de seu direito constitucional à livre concorrência e à livre-iniciativa.

Novamente, tal situação afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois inexistente uma correlação lógica entre o fator discriminador utilizado, bairro residencial, e a atividade empresarial desenvolvida, loja de produtos eletrônicos.

Portanto, não constando em lei as regras, que devem ser razoáveis e proporcionais, a serem observadas e se houver restrição ao exercício de direitos constitucionais, não pode um decreto impor limitações, uma vez que o art. 37 da Constituição Federal estabelece uma reserva legal, e apenas a lei, em sentido formal, pode determinar critérios específicos a serem observados e que, se descumpridos, podem acarretar sanções e multas.

Patente é o direito líquido e certo do Impetrante e ficou demonstrado que a Autoridade Coatora o desrespeitou ao aplicar a multa e estabelecer prazo para o encerramento das atividades empresariais, ofendendo expressamente o disposto nos arts. 5.º, II, LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5.º, LXIX, assegura o remédio constitucional do mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (...)”, e todos os entes federativos e autoridades

públicas ao agir devem respeitar os direitos e garantias, assegurando a todos o mínimo necessário para o seu exercício.

Para a proteção de todos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, há garantias que, no caso em tela, foram flagrantemente desrespeitadas.

No decreto foram criadas restrições que não são razoáveis nem proporcionais, devendo, desse modo, ser incidentalmente declarado inconstitucional, afastando-se sua aplicação e anulando o ato coator praticado, autorizando-se que o Impetrante mantenha as suas atividades empresariais normalmente.

DA LIMINAR

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

Assim, está presente o *fumus boni iuris*, pois a inconstitucionalidade é manifesta, uma vez que foram violados os princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa, o devido processo legal, bem como o *periculum in mora*, pois houve a aplicação da multa, no valor de R\$ 10.000,00, e foi fixado prazo para o encerramento das atividades empresariais, sob pena de interdição e lacre do estabelecimento.

Com tais ponderações, justifica-se o pedido da liminar.

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência se digne:

a) conceder in limine, a segurança requerida, com a expedição do competente ofício determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais, assegurando à Impetrante prosseguir com suas atividades empresariais e suspendendo a exigência da multa, até o julgamento do presente mandado;

b) determinar a notificação pessoal da autoridade coatora, o Secretário de Posturas do Município X, para prestar informações no prazo legal de dez dias, como de direito, entregando-lhe a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia;

c) dar ciência do feito ao representante judicial da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

d) determinar a intimação do Ministério Público para oferecer parecer, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009;

e) acatar as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia do ato impugnado);

f) fixar multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança e a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo de exercer as atividades empresariais no local em que está instalada, cancelando-se a multa imposta.

Dá-se à causa, para efeitos fiscais e de alçada, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.28. XVI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: A Assembleia Legislativa do Estado Y edita, em 1.º-3-2015, a Lei n. 8.888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos. Ressalta-se que não há qualquer lei complementar que autorize excepcionalmente ao Estado Y dispor sobre a questão, sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção desses postes de energia, cujo serviço fica às expensas dos usuários interessados. Há notícia também de que o Governador do Estado Y vetou integralmente o projeto de lei estadual, mas restou superado pela vontade da Assembleia Legislativa do Estado, que, ao final, promulgou a referida Lei. Diante da relevância e da urgência da questão, o partido político “Para Frente Brasil” – PFB, representado unicamente por um Deputado Federal, procura os seus serviços para objetar contra a lei estadual, por entender que a norma estadual viola diretamente a Constituição Federal. Considerando os dados acima, formule a peça adequada, fazendo introito sobre a legitimidade ativa e observando que o partido entende ser urgente a questão.

– Ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIn (art. 102, I, a, da Constituição Federal).

– Competência: Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a, da Constituição Federal).

– Legitimidade Ativa: Partido Político “Para Frente Brasil” – PFB.

– Legitimidade Passiva: Governador do Estado Y e da Assembleia Legislativa do Estado Y, responsáveis pela edição da Lei n. 8.888.

- Fundamentos: art. 21, XII, b, da Constituição Federal – domínio da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia elétrica; art. 22, IV, da Constituição Federal – competência privativa da União para dispor legislativamente sobre energia; art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal – competência da União para definir, por meio de lei, a política tarifária a ser observada na exploração deste serviço.
- Outros requisitos formais da peça: pedido de concessão de medida cautelar e, ao final, pedido de declaração de inconstitucionalidade. Devem ser requeridas as oitivas do Advogado-Geral da União e parecer do Ministério Público.

ATENÇÃO

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

O partido político “Para Frente Brasil” – PFB, com representação no Congresso Nacional, pessoa jurídica de direito privado, com sede (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____) local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 103, VIII, no art. 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 2.º, VIII, e 10 da Lei n. 9.868/99 e no art. 282 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR em face do senhor Governador do Estado Y e da Assembleia Legislativa do Estado Y, com endereços para intimações (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), responsáveis pela edição da Lei n. 8.888, que afronta dispositivos da Constituição Federal vigente, conforme a seguir será demonstrado:

I – DA NORMA IMPUGNADA

A Assembleia Legislativa do Estado Y editou, em 1.º de março de 2015, a Lei n. 8.888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos. O Governador vetou integralmente o projeto de Lei Estadual, mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, que, ao final, promulgou a referida lei.

Ocorre que não há qualquer lei complementar que autorize, excepcionalmente, ao Estado Y dispor sobre a questão, sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção desses postes de energia, cujo serviço fica às expensas dos usuários interessados.

Ao promulgar, nesses termos, a Lei n. 8.888, afrontou-se a Constituição Federal como se demonstrará a seguir.

II – FORO COMPETENTE E DO CABIMENTO DA ADIN

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

Restou, ainda, demonstrado o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, pois o controle abstrato de constitucionalidade tem como objeto a Lei Estadual n. 8.888.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

O Autor da presente ação é o Partido Político “Para Frente Brasil” – PFB, que está representado, no Congresso Nacional, por um Deputado Federal e, desse modo, nos termos do art. 103, VIII, da CF/88 e do art. 2.º, VIII, da Lei n. 9.868/99, é parte legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. O partido político é legitimado neutro ou universal e, assim, não há a exigência de se demonstrar a pertinência temática.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva da ação direta de inconstitucionalidade em referência é do Governador do Estado Y e da Assembleia Legislativa do Estado Y, que são os responsáveis pela edição da Lei n. 8.888.

V – INCONSTITUCIONALIDADE

A Lei n. 8.888 padece do vício de inconstitucionalidade formal, pois tem como objeto matéria de competência legislativa privativa da União, consoante se depreende do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

Sabe-se que a competência privativa da União é delegável aos Estados, e essa delegação se aperfeiçoa por intermédio de lei complementar (parágrafo único do art. 22 da CF/88) que, para o caso em tela, não existe.

Temos, então, o referido art. 22 que prevê:

“Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

Desse modo, o Estado Y, ao dispor sobre matéria de competência da União, sem que haja lei complementar a autorizar os Estados a legislarem sobre questão específica acerca de energia, agiu indevidamente, e a Lei n. 8.888 é inconstitucional e não pode permanecer vigente no ordenamento jurídico.

Prosseguindo, a lei vulnera, ainda, a competência administrativa da União estabelecida no art. 21 da CF/88, no caso, especificamente na alínea b do inciso XII.

Ressalta-se que o art. 21 da CF/88 estabelece a denominada competência exclusiva, ou seja, somente a União pode legislar, não se admitindo qualquer delegação.

Vejam, então, que é a União que pode explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia. Assim, não pode uma lei estadual estabelecer obrigações para a concessionária, sob pena de desrespeitar a distribuição constitucional da competência administrativa, resultando, também, em uma inconstitucionalidade formal.

Nessa toada, a Lei n. 8.888, ao estabelecer para a concessionária do serviço a obrigação de remover os postes de sustentação da rede elétrica que estejam causando transtornos ou impedimentos a particulares, sem custo para o usuário, vai de encontro ao art. 175, parágrafo único, III, da CF/88 e faz uma ingerência indevida na política tarifária, cuja tarefa é da União, por meio de lei.

Desse modo, restou demonstrado que a Lei Estadual n. 8.888 é inconstitucional.

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a determinação do art. 102, I, p, da CF/88 e do art. 10 da Lei n. 9.868/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade constante da inicial em virtude da patente contrariedade à Constituição Federal (*fumus boni iuris*). Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face do dano irreparável, pois a lei criou uma obrigação para as concessionárias, que tem um elevado custo para ser realizada e que não estava prevista nos contratos de concessão, o que pode alterar o custeio da prestação do serviço no setor elétrico.

VII – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que o Supremo Tribunal Federal determine:

a) a concessão de medida cautelar com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender os efeitos da Lei n. 8.888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede

elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

b) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que, como autoridades responsáveis pela lei, manifestem-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99;

c) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 8.888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de

fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

d) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que se manifestem, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

e) a intimação do excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 3.º, da CF/88;

f) a intimação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, para que emita seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da CF/88.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.29. XVII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: O Partido Político “Z”, que possui apenas três representantes na Câmara dos Deputados, por entender presente a violação de regras da CF/88, o procura para que, na qualidade de advogado especialista em direito constitucional, se posicione sobre a possibilidade de ser obtida alguma medida judicial em face da Lei Estadual “Y”, de janeiro de 2015, que contém 3 (três) artigos: art. 1.º, regras temporais sobre a criação de partidos políticos; em seu art. 2.º fica retirada a autorização para que partidos políticos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado; e, por fim, em seu art. 3.º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação.
- Ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIn (art. 102, I, a, da Constituição Federal) ou Parecer.
- Competência: Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a, da Constituição Federal).
- Legitimidade Ativa: o Partido Político “Z” representado pelo Presidente de sua Comissão Executiva Nacional.
- Legitimidade Passiva: Lei Estadual “Y” – Governador e Assembleia Legislativa.
- Outros requisitos formais da peça: pedido de concessão de medida cautelar e, ao final, pedido de declaração de inconstitucionalidade. Devem ser requeridas as oitivas do Advogado Geral da União e parecer do Ministério Público.

ATENÇÃO

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(espaço de cinco linhas)

O partido político “Z”, representado pelo presidente de sua Comissão Executiva Nacional, com representação no Congresso Nacional, pessoa jurídica de direito privado, com sede (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 103, VIII, e 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 2.º, VIII, e 10 da Lei n. 9.868/99 e no art. 282 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR em face do senhor Governador do Estado Y e da Assembleia Legislativa do Estado Y, com endereços para intimações (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), responsáveis pela edição da Lei Estadual “Y” que afronta dispositivos da Constituição Federal vigente, conforme a seguir será demonstrado:

I – DA NORMA IMPUGNADA

Está em vigor a Lei Estadual “Y”, de janeiro de 2015, que contém 3 (três) artigos sobre novas regras eleitorais, sendo estabelecidas, em seu art. 1.º, regras temporais sobre a criação de partidos políticos; em seu art. 2.º fica retirada a autorização para que partidos políticos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado; e, por fim, em seu art. 3.º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação.

Ao promulgar, nesses termos, a Lei Estadual “Y”, afrontou-se a Constituição Federal, como se demonstrará a seguir.

II – FORO COMPETENTE E DO CABIMENTO DA ADIN

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

Restou, ainda, demonstrado o cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois o controle abstrato de constitucionalidade tem como objeto a Lei Estadual “Y”.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

O Autor da presente ação é o Partido Político “Z”, que está representado, no Congresso Nacional, por três Deputados Federais e, desse modo, nos termos do art. 103, VIII, da CF/88 e do art. 2.º, VIII, da Lei n. 9.868/99, é parte legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. O partido político é legitimado neutro ou universal e, assim, não há a exigência de se demonstrar a pertinência temática.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva da ação direta de inconstitucionalidade em referência é do Governador do Estado Y e da Assembleia Legislativa do Estado Y, que são os responsáveis pela edição da Lei “Y”.

V – INCONSTITUCIONALIDADE

A Lei Estadual “Y” padece do vício de inconstitucionalidade formal, pois afronta o disposto no art. 22, I e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, onde se lê:

“art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (...); IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”.

Assim, a legislação federal é a competente para tratar do tema direito eleitoral, não sendo admissível lei estadual disciplinar tal matéria.

Sabe-se que a competência privativa da União é delegável aos Estados, e essa delegação se aperfeiçoa por intermédio de lei complementar (parágrafo único do art. 22 da CF/88) que, para o caso em tela, não existe.

Em relação à inconstitucionalidade material, houve afronta aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, pois inexiste uma correlação lógica entre o fator discriminador utilizado de menos de cinco Deputados Federais para ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado e a própria aplicação imediata da legislação estadual inconstitucional que cria regras temporais sobre a criação de partidos políticos.

No mesmo sentido, foram afrontados os ditames constitucionais do pluralismo político previsto no art. 1.º, V, e a liberdade para criação dos

partidos políticos assegurada no art. 17, caput e § 3.º, que assim determina:

“art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, (...)”

§ 3.º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. (...)”.

Desse modo, limitar temporalmente a criação dos partidos afeta a possibilidade do pluralismo político e resta demonstrado que a Lei Estadual “Y” é inconstitucional por todo o alegado.

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a determinação do art. 102, I, p, da CF/88 e do art. 10 da Lei n. 9.868/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade constante da inicial em virtude da patente contrariedade à Constituição Federal no que diz respeito a lei estadual tratar do tema direito eleitoral que é federal (*fumus boni iuris*). Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face do dano irreparável, pois com a vigência da lei o partido político “Y” será afetado pelas restrições de modo imediato.

VII – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que o Supremo Tribunal Federal determine:

a) a concessão de medida cautelar com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender os efeitos da Lei “Y” que estabelece

indevidamente restrições de direito eleitoral e partidárias (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

b) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que, como autoridades responsáveis pela lei, manifestem-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99;

c) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei “Y” que estabelece em seu art. 1.º, regras temporais sobre a criação de partidos políticos; em seu art. 2.º fica retirada a autorização para que partidos políticos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado; e, por fim, em seu art. 3.º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

d) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que se manifestem, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

e) a intimação do excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 3.º, da CF/88;

f) a intimação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, para que emita seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da CF/88.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

PARECER

Ementa: O Partido Político – três representantes na Câmara dos Deputados – violação de regras da CF/88 – medida judicial: Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Estadual “Y”, de janeiro de 2015 – inconstitucionalidade de 3 (três) artigos: art. 1.º, regras temporais sobre a criação de partidos políticos; art. 2.º fica retirada a autorização para que partidos políticos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso

gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado; art. 3.º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação – inconstitucionalidade formal – afronta o art. 22, I e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil – compete privativamente à União legislar, entre outros, sobre: direito eleitoral e sobre telecomunicações e radiodifusão; – inconstitucionalidade material – afronta ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, ao pluripartidarismo – art. 1.º, V, da CF/88 – direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão – art. 17, caput e § 3.º, da CF/88.

Relatório: O Partido Político “Z”, que possui apenas três representantes na Câmara dos Deputados, por entender presente a violação de regras da CF/88, o procura para que, na qualidade de advogado especialista em direito constitucional, se posicione sobre a possibilidade de ser obtida alguma medida judicial em face da Lei Estadual “Y”, de janeiro de 2015, que contém 3 (três) artigos. De acordo com a exposição de motivos do projeto que culminou na Lei Estadual “Y”, o seu objetivo é criar, no âmbito estadual, ambiente propício às discussões políticas de âmbito nacional, e, para alcançar esse objetivo, estabelece, em sua parte dispositiva, novas regras eleitorais, sendo estabelecidas, em seu art. 1.º, regras temporais sobre a criação de partidos políticos; em seu art. 2.º fica retirada a

autorização para que partidos políticos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado; e, por fim, em seu art. 3.º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação.

Fundamentação: inicialmente, a Lei Estadual “Y” é inconstitucional, pois afronta o disposto no art. 22, I e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, onde se lê:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (...) IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”.

Assim, padece de inconstitucionalidade formal.

Além disso, há inconstitucionalidade material, pois existe contrariedade aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, uma vez que não há uma correlação lógica entre o fator discriminador utilizado de menos de cinco Deputados Federais para ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado e a própria aplicação imediata da legislação estadual inconstitucional que cria regras temporais sobre a criação de partidos políticos.

Desse modo, foram violados: art. 1.º, V (pluralismo político) e art. 17, caput e § 3.º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde se lê:

“Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, (...)”

§ 3.º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. (...)”.

Deste modo, é possível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade para a realização do controle concentrado de

constitucionalidade da Lei Estadual “Y”, que deve ser ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Destaque-se a legitimidade ativa do Partido Político “Z”, representado pelo Presidente de sua Comissão Executiva Nacional, por possuir representação no Congresso Nacional, tal qual dispõe o art. 103, VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 2.º, VIII, da Lei n. 9.868 de 1999.

Por fim, admite-se o cabimento da medida cautelar, de modo a suspender a eficácia da lei até que seja definitivamente julgada a ação direta de inconstitucionalidade.

É importante salientar que a tutela jurisdicional cautelar se faz necessária, pois estão suficientemente demonstrados os requisitos do *fumus boni iuris*, pela clareza dos vícios de inconstitucionalidade apontados, e do *periculum in mora*, isso em razão do constrangimento decorrente do impedimento ao exercício de atividade lícita e constitucional dos partidos políticos.

Conclusão: É patente a inconstitucionalidade da Lei Estadual “Y” sendo possível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a formulação do requerimento de medida cautelar.

Local e data.

Advogado/OAB

5.30. XVIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: em razão de denúncias de irregularidades em contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A, com sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal abre inquérito civil e penal para apurar os fatos, com colheita de provas robustas de superfaturamento e

fraude nos quatro últimos contratos celebrados por esta Autarquia Federal. Tais fatos e grande parte das provas foram divulgados na imprensa, e o, ora impetrante, cidadão Pedro da Silva, indignado, se inteira mais sobre o acontecido, ficando ciente de que estes contratos foram realizados nos últimos 2 (dois) anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Ademais, obtém, também, documentos que comprovam mais ainda a fraude e a lesão, além de evidenciarem a participação do presidente da Autarquia A, de um Ministro de Estado e do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M. Indignado com o descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público, promove a presente ação popular visando à defesa e proteção do patrimônio público.

Pedro, ora Impetrante, é cidadão, ciente dos fatos, não teve outra alternativa a não ser impetrar a presente Ação Popular.

– Ação: Ação Popular – art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 4.717/65.

ATENÇÃO

Pedido de liminar (art. 5.º, § 4.º, da Lei n. 4.717/65).

Os arts. 39 e 282 do CPC de 1973 correspondem aos arts. 77, V, e 319 do CPC de 2015.

– Competência: Justiça Federal ou Vara Federal ou Juiz Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

– Legitimidade Ativa: Pedro da Silva (cidadão: título de eleitor – art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65).

– Legitimidade Passiva: Autarquia Federal A, Presidente da Autarquia Federal, Presidente da comissão de licitação, Ministro de Estado, Multinacional M e seu diretor executivo; nos termos do art. 6.º da Lei n. 4.717/65.

– Fundamentos: art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal e/ou art. 1.º da Lei n. 4.717/65. Art. 37, caput, da CF/88 (moralidade e legalidade); arts. 3.º e 4.º, III, c, ambos da Lei n. 4.717/65 (lesividade ao patrimônio público). Da medida liminar: especificar o fumus boni iuris e o periculum in mora.

– Outros requisitos formais da peça: comprovar a condição de cidadão com a cópia do título de eleitor (documento anexo, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), concessão liminar para suspensão dos contratos administrativos superfaturados; citação dos Impetrados para contestar, sob pena de revelia (art. 7.º da Lei n. 4.717/65), a intimação do representante do Ministério Público (arts. 6.º, § 4.º e 7.º, da Lei n. 4.717/65), a juntada dos documentos, julgar procedente o pedido, confirmando a liminar e declarando a nulidade dos contratos administrativos superfaturados; condenar os Impetrados no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65); condenação dos responsáveis ao ressarcimento dos danos (art. 11 da Lei n. 4.717/65). Provas (todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas). Valor da causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA
CÍVEL FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

(espaço de cinco linhas)

PEDRO DA SILVA, (qualificação completa: estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF) residente e domiciliado (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), portador do título de eleitor n. _____, Seção _____, Zona _____, cidadão em pleno gozo de

seus direitos (doc. para a comprovação da legitimidade ativa para a presente ação, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), por seu advogado inscrito na OAB/_____, sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso) com endereço (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 39 do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXXIII do art. 5.º da Constituição Federal e na Lei n. 4.717/65, impetrar AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR em face do senhor Ministro de Estado, da Autarquia Federal A, o Presidente da Autarquia Federal A, o Presidente da Comissão de Licitação, a Multinacional M e seu Diretor Executivo, respectivamente, cada qual com domicílio profissional (qualificações completas e com domicílios profissionais respectivos), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Em razão de denúncias de irregularidades em contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A, com sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal abre inquérito civil e penal para apurar os fatos, com colheita de provas robustas de superfaturamento e fraude nos quatro últimos contratos celebrados por esta Autarquia Federal. Tais fatos e grande parte das provas foram divulgados na imprensa, e o, ora impetrante, cidadão Pedro da Silva, indignado, se inteira mais sobre o acontecido, ficando ciente de que estes contratos foram realizados nos últimos 2 (dois) anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Ademais, obtém, também, documentos que comprovam mais ainda a fraude e a lesão, além de evidenciarem a participação do presidente da Autarquia A, de um Ministro de Estado e do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M.

Indignado com o descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público, promove a presente ação popular visando à defesa e proteção do patrimônio público.

II – DO DIREITO

A ação popular está prevista na Constituição Federal, no inciso LXXIII do art. 5.º, onde se lê:

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Tal, também, encontra-se previsto no art. 1.º da Lei n. 4.717/65.

Ademais, é legitimado ativo para propor a ação popular “qualquer cidadão”, assim entendido o brasileiro em pleno gozo de seus direitos políticos, o que o autor comprova juntando a cópia de seu Título de Eleitor, atendendo a exigência expressamente prevista no art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65.

Prosseguindo, o art. 6.º da Lei da Ação Popular estabelece a legitimidade passiva e determina que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1.º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Assim, figuraram no polo passivo da presente demanda o senhor Ministro de Estado, a Autarquia Federal A, o Presidente da Autarquia Federal A, o Presidente da Comissão de Licitação, a Multinacional M e seu diretor executivo.

No que diz respeito à competência, a ação popular deve ser proposta perante o juízo de primeiro grau (art. 5.º da Lei n. 4.717/65), não havendo competência originária de Tribunal para conhecê-la, ou seja, não há foro privilegiado para os chefes do Poder Executivo ou qualquer outra autoridade. A competência, no caso, é da Justiça Federal (art. 109 da CF/88), pois presente o interesse de autarquia federal.

O impetrante, o cidadão Pedro, fica ciente, por intermédio de fatos divulgados na imprensa, que há inquérito civil e penal para apurar superfaturamento e fraude em contratos celebrados pela Autarquia Federal A.

Indignado com tal situação e como se não bastasse, os referidos contratos foram realizados nos últimos dois anos e, pasmem, estão em fase de execução, com evidências da participação do presidente da referida autarquia, de um Ministro de Estado e do presidente da comissão de licitação. A empresa contratada e beneficiada com os referidos contratos é a multinacional M.

Nessa toada, verifica-se na referida contratação que há gastos indevidos e real prejuízo ao erário. Com a verificação do superfaturamento há afronta a moralidade e a legalidade, princípios basilares da Administração Pública (art. 37 da CF/88).

A ação popular é meio processual constitucional e como legítimo instrumento da cidadania protege os princípios da administração pública, e mais, a situação posta ofende o previsto no art. 3.º da lei que regula a ação popular, pois o superfaturamento causa lesividade ao patrimônio público.

Destaca-se, ainda, a afronta ao art. 4.º, III, c, da Lei n. 4.717/65, pois a fraude e a lesão foram perpetradas com a participação de um Ministro de Estado, do Presidente da Autarquia, do Presidente da Comissão de Licitação, de modo que limitaram as possibilidades

normais de competição na concorrência, em benefício da Multinacional M.

A gravidade dos fatos, inclusive, deu ensejo à abertura de inquérito civil e penal.

Além disso, os contratos ainda estão em execução, o que demanda uma atuação imediata do Poder Judiciário.

Está, pois, demonstrada, a lesão ao patrimônio público e aos princípios da Administração Pública.

Diante de todo o exposto e da gravidade dos fatos, deve a presente ação ser julgada procedente.

III – DA LIMINAR

Há previsão legal de concessão de liminar, na Lei n. 4.717/65, no art. 5.º, § 4.º, que assim estabelece:

“Art. 5.º (...)

§ 4.º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”.

Como já consignado, os contratos estão em execução o que demonstra o perigo da demora e há provas robustas de superfaturamento e fraude, o que demonstra inequivocamente o *fumus boni iuris*.

Presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, é cabível o pedido e necessária a concessão da liminar para suspender os contratos.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência:

a) conceda liminarmente a suspensão dos contratos administrativos, superfaturados, firmados com a Multinacional M;

b) determine a citação dos Impetrados, nos prazos e termos dos incisos I e IV do art. 7.º da Lei n. 4.717/65, com cópia da presente, bem como documentos acostados;

c) determine a intimação do Ministério Público (art. 6.º, § 4.º e art. 7.º, I, a, ambos da Lei n. 4.717/65);

d) ao final, julgue procedente o pedido, confirmando a liminar, e declare a nulidade dos contratos administrativos;

e) condene os impetrados e responsáveis a ressarcirem os danos causados, inclusive com a devolução dos valores pagos, considerando o superfaturamento (art. 11 da Lei n. 4.717/65);

f) condene os Impetrados no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65).

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.31. XIX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: determinado partido político, que possui representação no Congresso Nacional, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar, em nome do partido, a medida judicial objetiva apropriada, visando à regulamentação do

art. 7.º, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos.

– Ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão

– Competência: Supremo Tribunal Federal, segundo o art. 102 , I, a, da CF/88

– Legitimidade Ativa: Partido Político com representação no Congresso Nacional – art. 103, VIII, da Constituição Federal, e arts. 2.º e 12-A, ambos da Lei n. 9.868/99.

– Legitimidade Passiva: Congresso Nacional

– Fundamentos: devem ser abertos os seguintes tópicos: da Legitimidade Ativa – A legitimidade ativa do partido político para a propositura da presente encontra assento no art. 103, VIII, da CF/88; da Competência Originária – na forma do art. 102, I, a, da CF/88, é de competência originária do STF o processamento e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão; do Cabimento da Ação – Eficácia limitada do art. 7.º, XXIII, da CF/88 e a sua necessária regulamentação.

– Outros requisitos formais da peça: Pedido: diante do exposto e com fulcro na Lei n. 9.868/99,

1. seja julgado procedente o pedido, para que seja declarada a mora legislativa do Congresso Nacional na elaboração da lei específica do art. 7.º, XXIII, da CF/88;

2. seja dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias;

3. seja promovida a oitiva do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 12-E, § 3.º, da Lei n. 9.868/99.

Provas – Requer a produção de todas as provas admitidas em direito, na forma do art. 14, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99.

– Local e data Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Partido Político com representação no Congresso Nacional, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações art. 77, V, do CPC/2015, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 103, VIII, e 102, I, a, da Constituição Federal de 1988, no art. 12-A da Lei n. 9.868/99 e no art. 319 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO em face do Congresso Nacional.

I – DA NORMA NÃO REGULAMENTADA

O partido político, preocupado com a ausência de regulamentação da adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende buscar a regulamentação do art. 7.º, XXIII,

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Assim, não se pode compactuar com o desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos.

Trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada e a ação em referência busca a sua criação para viabilizar a proteção da saúde dos trabalhadores.

II – FORO COMPETENTE

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”.

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão é originária do Supremo Tribunal Federal.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

A legitimidade ativa do partido político com representação no Congresso Nacional para a propositura da presente ação encontra assento no art. 103, VIII, da CF/88 e no art. 12-A da Lei n. 9.868/99.

Trata-se de autor universal ou neutro, não necessitando demonstrar a pertinência temática.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

Cabe ao Congresso Nacional o poder de regulamentar normas previstas na Constituição em vigor, assim é justificada a legitimidade passiva.

V – INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

O art. 7.º, XXIII, da CF/88 determina que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais:

“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

Referido inciso não foi regulamentado e desse modo os trabalhadores brasileiros não podem contar com esse direito e sua proteção. Há, assim uma inconstitucionalidade por omissão que

justifica a proposta da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão visando a efetivar o seu acréscimo remuneratório.

VI – DO PEDIDO

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a intimação do Congresso Nacional para que, como autoridade responsável pela não edição da norma, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

b) a intimação do senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 12-E, § 2.º, da Lei n. 9.868/99;

c) a intimação do senhor Procurador-Geral da República, para emitir seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 12-E, § 3.º, da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da Constituição Federal de 1988;

d) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade por omissão e que seja dada ciência ao Congresso Nacional para adoção das providências necessárias para a regulamentação do adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas [§ 2.º do art. 103 da Constituição Federal de 1988 e art. 12-H, § 1.º, da Lei n. 9.868/99].

e) requer a produção de todas as provas admitidas em direito, na forma do art. 14, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

Termos em que,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

Observação: não foi exigida a medida cautelar e quem optou por colocá-la, não teve desconto na nota.

5.32. XX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Lei Orgânica do Município Alfa, publicada em 30 de maio de 1985, estabelece, no seu art. 11, diversas condutas como crime de responsabilidade do Prefeito, entre elas o não atendimento, ainda que justificado, a pedido de informações da Câmara Municipal, inclusive com previsão de afastamento imediato do Prefeito a partir da abertura do processo político. O art. 12 da mesma Lei Orgânica define a competência de processamento e julgamento do Prefeito pelo cometimento de crimes comuns perante a Justiça Estadual de primeira instância. Houve recente representação oferecida por Vereadores da oposição com o objetivo de instaurar processo de apuração de crime de responsabilidade com fundamento no referido art. 11 da Lei Orgânica contra o atual Prefeito, a qual poderá ser analisada a qualquer momento. O partido político do Prefeito (Beta), após o devido trâmite interno estabelecido no seu estatuto, conclui que a norma municipal está em dissonância com a CF/88 e decide adotar providência judicial em relação ao tema. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) do partido político Beta, utilizando-se do instrumento constitucional adequado, elabore a medida judicial de controle objetivo cabível.

– Ação: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

– Competência: Supremo Tribunal Federal, segundo o art. 102, § 1.º, da CF/88 e art. 1.º e s. da Lei n. 9.882/99.

– Legitimidade Ativa: Partido Político Beta.

- Legitimidade Passiva: Lei Orgânica do Município Alfa e Câmara Municipal.
- Fundamentos: devem ser abertos os seguintes tópicos: Não recepção, art. 85, parágrafo único, da CF (legislação federal para definir os crimes de responsabilidade e o seu processo), art. 22, I, CF (direito processual) e Súmula Vinculante 46, art. 4.º, §§ 1.º e 5.º, ambos da Lei n. 9.882/99.
- Outros requisitos formais da peça: Pedido: a) a intimação da Câmara Municipal; b) a intimação do Advogado-Geral da União; c) a intimação do senhor Procurador-Geral da República; d) a procedência do pedido de mérito para ratificar a liminar e declarar a não recepção da norma impugnada. Valor da causa de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Partido Político Beta, com representação no Congresso Nacional (art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99 combinado com o art. 103, VIII, da Constituição Federal de 1988), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado), local indicado para receber intimações (arts. 77, V, e 287 do CPC/2015) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, § 1.º, da Constituição Federal de 1988, no art. 1.º e s. da Lei n. 9.882/99 e no art. 319 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR em face da Lei Orgânica do Município Alfa (arts. 11 e 12) elaborada pela Câmara Municipal, conforme a seguir será demonstrado.

I – DO PRECEITO FUNDAMENTAL NO CASO APRESENTADO

A Lei Orgânica do Município Alfa de 1985, ao estabelecer, no art. 11, diversas condutas como crime de responsabilidade do Prefeito, entre elas o não atendimento, ainda que justificado, a pedido de informações da Câmara Municipal, inclusive com previsão de afastamento imediato do Prefeito a partir da abertura do processo político, bem como no art. 12 definir a competência de processamento e julgamento do Prefeito pelo cometimento de crimes comuns perante a Justiça Estadual de primeira instância, violou os seguintes preceitos fundamentais:

(i) o art. 2.º, que trata do princípio da separação de poderes, pois estaria o Poder Legislativo local invadindo competência do Poder Legislativo federal, inclusive para punir o titular do Poder Executivo do Município Alfa;

(ii) o art. 22, I, pois compete privativamente à União legislar sobre direito processual, com reflexo eleitoral e característica penal; e

(iii) o art. 29, caput e X, que dispõem sobre os Municípios e sobre as respectivas leis orgânicas, as quais devem observar os preceitos da Constituição da República, especialmente garantindo aos Prefeitos a prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça em crimes comuns.

Por fim, também foi violado o contido na Súmula Vinculante 46 do STF: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.

II – FORO COMPETENTE

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental deve ser endereçada ao Supremo Tribunal Federal, órgão judicial competente para processar e julgar a referida ação, conforme o previsto no art. 102, § 1.º, da CF/88 combinado com o art. 1.º da Lei n.

9.882/99.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

O partido político Beta, que possui representação no Congresso Nacional, na forma do art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99 combinado com o art. 103, VIII, da CF/88, possui

legitimidade ativa para a propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Trata-se de autor universal ou neutro, não necessitando demonstrar a pertinência temática.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é a única ação de controle concentrado de constitucionalidade cabível contra norma municipal e anterior à CF/88, na forma do art. 1.º, parágrafo único, I, e do art. 4.º, § 1.º, ambos da Lei n. 9.882/99. No presente caso, são objetos de impugnação os arts. 11 e 12 da Lei Orgânica do Município Alfa de 1985, elaborada pela Câmara Municipal.

V – DO CABIMENTO DA ADPF – DA INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PROCESSUAL IDÔNEO E EFICAZ PARA SANAR A LESIVIDADE

Aplica-se o Princípio da Subsidiariedade previsto no art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99, pois não há outro meio jurídico para sanar tal lesividade.

Trata-se de norma anterior à Constituição Federal vigente e não recepcionada.

VI – DA MEDIDA LIMINAR

Há plausibilidade jurídica na arguição de descumprimento de preceito fundamental constante da inicial em virtude da patente contrariedade ao art. 85, parágrafo único, da CF, devendo ser sustada a eficácia dos arts. 11 e 12 da Lei Municipal em questão e, por

consequência, suspender o trâmite da representação por crime de responsabilidade oferecida em desfavor do Prefeito. Assim há o “fumus boni iuris”. Está igualmente atendido o requisito do “periculum in mora”, em face da urgência do presente caso para proteger o Prefeito do Município Alfa de punição iminente.

VII – DO PEDIDO

Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne determinar:

a) a intimação da Câmara Municipal para que, como autoridade responsável pelo ato normativo questionado, manifeste-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida liminar, com fundamento no art. 5.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99;

b) a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da representação por crime de responsabilidade oferecida em desfavor do Prefeito e de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da presente ação (art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99);

c) a intimação da Câmara Municipal para que, como autoridade responsável pela prática do ato questionado, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de dez dias, nos termos do art. 6.º, caput, da Lei n. 9.882/99;

d) a intimação do senhor Procurador-Geral da República, para emitir seu parecer, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99;

e) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a incompatibilidade com a Constituição da República dos arts. 11 e 12 da Lei Orgânica, de 30 de maio de 1985, do Município Alfa (nos termos do art. 10 da Lei n. 9.882/99).

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.33. XXI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

Resumo dos Fatos: a Associação Alfa, constituída há 3 (três) anos, cujo objetivo é a defesa do patrimônio social e, particularmente, do direito à saúde de todos, mostrou-se inconformada com a negativa do Posto de Saúde Gama, gerido pelo Município Beta, de oferecer atendimento laboratorial adequado aos idosos que procuram esse serviço. O argumento das autoridades era o de que não havia profissionais capacitados e medicamentos disponíveis em quantitativo suficiente. Em razão desse estado de coisas e do elevado número de idosos correndo risco de morte, a Associação resolveu peticionar ao Secretário Municipal de Saúde, requerendo providências imediatas para a regularização do serviço público de Saúde. O Secretário respondeu que a situação da Saúde é realmente precária e que a comunidade precisa ter paciência e esperar a disponibilização de repasse dos recursos públicos federais, já que a receita prevista no orçamento municipal não fora integralmente realizada. Reiterou, ao final e pelas razões já aventadas, a negativa de atendimento laboratorial aos idosos. Apesar disso, as obras públicas da área de lazer do bairro em que estava situado o Posto de Saúde Gama, nos quais eram utilizados exclusivamente recursos públicos municipais, continuaram a ser realizadas.

– Ação: Ação Civil Pública – art. 1.º, IV ou VIII, da Lei n. 7.347/85.

– Competência: Juízo Cível da Comarca X ou Juízo de Fazenda Pública da Comarca X.

- Legitimidade Ativa: Associação Alfa.
- Legitimidade Passiva: Município Beta.
- Fundamentos: o direito à saúde dos idosos e a competência constitucional conferida para fins de prestação do serviço público de saúde (art. 30, VII, art. 196 e art. 230, todos da CF/88).

A dignidade da pessoa humana, amparada pelo art. 1.º, III, pelo art. 5.º, caput, pelo art. 6.º e pelo art. 196, todos da CF/88.

O cabimento da ação civil pública decorre do fato de o objetivo da demanda judicial ser a defesa de todos os idosos que procuram o atendimento do Posto de Saúde Gama. Como se discute a qualidade do serviço público oferecido à população e esses idosos não podem ser individualizados, trata-se de típico interesse difuso, enquadrando-se no art. 1.º, IV e VIII, da Lei n. 7.347/85.

Outros requisitos formais da peça: a citação do impetrado (art. 2.º da Lei n. 8.437/92), intimação para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC; concessão de medida liminar, a intimação do Ministério Público, a condenação de custas e honorários de advogado, provas e valor da causa.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA COMARCA X OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA X

A Associação Alfa (qualificação completa do seu representante legal, com sede e domicílio no endereço e CNPJ/MF), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____, e-mail _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei n. 7.347/85, impetrar AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR em face do Município Beta (qualificação completa do Secretário Municipal de Saúde), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

A Associação Alfa, constituída há 3 (três) anos, cujo objetivo é a defesa do patrimônio social e, particularmente, do direito à saúde de todos, mostrou-se inconformada com a negativa do Posto de Saúde Gama, gerido pelo Município Beta, de oferecer atendimento laboratorial adequado aos idosos que procuram esse serviço.

O argumento das autoridades era o de que não havia profissionais capacitados e medicamentos disponíveis em quantitativo suficiente. Em razão desse estado de coisas e do elevado número de idosos correndo risco de morte, a Associação resolveu peticionar ao Secretário Municipal de Saúde, requerendo providências imediatas para a regularização do serviço público de Saúde.

O Secretário respondeu que a situação da Saúde é realmente precária e que a comunidade precisa ter paciência e esperar a disponibilização de repasse dos recursos públicos federais, já que a receita prevista no orçamento municipal não fora integralmente realizada. Reiterou, ao final e pelas razões já aventadas, a negativa de atendimento laboratorial aos idosos.

Apesar disso, as obras públicas da área de lazer do bairro em que estava situado o Posto de Saúde Gama, nos quais eram utilizados exclusivamente recursos públicos municipais, continuaram a ser realizadas.

II – DO DIREITO

O Município tem o dever de assegurar o direito à saúde dos idosos e de cumprir a competência constitucional conferida para fins de prestação do serviço público de saúde (art. 30, VII, art. 196 e art. 230, todos da CF/88).

O que se verifica, na hipótese, é a necessidade de defesa do direito à vida e à saúde dos idosos que procuram os serviços do Posto de Saúde Gama, bem como de sua dignidade, amparados pelo art. 1.º, III, pelo art. 5.º, caput, pelo art. 6.º e pelo art. 196, todos da CF/88.

Esses direitos estão sendo preteridos para a realização de obras públicas na área de lazer, o que é constitucionalmente inadequado em razão da maior importância dos referidos direitos. Afinal, sem vida e saúde, não há possibilidade de lazer.

O cabimento da ação civil pública decorre do fato de o objetivo da demanda judicial ser a defesa de todos os idosos que procuram o atendimento do Posto de Saúde

Gama, nos termos das finalidades estatutárias da Associação – defesa do patrimônio social e, particularmente, do direito à saúde de todos –, e não eventual defesa de direito ou interesse individual. Como se discute a qualidade do serviço público oferecido à população e esses idosos não podem ser individualizados, trata-se de típico interesse difuso, enquadrando-se no art. 1.º, IV e VIII, da Lei n. 7.347/85.

A legitimidade passiva do Município Beta é justificada por ser o responsável pela gestão do Posto de Saúde Gama.

A legitimidade ativa da Associação Alfa decorre do fato de ter sido constituída há mais de 1 (um) ano e destinar-se à defesa do patrimônio social e do direito à saúde de todos, atendendo ao disposto no art. 5.º, V, a e b, da Lei n. 7.347/85.

III – DA LIMINAR

O art. 12 da Lei da Ação Civil Pública prevê que o juiz poderá conceder mandado liminar. Assim, a concessão de medida liminar é

necessária para o fim de compelir o Município a regularizar o sistema de saúde e prestar o atendimento laboratorial adequado aos idosos na localidade abrangida pelo Posto de Saúde, como acatamento de impositivo constitucional e legal dos direitos à vida e à saúde, bem como da dignidade humana. Presentes, portanto, o “fumus boni iuris”.

Há no presente caso, o risco de ineficácia da medida final, se a liminar não for deferida, tendo em vista a urgência da situação, uma vez que os idosos estão sujeitos a complicações de saúde e a risco de morte, caso não recebam o tratamento de saúde adequado, materializando o “periculum in mora”.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, o impetrante requer a Vossa Excelência:

a) a citação do impetrado, na pessoa de seu representante legal, para responder, sob pena de revelia aos termos da presente ação, bem como para se manifestar sobre o pedido de liminar no prazo de 72 (setenta e duas) horas (art. 2.º da Lei n. 8.437/92);

b) intimação para comparecimento a audiência de conciliação ou mediação na data a ser designada por Vossa Excelência nos termos do art. 319, VII, do CPC;

c) a concessão de medida liminar para impor ao Município a prestação adequada de serviço público de saúde pelo Posto Gama, inclusive atendimento laboratorial adequado aos idosos;

d) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer (art. 5.º, § 1.º, da Lei n. 7.347/85);

e) ao final seja o pedido julgado procedente, tornando definitiva a liminar concedida, e condenando-se o Município à prestação adequada de serviço público de saúde pelo Posto Gama, inclusive atendimento laboratorial adequado aos idosos;

f) a condenação do impetrado ao pagamento de custas e honorários de advogado.

V – DAS PROVAS

Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outros mais que se fizerem necessários, desde já requeridos.

Valor da causa: R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.34. XXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estrutura da peça:

Resumo dos Fatos: servidores públicos do Estado Beta, que trabalham no período da noite, procuram o Sindicato ao qual são filiados, inconformados por não receberem adicional noturno do Estado, que se recusa a pagar o referido benefício em razão da inexistência de lei estadual que regule as normas constitucionais que asseguram o seu pagamento. O Sindicato resolve, então, contratar escritório de advocacia para ingressar com o adequado remédio judicial, a fim de viabilizar o exercício em concreto, por seus filiados, da supramencionada prerrogativa constitucional, sabendo que há a previsão do valor de vinte por cento, a título de adicional noturno, no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Ação: Mandado de Injunção Coletivo – na medida em que visa à defesa dos interesses dos seus filiados na proteção do direito ao adicional noturno, conforme o disposto no art. 5.º, LXXI, da CF/88 e na Lei n. 13.300, de 23 de

junho de 2016.

Competência: Tribunal de Justiça do Estado Beta, art. 125, § 1.º, da CF/88, observando-se o princípio da simetria entre os entes federativos.

Legitimidade Ativa: Sindicato dos Servidores Públicos do Estado Beta, na forma do art. 12, III, da Lei n. 13.300/2016, dispensada a autorização dos filiados.

Legitimidade Passiva: o Governador do Estado Beta, por simetria ao que determina a CF/88 (art. 61, § 1.º, a e d, da CF/88).

Fundamentos: o direito ao benefício de adicional noturno é concedido aos servidores públicos que exercem atividade laboral noturna e é garantido em razão de previsão constitucional contida no art. 7.º, IX, e no art. 39, § 3.º, ambos da CF/88, devendo cada ente federativo regulamentar o referido benefício por meio de lei.

Outros requisitos formais da peça: a intimação do Ministério Público para oferecer parecer. Os pedidos devem ser de reconhecimento da omissão e do estado de mora legislativa, a fim de que seja concedida a ordem de injunção coletiva para: (i) ser determinado prazo razoável para que o Governador promova a edição da norma regulamentadora; (ii) seja suprida a omissão normativa garantindo-se a efetividade do direito à percepção do adicional noturno no percentual de 20% em relação à hora normal de trabalho, conforme disposições, aplicáveis por analogia, contidas no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, com eficácia para todos os servidores estaduais no exercício de atividade laboral noturna, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado (art. 8.º, I e II, e art. 13, ambos da Lei n. 13.300/2016). Valor da causa: R\$ 1.000,00 (mil reais)

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BETA

O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado Beta, com sede no endereço (...), CNPJ n. _____, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve

(instrumento de mandato incluso), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5.º, LXXI, da Constituição Federal de 1988 e na Lei n. 13.300/2016, impetrar MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO em face do Governador do Estado Beta, em virtude de sua inércia legislativa pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Os servidores públicos do Estado Beta, que trabalham no período da noite, procuraram o Sindicato, inconformados por não receberem adicional noturno do Estado, que se recusa a pagar o referido benefício em razão da inexistência de lei estadual que regule as normas constitucionais que asseguram o seu pagamento. O Sindicato resolve buscar o exercício em concreto, por seus filiados, da supramencionada prerrogativa constitucional, sabendo que há a previsão do valor de vinte por cento, a título de adicional noturno, no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho.

II – DO DIREITO

No presente caso, há respaldo constitucional e legal para a impetração do Mandado de Injunção Coletivo ajuizado pelo Sindicato, na medida em que visa à defesa dos interesses dos seus filiados na proteção do direito ao adicional noturno, conforme o disposto no art. 5.º, LXXI, da CF/88:

“conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à

soberania e à cidadania”.

Visando a regulamentar esse remédio constitucional, foi editada a Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016.

O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado Beta tem legitimidade ativa para a presente ação nos termos do art. 12, III, da Lei n. 13.300/2016, dispensada a autorização dos filiados.

Justifica-se o Governador do Estado Beta no polo passivo, uma vez que, no processo legislativo estadual, é quem detém competência privativa para iniciar o processo legislativo no presente caso, pois as regras constitucionais estaduais de competência devem observar, por simetria, o que determina a CF/88. No caso, o art. 61, § 1.º, a e d, da CF/88.

A presente ação deve ser proposta no Tribunal de Justiça do Estado Beta, uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil repartiu a competência para julgamento com base na fonte de onde deveria ter emanado a norma faltante e procurou concentrar a competência para processamento e julgamento do Mandado de Injunção nos Tribunais Superiores, sendo que, no plano estadual, a competência do Mandado de Injunção pode ser definida pelas Constituições dos Estados (art. 125, § 1.º, da CF/88), observando-se o princípio da simetria entre os entes federativos.

O direito ao benefício de adicional noturno é concedido aos servidores públicos que exercem atividade laboral noturna e é garantido em razão de previsão constitucional contida no art. 7.º, IX, e no art. 39, § 3.º, ambos da CF/88, devendo cada ente federativo regulamentar o referido benefício por meio de lei.

Deste modo, o sindicato tem legitimidade para impetrar o presente mandado de injunção coletivo em face da inércia do Governador em não apresentar o projeto de lei visando a iniciar o processo legislativo

que garanta aos servidores receberem adicional noturno do Estado Beta.

III – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que o Tribunal de Justiça do Estado Beta se digne determinar:

a) a notificação do Governador do Estado Beta para prestar informações no prazo legal, de dez dias, como de direito, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos;

b) a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito.

c) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer;

d) a concessão do direito pleiteado, em virtude da procedência do pedido para reconhecimento da omissão e do estado de mora legislativa, a fim de que seja concedida a ordem de injunção coletiva para:

(i) ser determinado prazo razoável para que o Governador promova a edição da norma regulamentadora;

(ii) seja suprida a omissão normativa garantindo-se a efetividade do direito à percepção do adicional noturno no percentual de 20% em relação à hora normal de trabalho, conforme disposições, aplicáveis por analogia, contidas no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, com eficácia para todos os servidores estaduais no exercício de atividade laboral noturna, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado (art. 8.º, I e II, e art. 13, ambos da Lei n. 13.300/2016).

Valor da causa: R\$ 1.000,00 (mil reais)

Termos em que,

pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.35. XXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Edson, idoso aposentado, foi acometido por doença que exige o uso contínuo de medicamento controlado, cuja ministração fora da forma exigida pode colocar em risco a sua vida. No último dia 5, foi informado, pelo Diretor do referido posto, que a central de distribuição não entregara o medicamento, já que o Município, em razão da crise financeira, não pagava os fornecedores havia cerca de seis meses. Inconformado com a informação recebida, Edson formulou, logo no dia seguinte, requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Saúde, autoridade responsável pela administração das dotações orçamentárias destinadas à área de saúde e pela aquisição dos medicamentos encaminhados à central de distribuição, órgão por ele dirigido. Na ocasião, esclareceu que a ausência do medicamento poderia colocar em risco sua própria vida. Em resposta escrita, o Secretário reconheceu que Edson tinha necessidade do medicamento, o que fora documentado pelos médicos do posto de saúde, e informou que estavam sendo adotadas as providências necessárias à solução da questão, mas que tal somente ocorreria dali a 160 (cento e sessenta) dias, quando o governador do Estado prometera repassar receitas a serem aplicadas à saúde municipal. Nesse meio-tempo, sugeriu que Edson procurasse o serviço de emergência sempre que o seu estado de saúde apresentasse alguma piora.

– Ação: Mandado de Segurança.

– Competência: Juízo Cível da Comarca X ou ao Juízo de Fazenda Pública da Comarca X.

- Legitimidade Ativa: Edson.
- Legitimidade Passiva: Secretário Municipal de Saúde.
- Fundamentos: a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, nos termos do art. 196, caput, da CF/88. Acresça-se que o serviço de saúde oferecido pelo Município deve assegurar o “atendimento integral”, conforme prevê o art. 198, II, da CF/88, o que inclui o fornecimento de medicamentos. Em razão das características pessoais de Edson, como a ausência do medicamento pode colocar em risco a sua vida, é evidente a sua exigibilidade como forma de materializar a dignidade humana, contemplada no art. 1.º, III, da CF/88.
- Fundamentos para a concessão da liminar – Fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida final, caso não seja deferida a liminar.
- Outros requisitos formais da peça: notificação da autoridade coatora para prestar informações; ciência ao órgão de representação judicial do Município; concessão da medida liminar para fornecimento do medicamento; procedência do pedido para a continuidade do fornecimento do medicamento; requerimento de oitiva do Ministério Público. Valor da Causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL
DA COMARCA X (OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

Edson (nacionalidade, estado civil, aposentado, RG, CPF/MF, residente e domiciliado na Rua _____, Bairro _____, nesta _____, com endereço eletrônico, por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato anexo), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, no art. 319 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face do Secretário Municipal de Saúde (qualificação completa), pelos motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

Edson, idoso aposentado, foi acometido por doença que exige o uso contínuo de medicamento controlado, cuja ministração fora da forma exigida pode colocar em risco a sua vida. No último dia 5, foi informado, pelo Diretor do posto de saúde, que a central de distribuição não entregara o medicamento, já que o Município, em razão da crise financeira, não pagava os fornecedores havia cerca de seis meses. Inconformado com a informação recebida, Edson formulou, logo no dia seguinte, requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Saúde, autoridade responsável pela administração das

dotações orçamentárias destinadas à área de saúde e pela aquisição dos medicamentos encaminhados à central de distribuição, órgão por ele dirigido. Na ocasião, esclareceu que a ausência do medicamento poderia colocar em risco sua própria vida. Em resposta escrita, o Secretário reconheceu que Edson tinha necessidade do medicamento, o que fora documentado pelos médicos do posto de saúde, e informou que estavam sendo adotadas as providências necessárias à solução da questão, mas que tal somente ocorreria dali a 160 (cento e sessenta) dias, quando o governador do Estado prometera repassar receitas a serem aplicadas à saúde municipal. Nesse meio-tempo, sugeriu que Edson procurasse o serviço de emergência sempre que o seu estado de saúde apresentasse alguma piora.

Assim, o Impetrante, portador de doença grave e que necessita do uso permanente de determinados medicamentos, não consegue retirá-los em virtude de ato coator cometido pelo Secretário Municipal de Saúde.

II – DO DIREITO

A Constituição Federal no art. 6.º estabelece que:

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Norma Fundamental deixa claro que a saúde deve ser assegurada a todos que se encontrem no Estado brasileiro.

Neste sentido, complementa tal conteúdo o art. 196 da Constituição Federal que determina ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

Percebe-se, assim, que a negativa do Município em fornecer o remédio ofende a Carta Magna brasileira.

Além disso, o serviço de saúde prestado pelo Município deve assegurar o “atendimento integral”, conforme prevê o art. 198, II, da Constituição vigente, o que inclui o fornecimento de medicamentos.

No caso em tela, a ausência do medicamento pode colocar em risco a vida do Impetrante, o que afronta a dignidade humana, contemplada no art. 1.º, III, e art. 5.º, caput, ambos da CF/88.

Deste modo, visa a presente ação à efetividade do direito social à saúde, conforme determina o art. 5.º, § 1.º, da Constituição Brasileira, onde se lê:

“As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.

Existe prova pré-constituída, uma vez que o Impetrado reconheceu que o Impetrante necessita do medicamento e de que o seu fornecimento fora suspenso. Assim, patente é o direito líquido e certo do Impetrante.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5.º, LXIX, assegura o

remédio constitucional do mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (...)”, e todos os entes federativos e autoridades públicas ao agir devem respeitar os direitos e garantias, assegurando a todos o mínimo necessário para o seu exercício.

Determina a Lei Fundamental do Estado que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para a proteção das pessoas que tenham direitos constitucionais violados que, no caso em tela, foram flagrantemente desrespeitados.

No mesmo sentido, há previsão no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009.

III – DA LIMINAR

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, “*fumus boni iuris*”. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado “*periculum in mora*”.

Assim, está presente o “*fumus boni iuris*”, pois a inconstitucionalidade é manifesta, uma vez que foram violados: a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e o atendimento integral. Por fim, há urgência no pleito, pois a demora coloca em risco a vida do Impetrante (*periculum in mora*).

Com tais ponderações, justifica-se o pedido da liminar.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência se digne:

a) conceder in limine, a segurança requerida, com a expedição do competente ofício determinando que a autoridade coatora restabeleça o fornecimento do medicamento que o Impetrante necessita, até o julgamento do presente mandado;

b) determinar a notificação pessoal da autoridade coatora, o Secretário de Saúde do Município X, para prestar informações no prazo legal de dez dias, como de direito, entregando-lhe a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia;

c) dar ciência do feito ao representante judicial da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

d) determinar a intimação do Ministério Público para oferecer parecer, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009.

e) acatar as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia do ato impugnado);

f) a fixar multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a procedência do pedido, com confirmação da concessão da ordem, atribuindo-se caráter definitivo à tutela liminar assegurando-se o direito líquido e certo de receber o medicamento necessário ao seu tratamento.

Dá-se à causa, para efeitos fiscais e de alçada, o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.36. XXIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos: Sindicato W, legalmente constituído e em funcionamento há vinte anos, que representava os interesses da categoria, em assembleia geral convocada especialmente para deliberar a respeito das medidas a serem adotadas pelos sindicalizados. Ao fim de ampla discussão, decidiram que, em vez da greve, que causaria grande prejuízo à população e à economia do país, iriam se encontrar nas praças da capital do Estado Alfa, com o objetivo de debater publicamente os interesses da categoria de forma organizada e ordeira, e ainda fariam passeatas semanais pelas principais ruas da capital. Em situações dessa natureza, a lei dispõe que seria necessária a prévia comunicação ao comandante da Polícia Militar. No mesmo dia em que recebeu a comunicação dos encontros e das passeatas semanais, que teriam início em dez dias, o comandante da Polícia Militar, em decisão formalmente comunicada ao Sindicato W, decidiu indeferi-los, sob o argumento de que atrapalhariam o direito ao lazer nas praças e a tranquilidade das pessoas, os quais são protegidos pela ordem jurídica. Inconformado com a decisão do comandante da Polícia Militar, o Sindicato W procurou um advogado e solicitou o manejo da ação judicial cabível, que dispensasse instrução probatória, considerando a farta prova documental existente, para que os trabalhadores pudessem cumprir o que foi deliberado na assembleia da categoria, no prazo inicialmente fixado, sob pena de esvaziamento da força do movimento.
- Ação: Mandado de Segurança coletivo – art. 5.º, LXX, b, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.
- Competência: Juízo Cível da Comarca X ou ao Juízo de Fazenda Pública da

Comarca X.

- Legitimidade Ativa: Sindicato W (organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano) – art. 21 da Lei n. 12.016/2009 ou pelo art. 5.º, LXX, b, da CF/88.
 - Legitimidade Passiva: Comandante da Polícia Militar.
 - Fundamentos: direitos fundamentais à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV), à liberdade de expressão (art. 5.º, IX) e à reunião pacífica (art. 5.º, XVI) da Constituição Federal de 1988.
 - Outros requisitos formais da peça: pedido de liminar, para que a autoridade coatora se abstenha de adotar qualquer medida que impeça a realização das reuniões e das passeatas (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009), notificação da autoridade coatora (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009) e da entidade da qual ele faz parte (art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009), intimação do membro do Ministério Público, não ocorrência do prazo decadencial, concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida para garantir a realização de reuniões e passeatas. Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.
- Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DA COMARCA X

O Sindicato W, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por seu presidente (qualificação completa), conforme documento anexo (doc. 1), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso – doc. 2), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com

fundamento no inciso LXX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, no art. 319 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR em face do Comandante da Polícia Militar, conforme os motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Após anos de defasagem salarial, milhares de trabalhadores que integravam o mesmo segmento profissional reuniram-se na sede do Sindicato W, legalmente constituído e em funcionamento há vinte anos, que representava os interesses da categoria, em assembleia geral convocada especialmente para deliberar a respeito das medidas a serem adotadas pelos sindicalizados. Ao fim de ampla discussão, decidiram que, em vez da greve, que causaria grande prejuízo à população e à economia do país, iriam se encontrar nas praças da capital do Estado Alfa, com o objetivo de debater publicamente os interesses da categoria de forma organizada e ordeira, e ainda fariam passeatas semanais pelas principais ruas da capital. Em situações dessa natureza, a lei dispõe que seria necessária a prévia comunicação ao comandante da Polícia Militar. No mesmo dia em que recebeu a comunicação dos encontros e das passeatas semanais, que teriam início em dez dias, o comandante da Polícia Militar, em decisão formalmente comunicada ao Sindicato W, decidiu indeferi-los, sob o argumento de que atrapalhariam o direito ao lazer nas praças e a tranquilidade das pessoas, os quais são protegidos pela ordem jurídica.

II – DO DIREITO

A competência para apreciação do presente mandado de segurança

é do Juízo Cível da Comarca X onde se consumou a violação ao direito líquido e certo de se reunir.

A legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança coletivo no caso em questão é Sindicato W, pessoa jurídica de direito privado, prevista na alínea b do inciso LXX do art. 5.º da Constituição Federal que estabelece ser competente a organização sindical em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

O Sindicato é legitimado para tutelar os interesses dos sindicalizados e age em nome próprio na defesa dos interesses dos seus membros. Nessa hipótese há legitimidade ativa extraordinária ocorrendo, no caso, substituição processual.

A autoridade coatora é o Comandante da Polícia Militar.

O prazo decadencial para interposição do mandado de segurança é de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009: "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".

No presente caso, tal prazo decadencial não ocorreu, pois a ação constitucional foi proposta em dia posterior à recusa do Comandante.

Os direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão e a reunião pacífica são assegurados no art. 5.º da Constituição Federal de 1988, nos respectivos incisos IV, IX e XVI.

Deste modo, quem se encontra no território brasileiro tem assegurada a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Além disso, é livre a expressão e comunicação, independentemente de censura ou licença, bem como todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

No mesmo sentido, é garantido o direito de reunião na Convenção Americana de Direitos Humanos no art. 15 do Decreto n. 678/92.

No presente caso, o Sindicato W e seus representados foram impedidos de exercer seus direitos constitucionais em virtude do ato abusivo do Comandante da Polícia Militar, que indeferiu os encontros nas praças da cidade da capital do Estado Alfa, impedindo o debate público dos interesses da categoria de forma organizada e ordeira, e ainda impediu as passeatas semanais pelas principais ruas da capital.

III – DA LIMINAR

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*. Enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

Assim, estão presentes o *fumus boni iuris*, pois a ilegalidade é manifesta, uma vez que foram violados os direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão e a reunião pacífica, bem como o *periculum in mora*, pois as reuniões e passeatas estão na iminência de acontecer, justificando plenamente o pedido de liminar.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência:

a) determine a oitiva do representante judicial da Polícia Militar do Estado Alfa, para se pronunciar no prazo de 72 horas, nos termos do §

2.º do art. 22 da Lei n. 12.016/2009;

b) a concessão de medida liminar, com a expedição do respectivo ofício à Autoridade coatora, considerando que os requisitos *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* restam evidenciados, no sentido de assegurar as reuniões nas praças e as passeatas na capital do Estado Alfa até que sobrevenha a decisão final do presente mandado de segurança;

c) determinar a notificação pessoal da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, dar ciência do feito ao órgão de representação judicial, bem como a intimação do Ministério Público para oferecer parecer;

d) determinar a ordem para que os direitos da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão e a reunião pacífica possam ser exercidos, considerando a ilegalidade do impedimento, conforme demonstrado;

e) a fixar multa, nos termos do Código de Processo Civil.

As provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência no mandado de segurança (cópia do ato impugnado – consistente na decisão publicada no Diário Oficial);

Requer, por fim, a concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida assegurando o exercício dos direitos constitucionais da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão e a reunião pacífica.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00(hum mil reais).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

5.37. XXV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: o prefeito do Município Alfa, situado no Estado Beta, é acusado pela imprensa local de negligenciar a saúde pública, deixando de realizar os investimentos constitucionais obrigatórios nos estabelecimentos médico-hospitalares situados na região. Com o objetivo de tirar proveito da situação para se autopromover, o prefeito elabora a seguinte estratégia: após obter expressa aprovação do Secretário Municipal do Meio Ambiente, em procedimento administrativo formalmente instaurado, às custas do erário e sob o subterfúgio de publicidade institucional, providencia a instalação de um grande painel de publicidade (outdoor) na encosta de um dos morros da cidade, o que era vedado pela legislação ambiental federal. Trata-se de área de proteção ambiental e notório ponto turístico, tendo ampla visibilidade. No outdoor, são elencadas todas as ações e investimentos da prefeitura relacionados à área da saúde durante a gestão do atual prefeito. Logo após a conclusão das obras, ambientalistas filiados a uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção ao meio ambiente comparecem ao local e detectam, dentre outras consequências prejudiciais, que a iluminação usada no outdoor durante o período noturno traria resultados nocivos à biodiversidade, ameaçando a sobrevivência de espécies animais notívagas da região. Essa nocividade se tornaria irreversível caso a iluminação viesse a ser utilizada por algumas semanas. Carlos, maior de idade, brasileiro nato no pleno gozo de seus direitos políticos, morador do Município Alfa, fica estarrecido ao tomar ciência do fato e indignado com a inércia das autoridades locais competentes. Diante disso, comparece a um escritório de advocacia indagando se poderia, devidamente representado em juízo por advogado(a) legalmente habilitado(a), adotar pessoalmente alguma providência judicial diante das

irregularidades apontadas. Carlos, ora Impetrante, é cidadão, ciente dos fatos, e não teve outra alternativa a não ser impetrar a presente Ação Popular.

– Ação: Ação Popular – art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 4.717/65.

– Competência: Justiça Estadual ou Vara Estadual .

– Legitimidade Ativa: Carlos (cidadão: título de eleitor – art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65).

– Legitimidade Passiva: o prefeito do Município Alfa, responsável pela expedição do ato, o secretário do meio ambiente que, em procedimento administrativo formal, aquiesceu expressamente com a construção e instalação do outdoor em área de proteção ambiental e o Município Alfa, pessoa jurídica de direito público interno, nos termos do art. 6.º da Lei n. 4.717/65.

– Fundamentos: art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal e/ou art. 1.º da Lei n. 4.717/65. Art. 37, caput, da CF/88 (legalidade, moralidade e impessoalidade), § 1.º (publicidade para promoção pessoal); arts. 3.º e 4.º, III, c, ambos da Lei n. 4.717/65 (lesividade ao patrimônio público), art. 225 da CF/88. Da medida liminar: especificar o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

– Outros requisitos formais da peça: comprovar a condição de cidadão com a cópia do título de eleitor (documento anexo, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65). Deverão ser formulados os seguintes pedidos: 1. deferimento de medida liminar para desativação da iluminação e/ou remoção do outdoor, nos termos do art. 5.º, § 4.º, da Lei Federal n. 4.717/65; 2. decretação de nulidade do ato que autorizou a instalação do outdoor, por conter vícios de ilegalidade e de desvio de finalidade, conforme alíneas c e e do art. 2.º da Lei Federal n. 4.717/65; 3. ressarcimento financeiro ao erário e reparação dos danos ambientais causados (art. 11 da

Lei n. 4.717/65); 4. citação dos Impetrados para contestar, sob pena de revelia (art. 7.º da Lei n. 4.717/65), 5. intimação do representante do Ministério Público (arts. 6.º, §§ 4.º e 7.º, da Lei n. 4.717/65). 6. juntada dos documentos, julgar procedente o pedido, confirmando a liminar e declarando a nulidade; 7. condenar os Impetrados no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65); provas (todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas). Valor da causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DE ALFA NO ESTADO BETA

(espaço de cinco linhas)

Carlos (qualificação completa: estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF), residente e domiciliado (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, Cidade/Estado, CEP: _____), portador do título de eleitor n. _____, Seção _____, Zona _____, cidadão em pleno gozo de seus direitos (doc. para a comprovação da legitimidade ativa para a presente ação, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), por seu advogado inscrito na OAB/_____, sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso) com endereço (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____) local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil) e endereço eletrônico _____, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXXIII do art. 5.º da Constituição Federal e na Lei n. 4.717/65, impetrar AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE

LIMINAR em face do senhor prefeito do Município Alfa, o secretário do meio ambiente e o Município Alfa, pessoa jurídica de direito público interno, respectivamente, cada qual com domicílio profissional (qualificações completas e com domicílios profissionais respectivos), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

Em matéria jornalística amplamente divulgada pela mídia, o prefeito do Município Alfa, situado no Estado Beta, é acusado pela imprensa local de negligenciar a saúde pública, deixando de realizar os investimentos constitucionais obrigatórios nos estabelecimentos médico-hospitalares situados na região. Com o objetivo de tirar proveito da situação para se autopromover, o prefeito elabora a seguinte estratégia: após obter expressa aprovação do Secretário Municipal do Meio Ambiente, em procedimento administrativo formalmente instaurado, às custas do erário e com o subterfúgio de publicidade institucional, providencia a instalação de um grande painel de publicidade (outdoor) na encosta de um dos morros da cidade, o que era vedado pela legislação ambiental federal. Trata-se de área de proteção ambiental e notório ponto turístico, tendo

ampla visibilidade. No outdoor, são elencadas todas as ações e investimentos da prefeitura relacionados à área da saúde durante a gestão do atual prefeito. Logo após a conclusão das obras, ambientalistas filiados a uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção ao meio ambiente comparecem ao local e detectam, dentre outras consequências prejudiciais, que a iluminação usada no outdoor durante o período noturno traria resultados nocivos à biodiversidade, ameaçando a sobrevivência de espécies animais notívagas da região.

II – DO DIREITO

A ação popular está prevista na Constituição Federal, no inciso LXXIII do art. 5.º, onde se lê:

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Tal remédio constitucional também encontra-se previsto no art. 1.º da Lei n. 4.717/65.

Ademais, é legitimado ativo para propor a ação popular “qualquer cidadão”, assim entendido o brasileiro em pleno gozo de seus direitos políticos, o que o autor comprova juntando a cópia de seu Título de Eleitor, atendendo a exigência expressamente prevista no art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65.

Prosseguindo, o art. 6.º da Lei da Ação Popular, estabelece a legitimidade passiva e determina que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1.º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Assim, figuraram no polo passivo da presente demanda o prefeito do Município Alfa, responsável pela expedição do ato, bem como o secretário do meio ambiente que, em procedimento administrativo formal, aquiesceu expressamente com a construção e instalação do outdoor em área de proteção ambiental. Figurará ainda no polo passivo o Município Alfa, pessoa jurídica de direito público interno.

No que diz respeito à competência, a ação popular deve ser proposta perante o juízo de primeiro grau (art. 5.º da Lei n. 4.717/65), não havendo competência originária de Tribunal para conhecê-la, ou seja, não há foro privilegiado para os chefes do Poder Executivo ou qualquer outra autoridade. A competência, no caso, é da justiça estadual, pois presente o interesse local foi atingido.

O impetrante, o cidadão Carlos, fica ciente, por intermédio de fatos divulgados na imprensa, que há ilegalidades cometidas pelo Prefeito que usa de propaganda oficial para se promover, violando o art. 37 , caput e § 1.º, ambos da CF/88, quais sejam, os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade.

Além disso, usando verba municipal e com a conivência do secretário municipal do meio ambiente, há adoção de ato concreto de instalação de grande painel de publicidade na encosta de um dos morros da cidade, o que era vedado pela legislação ambiental federal e que viola o meio ambiente protegido constitucionalmente no art. 225,

cuja iluminação usada durante o período noturno traria resultados nocivos à biodiversidade, ameaçando a sobrevivência de espécies animais notívagas da região. Essa nocividade se torna irreversível caso a iluminação viesse a ser utilizada por algumas semanas.

A ação popular é meio processual constitucional e como legítimo instrumento da cidadania protege os princípios da administração pública, e mais, o meio ambiente.

Está, pois, demonstrada, a lesão ao patrimônio público, ao meio ambiente e aos princípios da Administração Pública.

Diante de todo o exposto e da gravidade dos fatos, deve a presente ação ser julgada procedente.

III – DA LIMINAR

A liminar na ação popular é prevista no § 4.º do art. 5.º da Lei Federal n. 4.717/65 onde se lê:

“Art. 5.º (...) § 4.º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.”

Assim, uma vez presentes os requisitos legais de riscos de danos irreversíveis à biodiversidade em decorrência da iluminação inapropriada, caracterizando o periculum in mora, e o fundamento

relevante, demonstrando o fumus boni iuris, revela-se perfeitamente cabível o pedido liminar de desativação da iluminação e/ou remoção do outdoor.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência:

a) conceda a liminar para desativação da iluminação e/ou remoção do outdoor, nos termos do art. 5.º, § 4.º, da Lei Federal n. 4.717/65;

b) determine a citação dos Impetrados, nos prazos e termos dos incisos I e IV do art. 7.º da Lei n. 4.717/65, com cópia da presente, bem como documentos acostados, para contestar, sob pena de revelia;

c) determine a intimação do Ministério Público (art. 6.º, § 4.º e art. 7.º, I, a, ambos da Lei n. 4.717/65);

d) ao final, julgue procedente o pedido, confirmando a liminar, e declare a nulidade do ato que autorizou a instalação do outdoor, por conter vícios de ilegalidade e de desvio de finalidade, conforme alíneas c e e do art. 2.º da Lei Federal n. 4.717/65;

e) condene os impetrados e responsáveis a ressarcirem os danos causados, inclusive com a devolução dos valores gastos e a reparação dos danos ambientais (art. 11 da Lei n. 4.717/65);

f) condene os Impetrados no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65).

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que,
pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.38. XXVI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: com o objetivo de zelar pelo primado da ética, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa aprovou e o Governador do Estado sancionou uma minirreforma política, que direcionaria as eleições seguintes para os cargos de Deputado Estadual do Estado em questão.

Essa reforma foi veiculada por meio da Lei “X”. O art. 1.º dispunha que não seria admitido o registro de candidatura de qualquer pessoa com antecedentes criminais; o art. 2.º afastava a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e na televisão para os partidos políticos que abrigassem, em seus quadros, pessoas com antecedentes criminais; o art. 3.º dispunha sobre as distintas formas de exercício da cidadania no território do respectivo Estado. A Lei “X” do Estado Alfa foi saudada com grande entusiasmo pela população. Como o art. 4.º da Lei “X” dispunha que sua entrada em vigor seria imediata, aplicando-se inclusive às eleições que seriam realizadas três meses depois, era grande a expectativa de que as mudanças fossem percebidas de imediato. Apesar desse entusiasmo, o Partido Político Sigma, que tem representantes no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), e sofreria grandes prejuízos com a entrada em vigor da Lei “X”, por deliberação do seu Diretório Nacional, decidiu ingressar com a medida judicial adequada, utilizando, como paradigma, a Constituição da República. Esperava com esse procedimento que a constitucionalidade in abstracto desse diploma normativo fosse questionada perante o tribunal competente.

– Ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade: Lei estadual contraria a Constituição da República – art. 102, I, a, da CF/88.

- Competência: Supremo Tribunal Federal.
 - Legitimidade Ativa: Partido Político Sigma.
 - Legitimidade Passiva: deve ser indicado que o ato normativo foi editado pela Assembleia Legislativa do Estado Alfa e pelo Governador do Estado Alfa.
 - Fundamentos: a Lei "X" (arts. 1.º, 2.º e 4.º) viola a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, conforme dispõe o art. 22, I, da CF/88, assim há vício de inconstitucionalidade formal nos preceitos referidos. A Lei "X" (art. 4.º) afronta o princípio da anualidade eleitoral previsto no art. 16 da CF/88, assim há vício de inconstitucionalidade material no preceito referido. A Lei "X" (art. 3.º) afronta a competência privativa da União para legislar sobre cidadania, conforme dispõe o art. 22, XIII, da CF/88, assim há vício de inconstitucionalidade formal.
 - Outros requisitos formais da peça: fundamentos da cautelar: a patente inconstitucionalidade demonstrada nos fundamentos de mérito. O risco na demora, presente na realização da próxima eleição dentro de três meses, momento em que a Lei "X" será aplicada. Pedidos: pedido cautelar com o objetivo específico de sustar a eficácia da Lei "X", com fulcro no art. 10 da Lei n. 9.868/99. Pedido principal, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei "X". Fechamento. Data, nome, advogado e OAB
- Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Partido Político Sigma representado pelo presidente de sua Comissão Executiva Nacional, com representação no Congresso Nacional, pessoa jurídica de direito privado, com sede (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), por seu

advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações e com endereço eletrônico _____ (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 103, VIII, art. 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988, art. 2.º, VIII, e art. 10 da Lei n. 9.868/99 e no art. 319 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR em face do senhor Governador do Estado Alfa e da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, com endereços para intimações (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), responsáveis pela edição da Lei Estadual "X" que afronta dispositivos da Constituição Federal vigente, conforme a seguir será demonstrado:

I – DA NORMA IMPUGNADA

A Lei estadual "X" possui quatro artigos que afrontam a Constituição Federal vigente. Os arts. 1.º, 2.º e 4.º violam a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral.

O art. 4.º da Lei estadual "X" afronta o princípio da anualidade eleitoral previsto no art. 16 da CF/88.

O art. 3.º da Lei "X" afronta a competência privativa da União para legislar sobre cidadania.

Ao promulgar, nesses termos, a Lei Estadual "X" afrontou-se a Constituição Federal como se demonstrará a seguir.

II – FORO COMPETENTE E DO CABIMENTO DA ADIN

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

"Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

Restou, ainda, demonstrado o cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois o controle abstrato de constitucionalidade tem como objeto a Lei Estadual “X”.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

O Autor da presente ação é o Partido Político Sigma, que está representado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, portanto no Congresso Nacional e, desse modo, nos termos do art. 103, VIII, da CF/88 e art. 2.º, VIII, da Lei n. 9.868/99, é parte

legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. O partido político é legitimado neutro ou universal e, assim, não há a exigência de se demonstrar a pertinência temática.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva da ação direta de inconstitucionalidade em referência é do Governador do Estado Alfa e da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, que são os responsáveis pela edição da Lei “X”.

V – INCONSTITUCIONALIDADE

Os arts. 1.º, 2.º e 4.º da Lei Estadual “X” externam que houve a violação da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, conforme dispõe o art. 22, I, da CF/88. Neste caso, há vício de inconstitucionalidade formal nos preceitos referidos, uma vez que cabe

a lei federal disciplinar o tema direito eleitoral.

O art. 4.º da Lei “X” afronta o princípio da anualidade eleitoral previsto no art. 16 da CF/88, onde se lê:

“A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência”.

Assim há vício de inconstitucionalidade material deste art. 4.º, pois é um direito dos brasileiros não serem surpreendidos com mudanças repentinas no processo eleitoral.

O art. 3.º da Lei “X” afronta a competência privativa da União para legislar sobre cidadania, conforme dispõe o art. 22, XIII, da CF/88, assim há vício de inconstitucionalidade formal, pois lei estadual não pode disciplinar cidadania.

Sabe-se que a competência privativa da União é delegável aos Estados, e essa delegação se aperfeiçoa por intermédio de lei complementar (parágrafo único do art. 22 da CF/88) que, para o caso em tela, não existe.

Em breve síntese, legislação federal é a competente para tratar do tema direito eleitoral e cidadania, não sendo admissível lei estadual disciplinar tal matéria. Além disso, alteração no processo eleitoral deve entrar em vigor antes de um ano da data da próxima eleição.

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a determinação do art. 102, I, p, da CF/88 e do art. 10 da Lei n. 9.868/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade constante da inicial em virtude da patente contrariedade à Constituição

Federal no que diz respeito à lei estadual tratar do tema direito eleitoral e cidadania que é federal (*fumus boni iuris*). Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face do dano irreparável, pois com a vigência da lei o partido político Sigma será afetado pelas restrições de modo imediato.

VII – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que o Supremo Tribunal Federal determine:

a) a concessão de medida cautelar com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender os efeitos da Lei “X” que estabelece indevidamente restrições de direito eleitoral e cidadania (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

b) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que, como autoridades responsáveis pela Lei, manifestem-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99;

c) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei “X” que estabelece em seu art. 1.º que não seria admitido o registro de candidatura de qualquer pessoa com antecedentes criminais; o art. 2.º afasta a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e na televisão para os partidos políticos que abrigassem, em seus quadros, pessoas com antecedentes criminais; o art. 3.º dispõe sobre as distintas formas de exercício da cidadania no território do respectivo Estado; e o art. 4.º da Lei “X” dispõe que sua entrada em vigor é imediata, aplicando-se inclusive às eleições que seriam realizadas três meses depois (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

d) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que se manifestem, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

e) a intimação do excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 3.º, da CF/88;

f) a intimação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, para que emita seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da CF/88.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.39. OAB FGV 2018.3 – PROVA UNIFICADA XXVII

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos: Emenda à Constituição Estadual n. 5/2018 disciplinando, detalhadamente, a forma de exploração de diamantes no território do Estado Alfa, incluía os requisitos formais a serem cumpridos junto às autoridades estaduais e os limites quantitativos a serem observados na extração, no armazenamento e no transporte de cargas. A Emenda à Constituição Estadual n. 5/2018 foi sancionada pelo Governador do Estado.

– Ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade: Emenda Constitucional estadual contraria a Constituição da República – art. 102, I, a, da CF/88 c/c.

o art. 1.º da Lei n. 9.868/99.

– Competência: Supremo Tribunal Federal.

– Legitimidade Ativa: Associação Nacional dos Geólogos.

– Legitimidade Passiva: deve ser indicado que o ato normativo foi editado pela Assembleia Legislativa do Estado Alfa e pelo Governador do Estado Alfa.

– Fundamentos: existe inconstitucionalidade formal pois: a) a Emenda Constitucional estadual n. 5/2018 violou a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e mineração, conforme dispõe o art. 22, XII, da CF/88; b) a Emenda Constitucional n. 5/2018 violou a competência privativa da União para legislar sobre transporte, conforme dispõe o art. 22, XI, da CF/88; c) as normas sobre processo legislativo são de observância obrigatória pelos demais entes federativos, por força da simetria, prevista no art. 25, caput, da CF/88, não havendo previsão, no art. 60 da CF/88, de participação do chefe do Poder Executivo no fim do processo de reforma constitucional.

– Outros requisitos formais da peça: deve ser indicado o embasamento da medida cautelar a ser pleiteada, já que, além da patente inconstitucionalidade, há risco na demora, pois os novos requisitos criados podem inviabilizar a continuidade da atividade de exploração de diamantes. Deve ser formulado pedido de medida cautelar, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.868/99, com o objetivo específico de sustar a eficácia da Emenda Constitucional n. 5/2018. O pedido principal deve ser a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 5/2018. Por fim, deve haver o fechamento da petição com a identificação do advogado.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Associação Nacional dos Geólogos, representada pelo seu representante legal, pessoa jurídica de direito privado, com sede (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações e com endereço eletrônico _____ (art. 77, V, do Código de Processo Civil), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 103, IX, art. 102, I, a e p, da Constituição Federal de 1988, art. 2.º, IX, e art. 10 da Lei n. 9.868/99 e no art. 319 e s. do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR em face do Senhor Governador do Estado Alfa e da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, com endereços para intimações (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), responsáveis pela edição da Emenda Constitucional n. 5/2018 que afronta dispositivos da Constituição Federal vigente, conforme a seguir será demonstrado:

I – DA NORMA IMPUGNADA

A Emenda à Constituição Estadual n. 5/2018 possui conteúdo que afronta a Constituição Federal vigente, pois disciplina, detalhadamente, a forma de exploração de diamantes no território do Estado, bem como regulamenta o transporte das cargas exploradas.

Por fim, o Governador do Estado Alfa sancionou a citada emenda constitucional estadual, mais uma vez afrontando a Constituição Federal, como a seguir será demonstrado.

II – FORO COMPETENTE E DO CABIMENTO DA ADIN

O art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 estabelece que:

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”

Desse modo, verifica-se que a competência para processamento e julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade é originária do Supremo Tribunal Federal.

Restou, ainda, demonstrado o cabimento da Ação direta de Inconstitucionalidade, pois o controle abstrato de constitucionalidade tem como objeto a Emenda à Constituição Estadual n. 5/2018.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

A Autora da presente ação é a Associação Nacional do Geólogos, desse modo, nos termos do art. 103, IX, da CF/88, c/c. o art. 2.º, IX, da Lei n. 9.868/99, é parte legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, sendo nítida a pertinência temática do ato normativo com as atividades dos associados da entidade de classe.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva da ação direta de inconstitucionalidade em referência é do Governador do Estado Alfa e da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, que são os responsáveis pela edição da Emenda à Constituição Estadual n. 5/2018.

V – INCONSTITUCIONALIDADE

Percebe-se que há vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que norma estadual tratou de temas atinentes à competência privativa

da União, bem como houve violação do processo legislativo para a promulgação de emenda constitucional estadual.

A Emenda Constitucional n. 5/2018 violou a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e mineração, conforme dispõe o art. 22, XII, da CF/88.

A Emenda Constitucional n. 5/2018 violou a competência privativa da União para legislar sobre transporte, conforme dispõe o art. 22, XI, da CF/88.

Por fim, as normas sobre processo legislativo são de observância obrigatória pelos demais entes federativos, por força da simetria, prevista no art. 25, caput, da CF/88, não havendo previsão, no art. 60 da CF/88, de participação do chefe do Poder Executivo no fim do processo de reforma constitucional.

Em breve síntese, legislação federal é a competente para tratar do tema jazidas, mineração e transporte, não sendo admissível norma estadual disciplinar tal matéria. Além disso, caberia à Mesa da Assembleia Legislativa promulgar a Emenda Constitucional estadual.

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. Nesse sentido é a determinação do art. 102, I, p, da CF/88 e art. 10 da Lei n. 9.868/99.

Há plausibilidade jurídica na arguição de inconstitucionalidade constante da inicial em virtude da patente contrariedade à Constituição Federal no que diz respeito à emenda constitucional tratar do tema mineração e transporte que é federal e ser promulgada pelo Governador do Estado (*fumus boni iuris*). Está igualmente atendido o requisito do *periculum in mora*, em face do dano irreparável, pois a

vigência da emenda afetar a população, o meio ambiente e os interesses federais de modo imediato, podendo inviabilizar a continuidade da atividade de exploração de diamantes.

VII – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Autor que o Supremo Tribunal Federal determine:

a) a concessão de medida cautelar com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender os efeitos da Emenda Constitucional Estadual n. 5/2018, que trata indevidamente do tema jazidas, mineração, exploração, transporte e que foi promulgada pelo Governador (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

b) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que, como autoridades responsáveis pela lei, manifestem-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei n. 9.868/99;

c) a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional n. 5/2018, que violou a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, recursos minerais, mineração e transporte, bem como por violação do processo legislativo estabelecido na Constituição Federal (cópias anexas nos termos do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99);

d) a intimação do Presidente da Assembleia e do Governador para que se manifestem, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99;

e) a intimação do excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência

constitucional do art. 103, § 3.º, da CF/88;

f) a intimação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, para que emita seu parecer, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 8.º da Lei n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 1.º, da CF/88.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

5.40. OAB FGV 2019.1 – PROVA UNIFICADA XXVIII

Estruturação da peça:

– Resumo dos fatos:

– Ação: Ação Popular – art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 4.717/65.

– Competência: Juízo Cível da Comarca X ou ao Juízo de Fazenda Pública da Comarca X, já que os dados constantes do enunciado não permitem identificar a organização judiciária do local.

– Legitimidade Ativa: João da Silva (cidadão: título de eleitor – art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65).

– Legitimidade Passiva: Pedro dos Santos, o Prefeito Municipal, o Município Alfa e a Sociedade Empresária K, nos termos do art. 6.º da Lei n. 4.717/65.

– Fundamentos: art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal e/ou art. 1.º da Lei n. 4.717/65, art. 37, caput, da CF/88 (legalidade); o meio ambiente, nos termos do art. 225, caput, da CF/88, inclusive no âmbito da atividade econômica, conforme dispõe o art. 170, VI, da CF/88, a licença concedida é nula, em razão da ilegalidade do objeto (Lei n. 4.717/65, art. 2.º, caput, d), já que a realização da obra importará em afronta ao ato normativo que

considerou o local uma área de preservação ambiental permanente (Lei n. 4.717/65, art. 2.º, parágrafo único, c). Da medida liminar: especificar o fumus boni iuris e o periculum in mora.

– Outros requisitos formais da peça: comprovar a condição de cidadão com a cópia do título de eleitor (documento anexo, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), para impedir que a sociedade empresária K inicie as obras no local. O fumus boni iuris decorre da flagrante ilegalidade da licença de construção, e o periculum in mora da iminência de serem causados danos irreversíveis ao meio ambiente, considerando as raras espécies da fauna e da flora silvestre existentes no local. A declaração de nulidade da licença concedida pelo Município Alfa, assinada pelo prefeito Pedro dos Santos, e a proibição de realização de obras na área de preservação ambiental permanente. Citação dos Impetrados para contestar, sob pena de revelia (art. 7.º da Lei n. 4.717/65), a intimação do representante do Ministério Público (arts. 6.º, § 4.º, e V.º, da Lei n. 4.717/65), a juntada dos documentos, julgar procedente o pedido, confirmando a liminar e declarando a nulidade da licença; condenar os Impetrados ao pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/2019); condenação dos responsáveis ao ressarcimento dos danos (art. 11 da Lei n. 4.717/65). Provas (todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas). Valor da causa. Nesses termos, pede deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA
CÍVEL DA COMARCA X

(espaço de cinco linhas)

JOÃO DA SILVA, (qualificação completa: estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF) residente e domiciliado (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), portador do título de eleitor n. _____, Seção _____, Zona _____, cidadão em pleno gozo de seus direitos (doc. para a comprovação da legitimidade ativa para a presente ação, nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65), por seu advogado inscrito na OAB/_____, sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso), com endereço (na Rua _____, n. _____, Bairro _____, [Cidade/Estado], CEP: _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil) e endereço eletrônico _____, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXXIII

do art. 5.º da Constituição Federal e Lei n. 4.717/65, impetrar AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR em face do senhor Pedro dos Santos, o Prefeito Municipal, o representante jurídico e legal do Município Alfa e da Sociedade Empresária K, respectivamente, cada qual com domicílio profissional (qualificações completas e com domicílios profissionais respectivos), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

I – DOS FATOS

A sociedade empresária K, concessionária do serviço de manutenção de uma estrada municipal, decidiu ampliar suas instalações de apoio. Os equipamentos foram alugados e foi providenciado o cerco do local com tapumes. De imediato, foi fixada a placa, assinada por engenheiro responsável, indicando a natureza da obra a ser realizada e a data do seu início, o que ocorreria trinta dias depois, prazo necessário para a conclusão dos preparativos. O local escolhido era uma área de preservação ambiental permanente do Município Alfa. Considerando esse dado, foi formulado requerimento, dirigido à concessionária, solicitando que a obra não fosse realizada. A sociedade empresária K indeferiu o requerimento, sob o argumento de que o local escolhido fora aprovado pelo Município, que concedeu a respectiva licença,

assinada pelo prefeito Pedro dos Santos, permitindo o início das obras. O local abriga diversas espécies raras da flora e da fauna silvestre.

II – DO DIREITO

A ação popular está prevista na Constituição Federal, no inciso LXXIII do art. 5.º, onde se lê:

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

Tal ação também encontra-se prevista no art. 1.º da Lei n. 4.717/65.

Ademais, é legitimado ativo para propor a ação popular “qualquer cidadão”, assim entendido o brasileiro em pleno gozo de seus direitos políticos, o que o autor João comprova juntando a cópia de seu Título de Eleitor, atendendo a exigência expressamente prevista no art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65.

Prosseguindo, o art. 6.º da Lei da Ação Popular estabelece a legitimidade passiva e determina que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1.º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Assim, figuraram no polo passivo da presente demanda Pedro dos Santos, o Prefeito Municipal, o Município Alfa e a Sociedade Empresária K.

No que diz respeito à competência, a ação popular deve ser proposta perante o juízo de primeiro grau (art. 5.º da Lei n. 4.717/65), não havendo competência originária de Tribunal para conhecê-la, ou seja,

não há foro privilegiado para os chefes do Poder Executivo ou qualquer outra autoridade. A competência, no caso, é da justiça comum estadual, pois presente o interesse é local, ou seja, municipal.

A empresa contratada e beneficiada com a licença municipal ilegal é a Sociedade Empresária K.

Nessa toada, verifica-se violação do princípio da legalidade, princípio basilar da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

Em breve síntese, a ação popular é meio processual constitucional para o presente caso e como legítimo instrumento da cidadania para proteger os princípios da administração pública, e mais, o meio ambiente, nos termos do art. 225, caput, da CF/88, inclusive no âmbito da atividade econômica, conforme dispõe o art. 170, VI, da CF/88.

A licença municipal em questão concedida é nula, em razão da ilegalidade do objeto (Lei n. 4.717/65, art. 2.º, caput, d), já que a realização da obra importará em afronta ao ato normativo que considerou o local uma área de preservação ambiental permanente (Lei n. 4.717/65, art. 2.º, parágrafo único, c).

Diante de todo o exposto e da gravidade dos fatos, deve a presente ação ser julgada procedente.

III – DA LIMINAR

Há previsão legal de concessão de liminar na Lei n. 4.717/65, no art. 5.º, § 4.º, e no presente caso o fumus boni iuris decorre da flagrante ilegalidade da licença de construção, e o periculum in mora da iminência de serem causados danos irreversíveis ao meio ambiente, considerando as raras espécies da fauna e da flora silvestre existentes no local.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é cabível o

pedido e necessária a concessão da liminar para suspender os contratos.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante que Vossa Excelência:

a) conceda a liminar declarando a nulidade da licença municipal concedida e impedindo a iminente realização das obras no local escolhido, que abriga diversas espécies raras da flora e da fauna silvestre;

b) determine a citação dos Impetrados, nos prazos e termos dos incisos I e IV do art. 7.º da Lei n. 4.717/65, com cópia da presente, bem como documentos acostados;

c) determine a intimação do Ministério Público (art. 6.º, § 4.º, e art. 7.º, I, a, ambos da Lei n. 4.717/65);

d) ao final, julgue procedente o pedido, confirmando a liminar, e declare nula a licença municipal concedida com a interrupção definitiva da obra;

e) condene os impetrados e responsáveis a ressarcirem os danos causados (art. 11 da Lei n. 4.717/65);

f) condene os Impetrados ao pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 12 da Lei n. 4.717/65).

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que,

Pede deferimento.

Local e data.

5.41. OAB FGV 2019 – PROVA UNIFICADA XXIX

Estruturação da peça:

- Resumo dos fatos:
- Ação: Mandado de Segurança – art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 12.016/2009.
- Competência: Juízo Cível da Comarca X ou ao Juízo de Fazenda Pública da Comarca X.
- Legitimidade Ativa: João.
- Legitimidade Passiva: Secretário Municipal de Educação do Município Alfa.
- Fundamentos: direitos fundamentais de acesso à informação (art. 5.º, XIV), direito de receber dos órgãos públicos as informações de interesse coletivo ou geral (art. 5.º, XXXIII) e acesso ao teor dos atos de governo (art. 37, § 3.º, II), todos da Constituição Federal de 1988. A informação que deve ser fornecida no prazo estabelecido pelo art. 11 da Lei n. 12.527/2011, independentemente de qualquer esclarecimento a respeito dos motivos determinantes da solicitação, nos termos do art. 10, § 3.º, da Lei n. 12.527/2011. O fato de João não residir no Município é irrelevante, pois os entes federados não podem criar distinções entre brasileiros, nos termos do art. 19, III, da CF/88.
- Outros requisitos formais da peça: pedido de liminar, para receber as informações negadas (art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009), notificação da autoridade coatora (art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009) e da entidade da qual ele faz parte (art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009), intimação do membro do Ministério Público, não ocorrência do prazo decadencial, concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida para ter acesso às informações requeridas. Valor da causa. Nesses termos, pede e espera deferimento. Local e data. Advogado/OAB.

Sugestão de resposta:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA
CÍVEL DA COMARCA X

(espaço de cinco linhas)

João (qualificação completa), conforme documento anexo (doc. 1), por seu advogado inscrito na OAB/_____ sob n. _____, que esta subscreve (instrumento de mandato incluso – doc. 2), com endereço na (Rua _____, n. _____, Bairro _____), local indicado para receber intimações (art. 77, V, do Código de Processo Civil) e endereço eletrônico _____, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso LXIX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988, art. 319 do Código de Processo Civil e em conformidade com o art. 1.º e s. da Lei n. 12.016/2009, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face do Secretário Municipal de Educação do Município Alfa, conforme os motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

I – DOS FATOS

João decidiu fiscalizar a forma de distribuição dos recursos aplicados na área de educação no Município Alfa, sede da Comarca X e vizinho àquele em que residia, considerando as dificuldades enfrentadas pelos moradores do local. Para tanto, compareceu à respectiva Secretaria Municipal de Educação e requereu o fornecimento de informações detalhadas a respeito das despesas com educação no exercício anterior, a discriminação dos valores gastos com pessoal e custeio em geral e os montantes direcionados a cada unidade escolar, já que as contratações eram descentralizadas. O requerimento formulado

foi indeferido por escrito, pelo Secretário Municipal de Educação, sob o argumento de que João não residia no Município Alfa; os gastos com pessoal eram sigilosos, por dizerem respeito à intimidade dos servidores; as demais informações seriam disponibilizadas para o requerente e para o público em geral, via Internet, quando estivesse concluída a estruturação do “portal da transparência”, o que estava previsto para ocorrer em 2 (dois) anos.

II – DO DIREITO

A competência para apreciação do presente mandado de segurança é do Juízo Cível da Comarca X, onde se consumou a violação ao direito líquido e certo de ter acesso à informação e de receber dos órgãos públicos as informações de interesse coletivo ou geral.

A legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança no caso em questão é João, pois a Constituição Federal garante o acesso ao teor dos atos de governo (art. 37, § 3.º, II), o acesso à informação (art. 5.º, XIV) e o direito de receber dos órgãos públicos as informações de interesse coletivo ou geral (art. 5.º, XXXIII).

A autoridade coatora é o Secretário Municipal de Educação do Município Alfa, pois é o responsável pelo indeferimento do requerimento formulado.

Repise-se que os usuários têm assegurado o seu acesso ao teor dos atos de governo, nos termos do art. 37, § 3.º, II, da CF/88, informação que deve ser fornecida no prazo estabelecido pelo art. 11 da Lei n. 12.527/2011, independentemente de qualquer esclarecimento a respeito dos motivos determinantes da solicitação, nos termos do art. 10, § 3.º, da Lei n. 12.527/2011.

As informações relativas aos gastos com pessoal não dizem respeito

à intimidade dos servidores, pois refletem a maneira de gasto do dinheiro público, apresentando indiscutível interesse público. O fato de João não residir no Município é irrelevante, pois os entes federados não podem criar distinções entre brasileiros, nos termos do art. 19, III, da CF/88.

Há direito líquido e certo lastreado em prova pré-constituída, o que decorre do indeferimento, por escrito, do requerimento formulado por João.

O prazo decadencial para interposição do mandado de segurança é de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

No presente caso, tal prazo decadencial não ocorreu, pois a ação constitucional foi proposta logo após o indeferimento administrativo.

No presente caso, em breve síntese, João foi impedido de exercer seus direitos constitucionais em virtude do ato do Secretário Municipal de Educação que indeferiu o acesso à informação, nos termos do art. 5.º, XIV, da CF/88, e o direito de receber dos órgãos públicos as informações de interesse coletivo ou geral, conforme dispõe o art. 5.º, XXXIII, da CF/88. João tem assegurado o seu acesso ao teor dos atos de governo, nos termos do art. 37, § 3.º, II, da CF/88, informação que deve ser fornecida no prazo estabelecido pelo art. 11 da Lei n. 12.527/2011, independentemente de qualquer esclarecimento a respeito dos motivos determinantes da solicitação, nos termos do art. 10, § 3.º, da Lei n. 12.527/2011.

III – DA LIMINAR

O art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o

ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

A relevância do fundamento pode ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, *fumus boni iuris*, enquanto a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado *periculum in mora*.

Assim, estão presentes o *fumus boni iuris*, pois a ilegalidade é manifesta, uma vez que foram violados os direitos fundamentais do acesso à informação e o direito de receber dos órgãos públicos as informações de interesse coletivo ou geral, bem como o *periculum in mora*, pois tais informações podem auxiliar com celeridade as informações almejadas, o que permitiria sua divulgação à população interessada, permitindo-lhe avaliar a conduta do Prefeito Municipal, candidato à reeleição no processo eleitoral em curso, justificando plenamente o pedido de liminar.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer o Impetrante a Vossa Excelência:

a) a concessão de medida liminar, com a expedição do respectivo ofício à Autoridade coatora (Secretário Municipal de Educação do Município Alfa), considerando que os requisitos *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* restam evidenciados, no sentido de assegurar as informações requeridas até que sobrevenha a decisão final do presente mandado de segurança;

b) determinar a notificação pessoal da autoridade coatora (Secretário Municipal de Educação do Município Alfa) para prestar informações no prazo legal de dez dias, como de direito, entregando-lhe a segunda via da petição inicial acompanhada dos documentos reproduzidos por cópia;

c) dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7.º, II, da Lei n. 12.016/2009;

d) determinar a intimação do Ministério Público para oferecer parecer, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009;

e) acatar as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante que acompanham a presente petição inicial, confirmando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança (cópia do ato impugnado);

f) fixar multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil.

Requer, por fim, a concessão da segurança e a ratificação da liminar deferida assegurando o exercício dos direitos constitucionais de acesso à informação, nos termos do art. 5.º, XIV, da CF/88, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de interesse coletivo ou geral, conforme dispõe o art. 5.º, XXXIII, da CF/88, o acesso ao teor dos atos de governo, nos termos do art. 37, § 3.º, II, da CF/88, informação que deve ser fornecida no prazo estabelecido pelo art. 11 da Lei n. 12.527/2011, independentemente de qualquer esclarecimento a respeito dos motivos determinantes da solicitação, nos termos do art. 10, § 3.º, da Lei n. 12.527/2011.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que,

Pede deferimento.

Local e data.

Advogado/OAB

TERCEIRA PARTE

Questões Dissertativas

1

Questões dissertativas das provas do Exame da OAB

QUESTÃO 1

Um grupo de deputados federais apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 157/2003 – cujo texto é a seguir transcrito – com o objetivo de convocar uma assembleia de revisão constitucional.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 157, de 2003. Convoca assembleia de revisão constitucional e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3.º do art. 60 da CF/88, promulga a seguinte Emenda Constitucional:

“Art. 1.º Será instalada, no dia 1.º-1-2007, assembleia de revisão constitucional, formada pelos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o objetivo de revisar a Constituição.

Art. 2.º A revisão constitucional, consubstanciada em apenas um ato, será promulgada após a aprovação de seu texto, em dois turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta dos membros da assembleia de revisão constitucional.

Parágrafo único. A revisão constitucional observará o disposto no art. 60, § 4.º, da CF/88.

Art. 3.º A assembleia de revisão constitucional extinguir-se-á no prazo máximo de 12 meses contados da data de sua instalação.

Art. 4.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

Considerando a proposição legislativa acima descrita, elabore um texto

dissertativo avaliando, de forma justificada, a constitucionalidade da referida PEC, a legitimidade democrática da convocação da assembleia de revisão e a compatibilidade dessa convocação com a teoria do poder constituinte.

QUESTÃO 2

A anencefalia é uma má-formação congênita, caracterizada pelo não desenvolvimento do encéfalo, que é uma parte vital do cérebro humano. Os fetos anencefálicos não desenvolvem atividade cerebral e têm parada cardiorrespiratória poucos minutos após o parto.

Por considerar que exigir de uma mulher que espere, até o fim da gestação, o nascimento de um feto comprovadamente anencefálico fere o princípio da dignidade humana, um deputado federal apresentou projeto de lei autorizando a realização de aborto de anencéfalos, a qualquer momento da gestação. Esse projeto recebeu parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, sob os argumentos de que as regras propostas pelo deputado são incompatíveis com a previsão constitucional do direito à vida, que é o direito constitucional de maior hierarquia, e de que, portanto, a autorização do aborto de fetos anencefálicos somente poderia ser feita mediante emenda à própria Constituição da República.

Considerando as informações e a situação hipotética apresentada acima, redija um texto dissertativo analisando, de forma justificada, a constitucionalidade do projeto citado e avaliando, necessariamente, a consistência e a correção jurídica dos argumentos constantes no referido parecer da CCJC.

QUESTÃO 3

Durante uma partida de futebol realizada entre um time brasileiro e um time argentino, o jogador argentino Leandro, que reside em Buenos Aires,

foi preso em flagrante delito pela prática do crime de racismo, por ter dirigido contra um jogador brasileiro insultos de cunho racista. Leandro está preso em uma delegacia de polícia e seus advogados tentam fazer com que seu ato seja qualificado como injúria agravada por racismo, o que permitiria a sua libertação mediante pagamento de fiança, o que não acontece quando o crime é qualificado como racismo, que é um crime inafiançável. Consultado acerca do caso, um advogado afirmou o seguinte:

“Essa questão é juridicamente controvertida e Leandro possivelmente ficará preso por mais algum tempo. Os estrangeiros que não residem no Brasil não tem direito a habeas corpus, direito esse que é garantido pelo art. 5.º da CF/88 apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes no país”.

Considerando a situação hipotética acima, redija um texto dissertativo avaliando a correção da interpretação dada pelo advogado citado ao caput do art. 5.º da CF/88, combinado com o inciso LXVIII desse mesmo dispositivo, transcritos a seguir:

“Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

QUESTÃO 4

Há dois meses, André Soares, servidor público militar ocupante de cargo nas Forças Armadas, foi removido, ex officio, de Belém/PA para Salvador/BA. À época da remoção, seu filho, André Soares Jr., cursava o segundo semestre do curso de Direito em uma faculdade privada, na qual ingressou mediante aprovação no exame vestibular.

Com base no art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do art. 1.º da Lei n. 9.536/97, André Soares Jr. solicitou transferência obrigatória para a Universidade Federal da Bahia (UFBA). A solicitação foi negada, sob o argumento de que essa transferência violaria o princípio da isonomia e que, portanto, seria incabível admitir interpretação do referido art. 1.º que permitisse a transferência obrigatória de instituições privadas para instituições públicas de ensino.

LDB (Lei n. 9.394/96)

“Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.”

Lei n. 9.536/97

“Art. 1.º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou localidade mais próxima desta.”

Considerando a situação hipotética e os artigos de lei apresentados acima, redija texto dissertativo avaliando a correção jurídica do argumento utilizado pela UFBA indeferir a solicitação de André Soares Jr. e a possibilidade de utilização da inconstitucionalidade como fundamentação do referido ato administrativo de indeferimento.

QUESTÃO 5

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo promulgou emenda à Constituição Estadual determinando a criação de uma Procuradoria da

Assembleia Legislativa, órgão do Poder Legislativo competente para representar judicialmente os interesses da Assembleia, ativa ou passivamente, nos processos referentes ao Poder Legislativo estadual.

O governador do Espírito Santo, assessorado pela Procuradoria do Estado, decidiu impugnar judicialmente a referida emenda, por considerá-la incompatível com a Constituição Federal, mediante ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Considerando a situação hipotética acima descrita, redija um texto dissertativo avaliando a constitucionalidade da referida emenda e a possibilidade de o mencionado governador do ES impugná-la perante o STF mediante ação direta de inconstitucionalidade.

QUESTÃO 6

O art. 1.º da MedProv 293/2006 determina:

“A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas:

- I – exercer a representação dos trabalhadores, por meio das organizações sindicais a ela filiadas; e
- II – participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores.

Parágrafo único. Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta medida provisória, a entidade associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores.”

No tocante a essa medida, o Ministro do Trabalho observou que as centrais vão representar os trabalhadores nas negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam

composição tripartite, mas descartou a possibilidade de as entidades se envolverem em acordos e convenções coletivas. O Ministro justificou o reconhecimento das centrais por medida provisória, apesar de existir um anteprojeto do próprio governo já finalizado sobre esse assunto. "A urgência justifica-se pela necessidade de dar respaldo legal às centrais sindicais, como reconhecimento da legitimidade conquistada nos últimos 20 anos."

Disponível em: [www.camara.gov.br (com adaptações)].

Elabore um texto dissertativo que avalie a compatibilidade da medida provisória acima referida com o ordenamento constitucional, em relação tanto ao aspecto da compatibilidade com o sistema sindical desenhado na Constituição da República quanto ao da possibilidade do uso de medida provisória para regular a referida matéria.

QUESTÃO 7

O Governador do Espírito Santo ingressou perante o Supremo Tribunal Federal (STF) com ação direta de inconstitucionalidade (ADIn), impugnando a validade de uma lei estadual do Espírito Santo que atribuía ao Poder Legislativo iniciativa legislativa relativa a leis que aumentavam a remuneração dos servidores públicos ocupantes de cargos na administração estadual.

No tocante a essa ADIn, um professor de direito afirmou que (1) essa ação constitui instrumento de controle concreto de constitucionalidade, pois se trata do exame concreto da compatibilidade entre a lei impugnada e a Constituição da República; (2) o acórdão que viesse a decidir o referido processo somente teria efeitos erga omnes a partir do momento em que o Senado Federal suspendesse a vigência do dispositivo eventualmente declarado inconstitucional pelo STF; (3) a decisão do STF teria efeitos ex nunc, desde que três quintos dos ministros do STF não decidissem atribuir-lhe efeitos ex tunc.

Em face da situação hipotética acima descrita, redija um texto dissertativo

que avalie, quanto à correção, as três afirmações feitas pelo referido professor.

QUESTÃO 8

No curso de uma ação de reconhecimento de paternidade, o juiz de direito que presidia o feito determinou ao réu que fornecesse uma pequena quantidade de sangue com o objetivo de realizar o exame de DNA, o que possibilitaria uma decisão segura a respeito da paternidade que lhe era imputada. O réu recusou-se a promover o recolhimento do sangue, alegando que essa ordem era contrária aos princípios da dignidade humana, da intimidade e da intangibilidade do seu próprio corpo. O juiz, porém, em nome da defesa dos direitos indisponíveis da criança, cuja proteção tem caráter constitucional, determinou a realização coercitiva do referido exame.

A propósito da situação acima descrita, redija um texto dissertativo acerca da constitucionalidade do ato do juiz que determinou a realização coercitiva do exame de DNA do réu.

QUESTÃO 9

O Presidente da República editou a MedProv XX/2006, que, por não ter sido apreciada pela Câmara dos Deputados, estava obstruindo a pauta dessa casa legislativa. O Presidente da República tinha interesse em que se realizasse celeremente a votação de um projeto de emenda à Constituição cuja votação estava sobrestada pelo trancamento da pauta.

Frente a essa situação, um assessor sugeriu ao Presidente que editasse a MedProv YY/2006, ab-rogando a MedProv XX, pois isso acarretaria a sua imediata invalidação. Com isso, o Congresso Nacional não mais poderia apreciar a MedProv XX, o que destrancaria a pauta. Além disso, como a MedProv YY teria efeitos meramente revogatórios, ela não poderia ser apreciada pelo Congresso Nacional porque, como o ordenamento brasileiro

não admite a reprimenda, a inadmissão da MedProv YY não teria o condão de tornar novamente válida a MedProv XX.

Em face da situação hipotética acima descrita, redija um texto dissertativo que avalie a correção jurídica dos argumentos contidos na sugestão feita pelo assessor do Presidente.

QUESTÃO 10

Um deputado do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a redução de causas temerárias aumentaria a celeridade da tramitação dos feitos no Poder Judiciário estadual, apresentou projeto de lei ordinária determinando que:

“Art. 1.º Os autores de toda demanda judicial acerca de direitos patrimoniais disponíveis devem depositar compulsoriamente em juízo 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Art. 2.º Para ter direito a contestar uma ação que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis, o réu deve depositar previamente em juízo 5% do valor da causa.

Parágrafo único. Havendo contestação ao valor da causa, o réu deve depositar imediatamente 5% da parcela incontroversa e o restante, uma vez julgada a impugnação do valor da causa.

Art. 3.º Transitada em julgado a decisão do respectivo processo, o montante do depósito compulsório será revertido à parte vencedora, na qualidade de honorários advocatícios”.

Acerca da situação hipotética acima, redija um texto dissertativo que analise a compatibilidade do referido projeto com o ordenamento constitucional, avaliando a constitucionalidade formal e material.

QUESTÃO 11

Com o propósito de melhor adequar o questionamento de uma lei considerada inconstitucional, em vista dos mecanismos disponíveis para tal

fim, disserte, de forma objetiva, sobre o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, abordando, de forma sintética e fundamentada, os seguintes aspectos:

- Características do sistema adotado no Brasil;
- Os órgãos que realizam controle de constitucionalidade;
- Forma ou modo de controle e seus respectivos efeitos.

QUESTÃO 12

Deparando-se com decisões no STF que não admitiam ações diretas de inconstitucionalidade por falta de “pertinência temática”, determinada associação de âmbito nacional solicitou parecer sucinto sobre o tema para melhor orientar a compreensão dos diretores a esse respeito.

Como advogado responsável pela referida orientação, explique, de forma objetiva e fundamentada, o que vem a ser “pertinência temática” em tais ações.

QUESTÃO 13

Suponha que você seja procurado por um cliente em dúvida sobre a melhor medida a ser tomada para solucionar determinada questão, e que ele lhe encaminhe pedido de esclarecimentos técnicos sobre as principais diferenças entre a ação direta de inconstitucionalidade e o mandado de injunção.

Acerca desse tema, redija um texto dissertativo, abordando, de forma objetiva e fundamentada, os seguintes aspectos:

- natureza e finalidade de cada um desses instrumentos jurídicos;
- legitimidades ativas e passivas ad causam;
- competência;
- eficácia da decisão relativamente aos sujeitos por ela atingidos.

QUESTÃO 14

O que é violação indireta ou reflexa à Constituição Federal?

É cabível recurso extraordinário em tal hipótese? Justifique sua resposta.

QUESTÃO 15

Redija um texto, de forma fundamentada, acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal legislarem sobre aspectos da competência legislativa privativa da União.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 16 E 17

Um Estado brasileiro editou, em 2003, uma lei que estabeleceu que as condenações judiciais inferiores a 60 salários mínimos seriam dispensadas da regra do precatório, devendo ser pagas imediatamente pelo respectivo Ente Federativo.

O Governador do referido Estado propôs ação direta de inconstitucionalidade em face dessa lei, alegando que o art. 87 do ADCT estabelece o limite máximo de 40 salários mínimos, sendo, portanto, inconstitucional a referida lei estadual.

O STF julgou improcedente a referida ação direta de inconstitucionalidade, ao entendimento de que o art. 87 do ADCT é norma de transição até que os entes federativos, em sua soberania, estabeleçam os limites estaduais.

Ocorre que outro Estado da Federação editou, também em 2003, uma lei fixando igualmente o limite máximo de 60 salários mínimos para que as condenações judiciais fossem pagas imediatamente, dispensando a regra do precatório. João logrou-se vencedor em uma ação judicial, com decisão transitada em julgado, contra esse segundo Estado, o qual foi condenado a pagar 50 salários mínimos de dano material. Mas o juiz da causa nega-se a determinar o pagamento do referido crédito com dispensa de precatório, por entender que a lei é inconstitucional.

QUESTÃO 16

Diante da situação hipotética apresentada, indique a medida judicial mais apropriada para forçar o pagamento do crédito de João sem a regra do precatório e o órgão jurídico competente para apreciá-la. Justifique sua resposta.

QUESTÃO 17

Estabeleça as diferenças, no que se refere ao controle de constitucionalidade, entre a decisão proferida pelo STF e a proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, conforme relatado no texto.

QUESTÃO 18

Maria, servidora pública federal, exerce a função de auxiliar de enfermagem há 25 anos cumprindo carga horária de 40 horas semanais. Alega que a lei complementar prevista no § 4.º do art. 40 da CF/88 ainda não foi editada e que tal omissão está impedindo que ela se aposente, pois, por ser a sua atividade considerada insalubre, penosa ou perigosa, teria direito a se aposentar com 25 anos de serviço/contribuição, conforme a Lei n. 8.213, de 24-7-1991, que dispõe o seguinte:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1.º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá em uma renda mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício”.

Com base nessas informações e na situação hipotética em apreço, elabore um texto, sintético e objetivo, que responda às seguintes questões.

– Qual é a medida judicial de feição constitucional apropriada para garantir a aposentadoria a Maria?

- Qual é o órgão do poder judiciário competente para julgá-la?
- Qual é a consequência do provimento judicial eventualmente obtido nessa medida judicial, conforme o entendimento do STF e da doutrina vigente?

TEXTO PARA AS QUESTÕES 19 E 20

Pedro, servidor público federal, ingressou há 10 anos com uma ação de rito ordinário visando cobrar parcela de remuneração que não lhe teria sido paga de forma correta. Saiu-se vencedor em todas as instâncias, tendo sido a União condenada a pagar-lhe o valor de R\$ 120.000,00 mais 5% desse valor a título de condenação em honorários advocatícios, em decisão já transitada em julgado.

No entanto, requerido o pagamento do principal por via de precatório, a União pretende, com base no art. 19 da Lei n. 11.033/2004, que o levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de valores decorrentes de precatório judicial fique condicionada à apresentação, ao juízo, de certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, bem como de certidão de regularidade com a seguridade social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a dívida ativa da União, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Além disso, sustenta a União que não procede a pretensão do advogado de executar os honorários advocatícios sem a observância da regra do precatório, já que essa parcela não teria natureza alimentícia e não teria sido excepcionada no § 1.º do art. 100 da CF/88.

QUESTÃO 19

Tendo a situação hipotética apresentada como referência, redija um texto acerca da constitucionalidade ou não do art. 19 da Lei n. 11.033/2004, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- proporcionalidade;
- efetividade da jurisdição;

- coisa julgada;
- privilégios da Fazenda Pública.

QUESTÃO 20

Ainda acerca da situação hipotética relatada no texto, discorra sobre a natureza jurídica dos honorários advocatícios e o limite de exclusão da regra do precatório para essa parcela.

QUESTÃO 21

Nos autos de uma ação civil pública, foi pedido que não fosse aplicada determinada lei, tendo em vista sua inconstitucionalidade.

A propósito dessa situação, responda, de forma fundamentada, ao seguinte questionamento:

A ação civil pública pode ser utilizada como instrumento de controle de constitucionalidade das leis?

QUESTÃO 22

Antônio, Deputado Federal, recebeu vantagens indevidas em razão do seu cargo eletivo e foi condenado por falta de decoro parlamentar.

Acerca dessa situação hipotética, responda, de modo fundamentado, aos seguintes questionamentos:

- Qual o órgão competente para julgar e condenar Antônio por falta de decoro?
- Antônio pode renunciar ao mandato, visando a não aplicação da penalidade?

QUESTÃO 23

O Presidente da República apresentou projeto de lei ordinária que altera a organização do Ministério Público da União.

Frente a essa situação hipotética, responda: Há alguma

inconstitucionalidade nesse projeto de lei? Fundamente a sua resposta.

QUESTÃO 24

A MedProv X, publicada no dia 11-9-2001, determinou a abertura de crédito extraordinário no orçamento da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, para atender despesas decorrentes de enchentes ocorridas no sul do Estado de Minas Gerais.

O referido ministério imediatamente promoveu, juntamente com o Estado e com os Municípios envolvidos, a aquisição dos materiais necessários ao atendimento da população, como água, alimentação, remédios e vestuário, bem como possibilitou o alojamento temporário dos desabrigados em ginásios, estádios e outros prédios públicos dos municípios vizinhos, o que acabou por atender àquela situação.

No entanto, a referida medida provisória, até a presente data, não foi analisada pelo Congresso Nacional.

Com base na situação hipotética em apreço, responda, de modo justificado, às seguintes indagações:

- A medida provisória pode ser utilizada na espécie?
- Diante da inércia do Congresso Nacional, continua em vigor a referida medida provisória?

QUESTÃO 25

Uma lei estadual, publicada em 1987, estabeleceu que a remuneração dos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão de determinada autarquia devem ser remunerados por meio de múltiplos do salário mínimo, nacionalmente unificado.

O governador do Estado em questão pretende impugnar a constitucionalidade dessa norma, sob o argumento de que estaria sendo violada a parte final do inciso IV do art. 7.º da CF/88, que veda a vinculação ao salário mínimo na espécie.

Considerando essa situação hipotética, responda, de modo fundamentado, às perguntas a seguir:

- Qual é a medida judicial cabível na espécie para impugnar o citado ato no controle concentrado de constitucionalidade?
- Como é feito o pedido de medida liminar na espécie?

QUESTÃO 26

O Presidente da República, no exercício de suas atribuições, assinou um tratado internacional sobre comércio e assumiu, perante os demais chefes de Estado signatários, o compromisso de colocá-lo imediatamente em vigor no Brasil por ato unilateral do Executivo.

Tomando por base esta situação hipotética, redija um texto acerca da disciplina constitucional para a incorporação dos tratados e convenções internacionais à ordem jurídica brasileira, abordando o papel do Executivo e do Legislativo nesse processo, assim como sobre a posição hierárquica desses tratados no nosso sistema de direito interno.

QUESTÃO 27

Após coletar a assinatura de 25 colegas seus, um Senador apresentou uma proposta de emenda constitucional (PEC) que foi acolhida pela Mesa Diretora do Senado Federal e submetida à discussão e votação, em dois turnos, na Casa. No primeiro turno, a PEC obteve 65% dos votos dos membros do Senado, e, no segundo turno, obteve 55%.

Em face dessa situação hipotética, redija um texto dissertativo em resposta às seguintes perguntas:

- O Senador, ao apresentar a PEC, obedeceu ao trâmite previsto na Constituição Federal?
- A PEC seguiu o adequado procedimento de discussão e votação no Senado Federal, ou deveria ter sido votada em sessão conjunta?
- Em face da votação obtida no primeiro e segundo turnos, ela pode ser

considerada aprovada pelo Senado?

- É adequado dizer que compete ao Presidente da República sancionar as PECs, mas que não lhe cabe promulgar e fazer publicar as emendas constitucionais?

QUESTÃO 28

Em face da competência concorrente prevista na Constituição Federal, determinado Estado da Federação editou lei que versa sobre educação e cultura.

O Procurador-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF alegando que a lei estadual não respeitava as normas estabelecidas pela Lei Federal n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Tomando por base o sistema de repartição de competências adotado pela Constituição, redija um texto sobre o exercício da competência concorrente pelos Estados-membros e pela União, comentando qual o campo de atuação de cada um desses Entes.

De igual maneira, comente se a ação impetrada pelo Procurador-Geral da República é adequada, e se o mesmo tem legitimidade para propor a ação.

QUESTÃO 29

Uma confederação sindical ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) por omissão visando a que seja expedido ato normativo que permita o cumprimento de preceito constitucional que, sem aquele ato, não pode ser aplicado.

Em face dessa situação, redija um texto em resposta às seguintes perguntas:

- A confederação sindical tem legitimidade para ingressar com ADIn por omissão?
- É possível a concessão de liminar no presente caso?

- A oitiva do Advogado-Geral da União e a manifestação do Procurador-Geral da República são obrigatórias?
- Qual o quórum exigido para que a inconstitucionalidade por omissão seja declarada pelo STF?

QUESTÃO 30

Um Governador de Estado decidiu decretar intervenção em Município situado no território de seu Estado sob a alegação de que não foi aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme exige a Constituição Federal.

Diante dessa situação hipotética, discorra sobre a intervenção em Municípios, respondendo às seguintes perguntas:

- A intervenção poderia se realizar pelo Estado-membro, ou deveria ter sido decretada apenas pela União?
- É adequado dizer que a citada intervenção, para se concretizar, depende de prévia autorização judicial?
- Qual a forma pela qual a intervenção deverá se concretizar (resolução, decreto legislativo, decreto governamental, lei estadual ou lei federal, decisão judicial)?
- No caso apresentado, é necessário que o Poder Legislativo estadual aprecie o ato de intervenção? Se sua resposta for afirmativa, essa apreciação deve ser a priori ou a posteriori?

QUESTÃO 31

Um Município que tem como carro-chefe de sua economia a atividade pesqueira editou lei que estabelece normas para a captura, o transporte e a comercialização de pescado em sua área territorial e prevê a aplicação de sanções administrativas para os que descumprirem tais normas.

Tomando-se como referência o sistema de repartição de competências entre os Entes Federados, é correto dizer, quanto à situação hipotética

apresentada, que a referida lei municipal é constitucional? Justifique a sua resposta.

QUESTÃO 32

Um Governador de Estado encaminhou à assembleia legislativa projeto de lei que versa sobre reajuste de vencimentos dos servidores da administração direta. Mediante emenda parlamentar, foi introduzida no projeto emenda majorando o valor do reajuste, a qual foi aprovada pela maioria absoluta dos membros do Legislativo estadual.

No que diz respeito à situação hipotética apresentada, de acordo com o processo de formação das leis constante na Constituição Federal, pode-se considerar legítima a iniciativa do Governador e o procedimento de votação do projeto de lei? Justifique a sua resposta.

QUESTÃO 33

Determinado Município brasileiro editou lei instituindo taxa de limpeza urbana que visa à prestação de serviços de capinação de vias e logradouros públicos, limpeza de praias e outros.

Na situação hipotética apresentada, a instituição do tributo está de acordo com o que prevê a Constituição Federal sobre o tema? Justifique a sua resposta.

QUESTÃO 34

Pedro de Tal cumpriu dois mandatos consecutivos de Governador de Estado, tendo renunciado ao segundo mandato seis meses antes do próximo pleito. Com a renúncia, Pedro decidiu apoiar, como candidata a Governadora, uma senhora que vive maritalmente há 10 anos com o irmão dele.

Na situação hipotética descrita, é possível admitir que a candidatura da referida senhora esteja de acordo com o que estabelece a Constituição Federal? Justifique a sua resposta.

QUESTÃO 35

Partido político cuja bancada, no Congresso Nacional, se resume a um único senador, ajuizou, junto ao STF, ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) para impugnar um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, em fase de apreciação no âmbito das comissões da Casa. Na ADIn, o partido político alega vício de iniciativa, sustentando que o projeto, proposto por parlamentar, seria, segundo a Constituição, de iniciativa privativa do Presidente da República.

No que se refere à situação hipotética apresentada, a ADIn proposta atende aos pressupostos do controle abstrato de normas consagrado na ordem jurídica brasileira, tanto no que diz respeito à legitimidade para a propositura da ação quanto ao seu objeto? Justifique a sua resposta.

QUESTÃO 36

A Mesa da Assembleia Legislativa de um Estado da Federação ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) no STF contra decreto governamental que concedia aumento de vencimentos a servidores públicos daquele Estado.

Considerando a situação acima relatada, responda, de forma fundamentada, se a ação direta é cabível e se a Mesa da Assembleia Legislativa dispõe de legitimidade para ajuizar a ADIn. Em seu texto, comente a respeito da eficácia da decisão do STF em ADIn.

QUESTÃO 37

Um Município ajuizou, no STF, ação de execução contra uma sociedade de economia mista controlada pela União, alegando que a existência de litígio entre um Município e um Ente da Administração indireta federal justificaria a competência originária do STF.

Comente, justificando, se o entendimento do Município está correto.

QUESTÃO 38

A Assembleia Legislativa de um Estado da Federação aprovou projeto de decreto legislativo criando novo Município, resultante de desmembramento de outro, tendo sido realizada posteriormente à aprovação do decreto consulta plebiscitária junto às populações diretamente interessadas. Foram, ainda, apresentados e publicados os estudos que comprovam a viabilidade do novo ente que se quer formar.

Nessa situação hipotética, foram atendidos todos os requisitos constitucionais que permitam considerar criado o novo Município?

Justifique a sua resposta.

QUESTÃO 39

Um Deputado Federal eleito em 2002 afastou-se do cargo em fevereiro de 2006, a fim de assumir determinada secretaria da Prefeitura da capital de seu Estado de origem. No partido pelo qual se elegeu o parlamentar, havia apenas um suplente, que assumira definitivamente o mandato em razão da investidura de um Deputado titular no cargo de Prefeito ao qual se elegera nas eleições de 2004. Não há, assim, outro suplente que possa assumir o mandato do parlamentar que tomou posse na referida secretaria.

Em face dessa situação hipotética, responda de forma fundamentada:

- a) pode o Deputado afastar-se do cargo para assumir uma Secretaria da Prefeitura da capital de seu Estado?
- b) a Constituição Federal prevê alguma providência a ser adotada em face da falta de suplente?

QUESTÃO 40

Um integrante da Polícia Militar de determinado Estado da Federação pretende participar de processo eleitoral na condição de candidato a Vereador do Município onde reside. O militar conta com 11 anos de serviço na Polícia Militar e não possui filiação partidária, mas entende que o art.

142, § 3.º, V, da CF/88, que proíbe que o militar, enquanto em serviço ativo, possa estar filiado a partido político, aplica-se apenas aos militares federais. Assim, ele pretende participar da convenção partidária que vai oficializar a relação de candidatos de determinado partido, orientado que foi no sentido de que o registro da candidatura suprirá a ausência de prévia filiação partidária.

Nessas circunstâncias, o militar solicita aos seus superiores a condição de agregado, pois é sua intenção, se não for eleito, retornar aos quadros da corporação.

Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, às seguintes perguntas.

- Pode o policial militar ser candidato a Vereador sem se afastar definitivamente da corporação?
- Está correto o entendimento segundo o qual a vedação de filiação partidária, enquanto em serviço ativo, não se estende aos militares dos Estados?
- Está correta a orientação no sentido de que o registro da candidatura suprirá a falta de filiação partidária?
- Poderá o militar, se não for eleito, retornar aos quadros da Polícia Militar?

QUESTÃO 41

O Defensor Público-Geral da União apresentou, no STF, proposta de edição de súmula vinculante em matéria penal. Autuada a proposta, foi publicado o edital, no qual era estabelecido o prazo de cinco dias para a manifestação de interessados. Decorrido o prazo de cinco dias, não tendo havido manifestação de qualquer interessado, os autos foram enviados à comissão de jurisprudência do STF, que aprovou, por unanimidade, a proposta, após a oitiva do Procurador-Geral da República. A súmula vinculante foi, então, publicada no Diário Oficial da União.

Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, se está correto o procedimento adotado para a elaboração da súmula vinculante, em especial, no que diz respeito:

- à legitimidade para a propositura;
- à possibilidade de manifestação de interessados;
- ao papel do Procurador-Geral da República;
- ao quórum para aprovação da referida súmula.

QUESTÃO 42

Após procedimento administrativo de desapropriação efetuado pelo Incra, em que se constatou a improdutividade de determinado imóvel rural, o Presidente da República editou decreto declarando de interesse social para fins de reforma agrária a propriedade denominada Fazenda Mar de Terra, situada no Município de Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais. Em 18 de dezembro de 2008, o decreto de desapropriação foi publicado no Diário Oficial da União. Inconformados com a desapropriação, os proprietários dessa fazenda, entendendo inválido o procedimento administrativo de desapropriação, ante o atestado de produtividade do imóvel, conforme laudo emitido por perito de sua confiança, impetraram mandado de segurança perante o STF.

Considerando a situação hipotética apresentada, analise o cabimento do mandado de segurança, em especial no que tange ao cabimento da medida, ao ato atacado, à competência do órgão julgador e à legitimidade ativa e passiva.

QUESTÃO 43

A associação dos moradores de determinado Município da Federação ajuizou, perante o STF, arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de lei municipal que instituiu tributo que previa três tratamentos distintos aos contribuintes, de acordo com a base de cálculo

para a aferição do valor que seria recolhido: a primeira referia-se a imóveis edificadas e não edificadas; a segunda, a imóveis residenciais e não residenciais; e a terceira, ao maior ou menor consumo de energia elétrica. A requerente alegou ofensa ao preceito fundamental da isonomia, presente tanto na Constituição Federal quanto na Estadual. O relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), monocraticamente, não conheceu do pedido e determinou o arquivamento do processo.

Considerando essa situação hipotética, indique, com a devida fundamentação, duas razões para o não conhecimento da referida ADPF.

QUESTÃO 44

Paulo, delegado de polícia, preside o inquérito X, no qual é apurada a prática de crime de estupro, por João, que se encontra preso, contra a menor M, de 13 anos de idade. No curso do inquérito, a menor se retratou da acusação de estupro, mas Paulo não comunicou tal fato ao juiz de direito competente para proceder ao arquivamento do inquérito, razão pela qual foi aberta, a pedido do Ministério Público, ação penal para apurar eventual crime de prevaricação.

Tendo o juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca Y do Estado Z determinado a intimação de Paulo para audiência de transação penal, este impetrou habeas corpus com vistas a impedir seu comparecimento à audiência bem como a se livrar do referido inquérito, mas a Turma Recursal Estadual denegou o pedido.

Em face dessa situação hipotética, indique, com a devida fundamentação legal, a medida judicial mais adequada para que Paulo atinja o objetivo pretendido, bem como o órgão do Poder Judiciário competente para julgá-la.

QUESTÃO 45

Suponha que o Presidente da República encaminhe projeto de lei ordinária

cujo objeto seja alterar a Lei Orçamentária do ano de 2009, para aumentar a destinação de recursos públicos em determinado projeto. Suponha, ainda, que um Deputado Federal, por considerar insuficientes os recursos previstos no projeto original, pretenda apresentar emenda a esse projeto de lei, visando à ampliação dos referidos recursos. Nessa situação hipotética, a proposta de emenda encontraria algum óbice perante a Constituição Federal? Fundamente sua resposta.

QUESTÃO 46

João é depositário de determinado bem móvel, decorrente de contrato civil, devidamente notificado para entregá-lo, não cumpriu com a obrigação nem indicou o local onde estaria o bem. O interessado ingressou com a ação pertinente na Justiça Cível e, após o trâmite regular do processo, houve determinação no mesmo sentido pelo juiz que conduzia o processo, ou seja, que João deveria entregar o bem. João permaneceu inerte, o que ocasionou a determinação de sua ordem de prisão por 60 dias. Inconformado João impetrou habeas corpus no tribunal competente.

Diante da situação hipotética apresentada, indique a posição majoritária mais recente do STF sobre a legalidade da ordem de prisão do depositário infiel, informando, com fundamento nessa posição, se o habeas corpus deve ser concedido em favor de João.

QUESTÃO 47

Em junho de 2008, após processo administrativo disciplinar, Pedro foi exonerado da função que ocupava em órgão da Administração Pública municipal. Ato contínuo, ele ingressou com mandado de segurança para ser reintegrado ao serviço público, arguindo a nulidade do ato em razão de não haver sido apresentada defesa técnica por advogado inscrito na OAB, o que ofenderia a garantia do contraditório e da ampla defesa, estipulada no art. 5.º da CF/88.

O Tribunal de Justiça acolheu a argumentação e concedeu a Pedro a segurança sob o argumento de que a presença obrigatória do advogado seria essencial para a garantia da ampla defesa.

Em face dessa situação hipotética, na condição de Procurador do Município, aponte a medida judicial mais apropriada para impugnar a decisão do Tribunal de Justiça. Justifique a resposta, informando o Tribunal perante o qual a medida deve ser ajuizada.

QUESTÃO 48

O Prefeito do Município X editou decreto, majorando a alíquota do IPTU dos imóveis ali localizados. Um partido político de oposição, com representação na respectiva Assembleia Legislativa, pretende ingressar com mandado de segurança coletivo, visando à declaração judicial de inexistência de relação jurídica tributária entre o citado Município e os respectivos contribuintes do IPTU.

Em face dessa situação hipotética, responda, de forma fundamentada, se há possibilidade de propositura do referido mandado de segurança coletivo.

QUESTÃO 49

João, acusado de ter praticado crime de menor potencial ofensivo, teve negado pela turma recursal, o seu pedido de trancamento da ação penal em curso no Juizado Especial.

Nessa situação hipotética, caso queira ingressar com alguma medida judicial, como João deverá proceder? Fundamente sua resposta.

QUESTÃO 50

Paulo, empresário do ramo imobiliário, suspeito de participação em quadrilha envolvida na venda fraudulenta de grandes áreas de terras públicas, foi convocado a depor, como testemunha, em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Assembleia Legislativa de

determinado Estado da Federação para investigar a atuação de organizações não governamentais no estado.

Antes do dia do depoimento, o presidente da CPI afirmou, em entrevista, que, se Paulo faltasse à verdade ou se calasse no esclarecimento dos fatos, iria determinar sua imediata prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho.

Nessa situação hipotética, qual seria o instrumento processual adequado para evitar a prisão em flagrante e qual fundamentação de mérito deveria ser utilizada?

QUESTÃO 51

O presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para investigar escutas telefônicas clandestinas expediu ofício a várias operadoras de telefonia fixa e móvel, determinando o imediato envio de informações relacionadas a escutas telefônicas autorizadas, no ano de 2007, em processos judiciais que tramitam sob segredo de justiça. Entre as informações, o parlamentar pretendia obter o número de cada processo em que se autorizou a escuta, o nome das partes envolvidas, os titulares dos terminais interceptados, os números dos terminais e cópias dos mandados e das decisões que os acompanharam ou que os determinaram.

Paralelamente, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados solicitou ao ministro do STF, relator de inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime pelo deputado federal João da Silva, o encaminhamento de cópia dos autos desse inquérito, em trâmite com a cláusula de sigilo em razão da existência de escuta telefônica devidamente autorizada, para subsidiar procedimento administrativo disciplinar movido contra o parlamentar naquela Casa Legislativa.

O Deputado Federal João da Silva, diretamente atingido em ambas as situações, procurou os serviços de profissional da advocacia, indagando-lhe sobre a possibilidade, ou não, de a CPI e o presidente do Conselho de Ética

e Decoro Parlamentar obterem as informações solicitadas.

Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a) consultado(a) pelo parlamentar, responda à indagação de seu cliente, apresentando, inclusive, os fundamentos constitucionais pertinentes a cada um dos casos relatados.

QUESTÃO 52

O Procurador-Geral de Justiça (PGJ) de determinado Estado da Federação, ao analisar a recém-editada Lei Estadual n. YYY/2009, verificou que os arts. A e B dessa norma contrariavam frontalmente o art. X da Constituição Estadual, assim redigido: “A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração”.

Por essa razão, o PGJ propôs ação direta de inconstitucionalidade (ADIn), perante o Tribunal de Justiça do Estado, contra os referidos dispositivos legais, tendo o órgão, ao final, julgado improcedente a ação, sem afronta à autoridade de nenhuma decisão já proferida pelo STF.

Inconformado, o PGJ, pretendendo recorrer da decisão do TJ do Estado, solicitou ao seu assessor jurídico um estudo preliminar do caso.

Em face dessa situação hipotética, na condição do referido assessor jurídico, discorra sobre a (im)possibilidade de os Tribunais de Justiça dos Estados realizarem controle concentrado de constitucionalidade, informando se é cabível recurso ao STF contra a decisão que julgou improcedente a ADIn e especificando o recurso, tudo com o respectivo fundamento constitucional.

QUESTÃO 53

O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública com o objetivo de garantir o fornecimento de medicamento pelo Estado a pessoa idosa que

necessitava urgentemente de remédios indispensáveis à preservação de sua vida, tendo o Juiz de 1.º Grau concedido liminar determinando o fornecimento imediato dos medicamentos. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de Procurador do Estado convocado pelo Procurador-Geral do Estado para se manifestar sobre a referida ação civil pública, discorra acerca da legitimidade do Ministério Público estadual para o ajuizamento da ação, apontando os dispositivos constitucionais e legais que se aplicam ao caso.

QUESTÃO 54

Em investigação da Polícia Federal, ficou comprovado que a fazenda de João era usada para cultivo ilegal de planta psicotrópica. Ao descobrir que aguardaria o julgamento da ação penal em liberdade, João ficou relativamente tranquilo, pois, verificando que somente 10% da área de sua propriedade era usada para tal fim, concluiu que não sofreria perda significativa de sua terra quando da expropriação. Além disso, o fazendeiro estava convicto de que a Polícia Federal agia fora de suas atribuições, por acreditar que o cultivo da planta em sua fazenda não feria interesses da União.

Pretendendo obter esclarecimentos acerca do ocorrido, João procurou os serviços de profissional da advocacia. Em face dessa situação hipotética, na condição de advogado(a) consultado(a) por João, que explicações você lhe daria? Em sua resposta, aborde os dispositivos constitucionais pertinentes ao caso.

QUESTÃO 55

Foi promulgada e publicada, pelo Presidente da República, lei federal, de iniciativa do Poder Executivo, estabelecendo valor do salário mínimo claramente insuficiente para atender às necessidades vitais básicas e os valores protegidos no art. 7.º, IV, da CF/88, que determina ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua

condição social, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim estabelecido.

Em face dessa situação hipotética e considerando que o escritório de advocacia em que você trabalhe seja contratado para questionar a constitucionalidade dessa lei, indique, com a devida fundamentação, a ação mais adequada ao caso.

QUESTÃO 56

Jorge, com nacionalidade brasileira desde 1999, foi preso por determinação do STF, em face de pedido de extradição formulado por país que não tem tratado de extradição com o Brasil. Alega o país requerente que Jorge teria praticado, em 2001, em território daquele país, crime de estelionato.

Nessa situação hipotética, que medida judicial seria mais adequada aos interesses de Jorge? Fundamente sua resposta, apresentando o argumento de mérito a ser utilizado.

QUESTÃO 57

Determinado advogado, ao travar, em seu escritório profissional com um cliente, áspera discussão sobre o valor dos honorários que lhe eram devidos, dirigiu a este, gestos e palavras de baixo calão, chegando, inclusive, a ameaçá-lo física e moralmente diante de outras pessoas. Considerando-se agredido em sua honra e reputação, o cliente ajuizou ação de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sofrido insultos e humilhações injustificáveis. Em defesa própria, o advogado sustentou que os gestos e as palavras que proferira não poderiam ser considerados injuriosos, difamatórios ou caluniosos, sob o argumento de que, tendo sido

emitidos no âmbito da relação profissional com seu próprio cliente, estariam resguardados pela inviolabilidade (ou imunidade material) que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Em face da situação hipotética acima apresentada, discorra, de forma objetiva e devidamente fundamentada, sobre o argumento utilizado pelo advogado para justificar sua atitude com o cliente.

QUESTÃO 58

Dada a carência de delegados existente em determinado Estado da Federação, o Governador editou decreto atribuindo a sargentos da Polícia Militar que atuam nos Municípios de pequeno porte e população rarefeita o desempenho das funções de Delegado de Polícia Civil. De acordo com o decreto do Governador, os sargentos da Polícia Militar deveriam prestar o atendimento nas delegacias de polícia até que fosse realizado concurso com o fim de suprir a necessidade de servidores de carreira no âmbito da polícia de investigação. O decreto previa, ainda, a possibilidade de o Estado firmar convênio com os Municípios que constituíram guardas municipais, de modo a atribuir a essas guardas a responsabilidade de realizar o policiamento ostensivo e preventivo em seus respectivos Municípios, em igualdade de condições com os policiais militares.

Em face dessa situação hipotética, disserte, de forma objetiva e devidamente fundamentada, sobre a constitucionalidade do decreto do governador no que diz respeito ao exercício de funções de Delegado de Polícia Civil por integrantes da Polícia Militar; à realização de convênios que possibilitem a execução, pelas guardas municipais, dos serviços de policiamento ostensivo e preventivo.

QUESTÃO 59

O Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra agente público que se apropriou indevidamente de valores destinados a

determinado programa social. O Estado-membro ingressou no polo ativo da demanda. Ao impugnar o pedido, o agente afirmou que obtivera a aprovação das contas junto ao Tribunal de Contas, razão por que afirmou ser descabido o pedido deduzido na ação de improbidade administrativa, sob o argumento de que a decisão do tribunal de contas vincularia o sujeito ativo da ação de improbidade, que não poderia alegar a existência de dano ao erário. Argumentou, ainda, que o Poder Judiciário não poderia acolher o pedido formulado na ação, dada a ausência de dano, já reconhecida na decisão que aprovara as contas. Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada e na qualidade de advogado(a) do Estado-membro, se procedem os argumentos deduzidos pelo agente, abordando, necessariamente, o papel do Tribunal de Contas e a natureza jurídica de suas decisões, bem como a apontada vinculação do Ministério Público e do Poder Judiciário.

QUESTÃO 60

Rui, servidor público federal, foi surpreendido por agentes da Administração Tributária que adentraram sua residência, durante o dia, para apreender documentos e objetos considerados necessários em procedimento investigatório. A decisão de efetuar tal procedimento foi tomada por autoridade administrativa que considerou imprescindível a operação de busca e apreensão domiciliar, fundada na prerrogativa de autoexecutoriedade, inerente à atuação administrativa. Inconformado com o fato, Rui procurou o auxílio de profissional da advocacia.

Diante dessa situação hipotética e na condição de advogado(a) contratado(a) por Rui, exponha, de forma fundamentada, os argumentos a serem suscitados, em medida judicial, contra o ato administrativo que determinou a referida busca e apreensão domiciliar.

QUESTÃO 61

Considerando que a Assembleia Legislativa de um Estado da Federação

promova emenda ao seu regimento interno no qual se determine que a instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito seja aprovada pelo plenário da Casa, responda, de modo fundamentado aos seguintes questionamentos:

- A emenda em questão seria constitucional?
- Poderia ser proposta ADIn contra a norma regimental?

QUESTÃO 62

O Governador de determinado estado propôs emenda à Constituição estadual, no que se refere ao processo legislativo das emendas à Constituição, aumentando para quatro quintos o quórum exigido para aprovação de emendas. A proposta de emenda, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, foi encaminhada para deliberação; no entanto, um dos Deputados Estaduais, entendeu que essa proposta não pode tramitar por ser inconstitucional, razão pela qual pretende impugná-la judicialmente. Nessa situação hipotética, que medida judicial seria mais adequada ao caso? Fundamente sua resposta, apresentando o argumento de mérito a ser utilizado para a defesa da pretensão do Deputado.

QUESTÃO 63

Uma central de trabalhadores que congrega, em âmbito nacional, sindicatos e federações de diferentes categorias profissionais, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, contra lei editada pelo Estado X, devido a imposição de restrições à comercialização de produtos, as quais geram graves reflexos na economia dos Estados vizinhos e, por consequência, na garantia do emprego de milhares de trabalhadores.

Simultaneamente, determinado Prefeito de um Município do Estado X ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado, contra a mesma lei impugnada pela central de trabalhadores.

Considerando essa situação hipotética, responda, de forma fundamentada,

aos seguintes questionamentos.

- O STF admite que uma central de trabalhadores de âmbito nacional composta de membros de categorias profissionais ou econômicas heterogêneas tenha legitimidade para ingressar com ação direta genérica?
- É admissível a tramitação paralela de ações diretas de inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça local e no STF, interpostas contra a mesma lei estadual impugnada?
- O ajuizamento de ação direta se sujeita a algum prazo prescricional ou decadencial?

QUESTÃO 64

Em razão de inúmeras denúncias acerca de favorecimentos e dispensas irregulares de licitação na máquina pública de determinado Estado da Federação, a Assembleia Legislativa, tomou a iniciativa de inserir dispositivos na Constituição Estadual, estabelecendo que os convênios celebrados por secretários de Estado e os contratos por estes firmados serão eficazes apenas depois da aprovação do Poder Legislativo. No mesmo sentido, foi inserida na Carta Estadual, norma que exige autorização legislativa para que o Estado possa contrair dívidas. Inconformado com as ações unilaterais tomadas pela Assembleia Legislativa, o Governador avalia como proceder, juridicamente, para resguardar a independência e a autonomia do Poder Executivo Estadual.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, discorra de forma objetiva e devidamente fundamentada, sobre a legitimidade das iniciativas da Assembleia Legislativa e indique a medida mais adequada a ser tomada pelo Governador do Estado para tornar inválidas as normas constitucionais estabelecidas.

QUESTÃO 65

Pedro teve ciência informal de que fora denunciado a determinado órgão de controle da Administração Pública, pela prática de conduta ilícita. Com a finalidade de ajuizar ação em defesa de seu nome, sua honra e sua imagem, ele requereu ao Poder Público, informações quanto à identificação e aos dados do(s) denunciante(s). O órgão público indeferiu o pedido, destacando que o interessado deveria valer-se de habeas data. Inconformado com a negativa, Pedro procurou o auxílio de um profissional de advocacia.

Considerando essa situação hipotética, na qualidade de advogado(a) contratado(a) por Pedro, indique, com a devida fundamentação, a medida judicial cabível para que Pedro possa ter acesso à identificação e aos dados do(s) denunciante(s) e exponha os argumentos indispensáveis à adequada defesa de seu cliente.

QUESTÃO 66

O Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou projeto de lei complementar modificando artigos do Código Civil, nos termos do art. 22, I, da CF/88. Três meses após a entrada em vigor da referida lei, o Presidente da República editou medida provisória modificando novamente os referidos artigos do Código Civil com redação dada pela lei complementar.

Analise a constitucionalidade dos atos normativos mencionados.

QUESTÃO 67

Uma lei estadual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) ajuizada junto ao STF.

Supondo que o Tribunal tenha se pronunciado, neste caso, pela inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, explique o conceito acima, apontando quais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade neste caso.

QUESTÃO 68

O Conselho Federal da OAB ajuizou, junto ao STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), tendo por objeto um artigo de uma lei federal em vigor desde 2005, sendo manifesta a pertinência temática do dispositivo impugnado com o exercício da advocacia.

O STF entende que o referido dispositivo legal é inconstitucional, mas por fundamento distinto do que fora apresentado pelo Conselho Federal da OAB na ADI, tendo o STF inclusive declarado a inconstitucionalidade desse mesmo dispositivo no julgamento de um caso concreto, em Recurso Extraordinário (RE).

Com base nas informações acima, responda:

- I – O STF pode julgar a ADIn procedente a partir de fundamento diverso do que fora apresentado pelo Conselho Federal da OAB? Justifique.
- II – O STF pode julgar a ADIn procedente em relação também a outro dispositivo da mesma lei, mesmo não tendo este dispositivo sido objeto da ADIn? Justifique.

QUESTÃO 69

Em 2005, o STF julgou procedente ADC ajuizada pelo Procurador-Geral da República visando à declaração de constitucionalidade de uma lei federal que estava sendo questionada em diversos processos judiciais pelo país, gerando uma controvérsia judicial em torno da sua adequação ao texto constitucional. Nas eleições ocorridas em outubro de 2010, um determinado partido político conseguiu, pela primeira vez em sua história, eleger um parlamentar, no caso um Deputado Federal, graças à coligação partidária firmada com um partido político de maior expressão e base eleitoral.

O diretório nacional do referido partido político pretende, no próximo ano, após o início da sessão legislativa, ajuizar uma ADIn contra a mencionada lei federal, a partir de argumentos que não foram enfrentados pelos Ministros do STF em 2005.

Análise a pretensão do partido político, considerando os seguintes tópicos:

I – A legitimidade para a propositura da ação.

II – A possibilidade de o STF declarar a inconstitucionalidade da lei (com ou sem modulação dos efeitos).

QUESTÃO 70

A Constituição de determinado Estado da Federação, promulgada em 1989, ao dispor sobre a Administração Pública Estadual, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público é assegurada aos cidadãos naturais daquele Estado e depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Em 2009 foi promulgada pela Assembleia Legislativa daquele Estado (após a derrubada de veto do Governador), uma lei que permite o ingresso em determinada carreira por meio de livre nomeação, assegurada a estabilidade do servidor nomeado após três anos de efetivo exercício.

Considerando-se que a Constituição Estadual arrola o Governador como um dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual (art. 125, § 2.º, da CF/88), e considerando-se que o Governador pretende obter a declaração de inconstitucionalidade da referida lei estadual, responda:

I – O que ocorreria se logo após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade de âmbito estadual, ajuizada pelo Governador do Estado junto ao Tribunal de Justiça (nos termos do art. 125, § 2.º, da CF/88) e antes do julgamento, fosse ajuizada pelo Conselho Federal da OAB uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, tendo por objeto esta mesma lei? Explique.

II – Poderia o Presidente da República ajuizar ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF contra o dispositivo da Constituição

Estadual? Explique.

QUESTÃO 71

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa de determinado Estado-membro, ao disciplinar o processo de criação e instauração das Comissões Parlamentares de Inquérito, condiciona a criação de CPI à aprovação pelo Plenário da Casa Legislativa, de requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos Deputados Estaduais.

Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Analise, de maneira justificada, a constitucionalidade da referida previsão regimental.
- b) O Diretório Regional de Partido Político do Estado-membro em questão tem legitimidade para questionar a previsão regimental perante o STF por meio de ADIn?

QUESTÃO 72

O STF, ao julgar um recurso extraordinário, declarou a inconstitucionalidade, incidenter tantum, de uma lei estadual. Antônio Augusto, interessado em ser alcançado pelos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, impetrou mandado de segurança perante o STF objetivando a fixação de prazo para que o Senado Federal edite resolução para suspender a execução da mencionada lei estadual.

Considerando a situação hipotética narrada, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Quais são os efeitos subjetivos produzidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei em questão e qual é a função reservada ao Senado Federal pela norma do art. 52, X, da CF/88?

- b) De acordo com a tradição constitucional brasileira, é cabível o pretendido controle jurisdicional da atuação do Senado Federal em tal hipótese?
- c) O Senado Federal pode exercer a competência descrita no art. 52, X, da CF/88, em se tratando de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual?

QUESTÃO 73

Considere uma lei federal que aumentou a alíquota de determinado tributo, mas sem dispor expressamente que a nova alíquota só poderia ser cobrada no exercício financeiro seguinte. Suponha que uma turma de determinado Tribunal Regional Federal esteja julgando, em grau de recurso, um mandado de segurança impetrado por um contribuinte que se insurgiu contra a cobrança do tributo no mesmo ano em que fora instituído.

Diante desse quadro, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Pode a turma do TRF, ao julgar o caso, estabelecer que a nova alíquota só poderá ser cobrada no ano seguinte?
- b) Qual é o princípio que fundamenta a cláusula de reserva de plenário?

QUESTÃO 74

No início de um ano eleitoral, o Congresso Nacional aprovou e promulgou uma emenda constitucional suprimindo a alínea a do inciso II do § 1.º do art. 14 da CF/88 e alterando o § 2.º do mesmo dispositivo, que passaria a ter a seguinte redação: "Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, os analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos". Ocorre que, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno de votação da proposta (PEC) no Senado Federal, o Presidente da República havia decretado intervenção federal num determinado Estado da Federação.

Diante da dúvida generalizada a respeito do direito de voto dos analfabetos na eleição que ocorreria naquele ano, o Procurador-Geral da República houve por bem ajuizar ADIn contra a referida emenda constitucional.

A esse respeito, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Uma emenda constitucional pode ser objeto de ADIn?
- b) Há inconstitucionalidade formal ou material na emenda em questão?

QUESTÃO 75

Em 31 de dezembro de 2010, foi publicada a Lei ordinária federal n. 2.378, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e regulamentou o exercício da profissão de arquiteto e urbanista, estabelecendo, entre outros, as áreas de atuação privativa dos referidos profissionais. Suponha que, a partir da entrada em vigor da referida lei, tenha sido suscitada uma rica discussão sobre a sua constitucionalidade, com argumentos contrários e favoráveis à regulamentação legal daquelas atividades e que foram publicados nos diversos e mais importantes jornais do país, além de publicações em revistas especializadas das áreas de Direito, Urbanismo, Arquitetura e Engenharia.

Com base no exposto, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Seria cabível o ajuizamento de uma ADC pelo próprio Conselho criado pela norma?
- b) Seria cabível o ajuizamento de uma ADIn pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil?
- c) Assumindo que fosse cabível o ajuizamento da ADC, qual seria o efeito de uma decisão que julgasse improcedente, no mérito, a ação?

IV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 76

O Procurador-Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual X e uma ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto a lei federal Y – ambas ajuizadas com pedido de medida cautelar.

Considerando o exposto, responda fundamentadamente:

- a) Diante da ambivalência das ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade, se o STF indeferir a cautelar na ADIn, pode um juiz, no exame de um caso concreto (controle difuso), declarar a inconstitucionalidade da lei X?
- b) Se o STF deferir a cautelar na ADC, pode um juiz, no exame de um caso concreto, declarar a inconstitucionalidade da lei Y, mas por outros fundamentos, que não aqueles que deram causa à ação?

QUESTÃO 77

Determinado Partido Político com representação no Congresso Nacional ajuíza Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF para questionar a íntegra de uma lei estadual.

Em relação ao cenário acima, comente, justificadamente, as consequências jurídicas das seguintes hipóteses, considerando sua ocorrência antes do julgamento da ADIn:

- a) a lei estadual é revogada;
- b) o Partido Político deixa de ter representação no Congresso Nacional.

QUESTÃO 78

Suponha que o STF tenha reconhecido em diversos julgados (recursos extraordinários) a incompatibilidade de uma lei ordinária do Estado Y, em vigor desde 1999, com uma emenda constitucional promulgada no ano

seguinte.

Diante desses fatos, responda:

- a) As decisões proferidas pelo STF, reconhecendo a referida incompatibilidade entre lei e emenda constitucional, devem ser encaminhadas ao Senado?
- b) A 1.^a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Y tem competência para deixar de aplicar a lei estadual incompatível com a emenda constitucional? Explique.

QUESTÃO 79

Mévio, advogado com longos anos de carreira, resolve concorrer a vaga de magistrado surgida no Tribunal de Justiça K, tendo apresentado o seu currículo para a Ordem dos Advogados do Brasil, que o incluiu na lista de advogados. Mesma situação ocorreu com a lista escolhida pelo Tribunal de Justiça.

À luz das normas constitucionais, responda aos itens a seguir:

- a) Qual é o percentual de vagas destinada aos advogados nos Tribunais de Justiça?
- b) Quais são os ritos de escolha realizados pela OAB e pelo Tribunal de Justiça?
- c) De quem é a competência para nomeação?

V EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 80

Com o objetivo de incrementar a arrecadação tributária, projeto de lei estadual, de iniciativa parlamentar, cria uma gratificação de produtividade em favor dos Fiscais de Rendas que, no exercício de suas atribuições, alcancem metas previamente estabelecidas. O projeto é aprovado pela Assembleia Legislativa e, em seguida, encaminhado ao Governador do

Estado, que o sanciona.

Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Indique a inconstitucionalidade formal que a lei apresenta e informe se a sanção da chefia do Poder Executivo teve o condão de saná-la.
- b) Supondo que a lei seja questionada perante o STF por meio de ADIn, de que forma poderia o Sindicato dos Fiscais de Rendas daquele Estado atuar no feito em defesa da lei? Teria legitimidade para interposição de embargos declaratórios contra a decisão final adotada na ADIn?

QUESTÃO 81

O Tribunal de Contas da União (TCU), acolhendo representação contendo fortes indícios de irregularidades em procedimento licitatório realizado por entidade submetida à sua fiscalização, determina, cautelarmente, a suspensão do certame e fixa prazo para que o gestor responsável apresente defesa. Após regular instrução do processo, o TCU rejeita as razões de defesa, confirma a medida acautelatória e aplica multa sancionatória ao administrador público responsável pelas irregularidades.

Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) É juridicamente possível a suspensão cautelar do procedimento licitatório por decisão do TCU?
- b) Supondo que, contra a aplicação da multa sancionatória, não tenha sido interposto qualquer recurso administrativo, qual é a providência a ser adotada para sua execução?

QUESTÃO 82

Um fazendeiro descobriu que sua mulher o havia traído com um cidadão de

etnia indígena que morava numa reserva próxima à sua fazenda. No mesmo instante em que tomou ciência do fato, o fazendeiro dirigiu-se à reserva indígena e disparou três tiros contra o índio, que, no entanto, sobreviveu ao atentado.

Com base nesse cenário, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) A quem compete julgar esse caso?
- b) Qual é o fundamento do art. 109, XI, da Constituição da República?
- c) Caso o juiz federal entendesse ser incompetente para julgar esse caso e encaminhasse os autos ao juiz de direito e este também entendesse ser incompetente, a quem caberia decidir qual o juízo competente? Por quê?

QUESTÃO 83

O Presidente da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 5.º da Lei federal X, de 2005. Essa lei tem sido declarada totalmente inconstitucional pelo STF em reiteradas decisões, todas em sede de controle difuso.

Com base nesse cenário e à luz da jurisprudência do STF, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) O Advogado-Geral da União está obrigado a defender a constitucionalidade da Lei X? Explique.
- b) Ao julgar essa ADIn, pode o STF declarar a inconstitucionalidade de outro(s) dispositivo(s) da Lei X, além do art. 5.º? Explique.

QUESTÃO 84

Suponha que tramite perante a Câmara dos Deputados Proposta de Emenda à Constituição da República estabelecendo a obrigatoriedade de Estados, Municípios e Distrito Federal indexarem a remuneração de seus servidores

de acordo com o salário mínimo.

Considerando a situação hipotética, analise os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso:

- a) a constitucionalidade da referida PEC;
- b) a possibilidade de provimento jurisdicional que avalie a constitucionalidade da PEC ainda no curso do processo legislativo.

VI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 85

Marco Antônio, titular, desde 2006, de mandato de Senador pelo Estado X, pretende se reeleger, em 2014, para o Senado, mas dessa vez como Senador pelo Estado Y, governado pela sua esposa, Maria, eleita em 2010 e que pretende a reeleição em 2014. Como Marco Antônio irá concorrer, em 2014, ao cargo de Senador pelo Estado Y, Paulo, filho de Marco Antônio e Maria, decidiu que naquele ano irá se candidatar ao cargo de Senador pelo Estado X.

Diante desse quadro, responda:

- a) Pode Marco Antônio se candidatar ao cargo de Senador pelo Estado Y, em 2014.
- b) Pode Paulo se candidatar ao cargo de Senador pelo Estado X, em 2014.

QUESTÃO 86

O Prefeito do Município WK apresenta projeto de lei que outorga reajustes a determinadas categorias de servidores públicos, que veio a sofrer emendas pelos parlamentares ampliando os benefícios para outras categorias não acolhidas no projeto do Chefe do Executivo, com aumento de despesas, em previsibilidade orçamentária. A Constituição Estadual prescreve que nessa matéria a iniciativa é exclusiva do chefe do Executivo, repetindo normas da

Constituição Federal. A lei foi votada por maioria e sancionada pelo Prefeito. A legitimidade prevista para o controle de constitucionalidade repete, no plano local, aquela inscrita na Constituição Federal.

Responda fundamentadamente:

- a) A emenda parlamentar ao projeto de lei seria possível?
- b) Existiria algum meio de controle de constitucionalidade da lei votada pela Câmara?
- c) Teria o Prefeito legitimidade para propor a eventual ação direta de inconstitucionalidade, mesmo tendo sancionado o projeto?

QUESTÃO 87

O Senador da República Valdecir foi preso em flagrante por crime inafiançável. Os responsáveis pela prisão comunicaram o fato ao Poder Judiciário, que manteve a prisão.

- a) Diante do fato descrito, pode ser tomada alguma medida para que o Senador seja posto em liberdade?
- b) Em caso positivo, que medida seria e com que fundamento? Em caso negativo, justifique sua resposta.

VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 88

No mês de março, um projeto de emenda constitucional foi rejeitado logo no primeiro turno de votação, realizado na Câmara dos Deputados. Em agosto do mesmo ano, esse projeto de emenda foi novamente posto em votação na Câmara dos Deputados. Na sequência, determinado Deputado Federal, contrário ao projeto de emenda e decidido a impedir sua tramitação, afirmou que iria acessar o Poder Judiciário.

Discorra sobre a possibilidade de o Poder Judiciário exercer controle sobre a tramitação da emenda, bem como sobre a possível medida cabível no caso

em tela.

QUESTÃO 89

Erasmus, cidadão residente e eleitor do Estado "A", viveu sua infância no Estado "B", pelo qual possui grande apreço. Por entender que certo Deputado Federal, no exercício de sua função, e no âmbito territorial do Estado "B", praticou ato lesivo ao patrimônio público do ente ao qual está vinculado, Erasmus propôs ação popular em vara federal da seção judiciária de "B". O Deputado Federal, em sua contestação, alega a incompetência do juízo de 1.º grau, com o fundamento de que possui foro privilegiado, e a ilegitimidade ativa de Erasmus.

Responda aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Qual o órgão competente para conhecer a ação popular ajuizada em face do Deputado Federal?
- b) Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, Erasmus teria legitimidade ativa para ajuizar a ação popular na seção judiciária de "Z"?

QUESTÃO 90

Em determinado Estado da Federação, vieram a público denúncias de irregularidades praticadas em obra pública, com graves indícios de desvio de dinheiro do Erário. Tício, Deputado Estadual, pretende instalar Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração das denúncias, com base em previsão constante da Constituição Estadual.

Considerando a situação acima descrita, responda aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) É possível que a Constituição Estadual preveja a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito no plano estadual?

- b) É possível o ajuizamento de ação em que se questione a constitucionalidade de norma de Constituição Estadual perante a Constituição da República, de modo a invalidar aquela? O Governador do Estado tem legitimidade para fazê-lo?

QUESTÃO 91

Renata, servidora pública estadual, ingressou no serviço público antes da edição da Constituição da República de 1988, e é regida pela Lei X, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado-membro. Sobre a situação funcional de Renata, responda justificadamente:

- a) O que ocorrerá com a Lei X caso ela não tenha sido editada conforme os trâmites do processo legislativo previstos pela atual Constituição?
- b) É possível que Renata questione, em ação individual, por meio de controle difuso, a inconstitucionalidade formal da Lei X perante a constituição revogada?
- c) Tendo em vista que Renata já estava inserida em um regime jurídico, é possível afirmar que a mesma tem direito adquirido a não ser atingida pela Constituição de 1988 no que tange à sua situação funcional?

VIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 92

Uma agência reguladora federal editou, recentemente, uma portaria proibindo aos médicos prescrever a utilização de medicamentos que não tenham similar nacional.

A Associação Brasileira de Profissionais da Saúde, entidade de âmbito nacional constituída há mais de dois anos, propôs uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra aquela medida.

A respeito da situação acima, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao

caso.

- a) É possível a propositura da ADPF contra a portaria emitida pela agência reguladora federal?
- b) A Associação tem legitimidade para a propositura daquela ADPF?
- c) Pode um Estado instituir uma ADPF no plano estadual? Nesse caso, qual o instrumento jurídico apto à criação do instituto?

QUESTÃO 93

Maria alugou um prédio comercial no centro da cidade “P”, capital do Estado “K”, para que o Estado estrangeiro W ali instalasse sua representação consular. Foram estabelecidos aluguéis de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais.

Passados dois anos de vigência do contrato, em razão de dificuldades financeiras no continente onde se localiza o Estado W, o mesmo deixa de pagar aluguéis para Maria, que, inconformada, busca a orientação de um profissional da advocacia para melhor defender seus interesses.

O advogado contratado explica que proporá a ação em Vara Cível do Município “P”, cabendo eventual recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado K.

Responda, justificadamente, se a orientação do advogado contratado por Maria está na direção correta ao apontar os órgãos jurisdicionais competentes para a matéria em primeiro e em segundo grau de jurisdição.

QUESTÃO 94

Em 2010 foi aprovada emenda à Constituição do Estado “X”, acrescentando dispositivo que permite que o Governador do Estado edite medida provisória, com força de lei, com eficácia imediata, devendo ser convertida em até 30 dias. Com base neste dispositivo, em 15 de dezembro de 2011, o Governador do Estado editou medida provisória majorando as alíquotas mínima e máxima do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, visando à cobrança do imposto com as novas alíquotas em 2012. Não tendo sido apreciada nos primeiros vinte dias de vigência, a medida provisória entrou em regime de urgência, e foi finalmente aprovada pela Assembleia Legislativa.

A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) O dispositivo da Constituição do Estado X que confere ao Governador competência para editar medida provisória viola a Constituição da República?
- b) A alteração das alíquotas pela medida provisória editada pelo Governador é constitucional?
- c) As novas alíquotas podem ser cobradas em 2012?

QUESTÃO 95

Caio e Tício, servidores públicos federais, foram surpreendidos com o advento de uma Emenda Constitucional que alterou o sistema previdenciário dos servidores, aumentando a idade mínima para aposentadoria e a forma de cálculo dos proventos.

Caio já havia completado todos os requisitos para a aposentadoria (idade e tempo de contribuição), mas optou por permanecer em atividade. Tício ainda não havia preenchido todos os requisitos: apesar de já possuir a idade mínima, faltava-lhe um ano de contribuição.

A esse respeito, responda, justificadamente, aos itens a seguir:

- a) As novas normas são aplicáveis a Caio e Tício, no que diz respeito à idade para aposentadoria e à forma de cálculo dos proventos?
- b) Alguns anos depois, já aposentados, Caio e Tício recebem a notícia de que foi editada lei federal que, majorando seus proventos de aposentadoria, modificou a sua forma de composição. É válida a lei que

altera a composição da remuneração dos aposentados, quanto ao seu valor e a fórmula de cálculo?

IX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 96

José, em um evento de confraternização na empresa em que trabalha, ouviu de Roberto, alterado pela ingestão de bebida alcoólica, que este detinha cargo em comissão no Tribunal de Contas da União, ao qual nunca comparecera, exceto para retirada do contracheque, ao final de cada mês.

José se dirige no dia seguinte, ao Tribunal de Contas da União e solicita cópia dos assentamentos funcionais relativos a Roberto, a fim de instruir uma ação judicial.

O pedido administrativo foi dirigido ao Ministro Presidente daquela Corte de contas, que resolveu negá-lo. Consternado, José impetrou habeas data em face do Presidente do Tribunal de Contas da União.

Considerando a situação acima descrita, responda justificadamente aos itens a seguir.

- a) Qual o Juízo ou Tribunal competente para julgamento do habeas data impetrado por José? (valor: 0,40)
- b) O dispositivo de lei exige, para impetração do habeas data, demonstração da recusa ao acesso às informações, à luz do princípio da inafastabilidade de jurisdição, é constitucional? (valor: 0,40)
- c) A pretensão de José, nesse caso, pode ser veiculada por habeas data? (valor: 0,45)

QUESTÃO 97

Instituto destinado a dar maior eficiência aos comandos constitucionais, a medida provisória possibilita que, em situações excepcionais, o Presidente da República edite norma com força de lei ordinária. A avalanche de

medidas provisórias, porém, vem atravancando o trâmite dos projetos de lei, o que motivou nova orientação do então presidente da Câmara dos Deputados: a pauta não fica travada em relação a matérias que não podem, em tese, ser objeto de medida provisória.

Em relação ao tema medida provisória, responda, fundamentadamente, aos seguintes itens.

- a) Quais os limites para sua edição? (valor: 0,40)
- b) É possível Constituição Estadual prever edição de medida provisória pelo governador do Estado? Nesse caso, a norma constitucional poderia estabelecer limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil? (valor: 0,45)
- c) É possível o controle jurisdicional dos requisitos de relevância e urgência da medida provisória? (valor: 0,40)

QUESTÃO 98

A Lei Orgânica do Município "Y", que integra o Estado "X", ao dispor sobre ingresso na Administração Pública municipal, e em observância aos princípios de eficiência e da moralidade, estabeleceu que os cargos, empregos e funções públicas seriam acessíveis aos brasileiros naturais do Estado "X", que tivessem residência no Município "Y", e que seriam investidos nos cargos mediante aprovação prévia em concurso público de provas e de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Contra esse dispositivo da Lei Orgânica foi ajuizada, junto ao Tribunal de Justiça, uma ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 125, § 2.º, da CF/88, alegando violação a dispositivo da Constituição estadual que, basicamente, reproduz o art. 37 da CF/88. O Tribunal de Justiça conheceu da ação, mas julgou improcedente o pedido, entendendo que, respeitados os limites constitucionais, o Município pode criar regras próprias, no exercício da sua

capacidade de auto-organização.

A partir do caso apresentado, responda justificadamente aos itens a seguir.

- a) O Município tem autonomia para criar a regra citada no enunciado, conforme entendeu o Tribunal de Justiça? (valor: 0,40)
- b) A ADIn estadual pode ter por objeto dispositivo da Lei Orgânica? (valor: 0,45)
- c) Dessa decisão do Tribunal de Justiça, cabe Recurso Extraordinário ao STF? (valor: 0,40)

QUESTÃO 99

O Brasil assinou tratado internacional, discutido e votado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que regulamentava novas formas de controle sobre o comércio exterior. Ao invés de a função ser exercida pelo Ministério da Fazenda, como preceitua o art. 237 da CF/88, o texto do tratado veda qualquer possibilidade de controle interno do comércio internacional pelos países signatários.

A partir do fato acima, responda aos fatos a seguir.

- a) De acordo com o ordenamento constitucional vigente, a que autoridade ou órgão compete promover a internalização do referido tratado internacional? (valor: 0,50)
- b) Uma vez internalizado o tratado em questão, com que hierarquia ele passa a integrar o ordenamento jurídico pátrio? (valor: 0,25)
- c) Qual(is) princípio(s) de interpretação constitucional deve(em) nortear a resolução do conflito entre o texto do tratado e o texto constitucional? (valor: 0,50).

X EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 100

Determinado Ministério apresentou desempenho considerado insuficiente

pela imprensa e pela opinião pública, havendo sério questionamento quanto aos gastos públicos destinados para a sua manutenção. Dessa forma, um Senador pelo Estado Y apresentou um projeto de lei no sentido de extinguir este Ministério. Tal projeto foi votado em plenário em um dia em que 32 (trinta e dois) dos 81 (oitenta e um) senadores estavam presentes, sendo aprovado pelo voto da maioria dos presentes e encaminhado à Câmara dos Deputados. Contando com forte apoio popular, a proposta legislativa foi aprovada pela maioria absoluta dos deputados federais e encaminhada ao Presidente da República, que a sancionou 12 dias úteis depois de tê-la recebido, determinando sua imediata publicação no Diário Oficial da União. Uma semana após a publicação da lei na imprensa oficial, a Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade em que pleiteava a declaração de conformidade da nova norma legal com a Constituição.

Responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Há algum vício que fulmine a constitucionalidade da norma em questão? (valor: 0,80)
- b) A Conamp poderia ter ajuizado a ação declaratória de constitucionalidade? (valor: 0,45)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 101

Lei do Estado “Y”, editada em abril de 2012, com base no art. 215, § 1.º, da CF/88, regulamenta a chamada rinha de galo, prática popular em que dois galos se enfrentam em lutas e espectadores apostam no galo que acreditam ser o vencedor. Comumente, os dois galos saem muito feridos da contenda, e não raras vezes algum animal morre ou adquire sequelas permanentes que recomendam seu abate imediato. A Associação Comercial

do Estado "Y" ajuíza ação direta de inconstitucionalidade no STF em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da referida lei estadual. Em defesa da norma, parlamentar que votou pela sua aprovação, diz, em entrevista a uma rádio local, que a prática da conhecida briga de galos é comum em várias localidades rurais do Estado "Y", ocorrendo há várias gerações. Além do mais, animais, especialmente aves, são abatidos diariamente para servir de alimento, o que não ocorreria com as aves destinadas para as rinhas.

Responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Quanto ao mérito do pedido, é cabível a declaração de inconstitucionalidade da lei do Estado "Y" que regulamenta a chamada rinha de galo? (valor: 0,65)
- b) Há regularidade na legitimidade ativa da ação? (valor: 0,60)

QUESTÃO 102

Proposta de emenda à Constituição é apresentada por cerca de 10% (dez por cento) dos Deputados Federais, cujo teor é criar novo dispositivo constitucional que determine a submissão de todas as decisões do STF, no controle abstrato das normas, ao crivo do Congresso Nacional, de modo que a decisão do Tribunal somente produziria efeitos após a aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. A proposta é discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional, onde recebe a aprovação da maioria absoluta dos Deputados e Senadores nos dois turnos de votação. Encaminhada para o Presidente da República, este resolve sancionar a proposta, publicando a nova emenda no Diário Oficial. Cinco dias após a publicação da emenda constitucional, a Mesa da Câmara dos Deputados apresenta perante o STF ação declaratória de constitucionalidade em que pede a declaração da constitucionalidade

desta emenda com eficácia erga omnes e efeito vinculante.

A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Há inconstitucionalidades materiais ou formais na emenda em questão? (valor: 1,0)

b) A ação declaratória de constitucionalidade poderia ser conhecida pelo STF? (valor: 0,25)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 103

O Estado W, sem motivo de força maior, não repassa aos Municípios receitas tributárias determinadas pela Constituição Federal, nos prazos nela determinados. O Município JJ necessita dos recursos para realizar os serviços básicos de atendimento à população.

Diante do narrado, responda aos itens a seguir, de forma fundamentada.

a) Quais as consequências do não repasse das verbas referidas? (valor: 0,50)

b) Quais os procedimentos exigidos pela Constituição nesse caso? (valor: 0,75)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

XI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 104

Determinado Estado-membro aprovou uma lei que incluiu a disciplina de formação para o trânsito nos currículos do 1.º e do 2.º Graus de ensino da rede pública estadual.

A esse respeito, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos

jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Analise a constitucionalidade dessa lei estadual. (Valor: 0,65)
- b) O Governador de outro Estado pode ajuizar ADIn ou ADPF contra esta lei? Por qual(is) motivo(s)? (valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 105

Morales, de nacionalidade cubana, participante de reality show produzido e divulgado por emissora de televisão brasileira, alega que teve o seu direito fundamental à intimidade violado, ao serem amplamente divulgadas imagens suas em ato de convulsão, decorrentes de disfunção epilética que possui. Assim, após sua saída do programa, ingressa com demanda em face da emissora de televisão.

Considerando o fato acima descrito, responda fundamentadamente:

- a) É possível invocar um direito fundamental, previsto na Constituição, em uma demanda movida contra um particular? (valor: 0,65)
- b) Seria correto o argumento, posto em sede de defesa, que a norma constitucional que resguarda o direito à intimidade não pode ser invocado, tendo em vista a ausência de lei disciplinando o dispositivo constitucional? (valor: 0,60)

QUESTÃO 106

O partido político "X" move, perante o STF, ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do Estado "Y", que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito daquele Estado Federado, para atender às suas peculiaridades, sem afrontar normas gerais preexistentes. O partido alega que a referida lei estadual é inconstitucional, uma vez que a competência privativa para legislar sobre a matéria é da União, conforme o art. 22, XXVII, da CF/88. Parecer da Procuradoria-Geral da República opina no sentido do não conhecimento da ação, uma vez que o partido político "X"

possui em seus quadros apenas seis Deputados Federais, mas nenhum Senador, não sendo dessa maneira legitimado a mover a referida ação direta. Além disso, não estaria demonstrado na inicial o requisito da pertinência temática.

A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) É caso de se acolher o parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido do não conhecimento da ação? (valor: 0,65)
- b) Quanto ao fundamento de mérito apresentado, tem razão o partido político ao questionar a constitucionalidade da norma impugnada? (valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 107

Lei do Município YY, de iniciativa da Câmara de Vereadores, estipulou novo plano de carreira para a categoria de professores municipais, impondo remunerações escalonadas, fixando pisos mínimos e vinculando a remuneração global ao percebido por servidores do Poder Legislativo local.

Com base no caso proposto, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) Observadas as regras constitucionais, há vício na referida lei? (valor: 0,65)
- b) A vinculação de remunerações entre Poderes é acolhida no texto constitucional? (valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

XII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 108

Insatisfeito com a demora para a efetivação das desapropriações necessárias à construção de uma rodovia federal, o Presidente da República editou o Decreto n. 9.999, por meio do qual, expressamente, determinou a revogação do Decreto-lei 3.365/41, que dispunha sobre a desapropriação por utilidade pública, e, ao mesmo tempo, institui novo regramento a respeito do tema. Sobre a hipótese apresentada, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

- a) Em nosso ordenamento jurídico constitucional, existe previsão para a edição de decreto autônomo? (valor: 0,50)
- b) É possível a revogação do Decreto-lei 3.365/41 pelo decreto presidencial? (valor: 0,75)

QUESTÃO 109

Com a aproximação do pleito eleitoral, o Prefeito do Município ABC, que concorrerá à reeleição, vem tentando resgatar a sua imagem, desgastada por conta de sucessivos escândalos. O Prefeito deu início a uma série de obras públicas de embelezamento da cidade e quadruplicou as receitas destinadas à publicidade. Para fazer face a essas despesas, o Município deixou de aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde e anunciou corte ainda maior nas verbas destinadas à educação e saúde para o exercício financeiro seguinte. Considerando que a Constituição da República autoriza a intervenção nessa hipótese, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) A União pode intervir nos Municípios, caso o Estado deixe de fazê-lo? (valor: 0,65)
- b) Caso o Governador decrete a intervenção do Estado no Município, tal ato estará sujeito a alguma forma de controle político? (valor: 0,60)

QUESTÃO 110

O Estado "Z" editou lei que institui uma Taxa de Fiscalização de Estradas, impondo o pagamento de uma elevada quantia para o acesso ou para a saída do território daquele Estado por meio rodoviário. Sobre a hipótese sugerida, responda, fundamentadamente, aos seguintes itens.

- a) O Governador do Estado "Y" pode impugnar a lei editada pela Assembleia Legislativa do Estado "Z" por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade? (valor: 0,65)
- b) Caso a lei do Estado "Z" seja impugnada por um partido político, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pode prosseguir a ação em caso de perda superveniente da representação do partido no Congresso Nacional? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 111

Após intenso debate, a Assembleia Legislativa do Estado X editou a Lei n. 1.001, de iniciativa do Deputado "M", que prevê a obrigatoriedade de instalação, em até 360 (trezentos e sessenta dias), de um sistema eletrônico de limitação da velocidade de veículos automotores, de baixo custo, a fim de reduzir o número de acidentes com vítimas nas estradas estaduais. Irritado, o Deputado "P", da oposição, quando procurado por jornalistas, afirmou que estava envergonhado daquele dia, pois a lei aprovada era "uma piada, uma palhaçada, ridícula", protegia os empresários, e não a população e só poderia ter, como origem, um Deputado associado a grupos interessados no mercado de peças automotivas. Considerando o exposto, responda fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) O Deputado "P" pode ser responsabilizado pelas ofensas proferidas durante a entrevista? (valor: 0,85)
- b) É válida a lei estadual que impõe a obrigatoriedade de instalação de sistema de controle de velocidade de veículos automotores? (valor: 0,40)

XIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 112

Em 2004, entrou em vigor a lei estadual "X", de autoria de um deputado governista (partido A), sob protestos de alguns parlamentares da oposição (partido B), já que a lei era flagrantemente inconstitucional de acordo com a jurisprudência pacífica do STF. A oposição, contudo, venceu as eleições naquele ano e já em 2005, quando o partido B conquistou a maioria das cadeiras na Assembleia Legislativa, foi aprovada a lei "Y" que revogou a lei "X", ao dispor de forma distinta sobre a mesma matéria (revogação tácita), embora mantido vício de inconstitucionalidade. A partir do caso descrito, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, responda aos itens a seguir.

- a) Após a entrada em vigor da Lei "Y", pode o partido B ajuizar ADIn, junto ao STF, pedindo a declaração de inconstitucionalidade da lei "X"? (Valor: 0,55)
- b) O Procurador-Geral da República pode ajuizar ADIn pedindo a declaração de inconstitucionalidade das leis "Y" e "X", sucessivamente? (Valor: 0,70)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 113

Giácomo e Giovanna são turistas italianos que, apaixonados pelo Brasil, aqui fixam residência, obtêm emprego e constituem família. Seus dois filhos, Luigi e Filipa nasceram no Brasil, respectivamente em 1989 e 1991.

Considerando que o ordenamento italiano atribui nacionalidade italiana aos filhos de seus cidadãos, ainda que nascidos no estrangeiro, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) Filipa pode ser extraditada para a Itália, pela prática de crime comum, caso o Brasil mantenha tratado de extradição com aquele País? (Valor: 0,80)

b) A legislação ordinária pode estabelecer nova hipótese de aquisição de nacionalidade brasileira? (Valor: 0,45)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 114

O Deputado Federal "G", de matriz política conservadora, proferiu, em sessão realizada na Câmara dos Deputados, pesado discurso contra o reconhecimento legal do direito de diversas minorias. Sentindo-se lesados, representantes de diversas minorias vão a público para manifestar sua indignação. A partir da hipótese sugerida, pergunta-se:

a) O deputado "G" pode ser condenado, civil ou penalmente, pelo discurso ofensivo que proferiu no plenário? E se proferir tal discurso durante entrevista televisiva, fora do ambiente da Câmara dos Deputados? Responda fundamentadamente. (Valor: 0,65)

b) Os vereadores possuem a chamada imunidade material? Em que condições territoriais? (Valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

QUESTÃO 115

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pelo rito do art. 5.º, § 3.º, da CF/88.

Maria Y, portadora de necessidades especiais, consulta-o como advogado, indagando:

a) Ao ser incorporada ao ordenamento pátrio com base no art. 5.º, § 3.º, da CF/88, qual o status hierárquico normativo da referida convenção internacional? (Valor: 0,40)

b) Os demais tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados sem a observância do procedimento disposto no art. 5.º, § 3.º, da CF/88,

possuem o mesmo status hierárquico? Justifique. (Valor: 0,40)

- c) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, após seu processo de internalização, de acordo com o art. 5.º, § 3.º, da CF/88, pode servir de parâmetro para controle de constitucionalidade? Justifique sua resposta. (Valor: 0,45)

XIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 116

A Imprensa Oficial do Estado "X" publicou, em 23 de outubro de 2013, a Lei n. 1.234, de iniciativa do Governador, que veda a utilização de qualquer símbolo religioso nas repartições públicas estaduais. Pressionado por associações religiosas e pela opinião pública, o Governador ajuíza Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por objeto aquela lei, alegando violação ao preâmbulo da Constituição da República, que afirma "a proteção de Deus sobre os representantes na Assembleia Constituinte".

Diante do exposto, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) É possível o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por parâmetro preceito inscrito no preâmbulo da Constituição da República? (Valor: 0,65)
- b) É possível o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Governador do Estado, tendo por objeto lei de sua iniciativa? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 117

Sob forte influência de grandes produtores rurais, numerosos parlamentares do Congresso Nacional se mobilizam para a edição de uma emenda à Constituição, a fim de retirar do texto constitucional a referência à função social da propriedade. Como resposta, a sociedade civil começou uma campanha de coleta de assinaturas para deflagrar a edição, por iniciativa

popular, de uma emenda para tornar crime a manutenção de propriedades improdutivas.

Com base no fragmento acima, responda aos itens a seguir, fundamentadamente.

- a) Um parlamentar tem iniciativa no processo legislativo de emenda à Constituição? E a sociedade civil? (Valor: 0,60)
- b) É possível a edição de emenda com o conteúdo pretendido pelos produtores rurais? (Valor: 0,65)

QUESTÃO 118

Tício ajuizou demanda em face do Estado "X", postulando determinada prestação estatal. A sentença proferida pelo Juízo da 1.^a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, entretanto, julgou improcedente o pedido, apontando, no fundamento da decisão, os diferentes graus de eficácia das normas constitucionais, que impedem todos os efeitos pretendidos por Tício.

Com base no fragmento acima, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) Em que medida as normas constitucionais de eficácia plena se diferenciam das normas de eficácia contida? (Valor: 0,65)
- b) As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático, antes da intermediação legislativa, geram algum efeito jurídico? (Valor: 0,60)

QUESTÃO 119

A circulação no Brasil do subtipo 4 do vírus da dengue e o retorno do subtipo 1 podem aumentar o número de casos graves da doença no período que, historicamente, já registra o maior contingente de infectados. Para tentar conter a epidemia, o Estado com maior índice de contágio elabora lei que obriga os médicos públicos e particulares que atuam em seu território a

notificarem os casos de dengue à Secretaria de Saúde. A mesma lei, mediante outro dispositivo, imputou responsabilidade civil ao médico por falta de notificação.

Diante do caso, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) É constitucional a obrigatoriedade de notificação dos casos de dengue? (Valor: 0,60)
- b) É constitucional a responsabilização dos médicos que não notificarem? (Valor: 0,65)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 120

O Governador do Estado X ajuizou Representação de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, apontando a violação, pela Lei Estadual n. 1.111, de dispositivos da Constituição do Estado, que se apresentam como normas de reprodução obrigatória. Considerando o exposto, responda aos itens a seguir.

- a) O que são normas de reprodução obrigatória? (Valor: 0,65)
- b) Proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal arguindo violação dos mesmos dispositivos da Constituição Federal, cuja reprodução pela mesma lei estadual (Lei n. 1.111) era obrigatória na Constituição Estadual, sem que tenha ocorrido o julgamento da Representação de Inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça local, poderão as duas ações tramitar simultaneamente? (Valor: 0,60)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 121

O Estado X, integrante da República Federativa do Brasil, foi agraciado com

o anúncio da descoberta de enormes jazidas de ouro, ferro, estanho e petróleo em seu território. As jazidas de minério estão todas localizadas no Município de Alegria e as de petróleo, no Município de Felicidade, ambos localizados no Estado X. Tendo em vista o disposto no ordenamento jurídico nacional, responda aos itens a seguir.

- a) A qual ente federativo pertencem os recursos naturais recentemente descobertos? Os demais entes, em cujos territórios se deu a descoberta, recebem alguma participação no resultado da exploração desses recursos? (Valor: 0,85)
- b) Um dos entes federativos (Estado ou Município), insatisfeito com a destinação dos recursos naturais descobertos em seu território, pode, à luz do nosso ordenamento, propor a secessão, a fim de se constituir em ente soberano, único titular daqueles recursos? Caso positiva a resposta, qual o procedimento a ser seguido? (Valor: 0,40)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 122

Os jornais noticiaram violenta chacina ocorrida no Estado Y, onde foram torturadas e assassinadas dezenas de crianças e mulheres de uma comunidade rural de baixa renda, com suspeita de trabalho escravo. É aberto inquérito policial para a investigação dos fatos e, passado um mês do ocorrido, a polícia e as autoridades locais mantêm-se absolutamente inertes, configurando, de forma patente, omissão na apuração dos crimes. A imprensa nacional e a internacional dão destaque à omissão, afirmando que o Estado Y não é capaz de assegurar a proteção aos diversos direitos humanos contidos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Com base no caso apresentado, responda aos itens a seguir.

- a) O que se entende por federalização dos crimes contra os direitos humanos? (Valor: 0,65)
- b) O Presidente da República pode requerer a aplicação do instituto?

Perante qual juízo ou tribunal brasileiro deve ser suscitado o instituto da federalização dos crimes contra os direitos humanos? (Valor: 0,60)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 123

Denúncias de corrupção em determinada empresa pública federal foram publicadas na imprensa, o que motivou a instalação, na Câmara dos Deputados, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Em busca de esclarecimento dos fatos, a CPI decidiu convocar vários dirigentes da empresa pública para prestar depoimento. Em razão do interesse público envolvido, o jornalista que primeiro noticiou o caso na grande imprensa também foi convocado a prestar informações, sob pena de condução coercitiva, de modo a revelar a origem de suas fontes, permitindo, assim, a ampliação do rol dos investigados. Outra decisão da CPI foi a de quebrar o sigilo bancário dos dirigentes envolvidos nas denúncias de corrupção, objeto de apuração da comissão. Com base nessas informações, responda aos itens a seguir.

- a) A CPI tem poder para intimar alguém a prestar depoimento, sob pena de condução coercitiva caso não compareça espontaneamente? (Valor: 0,40)
- b) O jornalista convocado pode ser obrigado a responder indagações sobre a origem de suas fontes jornalísticas, em razão do interesse público envolvido? (Valor: 0,40)
- c) A CPI tem poder para determinar a quebra do sigilo bancário dos investigados? (Valor: 0,45)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XVI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 124

Uma entidade de classe de servidores públicos ajuizou mandado de

segurança coletivo contra decisão do diretor geral de um dado órgão público federal. Alegou que a decisão administrativa por ele proferida deixou de considerar direitos consolidados de uma das categorias que representa. O Diretor Geral informou ao seu advogado reconhecer que a questão sobre a existência ou não do direito em discussão envolvia grande complexidade jurídica. Esclareceu, ainda, que, apesar de alguns órgãos públicos aplicarem o direito almejado pelo impetrante, a maior parte não o reconhecia. Diante do relato acima, responda aos itens a seguir.

- a) No caso em questão, havendo dúvidas quanto à certeza em matéria de direito, é possível movimentar o Poder Judiciário pela via do mandado de segurança? Justifique. (Valor: 0,75)
- b) A entidade de classe em questão possui legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo, ainda que a pretensão veiculada diga respeito a apenas uma parte da categoria que representa? Justifique. (Valor: 0,50)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

QUESTÃO 125

Faltando um pouco mais de um ano para as eleições estaduais, Prudêncio Ferreira, governador de um dos Estados da Federação (Estado W), mesmo diante de grave crise política, decide que concorrerá a um segundo mandato, sem se afastar do exercício de sua função. No seu entender, a referida crise política decorre do fato de não possuir, na Assembleia Legislativa (do Estado W), além de seu filho Zacarias, um número maior de deputados aguerridos, que defendam o seu governo, de forma contundente, dos insistentes ataques desferidos pela oposição. Por essa razão, traça como estratégia política reforçar a sua base de apoio na Casa Legislativa, com pessoas que considera de sua inteira confiança. Assim, submete à cúpula do partido que o apoia uma lista de candidatos a Deputado Estadual

que deveriam receber especial apoio no decorrer da campanha. Os seguintes nomes constaram da relação, todos com mais de 21 anos: – Marcos Ferreira, seu neto, bacharel em Direito, que jamais exerceu qualquer cargo político; – Robervaldo Soberbo, seu sogro, que se encontra aposentado do cargo de fiscal de rendas do Estado W; – Carlos Ferreira, seu sobrinho, que não exerce nenhum cargo político no momento; e – Zacarias Ferreira, seu filho adotivo, político de carreira, que concorrerá à reeleição como deputado estadual no Estado W.

Segundo a Constituição Federal, responda aos itens a seguir.

- a) Dentre os nomes citados, quais estariam habilitados a concorrer ao cargo de Deputado Estadual do Estado W e quais não estariam? Justifique. (Valor: 0,70)
- b) Dentre os que não estariam habilitados a concorrer ao cargo de Deputado Estadual pelo Estado W, poderiam eles concorrer ao cargo de Deputado Estadual por outro Estado? Justifique sua resposta. (Valor: 0,55)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

QUESTÃO 126

Projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, contendo vício de iniciativa, foi encaminhado ao Senado Federal. Na Casa revisora, o texto foi aprovado com pequena modificação, sendo suprimida determinada expressão, sem, contudo, alterar o sentido normativo objetivado pelo texto aprovado na Câmara. O projeto foi, então, enviado ao Presidente da República, que, embora tenha protestado pelo fato de ser a matéria disciplinada pelo Parlamento, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sancionou-o por concordar com os termos ali estabelecidos, originando a Lei L. Diante dos fatos narrados, responda aos itens a seguir.

- a) A não devolução do processo à Casa Iniciadora sempre configurará

violação ao devido processo legislativo? Justifique. (Valor: 0,75)

b) No caso em tela, a sanção presidencial possuiria o condão de suprir o vício de iniciativa ao projeto de Lei? Justifique. (Valor: 0,50)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

QUESTÃO 127

Durante a campanha eleitoral, determinado candidato a Deputado Federal acusa o Governador do Estado de liderar atividades criminosas ligadas a bingos e cassinos clandestinos. Logo em seguida, o referido candidato é eleito. Após a posse, o Procurador-Geral da República oferece denúncia contra o referido Deputado Federal, perante o Supremo Tribunal Federal, pelo crime comum cometido. Em sua defesa, o parlamentar argumenta que se encontra amparado pela inviolabilidade (imunidade material) quanto às suas opiniões, palavras e votos, razão pela qual não poderia responder pelo crime que lhe é imputado. Diante de tais fatos, responda aos itens a seguir.

a) Poderia o Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra o Deputado Federal sem a prévia autorização da Câmara dos Deputados? (Valor: 0,50)

b) Na hipótese de um Deputado Federal responder por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal, o término do mandato tem alguma consequência sobre a definição e manutenção da competência jurisdicional? (Valor: 0,75)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

XVII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 128

O Congresso Nacional autorizou o Presidente da República a normatizar, por

via de lei delegada, na sua forma típica ou própria (sem necessidade de posterior aprovação pelo Congresso), matéria que trata de incentivo ao parque industrial brasileiro. Ocorre, porém, que o chefe do Poder Executivo, ao elaborar o diploma normativo, exorbitou dos poderes a ele conferidos, deixando de respeitar os limites estabelecidos pelo Congresso Nacional, por via de resolução. A partir dessa narrativa, responda aos itens a seguir.

- a) No caso em tela, o aperfeiçoamento do ato de delegação, com a publicação da resolução, retira do Congresso Nacional o direito de controlar, inclusive constitucionalmente, o conteúdo da lei delegada editada pelo Presidente da República? Justifique. (Valor: 0,75)
- b) Caso a resolução estabelecesse a necessidade de apreciação do projeto pelo Congresso Nacional (delegação atípica ou imprópria), poderia a Casa Legislativa alterar o texto elaborado pelo Presidente da República? Justifique. (Valor: 0,50)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 129

Leonardo, dirigente da tradicional Agremiação X, desconfiado de que o regulamento do campeonato estadual de remo do Estado E estaria beneficiando uma agremiação em detrimento das demais – em completa violação ao princípio da igualdade – busca auxílio jurídico. Preocupado, porém, em reduzir o tempo de disputa jurídica, Leonardo sugere ao Advogado da Agremiação X que ajuíze ação perante a Justiça Comum, sem acionar as instâncias desportivas. Na condição de estudante de Direito, Leonardo fundamentou sua sugestão no princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do que indica o art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal. Diante do caso acima narrado, responda aos itens a seguir.

- a) O encaminhamento sugerido por Leonardo deve ser seguido pelo advogado da Agremiação X? (Valor: 0,65)
- b) A denominada Justiça Desportiva profere decisões judiciais? Justifique.

(Valor: 0,60)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 130

A Medida Provisória Z (MedProv Z), editada pelo Governador do Estado H com o propósito de diminuir o alto grau de evasão escolar, regulou a concessão de bolsas escolares a alunos carentes matriculados em escolas públicas estaduais. Em virtude de crise política que surgiu entre o Executivo e o Legislativo, a referida medida provisória não foi convertida em lei. Ultrapassado o prazo de 60 dias, a Casa Legislativa não disciplinou as relações jurídicas surgidas no período em que a MedProv Z vigorou. João, que se beneficiou por três meses da referida bolsa, apreensivo, relatou a Carlos, um amigo, servidor da Assembleia Legislativa, que teme ter de devolver a totalidade do valor recebido. Carlos tranquilizou-o e informou-lhe que a crise política fora debelada, de modo que a Assembleia apenas aguarda a reedição da medida provisória, a fim de convertê-la em lei, ainda no mesmo ano legislativo em que a MedProv Z perdeu a eficácia. Considerando que a Constituição do Estado H regulou o processo legislativo em absoluta simetria com o modelo usado pela Constituição Federal, responda aos itens a seguir.

- a) João terá de devolver aos cofres públicos o dinheiro recebido a título da bolsa? Fundamente. (Valor: 0,75)
- b) A informação passada por Carlos a João encontra-se em harmonia com a sistemática constitucional? Justifique. (Valor: 0,50)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 131

Aprovado apenas pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, assim como no âmbito da mesma Comissão em razão dessa matéria do Senado Federal, determinado projeto

de lei, que versava sobre política externa brasileira, foi levado à apreciação do Presidente da República, que resolveu vetá-lo, ao argumento de que nenhum projeto de lei pode ser aprovado sem a respectiva votação do Plenário de cada uma das Casas Legislativas. Diante do relato acima, responda aos itens a seguir.

- a) O veto apresentado pelo chefe do Executivo encontra amparo constitucional? (Valor: 0,65)
- b) É correto afirmar que, de acordo com o processo legislativo brasileiro, o veto do Presidente da República deve ser apreciado pela Casa Inicial e revisto pela Casa Revisora, dentro do prazo de quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento? (Valor: 0,60)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XVIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 132

José, inconformado com decisão judicial proferida em primeiro grau, que o condenou ao pagamento de indenização, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado M. Distribuído o recurso para a 2.^a Câmara Cível do mencionado tribunal, os desembargadores desse órgão fracionário, ao analisarem a matéria, entenderam corretos os argumentos de José no que se referia à inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentou o pedido da parte autora, ora recorrida. Ao realizarem acurada pesquisa jurisprudencial, observaram que o Pleno e o Órgão Especial do próprio Tribunal de Justiça do Estado M, bem como o Supremo Tribunal Federal, nunca se manifestaram sobre a matéria. Diante da situação narrada, responda aos itens a seguir.

- a) Qual a providência a ser tomada pela 2.^a Câmara? Justifique. (Valor: 0,75)
- b) A solução seria diversa se houvesse manifestação do Supremo Tribunal

Federal sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão? Justifique. (Valor: 0,50)

Observação: A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 133

O Estado X editou a Lei n. 1.234, de 5 de fevereiro de 2010, para criar o Município Z, desmembrando-o do então Município W. Para a criação do ente federativo foram devidamente realizados os estudos de viabilidade municipal, bem como a consulta prévia às populações dos entes federativos envolvidos nesse evento. O novo Município estava em pleno funcionamento até que, em final de 2015, o vereador Toninho do Bem, do Município W, aventa publicamente a intenção do diretório municipal de seu partido “Vamos Brasil”, com representação no Congresso Nacional, de propor uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), perante o Supremo Tribunal Federal, para questionar a criação do Município Z. Com base no fragmento acima, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

- a) A partir das normas constitucionais sobre a criação de Município, a lei do Estado X é constitucional? (Valor: 0,65)
- b) O diretório municipal do partido “Vamos Brasil” possui legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade? (Valor: 0,60)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 134

O governador do Estado M decidiu propor duas emendas à Constituição estadual. A primeira, com o objetivo de instituir normas que disciplinem o rito procedimental e de julgamento dos crimes de responsabilidade, acrescentando sanções mais severas que as vigentes. A segunda, por sua vez, com o propósito de alterar o critério de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, de forma que três, do total de sete membros, passem a ser escolhidos, dentre os candidatos habilitados, pelo voto

popular. Sobre as propostas acima formuladas, de acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, responda aos itens a seguir.

- a) É possível que o poder constituinte derivado do Estado-membro M altere a Constituição Estadual para instituir normas que disciplinem o rito procedimental e de julgamento dos crimes de responsabilidade, bem como para acrescentar sanções? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) A autonomia estadual é suficiente para fundamentar a proposta de eleição para Conselheiro do Tribunal de Contas, nos termos propostos pelo Governador? Justifique. (Valor: 0,60)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 135

Os irmãos Guilherme e Flávio fazem parte de uma família de tradicionais políticos do Estado M, conhecida por suas práticas beligerantes. Em um curto espaço de tempo, os irmãos se viram envolvidos em duas situações policiais: Guilherme, vereador da capital, agrediu fisicamente um vizinho, em situação originada por uma discussão relacionada à vaga em um estacionamento; no dia seguinte, Flávio, eleito e diplomado para exercer o cargo de deputado estadual, embora ainda não empossado, em estado de embriaguez, atropelou duas pessoas. O advogado(a) da família é convocado e a ele (ela) são dirigidas as questões a seguir.

- a) Pelas práticas das ações acima descritas, estariam os irmãos Guilherme e Flávio cobertos pela prerrogativa da imunidade material a que fazem jus os membros do Poder Legislativo? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Estão ambos aptos a fruir o benefício da imunidade formal? Justifique (Valor: 0,65)

Observação: a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XIX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 136

Durante a tramitação de determinado projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, importantes juristas questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos nele inseridos. Apesar dessa controvérsia doutrinária, o projeto encaminhado ao Congresso Nacional foi aprovado, seguindo-se a sanção, a promulgação e a publicação. Sabendo que a lei seria alvo de ataques perante o Poder Judiciário em sede de controle difuso de constitucionalidade, o Presidente da República resolveu ajuizar, logo no primeiro dia de vigência, uma Ação Declaratória de Constitucionalidade. Diante da narrativa acima, responda aos itens a seguir.

- a) É cabível a propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nesse caso? (Valor: 0,65)
- b) Em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), é cabível a propositura de medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal? Quais seriam os efeitos da decisão do STF no âmbito dessa medida cautelar? (Valor: 0,60)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 137

A Associação Antíqua, formada por colecionadores de carros antigos, observando que Mário, um de seus membros, supostamente teria infringido regras do respectivo Estatuto, designou comissão especial para a apuração dos fatos, com estrita observância das regras estatutárias. A Comissão, composta por membros de reconhecida seriedade, ao concluir os trabalhos, resolveu propor a exclusão de Mário do quadro de sócios, o que foi referendado pela Direção da Associação Antíqua. Questionada por Mário sobre o fato de não ter tido a oportunidade de contraditar os fatos ou apresentar defesa, a Associação apresentou as seguintes alegações: em primeiro lugar, não seria possível a Mário contraditar os fatos ocorridos, já

que as provas de sua ocorrência eram incontestáveis; em segundo lugar, os trâmites processuais previstos no Estatuto foram rigorosamente respeitados; em terceiro lugar, tratando-se de uma instituição privada, a Associação Antíqua tinha plena autonomia para a elaboração de suas regras estatutárias, que, no caso, permitiam a exclusão sem oitiva do acusado. Por fim, a Associação ainda alegou que Mário, ao nela ingressar, assinara um documento em que reconhecia a impossibilidade de solucionar possíveis litígios com a referida Associação pela via judicial.

Inconformado, Mário o procurou para, como advogado(a), orientá-lo sobre as questões a seguir.

- a) O direito à ampla defesa e ao contraditório podem ser alegados quando regras convencionais não os preveem? (Valor: 0,80)
- b) É possível que o Estatuto da Associação Antíqua possa estabelecer regra que afaste a apreciação da causa pelo Poder Judiciário? (Valor: 0,45)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 138

No âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), foi determinada a busca e apreensão de documentos e de computadores nos escritórios das empresas do grupo investigado, tendo sido decretada, em decisão fundamentada, a indisponibilidade de bens e a quebra dos sigilos bancário e fiscal de um dos empresários envolvidos.

Com base no fragmento acima, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

- a) A medida adotada pela CPI, em relação aos bens do empresário, é amparada pela ordem constitucional? (Valor: 0,65)
- b) A CPI poderia determinar a quebra de sigilo narrada na questão, sem autorização judicial? (Valor: 0,60)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 139

O deputado federal João da Silva, impulsionado por solicitação do seu partido, quer propor a alteração de alguns dispositivos normativos constantes da Lei n. 1.234, produzida pela via ordinária, em momento anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Porém, a atual ordem constitucional dispôs que a matéria de que trata a referida Lei n. 1.234 deve ser regulamentada via lei complementar. Não sabendo como proceder, o referido deputado procura auxílio de sua assessoria jurídica a fim de sanar as dúvidas a seguir.

- a) É possível considerar que a Lei n. 1.234 tenha mantido a conformidade constitucional com o advento da nova Constituição? Justifique. (Valor: 0,75)
- b) Para a alteração dos dispositivos normativos constantes da Lei n. 1.234, que espécie legislativa deve ser utilizada pelo Deputado João da Silva? Justifique. (Valor: 0,50)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 140

Um candidato a Presidente da República, em discurso durante a campanha eleitoral, fez as proposições a seguir para seus eleitores:

- i. que iria revogar imediatamente uma medida provisória nociva ao interesse público, que foi editada em 10 de setembro de 2001, antes, portanto, da promulgação da Emenda Constitucional 32/2001 (que até hoje não foi apreciada pelo Congresso Nacional);

ii. que iria editar medida provisória para modificar alguns artigos da Lei n. 6.815/80, mais especificamente aqueles que tratam da naturalização do estrangeiro residente no Brasil, bem como fixar novas regras processuais da Lei n. 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A partir da hipótese apresentada, com base nas regras do processo legislativo brasileiro, responda aos itens a seguir.

a) É constitucionalmente possível revogar uma medida provisória que tenha sido editada há vários anos e que ainda não tenha sido objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, ou seja, não tenha sido rejeitada, nem convertida em lei, tal qual consta na primeira proposição feita pelo candidato? Justifique. (Valor: 0,65)

b) A segunda proposição feita pelo candidato no sentido de editar medida provisória com o intuito de regular a naturalização do estrangeiro residente no Brasil, bem como fixar novas regras processuais do Código de Defesa do Consumidor encontra amparo constitucional? Justifique. (Valor: 0,60)

Observação: sua resposta deve ser fundamentada. A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

QUESTÃO 141

O Presidente da República edita medida provisória estabelecendo novo projeto de ensino para a educação federal no País, que, dentre outros pontos, transfere o centenário Colégio Pedro II do Rio de Janeiro para Brasília, pois só fazia sentido que estivesse situado na cidade do Rio de Janeiro enquanto ela era a capital federal. Muitas críticas foram veiculadas na imprensa, sendo alegado que a medida provisória contraria o comando contido no art. 242, § 2.º, da CF/88. Em resposta, a Advocacia-Geral da União sustentou que não era correta a afirmação, já que o mencionado dispositivo da Constituição só é constitucional do ponto de vista formal, podendo, por isso, ser alterado por medida provisória. Considerando a

situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

- a) Segundo a Teoria Constitucional, qual é a diferença entre as denominadas normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais? (Valor: 0,75)
- b) O entendimento externado pela Advocacia-Geral da União à imprensa está correto, sendo possível a alteração de norma constitucional formal por medida provisória? (Valor: 0,50)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 142

A Assembleia Legislativa do Estado X elaborou lei estadual que determina que os veículos apreendidos pelas Polícias Militar e Civil, caso não sejam reclamados no período de três anos, serão levados a hasta pública, repartindo-se o produto do leilão entre o Estado e o Município. O Governador do Estado, preocupado com a constitucionalidade da lei, visto que ela atingirá patrimônio privado, consulta o Procurador-Geral do Estado. Com base no caso apresentado, responda aos itens a seguir.

- a) A lei estadual está de acordo com as normas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? (Valor: 0,65)
- b) O Governador do Estado X pode propor, perante órgão da União, alguma medida judicial visando à impugnação da lei estadual? Justifique. (Valor: 0,60)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 143

Após o pleito eleitoral, o Deputado Federal X, diplomado e empossado, resolveu trocar de legenda, alegando que as normas que disciplinam o

instituto jurídico da fidelidade partidária ainda não foram editadas no Brasil. O Deputado Federal X também conseguiu convencer o Senador Y, diplomado e empossado, a trocar de legenda, usando os mesmos argumentos. Efetuada a mudança para outra legenda já existente, o partido que perdeu os seus políticos resolveu pleitear, junto ao Poder Judiciário, a perda dos respectivos mandatos. Com base na situação narrada, responda aos itens a seguir.

- a) A iniciativa do partido político de reaver o mandato do Deputado Federal X tem fundamento na CF/88? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) A solução jurídica é a mesma para o caso do Senador Y? Justifique. (Valor: 0,60)

Observação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XXI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 144

O Governador do Estado Z, no decorrer de seu mandato, é processado por agredir fisicamente um funcionário do hotel em que se hospedara no decorrer de suas férias, pois esse funcionário não teria tido o devido cuidado no transporte de suas malas. O fato ganhou as manchetes dos meios de comunicação, o que deu origem a uma forte pressão popular para que o agente político respondesse penalmente pelo desvio de conduta cometido.

O Governador, preocupado, alega em sua defesa que se trata de conduta não passível de responsabilização, pois, quando a Constituição estabelece que o Presidente da República não responde por crimes estranhos ao exercício de sua função, estende tal direito, com base no princípio da simetria, a todos os chefes de Poder Executivo.

Sobre o fato descrito, responda aos itens a seguir.

- a) Tem razão o Governador quando afirma que, se a conduta descrita fosse praticada pelo Presidente da República, este não responderia criminalmente? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) No caso em tela, o Ministério Público poderia ajuizar a ação penal, de imediato, em face do Governador? Justifique. (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 145

O Governador de um Estado-membro da Federação vem externando sua indignação à mídia, em relação ao conteúdo da Lei Estadual n. 1.234/2015. Este diploma normativo, que está em vigor e resultou de projeto de lei de iniciativa de determinado deputado estadual, criou uma Secretaria de Estado especializada no combate à desigualdade racial. Diante de tal quadro, o Governador resolveu ajuizar, perante o Supremo Tribunal Federal, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) impugnando a Lei Estadual n. 1.234/2015.

Com base no fragmento acima, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

- a) A Lei Estadual n. 1.234/2015 apresenta algum vício de inconstitucionalidade? (Valor: 0,60)
- b) É cabível a medida judicial proposta pelo Governador? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 146

Luís, governador do Estado Beta, pertence a uma família de grande prestígio na esfera política estadual e é casado com Carla, que pertence a outro importante clã político do mesmo Estado. Após alguns desentendimentos públicos, todos devidamente acompanhados pela mídia,

o casal se divorciou. Imediatamente, Carla busca um advogado e solicita orientação sobre a possibilidade de concorrer ao cargo de governador do Estado Beta. Porém, passadas duas semanas da consulta, Luís tem um infarto, não resiste e falece.

De acordo com o caso concreto acima narrado e tendo por referência os aspectos jurídico-constitucionais que fundamentam o sistema jurídico brasileiro, responda aos itens a seguir.

- a) Qual a resposta corretamente dada a Carla pelo advogado? (Valor: 0,60)
- b) O advogado daria a mesma resposta, caso Carla o tivesse procurado após o falecimento de Luís? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 147

O prefeito do Município Sigma envia projeto de lei ao Poder Legislativo municipal, que fixa o valor do subsídio do chefe do Poder Executivo em idêntico valor ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tal projeto é aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo Chefe do Poder Executivo. No dia seguinte ao da publicação da referida norma municipal, o vereador José, do Município Sigma, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse tal lei declarada inconstitucional.

Diante do exposto, responda aos itens a seguir.

- a) Há vício de inconstitucionalidade na norma municipal? Justifique. (Valor: 0,85)
- b) A medida judicial adotada pelo Vereador está correta? Justifique. (Valor: 0,40)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 148

Suponha a seguinte situação hipotética: determinada Emenda Constitucional, promulgada em março de determinado ano, altera o regime das coligações eleitorais dos partidos políticos. Nos atos das disposições transitórias, a própria Emenda Constitucional estabelece que as novas regras atinentes às coligações partidárias já deverão ser observadas nas próximas eleições, que ocorrerão em outubro do mesmo ano.

Com base no fragmento acima, responda, fundamentadamente, aos itens abaixo:

- a) A referida emenda constitucional apresenta alguma violação aos limites constitucionais impostos ao Poder Constituinte Derivado Reformador? Justifique. (Valor: 0,70)
- b) No âmbito do ordenamento constitucional brasileiro, é correto afirmar que ainda vigora a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias? Justifique. (Valor: 0,55)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 149

Roberto, servidor público estadual, após se aposentar, surpreende-se com o corte do auxílio-alimentação que recebia quando em atividade. Indignado, requer à Administração que o referido benefício seja reinserido, já que o direito à alimentação integra o conceito de mínimo existencial. Todavia, ao negar o pedido, a Administração, alegando crise orçamentária, informa que esse direito, embora constitucionalmente previsto, é sempre hierarquicamente inferior aos demais direitos estabelecidos no rol de direitos fundamentais sociais, não tendo o Estado, portanto, o dever de contemplá-lo.

Inconformado com a resposta, Roberto procura um(a) advogado(a) para que esclareça os itens a seguir.

a) Diante do que informa o sistema jurídico-constitucional brasileiro e das informações acima apresentadas, há elementos jurídicos para reverter judicialmente a decisão administrativa do corte do auxílio-alimentação? (Valor: 0,65)

b) Independentemente da possibilidade ou impossibilidade jurídica do corte do auxílio-alimentação, a questão hierárquico-normativa suscitada pela Administração Pública pode ser considerada um argumento reconhecido pelo sistema jurídico-constitucional brasileiro? (Valor: 0,60)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 150

A Câmara de Vereadores do Município Beta aprova projeto de lei que divide o mencionado Município em dois, sem qualquer espécie de consulta pública à população e sem realizar qualquer estudo prévio de viabilidade do novo ente federativo. O prefeito de Beta veta o referido projeto e a Câmara derruba o seu veto, promulgando a lei. Logo em seguida, o prefeito de Beta, inconformado com a norma aprovada, decide realizar um referendo a fim de saber a opinião da população local, a qual, após a consulta, manifesta-se favoravelmente ao desmembramento.

A partir da situação narrada, responda aos itens a seguir.

a) A referida norma municipal é constitucional? Justifique. (Valor: 0,90)

b) À luz do sistema constitucional vigente, seria possível a fusão do Município Beta com o Município vizinho Alfa? Justifique. (Valor: 0,35)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 151

Em 1975, o Presidente da República estabeleceu, por decreto, que a localização da nova usina nuclear seria o Município Alfa. O Decreto de 1975 seguiu todas as prescrições legais então vigentes, sem nenhum tipo de violação à Constituição da época. Não obstante, tendo em vista diversos fatores econômicos, políticos e sociais, o início dos trabalhos ficou adiado para uma nova oportunidade. Com o advento da Constituição de 1988, o texto constitucional passou a determinar que a localização de usinas nucleares seja autorizada por Lei Federal.

Diante da narrativa acima, responda aos itens a seguir.

- a) O decreto do Presidente da República, editado em 1975, foi recepcionado pela nova Constituição? Justifique. (Valor: 0,70)
- b) O atual Presidente da República pode, por decreto presidencial, alterar a localização da usina nuclear para o Município Beta, no lugar de Alfa? Justifique. (Valor: 0,55)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

XXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 152

Determinado tratado internacional de proteção aos direitos humanos, após ser assinado pelo Presidente da República em 2005, foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por quatro quintos dos votos dos respectivos membros, sendo promulgado na ordem interna. Após a sua promulgação na ordem jurídica interna, percebeu-se que ele era absolutamente incompatível com regra constitucional que disciplinava certo direito dos administrados perante a Administração Pública, já que o ampliava consideravelmente.

Com base na situação narrada, responda aos itens a seguir.

- a) O referido tratado pode ser considerado norma válida de natureza

constitucional? (Valor: 0,75)

- b) Caso seja identificado algum vício de inconstitucionalidade, seria possível submeter esse tratado ao controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal? (Valor: 0,50)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 153

João, vereador do Município X, e José, senador pelo Estado Y, ambos pertencentes ao Partido K, proferiram inflamado discurso em Brasília contra as atividades desenvolvidas por determinada autarquia federal. Ao final, concluíram que os resultados alcançados nos últimos anos por essa pessoa jurídica de direito público eram pífios, o que era mais que esperado, já que o seu presidente, o Sr. Antônio, “era sabidamente inapto para o exercício da função”. Ao tomar conhecimento do discurso, o Sr. Antônio ficou transtornado. Afinal, era servidor público de carreira e era conhecido por todos pela lisura e seriedade do seu comportamento. Quanto aos maus resultados da autarquia, seriam sabidamente decorrentes da crise econômica que assolava o país, não da incompetência do seu presidente. Por fim, o Sr. Antônio procurou o seu advogado e disse que queria adotar as providências necessárias para a responsabilização do vereador João e do senador José pelos danos causados à sua honra.

Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

- a) O vereador João e o senador José podem ser responsabilizados civilmente pelas ofensas à honra do Sr. Antônio? (Valor: 0,75)
- b) O vereador João e o senador José, nas circunstâncias indicadas, seriam alcançados por alguma imunidade formal passível de influir na sua responsabilidade penal? (Valor: 0,50)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera

citação ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 154

Ernesto, de nacionalidade boliviana, imigrou para a República Federativa do Brasil em 2000 e, desde então, com aquiescência das autoridades brasileiras, fixou residência no território nacional. Cidadão de reputação ilibada e profundo admirador de nossa cultura, conheceu Cláudia, de nacionalidade portuguesa, também de reputação ilibada e que vivia no Brasil desde 2010. Ernesto e Cláudia, que começaram a viver juntos há cerca de um ano, requereram a nacionalidade brasileira. Para surpresa de ambos, os requerimentos foram indeferidos. No caso de Ernesto, argumentou-se que suas características pessoais, como idade e profissão, não se enquadravam nas diretrizes da política nacional de migração. Quanto a Cláudia, argumentou-se a ausência de utilidade na naturalização, já que, por ser portuguesa, seria alcançada pelo estatuto da igualdade entre portugueses e brasileiros. Inconformados com os indeferimentos, Ernesto e Cláudia procuraram os seus serviços como advogado(a) para que a situação de ambos fosse objeto de criteriosa análise jurídica.

Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

- a) Ernesto possui o direito subjetivo à obtenção da nacionalidade brasileira? (Valor: 0,60)
- b) As razões invocadas para o indeferimento do requerimento de Cláudia mostram-se constitucionalmente corretas? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 155

Determinado cidadão (jurisdicionado) apresentou reclamação, perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em face de juiz do trabalho. Ao apreciar

o caso, o CNJ, em sessão presidida pelo Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal Federal, conhece da reclamação e instaura Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Considerando que os fundamentos da defesa já tinham sido amplamente apresentados pelo juiz do trabalho em suas manifestações públicas, o CNJ, em prol da celeridade processual, afastou a necessidade de nova manifestação do referido agente, tendo decidido pela aposentadoria do magistrado com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Considere a seguinte situação hipotética e responda aos itens a seguir.

- a) O cidadão poderia ter se dirigido ao Conselho Nacional de Justiça na forma descrita?(Valor: 0,60)
- b) O procedimento do Conselho Nacional de Justiça foi correto? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

XXIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 156

O art. 123 da Constituição do Estado Alfa, que teve sua redação alterada por Emenda à Constituição Estadual, promulgada em junho de 2016, dispõe que todos os Municípios com mais de cinco mil habitantes situados no Estado, entre os quais está o Município Delta, deverão possuir, obrigatoriamente, um plano diretor, devidamente aprovado pela respectiva Câmara Municipal, que servirá como instrumento básico da política de desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana.

Levando em consideração que o prefeito do município Delta, com apenas seis mil habitantes, não pretende fazer uso dos instrumentos previstos no art. 182, § 4.º, da CF/88, responda aos questionamentos a seguir.

- a) O art. 123 da Constituição do Estado Alfa apresenta alguma incompatibilidade de ordem material com a Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988? (Valor: 0,60)

- b) O Procurador-Geral da República poderia propor uma Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva contra o Estado Alfa por violação de princípio constitucional sensível? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 157

Em uma Federação, sob o argumento de que, entre os governantes do Estado Alfa (os anteriores e o atual), consolidou-se uma forma de atuação administrativa que privilegia de forma desmedida a população de determinada região geográfica, a população das outras regiões passou a pleitear autonomia política por meio de grandes manifestações. Para tanto, alimentam a pretensão de formar um novo Estado-membro, a ser denominado Estado Beta.

Diante do quadro acima e considerando o que informa o sistema jurídico-constitucional, responda aos itens a seguir.

- a) De acordo com a CF/88, é viável a formação do Estado Beta? (Valor 0,45)
- b) O surgimento do Estado Beta configurará o fenômeno da secessão? Justifique. (Valor 0,40)
- c) Caso seja criado o Estado Beta, de acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, suas competências materiais e legislativas estariam todas expressas na CF/88? Justifique. (Valor 0,40)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 158

O Supremo Tribunal Federal, há vinte anos, ao julgar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal W,

que estabeleceu critérios para a fruição de determinado benefício assistencial, dentre os quais o limite da renda familiar. Apesar do trânsito em julgado do acórdão proferido, determinado partido político entendia que os critérios estabelecidos pela Lei Federal W eram absolutamente incompatíveis com as características sociais e econômicas da realidade atual. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a referida ação, invocara as características sociais e econômicas da época para delinear o sentido das normas da Constituição da República utilizadas como paradigma de análise, o partido político procurou um advogado e solicitou a análise da questão.

Na posição de advogado do partido político, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

- a) É possível que o sentido das referidas normas constitucionais, utilizadas como paradigma de análise, seja outro na atualidade, apesar de o texto constitucional permanecer o mesmo? (Valor: 0,75)
- b) A improcedência do pedido na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade impede que nova ação dessa natureza tenha a Lei Federal W como objeto? (Valor: 0,50)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 159

No segundo ano do seu segundo mandato consecutivo, Maria da Silva, governadora do Estado Alfa, divorcia-se de seu marido, Antônio da Silva, com quem era casada há muitos anos. Antônio da Silva, que, no momento, não exerce qualquer cargo eletivo, mas sempre almejou concorrer ao cargo de senador, filia-se, em razão da separação, ao partido político oponente ao de sua ex-mulher. Ocorre que o partido solicita a ele, que, em vez de candidatar-se ao Senado Federal, apresente-se como candidato a governador do Estado Alfa, de modo a suceder sua ex-mulher.

Diante do exposto, responda aos itens a seguir.

- a) Antônio da Silva pode concorrer aos referidos cargos (senador ou governador)? Justifique. (Valor: 0,80)
- b) Seria diferente a análise do caso em tela se a dissolução do vínculo conjugal se desse em razão de morte da governadora no início do último ano do seu mandato? Justifique. (Valor: 0,45)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XXV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 160

O Presidente da República editou o Decreto X, que regulamentou a Lei Federal Z. Ocorre que o Congresso Nacional, ao examinar o teor do Decreto X, entendeu que ele criava direitos não previstos na Lei Federal Z, ferindo, portanto, o princípio da legalidade. Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

- a) Que medida poderia ser adotada pelo Congresso Nacional para retirar os efeitos do Decreto X? (Valor: 0,50)
- b) Caso o Presidente da República entenda que essa medida não tem qualquer fundamento, terminando por restringir a competência constitucional do chefe do Executivo, é possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal? (Valor: 0,75)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 161

O Município Alfa, com o objetivo de solucionar a falta de profissionais dedicados à saúde pública, após o regular processo legislativo, altera a Lei

Orgânica Municipal (LOM), de modo a permitir a acumulação remunerada de 3 (três) cargos de profissionais da área de saúde. No que tange à acumulação de cargos, as normas da Constituição do estado em questão reproduzem as normas da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Dito isso, a associação municipal de enfermeiros resolve tomar providências, com o objetivo de afastar o novo regramento conferido pela LOM, pois entende que a referida acumulação acarretará desgaste à saúde dos profissionais e comprometerá a eficiência dos serviços prestados na área de saúde pública municipal.

A partir da situação narrada, responda aos itens a seguir.

- a) Diante da autonomia federativa do Município Alfa, a referida norma da Lei Orgânica Municipal é constitucional? Justifique. (Valor: 0,70)
- b) A Lei Orgânica Municipal que permitiu a acumulação de cargos pode ser objeto de ação de representação por inconstitucionalidade, ajuizada por um dos legitimados ativos previstos na Constituição Estadual? Justifique. (Valor 0,55)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 162

Edson, candidato ao cargo de Prefeito do Município Alfa, ficou surpreso ao saber que o Tribunal Regional Eleitoral competente acabara de deferir o requerimento de registro da candidatura a esse mesmo cargo formulado por Pedro. O requerimento fora indeferido em primeira instância sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República, tese objeto de amplo debate em segunda instância e que terminou por ser rechaçada. A razão da surpresa de Edson decorria do fato de Pedro ter sido Prefeito do Município Beta nas duas legislaturas imediatamente anteriores.

À luz desses fatos, Edson, que impugnara o registro da candidatura em primeira instância, procurou seu advogado para que ele o orientasse sobre

os questionamentos a seguir.

- a) O entendimento de que Pedro pode se candidatar ao cargo de Prefeito do Município Alfa é constitucional? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Caso a decisão do Tribunal Regional Eleitoral seja considerada incompatível com a Constituição da República, é possível impugná-la por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental? (Valor: 0,60)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 163

Pedro, cidadão brasileiro, viu-se impossibilitado de exercer certos direitos e liberdades constitucionais em razão da falta de norma regulamentadora, sendo que o poder de iniciativa legislativa é reservado ao Presidente da República, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo projeto. Irresignado com a situação, Pedro formula os questionamentos a seguir.

- a) Para combater a mora legislativa descrita na situação acima, qual a medida judicial a ser utilizada pelo cidadão? Justifique. (Valor: 0,50)
- b) Qual é o órgão competente do Poder Judiciário para apreciar a medida judicial? Justifique. (Valor: 0,35)
- c) Uma vez reconhecida a mora legislativa no processo que ele, Pedro, vier a instaurar, quais podem ser os efeitos da decisão judicial? (Valor: 0,40)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XXVI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 164

A sociedade empresária Vertical, que possui uma rede de lojas de material de construção nos Municípios A, B e C, decidiu abrir uma nova loja no

Município D. Após realizar pesquisa de mercado, identificou o bairro XX como o de maior potencial para a construção civil. Ato contínuo, solicitou autorização à autoridade municipal competente para instalar sua nova loja no referido bairro. Para surpresa da sociedade empresária Vertical, o requerimento formulado à autoridade competente do Município D foi indeferido sob o argumento de que o bairro XX já contava com quatro lojas de material de construção, sendo que a Lei Municipal n. 123/2010 vedava que estabelecimentos dessa natureza fossem instalados, no mesmo bairro, a menos de 500m de distância um do outro, óbice que não poderia ser contornado naquele caso. Manejados os recursos administrativos cabíveis e esgotada a via administrativa, a proibição foi mantida. À luz da narrativa acima, responda aos questionamentos a seguir.

- a) A Lei n. 123/2010, do Município D, apresenta alguma incompatibilidade de ordem material com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988? (Valor: 0,60)
- b) A sociedade empresária Vertical tem legitimidade para impugnar, perante o Supremo Tribunal Federal, a decisão da autoridade competente do Município D, que indeferiu o pedido de autorização para a instalação da loja de material de construção no bairro XX? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 165

A Lei n. 123/2017 do Estado Ômega, dispôs que os estacionamentos explorados em caráter comercial deveriam cobrar valores proporcionais ao tempo de uso do respectivo espaço, nos termos do regulamento, vedada a cobrança de tarifa única. Com base nesse diploma normativo, foi editado o Decreto n. 45/2017, que definiu, de modo proporcional ao tempo de uso, o escalonamento de valores a serem cobrados. Insatisfeito com esse estado de coisas, um legitimado à deflagração do controle concentrado de

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal procurou você, como advogado(a), e formulou os questionamentos a seguir.

- a) É possível ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade apenas para impugnar o Decreto n. 45/2017, não a Lei n. 123/2017? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) É possível ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade para impugnar a Lei n. 123/2017 e o Decreto n. 45/2017, que a regulamenta? Justifique. (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 166

O Congresso Nacional estabeleceu novas regras gerais sobre o regime dos portos brasileiros. Imediatamente, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa, interessada na temática, posto estar em fase final a construção de um grande porto no Estado, legislou sobre questões específicas da matéria.

Inconformado com o teor das normas específicas estabelecidas pela Lei Y, de autoria do Estado Alfa, que poderiam causar grande prejuízo aos interesses econômicos e políticos do Estado Beta, o governador de Beta solicitou que sua assessoria jurídica respondesse, com base no que informa o sistema jurídico-constitucional brasileiro, às indagações a seguir.

- a) Pode o Estado Alfa produzir a normatização específica a que se refere o enunciado? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Está o governador do Estado Beta legitimado a questionar a constitucionalidade da Lei Y, do Estado Alfa, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)? Justifique. (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 167

O Presidente da República, ao constatar que o índice de violência no Estado Delta alcançara números alarmantes, resolveu decretar a intervenção federal nesse Estado. Apresentou como justificativa a necessidade de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Ao consultar os Conselhos da República e de Defesa Nacional, esses órgãos desaconselharam a medida, entendendo que outras ações menos invasivas na esfera de autonomia do referido Estado poderiam ser tomadas. Todavia, convicto de que a ação se fazia absolutamente necessária, o Presidente, agindo de ofício, decretou a intervenção, sem submeter a referida questão ao controle político.

Diante de tal fato, responda, tendo por pressuposto a inteligência jurídico-constitucional da Constituição da República de 1988, aos itens a seguir.

- a) No caso em tela, havia necessidade de a referida intervenção ter sido submetida a algum controle prévio de natureza política? (Valor: 0,60)
- b) O Presidente da República, ao decretar a intervenção federal desconsiderando os aconselhamentos dos Conselhos da República e de Defesa Nacional, agiu nos limites constitucionais a ele impostos? Justifique. (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XXVII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 168

Após a promulgação da Constituição de 1988, a Lei Federal X alterou a sistemática de registro de candidaturas para as eleições, tendo estatuído, de modo expresso, que as novas regras seriam aplicadas às eleições a serem realizadas no ano seguinte, onze meses após a sua entrada em vigor, o que ocorreu na data de sua publicação. Essa alteração foi considerada lesiva pela direção nacional do Partido Político Alfa, que

somente contava com representantes no âmbito das Assembleias legislativas estaduais.

À luz desse quadro, responda, como advogado(a), aos questionamentos a seguir.

- a) A Lei Federal X é compatível, sob os aspectos material e formal, com a Constituição da República Federativa do Brasil? (Valor: 0,65)
- b) Caso a Lei Federal X seja inconstitucional, o partido político Alfa pode deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal? (Valor: 0,60)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 169

Um grupo de criminosos fortemente armados desferiu disparos de arma de fogo contra diversos populares no Estado Alfa, dando causa à morte de trinta pessoas. No dia seguinte aos fatos, momento em que as autoridades estaduais já tinham iniciado a investigação do ocorrido, certa autoridade federal afirmou que os fatos eram de extrema gravidade, sendo evidente o descumprimento das obrigações internacionais assumidas pela República Federativa do Brasil, bem como que adotaria medida, nesse mesmo dia, para que a investigação dos crimes não fosse realizada por autoridades estaduais.

À luz da narrativa acima, responda aos questionamentos a seguir.

- a) Que medida judicial poderia ser adotada pela autoridade federal competente para que a investigação dos crimes fosse transferida das autoridades estaduais para as federais? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Considerando os dados da narrativa acima, em especial o fato de não haver qualquer notícia da ineficiência das autoridades estaduais, a medida judicial eventualmente ajuizada deveria ser acolhida pelo Tribunal

competente? Justifique. (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação

QUESTÃO 170

Pedro requereu a determinada Secretaria de Estado que fornecesse a relação dos programas de governo desenvolvidos, nos últimos três anos, em certa área temática relacionada aos direitos sociais, indicando-se, ainda, o montante dos recursos gastos. O Secretário de Estado ao qual foi endereçado o requerimento informou que a área temática indicada não estava vinculada à sua Secretaria, o que era correto, acrescentando que Pedro deveria informar-se melhor e descobrir qual seria o órgão estadual competente para analisar o seu requerimento. Além disso, afirmou que todas as informações financeiras do Estado, especialmente aquelas relacionadas à execução orçamentária, estão cobertas pelo sigilo, não sendo possível que Pedro venha a acessá-las. Considerando a narrativa acima, responda aos questionamentos a seguir.

- a) Ao informar que Pedro deveria “descobrir” o órgão para o qual endereçaria o seu requerimento, o posicionamento do Secretário de Estado está correto? (Valor: 0,60)
- b) É correto o entendimento de que as informações financeiras do Estado estão cobertas pelo sigilo, o que impede que Pedro tenha acesso ao montante de recursos gastos com programas de trabalho em certa área temática relacionada aos direitos sociais? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 171

Com o objetivo de combater os graves problemas de infraestrutura verificados no território do Estado Alfa, a Assembleia Legislativa promulgou

a Emenda Constitucional n. XX/2018, vinculando 50% da receita arrecadada com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de qualquer natureza (ICMS) às obras de infraestrutura. Além disso, estatuiu, como programa, as estradas a serem reformadas e aquelas que deveriam ser construídas nos próximos dez anos, bem como o percentual dos recursos a ser direcionado a cada uma delas.

a) A vinculação do produto da arrecadação do ICMS aos fins referidos na Emenda Constitucional n. XX/2018 é compatível com a Constituição da República? Justifique. (Valor: 0,65)

b) A programação financeira estabelecida pela Emenda Constitucional n. XX/2018 está em harmonia com a Constituição da República? Justifique. (Valor: 0,60)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação

XXVIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 172

Em razão do grande quantitativo de acidentes fatais na área urbana, a Câmara Municipal do Município Alfa aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei n. 123/2018. Esse diploma normativo previu multas um pouco mais elevadas que aquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro para os motoristas que trafegassem em velocidade superior à permitida no território do Município Alfa. À luz da narrativa acima, responda aos questionamentos a seguir.

a) A Lei n. 123/2018, do Município Alfa, sob o prisma formal, está em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988? Justifique. (Valor: 0,60)

b) Se a lei municipal se limitar a estabelecer a velocidade máxima a ser observada nas vias urbanas do Município, há alguma incompatibilidade

formal com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988? Justifique. (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 173

O Partido Político Alfa, com representação no Congresso Nacional, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade impugnando a Medida Provisória n. 123/2017, a qual, no seu entender, seria dissonante da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. No curso do processo objetivo, a referida Medida Provisória foi convertida na Lei Federal n. 211/2018. À luz dessa narrativa, responda aos questionamentos a seguir.

- a) Com a conversão da Medida Provisória n. 123/2017 na Lei Federal n. 211/2018, que medida deve ser adotada pelo autor para o prosseguimento do processo de controle concentrado de constitucionalidade? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Se a Medida Provisória n. 123/2017 tivesse, antes da conversão, sido integralmente revogada por lei superveniente, qual seria a consequência para o processo de controle concentrado de constitucionalidade? Justifique. (Valor: 0,60)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 174

A Executiva Nacional do Partido Político CX decidiu formar coligação com o Partido Político JT, visando à eleição majoritária para a Chefia do Executivo Federal. Ocorre que, dias depois, tomou conhecimento de que este último partido político, por sua Executiva Estadual, veio a formar coligação com o Partido Político BN para as eleições proporcionais de nível estadual. Preocupada com essa situação, a Executiva Nacional do Partido Político CX

procurou seus serviços como advogado(a) e solicitou que fossem respondidos os questionamentos a seguir.

- a) O Partido Político JT agiu de forma compatível com a Constituição da República ao formar coligações com os partidos políticos CX e BN? (Valor: 0,50)
- b) Caso a Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral competente, reconheça que a coligação formada entre os Partidos Políticos JT e BN destoa da Constituição da República, qual é o Tribunal competente para conhecer do recurso cabível? (Valor: 0,75)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 175

João da Silva, servidor público estadual, respondeu a processo administrativo disciplinar sob a alegação de ter praticado determinada infração no exercício da função. Ao final, foi condenado e sofreu a sanção de advertência. A conduta de João, apesar de eticamente reprovável, somente foi tipificada em lei em momento posterior à sua prática, o que foi considerado irrelevante pela autoridade administrativa competente, pois “inexistiria norma constitucional vedando a retroação da lei que tipificou a infração administrativa”. Além disso, João não constituiu advogado para sua defesa técnica no processo administrativo. Considerando a narrativa acima, responda aos questionamentos a seguir.

- a) A tese da autoridade administrativa, no sentido de que a retroação da tipificação da infração não é vedada pela Constituição da República, está correta? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Sob a ótica constitucional, o processo administrativo a que João respondeu sem a representação técnica de advogado é válido? (Valor: 0,60)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera

citação do dispositivo legal não confere pontuação.

XXIX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

QUESTÃO 176

Um Deputado Estadual foi condenado, em sentença criminal transitada em julgado, à pena de 4 (quatro) anos de detenção, que veio a ser convertida em pena restritiva de direitos. Em casos como esse, a lei estadual dispunha que o Deputado Estadual não teria os direitos políticos suspensos, salvo se a pena restritiva de direitos fosse descumprida e viesse a ser convertida em pena privativa de liberdade. Nesse caso, a suspensão dos direitos políticos iria perdurar até que fosse cumprida a pena. Considerando a narrativa acima e o princípio da simetria, responda aos questionamentos a seguir.

- a) A lei estadual, ao disciplinar a suspensão dos direitos políticos, é formal e materialmente compatível com a Constituição da República? (Valor: 0,80)
- b) Na situação narrada, é possível que o Deputado Estadual preserve o seu mandato mesmo tendo os direitos políticos suspensos? (Valor: 0,45)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 177

Ednaldo, diretor-presidente da autarquia XX do Estado Alfa, celebrou contrato de compra e venda, no qual o referido ente, sem a prévia realização de licitação, alienou a Pedro e a Marcos diversos veículos de sua frota por menos de dez por cento de seu valor de mercado. Irresignado com o ocorrido, o vereador José decidiu contratar você, como advogado(a), para ajuizar a ação cabível com o objetivo de anular o negócio jurídico e responsabilizar os autores.

- a) Qual é a ação judicial, de natureza constitucional, passível de ser proposta por José? Justifique. (Valor: 0,55)

b) Quem deve figurar no polo passivo da referida ação? Justifique. (Valor: 0,70)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação

QUESTÃO 178

A Constituição do Estado Alfa dispôs que os prefeitos municipais deveriam observar, em sua gestão, as diretrizes traçadas no plano anual estabelecido pelo Governador do Estado, que seriam executadas em conjunto com os secretários municipais, a serem nomeados após aprovação da respectiva Câmara Municipal. A partir da hipótese apresentada, responda aos itens a seguir.

a) A vinculação dos prefeitos municipais ao plano anual do governo estadual é compatível com a Constituição da República? (Valor: 0,60)

b) A competência outorgada às Câmaras Municipais está em harmonia com a Constituição da República? (Valor: 0,65)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

QUESTÃO 179

O Presidente da República editou a Medida Provisória n. XW/2018, permitindo que os Estados editassem lei dispensando a inserção, no âmbito do seu território, de algumas das informações a serem incluídas no registro civil das pessoas naturais. Face à importância da temática versada, a Medida Provisória n. XW/2018, por deliberação do colégio de líderes, foi imediatamente submetida à apreciação do plenário de cada casa do Congresso Nacional, daí resultando sua aprovação e a consequente promulgação da Lei n. DD/2018.

a) Com abstração de considerações em torno de sua relevância e urgência, a Medida Provisória n. XW/18 atende aos seus pressupostos

constitucionais? (Valor: 0,75)

b) O processo legislativo que culminou na aprovação da Lei n. DD/2018 é compatível com a ordem constitucional? (Valor: 0,50)

Observação: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Gabarito das questões dissertativas OAB¹

Na resolução das questões da prova não se deve fazer citações ou transcrições, pois o espaço é diminuto. Deve o candidato ler a doutrina e a jurisprudência e responder com suas palavras à questão.¹

No presente gabarito foram usadas citações e transcrições para facilitar o entendimento da matéria.

RESPOSTA À QUESTÃO 1

Historicamente, o Poder Constituinte é o poder de elaborar uma Constituição, podendo ser a primeira ou uma nova Norma Fundamental para um Estado. Pode ser classificado em:

- a) Poder constituinte originário. É um poder de fato que institui a Constituição de um Estado;
- b) Poder constituinte derivado de reforma ou de emendabilidade. É o poder que estabelece como poderá ser alterado o texto constitucional, tarefa que cabe ao legislador ordinário (Congresso Nacional).

No Brasil, tal poder é representado pelo art. 60 da CF/88 e pelo art. 3.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Na atualidade, a Constituição Federal de 1988 só pode ser modificada pelo procedimento previsto no art. 60 da Constituição Federal vigente. Trata-se das Emendas Constitucionais.

O art. 3.º do ADCT da CF/88 estabeleceu que a revisão constitucional seria realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão

unicameral.

Dessa forma, a revisão constitucional só poderia iniciar-se após 05 de outubro de 1993, fato que realmente ocorreu com a edição das seis Emendas Constitucionais de Revisão (ECR), sendo a primeira promulgada em 1.º de março de 1994 e a última em 7 de junho de 1994. A revisão da Constituição Federal de 1988 só seria possível após cinco anos de sua promulgação e somente uma vez (devendo respeitar as cláusulas pétreas). Essa foi a determinação do STF ao julgar a ADIn 981/93 (revisão constitucional a ser feita uma só vez).

Nesse sentido, manifestam-se Leda Pereira Mota, Celso Spitzcovisky (Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 7-8) e Erival da Silva Oliveira (Direito constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2009, p. 31), entre outros.

As Emendas Constitucionais estão previstas no art. 60 da CF/88.

O art. 60, I, II e III, trata da iniciativa, ou seja, quem pode propor um projeto ou proposta de emenda constitucional (PEC).

Os §§ 2.º, 3.º e 5.º do art. 60 estabelecem como deve ser o procedimento para emendar a Constituição.

O art. 60, em seu § 1.º, estabelece que, havendo determinadas circunstâncias, a Constituição não poderá ser emendada. São os casos de vigência de intervenção federal (arts. 34 a 36 da CF/88), de estado de defesa (art. 136 da CF/88) ou de estado de sítio (arts. 137 a 139 da CF/88).

Deve-se destacar que existem partes da Constituição Federal vigente que não admitem modificação para a redução de direitos. São as chamadas limitações materiais, cláusulas pétreas, cerne fixo, cláusulas de inamovibilidade, cláusulas inabolíveis, cláusulas inamovíveis ou núcleos constitucionais intangíveis.

c) Poder constituinte derivado decorrente. É o poder dos Estados-membros da Federação de se constituírem, ou seja, de elaborarem suas próprias

Constituições, respeitando os princípios constitucionais da Lei Fundamental da União (Constituição Federal vigente).

Cumprir destacar o conteúdo do art. 11 do ADCT que assim estabeleceu: "Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal (...). Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação (...)".

Na questão apresentada pode-se concluir pela inconstitucionalidade da PEC, uma vez que há redução do quórum necessário para a aprovação de uma emenda constitucional, que é de maioria qualificada de três quintos para a maioria absoluta. Há nesse caso violação expressa do § 2.º do art. 60 da Constituição Federal de 1988. Além disso, há o desrespeito de uma decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADIn 981/93), bem como violação as limitações materiais implícitas.

No que diz respeito à legitimidade democrática da convocação da assembleia de revisão, o Congresso Nacional deveria fazer um plebiscito para verificar se o povo, titular do poder constituinte, autorizaria uma eleição para uma assembleia nacional de revisão constitucional, que, se fosse o caso, uma vez eleita iria realizar a modificação constitucional respeitando os requisitos previstos no próprio art. 60 da CF/88. Desse modo, haveria compatibilidade da convocação com a teoria do poder constituinte.

RESPOSTA À QUESTÃO 2

A questão apresentada representa verdadeira colisão de normas fundamentais entre o direito à vida e o princípio da dignidade humana.

O direito à vida é o primeiro e mais importante dos direitos fundamentais, devendo o Estado proteger a vida de maneira global, inclusive a vida uterina, além de viabilizar a subsistência dos necessitados.

O direito à vida engloba, em regra, a não interrupção do processo vital senão pela morte espontânea e inevitável.

Como explicitado na questão, a anencefalia é uma má-formação congênita, caracterizada pelo não desenvolvimento do encéfalo, que é uma parte vital do cérebro humano. Os fetos anencefálicos não desenvolvem atividade cerebral e têm parada cardiorrespiratória poucos minutos após o parto.

Tal problemática foi levada ao Supremo Tribunal Federal por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, com pedido de medida liminar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), que alegou violação da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CF/88), da legalidade e autonomia da vontade (art. 5.º, II, da CF/88) e direito à saúde (arts. 6.º e 196 da CF/88), e, como ato do Poder Público, causador da lesão, o conjunto normativo ensejado pelos arts. 124, 126, caput, e 128, I e II, do CP, requerendo em última análise, a interpretação conforme a Constituição dos referidos dispositivos do Código Penal, a fim de explicitar que não se aplicam aos casos de aborto de feto anencéfalo.

Aqueles que sustentam ser o direito à vida o bem de maior relevância afirmam que tal direito inicia-se com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando num ovo ou zigoto. Desse modo, deve-se aplicar a determinação prevista no art. 5.º, caput, da CF/88.

A inviolabilidade do direito à vida deve ser implementada pelo Estado brasileiro, salvo exceção constitucional, como a pena de morte em tempo de guerra declarada (art. 5.º, XLVII, a).

Por outro lado, aqueles que entendem ser possível a realização do aborto, relativizam o direito à vida em prol da predominância do princípio da dignidade humana, uma vez que serão causados problemas psicológicos à gestante que sabe que seu filho irá morrer no momento do parto ou logo após, acarretando grave sofrimento físico e mental. Além disso, o

ordenamento jurídico possibilita o aborto no art. 128 do CP, em caso de estupro ou em caso de perigo para a vida da gestante, devendo ser ampliado o seu âmbito de atuação para anencefalia demonstrada clinicamente.

Do exposto, o projeto de lei autorizando a realização de aborto de anencéfalos, em qualquer momento da gestação não é incompatível com a previsão constitucional do direito à vida, uma vez que tal direito pode ser relativizado em situação prevista no Código Penal brasileiro no art. 128 (aborto necessário e em caso de gravidez resultante de estupro), que é norma infraconstitucional, recepcionada pela Constituição Federal vigente.

A questão da hierarquia de normas constitucionais compatíveis entre si não é pacífica devendo o Poder Judiciário resolver caso a caso.

RESPOSTA À QUESTÃO 3

O habeas corpus é remédio constitucional, também conhecido como ação penal de natureza constitucional. Tem por finalidade prevenir ou sanar a ocorrência de violência ou coação na liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

As normas previstas no art. 5.º da CF/88 visam a assegurar a validade e gozo dos direitos fundamentais dentro do território brasileiro para todos os indivíduos, não se excluindo os estrangeiros em trânsito. São protegidas também as pessoas jurídicas acusadas ilegalmente ou abusivamente de cometer crimes ambientais (doutrina minoritária). Dessa forma, são titulares dos direitos e garantias fundamentais: os brasileiros, os estrangeiros, as pessoas físicas e jurídicas.

As normas constitucionais devem ser interpretadas de modo ampliativo para a proteção da pessoa humana, inclusive de estrangeiros de passagem pelo território nacional.

Portanto, equivocada é a interpretação do advogado ao afirmar que os estrangeiros que não residem no Brasil não têm direito a habeas corpus

com base no caput do art. 5.º da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 4

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, caput, da CF/88).

No caso apresentado, servidor público militar ocupante de cargo nas Forças Armadas, foi removido, ex officio, de Belém/PA para Salvador/BA. O seu filho, na época da remoção, cursava o segundo semestre do curso de Direito em uma faculdade privada, na qual ingressou mediante aprovação no exame vestibular.

Com fundamento no art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do art. 1.º da Lei n. 9.536/97, o filho do militar solicitou transferência obrigatória para a Universidade Federal da Bahia (UFBA). A solicitação foi negada, sob o argumento de que essa transferência violaria o princípio da isonomia e que, portanto, seria incabível admitir interpretação do referido art. 1.º que permitisse a transferência obrigatória de instituições privadas para instituições públicas de ensino.

Nesse caso, razão assiste à UFBA, pois deve ser observada a natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem. De entidade privada seria plenamente possível a transferência para entidade privada, do mesmo modo de entidade pública para entidade pública.

Destaque-se a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o art. 1.º da Lei n. 9.536/97: "É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. Universidade. Transferência obrigatória de aluno. Lei n. 9.536/97. A constitucionalidade do

art. 1.º da Lei n. 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para pública –, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem – de privada para pública” (STF, Pleno, ADIn 3.324/DF. rel. Min. Marco Aurélio, DJ 5-8-2005).

Admitir-se, sem justificativa e em caso de excepcionalidade, a transferência de entidade privada para entidade pública viola o princípio da isonomia. Não se pode negar que tal situação seria, em tese, admissível se naquele Estado existisse apenas uma faculdade de direito pública. Nesse caso, não se poderia punir o filho do militar que foi removido de ofício.

RESPOSTA À QUESTÃO 5

A Constituição Federal de 1988, no art. 132, caput, estabelece que: “Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos (...), exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas”.

E ainda sobre o tema no art. 69 do ADCT é determinado que: “Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções”.

Desse modo, cabe aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercer a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, sendo permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, tivessem órgãos distintos para as respectivas funções.

Como se percebe, não há impedimento para a criação de uma Procuradoria

da Assembleia Legislativa, órgão do Poder Legislativo competente para representar judicialmente os interesses da Assembleia, ativa ou passivamente, nos processos referentes ao Poder Legislativo estadual. Saliente-se que deve ser restrita, porém essa representação judicial, às hipóteses em que compareça a Câmara a Juízo em nome próprio.

Portanto, a emenda apresentada na questão seria constitucional nos termos apresentados acima. No entanto, havendo invasão das atribuições dos Procuradores do Estado, poderia ser sustentada a inconstitucionalidade através de Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo governador do Estado, que tem legitimidade ativa prevista no art. 103, V, da CF/88. Saliente-se que deveria ser demonstrada a pertinência temática para a propositura da ação.

RESPOSTA À QUESTÃO 6

As medidas provisórias estão previstas no art. 62 da CF/88 e na Emenda Constitucional n. 32/2001. Constituem espécie normativa privativa do Presidente da República, tendo por requisitos a relevância e urgência, e suas vedações estão previstas, em especial, no § 1.º do art. 62.

Preconiza a Constituição Federal de 1988 que é livre a associação profissional ou sindical e que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical (art. 8.º, caput, e I).

Verifica-se no caso apresentado que houve afronta à vedação da interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindical. Além disso, já há previsão expressa no inciso III do art. 8.º da CF/88, que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Desse modo, existe incompatibilidade da medida provisória acima referida com o ordenamento constitucional, por violação do art. 8.º, caput, I e III, da

CF/88.

No que diz respeito à possibilidade do uso de medida provisória para regular a matéria da questão apresentada, entende-se que não há violação das vedações expressas no § 1.º do art. 62.

Cumprir destacar que, salvo melhor juízo, não há relevância e urgência sobre o tema tratado na Medida Provisória em questão.

Por fim, na questão se afirma que existe anteprojeto do próprio governo já finalizado sobre esse assunto e que tecnicamente não impediria o trâmite da referida Medida Provisória, pois o inciso IV do § 1.º do art. 62 da CF/88 prevê matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

RESPOSTA À QUESTÃO 7

O governador do Espírito Santo ingressou perante o STF com ação direta de inconstitucionalidade, impugnando a validade de uma lei estadual do Espírito Santo que atribuía ao Poder Legislativo iniciativa legislativa relativa à lei que aumentava a remuneração dos servidores públicos ocupantes de cargos na administração estadual.

A ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) constitui instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, também chamado de controle em tese de constitucionalidade, não se levando em consideração o caso concreto. Verifica-se a incompatibilidade vertical de uma lei federal ou estadual em face da Constituição Federal de 1988.

Portanto, incorreta está a primeira afirmação do professor de direito. Não se trata de controle concreto, incidental ou entre partes, mas sim de controle abstrato, principal ou objetivo.

No que diz respeito às decisões de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 102, § 2.º, estabelece que: "As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas

ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Em tal situação, não há participação do Senado Federal.

Na verdade, a afirmação do professor se aplica ao controle difuso de constitucionalidade, nos termos do inciso X do art. 52 da CF/88.

Seria o caso do julgamento de um recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, a decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade genérica tem efeito retroativo, também chamado de *ex tunc* e não *ex nunc* (em diante), conforme afirmado pelo professor de direito.

Saliente-se que é possível a modulação temporal ou mudança dos efeitos previstos no art. 27 da Lei n. 9.868/99 assim determina: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, (...) restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

Desse modo, em regra, a decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade tem efeito *ex tunc*, mas poderá por maioria de dois terços de seus membros, haver a modulação temporal para *ex nunc*.

O Governador de Estado, por ser autor especial, ao propor Ação Direta de Inconstitucionalidade deve demonstrar a pertinência temática (justificar a ação – plausibilidade, conveniência e interesse – conforme jurisprudência do STF).

RESPOSTA À QUESTÃO 8

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227 determina que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Como se percebe na questão, o direito da criança de saber quem é seu pai está vinculado à dignidade que o Estado, a sociedade e a família lhe devem assegurar.

No mesmo sentido, existem as seguintes normas constitucionais: (1) § 6.º do art. 227, § 7.º do art. 226 e o art. 229.

No entanto, a ordem judicial que determinou a realização coercitiva do exame de DNA não se coaduna com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que em algumas decisões, por maioria de votos, concluiu que não se pode submeter o possível pai à realização do exame de DNA, algo que discrepa das garantias constitucionais implícitas e explícitas, a exemplo da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer. Assim, afiguram-se inadmissíveis provimentos judiciais que, em sede de ação civil de investigação de paternidade, determinem a condução do réu ao laboratório “debaixo de vara”, para coleta do material indispensável à feitura do exame de DNA (Uadi Lammêgo Bulos. Curso de direito constitucional. São Paulo, Saraiva: 2007, p. 1.328 – STF, HC 71.373, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 22-11-1996).

Sobre o tema, Alexandre de Moraes tem opinião interessante: “O princípio da paternidade responsável, consagrado no § 7.º do art. 226, deve ser compatibilizado com o princípio da dignidade humana durante a produção probatória, permitindo-se a realização compulsória do exame de DNA – por métodos não invasivos –, como, por exemplo, coleta de fios de cabelo ou

mesmo da saliva” (Constituição do Brasil interpretada. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2.211).

O tema é polêmico, diante dos princípios em conflito, devendo prevalecer o entendimento do Pretório Excelso, pela inconstitucionalidade da realização coercitiva do exame de DNA através de coleta de sangue do réu.

RESPOSTA À QUESTÃO 9

As medidas provisórias estão previstas no art. 62 da CF/88 e na Emenda Constitucional n. 32/2001. Constituem espécie normativa privativa do Presidente da República, tendo por requisitos a relevância e urgência, e suas vedações estão previstas, em especial, no § 1.º do art. 62 da CF/88.

Uadi Lammêgo Bulos ensina que: “O Presidente da República não poderá voltar atrás, tentando retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória que ele próprio editou com força de lei e de eficácia imediata, sob pena de violar a competência excepcional que a Constituição lhe conferiu, além de subtrair um dever imposto ao Poder Legislativo. Mas poderá abrogar a medida provisória, editando outra para substituí-la, suspendendo, assim, ‘efeitos da primeira, efeitos esses que, todavia, o Congresso poderá restabelecer, mediante rejeição da medida ab-rogatória’” (Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 987 e STF, ADIn 1.315-7-ML/DF rel. Ilmar Galvão, DJ 22-9-1995 e ADIn 2.984-MC, rel. Ellen Gracie, DJ 14-5-2004 – Precedente STF, RTJ, 157:856).

Alexandre de Moraes destaca a proibição de o Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional uma medida provisória que tiver editado, cabendo-lhe, tão somente, abrogá-la por meio de edição de nova medida provisória, que suspenderia os efeitos da primeira, até que o Congresso Nacional analisasse ambas. Nessa hipótese, o Congresso Nacional poderá agir de três maneiras: (1) aprova a segunda medida provisória, transformando-a em lei. Com isso, a revogação da primeira torna-se definitiva; (2) rejeita a segunda medida provisória e aprova a

primeira (que estava com seus efeitos temporariamente suspensos), convertendo-a em lei, quando então retornarão seus efeitos; (3) rejeita ambas as medidas provisórias. Nessa hipótese, deverá regulamentar as relações jurídicas resultantes por meio de decreto legislativo (Constituição do Brasil interpretada. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 1.154-1.155).

Como se vê, o Presidente da República pode editar nova medida provisória ab-rogando a anterior, mas apenas suspende temporariamente seus efeitos, não causando sua imediata invalidação.

O Congresso Nacional deverá apreciar ambas as medidas provisórias. Caso o Congresso Nacional rejeite a segunda medida provisória, pode vir a aprovar a primeira, transformando-a em lei, ou rejeitar ambas as medidas provisórias.

Por fim, também está incorreta a conclusão de que, como a segunda medida provisória teria efeitos meramente revogatórios, ela não poderia ser apreciada pelo Congresso Nacional, uma vez que o ordenamento brasileiro não admite a repristinação, a não aprovação da segunda não teria o condão de tornar novamente válida a primeira.

A medida provisória ab-rogatória deverá ser apreciada pelo Congresso e, se aprovada, com sua transformação em lei ordinária federal, a revogação da primeira torna-se definitiva. De outro modo, se rejeitada a segunda medida provisória, poderá vir a aprovar a primeira, que estava com seus efeitos apenas temporariamente suspensos, como estabelece o entendimento do Pretório Excelso.

RESPOSTA À QUESTÃO 10

Na questão verifica-se que um deputado estadual do Estado do Espírito Santo apresentou projeto de lei ordinária na assembleia legislativa de seu Estado, sobre matéria processual, criando exigências para o exercício do direito de ação e de defesa das partes em processo que envolva direitos patrimoniais disponíveis.

No caso em questão, há inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e material por restrição de direito fundamental.

A inconstitucionalidade formal é caracterizada quando há violação de procedimento previsto na Constituição. São exemplos comuns, a violação da iniciativa legislativa, do sistema de aprovação e da espécie normativa.

Constata-se que o projeto de lei foi apresentado por autoridade incompetente (deputado estadual) ao órgão legislativo também incompetente (Assembleia Legislativa estadual).

O art. 22, I, da CF/88, estabelece competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

Seriam competentes para apresentar tal projeto as pessoas previstas no art. 61, caput, da CF/88.

A inconstitucionalidade material é a adoção de atos jurídicos que violem as cláusulas pétreas ou direitos materiais constitucionais. No caso apresentado, existem restrições criadas pela lei para o exercício do direito de ação e de defesa das partes no processo caracterizando ofensa aos seguintes comandos constitucionais previstos no art. 5.º: (a) Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário – inciso XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”; (b) Princípio do devido processo legal – LIV – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”; (c) Princípio do contraditório e da ampla defesa – LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Desse modo, o projeto de lei ao criar uma série de dificuldades e restrições ao direito de ação e de defesa, fere o princípio do devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, conclui-se que o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, pelos motivos acima expostos.

RESPOSTA À QUESTÃO 11

O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade vertical que necessariamente deve existir entre as normas infraconstitucionais ou atos jurídicos e a Constituição.

No Brasil, adotou-se o sistema misto de controle jurisdicional de constitucionalidade, podendo ser efetivado pelo modo concentrado ou difuso.

O controle concentrado de constitucionalidade foi idealizado por Hans Kelsen, sendo aquele realizado por um Tribunal Constitucional, sobre uma lei em tese, produzindo efeito erga omnes e vinculante. No Brasil, na esfera federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as seguintes ações: ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesses casos, ocorre afronta à Constituição Federal de 1988. Destaque-se que é possível tal controle na esfera estadual a ser realizado pelo Tribunal de Justiça se houver contrariedade à Constituição estadual.

O controle difuso de constitucionalidade surgiu nos Estados Unidos da América, em 1803, do julgamento do caso Marbury X Madison. Tal controle é feito sobre um caso concreto, no qual se alega a inconstitucionalidade para se defender um bem da vida. Produz efeitos, em regra, inter partes. O controle difuso é exercido por qualquer magistrado competente para tal julgamento, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Podem ser considerados exemplos do controle difuso o julgamento de: recurso extraordinário, mandado de segurança, habeas corpus, entre outros.

Em regra, as decisões que declaram a inconstitucionalidade têm efeitos retroativos – ex tunc, podendo ser atribuído efeitos da decisão em diante – ex nunc, através de modulação temporal.

Por fim, quanto ao momento em que é exercido, o controle de constitucionalidade pode ser classificado em: (a) preventivo: opera antes

que o ato (particularmente a lei) se aperfeiçoe, ou seja, o controle é feito sobre o projeto de lei. No Brasil, o controle preventivo é exercido pelo Poder Legislativo (Comissões de Constituição e Justiça) e pelo Poder Executivo por meio do veto presidencial por inconstitucionalidade (art. 66, § 1.º, da CF/88). Nada impede que o Poder Judiciário o exerça excepcionalmente, por exemplo, mandado de segurança proposto por parlamentar federal no Supremo Tribunal Federal referente a processo legislativo em andamento (Informativo do STF 320); (b) Repressivo: Controle exercido sobre a lei ou ato normativo, em regra, já existente no ordenamento jurídico. A exceção ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada ainda não regulamentadas (casos de mandado de injunção ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão).

No Brasil, o controle repressivo é confiado ao Poder Judiciário. Excepcionalmente, a Constituição Federal vigente admite que o Poder Legislativo retire a efetividade de certas normas infraconstitucionais. São os seguintes casos: (a) medidas provisórias rejeitadas pelo Congresso Nacional por não atenderem aos requisitos de relevância e urgência ou outra inconstitucionalidade (art. 62, § 5.º); (b) decreto legislativo do Congresso Nacional visando a sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa (art. 49, V, c/c arts. 84, IV, e 68); (c) Resolução do Senado nos termos do inciso X do art. 52 em controle difuso de constitucionalidade.

RESPOSTA À QUESTÃO 12

A Constituição Federal de 1988 estabelece a legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade no art. 103. Tal legitimidade é concorrente (mais de um legitimado possui a titularidade para ingressar em juízo a fim de pleitear a tutela jurisdicional de um direito ou prerrogativa).

A pertinência temática é um requisito objetivo que revela o liame entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação, ou

seja, deve existir relação entre a norma impugnada e as atividades institucionais do requerente. Da análise da pertinência temática estabelecem-se dois tipos de legitimados ativos para o ajuizamento das ações diretas de inconstitucionalidade: os universais/neutros e os especiais/restritivos.

Os legitimados ativos universais ou neutros são aqueles que não necessitam demonstrar interesse especial para a propositura da ação de inconstitucionalidade, ou seja, presume-se de forma absoluta a pertinência temática, em face de suas próprias atribuições institucionais, para: o Presidente da República, Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Já os legitimados ativos especiais, restritivos ou interessados devem demonstrar a pertinência temática (interesse) para propor a ação direta de inconstitucionalidade e são eles: Mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os Governadores dos Estados ou do Distrito Federal e as confederações sindicais ou entidades de âmbito nacional.

RESPOSTA À QUESTÃO 13

O Mandado de Injunção está previsto no art. 5.º, LXXI, da CF/88.

É uma ação constitucional de caráter essencialmente mandamental, também chamado de remédio ou garantia constitucional. É instrumento de defesa difusa da Constituição (controle difuso de constitucionalidade), visando a tutelar direitos subjetivos constitucionais no caso concreto, pois existe uma norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada impedindo o exercício de um direito em caso concreto (inconstitucionalidade por omissão).

O Supremo Tribunal Federal entendia haver apenas mera recomendação ao Poder Legislativo para que editasse a norma, sem qualquer consequência

no caso de não atendimento (não concretista).

A doutrina sustentava que podia haver a solução apenas do caso concreto pelo Poder Judiciário, e esse é o atual entendimento do STF, conforme decisões nos MI 670, 712, 795 e 721 (concretista).

O mandado de injunção pode ser proposto por qualquer pessoa (física ou jurídica) interessada na questão, grupos, partidos, associações (desde que haja autorização expressa dos associados).

A legitimidade passiva é em face do órgão ou poder incumbido de elaborar a norma.

A competência constitucional é a seguinte: Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, q), Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, h), Tribunal Superior Eleitoral (art. 121, § 4.º, V) e Tribunal de Justiça (art. 125, § 1.º).

A eficácia da decisão relativamente aos sujeitos por ela atingidos é a seguinte: inter partes e, em regra, ex nunc, pois a regulamentação será feita posteriormente.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão ou supridora da omissão está prevista no art. 103, § 2.º, da CF/88 e no art. 12-A e s. da Lei n. 9.868/99.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão é instrumento de defesa abstrata da Constituição (controle concentrado de constitucionalidade) e tem por finalidade pleitear a regulamentação de uma norma constitucional.

Há omissão do legislador que deixa de criar a lei necessária à aplicabilidade e eficácia de normas constitucionais ou do administrador que não adote as providências necessárias para tornar efetiva a medida constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada (inconstitucionalidade por omissão). Visa a cientificar o poder competente para editar normatividade suficiente à regulamentação de norma constitucional.

Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade as pessoas indicadas no art. 103, caput, I a IX, da CF/88 e no art. 2.º da Lei n. 9.868/99, em face

do ente estatal competente para elaborar a norma.

A competência para julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade é privativa do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a).

No que diz respeito à eficácia da decisão relativamente aos sujeitos por ela atingidos, o Supremo Tribunal Federal deverá dar ciência ao poder competente para que sejam tomadas as medidas necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias (art. 103, § 2.º, da CF/88).

Esclareça-se que o enunciado não indica expressamente se é o caso de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou de uma ação direta de inconstitucionalidade genérica. O melhor entendimento levaria o aluno a comparar o mandado de injunção com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma vez que possuem um ponto em comum que é a ausência de regulamentação de uma norma que torna inviável o exercício de um direito ou liberdade constitucional.

Caso o aluno opinasse pela ação direta de inconstitucionalidade genérica deveria informar:

Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica: art. 102, I, a, da CF/88. (a) Natureza jurídica: ação direta de inconstitucionalidade. É instrumento de defesa abstrata da Constituição (controle concentrado de constitucionalidade); (b) Finalidade: declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual; (c) Legitimidade ativa: as pessoas indicadas no art. 103, caput, I a IX, da CF/88 e no art. 2.º da Lei n. 9.868/99; (d) Legitimidade passiva: em face do órgão ou autoridade do qual emanou o ato que se pretende impugnar, não obstante, parte da doutrina entende que por se tratar de processo objetivo, em abstrato, que objetiva, somente, retirar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo federal ou estadual, não haveria legitimidade passiva; (e) Competência: privativa do STF (art. 102, I, a, da CF/88); (f) Eficácia da decisão

relativamente aos sujeitos por ela atingidos: As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2.º, da CF/88).

Em resumo, tem efeitos erga omnes, vinculante e, em regra, ex tunc.

RESPOSTA À QUESTÃO 14

A violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, também denominada implícita, mediata ou não manifesta é aquela em que uma lei ou ato normativo se contrapõem à Constituição de modo oblíquo ou reflexo. Por exemplo, um regulamento contém disposição que, implicitamente, ofende o princípio da reserva constitucional de jurisdição (art. 5.º, XXXV, da CF/88).

O STF manifestou-se sobre o tema no seguinte julgado: “Tem-se inconstitucionalidade reflexa – a cuja verificação não se presta a ação direta – quando o vício de ilegitimidade irrogado a um ato normativo é o desrespeito à Lei Fundamental por haver violado norma infraconstitucional interposta, a cuja observância estaria vinculado pela Constituição” (ADIn/MC 2.535/MT).

O recurso extraordinário é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo previsto no art. 102, III, da CF/88.

Trata-se de controle difuso de constitucionalidade envolvendo um caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não é cabível recurso extraordinário, na ocorrência de ofensa indireta ou reflexa, conforme se verifica no seguinte julgado: “A alegada ofensa à Constituição, acaso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, por exigir – para efeito de seu reconhecimento – confronto prévio da legislação comum com o texto

constitucional, circunstância esta que, por si só, basta para inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (AgRg em AgIn, 250.730/MG).

RESPOSTA À QUESTÃO 15

A competência legislativa privativa da União para legislar está elencada no art. 22 da CF/88.

No seu parágrafo único está previsto que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no citado artigo.

A Constituição Federal de 1988 no art. 32, § 1.º determina que: “Ao Distrito Federal são atribuídas às competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”.

Desse modo, pode-se afirmar que o Distrito Federal pode legislar em competência legislativa privativa desde que autorizado por lei complementar federal. Trata-se da aplicação do princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional.

RESPOSTA À QUESTÃO 16

O enunciado da pergunta esclarece que o STF já se pronunciou sobre a questão, quando julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta por um Estado, entendendo que o art. 87 do ADCT é norma de transição, até que os entes federativos, em sua soberania, estabeleçam os limites estaduais.

A eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade está prevista no art. 102, § 2.º, da CF/88. No mesmo sentido, é a previsão do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99.

A medida cabível é a reclamação, pois a decisão do Supremo Tribunal Federal na Direta de Inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário.

Desse modo, caberia reclamação a ser proposta no Supremo Tribunal

Federal, nos termos do art. 102, I, I, da CF/88 e dos arts. 13 a 18 da Lei n. 8.038/90 (revogados pelo CPC/2015).

IMPORTANTE

Na época da prova, adotou-se o gabarito citado, porém nos casos do julgamento da Reclamação 3.014 e do AgRg na Reclamação 11.477 ficou consignado que não é possível o ajuizamento de Reclamação, porquanto na decisão que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual deve ser considerada apenas a parte dispositiva e não os motivos que a embasaram. Não se adota a transcendência dos motivos determinantes.

No julgamento do AgRg na Reclamação 11.477 é determinado que não cabe a Reclamação, pois se trata de normas de entes federativos distintos.

DICA

O art. 1.072, IV, do CPC de 2.015 revogou os arts. 13 a 18 da Lei n. 8.038/90. A reclamação é prevista nos arts. 988 a 993 do CPC de 2015.

RESPOSTA À QUESTÃO 17

Consta no texto que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade (ADIn), em face de uma lei estadual. Um outro Estado da Federação editou uma lei de igual teor da primeira já apreciada pelo STF. Em caso concreto o juiz da causa negou o direito da parte por entender que a lei era inconstitucional.

O controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal em uma ADIn é denominado controle concentrado de constitucionalidade por via de ação, também conhecido por controle em tese, abstrato, objetivo, restritivo e austríaco. No caso apresentado se trata de uma ADIn genérica.

Cabe lembrar que o controle jurisdicional concentrado exercido pelo Supremo Tribunal Federal, é o que fiscaliza a inconstitucionalidade das leis e atos normativos federais e estaduais, em sede de ação direta (art. 102, I, a, da CF/88). São legitimadas ativas as pessoas elencadas no art. 103, I a

IX, da CF/88.

Tal ação tem efeito, como regra, retroativo (ex tunc), mas pode ser dado efeito ex nunc (modulação de efeitos) se houver manifestação de dois terços dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 27 da Lei n. 9.868/99), contra todos (erga omnes), e vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública direta e indireta federal, estadual e municipal (art. 102, § 2.º, da CF/88).

O Controle de constitucionalidade feito pelo juiz da causa é o controle jurisdicional difuso, por via de exceção, subjetivo, ampliativo, norte-americano ou incidental realizado por juízes e tribunais, no caso concreto. Não há restrição para a legitimidade, podendo ser pleiteado por qualquer pessoa, seja autor, réu, o Ministério Público, o magistrado de ofício, entre outros. Os efeitos da decisão, como regra, são inter partes e ex tunc (retroativo), mas pode ter efeito ex nunc (modulação de efeitos, semelhante à ADIn genérica – RE 353.657/PR e RE 370.682/SC – Informativo do STF 473).

Em suma, o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal em ADIn é concentrado, enquanto o feito pelo juiz no caso é difuso. Os efeitos da decisão da ADIn são erga omnes e vinculante, enquanto o efeito da decisão do juiz no caso concreto é inter partes.

RESPOSTA À QUESTÃO 18

Na situação hipotética apresentada há uma norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada, que caracteriza uma inconstitucionalidade por omissão, e que impede Maria, servidora pública federal, de exercer o direito de se aposentar nas condições e exigências da aposentadoria especial.

A medida judicial de feição constitucional apropriada para garantir a aposentadoria a Maria é o Mandado de Injunção, nos termos do inciso LXXI do art. 5.º da CF/88.

O órgão do Poder Judiciário competente para julgá-lo é o Supremo Tribunal Federal, pois caberia ao Presidente da República (art. 61, § 1.º, II, c, da CF/88) apresentar o projeto de lei complementar exigida no § 4.º do art. 40 da CF/88, nos termos do art. 102, I, q.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entendia haver apenas uma mera recomendação ao poder omissor (Poder Legislativo ou Presidente da República) para que editasse a norma, sem qualquer consequência no caso de não atendimento.

O Min. Marco Aurélio, ao relatar o MI 721/DF, que tratava de caso semelhante ao problema apresentado na questão, sustentou: “(...) salientando o caráter mandamental e não simplesmente declaratório do mandado de injunção, asseverou que cabe ao Judiciário, por força do disposto no art. 5.º, LXXI e seu § 1.º, da CF/88, não apenas emitir certidão de omissão do Poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas viabilizar, no caso concreto, o exercício desse direito, afastando as consequências da inércia do legislador” (j. 27-9-2006).

Em 30 de agosto de 2007, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, acompanhou o voto do relator, deferindo ao impetrante o direito pleiteado, possibilitando a aposentadoria (teoria concretista).

RESPOSTA À QUESTÃO 19

Uadi Lammêgo Bulos preleciona que: “Precatório é o instrumento que consubstancia uma requisição judicial. A Carta de 1988 concebeu-lhe como forma de assegurar a isonomia entre credores e a impessoalidade administrativa, para evitar favorecimentos políticos ou pessoais. Trata-se de uma carta expedida pelos juízes da execução de sentença ao presidente do tribunal, em virtude de a Fazenda Pública ter sido condenada ao pagamento de quantia certa” (Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.054-1.055).

Sobre o tema, trata o art. 100 e seus parágrafos da CF/88.

Uadi Lammêgo Bulos sustenta que: "O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato de compreender os textos normativos eliminando o arbítrio e o abuso do poder. (...) os americanos usam o qualificativo razoabilidade; os alemães proporcionalidade; os europeus proibição de excesso. Todos esses termos são apropriados, pois computam ideia de prudência, sensatez, bom senso, equilíbrio. Isso é o que interessa" (Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 528).

O princípio da proporcionalidade está implícito no direito constitucional brasileiro, sendo uma criação doutrinária e jurisprudencial que assegura o Estado democrático de direito brasileiro.

Tendo em vista o inciso XXXVI do art. 5.º da CF/88, que estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, na situação hipotética apresentada existe uma inconstitucionalidade cometida pela União, pois há uma decisão transitada em julgado, que deu origem a um precatório e exige-se para o levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de valores decorrentes do precatório judicial fique condicionada à apresentação, ao juízo, de certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, bem como de certidão de regularidade com a seguridade social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a dívida ativa da União, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ao fazer tais exigências a União restringe e protela a efetividade da jurisdição, ao dificultar o rápido cumprimento da decisão, afrontando assim o princípio da celeridade previsto expressamente no art. 5.º, LXXVIII, da CF/88. Além disso, a coisa julgada que se caracteriza pela imutabilidade das decisões judiciais também fica limitada.

Em suma: a atuação da União no caso hipotético violou o princípio da proporcionalidade, criou obstáculo à efetividade da jurisdição e à coisa julgada, bem como criou privilégio para a Fazenda Pública incompatível com o ordenamento jurídico.

RESPOSTA À QUESTÃO 20

Os honorários advocatícios têm por objetivo remunerar a atividade realizada pelo advogado. Para o Pretório Excelso, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, pois visam a prover a subsistência do advogado e de sua família. Desse modo, estão incluídos na regra dos pagamentos efetuados por precatórios.

Quanto aos honorários advocatícios, o STF formou entendimento a respeito. Mostrou o Ministro Marco Aurélio que eles têm natureza alimentícia, pois visam prover a subsistência do advogado e de sua família. E, consoante os arts. 22 e 23 da Lei n. 8.906/94, a verba honorária incluída na condenação por arbitramento ou sucumbência pertence ao advogado, que goza do direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo, até, requerer que o precatório seja expedido a seu favor. STF, RE 470.407, rel. Min. Marco Aurélio, Informativo 426 (Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.058).

Sobre o tema deve-se lembrar a existência das seguintes súmulas: Súmula 655 do STF: "A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza". Súmula 144 do STJ: "Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa".

Por fim, não se pode esquecer que se os créditos forem de pequeno valor, não há a sujeição ao precatório judicial, mas a requisição de pequeno valor,

nos termos do art. 87 do ADCT.

Conclui-se que os honorários advocatícios têm natureza jurídica alimentar, submetendo-se à regra dos precatórios alimentares, com a ressalva dos créditos de pequeno valor, conforme descrito acima.

RESPOSTA À QUESTÃO 21

A ação civil pública foi introduzida no Brasil pela Lei n. 7.347/85 para a proteção dos direitos do consumidor, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a ordem econômica e urbanística.

É uma ação judicial de natureza constitucional, em virtude do art. 129, III, da CF/88. Entende-se que a ação civil pública é um remédio constitucional por conta de sua localização e a comparação de seu âmbito de atuação em relação à ação popular.

Em resposta a questão formulada pode-se afirmar que sim, a ação civil pública pode ser utilizada como instrumento de controle de constitucionalidade das leis desde que seja incidentalmente, ou seja, no curso de um processo concreto. Neste caso, os efeitos estarão vinculados às partes do processo.

Cabe observar que se a questão constitucional for o objeto principal da demanda, não se admitirá a ação civil pública, pois os seus efeitos são erga omnes e deste modo haveria a equiparação aos efeitos do controle concentrado e usurpação da competência do STF. Nesse sentido, já se manifestou o Pretório Excelso nos seguintes julgados: Rcl 633-6/SP, Min. Francisco Rezek, Rcl. 1.733/SP, Min. Celso de Mello, entre outros.

Em suma, admite-se a ação civil pública somente como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, no caso concreto e incidentalmente.

RESPOSTA À QUESTÃO 22

O decoro parlamentar corresponde ao respeito que um membro do Poder

Legislativo deve ter pela Constituição, pelas leis e outras normas, sejam legais ou consuetudinárias.

A falta de decoro parlamentar é uma das previsões constitucionais para a perda de mandato de Deputado ou Senador (art. 55, II, da CF/88).

A falta de decoro parlamentar é prevista no § 1.º do art. 55 da CF/88.

A falta de decoro parlamentar do deputado federal Antônio deve ser julgada pela Câmara dos Deputados, conforme previsão do § 2.º do art. 55 da CF/88, que assim determina: "Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa".

No caso apresentado, o deputado federal poderá renunciar ao cargo, mas sendo essa renúncia manifestada após a abertura do processo que vise ou possa levar à perda do mandato, na forma do § 4.º do art. 55 da CF/88, essa renúncia ficará suspensa até que haja a deliberação final da Casa.

As situações de perda do mandato parlamentar, órgão competente para julgamento, sistema de aprovação, entre outras peculiaridades, estão tratadas no art. 55 da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 23

Sim, existe uma inconstitucionalidade formal, pois houve uma incompatibilidade de espécie normativa para regulamentar a matéria, ao invés de projeto de lei complementar foi apresentado projeto de lei ordinária.

Tal conduta contraria a Constituição, pois a organização do Ministério Público da União deve ser disciplinada por lei complementar, nos termos do art. 128, § 5.º, da CF/88.

Por fim, cabe destacar que não houve inconstitucionalidade quanto à

iniciativa, pois o Presidente da República tem competência concorrente com o Procurador-Geral da República para apresentar projeto de lei sobre a organização do Ministério Público, conforme previsão constitucional da alínea d do inciso II do § 1.º do art. 61 e do § 5.º do art. 128.

RESPOSTA À QUESTÃO 24

As medidas provisórias estão disciplinadas no art. 62 da CF/88, bem como na Emenda Constitucional n. 32/2001.

Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, conforme a previsão constitucional do caput do art. 62.

Na situação apresentada a medida provisória pode ser utilizada, tendo em vista a situação de calamidade pública que autoriza a abertura de crédito extraordinário na lei orçamentária anual, pois trata-se de despesas imprevisíveis e urgentes, havendo expressa previsão constitucional nos termos do art. 167, § 3.º.

Em relação à inércia do Congresso Nacional e o vigor da referida medida provisória é preciso ressaltar que a Emenda Constitucional n. 32/2001, alterou o prazo de vigência e a disciplina constitucional das medidas provisórias. Hoje, no art. 62, § 3.º (Incluído pela EC 32/2001), da CF/88, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do § 7.º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

Destaque-se, porém, que o art. 2.º da Emenda Constitucional n. 32/2001 estabelece que as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação dessa emenda, portanto, antes de 12 de setembro de 2001, continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional, como a

medida provisória foi publicada no dia 12 de setembro de 2001, tem-se a aplicação desse dispositivo, de forma que essa medida apresentada na questão ficará em vigor até que seja revogada expressamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

RESPOSTA À QUESTÃO 25

Na questão apresentada deve ser utilizada uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que está prevista no art. 102, § 1.º, da CF/88 e que foi regulamentada pela Lei n. 9.882/99. Tal ação tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público, sendo cabível também quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1.º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99). Consideram-se preceitos fundamentais os princípios e normas da Constituição Federal vigente.

O art. 7.º, IV, da CF/88 estabelece que: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (...)".

Na questão apresentada existe uma lei estadual de 1987 que vincula a remuneração dos servidores públicos por meio de múltiplos do salário mínimo, nacionalmente unificado. Desse modo existe lesão de preceito fundamental, por norma estadual anterior à Constituição vigente e que viola a vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim prevista na parte final do inciso IV do art. 7.º da CF/88, autorizando a utilização da ADPF.

Ressalte-se o caráter subsidiário da ADPF, ou seja, só é admitida quando

não houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. A competência para julgar é do STF (art. 102, § 1.º, da CF/88). A legitimidade está prevista no art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99 que estabelece: “Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: I – os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; (...)”.

Portanto, são as mesmas pessoas do art. 103, I a IX, da CF/88. No caso em questão, o Governador do Estado teria legitimidade ativa (inciso V do art. 103 da CF/88), porém deveria demonstrar a pertinência temática.

O pedido de medida liminar é feito na petição inicial da arguição de descumprimento de preceito fundamental, devendo ser demonstrada a extrema urgência ou o perigo de lesão grave, requerendo a suspensão dos efeitos da lei estadual (art. 5.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99).

O art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99 prevê a possibilidade de concessão de liminar que deve ser no sentido de que, por decisão da maioria absoluta de seus membros, se determine aos juízes e tribunais que suspendam o andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes de coisa julgada.

Desse modo, a liminar tem efeitos ex nunc. Julgado o mérito da ação, os efeitos poderão ser retroativos (ex tunc), erga omnes e vinculante (art. 10, § 3.º, da Lei n. 9.882/99).

Por fim, destaque-se que se a lei estadual que violou preceito fundamental fosse feita depois da Constituição Federal de 1988 seria o caso de se utilizar no controle concentrado de constitucionalidade de uma ação direta de inconstitucionalidade genérica (art. 102, I, a, da Constituição Federal de 1988 e Lei n. 9.868/99). O Pretório Excelso, julgando caso semelhante, deferiu a liminar (ADPF-MC 33/PA, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29-10-2003).

RESPOSTA À QUESTÃO 26

Os tratados internacionais são pactos ou acordos celebrados entre dois ou mais sujeitos da comunidade internacional e podem ser incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.

Anteriormente à Emenda Constitucional n. 45/2004, os tratados internacionais, segundo o STF, se incorporavam ao ordenamento jurídico brasileiro como normas infraconstitucionais.

Após a EC n. 45/2004 houve a possibilidade de “constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos”, ou seja, utilizando-se do mesmo sistema de aprovação de uma emenda constitucional pode-se elevar um tratado internacional sobre direitos humanos que o Brasil faça parte para o status de norma constitucional. Esta é a previsão do § 3.º do art. 5.º da CF/88. Só o Decreto n. 6.949/2009 tem natureza de emenda constitucional.

Tal situação caracteriza o chamado “bloco de constitucionalidade”, que é a somatória de vários diplomas legais considerados como normas constitucionais, não obstante terem sido elaborados em momentos diferentes.

Normalmente, a incorporação de um tratado internacional segue o seguinte caminho:

1.ª Fase: negociação do conteúdo dos tratados internacionais feita pelo Ministério das Relações Exteriores.

2.ª Fase: assinatura do acordo. O art. 84, VIII, da CF/88 determina que: “Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; (...)”.

3.ª Fase: é a fase do referendo. O art. 49, I, da CF/88 estabelece que: “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

(...)”.

É editado um decreto legislativo promulgado e publicado pelo presidente do Senado Federal.

4.^a Fase: é a ratificação ou confirmação. O Presidente da República edita um decreto promulgando o tratado internacional ratificado pelo Congresso Nacional.

Cumprе destacar que o compromisso do Presidente da República no caso apresentado de colocar o tratado assinado imediatamente em vigor no Brasil por ato unilateral do Executivo não encontra amparo na Constituição Federal de 1988.

RESPOSTA À QUESTÃO 27

As emendas constitucionais são mecanismos de mudança da Constituição Federal de 1988 e estão disciplinadas no art. 60.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada no Senado Federal deve ter a concordância de 1/3 dos senadores (art. 60, I, da CF/88). Na atualidade, o Senado Federal é composto por oitenta e um senadores. Desse modo a PEC deve contar com a concordância (assinatura) de no mínimo vinte e sete senadores.

Verifica-se, portanto, que o senador não obedeceu ao requisito para a iniciativa da PEC.

A PEC deveria ter sido então analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e, não havendo outra comissão específica sobre o assunto, deveria ser encaminhada para aprovação pelo plenário da Casa (Senado) em dois turnos distintos, obtendo em cada três quintos dos membros (49 senadores). Essa é a previsão do § 2.º do art. 60 da CF/88. Cumprе observar que não é o caso de uma votação conjunta.

No caso apresentado, a PEC não seguiu o procedimento adequado, pois não passou pela CCJ e não obteve o quórum de aprovação necessário na

segunda votação (1.^a votação: 65% – 52 senadores; 2.^a votação 55% – 45 senadores).

Após a votação, a emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (§ 3.º do art. 60 da CF/88), seguindo para a publicação. Não havendo a participação do Presidente da República na sanção, promulgação e publicação das emendas constitucionais.

Em suma, o senador não obedeceu ao trâmite quanto à iniciativa, a proposta de emenda constitucional não obedeceu ao procedimento de discussão e votação (incompleta na segunda votação) e não há participação do Presidente da República na sanção, promulgação e publicação das emendas constitucionais.

RESPOSTA À QUESTÃO 28

Na Constituição Federal de 1988, na repartição de competências entre as entidades federativas, há o princípio da predominância do interesse, segundo o qual à União caberá às matérias e questões de predominante interesse geral, ao passo que aos Estados ficarão as matérias e assuntos de interesse regional, e aos Municípios, as questões de predominante interesse local.

Verifica-se que nos parágrafos do art. 24 da CF/88 existem regras de aplicação da competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer normas gerais através de leis federais. Aos Estados e ao Distrito Federal cabe suplementar a legislação federal através de leis estaduais e distritais. Não se pode esquecer que os Municípios podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber e desde que seja no interesse local (art. 30, I e II, c/c § 2.º do art. 24 da CF/88). Não havendo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena (normas gerais e especiais), para atender a suas peculiaridades (dentro do seu território). Por fim, a superveniência de lei federal sobre normas gerais

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Na questão, determinado Estado da Federação editou lei que versa sobre educação e cultura. Tal tema é disciplinado no inciso IX do art. 24 da CF/88. Desse modo, poderia o Estado da Federação legislar supletivamente sobre educação e cultura, não podendo contrariar as normas gerais estabelecidas na lei federal.

Caso ocorresse tal contrariedade seria possível a utilização de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.

O Procurador-Geral da República é um dos legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no art. 103, VI, da CF/88.

Cumprir observar que o art. 22 da CF/88 estabelece que: “Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIV – diretrizes e bases da educação nacional; (...)”.

Pode a União, por lei complementar, autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no art. 22 (parágrafo único do art. 22 da CF/88). Também nesse caso, havendo contrariedade de tais normas, seria possível a ADIn proposta pelo Procurador-Geral da República ou outro legitimado pelo art. 103 da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 29

A ação direta de inconstitucionalidade supridora da omissão ou por omissão (ADIn/ADIn-SO/PO) tem por objetivo pleitear a regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada.

Possuem legitimidade para propor tal ação as pessoas indicadas no art. 103, I a IX, da CF/88 e no art. 12-A da Lei n. 9.868/99. Saliente-se que as Mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional devem demonstrar a pertinência temática (interesse) para propor a ação direta de

inconstitucionalidade, por isso são também denominados autores especiais ou interessados.

A competência para julgar a ADIn é do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a, da CF/88). O quórum de instalação é de oito Ministros (dois terços de seus membros – art. 22 da Lei n. 9.868/99) e o quórum de aprovação é de maioria absoluta, ou seja, pelo menos seis dos onze Ministros do Supremo Tribunal Federal devem manifestar-se pela inconstitucionalidade por omissão (art. 97 da CF/88 e art. 23 da Lei n. 9.868/99).

Os efeitos de tal ação estão previstos no § 2.º do art. 103 da CF/88 e no art. 12-H da Lei n. 9.868/99.

O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 103, § 1.º, da CF/88 e art. 12- E da Lei n. 9.868/99).

De todo o exposto, verifica-se que a confederação sindical tem legitimidade para ingressar com a referida ação.

Cumprе destacar que é incompatível com o objeto da ADIn/SO (supridora de omissão) a concessão de medida cautelar. Nesse sentido, o Pretório Excelso se manifestou nas seguintes decisões: “A suspensão liminar de eficácia de atos normativos, questionados em sede de controle concentrado, não se revela compatível com a natureza e a finalidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eis que, nesta, a única consequência político-jurídica possível traduz-se na mera comunicação formal, ao órgão estatal inadimplente, de que está em mora constitucional” (ADIn 267-8/MC, rel. Min. Celso de Mello, DJU 19-5-1995); “É incompatível com o objeto mediato da referida demanda a concessão de liminar. Se nem mesmo o provimento judicial último pode implicar o afastamento da omissão, o que se dirá quanto ao exame preliminar” (ADIn 361-5, rel. Min. Carlos Velloso).

A nova composição do STF pode alterar tal posicionamento, pois tem dado

efeito concreto no julgamento de mandados de injunção (MI 670, 721, 758 e 795 – efeito concretista).

Saliente-se que existe a previsão legal de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 12-F da Lei n. 9.868/99).

Verifica-se do texto constitucional que na ADIn/SO não é obrigatória a oitiva do Advogado-Geral da União, uma vez que não há ato impugnado a ser defendido, enquanto o Procurador-Geral da República sempre deverá se manifestar. Destaque-se que o relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União (art. 12-E, § 2.º, da Lei n. 9.868/99).

RESPOSTA À QUESTÃO 30

A intervenção é medida excepcional e só deve ocorrer nos casos previstos expressamente na Constituição (arts. 34 e 35 da CF/88).

Na atualidade, a União poderá intervir nos Estados-membros e no Distrito Federal, enquanto os Estados-membros somente poderão intervir nos Municípios localizados em seus respectivos territórios.

Inferre-se que a União não pode intervir diretamente nos Municípios brasileiros, salvo se localizados em Território Federal (art. 35, caput, da CF/88). Cumpre lembrar que atualmente não existem Territórios Federais.

Sobre o tema intervenção devem ser observados do art. 34 ao art. 36 da CF/88.

Na situação hipotética apresentada, a intervenção pode ser realizada pelo Estado-membro no Município que deixou de aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 35, III, da CF/88).

A União só poderia decretar intervenção em Município localizado em território federal (art. 35, caput, 2.ª parte, da CF/88).

Na esfera federal, para a situação semelhante de não aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, deve o Procurador-Geral da República (art. 36, III, da CF/88) propor ação direta de inconstitucionalidade interventiva (ou representação interventiva) no Supremo Tribunal Federal por violação de princípio constitucional sensível.

Aplicando-se o princípio da simetria federativa ou o princípio do paralelismo constitucional, na situação apresentada na questão, deveria o Procurador-Geral de Justiça propor a ação direta de inconstitucionalidade estadual no Tribunal de Justiça local. Posteriormente, por maioria absoluta do Tribunal (art. 97 da CF/88) seria determinado ao Governador do Estado que editasse decreto governamental concretizando a intervenção.

No caso apresentado, por se tratar de intervenção estadual por requisição judicial não há controle político a ser realizado pelo Poder Legislativo estadual.

Em breve síntese, no caso apresentado é possível a intervenção estadual no Município, que dependeria de prévia autorização judicial, para que o governador decretasse a intervenção. A forma pela qual a intervenção deverá se concretizar é o decreto governamental, e não haverá controle político feito pelo Poder Legislativo.

RESPOSTA À QUESTÃO 31

Nos parágrafos do art. 24 da CF/88 existem regras de aplicação da competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer normas gerais através de leis federais. Aos Estados e ao Distrito Federal cabe complementar a legislação federal através de leis estaduais e distritais. Não se pode esquecer que os Municípios podem complementar a legislação federal e estadual no que couber e desde que seja no interesse local (art. 30, I e II, c/c § 2.º do art. 24 da CF/88). Não havendo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena (normas gerais e especiais), para atender a suas peculiaridades (dentro do seu território). Por

fim, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

O art. 30 da CF/88 afirma que: “Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de interesse local; II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...)”.

Da conjugação do art. 24, VI, e § 2.º com o art. 30, I e II, pode-se concluir que sobre a matéria “pesca” os Municípios podem suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que seja sobre assuntos de interesse local, como no caso apresentado na questão que diz expressamente: “que um Município que tem como carro-chefe de sua economia a atividade pesqueira editou lei que estabelece normas para a captura, o transporte e a comercialização de pescado em sua área territorial e prevê a aplicação de sanções administrativas para os que descumprirem tais normas”.

Não se deve esquecer que a pesca tem vinculação com matérias ambientais, desse modo, sobre o assunto é importante citar a competência comum prevista no art. 23, VI e VII, e a proteção do meio ambiente prevista no art. 225, § 1.º, I, V, VII e § 3.º, todos da CF/88, que assim estabelecem: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; (...)”.

Desse modo, cabe ao Poder Público de qualquer esfera administrativa o dever de proteger o meio ambiente, podendo aplicar sanções administrativas para os que descumprirem as normas ambientais (poder de polícia).

Sobre o tema pesca e meio ambiente cabe destacar a existência das seguintes normas: Código de Pesca – Decreto-lei n. 221/67, Código de Caça – Lei n. 5.197/67, Código Florestal – Lei n. 12.651/2012, Proteção ao Meio Ambiente – Lei n. 9.605/98 e Decreto n. 3.179/99 (revogado pelo Decreto

n. 6.514/2008), entre outros.

Pode-se concluir, diante dos argumentos apresentados, que é constitucional a referida lei municipal, uma vez que o Município que tem como carro-chefe de sua economia a atividade pesqueira, editou lei de interesse local, suplementando a legislação federal, estabelecendo normas para captura, transporte e comercialização de pescado em sua área territorial e determinando a aplicação de sanções administrativas para os que descumprirem tais normas. Como fundamento jurídico constitucional há aplicação do art. 24, VI e § 2.º, e do art. 30, I e II, todos da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 32

No caso em questão, estabelece o § 1.º, II, a, do art. 61 da CF/88 que: “§ 1.º – São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...) II – disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (...)”.

Referida norma aplica-se ao Chefe do Poder Executivo federal e pelo princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional é de aplicação obrigatória aos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Portanto, a iniciativa do projeto de lei é do Chefe do Poder Executivo respectivo.

Tal princípio pode ser deduzido do caput dos arts. 25, 29 e 32 da CF/88.

É importante destacar que, em regra, não será admitido aumento da despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Esta é a previsão do art. 63, I, da CF/88. Nesse sentido, se manifestou o STF (ADIn 774/RS, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 152/71).

Deduz-se que a Constituição do Estado deve estabelecer que a iniciativa para encaminhar projeto de lei que verse sobre reajuste de vencimentos dos servidores da Administração direta é do governador de Estado e deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa, em virtude do princípio da

simetria federativa ou do paralelismo constitucional.

Portanto, pode-se considerar legítima a iniciativa do governador ao encaminhar à assembleia legislativa projeto de lei que versa sobre reajuste de vencimentos dos servidores da Administração direta.

No que diz respeito ao procedimento de votação do projeto de lei duas são as observações necessárias:

- 1.º) não se admite emenda parlamentar para aumento da despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado (art. 63, I, da CF/88 – princípio da simetria federativa de repetição obrigatória);
- 2.º) não se exige a aprovação por maioria absoluta (maioria do total de membros), pois se trata de projeto de lei ordinária, que é aprovado por maioria simples (maioria dos presentes, estando na sessão, no mínimo, a maioria absoluta).

A maioria simples é prevista no art. 47 da CF/88.

Só haverá necessidade de maioria absoluta ou de maioria qualificada quando a Constituição o exigir expressamente.

Do exposto, conclui-se que foi legítima a iniciativa do governador na proposição legislativa quanto à matéria sobre reajuste de vencimentos dos servidores da Administração direta, porém, inconstitucional foi a apresentação de emenda parlamentar ao referido projeto majorando o valor do reajuste, implicando aumento de despesa. Por fim, não seria necessária a aprovação por maioria absoluta da Assembleia Legislativa, sendo necessária apenas a maioria relativa.

RESPOSTA À QUESTÃO 33

A taxa é tributo vinculado a uma atuação estatal, que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (art. 77, caput, do CTN).

As taxas estão previstas no art. 145, II, da CF/88.

O CTN, no art. 79, estabelece: “Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se: I – utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; II – específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidade públicas; III – divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários”.

Na questão, a taxa foi instituída por Município em razão da prestação de serviços públicos: capinação de vias e logradouros públicos, limpeza de praias e outros. Nesse caso, os serviços enumerados na lei municipal não são específicos ou divisíveis, desrespeitando o mandamento constitucional previsto no art. 145, II. Nesse sentido, manifestou-se o STF: “Taxa de manutenção e conservação de vias públicas – é inconstitucional, porque sua base de cálculo é própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis postos à disposição do contribuinte” (RE 293.536, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17-5-2002). No mesmo sentido, RE 245.539/RJ-2000 e RE 361.437/MG-2002.

Por fim, no caso apresentado é inconstitucional a instituição por lei municipal da instituição de taxa de limpeza urbana que visa à prestação de serviços de capinação de vias e logradouros públicos, limpeza de praias e outros, que se caracterizam por sua indivisibilidade e não especificidade.

RESPOSTA À QUESTÃO 34

A inelegibilidade é uma restrição à capacidade eleitoral passiva, ou seja, o ordenamento jurídico restringe que certas pessoas se candidatem em virtude de determinadas situações. Os casos estão previstos nos §§ 4.º ao 7.º do art. 14 da CF/88.

O caso apresentado é conhecido por inelegibilidade reflexa, sendo

disciplinado no § 7.º do art. 14 da CF/88. Desse modo, são inelegíveis no território da circunscrição (e não de jurisdição como prevê a CF/88 no art. 14, § 7.º) do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins (sogra, cunhado), até o 2.º grau ou por adoção, dos cargos do Poder Executivo ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição. O cônjuge e parentes até 2.º grau, consanguíneos ou afins de Governador não poderão se candidatar a qualquer cargo eletivo no Estado (Vereador, Prefeito, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador e Governador do mesmo Estado). Cumpre observar que a Constituição permite que concorram à reeleição o cônjuge, parente ou afim que já possuir mandato eletivo.

A inelegibilidade reflexa alcança a pessoa que vive maritalmente com o chefe do Poder Executivo, ou mesmo com seu irmão (afim de segundo grau). Trata-se de ampliar o conceito de entidade familiar, nos termos do § 3.º do art. 226 da CF/88, que assim estabelece.

Nesse sentido, há manifestação do TSE (Consulta 12.626/DF, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 12-6-1992; Consulta 949/DF, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10-10-2003).

Sobre o tema, o TSE decidiu: "O cônjuge e os parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau, são elegíveis no território de jurisdição do titular, desde que este não esteja no exercício de mandato fruto de reeleição" (Consulta 990/DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 5-7-2004). O STF ratificou tal posicionamento no julgamento do RE 344.882/BA.

Em breve síntese, como Pedro de Tal já havia cumprido dois mandatos consecutivos de Governador de Estado (reeleito), não é possível admitir a candidatura da referida senhora, que vive maritalmente há dez anos com o irmão dele, pois não está de acordo com o que estabelece a Constituição e as jurisprudências do TSE e do STF.

RESPOSTA À QUESTÃO 35

O controle de constitucionalidade pode ser realizado pelo Poder Judiciário, ao decidir um caso concreto ou ao julgar as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Uma das espécies é a ação direta de inconstitucionalidade genérica (ADIn/ADIn Genérica) que tem por objetivo banir do ordenamento jurídico a lei ou o ato normativo estadual ou federal em tese atingidos pelo vício da inconstitucionalidade (art. 102, I, a, da CF/88).

São legitimadas para propor tal ação as pessoas elencadas no art. 103, I a IX, da CF/88 e no art. 2.º da Lei n. 9.868/99.

O foro competente é o Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, a, da CF/88).

Como se percebe, o partido político com representação no Congresso Nacional tem legitimidade para a propositura da ação, mesmo tendo apenas um deputado federal ou senador em sua bancada. Além disso, o objeto de controle por via de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) é uma norma em vigor (lei ou ato normativo). Desse modo, não se admite ADIn em face de projeto de lei.

Pode-se concluir que não houve vício constitucional quanto à legitimidade, pois se admite ADIn proposta por partido político com representação no Congresso Nacional (art. 103, VIII, da CF/88). Porém, não é cabível a ADIn para impugnar um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em fase de apreciação no âmbito das comissões da Casa (art. 102, I, a, da CF/88).

RESPOSTA À QUESTÃO 36

Nos termos do art. 102, I, a, da CF/88 seria possível a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), pois se trata de ato normativo estadual que concedia aumento de vencimentos a servidores públicos daquele Estado.

O decreto citado na pergunta possui as características da generalidade, impessoalidade e abstração, que mesmo tendo efeitos concretos autorizam o uso da ADIn tendo em vista a inconstitucionalidade formal pela espécie

normativa indevidamente utilizada. Sobre o tema deve-se observar o destaque de Gilmar Ferreira Mendes que assim aduz: “Devem ser considerados leis ou atos normativos estaduais, podendo ser objeto somente de ação direta de inconstitucionalidade (...) 4. decreto editado com força de lei;” (ADIn 460/DF, rel. Sepúlveda Pertence, DJ 10-5-1991, p. 5.929; ADIn 519/DF, rel. Moreira Alves, DJ 11-10-1991, p. 14.248) (Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.059).

No caso em questão, o correto seria o tema ser tratado por lei ordinária conforme estabelece o § 1.º, II, a, do art. 61 da CF/88.

Referida norma aplica-se ao chefe do Poder Executivo Federal e pelo princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional é de aplicação obrigatória aos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Portanto, a iniciativa do projeto de lei é do chefe do Poder Executivo respectivo.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado da Federação tem legitimidade ativa para ajuizar a ADIn, nos termos do art. 103, IV, da CF/88.

É importante destacar que a Mesa da Assembleia Legislativa é considerada autor especial ou interessado devendo demonstrar a pertinência temática para ajuizar a ADIn.

A eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal em ADIn é prevista no art. 102, § 2.º.

No mesmo sentido, é a previsão do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99.

Tais decisões, em regra, têm efeitos ex tunc, podendo haver a modulação temporal para ser dado efeito ex nunc se houver manifestação de dois terços dos Ministros e relevante interesse público (art. 27 da Lei n. 9.868/99).

RESPOSTA À QUESTÃO 37

A competência do Supremo Tribunal Federal é prevista no art. 102 da CF/88.

Conforme se vê, o entendimento do Município está incorreto, pois não há previsão constitucional para o caso em tela.

Normalmente, as ações de execução tramitam no juízo da ação ou nas Varas de Execução onde houver. Essa é a determinação do art. 475-P do CPC (art. 516 do CPC de 2015).

Sobre sociedade de economia mista devem ser lembradas as seguintes súmulas do Supremo Tribunal Federal: (Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista"; Súmula 517: "As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente").

Em suma: o Município agiu incorretamente, pois não há previsão constitucional para referida ação no Supremo Tribunal Federal e ações que envolvem sociedade de economia mista tramitam, em regra, na Justiça Comum.

RESPOSTA À QUESTÃO 38

Não foram atendidos todos os requisitos constitucionais para a criação de um novo Município. Tais requisitos estão previstos no § 4.º do art. 18 da CF/88, que assim estabelece: "(...) § 4.º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei".

Teoricamente, o caminho a seguir seria: 1) lei complementar federal estabelecendo o prazo para criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios; 2) lei ordinária (comum) federal

estabelecendo os requisitos genéricos exigidos, bem como a apresentação e publicação dos Estudos de Viabilidade Municipal; 3) consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos; 4) lei ordinária estadual criando o Município.

No caso, existe a adoção de espécie normativa incompatível, ou seja, foi usado um decreto legislativo, quando o correto seria lei ordinária estadual. Deveria ter sido feita uma consulta prévia e não consulta posterior.

Sobre o tema deve-se lembrar que o STF manifestou-se sobre a necessidade da elaboração da lei complementar federal nas ADIns 3.682/MT, 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 – Informativos do STF 466 e 474.

RESPOSTA À QUESTÃO 39

- a) Sim, pode o deputado afastar-se do cargo para assumir uma secretaria da prefeitura da capital de seu Estado, conforme prevê o art. 56, I, da CF/88: “Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária; (...)”.
- b) Sim, a Constituição Federal prevê a convocação e a providência a ser adotada em face da falta de suplente no art. 56, §§ 1.º e 2.º: “(...) § 1.º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. § 2.º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato”.

Vê-se que se não houver suplente, a Constituição Federal prevê duas soluções, dependendo do prazo para o término do mandato: a) se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato haverá nova eleição para o preenchimento da vaga; e b) a contrário senso, se faltarem menos de 15 meses, a vaga não será preenchida.

Na situação hipotética apresentada faltam menos de 15 meses para o

término do mandato, portanto, a vaga não será preenchida.

RESPOSTA À QUESTÃO 40

- Quanto à elegibilidade e os direitos políticos do militar, a matéria é tratada no art. 14, § 8.º, CF/88.

Assim, na situação hipotética apresentada, o militar deverá ser mantido na condição de agregado, ou seja, afastado temporariamente, pois conta com mais de dez anos de serviço. Nesse sentido, já decidiu o TSE (Resolução n. 17.845 e Acórdão 11.314/90).

Portanto, pode o policial militar ser candidato a vereador sem se afastar definitivamente da corporação.

- Não está correto o entendimento segundo o qual a vedação de filiação partidária, enquanto em serviço ativo, não se estende aos militares dos Estados.
- Sim, está correta a orientação no sentido de que o registro da candidatura apresentada pelo partido, suprirá a falta de filiação partidária prévia. É esse o entendimento do TSE para solucionar o aparente conflito das disposições constitucionais do art. 14, § 3.º, V, e o § 8.º: “A filiação partidária contida no art. 14, § 3.º, V, CF/88 não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de registro de candidatura após prévia escolha em convenção partidária (Res. TSE n. 21.608/2004, art. 14, § 1.º)” (TSE, Consulta n. 1.014/DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 5-7-2004).
- Sim, poderá o militar que contar com mais de dez anos de serviço, se não for eleito, retornar aos quadros da Polícia Militar, nos termos do art. 14, § 8.º, II, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 41

A súmula vinculante está prevista no art. 103-A da CF/88, introduzido no texto constitucional pela Emenda Constitucional n. 45/2004.

Referido artigo foi regulamentado pela Lei n. 11.417/2006.

A legitimidade do Defensor Público Geral da União para propor a edição, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante está prevista no inciso VI do art. 3.º da Lei n. 11.417/2006.

A lei prevê no § 2.º do citado art. 3.º, que o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão.

Quanto ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 3.º, IV, é um dos legitimados para propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula e ainda, nos termos do § 2.º do art. 2.º da Lei n. 11.417/2006, nas propostas que não houver formulado deverá se manifestar previamente.

O quórum para aprovação está previsto no § 3.º do art. 2.º da lei: dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária.

Dessa forma e considerando a situação hipotética apresentada está correto o procedimento adotado para a elaboração da súmula vinculante.

RESPOSTA À QUESTÃO 42

O art. 184 da CF/88 estabelece a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária do imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Somente a terra nua e as benfeitorias voluptuárias é que podem ser indenizadas por títulos da dívida agrária, as benfeitorias úteis e as necessárias devem ser indenizadas em dinheiro. A desapropriação para fins de reforma agrária é de competência privativa da União e somente incide sobre imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social (art. 186 da CF/88).

Os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária estão regulamentados na Lei n. 8.629/93.

O procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária é sumário e segue o estabelecido na Lei Complementar n. 76/93: a desapropriação deve ser proposta em dois anos da publicação do decreto expropriatório (art. 3.º); a petição inicial deve conter, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, a oferta do preço e os documentos do art. 5.º; em 48 horas, o juiz mandará imitar o autor na posse do imóvel, determinará a citação do expropriando para contestar e indicar assistente técnico; a contestação somente pode discutir o preço ou defeitos formais do processo, vedada a apreciação quanto ao interesse social (art. 9.º); a prova pericial, se necessária, será realizada em 60 dias e não havendo acordo sobre o preço, será designada audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz proferir sentença na própria audiência ou nos trinta dias subsequentes (art. 12).

O mandado de segurança seria cabível no caso apresentado para proteger direito líquido e certo do proprietário do bem no caso de desobediência ao previsto na legislação sobre o tema. Em julgado do Supremo Tribunal Federal, MS 23.032, se discutiu a necessidade de notificação regular do proprietário do bem sobre a vistoria a ser realizada pelo INCRA.

No enunciado proposto e levando-se em conta o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

- cabimento do mandado de segurança: em tese seria possível, desde que não se pretendesse discutir índice de produtividade do imóvel;
- ato atacado: seria o decreto expropriatório;
- competência do órgão julgador: Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, d, da CF/88);
- legitimidade ativa: proprietários do imóvel;
- legitimidade passiva: Presidente da República.

RESPOSTA À QUESTÃO 43

Na Constituição Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental está prevista no § 1.º do art. 102 e foi regulamentada pela Lei n. 9.882/99.

Tem por objetivo: evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público (art. 1.º, caput, da Lei n. 9.882/99). Caberá também quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1.º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99).

O art. 2.º da Lei n. 9.882/99 estabelece que podem propor tal ação os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Ressalte-se que os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade estão previstos na Constituição no art. 103.

Dessa forma, por ausência de previsão legal a associação dos moradores de determinado Município não tem legitimidade ativa para propor a ADPF.

Como segundo motivo para o arquivamento há a previsão da subsidiariedade da ADPF determinada no art. 4.º da Lei n. 9.882/99. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 100-MC (rel. Min. Celso de Melo, decisão monocrática, j. 15-12-2008, DJe 18-12-2008).

Temos, assim, duas razões para o não conhecimento da referida ADPF: a ausência de legitimidade e o princípio da subsidiariedade.

RESPOSTA À QUESTÃO 44

A CF/88 estabelece no art. 5.º, LXVIII que se concederá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

O tema do enunciado proposto é a competência para julgar o habeas corpus impetrado em face de Turma Recursal Estadual e, sobre tal competência houve importante mudança de orientação no STF: "Ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal e Competência. O Tribunal, por maioria, mantendo a liminar deferida, declinou da sua competência para o Tribunal

de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que julgue habeas corpus impetrado contra ato da Turma Recursal do Juizado Criminal da Comarca de Araçatuba – SP em que se pretende o trancamento de ação penal movida contra delegado de polícia acusado da prática do crime de prevaricação – vide Informativo 413. Entendeu-se que, em razão de competir aos tribunais de justiça o processo e julgamento dos juízes estaduais nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (CF/88, art. 96, III), a eles deve caber o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal. Asseverou-se que, em reforço a esse entendimento, tem-se que a competência originária e recursal do STF está prevista na própria Constituição, inexistindo preceito que delas trate que leve à conclusão de competir ao Supremo a apreciação de habeas ajuizados contra atos de Turmas Recursais Criminais. Considerou-se que a Emenda Constitucional n. 22/99 explicitou, relativamente à alínea i do inciso I do art. 102 da CF/88, que cumpre ao Supremo julgar os habeas corpus quando o coator for tribunal superior, constituindo paradoxo admitir-se também sua competência quando se tratar de ato de turma recursal criminal, cujos integrantes sequer compõem tribunal” (HC 86.834/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 23-8-2006).

Deve-se observar que com a mudança de orientação do STF deixou de ser aplicada a Súmula 690 que estabelece: “Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais Criminais”.

A competência dos Tribunais de Justiça está prevista na CF/88 no art. 96.

Dessa forma, a medida judicial mais adequada para que Paulo atinja o objetivo pretendido é o habeas corpus que deverá ser impetrado no Tribunal de Justiça do Estado Z que é o órgão do Poder Judiciário competente para julgá-lo.

RESPOSTA À QUESTÃO 45

O orçamento pode ser conceituado como ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em detalhes, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins, adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em leis. É um documento programático, pois estabelece os objetivos do Estado em um determinado lapso de tempo. É lei, pois deve ser aprovado pelo Poder Legislativo. É de cumprimento obrigatório pelo ente público.

O art. 165 da CF/88 estabelece que três leis compõem o orçamento: I – o plano plurianual (PPA): é aprovado a cada 4 anos e estabelece um planejamento macro das atividades governamentais. No PPA: objetivos, diretrizes e metas da Administração Federal para despesas de capital e de duração continuada (art. 165, § 1.º, da CF/88) e os investimentos superiores a 1 ano (art. 167, § 1.º, CF/88); II – as diretrizes orçamentárias (LDO): estabelece as metas e prioridades da Administração para o período de 1 ano e as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual. No art. 165, § 2.º, da CF/88 e no art. 4.º, I, §§ 1.º a 3.º, da Lei de Responsabilidade Fiscal estão previstos os requisitos da LDO; III – orçamentos anuais (LOA): estabelece efetivamente as receitas e despesas. O § 5.º do art. 165 da CF/88 estabelece que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. Os requisitos da lei orçamentária anual estão previstos no art. 165, § 6.º, da CF/88 e no art. 5.º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No enunciado proposto o Presidente da República encaminha projeto de lei ordinária para alterar a lei orçamentária do ano de 2009, aumentando a destinação de recursos públicos em determinado projeto. Um deputado federal, por considerar insuficientes os recursos previstos no projeto original, pode apresentar emenda a esse projeto de lei, visando à ampliação dos referidos recursos. O art. 166 da CF/88 estabelece o

regramento da situação.

Assim, há possibilidade de emenda ao projeto de lei que altera a Lei Orçamentária, conforme previsão do art. 166 da CF/88.

Referidas emendas, porém, devem respeitar os limites estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 166 da CF/88, quais sejam: devem ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e devem indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

RESPOSTA À QUESTÃO 46

A posição mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a situação apresentada é pela ilegalidade da ordem de prisão civil do depositário infiel, prevalecendo a tese da supralegalidade (norma acima das leis, mas abaixo da Constituição) do Pacto de São José da Costa Rica, conforme foi decidido no RE 466.343, rel. Min. Cezar Peluso, j. 3-12-2008.

Dessa forma a posição majoritária mais recente do Supremo Tribunal Federal é pela ilegalidade da ordem de prisão do depositário infiel, e com fundamento nessa posição, o habeas corpus deve ser concedido em favor de João. Saliente-se a existência da Súmula Vinculante 25, que determina que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Tal súmula teve como precedente o RE 466.343 cujo principal fundamento foi a limitação da prisão civil, que só seria admitida em caso de obrigação alimentar (art. 7.º, item 7 do Decreto n. 678/92). Se houver descumprimento, é cabível reclamação no Supremo Tribunal Federal.

RESPOSTA À QUESTÃO 47

Em face da situação hipotética apresentada a medida judicial mais apropriada para impugnar a decisão do Tribunal de Justiça é a Reclamação que tem previsão no art. 103-A, § 3.º, da CF/88.

O referido artigo foi regulamentado pela Lei n. 11.417/2006 que determina em seu art. 7.º, caput: "Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação."

O tema apresentado no enunciado da questão encontra-se sumulado na Súmula Vinculante 5, de 16-5-2008, que assim estabelece: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição".

Desse modo, o Tribunal de Justiça ao acolher a argumentação e conceder a Pedro a segurança sob o argumento de que a presença obrigatória do advogado seria essencial para a garantia da ampla defesa contrariou o enunciado da Súmula Vinculante 5, dessa forma é cabível a reclamação que deve ser proposta no Supremo Tribunal Federal (art. 103-A, § 3.º, CF/88).

RESPOSTA À QUESTÃO 48

O mandado de segurança coletivo está previsto no art. 5.º, LXX, da CF/88, que assim estabelece: "art. 5.º (...) LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados".

Os requisitos para a impetração do mandado de segurança coletivo são os mesmos do mandado de segurança individual, conforme previsto no art. 5.º, LXIX, da CF/88: "art. 5.º (...) LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Não cabe mandado de segurança coletivo, pois se trata de direitos

individuais disponíveis em relação jurídica tributária entre o citado Município e os respectivos contribuintes do IPTU.

RESPOSTA À QUESTÃO 49

A Constituição Federal estabelece no art. 5.º, LXVIII, que se concederá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Na situação hipotética apresentada, caso queira ingressar com alguma medida judicial, João deverá impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado.

Sobre a competência para julgar o habeas corpus impetrado em face de Turma Recursal Estadual houve importante mudança de orientação no Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 86.834/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 23-8-2006: "(...) Entendeu que a competência do Supremo está prevista de forma exaustiva (CF/88, art. 102, I), e que, ante a Emenda Constitucional n. 22/99, cabe a ele processar e julgar, originariamente, o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam diretamente sujeitos a sua jurisdição, o que não ocorre no caso".

A competência dos Tribunais de Justiça está prevista na Constituição Federal no art. 96.

Dessa forma, a medida judicial mais adequada para que João atinja o objetivo pretendido é o habeas corpus, que deverá ser impetrado no Tribunal de Justiça do Estado que é o órgão do Poder Judiciário competente para julgá-lo.

RESPOSTA À QUESTÃO 50

A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão nomeada por uma Câmara, composta por membros desta e que agem em seu nome para

realizar uma investigação sobre determinado objeto. Esse objeto pode ser um fato ou um conjunto de fatos alusivos a acontecimentos políticos, abusos ou ilegalidades da Administração, questões financeiras, agrícolas, industriais, entre outros, desde que atinentes à boa atividade do Estado.

São requisitos constitucionais de uma CPI na esfera federal: requerimento de 1/3 dos membros da respectiva Casa, para investigar fato determinado e por prazo certo, com poderes próprios de autoridades judiciais e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público que promoverá a responsabilidade civil e criminal dos infratores (art. 58, § 3.º, da CF/88).

O instrumento processual adequado para evitar a prisão em flagrante é o habeas corpus preventivo (art. 5.º, LXVIII, da CF/88), pois a CPI tem poderes investigativos e poderia determinar a prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho. A fundamentação de mérito do referido habeas corpus é o direito ao silêncio (art. 5.º, LXIII, da CF/88) para não produzir prova contra si mesmo.

Desse modo, na situação hipotética apresentada, o instrumento processual adequado para evitar a prisão em flagrante de Paulo seria o habeas corpus preventivo (art. 5.º, LXVIII, da CF/88), e a fundamentação de mérito é o direito ao silêncio (art. 5.º, LXIII, da CF/88) para não produzir prova contra si mesmo.

RESPOSTA À QUESTÃO 51

No primeiro caso, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) não pode obter as informações em razão de os processos em que é determinada a quebra do sigilo telefônico tramitarem sob segredo de justiça, como foi afirmado no enunciado da questão. O segredo de justiça implica em restrição à publicidade dos atos judiciais. Desse modo, em atenção ao princípio da separação dos poderes, bem como ao direito à intimidade, e em virtude de a CPI ter poderes de investigação próprios das autoridades

judiciais, não pode tal CPI revogar, suspender ou reformar decisão judicial que determina o segredo de justiça em determinado processo. Nem o próprio Supremo Tribunal Federal pode invadir a competência de outro juízo e determinar a quebra do sigilo judicial. Nesse sentido, a liminar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no MS 27.483, noticiada no Informativo STF 515. Os fundamentos constitucionais para se vedar o encaminhamento das informações são: art. 5.º, X e LX, e art. 58, § 3.º.

No segundo caso apresentado, o Supremo Tribunal Federal pode encaminhar as cópias do inquérito relativo à investigação criminal de Deputado Federal que se sujeita a processo administrativo disciplinar perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, pois os elementos informativos de uma investigação criminal ou as provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente autorizada por juiz competente, como no caso, podem ser compartilhados para fins de instruir procedimento administrativo disciplinar, em especial, no caso de uma CPI, desde que os áudios sejam isolados e haja o compromisso de se manter o sigilo das informações. É conveniente lembrar que as CPIs, seja federal, estadual ou distrital, podem determinar a quebra de sigilo telefônico (ver os extratos das ligações feitas) diretamente aos órgãos desde que o faça fundamentadamente. A interceptação telefônica só pode ser determinada por autorização judicial em processo ou investigação criminal. Sobre o tema o STF já se manifestou no julgamento de questão de Ordem no Inquérito 2.725, noticiado no Informativo do STF 512. Os fundamentos constitucionais: art. 5.º, XII, e art. 55, § 2.º, da CF/88 (juízo de proporcionalidade).

RESPOSTA À QUESTÃO 52

Os Tribunais de Justiça podem julgar ações diretas de inconstitucionalidade

em face da Constituição Estadual. Nesse caso, o parâmetro do controle de constitucionalidade será a Constituição Estadual. A autorização para tanto está no art. 125, § 2.º, da CF/88.

Na questão apresentada, tendo conhecimento de que o art. X da Constituição Estadual é mera repetição do art. 37, II, da CF/88, caberia, em tese, o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, III, a e c, pois houve violação ou não aplicação do disposto no art. 37, II, da CF/88.

Não é cabível a reclamação, pois o enunciado esclarece que a decisão do Tribunal de Justiça não afrontou a autoridade de nenhuma decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, conforme concluído nas decisões proferidas em sede de reclamação ao Supremo Tribunal Federal acima listadas, o Tribunal local não usurpa a competência do Egrégio Tribunal ao analisar ação direta de inconstitucionalidade que tem como parâmetro artigo da Constituição Estadual que é mera repetição da Constituição Federal.

RESPOSTA À QUESTÃO 53

O Ministério Público estadual tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de garantir o fornecimento de medicamento pelo Estado a pessoa idosa que necessitava urgentemente de remédios indispensáveis à preservação de sua vida. O Ministério Público tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88). Cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF/88). Além disso, é função institucional do Parquet zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da CF/88).

No caso, o Ministério Público é parte legítima, pois o direito que busca tutelar é o direito à saúde, que é um direito de todos e um dever do Estado previsto no art. 196 da CF/88.

No mesmo sentido, o Estatuto do Idoso determina que o Ministério Público atue como substituto processual do idoso quando este estiver em situação de risco e zele pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais asseguradas ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (art. 74, III e VII, da Lei n. 10.741/2003).

Cumprido destacar que o art. 230 da CF/88 é expresso ao destacar que o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar e lhes garantindo o direito à vida.

RESPOSTA À QUESTÃO 54

O confisco da propriedade usada para o cultivo de plantas psicotrópicas está previsto no art. 243 da CF/88, que assim estabelece:

“As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5.º” (Redação dada pela EC n. 81/2014).

Desse modo, o raciocínio de João está errado. Ele perderá toda a propriedade e não uma parte dela.

A Polícia Federal estaria atuando de acordo com suas atribuições, nos termos do art. 144, § 1.º, II, da CF/88:

“A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (...) II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência”.

Desse modo, também houve erro no entendimento de João, pois a Polícia Federal tem competência para investigar tal delito.

RESPOSTA À QUESTÃO 55

Verifica-se na questão uma omissão parcial, hipótese que enseja a propositura de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.

A inconstitucionalidade pode ocorrer mediante ação ou omissão estatal. A inconstitucionalidade por ação está vinculada à elaboração de uma norma infraconstitucional ou ato normativo que contrarie a Constituição. Nesse caso, seria possível, por exemplo, a utilização de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica se existisse uma lei ou ato normativo federal ou estadual contrariando a Constituição Federal de 1988. No entanto, se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à efetivação de normas constitucionais de eficácia limitada incidirá em uma inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando nenhuma providência é adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. Na questão verifica-se essa última situação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

“A insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definido em importância que se revele incapaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como o sujeito concretizante do postulado constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração (CF/88, art. 7.º, IV), estará realizando, de modo imperfeito, o programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica” (ADIn 1.458-7/DF, j. 23-5-1996, rel. Min. Celso de Melo, DJ 20-9-1996).

RESPOSTA À QUESTÃO 56

A medida judicial mais adequada aos interesses de Jorge, brasileiro naturalizado desde 1999, será requerer o relaxamento da sua prisão administrativa perante o ministro relator do pedido de prisão (art. 85, § 1.º, da Lei n. 6.815/80) ou ingressar diretamente com habeas corpus perante o

Supremo Tribunal Federal. Essa é a previsão constitucional do art. 5.º, LXV e LXVIII, a seguir transcritos:

“LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;”

“LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”

O argumento de mérito a ser utilizado também tem previsão constitucional no art. 5.º, LI, o qual estabelece que não se pode extraditar brasileiro naturalizado por crime comum praticado após a naturalização.

Não seria óbice para uma eventual extradição o fato de o pedido ter sido formulado por país que não tem tratado de extradição com o Brasil. Nessa situação, ou seja, quando não houver tratado, o pedido deve ser instruído com os documentos previstos na Lei n. 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e ser solicitado com base na promessa de reciprocidade de tratamento para casos análogos, respeitando os preceitos constitucionais sobre o tema.

RESPOSTA À QUESTÃO 57

O art. 133 da CF/88, assim dispõe:

“O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”

O referido dispositivo constitucional consagra a imunidade material do advogado, assegurando-lhe a inviolabilidade por seus atos e manifestações, desde que esteja no exercício da profissão e nos limites da lei, pois tal garantia não é absoluta. Analisando-se o caso concreto, é importante frisar que a imunidade do advogado não alcança as relações do profissional com o seu próprio cliente, quando a ofensa for gratuita, desvinculada do exercício profissional e não guardar pertinência com a discussão da causa.

Com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal considera que a

prática, por parte de advogado, de atos, gestos e palavras ofensivos que ensejam agressão física ou moral, insulto pessoal e humilhação pública, não estão cobertos pela inviolabilidade do art. 133 da CF/88 (STF, AO 933, rel. Min. Carlos Britto, DJ 6-2-2004; STF, AO 1.300, rel. Min. Carlos Britto, DJ 7-4-2006). Como observou o Superior Tribunal de Justiça, a inviolabilidade do advogado não configura imunidade penal ampla e absoluta nos crimes contra a honra e até no desacato, imunidade que não é conferida ao cidadão brasileiro, às partes litigantes nem mesmo aos juízes e promotores.

RESPOSTA À QUESTÃO 58

O decreto do governador não está de acordo com a previsão constitucional do Título V, Capítulo III, que trata da Segurança Pública.

Dispõe o art. 144, caput, IV e V, e §§ 4.º e 5.º, da CF/88, a atribuição às polícias civis, com exclusividade, a incumbência de exercer as funções de polícia judiciária.

Ademais, indicar integrantes da Polícia Militar para desempenharem as funções de delegado de polícia de carreira, caracterizaria desvio de função. Assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal na ADIn 3.614, rel. p/ o Ac. Min. Carmen Lúcia, j. 20-9-2007, DJ 23-11-2007.

No que diz respeito à possibilidade de o Estado firmar convênio com os Municípios que constituíram guardas municipais, de modo a atribuir a essas guardas a responsabilidade de realizar o policiamento ostensivo e preventivo em seus respectivos Municípios, em igualdade de condições com os policiais militares, também, não está de acordo com a Constituição e o disposto no art. 144, §§ 5.º e 8.º, pois cabe exclusivamente à Polícia Militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (§ 5.º) e às guardas municipais são destinadas a proteção dos bens, serviços e instalações do Município, o que corresponde ao policiamento administrativo da cidade, visando à proteção do patrimônio público (§ 8.º).

Desse modo, o decreto do Governador é inconstitucional.

RESPOSTA À QUESTÃO 59

A Constituição Federal prevê no art. 71 que o Tribunal de Contas é órgão de auxílio do Poder Legislativo no exercício do denominado controle externo, cabendo-lhe a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, no que diz respeito à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. O Tribunal de Contas é autônomo, não tendo qualquer vínculo de subordinação. É órgão auxiliar do Legislativo e não integra o Poder Judiciário.

O Tribunal de Contas emite pareceres técnicos e limitados aos aspectos de fiscalização contábil, orçamentária e fiscal. Desse modo, suas decisões são administrativas e não vinculam o Poder Judiciário ou o Ministério Público.

Ressalte-se, assim, que a atuação do Tribunal de Contas não é jurisdicional e, portanto não afasta o que preceitua o art. 5.º, XXXV, da CF/88, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça poderá ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário.

Não bastassem, tais considerações, para afastar os argumentos do agente público, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei n. 8.429/92, prevê expressamente no art. 21, II, que a aplicação das sanções previstas na referida lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas.

Desse modo é plenamente possível e tem amparo legal o fato de o Ministério Público ajuizar ação de improbidade administrativa contra agente público que se apropriou indevidamente de valores destinados a determinado programa social, mesmo que o referido agente tenha as contas aprovadas junto ao Tribunal de Contas.

RESPOSTA À QUESTÃO 60

A Constituição Federal prevê no art. 5.º, XI, que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Há, portanto, proteção constitucional ao domicílio e, desse modo, a denominada invasão domiciliar somente pode ser considerada legítima se for praticada em observância aos limites estabelecidos pelo legislador constituinte originário.

De acordo com a previsão constitucional, a invasão domiciliar, durante o dia, se sujeita à cláusula de reserva jurisdicional, pois cabe exclusivamente ao Poder Judiciário a competência para autorizar a prática do referido ato.

Desse modo, no caso concreto analisado, a invasão domiciliar mediante ordem da autoridade administrativa, com a justificativa da autoexecutoriedade administrativa, não está de acordo com o comando constitucional. A ordem judicial é imprescindível para efeito da medida de busca e apreensão domiciliar, como forma de concretização da garantia constitucional relativa à inviolabilidade do domicílio.

RESPOSTA À QUESTÃO 61

A emenda ao regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Federação seria materialmente inconstitucional, pois os requisitos exigidos para a criação das comissões parlamentares de inquérito federais previstos no § 3.º do art. 58 da CF/88 vigente são de observância obrigatória por todos os entes federativos.

Trata-se da aplicação do princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional.

O § 3.º do art. 58 da CF/88 estabelece que:

“As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de

fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.

O requerimento de um terço de seus membros garante o exercício de fiscalização e investigação por parte da minoria, normalmente, caracterizada pela oposição.

Como se trata de norma geral e abstrata, a medida pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade.

RESPOSTA À QUESTÃO 62

O deputado estadual tem direito líquido e certo de participar do devido processo legislativo nos termos dos padrões constitucionais exigidos. Desse modo, poderia impetrar mandado de segurança.

O mandado de segurança está previsto no inciso LXIX do art. 5.º da CF/88, onde se lê:

“LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

O § 2.º do art. 60 da CF/88 vigente exige para a aprovação de uma emenda constitucional que a proposta seja discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

A imposição de tal sistema de aprovação é uma hipótese de cláusula pétrea implícita, não se admitindo uma proposta de emenda constitucional para alterá-lo. Além disso, a exigência de quórum de quatro quintos acabaria por restringir a possibilidade de mudança da Constituição.

Tal requisito de aprovação é de repetição obrigatória pelas demais normas fundamentais dos entes federativos. Trata-se da aplicação do princípio da

simetria federativa ou do paralelismo constitucional.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assim entendeu:

“Processo de reforma da Constituição estadual – Necessária observância dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal (art. 60, §§ 1.º a 5.º) – Impossibilidade constitucional de o Estado-membro, em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma da Constituição estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 (quatro quintos) da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa – Exigência que virtualmente esteriliza o exercício da função reformadora pelo Poder Legislativo local – A questão da autonomia dos Estados-membros (CF/88, art. 25) – Subordinação jurídica do poder constituinte decorrente as limitações que o órgão investido de funções constituintes primárias ou originárias estabeleceu no texto da Constituição da República (...)” (ADIn 486, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, j. 3-4-1997, DJ 10-11-2006).

RESPOSTA À QUESTÃO 63

O Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, é bastante restritivo quanto à possibilidade de entidades de classe ajuizarem ações diretas de inconstitucionalidade. Elas só têm legitimidade se for observada a relação de pertinência temática entre o interesse específico da classe, para cuja defesa essas entidades foram constituídas, e o ato normativo alegado como inconstitucional.

Segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não configuraria entidade de classe de âmbito nacional, para os efeitos do art. 103, IX, da CF/88, organização formada por associados pertencentes a categorias diversas, como no caso em análise. Assim, o Egrégio Tribunal decidiu: “Não se configuram como entidades de classe aquelas instituições que são integradas por membros vinculados a extratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos, individualmente considerados, revelam-se contrastantes” (ADIn 108/DF, rel. Min. Celso de

Mello, DJ de 5-6-1992, p. 8.426).

Quanto à tramitação paralela de ações diretas no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Justiça local, interpostas contra a mesma lei estadual, não se admite que isso ocorra, devendo-se, em tal circunstância, suspender o curso da ação direta ajuizada na Corte estadual até o julgamento final da ação direta proposta no Supremo Tribunal Federal.

Esse entendimento decorre da lógica do sistema: o paradigma da primeira hipótese será a Carta da República, e, da segunda, a Carta estadual. A decisão que haverá de prevalecer, logicamente, será a do Supremo Tribunal Federal, ficando o processo no Tribunal de Justiça sobrestado até que o Supremo julgue em definitivo o mérito da controvérsia. Nesse sentido, existem os seguintes precedentes: STF, ADIn 1.423-4-MC/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJU 22-2-1996; STF, Recl. 386-8/SC, rel. Min. Octavio Gallotti; STF, Recl. 1.341-6/SP, rel. Min. Francisco Rezek; Pleno; STF, Recl. 425-2/RJ, rel. Min. Neri da Silveira, j. 27-5-1993, DJ, 1, 22-10-1993.

Relativamente à prescrição e decadência, o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade não se sujeita à observância de qualquer prazo prescricional ou decadencial, pois os atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso de tempo (STF, Pleno, ADIn 1.247-MC/PA, j. 17-8-1995, rel. Min. Celso de Mello, DJ, 1, 8-9-1995, p. 28.354). Sobre o tema, pode-se aplicar a primeira parte da Súmula 360 do STF: “Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade (...)”.

RESPOSTA À QUESTÃO 64

Na hipótese, os dispositivos constitucionais aprovados pela Assembleia Legislativa na Constituição estadual contrariam o princípio da separação de poderes (art. 60, § 4.º, III, da CF/88) e os ditames constitucionais adotados, no âmbito federal, sobre o tema.

Desse modo, não cabe, por não haver paralelo com o modelo federal da tripartição de poderes, subordinar a eficácia de convênios celebrados por

secretários de Estado, ou de contratos por estes firmados, à aprovação da Assembleia Legislativa, criando, assim, uma subordinação da ação do Poder Executivo ao Poder Legislativo. De igual modo, a Constituição Federal não exige autorização legislativa para que o Estado venha a contrair dívidas. O Poder Legislativo estaria realizando uma interferência indevida na administração do Estado, que é uma função típica do Poder Executivo.

Pelo princípio do paralelismo constitucional ou da simetria federativa, o constituinte estadual está obrigado a seguir fielmente as opções de organização e de relacionamento entre os poderes previstos na Constituição Federal.

O Governador poderá se utilizar de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ser ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, para tornar inválidas as normas constitucionais estabelecidas. Sua legitimidade ativa está prevista no art. 103, V, da CF/88.

Não se deve esquecer que o governador deverá demonstrar a pertinência temática na petição inicial, ou seja, deverá justificar a propositura da ação.

RESPOSTA À QUESTÃO 65

A medida judicial para Pedro ter acesso à identificação e aos dados do(s) denunciante(s) é o mandado de segurança, com fundamento no art. 5.º, LXIX, da CF/88, que determina:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O impetrante tem o direito líquido e certo de obter informações acerca da identidade da pessoa do denunciante, como meio para postular a defesa de sua intimidade, vida privada, honra, nome e imagem.

A Constituição Federal é expressa ao estabelecer no inciso X do art. 5.º que:

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese, como se pretende obter dados inerentes a terceiro (o denunciante), o mandado de segurança configura o remédio apto a impugnar a ilegalidade e o abuso de poder.

Em tais circunstâncias, quando se envolve a proteção à honra e à imagem, a defesa precisa ser promovida de imediato, antes que as afirmações difamatórias possam ser difundidas, em prejuízo irreparável para o impetrante.

Nesse sentido, restam demonstradas a liquidez e a certeza do direito do impetrante de obter conhecimento quanto à identificação do(s) denunciante(s), como forma de viabilizar a defesa de seu nome e de sua honra.

Não se revela cabível o habeas data na medida em que se pretende obter informações a respeito de terceiro, e não do próprio impetrante, sendo certo que a referida ação constitucional tem caráter personalíssimo. Assim, por meio de habeas data, somente podem ser pleiteadas informações relativas ao próprio impetrante, nunca de terceiros, conforme é previsto no inciso LXXII do art. 5.º da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 66

Antes da análise da constitucionalidade das espécies normativas, é necessário ressaltar as duas diferenças básicas entre lei complementar e a lei ordinária, quais sejam: quórum de aprovação e a reserva constitucional de matéria (especificidade de matéria). Há determinadas matérias, previstas expressamente no texto constitucional, como por exemplo, o art. 163, que estabelece que estas só podem ser reguladas por meio de lei complementar, exigido o quórum de aprovação de maioria absoluta (art. 69 da CF/88 – maioria do total dos membros). Por outro lado, a lei ordinária

pode ser aprovada por maioria simples (maioria dos votos dos presentes), presente à sessão a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, nos termos do art. 47 da CF/88. Ressalte-se o entendimento da doutrina, corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, de que não há hierarquia, mas sim hipótese de incidência diferenciada entre as citadas espécies normativas.

O atual Código Civil brasileiro foi instituído pela Lei Ordinária n. 10.406/2002 e como se trata de uma lei ordinária não há óbice que seja alterado por uma lei complementar. Desse modo, é constitucional o projeto de lei complementar, aprovado pelo Congresso Nacional, modificando artigos do Código Civil, e sancionado pelo Presidente da República, nos termos do art. 22, I, da CF/88. Importante, porém é ressaltar que teremos uma lei complementar com status de lei ordinária.

No art. 62, § 1.º, III, da CF/88, temos a determinação que não será objeto de medida provisória a matéria reservada a lei complementar, mas tal vedação não se aplica ao enunciado proposto, pois como já foi dito a matéria, objeto da lei sancionada, é a modificação de artigos do Código Civil (lei ordinária em sua origem) que, repise-se, não é reservada a lei complementar. Assim, temos igualmente constitucional a edição, pelo Presidente da República, de medida provisória modificando, novamente, os referidos artigos do Código Civil de 2002, com redação dada pela lei complementar, que no caso tem status de lei ordinária.

Desse modo, nos casos apresentados, ambas as espécies normativas são constitucionais.

RESPOSTA À QUESTÃO 67

A inconstitucionalidade parcial sem redução de texto é uma modalidade de declaração de inconstitucionalidade na qual há a declaração de inconstitucionalidade de uma determinada interpretação, sem afetar o texto da norma. Em outras palavras, para que haja esse tipo de

inconstitucionalidade é necessário que a norma legal possua mais de uma interpretação, de modo que declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, permaneça apenas a interpretação conforme a Constituição, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade não é a do texto da norma, mas de sua interpretação.

Tal declaração de inconstitucionalidade terá eficácia erga omnes (contra todos) e efeito vinculante, conforme está previsto no art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99: "A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal".

RESPOSTA À QUESTÃO 68

Quanto ao item I, sim, o Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por motivo diverso do pedido na inicial, pois há entendimento pacificado de que a Corte não está adstrita à causa de pedir sustentada pela parte autora. Assim, segundo a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal está vinculado ao pedido nas ações diretas de inconstitucionalidade, e não à causa de pedir. Poderá, desse modo, considerar a inconstitucionalidade da lei por motivos diversos daqueles apresentados pelo proponente da ação, tendo em vista que, em sede do controle de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta. Não fosse assim, uma ação direta de inconstitucionalidade mal redigida ou mal fundamentada poderia acarretar a improcedência da ação, com a declaração de constitucionalidade da norma.

Em relação à segunda pergunta que diz respeito ao pedido, este, a princípio, é limitado ao que foi questionado pelo proponente da ação, mas o Supremo Tribunal Federal admite julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente em relação a outros dispositivos não

questionados na ação, em caráter excepcional, em virtude da dependência dos dispositivos. É o que ocorre na denominada inconstitucionalidade por “arrastamento”, por “atração” ou “consequente”. Fenômeno que ocorre nos casos em que a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado implica necessariamente a inconstitucionalidade de outro não impugnado, isto é, o dispositivo que depender daquilo que foi declarado inconstitucional pelo órgão Supremo, será também inconstitucional.

RESPOSTA À QUESTÃO 69

O art. 103 da CF/88 estabelece o rol dos legitimados para propor a ação de inconstitucionalidade (ADI), não estabelecendo qualquer distinção entre eles. O partido político (art. 103, VIII) é legitimado universal e, desse modo, não precisa demonstrar a pertinência temática para ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Para que o partido político tenha configurado o requisito, previsto no art. 103, VIII, da CF/88, “com representação no Congresso Nacional”, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que basta a representação em uma das Casas do Congresso.

Quanto à modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade da lei (com ou sem modulação dos efeitos), a partir de argumentos que não foram enfrentados pelos ministros em 2005. E tal permissivo tem amparo na doutrina, uma vez que não admitir essa possibilidade resultaria no engessamento de posicionamento do Supremo, e desse modo, após ter declarado a constitucionalidade de uma lei, jamais poderia mudar seu entendimento.

Temos, então, que no caso proposto mesmo que o Supremo Tribunal Federal já tenha declarado constitucional a lei federal em momento anterior, a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo partido político, fundada em novos argumentos até então não enfrentados, poderá ser conhecida.

Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em regra, esse é retroativo (*ex tunc*), mas por motivo de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, os membros do Supremo Tribunal Federal, por maioria qualificada de 2/3 (oito ministros), podem restringir os efeitos da declaração, declarando a inconstitucionalidade com efeito não retroativo (*ex nunc*) ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou outro momento que venha a ser fixado, de acordo com o art. 27 da Lei n. 9.868/99.

Dessa forma, conclui-se que o Partido Político com um único representante do Congresso Nacional tem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, e que, também, é possível que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da lei federal e a modulação dos efeitos dessa decisão é totalmente plausível.

RESPOSTA À QUESTÃO 70

Primeiramente, cabe observar que o dispositivo da Constituição Estadual, ao limitar o direito de ingresso na carreira aos cidadãos naturais do respectivo Estado, padece de inconstitucionalidade material, pois viola o disposto no art. 37, II, da CF/88, que dispõe que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. Tal regra deve ser aplicada aos Estados-membros. Nesse sentido, é a previsão do art. 25, caput, da CF/88, “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”.

Igualmente, a lei estadual promulgada em 2009 pela Assembleia Legislativa daquele Estado viola a regra do concurso público, e neste caso duplamente, pois ofende a Constituição Federal e a Constituição do respectivo Estado.

Além disso, contraria também o art. 19, III, da CF/88, que veda a discriminação entre nacionais.

Desse modo, é plenamente possível ao Governador do Estado ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual e a sua legitimidade está expressa no enunciado proposto, bem como é possível ao Conselho Federal da OAB (art. 103, VII, da CF/88) propor uma Ação Direta de Inconstitucionalidade federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto a referida lei estadual.

E tal situação é possível, pois lei estadual pode ser objeto de ambas as ações no que diz respeito ao controle de constitucionalidade (arts. 102, I, a, e 125, § 2.º, da CF/88), bem como é possível que as duas ações, a de âmbito estadual e a de âmbito federal, sejam ajuizadas concomitantemente. No entanto, de acordo com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neste caso a ação estadual ficaria suspensa, aguardando a decisão do Egrégio Tribunal.

Por este mesmo raciocínio, poderia o Presidente da República (legitimidade universal: art. 103, I, da CF/88) ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal contra o dispositivo da Constituição estadual.

RESPOSTA À QUESTÃO 71

A norma inserta no art. 58, § 3.º, da CF/88, estabelece que as Comissões Parlamentares de Inquérito sejam criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Atendidos tais requisitos não há que se falar em outras exigências, pois o que se pretende resguardar é o direito da oposição de investigar e as prerrogativas da minoria parlamentar.

O referido art. 58 da CF/88 é norma de repetição obrigatória e, desse modo, deve estar nas respectivas Constituições Estaduais, respeitando-se o

princípio da simetria com a Constituição Federal.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa de determinado Estado-membro ao condicionar a criação de CPI à aprovação pelo Plenário da Casa Legislativa cria um requisito novo que afronta o texto da Constituição Federal e desse modo está maculado pelo vício de inconstitucionalidade.

O rol dos legitimados, para o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF, está no art. 103 da CF/88, que estabelece, em seu inciso VIII, o partido político com representação no Congresso Nacional. Desse modo, a legitimidade é do partido político com representação no Congresso Nacional (legitimado universal), que poderá ajuizar a Ação Direta Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, devidamente representado pelo seu Diretório Nacional.

RESPOSTA À QUESTÃO 72

A declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, ocorre no denominado controle de constitucionalidade difuso, aberto, indireto, pela via de exceção ou defesa, e é realizado por qualquer juiz ou Tribunal. O Supremo Tribunal Federal também realiza o controle difuso, nos termos do art. 102, I, d, i, l, q, r, II, III, da CF/88. Os efeitos subjetivos produzidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei em questão atingem apenas as partes litigantes, ou seja, são inter partes.

O art. 52, X, da CF/88, estabelece a competência privativa do Senado Federal de, mediante uma resolução, suspender a execução no todo ou em parte, ou seja, atribuir efeitos erga omnes, à decisão definitiva do STF que declarou a lei inconstitucional, incidenter tantum. Tal competência do Senado Federal é, porém, discricionária e política, não cabendo o seu controle jurisdicional, preservando-se, assim o princípio da separação dos poderes.

O exercício da competência prevista no art. 52, X, pelo Senado Federal, poderá ocorrer em se tratando de declaração de inconstitucionalidade, pelo

STF de modo incidental no controle difuso, de lei estadual, bem como de lei federal, distrital ou municipal.

RESPOSTA À QUESTÃO 73

No enunciado proposto, a Turma do determinado TRF estaria julgando em grau de recurso, um Mandado de Segurança impetrado por um contribuinte que se insurgiu contra a cobrança do tributo no mesmo ano em que fora instituído e, desse modo ao decidir que a nova alíquota só poderia ser cobrada no ano seguinte ao da sua majoração, a referida Turma decidiria pela inconstitucionalidade da lei federal (afronta ao art. 150, III, b, da CF/88). Como se trata de uma declaração de inconstitucionalidade é necessário que seja observado o previsto no art. 97 da CF/88 que estabelece a denominada cláusula de reserva de plenário.

Não se pode esquecer que a matéria já foi objeto de súmula vinculante, a saber, a de número 10 que assim estabelece: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Vemos, então, que a referida cláusula, bem como a Súmula Vinculante 10, determina que o questionamento acerca da constitucionalidade da lei seja decidido, pelo voto da maioria absoluta dos membros, do Pleno ou do órgão especial do Tribunal. Portanto, não é a Turma, mas sim o Pleno ou o órgão especial (se houver) do Tribunal que é o competente, no caso, para declarar inconstitucional a referida lei federal que aumentou a alíquota de determinado tributo, mas sem dispor expressamente que a nova alíquota só poderia ser cobrada no exercício financeiro seguinte.

O princípio que fundamenta a cláusula de reserva de plenário é o da presunção de constitucionalidade das leis.

RESPOSTA À QUESTÃO 74

A Ação Direta de Inconstitucionalidade tem o objetivo de retirar do ordenamento jurídico a lei ou ato normativo estadual ou federal atingidos pelo vício da inconstitucionalidade (art. 102, I, a, da CF/88).

A emenda constitucional é um ato normativo que tem por finalidade modificar o texto constitucional e como resulta do poder constituinte derivado deve respeitar os limites circunstanciais (art. 60, § 1.º, da CF/88), os limites materiais expressos (art. 60, § 4.º, da CF/88) e os limites materiais implícitos (art. 1.º, parágrafo único, e art. 60, §§ 2.º e 3.º, da CF/88), sob pena de haver uma incompatibilidade vertical, ou seja, uma inconstitucionalidade.

Assim, como as emendas constitucionais são atos legislativos poderão ser objeto de uma ADIn se houver o desrespeito dos limites impostos na Constituição Federal (inconstitucionalidade formal ou material).

No caso, a emenda em questão padece de inconstitucionalidade formal, pois no intervalo entre o primeiro e o segundo turno de votação da proposta (PEC) no Senado Federal, o Presidente da República havia decretado intervenção federal num determinado Estado da Federação (violou o art. 60, § 1.º, da CF/88) e de inconstitucionalidade material ao incluir os analfabetos como inalistáveis (violou art. 60, § 4.º, II, e o art. 14, § 1.º, II, a, ambos da CF/88).

RESPOSTA À QUESTÃO 75

A Ação Declaratória de Constitucionalidade é um das ações do controle concentrado e tem por objetivo definir a constitucionalidade da lei ou ato normativo federal (art. 102, I, a, da CF/88). Foi regulamentada pela Lei n. 9.868/99, tendo como pressuposto de admissibilidade a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória, devendo a prova da controvérsia acompanhar a petição inicial (art. 14, III e parágrafo único, da Lei n. 9.868/99). Desse modo, temos que a lei ou ato normativo federal está sendo impugnado em

processos concretos, tendo recebido, nas instâncias inferiores, a maioria de decisões desfavoráveis. A legitimidade ativa está prevista no art. 103 da CF/88. Assim, com relação somente à legitimidade, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, criado pela norma, poderia propor ADC, como legitimado especial demonstrando a pertinência temática, tendo em vista a previsão do inciso IX do art. 103 da CF/88, porém, como o enunciado diz expressamente que o debate se limitou aos jornais e revistas especializadas, não há o pressuposto de admissibilidade da existência de controvérsia judicial relevante sobre o ato normativo que seria objeto da ação declaratória.

Por outro lado, poderia, sim, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois é um dos legitimados para tanto, nos termos do art. 103, VII, da CF/88. E, como se trata de um legitimado universal ou neutro, não necessita demonstrar pertinência temática.

Assumindo que fosse cabível o ajuizamento da ADC, o efeito da decisão que a julgasse improcedente, no mérito, seria erga omnes e vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (art. 102, § 2.º, da CF/88 e arts. 24 e 28, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.868/99).

IV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 76

a) Sim, pode um juiz, no exame de um caso concreto (controle difuso), declarar a inconstitucionalidade da lei X, uma vez que o indeferimento da cautelar na ADIn não impede o julgamento dos casos concretos pelos demais magistrados. Acrescente-se que não houve o julgamento do mérito, como exige o texto constitucional no § 2.º do art. 102. Além disso, não há impedimento legal para tanto (arts. 10 a 12 da Lei n. 9.868/99).

Saliente-se que a medida cautelar nas ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade não possuem caráter ambivalente, assim o indeferimento de medida cautelar em ADIn não implica a declaração de constitucionalidade.

- b) Não, uma vez que ao deferir a cautelar na ADC os demais processos que envolvem a norma objeto de julgamento ficarão suspensos até o julgamento definitivo. Desse modo, um juiz não poderia, depois de deferida a cautelar em ADC, declarar a inconstitucionalidade da lei (art. 21 da Lei n. 9.868/99).

RESPOSTA À QUESTÃO 77

- a) Se a lei estadual é revogada a Ação Direta de Inconstitucionalidade será prejudicada, sendo extinta sem exame de mérito, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADIn 3.209).
- b) Se o Partido Político deixa de ter representação no Congresso Nacional o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade deverá prosseguir. Saliente-se que o STF, em sua jurisprudência inicial, considerava que a ADIn deveria ser extinta, sem exame de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa. Porém, no julgamento do Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática adotada na ADIn 2.618/PR, o STF reviu sua posição e atualmente entende que a perda superveniente de representação do Partido Político não repercute sobre o julgamento da ADIn. Entende-se que a aferição da legitimidade ativa do Partido Político deve ser realizada à época do ajuizamento da ADIn em razão da objetividade do processo e da indisponibilidade da ação.

RESPOSTA À QUESTÃO 78

- a) Não, não se encaminha ao Senado quando é caso de revogação. No caso, a lei é de 1999, posterior à Constituição de 1988, mas anterior à emenda

constitucional de 2000. De acordo com a jurisprudência do STF (ADIn 2), a incompatibilidade entre uma lei e uma norma constitucional posterior a ela implica a revogação da lei e não a sua inconstitucionalidade. Tratando-se de revogação e não de inconstitucionalidade, e considerando-se que a competência do Senado restringe-se aos casos de declaração de inconstitucionalidade, a decisão não deveria ser encaminhada àquela Casa Legislativa. Caso fosse o tema de inconstitucionalidade seria um dever do Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhar a decisão para o Senado Federal. Tal imposição é prevista no Regimento Interno do STF (art. 178).

- b) Sim, pois se trata de caso de revogação, em que não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Embora o art. 481, parágrafo único, do CPC (art. 949, parágrafo único, do CPC/2015) dispense o órgão fracionário de um Tribunal de encaminhar a questão constitucional ao pleno (art. 97 da CF/88) quando há decisão do STF sobre a constitucionalidade da lei, como o caso envolve revogação, e não inconstitucionalidade, a cláusula de reserva de plenário não se aplica, tampouco a exceção a ela, prevista no Código de Processo Civil.

RESPOSTA À QUESTÃO 79

- a) De acordo com a Constituição Federal vigente, um quinto dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios será composto por membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Desse modo, se um Tribunal tem cem desembargadores, vinte deve ser composto por membros do Ministério Público e da advocacia. Assim, 20% (vinte por cento) deve ser dividido entre os dois órgãos, portanto, 10% (dez por cento) do Tribunal deve ser

preenchido por advogados.

- b) A OAB elabora uma lista sêxtupla dentre advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, encaminha para o Tribunal, que a reduz para uma lista tríplice, que é encaminhada para o respectivo chefe do Poder Executivo.
- c) A competência para a nomeação do advogado para compor o quinto constitucional do Tribunal de Justiça é do Governador do Estado. Se fosse para o TRF seria competente o Presidente da República.

V EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 80

A inconstitucionalidade formal corresponde à violação de um procedimento ou caminho para a confecção da norma prevista na Constituição do Estado. Assim, se não forem observadas as regras do processo legislativo previstas na Constituição da República, que são, conforme jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal, de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais, ocorrerá a inconstitucionalidade formal.

Na situação proposta, o projeto de lei de iniciativa parlamentar contraria a norma do art. 61, § 1.º, II, a, da CF/88, aplicável, pelo princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional, aos Estados-membros. No que tange à sanção governamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em reconhecer que a sanção do chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governador de Estado e Prefeito) não tem o condão de convalidar o vício de iniciativa.

O Sindicato dos Fiscais de Rendas do Estado poderia requerer a sua admissão no feito na qualidade de *amicus curiae*, nos termos do art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99. Em sendo deferido o pedido, poderia o Sindicato manifestar-se por escrito e realizar sustentação oral, mas não poderia interpor recurso, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RESPOSTA À QUESTÃO 81

- a) Sim, a adoção de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas da União é possível. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a atribuição de índole cautelar às Cortes de Contas, com apoio na teoria dos poderes implícitos, permitindo a adoção das medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República. O “leading case” na matéria foi o Mandado de Segurança 24.510 (STF, Plenário, j. 19-11-2003, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 19-3-2004). Além disso, seria um poder implícito decorrente da competência expressa no art. 71, IX, da CF/88.
- b) As decisões dos Tribunais de Contas de que resulte aplicação de multa ostentam eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3.º, da CF/88) e sua execução compete ao órgão de representação judicial do ente público beneficiário da condenação, no caso, a Advocacia-Geral da União.

RESPOSTA À QUESTÃO 82

- a) O caso deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri da Justiça Estadual Comum por se tratar de crime doloso contra a vida (art. 5.º, XXXVIII, d, da CF/88). Embora a vítima seja um índio, o caso não está relacionado à disputa de direitos indígenas, razão pela qual não seria competência da Justiça Federal (art. 109, XI, da CF/88).
- b) A atribuição à Justiça Federal da competência para julgar disputas sobre direitos indígenas decorre da competência atribuída à União Federal para proteção da cultura indígena, seus bens e valores (art. 231 da CF/88). É por esta razão que a competência, nestas hipóteses, será da Justiça Federal, independentemente do Estado onde o caso tenha ocorrido. Importante destacar que no gabarito oficial foi considerado como correto se o candidato fizesse menção que a proteção dos direitos dos índios é

competência da União (art. 109, XI, da CF/88) ou fizesse referência ao fundamento contido no art. 109, XI, da CF/88).

- c) A decisão do juízo competente, neste caso, será do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de conflito negativo de competência entre órgãos vinculados a tribunais diversos. O fundamento está no art. 105, I, d, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 83

- a) Pelo texto constitucional o Advogado-Geral da União está obrigado a defender a constitucionalidade da norma (art. 103, § 3.º, da CF/88). Para o Supremo Tribunal Federal, embora a Constituição determine que o Advogado-Geral da União deve defender a constitucionalidade das leis impugnadas através de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de acordo com o que foi decidido na ADIn 1.616, o Advogado-Geral da União está dispensado desta obrigação se a lei em questão já tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal através de controle concreto-difuso.
- b) Sim, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIn caso haja interdependência do art. 5.º com outro dispositivo legal poderá também considerá-lo inconstitucional. É a chamada inconstitucionalidade por arrastamento.

RESPOSTA À QUESTÃO 84

- a) A proposta de emenda à Constituição da República estabelecendo a obrigatoriedade de Estados, Municípios e Distrito Federal indexarem a remuneração de seus servidores de acordo com o salário mínimo por violar as limitações materiais ao poder de reforma, estabelecidas no art. 60, § 4.º, da CF/88 padece do vício de inconstitucionalidade material. E a violação está caracterizada, mais especificamente, na ofensa do inciso I do § 4.º do art. 60 da CF/88, que estabelece a cláusula pétrea da forma

federativa de Estado (pacto federativo), pois a indexação da remuneração dos servidores estaduais, distritais e municipais pelo salário mínimo (fixado em lei da União Federal) importa em vulneração da autonomia dos entes federativos e, nesse sentido, em quebra do pacto federativo. Ressalte-se, ainda, o art. 7.º, IV, da CF/88, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

b) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em reconhecer a possibilidade de controle jurisdicional da proposta de emenda constitucional em tramitação. É reconhecida a legitimidade dos deputados e senadores, e somente dos parlamentares, para a impetração de mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Os parlamentares têm direito, líquido e certo, à observância do devido processo legislativo. Trata-se da situação em que o Poder Judiciário, excepcionalmente, realiza o controle de constitucionalidade preventivo.

VI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 85

O enunciado trata das denominadas inelegibilidades, que são impedimentos à capacidade eleitoral passiva (art. 14, §§ 4.º ao 7.º, da CF/88). As inelegibilidades podem ser: 1) absolutas: impedem que o indivíduo concorra a qualquer cargo eletivo; e 2) relativas: consistem em restrições à elegibilidade para determinados mandatos em razão de situações especiais em que, no momento da eleição, se encontre o cidadão. As restrições podem ser por motivos funcionais (§§ 5.º e 6.º do art. 14 da CF/88); dos militares (§ 8.º do art. 14 da CF/88); por previsões de ordem legal (§ 9.º do art. 14 da CF/88, Lei Complementar n. 64/90 e Lei Complementar n. 81/94); por motivo de domicílio eleitoral na circunscrição e, por fim, por motivo de

casamento, parentesco ou afinidade (§ 7.º do art. 14 da CF/88, com a ressalva ao final que permite concorrer à reeleição o cônjuge, parente ou afim que já possuir mandato eletivo). Feitas tais considerações, em resposta ao quadro apresentado no enunciado:

- a) Marco Antônio não pode se candidatar ao cargo de Senador pelo Estado Y, em 2014, pois há impedimento em razão do parentesco. Temos que Marco Antônio será candidato ao Senado pelo Estado Y, Estado este em que sua esposa é Governadora e pretende concorrer à reeleição. A exceção prevista no art. 14, § 7.º, parte final, da CF/88, não se aplica à situação de Marco Antônio, pois este não é “titular do cargo de Senador pelo Estado Y”, ou seja, não é o caso de reeleição para o cargo de Senador pelo mesmo Estado.
- b) Paulo, filho de Marco Antônio e Maria, pode, sim, candidatar-se ao cargo de Senador pelo Estado X, porque o impedimento previsto no art. 14, § 7.º, da CF/88, limita-se aos parentes dos chefes do Poder Executivo (Prefeito, Governador e Presidente) e, sua mãe Maria, chefe do Poder Executivo, é Governadora do Estado Y (Estado diverso do Estado da candidatura de Paulo) e seu pai Marco, ainda que pelo Estado X, é Senador.

RESPOSTA À QUESTÃO 86

- a) A emenda parlamentar ao projeto de lei não seria possível, pois nas leis de iniciativa exclusiva ou privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1.º, II, a, da CF/88), não pode ocorrer emenda parlamentar que gere aumento de despesas (art. 63, I, da CF/88).
- b) O meio de controle de constitucionalidade da lei votada pela Câmara é a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal, pois há ofensa à Constituição Estadual. A competência é do Tribunal de Justiça estadual (art. 125, § 2.º, da CF/88), com a legitimidade conferida ao chefe do Poder Executivo local, por simetria com a Constituição Federal.

c) Mesmo com a sanção não seria possível convalidar a norma, pois a sanção não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa, sendo a jurisprudência do STF pacífica nessa matéria. Desse modo, é possível o controle de constitucionalidade e, nos termos do enunciado, o Prefeito do Município WK teria legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.

RESPOSTA À QUESTÃO 87

- a) O art. 53, caput, da CF/88 estabelece que os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, é a chamada inviolabilidade material. Já o § 2.º do art. 53 da CF/88 prevê a chamada inviolabilidade formal ao estabelecer que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável e nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Assim, e considerando a imunidade formal e o fato de Valdecir ser Senador da República, caberá sim alguma medida para que o Senador seja posto em liberdade, pois cabe ao Senado deliberar sobre a manutenção da prisão dos seus membros nos casos de crime inafiançável.
- b) E a medida cabível é o habeas corpus (arts. 647 e 648 do CPP) que deverá ser impetrado perante o Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, b e d).

VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 88

Sim, é possível o controle da constitucionalidade pelo Judiciário. Excepcionalmente, aceita-se o controle preventivo, por meio de mandado de segurança impetrado por parlamentar no Supremo Tribunal Federal, sob fundamento de violação do devido processo legislativo.

Fundamentos: art. 5.º, LXIX, da CF/88 e Lei n. 12.016/2009. Ainda, deveria ser mencionado o art. 60, § 5.º, da CF/88, que dispõe que a matéria constante de proposta rejeitada não pode ser discutida na mesma sessão legislativa.

Julgados: MS 20.257/DF e 20.452/DF do STF.

RESPOSTA À QUESTÃO 89

a) O órgão competente para julgar a ação popular é o juízo de primeiro grau. Não há prerrogativa de foro na ação popular (art. 5.º da Lei n. 4.717/65). O Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradamente que o rol de competências originárias fixadas no art. 102 da CF/88 é taxativo, e que a prerrogativa de foro, unicamente invocável em procedimentos de caráter penal, não se estende às causas de natureza civil (ex.: Pet 3.152 AgR/PA e 1.738 AgR/MG). Logo, não são de sua competência originária as ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha foro por prerrogativa de função no STF.

ATENÇÃO

Ressalta-se que o enunciado deixou dúvida a questão, pois não se sabe se a lesão causada pelo parlamentar refere-se ao patrimônio estadual ou federal. Caso se trate de patrimônio estadual o juízo competente será o “Juiz da Vara Cível da Comarca de...” ou ainda o Juiz da Vara da Fazenda Pública. De outro modo, caso se refira ao patrimônio federal, o juízo competente será “Juiz da [REDACTED] Vara Cível da Seção Judiciário do Estado...”.

Julgados: QO na AO 859/2001 e Ag. Reg. na Rcl. 2.769/2009, ambos do STF.

b) Erasmo tem legitimidade ativa para propor a ação popular em qualquer foro. Basta demonstrar que é cidadão. O requisito não fica vinculado à localidade onde ele exerce seus direitos políticos – Vide: REsp

1.242.800/MS.

RESPOSTA À QUESTÃO 90

- a) Sim, é possível a previsão da Comissão Parlamentar de Inquérito na Constituição Estadual, em virtude da autonomia do Estado. Ou seja, ao conferir poder de auto-organização aos Estados da Federação, o art. 18 da CF/88 permitiu que editassem Constituições prevendo formas de investigação, como a CPI (STF, ACO 730-RJ), por força do princípio da simetria federativa, tendo por base o art. 58, § 3.º, da CF/88.
- b) Sim, é possível Controle de Constitucionalidade por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 102, I, a, da CF/88. As Constituições dos Estados devem observar os preceitos da Constituição Federal (art. 25 da CF/88). O Governador tem legitimidade para propor a ação, basta demonstrar a pertinência temática, pois é legitimado especial (art. 103, V, CF/88).

RESPOSTA À QUESTÃO 91

- a) A norma será recepcionada normalmente. Embora não seja formalmente compatível, ela é materialmente compatível, o que permite a recepção. Exemplo: o Código Tributário Nacional que tinha status de lei ordinária e foi recepcionado como lei complementar. Ou então, o Código Penal que era decreto-lei e foi recepcionado como lei ordinária. Assim, a incompatibilidade analisada é a de conteúdo e não de forma, que é regida pelo princípio do tempus regit actum.
- b) Sim, é possível Renata ajuizar ação individual para discutir a inconstitucionalidade formal com parâmetro na Constituição anterior. A discussão será pela via incidental. Nesse caso, adota-se a teoria do tempus regit actum, pois a lei era vigente sob a égide da Constituição revogada.
- c) Não há direito adquirido de servidor público quando ocorre a mudança

das regras que os regem, salvo se o servidor já cumprira todos os requisitos antes da modificação, dessa forma terá o direito adquirido – Vide STF, MS 24.875/DF. A Constituição é o fundamento de validade de toda ordem jurídica. Nesse sentido, todas as normas (como é o caso da Lei X da questão) existentes no regime constitucional anterior, no que são materialmente incompatíveis com a nova Constituição, ficam revogadas, salvo disposição expressa da Constituição nova. Saliente-se que há reiterada jurisprudência do STF no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico.

VIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 92

- a) Tendo em vista tratar-se de uma Portaria da Anvisa (um ato administrativo regulamentar, a princípio), não se poderia falar em ADIn, em virtude de se cuidar de um ato secundário. Dessa forma, a ADPF poderia ser utilizada, tendo em vista seu caráter mais abrangente, por ter como objeto ato do Poder Público que viole preceito fundamental, consoante o art. 1.º da Lei n. 9.882/99, observada a subsidiariedade da medida (art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99). (Gabarito oficial)

ATENÇÃO

Não obstante, há entendimento jurisprudencial no sentido de que se a portaria assume caráter de ato normativo, dotado de generalidade e abstração, como o presente caso poderia dar a entender (proibição a todos os médicos do país) e, ainda, violar diretamente a Constituição, a medida mais adequada será a ADIn. Assim, por força da subsidiariedade, a ADPF seria incabível. Nesse sentido, ler ADPF 72 QO/PA.

- b) Trata-se de Associação Brasileira de Profissionais da Saúde de âmbito nacional, razão pela qual, nos termos do art. 2.º da Lei n. 9.882/99, bem como nos termos do art. 103, IX, da CF/88, uma vez demonstrada a

pertinência temática, a referida associação teria legitimidade ativa para promover a ADPF. No caso, tal requisito encontra-se atendido, tendo em vista que a norma impugnada se dirige, exatamente, aos profissionais da saúde.

Por outro lado, o STF possui entendimento jurisprudencial no sentido de que associações com caráter heterogêneo (que representam mais de uma classe ou categoria) não teriam legitimidade ativa para propor as ações de controle, eis que haveria interesses conflitantes entre os representados, descaracterizando o interesse de agir. Ler ADIn 3.381-6.

Apesar do referido posicionamento do STF, não se verifica, a princípio, um contraste de objetivos entre os possíveis membros da associação (profissionais da Saúde – médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, entre outros), motivo pelo qual a Associação seria apta a apresentar a ADPF.

c) É possível a criação de ADPF no âmbito estadual, diante do Princípio da Simetria Federativa. Tal ação poderia ser criada por meio de emenda à Constituição do Estado. Como exemplo, há previsão de ADPF no âmbito da Constituição do Estado de Alagoas (art. 133, IX, r).

A Constituição Federal não previu a arguição no âmbito dos Estados-membros – como fez com a ação direta de inconstitucionalidade (art. 125, § 2.º) – mas, a exemplo do que se passa com a ação direta de constitucionalidade, pode ser instituída pelo constituinte estadual, com base no princípio da simetria com o modelo federal.

RESPOSTA À QUESTÃO 93

A informação indicada pelo advogado está incorreta, pois a ação deveria ser proposta na Justiça Federal, nos termos do art. 109, II, da CF/88. O recurso a ser interposto seria o Recurso Ordinário Constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, II, c, da CF/88 (a Lei n. 8.038/90, nos termos do art. 36, chama o recurso de Apelação Cível).

RESPOSTA À QUESTÃO 94

- a) Seria possível a criação da medida provisória no âmbito estadual, aplicando-se o Princípio da Simetria Federativa, desde que observados todos os requisitos do art. 62 da CF/88. Basta a previsão na Constituição Estadual (art. 25, caput, da CF/88). Ressalte-se que no caso, o dispositivo da Constituição do Estado "X" violou o art. 62, § 3.º, da CF/88, pois estabeleceu prazo de 30 dias para apreciação da Assembleia Legislativa, sendo que a Constituição Federal prevê o prazo de 60 dias.
- b) Sim, a majoração da alíquota mínima do ITCMD é constitucional, uma vez que não viola o art. 155, § 1.º IV, da CF/88, bem como o art. 62 da CF/88. Contudo, quanto à majoração da alíquota máxima do ITCMD era necessário observar que esta é estabelecida pelo Senado Federal nos termos do art. 155, § 1.º, IV, da CF/88, razão pela qual se verifica a inconstitucionalidade formal parcial.
- c) Não, as majorações ocorridas nas alíquotas não poderiam ser cobradas no ano de 2012, pois conforme o art. 62, § 2.º, da CF/88, a Medida Provisória que institui ou majora imposto, salvo determinados tributos, somente produzirá efeitos no exercício seguinte, se a lei de conversão for aprovada no mesmo ano em que a Medida Provisória foi produzida. No caso em tela, verifica-se que a lei somente foi aprovada em 2012 (Medida Provisória de 15-12-2011 – lei de conversão aprovada 20 dias depois, ou seja, em 4-1-2012), motivo pelo qual, em razão do Princípio da Anterioridade Tributária (art. 150, III, b e c, da CF/88), a majoração das alíquotas só entrará em vigor em 2013 (próximo exercício financeiro).

RESPOSTA À QUESTÃO 95

- a) No caso em questão, com relação a Caio as novas regras não serão aplicadas, uma vez que preencheu todos os requisitos, tendo assim direito adquirido ao regime jurídico anterior (art. 5.º, XXXVI, CF/88 e art. 6.º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro). Em contrapartida,

Tício, por não ter preenchido os requisitos para a aposentadoria, tem mera expectativa de direito, o que segundo a jurisprudência do STF, não gera direito adquirido. É possível que a emenda constitucional traga regra de transição para englobar aqueles que já eram servidores ao tempo de sua edição, mas, caso não exista essa regra (ou caso o servidor não se enquadre nessa regra), a nova sistemática da aposentadoria é imediatamente aplicável.

- b) É possível que a lei federal venha para aumentar ou modificar a fórmula de cálculo dos proventos dos aposentados, pois não existe direito adquirido a regime jurídico no que diz respeito à forma de composição dos vencimentos. Deve-se respeitar a irredutibilidade dos proventos, mas não a forma de cálculo do benefício. O que não pode ocorrer é a modificação que gere a diminuição dos proventos, sob pena de violar o direito adquirido (vide MS 24.875/DF e AI 814.444/PB).

IX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 96

- a) Considerando que o habeas data foi interposto em face do presidente do Tribunal de Contas da União, a competência é do supremo Tribunal Federal conforme previsão expressa da alínea d do inciso I do art. 102 da CF/88.
- b) Sim, é constitucional, pois consubstancia o interesse de agir para a interposição do habeas data. A Lei n. 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data, estabeleceu expressamente como condição da ação que a petição inicial do HD seja instruída com a prova, a depender do caso concreto, da recusa do acesso às informações, recusa em fazer-se a retificação, recusa em fazer-se a anotação, ou, em cada caso, do decurso do prazo definido sem decisão quanto ao que foi solicitado (incisos I, II e III do parágrafo único

do art. 8.º da Lei n. 9.507/97). Esse é o entendimento do STF (RHD 22 e AgRg no HD 87) e do STJ (Súmula 2).

- c) A pretensão de José, no caso apresentado, não pode ser veiculada por habeas data, pois estabelecem o art. 5.º, LXXII, a, da CF/88 e o art. 7.º, I, da Lei n. 9.507/97 que o referido remédio se destina a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

RESPOSTA À QUESTÃO 97

- a) Os limites para a edição das medidas provisórias estão previstos nos parágrafos do art. 62 da CF/88. Vejamos: no § 1.º do art. 62 estão previstos os limites materiais; nos §§ 2.º e 7.º do art. 62 estão previstos os limites temporais e, por fim, no § 10 temos os limites circunstanciais para a reapresentação da medida provisória.
- b) Sim, pois se aplica o princípio do paralelismo ou simetria das normas. Desse modo, é possível Constituição Estadual prever edição de medida provisória pelo governador do Estado, porém a norma constitucional estadual não poderá estabelecer requisitos e limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil.
- c) Há previsão expressa no caput do art. 62 da CF/88 da necessidade de relevância e urgência para a edição de medida provisória e o Supremo Tribunal admite o exame jurisdicional do mérito desses requisitos em casos excepcionais e quando a ausência desses pressupostos for evidente.

RESPOSTA À QUESTÃO 98

- a) Não, o Município não tem autonomia para criar a regra citada no enunciado. Há violação do princípio da isonomia previsto no art. 5.º da CF/88, bem como da isonomia federativa e a vedação da discriminação entre nacionais (art. 19, III, da CF/88). Ademais, viola frontalmente as

regras previstas nos incisos I e II do art. 37 da CF/88, que estabelecem que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como que a investidura dependerá de prévia aprovação em concurso público.

- b) Sim, a ADIn estadual pode ter por objeto dispositivo da Lei Orgânica. As ações Diretas de Inconstitucionalidade Estaduais podem ter por objeto atos normativos estaduais e municipais, o que inclui as Leis Orgânicas dos Municípios. Importante ressaltar que a Lei Orgânica do Município deve estar de acordo com a Constituição da República e com a respectiva Constituição do Estado do qual o Município faz parte. Essa é a previsão dos arts. 29 e 125, § 2.º, da CF/88.
- c) Sim, pois o dispositivo da Constituição Estadual que foi violado é norma de reprodução obrigatória e, nesses casos, o STF entende que é cabível o Recurso Extraordinário (art. 102, III, a e c, da CF/88).

RESPOSTA À QUESTÃO 99

- a) Cabe ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos ao referendo do Congresso Nacional externado pela aprovação de um decreto legislativo. Desse modo, o Presidente da República assina o documento (tratado internacional), nos termos do art. 84, VIII, da CF/88. O referido tratado será, então, submetido ao Congresso Nacional que votará o decreto legislativo (art. 49, I, da CF/88). Posteriormente, o Presidente da República ratifica o tratado com a publicação de um Decreto Presidencial ultimando a internalização do tratado.
- b) O tratado foi discutido e votado no âmbito da Organização Mundial do Comércio e regulamenta novas formas de controle sobre o comércio exterior. Desse modo, uma vez internalizado ingressará no nosso ordenamento jurídico como lei ordinária. Importante lembrar que os

ministros do STF, por maioria de votos, entenderam que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos ingressam no ordenamento jurídico com status de norma suprallegal, ou seja, acima das leis, mas abaixo da Constituição (HC 87.585/TO, RE 466.343/SP: Informativo 531).

- c) O conflito entre norma constitucional e norma de hierarquia de lei ordinária deve ser resolvido pelo Princípio da Supremacia da Constituição. Desse modo, se houver conflito entre o texto do tratado internalizado e o texto constitucional, deverá prevalecer o dispositivo constitucional.

X EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 100

- a) Sim, a norma é inconstitucional. O primeiro vício é de iniciativa, pois projeto de lei para extinguir Ministério é de iniciativa do Presidente da República (art. 61, § 1.º, II, e, da CF/88). Além disso, houve vício na votação do projeto no Senado Federal, pois o art. 47 da CF/88 prevê a maioria absoluta dos membros para a votação de um projeto de lei. No caso seria necessária a presença de pelo menos 41 senadores para que houvesse a votação.
- b) O art. 103, IX, da CF/88 estabelece que a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional podem propor a ADIn e a ADC, porém como legitimadas especiais teriam que comprovar a pertinência temática. Desse modo, pelo enunciado proposto não haveria a pertinência temática para a Conamp propor a ADC. Ademais, o enunciado diz que a ação foi proposta uma semana após a publicação da lei na imprensa oficial o que resulta na não observância do requisito da controvérsia judicial relevante, ou seja, a existência de várias ações judiciais nas quais a União está perdendo (art. 14, III, da Lei n. 9.868/99).

RESPOSTA À QUESTÃO 101

- a) Sim, é cabível a declaração de inconstitucionalidade da lei do Estado “Y” que regulamenta a chamada rinha de galo, pois a Constituição Federal (art. 225, § 1.º, VII) proíbe práticas que submetam os animais à crueldade. Desse modo, não pode o Estado “Y” alegar que protege manifestações culturais, pois prevalece o princípio da unidade da Constituição ou princípio da especialidade. Nesse sentido: STF ADIns 3.776, 1.856 e 2.514.
- b) Não há regularidade na legitimidade ativa da ação, pois a Associação Comercial do Estado “Y” não é entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF/88 e art. 2.º, IX, da Lei n. 9.868/99). Ademais, além da exigência de ser entidade de classe de âmbito nacional, deveria haver a pertinência temática que é exigida para os legitimados especiais.

RESPOSTA À QUESTÃO 102

- a) A Proposta de Emenda Constitucional padece das seguintes inconstitucionalidades formais: primeiro, não houve a observância do art. 60, I, da CF/88, que estabelece que a PEC deve ser proposta por no mínimo um terço dos membros da Câmara dos Deputados. Segundo, não houve observância do quórum de aprovação previsto no art. 60, § 2.º, da CF/88 que exige três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional. Terceiro, não houve observância do art. 60, § 3.º, da CF/88, que estabelece que as emendas deverão ser promulgadas pelas Mesas da Câmara e do Senado. A PEC padece ainda de inconstitucionalidade material, pois submeter as decisões do STF, no controle abstrato das normas, ao crivo do Congresso Nacional atenta contra a cláusula pétrea da separação dos poderes e do sistema de freios e contrapesos que possibilita o controle e vigilância dos poderes entre si (art. 60, § 4.º, III, da CF/88).
- b) A ação declaratória de constitucionalidade não poderia ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ausência do requisito legal previsto no

art. 14, III, da Lei n. 9.868/99, a saber: existência de controvérsia judicial relevante, pois o enunciado diz que a ação foi proposta apenas cinco dias após a publicação da emenda constitucional.

RESPOSTA À QUESTÃO 103

- a) O não repasse das verbas referidas, sem motivo de força maior, poderá resultar na intervenção federal, ou seja, a União poderá intervir no Estado W, nos termos do art. 34, V, b, da CF/88.
- b) Constatado o fato de as verbas não serem repassadas, a intervenção materializa-se por decreto do Presidente da República (art. 36 da CF/88), nomeando-se um interventor. Há apreciação pelo Congresso Nacional, no prazo de 24 horas (art. 36, § 1.º, da CF/88). Se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente (art. 36, § 2.º, da CF/88). No caso, o Presidente da República deve ouvir o Conselho da República (art. 90, I, da CF/88) e o Conselho de Defesa Nacional (art. 91, § 1.º, II, da CF/88).

XI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 104

- a) A lei do referido Estado-membro inclui a disciplina de formação para o trânsito nos currículos do 1.º e do 2.º graus de ensino da rede pública estadual e, portanto, trata de educação. A Constituição Federal, no art. 24, estabelece a competência legislativa concorrente, ou seja, pode ser exercida por mais de um ente federativo. A competência legislativa concorrente é atribuída à União, Estados e Distrito Federal, cabendo à União estabelecer as normas gerais, nos termos do § 1.º do art. 24. Desse modo, consoante se depreende da previsão constitucional acerca da competência legislativa sobre educação, a referida lei é constitucional, pois o art. 24, IX, atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre educação, cultura, ensino e

desporto. Nesse sentido, já se pronunciou o STF, ao julgar a ADIn 1.991/DF (rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, unânime, j. 3-11-2004). Ressalta-se que se a lei aprovada tratasse sobre trânsito e transporte, diverso seria o entendimento, posto que neste caso a competência seria privativa da União (art. 22, XI, da CF/88).

- b) Os legitimados para propor ADIn e ADPF estão elencados no art. 103, I a IX, da CF/88 e nas Leis n. 9.868/99 e 9.882/99. A jurisprudência do STF assentou o entendimento de que o Governador de Estado é legitimado especial. Desse modo, para poder ajuizar a ação deve demonstrar a pertinência temática, ou seja, a repercussão da lei impugnada considerando os interesses de seu Estado. Considerando a lei aprovada a ser impugnada, nos termos do enunciado, o Governador de outro Estado não pode ajuizar ADIn ou ADPF contra essa lei, pois não há pertinência temática entre o interesse do Estado e o objeto da ação.

RESPOSTA À QUESTÃO 105

- a) Sim, é possível invocar um direito fundamental, previsto na Constituição, em uma demanda movida contra um particular e tal possibilidade resulta da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que decorre da dimensão objetiva desses direitos. Pode haver violação a direitos fundamentais nas relações entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado e não somente nas relações entre os cidadãos e o Estado, ou seja, uma série de direitos fundamentais destina-se não apenas a garantir os direitos em face do Estado, mas também a estabelecer as bases essenciais da vida social. Os direitos fundamentais consagram valores muito importantes com eficácia em todo o ordenamento e a sua dimensão objetiva possibilita invocar um direito fundamental, previsto na Constituição, em uma demanda movida contra um particular.
- b) Não é correto o argumento da defesa, pois as normas definidoras dos direitos individuais têm aplicabilidade imediata, essa é a previsão

expressa do art. 5.º, § 1.º, da CF/88. Desse modo, as normas definidoras dos direitos individuais não necessitam de edição de norma regulamentadora, salvo quando a própria Constituição assim o exigir expressamente. É o que ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada.

RESPOSTA À QUESTÃO 106

- a) O parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido do não conhecimento da ação não deve ser acolhido. Nos termos do art. 103, VIII, da CF/88 para ter legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade o partido político deve ter representação no Congresso Nacional, ou seja, é necessário e suficiente ter ao menos um representante na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não sendo necessário que possua representantes nas duas Casas Legislativas. Ressalte-se que não é exigido que demonstre na inicial o requisito da pertinência temática, pois o partido político é legitimado universal.
- b) Não. Quanto ao mérito, não tem razão o partido político no seu pleito, sendo caso de improcedência da ação, uma vez que a competência privativa da União do art. 22, XXVII, da CF/88 se refere a normas gerais, tendo os Estados federados competência para legislar sobre o tema para atender às suas peculiaridades, desde que não haja afronta às normas gerais editadas pela União.

Assim, quanto ao mérito, não tem razão o partido político, pois o que se depreende do enunciado proposto é que a lei do Estado "Y" sobre licitações e contratos administrativos atende às peculiaridades daquele Estado federado e o faz sem afrontar normas gerais, sendo, assim, caso de improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.

RESPOSTA À QUESTÃO 107

- a) Há o vício insanável de iniciativa na Lei do Município YY, pois foi de

iniciativa da Câmara de Vereadores e estipulou novo plano de carreira para a categoria de professores municipais, impondo remunerações escalonadas, fixando pisos mínimos e vinculando a remuneração global ao percebido por servidores do Poder Legislativo local. Lei que trate da criação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como trate do aumento de sua remuneração, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1.º, II, a e c, da CF/88. Tal norma deve ser observada pelos Estados e Municípios em razão da simetria ou paralelismo constitucional, ou seja, é norma de reprodução e observância obrigatórias. No caso, caberia ao Prefeito a iniciativa legislativa.

- b) Não foi acolhida no texto constitucional a vinculação de remunerações entre Poderes. É o que se depreende do inciso XIII do art. 37 da CF/88 que estabelece que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Desse modo a Lei do Município YY que impôs remunerações escalonadas, fixando pisos mínimos e vinculando a remuneração global ao percebido por servidores do Poder Legislativo local padece nesse ponto de inconstitucionalidade.

XII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 108

- a) Há, sim, em nosso ordenamento jurídico constitucional a previsão para a edição de decreto autônomo, que passou a ser admitido a partir da Emenda Constitucional n. 32/2001 que alterou a redação do inciso VI do art. 84 da CF/88. Desse modo, o decreto autônomo, de competência do chefe do Poder Executivo, tem a finalidade de organização e funcionamento da Administração Pública desde que não implique em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e seu

fundamento de validade está na Constituição. Tal previsão constitucional é aplicável aos Estados e Municípios. Há ainda os denominados decretos regulamentares ou de execução, que têm a finalidade de assegurar a execução das leis, são necessários quando precisa que seja dada a forma de execução a algum aspecto da lei, seja de ordem prática seja de ordem técnica. Cabe ao chefe do Poder Executivo este poder regulamentar. Isto tudo nos termos do inciso IV do art. 84 c/c art. 5.º, II, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal admite o controle, por via de ação direta de inconstitucionalidade, do decreto autônomo, revestido de conteúdo normativo, mas não o admite quando se tratar de decreto de regulamentação da lei.

- b) Não é possível a revogação do Decreto-lei n. 3.365/41 pelo decreto presidencial. Importante destacar que a desapropriação tem previsão constitucional no art. 5.º, XXIV, da CF/88, que prevê que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Desse modo, o que se depreende é que o tema desapropriação deve ser tratado por lei, e lei ordinária, posto que não há a ressalva expressa de exigência de lei complementar. Como o Decreto-lei n. 3.365/41 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ainda que formalmente como decreto, é, na verdade, materialmente uma lei ordinária e deve ser alterado ou revogado por no mínimo uma lei ordinária. E o decreto autônomo somente pode ser utilizado para as hipóteses do art. 84, VI, da CF/88, cabendo-lhe, no mais, apenas a regulamentação das leis. Por essa razão, decreto que cria disciplina nova ou que revoga ato normativo hierarquicamente superior exorbita da disciplina constitucional (ADIn 3.232, ADIn 3.990, ADIn 2.564).

RESPOSTA À QUESTÃO 109

- a) A União não poderá intervir nos Municípios, pois a intervenção como medida excepcional somente poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente

enumeradas no texto constitucional. A Constituição Federal autoriza a intervenção federal em Estados ou em Municípios situados em territórios federais (arts. 34 e 35 da CF/88), mas não a intervenção federal em Municípios situados em Estados, mesmo que haja omissão do respectivo Estado. Desse modo, a União somente tem legitimidade para intervir nos Municípios localizados em Território Federal e os demais Municípios poderão sofrer intervenção do respectivo Estado-membro. O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, registrando que os Municípios situados no âmbito dos Estados-membros não se expõem à possibilidade constitucional de sofrerem intervenção decretada pela União, eis que, relativamente a esses entes municipais, a única pessoa política ativamente legitimada a neles intervir é o Estado-membro. Por isso mesmo, no sistema constitucional brasileiro, falece legitimidade ativa à União para intervir em quaisquer Municípios, ressalvados, unicamente, os Municípios localizados em Território Federal.

- b) Sim, há controle político, nos termos do art. 36, § 1.º, da CF/88 que se aplicará aos Estados pelo princípio da simetria. No caso descrito, a intervenção do Estado no Município se materializa por decreto do chefe do Executivo, o Governador, e estará sujeito ao controle político a posteriori da Assembleia Legislativa do Estado.

RESPOSTA À QUESTÃO 110

- a) Os legitimados ativos da ADIn e ADC estão relacionados no art. 103, I a IX, da CF/88 e no art. 2.º, I a IX, da Lei n. 9.868/99. Especificamente as Mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa, os Governadores dos Estados, o Governador do Distrito Federal e as Confederações sindicais (art. 103, IV, V e IX, da CF/88 e art. 2.º, IV, V e IX, da Lei n. 9.868/99) são denominados autores especiais e, por isso, devem demonstrar a pertinência temática (interesse) para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Esse requisito se refere à comprovação

de que o objeto da instituição guarda relação com o pedido da ação direta proposta por referida entidade e é um requisito jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nessa toada, o Governador do Estado "Y" poderá impugnar a lei editada pela Assembleia Legislativa do Estado "Z" por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade desde que demonstre a pertinência temática, ou seja, que o conteúdo debatido em tal ação de controle de constitucionalidade (isto é, a lei do outro Estado da Federação, qual seja o Estado "Z") tem ligação, no mínimo indireta, com o interesse do seu Estado e de sua população. (ADIn 902-MC, ADIn 2.747, entre outras).

- b) O Partido Político é um dos legitimados ativos da ADIn e ADC. Está relacionado no art. 103, VIII, da CF/88 e no art. 2.º, VIII, da Lei n. 9.868/99. É denominado universal ou neutro não necessitando demonstrar interesse especial para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade. A exigência constitucional e legal é que no momento da propositura da ação tenha representação no Congresso Nacional, ou seja, tenha ao menos um Deputado Federal ou um Senador. Assim, o partido político pode prosseguir com a Ação Direta de Inconstitucionalidade mesmo que ocorra a perda superveniente da representação do partido no Congresso Nacional. Nesse sentido a jurisprudência atual do STF: AgRg na ADIn 2.618, ADIn 2.427, ADIn 1.396, entre outras.

RESPOSTA À QUESTÃO 111

- a) O Deputado "P" não pode ser responsabilizado pelas ofensas proferidas a outro Deputado durante a entrevista, pois tal manifestação está vinculada ao desempenho de seu mandato. É decorrência da inviolabilidade, prevista no art. 53 da CF/88, que assegura que os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso significa que não cometem crime, pois não há

ilicitude (ato contrário à lei), nem respondem na ordem civil por tais atos. É a denominada imunidade material ou absoluta que abrange também as entrevistas jornalísticas e as declarações feitas aos meios de comunicação social, desde que tais manifestações estejam vinculadas ao desempenho do mandato. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Inq. 1.958, Inq. 2.130, Inq. 655, entre outros).

- b) Não é válida a lei estadual que impôs a obrigatoriedade de instalação de sistema de controle de velocidade de veículos automotores, pois a Constituição Federal estabelece um sistema de repartição de competências legislativas que deve ser observado. Legislar sobre trânsito e transporte é de competência privativa da União, consoante se depreende do inciso XI do art. 22 da CF/88. A lei estadual em questão, ao estabelecer a obrigatoriedade de instalação de sistema de controle de velocidade de veículos automotores invade tema reservado à competência privativa da União. Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal (ADIn 3.055, ADIn 3.254, MC na ADIn 3.625, entre outras).

XII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 112

- a) Não caberia ADIn, pois na verdade não haveria objeto para a ação, pois a lei "X" já havia sido revogada.
- b) Sim, o Procurador-Geral da República pode ajuizar ADIn pedindo a declaração de inconstitucionalidade das leis "Y" e "X", sucessivamente. A justificativa é que se a lei "Y" fosse declarada inconstitucional, a lei "X" voltaria a vigorar. O STF entende que é possível, na mesma ação, declarar a inconstitucionalidade da lei anterior, que volta a ter vigência.

Contudo, vale salientar que no gabarito oficial, a banca examinadora também aceitou resposta em sentido diverso para atribuir pontuação ao candidato: "Não. O Procurador-Geral da República pode pedir a

inconstitucionalidade da lei Y e, declarada sua inconstitucionalidade, que não haja efeito repristinatório em relação à lei X, conforme entendimento atual do STF”.

RESPOSTA À QUESTÃO 113

- a) Os brasileiros natos não podem ser extraditados, nos termos do art. 5.º, LI, CF/88. A Constituição considera brasileiro nato aquele que nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Filipa nasceu no Brasil, que adota o critério do *ius solis* e seus pais obtêm emprego aqui (não estão a serviço da Itália), portanto, é brasileira nata, conforme previsão constante do art. 12, I, da CF/88. Feitas tais considerações, Filipa não pode ser extraditada, pois é brasileira nata (arts. 5.º, LI; 12, I, e § 4.º, II, todos da CF/88).
- b) A nacionalidade é o vínculo político e pessoal que se estabelece entre o Estado e o indivíduo, define o elo que une o indivíduo a um Estado determinado. A nacionalidade (originária ou derivada) tem fundamental importância para um Estado soberano, assim, o modo de aquisição e perda da nacionalidade está previsto na Constituição. Portanto, a legislação ordinária não pode estabelecer nova hipótese de aquisição de nacionalidade brasileira.

RESPOSTA À QUESTÃO 114

- a) O Deputado “G” não pode ser responsabilizado pelas ofensas proferidas no discurso feito no plenário (inviolabilidade prevista no art. 53 da CF/88). Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A referida imunidade material se estende para fora do ambiente do Congresso Nacional, desde que a manifestação esteja vinculada ao desempenho do mandato. Desse modo, se proferir o discurso durante entrevista televisiva, fora do ambiente da Câmara dos Deputados, mas em razão do exercício do mandato parlamentar (isto é, na qualidade de agente político) o

Deputado “G” estará protegido pela inviolabilidade constitucional. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Inq. 1.958, Inq. 2.130, Inq. 655, RE 210.917, AgRg no AgIn 493.632) entre outros.

- b) Para o vereador há a imunidade material desde que o ato tenha sido praticado no desempenho ou em razão do cargo e na circunscrição do Município. Desse modo, há a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato, mesmo que fora do recinto da Câmara Municipal, desde que na circunscrição do Município (limites territoriais do Município a que se acha funcionalmente vinculado), nos termos do art. 29, VIII, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 115

- a) Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum qualificado de três quintos dos votos em dois turnos nas duas casas do Congresso Nacional, nos termos do § 3.º do art. 5.º da CF/88, serão equivalentes às Emendas Constitucionais. Temos, então, que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Dec. n. 6.949, de 25-8-2009) incorporada ao ordenamento pátrio com base no art. 5.º, § 3.º, da CF/88, tem status hierárquico normativo de emenda constitucional.
- b) O entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que os tratados internacionais de direitos humanos não incorporados segundo o procedimento do art. 5.º, § 3.º, da CF/88, possuem status hierárquico de norma supralegal. Confira-se no RE 466.343/SP; HC 90.172/SP.
- c) Como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada conforme o procedimento descrito pelo art. 5.º, § 3.º, da CF/88, tem status de norma constitucional e, portanto, pode vir a ser considerada como parâmetro para controle de constitucionalidade.

XIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 116

- a) O preâmbulo da Constituição da República não tem força normativa, de forma que se apresenta sem força cogente. Assim, não é possível o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por parâmetro preceito inscrito no preâmbulo. Dessa forma foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 2.076.
- b) A Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objetivo retirar do ordenamento jurídico a lei ou ato normativo estadual ou federal atingido pelo vício da inconstitucionalidade, preservando, assim, a higidez do ordenamento jurídico. Os legitimados estão previstos no art. 103 da CF/88, e o Governador do Estado figura no inciso V. Assim, a ADIn pode ser proposta pelo Governador do Estado mesmo que o objeto da ação seja uma lei de sua iniciativa, pois se trata de processo objetivo para preservar a supremacia da Constituição.

RESPOSTA À QUESTÃO 117

- a) Não, existem limitações, ao poder de emenda, previstas na Constituição. A questão trata das limitações procedimentais que se relacionam ao procedimento a ser adotado para modificar a Constituição. Mais especificamente trata da iniciativa, ou seja, quem pode propor um projeto de emenda constitucional. A previsão está nos incisos I, II e III do art. 60 da CF/88 que estabelecem a iniciativa: de no mínimo um terço dos Deputados Federais ou dos Senadores; do Presidente da República; de um projeto com a anuência de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se a maioria relativa de seus membros em cada uma delas. Desse modo, observa-se que não há previsão para que um parlamentar, isoladamente, ou a sociedade civil, coletando assinaturas, deflagrem o processo legislativo de emenda

constitucional. Deve-se consignar que não se confunde a iniciativa popular para a edição de leis, prevista no art. 61, § 2.º, da Constituição Federal, com a iniciativa para a edição de emendas à Constituição. A resposta, portanto, é que um parlamentar ou a sociedade civil não têm iniciativa no processo legislativo de Emenda à Constituição.

- b) Não, trata-se das limitações materiais ou cláusulas pétreas, ou seja, partes da Constituição que não podem ser modificadas por emendas constitucionais para abolir direitos. A previsão está no § 4.º do art. 60 da CF/88 que estabelece as cláusulas pétreas explícitas, entre elas, os direitos e garantias individuais. Nessa toada, o art. 5.º, XXII, estabelece que é garantido o direito de propriedade e, na sequência, o inciso XXIII estabelece que a propriedade atenderá a função social. Temos, então, que o direito de propriedade não é absoluto, pois função social é estabelecida como inerente e faz parte do próprio direito à propriedade. A função social incide sobre a estrutura e o conteúdo da propriedade, sobre a própria configuração do direito, e constitui elemento que qualifica sua situação jurídica. Desse modo, não pode ser alterada por emenda à Constituição.

RESPOSTA À QUESTÃO 118

- a) As normas constitucionais de eficácia plena têm aplicabilidade imediata, direta, integral, independentemente de legislação infraconstitucional para sua inteira operatividade (autoaplicáveis ou autoexecutáveis). As normas de eficácia contida também possuem aplicabilidade imediata, mas podem ter reduzido o seu alcance pela atividade do legislador ordinário, em virtude de autorização constitucional. São também chamadas de normas de eficácia redutível ou restringível. Assim, a diferença entre ambas reside na possibilidade de as normas de eficácia contida poderem ter o seu alcance restringido pela legislação infraconstitucional.
- b) As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático,

apesar de dependerem da integração da lei para a produção da plenitude de seus efeitos, geram de imediato, efeitos jurídicos. Assim, apesar de não se poder extrair de imediato, da norma, a plenitude de seus efeitos, em especial a eficácia positiva, capaz de amparar a pretensão de produção da consequência jurídica prevista na norma, é possível extrair, da norma, uma eficácia interpretativa, capaz de reger a interpretação das normas de hierarquia inferior, bem como uma eficácia negativa, isto é, a capacidade de servir de parâmetro ao controle de constitucionalidade das normas de hierarquia inferior que vierem a lhe contrariar ou ao controle de constitucionalidade das omissões do Poder Público.

RESPOSTA À QUESTÃO 119

- a) Sim, estabelecer a obrigação para que os médicos públicos e particulares notifiquem os casos de dengue à Secretaria de Saúde é constitucional, pois a matéria encontra-se no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados para legislar sobre defesa da saúde, conforme art. 24, XII, da Constituição Federal.
- b) O dispositivo da lei estadual que atribui responsabilização civil ao médico por falta de notificação é inconstitucional, pois cabe à União legislar sobre essa matéria (direito civil), nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. (ADIn 2.875, DJe 20-6-2008).

XV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 120

- a) As normas de reprodução obrigatória são aquelas que devem, necessariamente, estar inseridas no texto da Constituição Estadual e, isto, em razão da subordinação à Constituição da República, que é a matriz do ordenamento jurídico parcial dos Estados-membros. Assim, as normas de reprodução decorrem do caráter compulsório da norma constitucional federal (art. 25, caput, da CF/88).

b) Não, as duas ações não poderão tramitar simultaneamente. Desse modo, se a lei estadual for impugnada perante o Tribunal de Justiça local e perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento em norma constitucional de reprodução obrigatória, com base no princípio da simetria, suspende-se a ação direta proposta na Justiça Estadual até a decisão final do Supremo Tribunal Federal, que poderá ter efeitos erga omnes e eficácia vinculante para o Tribunal de Justiça, se julgada procedente. Essa é a solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que indica como fundamentos a esse entendimento, a primazia da Constituição da República (e, conseqüentemente, a primazia de sua guarda) e a prejudicialidade do julgamento daquela Corte com relação aos Tribunais de Justiça locais.

RESPOSTA À QUESTÃO 121

a) As enormes jazidas de ouro, ferro, estanho e petróleo descobertas pertencem à União. Tal previsão está na Constituição Federal, na espécie, no inciso IX do art. 20 da CF/88 que prevê que são bens que pertencem à União, os recursos naturais, inclusive os do subsolo. Há, ainda, que se destacar, no mesmo sentido, o art. 176, também da CF/88, que dispõe que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União. Desse modo, a titularidade da propriedade mineral foi atribuída constitucionalmente à União. Com relação ao resultado da exploração dos recursos, os demais entes, em cujos territórios se deram a descoberta, recebem sim participação no resultado. Tal decorre da expressa determinação estabelecida no § 1.º do art. 20 da CF/88 que assegura, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da Administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de

outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Assim, garante-se o Estado "X" e os Municípios de Alegria e Felicidade participação no resultado ou compensação financeira pela exploração de recursos em seus territórios.

- b) Não, qualquer dos entes federativos, seja o Estado ou um dos Municípios, insatisfeito com a destinação dos recursos naturais descobertos em seu território, não pode, à luz do nosso ordenamento, propor a secessão, a fim de se constituir em ente soberano, único titular daqueles recursos. A Constituição Federal veda a secessão, pois estabelece, como princípio fundamental, em seu art. 1.º que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. No mesmo sentido, é a previsão do art. 18.

RESPOSTA À QUESTÃO 122

- a) A federalização dos crimes contra os direitos humanos é um dos principais pontos da Emenda Constitucional n. 45/2004. Trata-se de instituto que prevê a mudança da competência da Justiça local (Estadual) para a Justiça Federal em situação que restar configurada grave violação aos direitos humanos. Está previsto no § 5.º do art. 109 da CF/88, e tem a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil, dando-lhes proteção efetiva.
- b) O Presidente da República não pode requerer a aplicação do instituto. Cabe, somente, ao Procurador-Geral da República suscitar o instituto da federalização dos crimes contra os direitos humanos no Superior Tribunal de Justiça, nos termos estabelecidos no art. 109, § 5.º, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 123

- a) A Constituição Federal estabelece, no § 3.º do art. 58, que as Comissões

Parlamentares de Inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades, assim, poderá determinar a condução coercitiva de testemunha (gabarito oficial).

Crítica: não pode determinar a condução coercitiva de testemunha, podendo requerer ao juiz criminal da localidade (art. 3.º, § 1.º, da Lei n. 1.579/52).

b) A Constituição Federal ao garantir a liberdade de imprensa, no art. 5.º, XIV, protegeu o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. A profissão de jornalista guarda, para o seu exercício, vinculação com o exercício das liberdades de expressão e de informação. Portanto, o jornalista não pode ser obrigado a responder indagações sobre a origem de suas fontes.

c) Sim, o STF reconhece o poder da CPI para determinar a quebra do sigilo bancário dos investigados, observada a devida fundamentação para tanto, pois a competência decorre da atribuição de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, e a matéria não se insere na cláusula de reserva de jurisdição.

XVI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 124

a) Sim, pois a existência de dúvida sobre matéria de direito não impede a movimentação do Judiciário por intermédio do mandado de segurança. A questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que em relação ao tema editou o verbete da Súmula 625, que assim estabelece: "Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança". Portanto, a exigência de direito líquido e certo para a impetração de mandado de segurança não se refere à inexistência de "controvérsia sobre matéria de direito", mas à inexistência de controvérsia sobre fatos, que devem ser objeto de pronta comprovação.

b) Sim. A entidade de classe dos servidores públicos tem legitimidade para

impetrar o mandado de segurança, mesmo que a pretensão diga respeito apenas a uma parte da respectiva categoria. É o que dispõe a Súmula 630 do STF (“A entidade de classe tem legitimção para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”).

RESPOSTA À QUESTÃO 125

- a) Para responder ao questionamento deve-se analisar o que está previsto no § 7.º do art. 14 da CF/88. Carlos, como sobrinho do Governador, tem parentesco consanguíneo de “terceiro grau”, pela linha colateral, portanto pode se candidatar, pois a inelegibilidade atinge tão somente parentes (consanguíneos ou afins) até o segundo grau. Zacarias é filho adotivo de Prudêncio, portanto o seu parentesco é de primeiro grau por adoção, mas como já é titular de mandato eletivo e está concorrendo à reeleição para o cargo de Deputado Estadual do Estado W, poderá concorrer, pois se enquadra na exceção prevista no mesmo dispositivo (“salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”). Já Marcos, que é neto de Prudêncio Ferreira, governador do Estado W, tem parentesco consanguíneo de segundo grau pela linha direta e Roberval, de seu turno, que é genro de Prudêncio, tem, portanto, parentesco de primeiro grau por afinidade, não poderão se candidatar, pois são inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. Assim, Carlos Ferreira e Zacarias Ferreira, na forma do art. 14, § 7.º, da Constituição Federal, podem se candidatar. Marcos e Roberval não poderão concorrer, por força, também, do que estabelece o citado art. 14, § 7.º, da Constituição Federal.
- b) Não estão habilitados a concorrer ao cargo de Deputado Estadual pelo Estado W, Roberval (genro) e Marco (neto) em razão do parentesco com Prudêncio que é o Governador e concorrerá a um segundo mandato. Assim, nos termos do art. 14, § 7.º, da Constituição Federal, a

inelegibilidade se dá no território de jurisdição do titular, ou seja, para cargos eletivos no Estado W. Portanto, se Roberval e Marco tiverem preenchido as condições de elegibilidade do art. 14 da Constituição Federal, poderão disputar a eleição em qualquer outro Estado da Federação, pois a restrição pelo parentesco se restringe ao Estado W, onde o sogro (de Roberval) e o avô (de Marco) é o Governador.

RESPOSTA À QUESTÃO 126

- a) Não, a alteração de texto do projeto não implica, necessariamente, o retorno do projeto à Casa iniciadora, já que mudança dessa natureza apenas tem relevância se houver alteração do significado normativo. Neste sentido, “Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. LC n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). MP 1.980-22/2000. (...) LC n. 101/2000. Vício formal. Inexistência. O parágrafo único do art. 65 da CF/88 só determina o retorno do projeto de lei à Casa iniciadora se a emenda parlamentar introduzida acarretar modificação no sentido da proposição jurídica”.
- b) Não, uma vez confirmada a usurpação do poder de iniciativa do Poder Executivo, mesmo a sanção do projeto de lei não tem o poder de afastar o vício de inconstitucionalidade formal.

Importante destacar que está superada a Súmula 5 do STF. Assim, a sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa.

RESPOSTA À QUESTÃO 127

- a) Sim, não há necessidade de autorização prévia da Câmara dos Deputados a fim de dar início à ação penal. Nesse sentido, há previsão no art. 53, § 3.º, da Constituição de 1988. Permite-se a abertura de processo penal no Supremo Tribunal Federal sem necessidade da licença prévia, sendo possível, apenas, pelo voto da maioria absoluta da respectiva Casa

Legislativa, sustar o andamento da ação.

- b) Sim, a jurisprudência do STF evoluiu no sentido de não manter, após o término do mandato legislativo, o foro por prerrogativa de função previsto no art. 53, § 1.º, da Constituição Federal.

Assim, era aplicada a Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal, que preservava o foro para os atos praticados no exercício do mandato, mesmo após o término deste. Porém, a súmula foi cancelada e a competência deixou de ser do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se que a atual jurisprudência do STF entende que o foro especial por prerrogativa de função não permanece após o término do exercício da função pública, devendo o processo ser remetido à Justiça ordinária competente.

XVII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 128

- a) Não, de acordo com o previsto no inciso V do art. 49 da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Congresso Nacional (o poder delegante) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa. Trata-se de verdadeiro controle político e de constitucionalidade, na modalidade repressiva, exercido pelo Poder Legislativo.
- b) Não, nos termos do art. 68, § 3.º, da Constituição Federal, ao deliberar sobre o projeto, ou o Congresso Nacional o aprova integralmente ou o rejeita em sua totalidade, sendo vedada qualquer emenda.

RESPOSTA À QUESTÃO 129

- a) Não, pois a própria Constituição Federal exige do jurisdicionado a comprovação de exaurimento na esfera administrativa antes de se dirigir ao Poder Judiciário (art. 217, § 1.º, da Constituição Federal).

Nesse sentido: “No inciso XXXV do art. 5.º, previu-se que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. (...) O próprio legislador constituinte de 1988 limitou a condição de ter-se o esgotamento da fase administrativa, para chegar-se à formalização de pleito no Judiciário. Fê-lo no tocante ao desporto, (...) no art. 217, § 1.º, (...). Vale dizer que, sob o ângulo constitucional, o livre acesso ao Judiciário sofre uma mitigação e, aí, consubstanciando o preceito respectivo de exceção, cabe tão só o empréstimo de interpretação estrita. Destarte, a necessidade de esgotamento da fase administrativa está jungida ao desporto e, mesmo assim, tratando-se de controvérsia a envolver disciplina e competições, sendo que a chamada Justiça Desportiva há de atuar dentro do prazo máximo de sessenta dias, contados da formalização do processo, proferindo, então, decisão final – § 2.º do art. 217 da CF/88” (ADIn 2.139-MC e ADIn 2.160-MC, Plenário, j. 13-5-2009, voto do rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, DJe 23-10-2009.)

b) Não, a Justiça Desportiva não faz parte do Poder Judiciário. A estrutura do Poder Judiciário brasileiro é prevista no art. 92 da Constituição Federal. As decisões da Justiça desportiva possuem natureza “administrativa” e não jurisdicional.

RESPOSTA À QUESTÃO 130

a) Não, as relações jurídicas constituídas na vigência da medida provisória caracterizam direito adquirido e João não precisará devolver o valor recebido a título de bolsa, uma vez que a não edição de decreto legislativo que regulamentasse as relações jurídicas estabelecidas pela MedProv Z, no prazo de sessenta dias após a perda de sua eficácia, acabou por implicar o reconhecimento dos efeitos jurídicos produzidos no período em que ela esteve vigente, nos termos do que informa o art. 62, § 11, da Constituição Federal.

b) Não, pois, no citado caso, tendo a medida provisória perdido sua eficácia,

vedada seria sua reedição na mesma sessão legislativa, nos termos do que informa o art. 62, § 10, da Constituição Federal.

RESPOSTA À QUESTÃO 131

a) Não, pois de acordo com o art. 58, § 2.º, I, da Constituição Federal, há projetos de lei que podem ser discutidos e votados apenas no âmbito das comissões constituídas, em razão da matéria de sua competência, na forma do Regimento Interno da Casa Legislativa, sem a necessidade de apreciação pelo Plenário, desde que não haja recurso de um décimo dos membros da respectiva Casa.

Assim, o veto do Presidente da República não encontra amparo constitucional. Nesse sentido, é constitucionalmente possível que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprove um projeto de lei que verse sobre a política externa brasileira (matéria da competência da referida Comissão) sem a necessidade de passar pelo Plenário da Casa, desde que não haja oposição de um décimo dos seus membros.

Portanto, a Constituição admite a possibilidade de se afastar a incidência do princípio da reserva de plenário, atribuindo às Comissões, em razão da matéria de sua competência, a prerrogativa de discutir, votar e decidir as proposições legislativas.

b) Não, nos termos do art. 66, § 4.º, da Constituição Federal, o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro do prazo de trinta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Esgotado o prazo de trinta dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final.

XVIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 132

- a) A 2.^a Câmara, entendendo que deva ser reconhecida a inconstitucionalidade, deverá encaminhar o exame da constitucionalidade do ato normativo em questão à apreciação do órgão especial do próprio Tribunal. Isso se deve em observância ao art. 97 da CF/88 (reserva de plenário). Ressalta-se que a manifestação do órgão especial deverá ser seguida pelo órgão fracionário quando analisar o recurso.
- b) Sim, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão da inconstitucionalidade/constitucionalidade da matéria não se envia ao Plenário ou órgão especial, nos termos da norma inserta no art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Observação: art. 949, parágrafo único, do CPC/2015).

RESPOSTA À QUESTÃO 133

- a) A lei do Estado X é inconstitucional. É necessário observar o art. 18, § 4.º, da CF/88 (redação da EC n. 15/96) que exige a edição de lei complementar federal para determinar o período de criação de Municípios por meio de lei estadual (norma constitucional de eficácia limitada que dependente de integração do legislativo federal para que todos os seus efeitos jurídicos possam ser produzidos). Ressalta-se que ainda não há a referida lei complementar. Ademais, o período da lei estadual está fora do âmbito da Emenda Constitucional n. 57/2008 (art. 96 do ADCT), evidenciando, portanto, flagrante inconstitucionalidade por omissão, já pronunciada pelo STF.
- b) O partido político possui legitimidade para a propositura de ADIn desde que possua representação no Congresso Nacional, conforme o disposto no art. 103, VIII, da CF/88 (no mesmo sentido a Lei n. 9.868/99). Importante, no caso em tela, destacar que o STF já se manifestou entendendo que o diretório municipal dos partidos políticos não tem legitimidade para a propositura de ADIn em razão de não possuir condições para atuação em âmbito nacional, pois somente os diretórios

nacionais e a executiva nacional do partido político possuem esta atribuição.

RESPOSTA À QUESTÃO 134

- a) Não, pois a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da União nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal (direito penal e direito processual). Ademais, há a previsão do art. 85, parágrafo único, da CF/88 e a Súmula Vinculante 46.
- b) Não, em razão do princípio da simetria, cuja observância, para o caso, está expressa no art. 75 da CF/88. O poder constituinte derivado decorrente (no caso a Constituição Estadual) não pode afrontar mandamento imposto pelo constituinte originário. Assim, a proposta do Governador violaria as regras estabelecidas no art. 73, § 2.º, e no art. 75, parágrafo único, ambos da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 135

- a) A Constituição Federal vigente estabelece a inviolabilidade, por opiniões, palavras e votos aos deputados estaduais (art. 27, § 1.º) e aos vereadores, nos limites da circunscrição de seu Município (art. 29, VIII). É a denominada inviolabilidade material, que se dá no exercício do respectivo mandato. Os irmãos Guilherme e Flávio se envolveram em situações que não se relacionam com a emanção de quaisquer opiniões, palavras ou votos no âmbito da atuação parlamentar, não havendo que se cogitar, portanto, de incidência da referida imunidade material.
- b) As chamadas imunidades formais ou processuais são prerrogativas aplicáveis aos deputados estaduais. Desse modo, Flávio que já foi diplomado, mesmo não tendo tomado posse, fará jus às prerrogativas decorrentes da imunidade formal, previstas no art. 53 da CF/88. Aos vereadores não se aplicam as imunidades formais, de sorte que Guilherme não se beneficiará de regras afetas à referida imunidade formal.

XIX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 136

a) Não, não caberia a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) por falta de comprovação de relevante controvérsia perante juízes e tribunais a respeito da constitucionalidade da lei. A controvérsia existente no âmbito da doutrina não torna possível o ajuizamento da ADC.

Presume-se que, no primeiro dia de vigência da lei, não houve ainda tempo hábil para a formação de relevante controvérsia judicial, isto é, não haveria decisões conflitantes de tribunais e juízes pelo Brasil.

O art. 14, III, da Lei n. 9.868/99 estabelece a necessidade de comprovação da relevante controvérsia judicial, ou seja, várias decisões judiciais nas quais a União está perdendo.

b) Sim, de acordo com o art. 21, caput, da Lei 9868/99, os efeitos da medida cautelar, em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade serão erga omnes e ex nunc, consistindo na determinação de que juízes e Tribunais suspendam o julgamento dos processos pendentes que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo que, de qualquer maneira, há de se verificar no prazo de cento e oitenta dias, nos termos do art. 21, parágrafo único, da referida lei.

A decisão caberá ao Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros. Tais efeitos são de natureza vinculante, ou seja, a concessão da medida liminar serviria para determinar que juízes e tribunais do país não pudessem afastar a incidência de qualquer dos preceitos da lei nos casos concretos, evitando, desde logo, decisões conflitantes.

RESPOSTA À QUESTÃO 137

a) No caso apresentado, o direito à ampla defesa e ao contraditório,

previsto no art. 5.º, LV, da CF/88, constitui preceito de ordem pública e não poderia ser desobedecido, mesmo no âmbito das relações privadas, configurando verdadeiro direito subjetivo de Mário.

Os direitos fundamentais dessa natureza devem ser observados tanto pelo Poder Público como pelos particulares. Nessa linha, o sistema jurídico-constitucional brasileiro tem reconhecido a possibilidade de aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Deste modo, as violações aos direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o particular e o Estado, mas igualmente nas relações estabelecidas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam, diretamente, não apenas os poderes públicos, como também estão direcionados à proteção dos particulares em face do poder privado.

b) Não, pois o inciso XXXV do art. 5.º da Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Assim, o “Estatuto” de uma entidade privada também não poderá fazê-lo.

Trata-se de dispositivo com natureza de direito fundamental, devendo ser respeitado por todos.

RESPOSTA À QUESTÃO 138

a) Não, pois o ato em questão é privativo do Poder Judiciário. Apesar de o poder de investigar constituir uma das funções institucionais do Poder Legislativo, os poderes parlamentares de investigação sofrem limitações de ordem jurídico-constitucional.

A Constituição Federal, ao conferir às CPIs “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais” (art. 58, § 3.º), delimitou a natureza de suas competências, mas não permitiu o exercício daqueles atos privativos do Poder Judiciário, como a decretação de indisponibilidade de bens e a diligência de busca e apreensão de documentos em escritório. Trata-se de

reserva constitucional de jurisdição, ou seja, tais atos somente podem ser praticados por magistrados.

b) Sim, é entendimento do Supremo Tribunal Federal que uma Comissão Parlamentar de Inquérito possui poderes próprios das autoridades judiciais para, em decisão fundamentada, determinar a quebra de sigilo fiscal e bancário, pois o que está em jogo é o acesso a informações já existentes.

RESPOSTA À QUESTÃO 139

a) Sim, pois, nesse caso, há o fenômeno da recepção, que corresponde a uma revalidação das normas que não contrariam, materialmente, a nova Constituição. A lei anterior não pode violar materialmente a nova Constituição, pouco importando qual a forma com que se revista.

Não se deve conferir importância a eventual incompatibilidade de forma com a nova Constituição, pois a forma é regida pela lei da época do ato (*tempus regit actum*). Assim, mesmo que o ato normativo seja veiculado por instrumento diverso daquele que a nova Carta exige para a regulação de determinada matéria, permanecerá em vigor e válido se houver concordância material (direito), ou seja, no seu conteúdo, com as novas normas constitucionais.

b) Lei complementar. A partir da promulgação da nova Constituição, a Lei n. 1.234 foi recepcionada como "lei complementar"; portanto, diante da reserva constitucional expressa, qualquer alteração no seu texto deverá ser realizada por intermédio desta espécie legislativa.

XX EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 140

a) Sim. A proposição da Medida Provisória é constitucional nos termos do art. 2.º da Emenda Constitucional n. 32/2001, que estabelece que as

medidas provisórias antigas, editadas em data anterior à promulgação daquela EC, continuam em vigor até que venham a ser revogadas ou apreciadas pelo Congresso Nacional.

Levando em consideração que a data da Emenda Constitucional n. 32 é de 11 de setembro de 2001, é correto afirmar que a medida provisória editada em 10 de setembro de 2001 ainda se encontra em vigor. Destaque-se que todas as medidas provisórias editadas anteriormente à Emenda Constitucional n. 32 de 11 de setembro de 2001, continuam em vigor até hoje, se não foram rejeitadas pelo Congresso Nacional ou revogadas por outra medida provisória do Presidente da República.

b) Não. A medida provisória objeto da questão é duplamente inconstitucional. Em primeiro lugar, porque estaria regulando matéria vedada a medida provisória, nos termos do art. 62, § 1.º, I, a, ou seja, matéria relativa à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos (situação jurídica do estrangeiro no Brasil). Em segundo lugar, tal medida provisória seria incompatível com a CF/88, nos termos do art. 62, § 1.º, I, b, isto é, estaria versando sobre matéria de direito processual civil (Código de Defesa do Consumidor).

RESPOSTA À QUESTÃO 141

a) As normas materialmente constitucionais possuem status constitucional em razão do seu conteúdo, pois estabelecem normas referentes à estrutura organizacional do Estado, à separação dos Poderes e aos direitos e garantias fundamentais, enquanto as normas formalmente constitucionais só possuem o caráter de constitucionais porque se encontram na Constituição, ou seja, foram elaboradas com o uso do processo legislativo próprio das normas constitucionais.

b) O entendimento externado pela Advocacia-Geral da União à imprensa está incorreto, pois, independentemente da essência da norma, todo dispositivo que estiver presente no texto constitucional, em razão da

rigidez constitucional, só poderá ser alterado por emendas constitucionais, como previsto no art. 60 da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 142

- a) Há um vício formal de constitucionalidade (inconstitucionalidade por ação formal), pois a Lei Estadual viola o art. 22, I, da CF/88, que dispõe ser da competência privativa da União legislar sobre direito civil, já que trata de perda da propriedade.
- b) O Governador é um dos legitimados ativos à propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de acordo com o art. 103, V, da CF/88. A pertinência temática deve ser demonstrada e é possível questionar esse ato normativo por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de acordo com o art. 102, I, a, da CF/88 e a Lei n. 9.868/99.

RESPOSTA À QUESTÃO 143

- a) Sim. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, nos cargos sujeitos ao sistema proporcional (deputados federais, deputados estaduais e vereadores) previsto no art. 45, caput, da CF/88, o mandato eletivo pertence ao partido político, e não ao parlamentar. No caso em tela, o abandono de legenda pelo Deputado Federal “X” enseja a extinção do seu mandato parlamentar, porque não há a caracterização de justa causa, ou seja, mudanças na ideologia do partido ou criação de um novo partido político. Portanto, a iniciativa deve ser julgada procedente, em atenção às características do sistema proporcional, cuja ênfase é dada aos votos obtidos pelos partidos políticos, e não pelos parlamentares.
- b) Não. A solução jurídica não deve ser a mesma, porque, nos cargos sujeitos ao sistema majoritário (Presidente da República, Governador, Prefeito e Senador), o mandato eletivo pertence ao político (parlamentar) e não ao partido político. Nesse caso, o abandono de legenda pelo Senador “Y” não enseja a extinção do seu mandato parlamentar, porque o

sistema majoritário se caracteriza pela ênfase na figura do candidato, daí a jurisprudência do STF no sentido da inaplicabilidade da regra de perda do mandato por infidelidade partidária. Portanto, a iniciativa deve ser julgada improcedente, em atenção ao princípio da soberania popular. Ou seja, no caso em tela, a mudança de partido feita pelo Senador “Y”, sem qualquer justa causa, não frustra a vontade do eleitor e não viola o princípio da soberania popular (art. 1.º, parágrafo único, e art. 14, caput, ambos da CF/88).

XXI EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 144

- a) O Governador não possui razão, pois o que o art. 86, § 4.º, da CF/88 confere ao Presidente da República não é imunidade penal, mas imunidade temporária à persecução penal que impede a sua responsabilização enquanto não finalizar sua investidura no cargo de Presidente da República.
- b) Sim, o Ministério Público poderia ajuizar a ação penal de modo imediato em face do Governador, pois ele não goza da imunidade temporária à persecução penal outorgada ao Presidente da República pelo art. 86, § 4.º, da CF/88. Essa proteção é unicamente compatível com a condição institucional de chefe de Estado, e não com a de chefe de Governo. Nesse sentido, a aplicação da simetria no caso em questão violaria o princípio republicano, previsto no art. 1.º, caput, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 145

- a) Sim, a Lei Estadual n. 1.234/2015 apresenta vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que apenas lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo pode criar órgãos de apoio ao Poder Executivo. É o que dispõe o art. 61, § 1.º, II, e, da CF/88, aplicável pelo princípio da simetria aos Estados.

b) Não, o Governador não pode propor a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude do princípio da subsidiariedade dessa ação, previsto no art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9882/99. Assim, o Governador deveria propor uma de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

RESPOSTA À QUESTÃO 146

- a) Carla não pode se candidatar ao cargo de governador do Estado Beta, pois a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal em razão do divórcio no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, conforme é o conteúdo da Súmula Vinculante 18 do STF.
- b) Não, a orientação constante na Súmula Vinculante 18 do STF não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Essa é a posição do STF conforme tese de repercussão geral reconhecida no RE n. 758.461.

RESPOSTA À QUESTÃO 147

- a) Sim, há vício de inconstitucionalidade formal na norma municipal, pois deveria ter sido iniciada pela Câmara Municipal, conforme há previsão expressa do art. 29, V, da CF/88. Além disso, também há inconstitucionalidade material na lei municipal, pois o vício de iniciativa ofende o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2.º da CF/88.
- b) Não, a medida judicial adotada pelo vereador está incorreta, pois a norma municipal não pode ser objeto de ADIn perante o STF, conforme estabelece o art. 102, I, a, da CF/88.

XXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 148

- a) Sim, a Emenda Constitucional viola uma cláusula pétrea, ou seja, limitações constitucionais de ordem material ao determinar que as novas

regras que alteram o regime das coligações eleitorais dos partidos políticos já deverão ser observadas no mesmo ano da sua promulgação. Há violação do princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da CF/88, que, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, representa garantia individual do cidadão, titular do poder exercido pelos representantes eleitos.

Repise-se, viola a referida emenda constitucional o princípio da anterioridade eleitoral, que é uma garantia fundamental do cidadão-eleitor que tem o direito de receber, do Estado, o necessário grau de segurança e de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral.

Portanto, a referida Emenda Constitucional violou uma cláusula pétrea nos termos do art. 60, § 4.º, IV, da CF/88, transcendendo, pois, os limites constitucionais de ordem material, estabelecidos ao poder constituinte derivado reformador.

b) Não, a Emenda Constitucional n. 52/2006 alterou o texto do art. 17, § 1.º, da CF/88, conferindo plena autonomia aos partidos políticos para definir o regime de suas coligações eleitorais, extinguindo a chamada verticalização das coligações partidárias.

Deste modo, tal verticalização já não mais existe no direito constitucional brasileiro. A partir da referida emenda constitucional, as coligações partidárias realizadas em âmbito nacional deixaram de ser obrigatórias em âmbito estadual, distrital ou municipal. Assim, não há qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal.

RESPOSTA À QUESTÃO 149

a) Não, nos termos da Súmula Vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal, “o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.” Neste sentido, não se desviou do ordenamento jurídico-constitucional a

Administração Pública estadual ao deixar de conceder o auxílio-alimentação a Roberto quando passou à inatividade.

É o que se conclui do texto constitucional previsto no art. 103-A, quando afirma que a súmula vinculante, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

b) Não, prepondera a teoria de que não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada na análise do caso concreto. Dessa forma, conclui-se que os direitos fundamentais, incluindo os sociais, não possuem escala hierárquica prévia, inexistindo prevalência dos direitos fundamentais sociais sobre o direito à alimentação e vice-versa.

Assim, o princípio da ponderação ou harmonização (ou concordância prática) consiste em uma sugestão ou recomendação para que o operador do direito ou intérprete, deparando-se com situação de concorrência de direitos, adote uma solução que otimize a realização de todos eles e, ao mesmo tempo, não acarrete a negação de nenhum deles.

RESPOSTA À QUESTÃO 150

a) A norma municipal é inconstitucional, pois foram violadas as normas previstas no art. 18, § 4.º, da CF/88. Compete ao Estado autorizar, mediante lei ordinária, o desmembramento do município, desde que:

1) seja realizado um plebiscito (consulta pública prévia) com a participação dos munícipes afetados; 2) seja apresentado e publicado Estudo Prévio de Viabilidade Municipal; 3) se respeitem os prazos previstos em lei complementar federal, a qual, por ainda não existir, inviabiliza a criação de novos Municípios.

b) Não é possível, atualmente, nem a criação, nem o desmembramento e nem a fusão de municípios até que seja editada a lei complementar

federal, prevista no art. 18, § 4.º, da CF/88, que discipline os prazos para tais atos. O STF decidiu acerca do tema na ADIn 2.702/PR e na ADIn 2.632/BA.

RESPOSTA À QUESTÃO 151

a) Sim, porque o direito brasileiro não admite a inconstitucionalidade formal superveniente. O decreto presidencial de 1975 foi recepcionado pela nova Constituição, na medida em que não há nenhuma incompatibilidade material com este paradigma de análise, ou seja, não há nenhuma vedação à construção de usinas nucleares, bem como nenhuma proibição constitucional acerca da sua localização no Município Alfa. Portanto, a inexistência de incompatibilidade material entre a nova ordem constitucional e o decreto presidencial de 1975 indica que este ato normativo foi recepcionado pela nova Constituição.

No direito brasileiro, o fenômeno da recepção analisa tão somente a compatibilidade material (direitos) perante a nova Constituição, não importando a forma do ato normativo, daí a inexistência de inconstitucionalidade formal superveniente. No caso, a evidente incompatibilidade da forma do ato normativo (decreto presidencial ao invés de lei federal) não é suficiente para impedir sua recepção.

b) Não, porque o decreto presidencial de 1975 foi recepcionado pela nova ordem constitucional com o status de lei federal, já que a norma infraconstitucional que não contrariar materialmente a nova Constituição será recepcionada, devendo, inclusive, adquirir a natureza que a nova Constituição estabelece para a matéria que regula. Foi exatamente esse o caso do decreto presidencial de 1975, que foi recepcionado com eficácia de lei federal, no que se refere à localização da usina nuclear, não podendo, portanto, ser alterado por outro decreto presidencial. Hoje, seria necessária a edição de uma lei federal para autorizar a nova localização da usina no Município Beta, nos termos do art. 225, § 6.º, da CFRB/88.

XXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 152

a) O tratado foi aprovado de acordo com o procedimento previsto no art. 5.º, § 3.º, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, logo, é formalmente válido. Além disso, o fato de destoar da Constituição da República, por ter ampliado um direito, não caracteriza qualquer violação às cláusulas pétreas previstas no art. 60, § 4.º, da CF/88, preceito que lhe é aplicável por ter a natureza de emenda constitucional. Portanto, é materialmente válido.

Em suma, não violou procedimento (formal) e nem direito (material) da Constituição Federal.

b) O tratado aprovado na forma indicada está sujeito ao controle concentrado de constitucionalidade por ser equivalente a uma emenda constitucional, consoante o disposto no art. 102, I, a, da CF/88, tendo a natureza de ato normativo.

RESPOSTA À QUESTÃO 153

a) O senador José não poderia ser responsabilizado civilmente, pois é inviolável por suas opiniões e palavras vinculadas ao exercício do mandato (art. 53, caput, da CF/88), sendo certo que compete ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar os entes da Administração indireta (art. 49, X, da CF/88). Possui, portanto, imunidade material, também conhecida por absoluta ou inviolabilidade. Já o vereador João poderia ser responsabilizado, pois a inviolabilidade por suas opiniões e palavras é restrita à circunscrição do Município e ao exercício do mandato (art. 29, VIII, da CF/88).

b) O senador José possui imunidade formal, relativa ou imunidade propriamente dita, consistente na impossibilidade de ser preso, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável (art. 53, § 2.º, da CF/88) e na

possibilidade de a tramitação do processo penal que venha a responder ser sustada por deliberação do Senado Federal (art. 53, § 3.º, da CF/88). O vereador João, por sua vez, não possui imunidade formal, relativa ou imunidade propriamente dita (art. 29, VIII, da CF/88).

RESPOSTA À QUESTÃO 154

- a) Sim, um estrangeiro, como Ernesto, possui o direito à obtenção da nacionalidade brasileira, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 12, II, b, da CF/88.
- b) Não, o estrangeiro que preenche os requisitos exigidos, inclusive aquele originário dos países que adotam a língua portuguesa, possui direito subjetivo à nacionalidade brasileira, nos termos do contido no art. 12, II, a, da CF/88

RESPOSTA À QUESTÃO 155

- a) Qualquer pessoa é parte legítima para representar ilegalidades perante o Conselho Nacional de Justiça, de acordo com o direito de petição ou direito de apresentar reclamação, previsto no art. 5.º, XXXIV, a, da CF/88 ou art. 103-B, § 4.º, III, da CF/88.
- b) Não, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, de acordo com o art. 5.º, LV, da CF/88. O direito fundamental à defesa do juiz, não pode ser prejudicado ou relativizado por conduta não prevista na Constituição da República.

XXIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 156

- a) Sim, o art. 123 da Constituição do Estado Alfa é materialmente inconstitucional, uma vez que ampliou, aos municípios com número de habitantes superior a cinco mil, a imposição que a CF/88 fez àqueles com

mais de vinte mil (art. 182, § 1.º, da CF/88). Assim, violou o princípio da autonomia dos Municípios com mais de cinco mil e até vinte mil habitantes, como é o caso do Município Delta, que possui seis mil habitantes.

- b) Sim, o caso apresentado representa um nítido exemplo de violação da autonomia dos Municípios, prevista no art. 18 da CF/88. O art. 123 da Constituição do Estado Alfa afronta a autonomia municipal, que é um princípio constitucional sensível ou expresso, conforme previsão do art. 34, VII, c, da CF/88, assim, representa uma das hipóteses de Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva federal proposta pelo PGR junto ao STF, nos termos do art. 36, III, da CF/88. O PGR deve propor Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva federal por violação de princípio constitucional sensível.

RESPOSTA À QUESTÃO 157

- a) No caso apresentado há o desmembramento, ou seja, o estado original perde uma parte de seu território e de sua população, que passa a formar um novo Estado. O art. 18, § 3.º, da CF/88, prevê a ocorrência desse fenômeno, sendo necessária a aprovação da população interessada por um plebiscito e a edição de uma lei complementar pelo Congresso Nacional.
- b) Não, o termo secessão é utilizado em direito constitucional para definir a separação de um Estado-membro ou território em relação ao país do qual fazia parte. O Brasil, por ser uma Federação (art. 1.º da CF/88), é indissolúvel. Aliás, sendo a forma federativa de Estado cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4.º, da CF/88, não é possível por via de emenda constitucional a secessão.
- c) Não, pois a CF/88 atribuiu aos Estados-membros a denominada competência residual, remanescente ou reservada (art. 25, § 1.º, da CF/88), ou seja, as matérias não expressas ou não enumeradas no rol de

competências dos entes federados são da competência dos Estados-membros.

RESPOSTA À QUESTÃO 158

- a) Do mesmo texto, pode ser obtida uma nova norma constitucional em razão das alterações verificadas na realidade, as quais influenciarão o processo de interpretação constitucional. Trata-se do processo informal de alteração da Constituição conhecido como “mutação constitucional”.
- b) Não há obstáculo ao ajuizamento de nova ação direta de inconstitucionalidade tendo a Lei Federal W como objeto, já que, no caso concreto, o pedido apresentado na primeira ação foi julgado improcedente e o cotejo será realizado com normas constitucionais de sentido e alcance diversos daquelas que embasaram a prolação do primeiro acórdão.

RESPOSTA À QUESTÃO 159

- a) Segundo o art. 14, § 7.º, da CF/88, o cônjuge do ocupante do cargo de governador é inelegível no território de jurisdição do titular do cargo, salvo se já fosse titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. No caso concreto, Antônio da Silva é alcançado pelo instituto na inelegibilidade reflexa, já que, marido da governadora e sem exercer qualquer cargo eletivo, não poderia, por conclusão lógica, ser candidato a senador ou governador. O fato de estarem divorciados não altera a situação de Antônio da Silva, pois segundo a Súmula Vinculante 18 do STF, “a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7.º, da Constituição Federal”. Assim sendo, não poderá Antônio da Silva concorrer a qualquer cargo no Estado Alfa.
- b) Sim, por força do que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no âmbito da Tese de Repercussão Geral n. 678 (“A Súmula Vinculante 18 do STF não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um

dos cônjuges”). Assim, a ocorrência do óbito da governadora teria o condão de afastar a inelegibilidade de Antônio da Silva, que estaria, no caso, habilitado a concorrer a qualquer um dos cargos citados.

XXV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 160

- a) Se o Congresso Nacional entender que o Decreto X exorbitou do poder regulamentar, é possível sustar os seus efeitos, editando um decreto legislativo (art. 59, VI, da CF/88) com fundamento no art. 49, V, da CF/88.
- b) O decreto legislativo de sustação tem a natureza jurídica de ato normativo primário, pois é previsto no art. 59, VI, da CF/88, sendo passível de impugnação por ação direta de inconstitucionalidade (art. 102, I, a, da CF/88). O Presidente da República, portanto, tem legitimidade para ajuizar essa ação (art. 103, I, da CF/88), com o objetivo de reconhecer a inconstitucionalidade do decreto legislativo, argumentando que o Decreto X estava circunscrito à esfera de competências do Chefe do Executivo.

RESPOSTA À QUESTÃO 161

- a) A norma é inconstitucional, pois na Constituição Federal Brasileira, o art. 37, XVI, c, somente permite a acumulação remunerada de 2 (dois) cargos ou empregos de profissionais da área de saúde, sendo de observância obrigatória pela Lei Orgânica Municipal, conforme dispõe o art. 29, caput, da CF/88.
- b) A norma da Lei Orgânica, por ter natureza municipal, pode ser objeto da representação por inconstitucionalidade estadual no Tribunal de Justiça, na forma do art. 29 e do art. 125, § 2.º, ambos da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 162

- a) Não, o Prefeito Municipal ou quem o houver sucedido ou substituído no

curso do mandato somente poderá ser reeleito para um período subsequente, nos termos do art. 14, § 5.º, da CF/88. Apesar de Pedro estar se candidatando pela primeira vez ao cargo de Prefeito do Município Alfa, a limitação constitucional a uma única reeleição indica a impossibilidade de uma pessoa ocupar esse cargo mais de duas vezes consecutivas.

- b) Não, da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que contrarie a Constituição da República cabe recurso (rectius: especial), nos termos do art. 121, § 4.º, III, da CF/88. Não será atendido, portanto, o requisito da subsidiariedade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, conforme dispõe o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99.

RESPOSTA À QUESTÃO 163

- a) O instrumento processual a ser utilizado, em razão da impossibilidade de exercer direitos e liberdades constitucionais por ausência de regulamentação, é o Mandado de Injunção (art. 5.º, LXXI, da CF/88 e Lei n. 13.300/2016).
- b) O órgão do Poder Judiciário que deverá apreciar o mandado de injunção é o Supremo Tribunal Federal, porque a edição da norma regulamentadora é de competência do Congresso Nacional, a partir de iniciativa do Presidente da República, nos termos do art. 102, I, q, da CF/88.
- c) Os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal serão aqueles previstos no art. 8.º da Lei n. 13.300/2016, isto é, ao reconhecer o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados.

RESPOSTA À QUESTÃO 164

- a) A Lei n. 123/2010, ao não permitir a instalação de outra loja de material de construção no Bairro, ofendeu o princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, IV, da CF/88. Neste sentido, há a Súmula Vinculante 49, onde se lê: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.
- b) Como a decisão administrativa afrontou a Súmula Vinculante 49 e foi exaurida a instância administrativa, a sociedade empresária Vertical tem legitimidade para ajuizar uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 7.º, caput e § 1.º, da Lei n. 11.417/2006 ou art. 103-A, § 3.º, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 165

- a) Como a Ação Direta de Inconstitucionalidade se destina apenas ao controle de constitucionalidade dos atos normativos, nos termos do art. 102, I, a, da CF/88, e não ao controle de legalidade, não seria possível utilizá-la para impugnar somente o Decreto n. 45/2017. Nesse caso, a ofensa à Constituição é apenas reflexa, não direta.
- b) A Lei n. 123/2017, por ser norma estadual, pode ser impugnada via Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 102, I, a, da CF/88. O Decreto n. 45/2017, por sua vez, apesar de encontrar o seu fundamento de validade na lei, pode ter a inconstitucionalidade declarada por arrastamento, o que possibilita a sua inclusão no objeto da ação.

RESPOSTA À QUESTÃO 166

- a) A legislação acerca de regime dos portos é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, X, da CF/88. Portanto, a Assembleia Legislativa somente pode legislar sobre questões específicas afetas ao tema, por meio da Lei Estadual Y, caso haja a devida autorização pelo

Congresso Nacional, por lei complementar, conforme disciplina constante no art. 22, parágrafo único, da Constituição da República. Caso contrário, a Lei Estadual Y é formalmente inconstitucional, posto estar presente uma inconstitucionalidade formal orgânica.

- b) O Governador do Estado Beta, como legitimado pelo art. 103, V, da CF/88, em princípio, pode atacar a Lei Y (ato normativo estadual), por via de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do que preceitua o art. 102, I, a, da CF/88. Porém, de acordo com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo sua legitimidade especial, terá que demonstrar a devida pertinência temática, ou seja, no caso, evidenciar que a Lei Y do Estado Alfa afeta os interesses do seu Estado, o Beta.

RESPOSTA À QUESTÃO 167

- a) Conforme o art. 36, § 1.º, da CF/88, o decreto de intervenção, expedido pelo Presidente da República, deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de vinte e quatro horas após a sua expedição. Embora, no caso em tela, haja a necessidade de controle político, ele é realizado a posteriori, não previamente.
- b) O Presidente da República não ultrapassou os limites concedidos pela Constituição da República quando decretou a intervenção federal, pois, embora fosse obrigatória a oitiva dos Conselhos da República (art. 90, I, da CF/88) e de Defesa Nacional (art. 91, § 1.º, II, da CF/88) suas manifestações não possuem caráter vinculante em relação aos atos a serem praticados pelo Presidente da República, mas meramente consultivo, conforme dispõe o caput dos arts. 89 e 91.

XXVII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 168

- a) A Lei Federal X é formalmente compatível com a CF/88, pois compete à União legislar sobre direito eleitoral, nos termos do art. 22, I, da CF/88, e materialmente incompatível com a CF/88, pois determina sua aplicação às eleições que ocorrerão antes de doze meses de sua vigência, o que afronta o art. 16 da CF/88.
- b) O partido político Alfa não conta com representantes no Congresso Nacional, logo, não tem legitimidade para iniciar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 103, VIII, da CF/88 OU o art. 2.º, VIII, da Lei n. 9.868/99.

RESPOSTA À QUESTÃO 169

- a) A medida judicial que poderia ser ajuizada, pelo Procurador-Geral da República, é o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, isso em razão da grave violação de direitos humanos, conforme dispõe o art. 109, § 5.º, da CF/88.
- b) A medida judicial não deveria ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, já que ajuizada no dia seguinte aos fatos, não existindo notícia de inércia ou ineficiência das autoridades estaduais na apuração dos delitos. Exige-se que a atuação federal ocorra em caráter subsidiário, conforme reiterada interpretação do Tribunal a respeito do art. 109, § 5.º, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 170

- a) Não, o Secretário de Estado deveria ter informado a Pedro o local onde pode ser obtida a informação desejada, nos termos do art. 5.º, XXXIII, da CF e do art. 7.º, I, da Lei n. 12.527/2011.
- b) Não, Pedro tem o direito de receber informações de interesse geral, nos termos do art. 5.º, XXXIII, da CF/88 OU da Lei n. 12.527/2011, como são aquelas relacionadas à execução orçamentária, as quais não são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, o que afasta a tese do sigilo.

RESPOSTA À QUESTÃO 171

- a) Não, é vedada a vinculação da receita de impostos a despesas específicas, ressalvadas apenas as exceções constitucionais, conforme dispõe o art. 167, IV, da CF/88.
- b) Não, a programação financeira deve ser estabelecida na Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 167, I, da CF/88, a qual conta com rito próprio de tramitação e não pode ser substituída pela Constituição do Estado.

XXVIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB FGV

RESPOSTA À QUESTÃO 172

- a) A Lei n. 123/2018 é formalmente inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre trânsito, nos termos do art. 22, XI, da CF/88.
- b) Se a lei municipal apenas estabelecer a velocidade máxima a ser observada nas vias urbanas do Município seguindo o limite da legislação federal, não padecerá de qualquer vício de inconstitucionalidade formal, neste último caso por consubstanciar matéria de interesse local, o que atrai a competência legislativa do Município, nos termos do art. 30, I, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 173

- a) O autor deve promover o aditamento da petição inicial, para se estender à lei de conversão a impugnação originariamente proposta.
- b) A revogação da Medida Provisória n. 123/2017 acarretaria a perda superveniente do interesse processual, com a consequente perda de objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade. A não ser assim, o processo objetivo se transformaria em instrumento de proteção de situações concretas.

RESPOSTA À QUESTÃO 174

- a) Sim, as coligações eleitorais formadas em âmbito nacional, visando à eleição majoritária para a Chefia do Poder Executivo (Presidente da República), não estão vinculadas àquelas celebradas no âmbito estadual para as eleições proporcionais (deputados), conforme dispõe o art. 17, § 1.º, da CF/88.
- b) O Tribunal Superior Eleitoral é competente para examinar o recurso interposto, com base no art. 121, § 4.º, I, da CF/88, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que contrarie a ordem constitucional. Assim ocorre porque o Supremo Tribunal Federal somente aprecia recursos dessa natureza em relação às causas decididas em única ou última instância, nos termos do art. 102, III, da CF/88, o que não é o caso, bem como porque a última instância é o Tribunal Superior Eleitoral, cujas decisões, caso contrariem a Constituição, serão recorríveis, nos termos do art. 121, § 3.º, para o Supremo Tribunal Federal.

RESPOSTA À QUESTÃO 175

- a) Não, a ordem constitucional veda a retroação de normas punitivas. Trata-se de princípio implícito, extraído do art. 5.º, XXXIX, da CF/88, segundo o qual “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

Assim, a tese da autoridade administrativa, no sentido de que a retroação da tipificação da infração não é vedada pela Constituição da República, está incorreta.

- b) Sim, em que pese o advogado ser indispensável à administração da justiça, como previsto no art. 133 da CF/88, de outro modo há o verbete da Súmula Vinculante 5 do STF, “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

RESPOSTA À QUESTÃO 176

- a) A lei estadual é formalmente incompatível com a Constituição da República, pois a suspensão dos direitos políticos impõe restrições à cidadania, sendo que a União possui competência legislativa privativa para legislar sobre essa matéria, nos termos do art. 22, XIII, da CF/88. Além disso, é materialmente inconstitucional, pois a suspensão dos direitos políticos deve manter-se operativa enquanto durarem os efeitos da sentença criminal transitada em julgado, qualquer que seja a pena aplicada, nos termos do art. 15, III, da CF/88.
- b) O Deputado Estadual pode preservar o seu mandato, mesmo tendo os direitos políticos suspensos, caso assim o decida a Casa Legislativa, segundo o art. 55, VI e § 2.º, c/c o art. 27, § 1.º, da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 177

- a) José, por ser cidadão, qualidade intrínseca à sua condição de vereador, pode ajuizar Ação Popular para anular o ato lesivo ao patrimônio público, nos termos do art. 5.º, LXXIII, da CF/88 ou do art. 1.º, caput, da Lei n. 4.717/65.
- b) O polo passivo deve ser ocupado por Ednaldo, que assinou o contrato lesivo ao patrimônio público (art. 6.º, caput, da Lei n. 4.717/65); por Pedro e Marcos, que dele se beneficiaram (art. 6.º, caput, da Lei n. 4.717/65); e pela autarquia XX do Estado Alfa, por se almejar a anulação de um contrato celebrado por ente da Administração Pública indireta (art. 6.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65).

RESPOSTA À QUESTÃO 178

- a) Não, a autonomia municipal, prevista no art. 18, caput, c/c o art. 25, caput, ambos da CF/88, impede a vinculação dos prefeitos municipais às diretrizes políticas de autoridade vinculada a outro nível federativo.
- b) Não, é atribuição do chefe do Poder Executivo municipal nomear os

secretários municipais, independentemente de prévia aprovação da Câmara Municipal, conforme dispõe o art. 84, I, c/c o art. 25, caput, e o art. 29, caput, todos da CF/88, sendo que o previsto na Constituição Estadual também afronta o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2.º da CF/88.

RESPOSTA À QUESTÃO 179

- a) Não. Compete privativamente à União legislar sobre registros públicos, nos termos do art. 22, XXV, da CF/88, e a autorização para que os Estados legislem sobre a matéria deve ser veiculada em lei complementar, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único, da CF/88. No entanto, nos termos do art. 62, § 1.º, III, da CF/88, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar, como é o caso.
- b) Não. Por imposição do art. 62, § 9.º, da CF/88, a Medida Provisória n. XW/2018 deve ser previamente submetida a uma comissão mista de Deputados e Senadores, antes de sua apreciação pelo plenário de cada Casa do Congresso Nacional.

Referências

- AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.
- BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 11. ed. Brasília: UNB, 1998.
- BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
- BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.
- CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.
- CAPEZ, Fernando; CHIMENTI, Ricardo Cunha; ROSA, Márcio F. Elias; SANTOS, Marisa F. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- COMPARATO, Fábio Konder. A formação histórica dos direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- CONGRESSO NACIONAL. Constituição da República Federativa do Brasil.

Brasília: de 5 de outubro de 1988.

CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992.

DANTAS, Ivo. Instituições de direito constitucional brasileiro. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2001.

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 3.

FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

_____. Enciclopédia Saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 62.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

_____. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

_____. Direitos humanos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

GOLDZVEIG, Gustavo. Comentários à convenção americana de direitos humanos. São Paulo: Litera, 2012.

GOMES, Luiz Flávio. Estado constitucional de direito e a nova pirâmide jurídica. São Paulo: Premier Máxima, 2008.

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Evolução institucional do ministério público brasileiro. São Paulo: Atlas, 1997.

MARCATO, Antonio Carlos (Coord.). Código de processo civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MENDES, Gilmar Ferreira e outros. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, São Paulo, 2007.

MONTENEGRO FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado. São Paulo: Atlas, 2008.

_____. Curso de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. v. 1-3.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

_____. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MOTA, Leda Pereira; SPITZCOVISKY, Celso. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: RT, 2007.

_____. Constituição federal comentada e legislação constitucional. São Paulo: RT, 2006.

NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Método, 2008.

NUNES JÚNIOR, Flávio Martins Alves. Remédios constitucionais. São Paulo: Premier Máxima, 2008.

OLIVEIRA, Erival da Silva. Comissão parlamentar de inquérito. São Paulo: Lumen Juris, 2000.

_____. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: RT, 2016.

_____. Direito humanos. 5. ed. São Paulo: RT, 2016.

_____. Direito em áudio. 3. ed. São Paulo: RT, 2013.

_____. Direitos das pessoas com deficiência. São Paulo: Saraiva, 2019.

_____. Exames de OAB – Testes e comentários. 4. ed. São Paulo: Premier Máxima, 2007.

_____. Exames de OAB Nacional – Testes e comentários. São Paulo:

Premier Máxima, 2005.

_____. Exame de Ordem e Concursos. São Paulo: Saraiva, 2019.

_____. Introdução ao estudo do direito constitucional. São Paulo: Artchip, 2003.

_____. Manual funcional de direitos humanos para concursos. São Paulo: RT, 2013.

_____. Manual de direitos humanos para concursos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

_____. Questões comentadas dos exames de OAB. 2. ed. São Paulo: RT, 2010.

_____. Resumo de bolso. Direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Premier Máxima, 2008.

_____. Resumo de bolso. Direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Premier Máxima, 2008.

_____. Resumo de bolso. Remédios constitucionais e súmula vinculante. São Paulo: Premier Máxima, 2008.

_____. Reta final. Direito constitucional – Parte I. 5. ed. São Paulo: RT, 2011.

_____. Reta final. Direito constitucional – Parte II. 5. ed. São Paulo: RT, 2011.

_____. Reta final. Direitos humanos. 5. ed. São Paulo: RT, 2012.

_____. Reta final. Remédios constitucionais e súmulas vinculantes. São Paulo: RT, 2010.

_____. Vade Mecum Conjugado: administrativo, constitucional e tributário. São Paulo: Saraiva, 2019.

PEIXOTO, Paulo Henrique Lêdo. Comentário ao estatuto da igualdade racial.

São Paulo: Litera, 2012.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional Internacional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

POLETTI, Ronaldo. Controle da constitucionalidade das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos em juízo. São Paulo: Max Limonad, 2001.

SIDOU, J. M. Othon. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular. As garantias ativas dos direitos coletivos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.

_____. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: RT, 1982.

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002.

ZIMMERMANN, Augusto. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

1. ASSUNTOS DE MAIOR INCIDÊNCIA NAS PEÇAS DE SEGUNDA FASE EM DIREITO CONSTITUCIONAL

Após levantamento feito nas últimas provas da OAB, constatou-se que as peças mais recorrentes são as seguintes:

- Mandado de Segurança Individual;
- Reclamação Constitucional;
- Mandado de Segurança Coletivo;
- Habeas Corpus;
- Habeas Data;
- Ação Direta de Inconstitucionalidade;
- Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão;
- Mandado de Injunção;
- Ação Popular;
- Recurso Extraordinário;
- Recurso Ordinário Constitucional;
- Apelação em Mandado de Segurança;
- Ação Ordinária com Tutela Antecipada;
- Parecer;
- Ação Civil Pública.

2. TEMAS RECORRENTES NAS QUESTÕES DISSERTATIVAS

No que diz respeito às questões discursivas, verificou-se uma enorme variedade de assuntos, porém os de maior incidência são os seguintes:

- Controle de Constitucionalidade;
- Ação Direta de Inconstitucionalidade;
- Iniciativa Legislativa;
- Mandado de Segurança;
- Competência (Medida Provisória);
- Competência Legislativa;
- Competência Legislativa Privativa e Concorrente;
- Emenda Constitucional;
- Pertinência Temática;
- Reclamação Constitucional;
- Mandado de Injunção;
- Presidente da República;
- Simetria Federativa;
- Procurador-Geral da República;
- Reajuste dos Servidores Públicos;
- Aborto Anencéfalo e Direito à Vida;
- Habeas Corpus;
- Transferência Compulsória de Militar e Matrícula em Faculdade;
- Direitos Fundamentais;
- Recurso Extraordinário;
- Precatório;
- Honorários de Advogado;
- Ação Civil Pública;

- Perda do Cargo de Parlamentar;
- Legitimidade;
- Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental;
- Intervenção Federal e Estadual;
- Internacionalização de Tratado Internacional;
- Advocacia-Geral da União;
- Taxa de Limpeza Urbana;
- Inelegibilidade Reflexa;
- Novos Municípios;
- Militares e Direitos Políticos;
- Afastamento de Deputado Federal para Assumir Secretaria Municipal de Capital;
- Congresso Nacional – Decreto Legislativo;
- Súmula Vinculante;
- Lei Orçamentária;
- Desapropriação;
- Responsabilidade Objetiva do Estado;
- Poder Legislativo;
- Poder Executivo;
- Poder Judiciário;
- Tratados Internacionais de Direitos Humanos – Incorporação e controle de constitucionalidade;
- Comissão Parlamentar de Inquérito;
- Imunidade Parlamentar;
- Direitos Políticos;

- Nacionalidade;
- Da Ordem Social.

1 Disponível em: [<http://www.stf.jus.br/porta/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306614>]. Acesso em: 17 dez. 2015.

2. Veja notícia: “STF reafirma rito aplicado ao processo de impeachment de Fernando Collor” na Primeira Parte – capítulo 6.

1. Importante: As provas 2006.1 até 2015.3 foram fundamentadas no Código de Processo Civil de 1973 (até então em vigor no momento da aplicação das provas). No entanto, sempre que existem, há indicação dos dispositivos correspondentes do CPC/2015 nos quadros de "Atenção".
2. As provas 2006.1 até 2009.3 apresentam apenas as estruturas das peças. Da prova 2010.1 em diante existem sugestões de redação em virtude de serem mais recentes.

1. Importante: As provas 2006.1 até 2015.3 foram fundamentadas no Código de Processo Civil de 1973 (até então em vigor no momento da aplicação das provas).